Systematischer Überblick über das deutsche Fallrecht zwischen 2017 und 2019 zur FRAND Lizenzierung standardessentieller Patente und dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand

Erik Habich[1]

Das vorliegende Research Paper stellt das dem Verfasser zur Verfügung stehende deutsche Fallrecht zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand bei Streitigkeiten zur Lizenzierung standardessenzieller Patente (SEP) zur angemessenen und nicht-diskriminierenden (fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND) Bedingungen zwischen November 2016 und Oktober 2019 systematisiert, teils zusammenfassend und kommentierend dar.

Die dargestellte Rechtsprechung ist geprägt von der EuGH-Leitentscheidung *Huawei/ZTE* zum kartellrechtlichen Missbrauchsverbot bei der klageweisen Geltendmachung eines SEP unter einer FRAND-Erklärung des marktbeherrschenden Patentinhabers und der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand.[2] Das dargestellte Fallrecht ist insbesondere vor den durchaus revolutionären Leitentscheiden des BGH *FRAND-Einwand I* und *FRAND-Einwand II* ergangen, mit der sich wichtige Grundsätze gegenüber der dargestellten Rechtslage geändert haben.[3] Zu den in der BGH-Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen vgl. bspw. *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>. Dennoch behält die in diesem Research Paper behandelte Rechtslage zum großen Teil ihre Relevanz, da nebst der historischen Darstellung der Rechtsentwicklung einerseits alternative Argumentationsstränge zur kritischen Hinterfragung des Status Quo aufgezeigt werden, sowie andere Grundsätze und Detailfragen in FRAND-Einwand nicht behandelt oder bestätigt wurden.

Der von diesem Research Paper gewählte Darstellungszeitraum erklärt sich aus dem publikatorischen Kontext: Es schliesst zeitlich einerseits die Untersuchung von *Peter Georg Picht* an, die das deutsche FRAND-Fallrecht bis 2016 darstellt und eingehend analysiert.[4] Zum anderen erscheint demnächst das Case Law Book *FRAND: German Case Law and Global Perspectives* herausgegeben von *Peter Georg Picht*, *Thomas Cotter* und *Erik Habich*,[5] das schwerpunktmässig das seit Oktober 2019 ergangene deutsche FRAND-Fallrecht, inklusive der *FRAND-Einwand*-Rechtsprechung des BGH, systematisierend und auf Englisch darstellt und in diesem Sinne das Anschlusswerk an dieses Research Paper ist.

---

[1] MLaw, Doktorand im Wettbewerbsrecht Universität Zürich, Doc.CH Stipendiat Schweizerischer Nationalfonds, Research Fellow Stanford-Vienna Transatlantic Technology Law Forum, für Anregungen und Anmerkungen erik.habich@uzh.ch.

[2] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE*; BGH, 6.5.2009 – KZR 30/06 – *Orange-Book-Standard*; zum Kontext und den Entscheidungen vgl. *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>.

[3] BGH, 5.5.2020 – KZR 36/17 – FRAND-Einwand I; 24.11.2020 – KZR 35/17 – FRAND-Einwand II, dazu *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>.

[4] *Peter Georg Picht*, „FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 7 <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916544>.

[5] *Peter Georg Picht, Thomas Cotter, Erik Habich* (Hrsg.), FRAND: German Case Law and Global Perspectives, Edward Elgar, *forthcoming* 2023.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Systematic Overview over the German Case Law on the FRAND Licensing of Standard-Essential Patents between 2017 and 2019

This research paper presents in a systematized, partly summary and commentary manner the German case law between November 2016 and October 2019 available to the author on the antitrust compulsory licensing defense for infringement suits of standard essential patents (SEP) for which there is a commitment to license on fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) terms.

The case law presented sits in the aftermath of the ECJ's decision *Huawei/ZTE* on the criteria for a non-abusive refusal to license an SEP for which FRAND declaration was submitted as well as the *Orange Book Standard* decision of the German Federal Court of Justice (BGH) on the antitrust compulsory licensing defense. However, the case law presented in this Paper was issued before the BGH's seminal decisions *FRAND-Einwand I* and *FRAND-Einwand II*, which changed important principles compared to the legal situation presented. On the principles developed in the subsequent BGH case law, cf. Erik Habich, *Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen*, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>. Nevertheless, the legal situation discussed in this Research Paper retains its relevance because, in addition to the historical presentation of the development of the case law, alternative strands of argumentation for critically questioning the status quo are presented while other principles and issues regarding FRAND remain unaffected in the subsequent case law.

The time frame chosen by this Research Paper is explained by the publishing context: On the one hand, it follows the study by Peter Georg Picht which presents and analyzes in detail the German FRAND case law until 2016. On the other hand, the case law book *FRAND: German Case Law and Global Perspectives*, edited by Peter Georg Picht, Thomas Cotter and Erik Habich, will be published in early 2023, focusing on and systemically presenting in English the German FRAND case law since October 2019, including the most recent FRAND jurisprudence of the Federal Court of Justice.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Inhaltsübersicht

I. Internationale Zuständigkeit ... 1
A. Rechtshängigkeit ... 1
B. Vorsorgliche Maßnahme gegen eine Anti-Suit Injunction ... 2
II. Erfüllung der Huawei-Obliegenheiten vor, bei oder nach Verfahrensbeginn ... 10
III. FRAND-Verhalten trotzt non-FRAND Reaktion? ... 20
IV. Patentverletzung und Standardessenzialität ... 22
V. Marktmacht des Patentinhabers ... 26
VI. Poollizenzen ... 29
A. Verhaltensanforderungen ... 29
B. Inhaltserfordernis ... 30
1. Angemessenheit ... 30
2. Diskriminierungsfreiheit ... 38
3. Darlegungs- und Beweislast bei Poollizenzen ... 39
VII. Übertragung des SEP ... 41
A. Übergang der FRAND-Obliegenheiten auf den Erwerber ... 41
B. Informationspflicht des Veräußerers und Geheimnisschutz ... 46
C. Bestimmung des Diskriminierungsmaßstabs: Bewertung eines Teilportfolios ... 49
D. SEP-Übertragung als wettbewerbsbeschränkende Abrede (Art. 101 AEUV) ... 51
VIII. Verletzungsanzeige des Patentinhabers ... 55
A. Zweck ... 55
B. Inhalt und Zeitpunkt ... 55
1. Inhalt ... 55
2. Zeitpunkt ... 58
C. Handeln durch einen Dritten ... 59
D. Adressat im Konzern ... 63
IX. Lizenzbereitschaftserklärung des Standard-Implementierers ... 65
A. Inhalt und Zeitpunkt ... 65
1. Lizenzbereitschaft ... 65
2. Grenze zur Lizenzverweigerung ... 69
B. Lizenzbereitschaftserklärung im Konzern ... 72
C. Weitere Mitwirkungsobliegenheiten des Patentbenutzers? ... 72
X. Vorbemerkungen zu den FRAND-Angeboten von Patentinhaber und -benutzer ... 74
XI. Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers ... 76
A. Verhaltensanforderungen („conduct requirement“) ... 76
1. Angebotshandlung ... 76
2. Adressat der Lizenzvertragsangebots ... 76
3. Angebotsobliegenheit auch ohne Informationsgefälle ... 78
4. Zeitpunkt der Unterbreitung ... 79
5. Form des Angebots ... 82
6. Zulässigkeit einer Änderungskündigung ... 84
B. Sachlich-inhaltliche Anforderungen („content requirement“) ... 85

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

1. Konkretes Lizenzvertragsangebot mit Art und Weise der Berechnung 85
2. Fairer und angemessener Inhalt (FR) 143
3. Diskriminierungsfreier Inhalt (ND) 167

C. Rechtsfolgen des Lizenzvertragsangebots 191

1. Rechtsfolge bei FRAND-gemäßem Angebot 191
2. Keine Pflicht zum Gegenangebot und Ablehnung der Verletzungsklage als „derzeit unbegründet“ 192
3. Rechtfolgen bei abgelaufenem Klagepatent 194
4. Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch bei nur mittelbarer Patentverletzung 195

XII. Gegenangebot des Standard-Implementierers 199

A. Verhaltensanforderungen („conduct requirement“) 199

1. Verhandlungen nach Treu und Glauben und Lizenzwilligkeit 199
2. Angebotshandlung und Qualifikation als Gegenangebot 200
3. Rechtzeitigkeit des Gegenangebots 201

B. Sachlich-inhaltliche Anforderungen („content requirement“) 201

1. Allgemeine Bemerkungen zu den sachlich-inhaltlichen Anforderungen 201
2. Gegenangebot zur Lizenzierung nur der Tochtergesellschaft 201
3. Einräumung einer Portfoliolizenz statt einer Poollizenz 203
4. Differenzierung der Lizenzhöhe nach unterschiedlichen Regionen 206
5. Rückwirkung des Lizenzvertrags 207

XIII. Schadenersatzansprüche, Anspruch auf Auskunft- und Rechnungslegung 208

A. Bestand 208

1. Generell 208
2. Stufenklage und Rechtsschutzinteresse 212

B. Höhe 215

C. Auskunft- und Rechnungslegung 216

XIV. Patent Ambush 225

XV. Rolle des Art. 101 AEUV 228

XVI. Weitere prozessuale Themen 233

A. Trennungsprinzip und Aussetzung 233

B. FRAND-Einwand und Grenzbeschlagnahmeverfahren 233

C. Rolle des Gerichts im FRAND-Prozedere 235

D. Einstweiliger Rechtsschutz und SEP 236

1. Einstweiliger Rechtsschutz des Patentinhabers 236
2. Einstweiliger Rechtsschutz des Lizenzsuchers 252

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Inhaltsverzeichnis

I. Internationale Zuständigkeit ... 1
A. Rechtshängigkeit ... 1
B. Vorsorgliche Maßnahme gegen eine Anti-Suit Injunction ... 2
II. Erfüllung der Huawei-Obliegenheiten vor, bei oder nach Verfahrensbeginn ... 10
III. FRAND-Verhalten trotzt non-FRAND Reaktion? ... 20
IV. Patentverletzung und Standardessenzialität ... 22
V. Marktmacht des Patentinhabers ... 26
VI. Poollizenzen ... 29
A. Verhaltensanforderungen ... 29
B. Inhaltserfordernis ... 30
1. Angemessenheit ... 30
a) Angemessenheit von Pool-Lizenzverträgen im Allgemeinen ... 30
b) Begründung der Indizwirkung ... 31
c) Widerlegung der indizierten Angemessenheit durch Unangemessenheit ... 33
1) Unangemessenheit durch unterschiedliche Anzahl der in Kraft stehenden Poolpatente in einzelnen Ländern ... 33
2) Unangemessenheit durch kartellrechtswidrige Zusammensetzung des Pools ... 34
i) Unangemessenheit durch zwingende Kombination von verschiedenen Profilen und technische Bandbreite ... 34
ii) Unangemessenheit durch zwingende Kombination von standardessenziellen und nicht-standardessenzielle Patenten ... 36
iii) Gesamtbelastung: Unangemessenheit durch die Erforderlichkeit zusätzlicher Lizenzen von weiteren Patentinhabern neben den streitgegenständlichen Schutzrechten ... 38
2. Diskriminierungsfreiheit ... 38
3. Darlegungs- und Beweislast bei Poollizenzen ... 39
VII. Übertragung des SEP ... 41
A. Übergang der FRAND-Obliegenheiten auf den Erwerber ... 41
B. Informationspflicht des Veräußerers und Geheimnisschutz ... 46
C. Bestimmung des Diskriminierungsmaßstabs: Bewertung eines Teilportfolios ... 49
D. SEP-Übertragung als wettbewerbsbeschränkende Abrede (Art. 101 AEUV) ... 51
VIII. Verletzungsanzeige des Patentinhabers ... 55
A. Zweck ... 55
B. Inhalt und Zeitpunkt ... 55
1. Inhalt ... 55
2. Zeitpunkt ... 58
C. Handeln durch einen Dritten ... 59
D. Adressat im Konzern ... 63
IX. Lizenzbereitschaftserklärung des Standard-Implementierers ... 65
A. Inhalt und Zeitpunkt ... 65
1. Lizenzbereitschaft ... 65
a) Inhalt ... 65
b) Zeitpunkt ... 67

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

2. Grenze zur Lizenzverweigerung ... 69

B. Lizenzbereitschaftserklärung im Konzern ... 72

C. Weitere Mitwirkungsobliegenheiten des Patentbenutzers? ... 72

X. Vorbemerkungen zu den FRAND-Angeboten von Patentinhaber und -benutzer ... 74

XI. Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers ... 76

A. Verhaltensanforderungen („conduct requirement“) ... 76

1. Angebotshandlung ... 76
2. Adressat der Lizenzvertragsangebots ... 76
3. Angebotsobliegenheit auch ohne Informationsgefälle ... 78
4. Zeitpunkt der Unterbreitung ... 79
5. Form des Angebots ... 82
6. Zulässigkeit einer Änderungskündigung ... 84

B. Sachlich-inhaltliche Anforderungen („content requirement“) ... 85

1. Konkretes Lizenzvertragsangebot mit Art und Weise der Berechnung ... 85

a) Art und Weise der Berechnung allgemein ... 85

b) Begründung der angebotenen Bedingungen als FRAND-gemäß ... 88

c) Substantiierung der Art und Weise der Berechnung und der FRAND-Gemäßheit ... 89

1) Verteilung der Darlegungs- und Substantiierungslast ... 89

2) Darlegungs- und Beweislast des Patentinhabers ... 91

i) Rolle der Substantiierung im Rahmen der beiden Prongs ... 91

ii) Substantiierung der Patentverletzung ... 92

iii) Substantiierung der FRAND-Gemäßheit des Angebotsinhalts ... 93

iv) Vortrag zu bestehenden Vereinbarungen ... 96

(a) Konkreter Sachvortrag zu bestehenden Vereinbarungen ... 96

(b) Sukzessionsschutz ... 100

v) Vortrag zu Gerichtsentscheiden ... 101

vi) Vortrag zu anderen Berechnungen und Multiplikatoren und weitere Angaben ... 103

3) Confidentiality: Geheimhaltung und Akteneinsichtsrecht ... 104

i) Ausgangspunkt: Vortrag zu bestehenden Vereinbarungen ... 104

ii) Grundsatz: Akteneinsichtsrecht und rechtliches Gehör ... 107

(a) Akteneinsichtsrecht und „Vorsorgeobliegenheit“ zu Geheimhaltung ... 107

(b) Akteneinsichtsrecht des Streithelfers ... 109

iii) Geheimnisschutz durch Schutzanordnungen und andere prozessrechtliche Mechanismen ... 112

(a) Schutzanordnung nach GVG ... 112

(b) Anonymisierter oder teilweise geschwärzter Vortrag ... 112

(c) Andere verfahrensrechtliche Möglichkeiten? ... 115

iv) Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens und Konsequenzen bei Weigerung ... 118

(a) Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens allgemein ... 118

(b) Inhalt des Geheimhaltungsabkommens ... 120

(c) Zeitpunkt des Abschlusses ... 122

(d) Weigerung, Verzögerung des Abschlusses oder Lossagung vom Geheimhaltungsabkommen ... 122

(e) Rechtsfolge bei Weigerung, Verzögerung oder vorwerfbarem Verstoß gegen das Geheimhaltungsabkommen: Reduzierung der Darlegungslast ... 127

v) Geheimnisschutz bei SEP-(Portfolio-)Übertragung ... 134

4) Darlegungs- und Beweislast des Lizenzsuchers ... 137

i) Allgemein ... 137

ii) Vortrag zur Angemessenheit ... 137

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

iii) Vortrag zum Diskriminierungsverbot ... *138*
d) Diverses ... *139*
1) Standardlizenzvertrag als hinreichende Darlegung der Art und Weise der Berechnung? 139
2) Tatrichterliche Feststellung oder negative Evidenzkontrolle? ... 141
3) Doppelte Prüfung und Spannungsfeld ... 142
2. Fairer und angemessener Inhalt (FR) ... 143
a) Generelles zum FR-Prong ... *143*
b) Angemessene Höhe ... *147*
c) Weitere Angebotsmodalitäten ... *154*
1) Bestehen auf konzern- oder weltweite Lizenz ... 154
2) Erschöpfung und Beschränkungen in der Vertriebskette ... 157
i) Doppellizenzierung und Erschöpfung ... *157*
ii) Beschränkung auf bestimmte Geschäftsfelder und Teile der Vertriebskette ... *160*
3) Anpassungsklausel und nachträgliche Veränderung des Portfolios durch Ungültigkeit, Erschöpfung und Ablauf ... 163
i) Anpassungsklausel generell ... *163*
ii) Anpassungsklausel bei Ablauf der Schutzdauer ... *164*
iii) Einer Anpassungsklausel gleichwertige, andere Mechanismen ... *164*
iv) Veränderung des Schutzrechtsbestands und Diskriminierungsverbot ... *166*
v) Weitere Bemerkungen ... *166*
4) Diverse weitere Bestimmungen ... 167
3. Diskriminierungsfreier Inhalt (ND) ... 167
a) Rahmen ... *167*
b) Gleichbehandlung betreffend Lizenzbedingungen ... *169*
1) Gesamtbetrachtung von Vergleichbarkeit, Ungleichbehandlung und sachlicher Rechtfertigung ... 170
2) Insbesondere Vergleichbarkeit und Ungleichbehandlung ... 173
3) Insbesondere sachliche Rechtfertigung ... 176
i) Branchenübliche Rabatte ... *177*
ii) Sonderstellung als Referenzkunde ... *179*
iii) Spezifische Risikoverteilung des Lizenzvertrages ... *182*
iv) Fehlendes Interesse des Lizenzsuchers an den nicht-diskriminierenden Lizenzbedingungen ... *183*
v) Unterschiedliche prozessuale Situation ... *184*
vi) Behördliche Einflussnahme auf Lizenzkonditionen als besondere Begleitumstände ... *185*
vii) Aussparung der Lizenzvergabe an die Muttergesellschaften ... *186*
viii) Diskriminierungskonstellationen bei Patentpools ... *186*
c) Gleichbehandlung betreffend Rechtsdurchsetzung ... *186*
C. Rechtsfolgen des Lizenzvertragsangebots ... 191
1. Rechtsfolge bei FRAND-gemäßem Angebot ... 191
2. Keine Pflicht zum Gegenangebot und Ablehnung der Verletzungsklage als „derzeit unbegründet“ ... 192
3. Rechtfolgen bei abgelaufenem Klagepatent ... 194
4. Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch bei nur mittelbarer Patentverletzung ... 195
XII. Gegenangebot des Standard-Implementierers ... 199
A. Verhaltensanforderungen („conduct requirement“) ... 199
1. Verhandlungen nach Treu und Glauben und Lizenzwilligkeit ... 199

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

2. Angebotshandlung und Qualifikation als Gegenangebot 200
3. Rechtzeitigkeit des Gegenangebots 201
B. Sachlich-inhaltliche Anforderungen („content requirement“) 201
1. Allgemeine Bemerkungen zu den sachlich-inhaltlichen Anforderungen 201
2. Gegenangebot zur Lizenzierung nur der Tochtergesellschaft 201
3. Einräumung einer Portfoliolizenz statt einer Poollizenz 203
4. Differenzierung der Lizenzhöhe nach unterschiedlichen Regionen 206
5. Rückwirkung des Lizenzvertrags 207
XIII. Schadenersatzansprüche, Anspruch auf Auskunft- und Rechnungslegung 208
A. Bestand 208
1. Generell 208
2. Stufenklage und Rechtsschutzinteresse 212
B. Höhe 215
C. Auskunft- und Rechnungslegung 216
XIV. Patent Ambush 225
XV. Rolle des Art. 101 AEUV 228
XVI. Weitere prozessuale Themen 233
A. Trennungsprinzip und Aussetzung 233
B. FRAND-Einwand und Grenzbeschlagnahmeverfahren 233
C. Rolle des Gerichts im FRAND-Prozedere 235
D. Einstweiliger Rechtsschutz und SEP 236
1. Einstweiliger Rechtsschutz des Patentinhabers 236
2. Einstweiliger Rechtsschutz des Lizenzsuchers 252

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

I. Internationale Zuständigkeit

A. Rechtshängigkeit

Betreffend die Zuständigkeit der jeweiligen Gerichte wurden vor deutschen Gerichten gelegentlich Argumente, die in der oftmals globalen Dimension der FRAND-Streitigkeit fußen, geltend gemacht. Betraf das Argument der Rechtshängigkeit einen Mitgliedstaat, wendete das Landgericht Düsseldorf gemäß Art. 1 Abs. 1 S. 1 EuGVVO die Regelung des Art. 29 EuGVVO an. Danach habe, wenn bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht würden, das später angerufene Gericht unbeschadet des Art. 31 Abs. 2 EuGVVO das Verfahren von Amtes wegen auszusetzen bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststehe (Art. 29 Abs. 1 EuGVVO), wonach sich das später angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig erkläre.[6] Im konkreten Fall war jedoch keine Anspruchsidentität gegeben, da im Verfahren vor dem LG Düsseldorf ein Unterlassungsanspruch verfolgt wurde, während zwei Jahre zuvor der High Court Dublin sich für eine Feststellungsklage derselben Beklagten zuständig erklärt hatte.[7] Nach der vom EuGH angewendeten Kernpunkttheorie sei „derselbe Anspruch" gegeben, wenn es in den Prozessen im Kern um denselben Streit, mithin die Rechtsfolgen aus ein und demselben Sachverhalt gehe.[8] Für die Frage, ob zwei Klagen, die zwischen denselben Parteien bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhängig gemacht würden, denselben Gegenstand hätten, seien jedoch nur die Klageansprüche des jeweiligen Klägers und nicht auch die vom Beklagten erhobenen materiellen Einwendungen zu berücksichtigen.[9] Unter Berücksichtigung dieser Umstände handle es sich beim Streitgegenstand des irischen Verfahrens um einen anderen Streitgegenstand als in der hiesigen Klage.[10] Unabhängig davon, dass es sich bei der Unterlassung wegen einer Patentverletzung und der (Nicht-)Feststellung bestimmter Eigenschaften der Lizenzangebote (FRAND) bereits um gänzlich verschiedene (Klage-)Ansprüche handle, die nicht identisch seien, scheitere eine Anspruchsidentität im Sinne des Art. 29 EuGVVO jedenfalls bereits daran, dass es sich bei der dem LG Düsseldorf vorliegenden Frage, ob die Angebote der Klägerin bzw. der Beklagten FRAND seien, dogmatisch um einen Einwand der Beklagten handle (sog. Kartellrechtseinwand), der nach der Rechtsprechung des EuGH eine Anspruchsidentität nicht begründen könne.[11]

Weiter lehnte das Landgericht Düsseldorf auch eine Aussetzung nach Art. 30 Abs. 1 EuGVVO ab. So sei eine Aussetzung des Verfahrens unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht geboten, denn bereits auf Grund des Umstandes, dass ein im dem LG Düsseldorf vorliegenden Verfahren drittes Lizenzangebot nicht Gegenstand des irischen Verfahrens sei, bestehe keine Gefahr, dass widersprechende Entscheidungen ergehen könnten.[12] Zudem habe die Beklagte weder vorgebracht, noch sei ersichtlich, dass eine Entscheidung des irischen High Courts über die dort aufgeworfenen FRAND-Fragen überhaupt eine Bindungswirkung für das dem LG Düsseldorf vorliegende Verletzungsverfahren begründen, mithin in irgendeiner Art und Weise vorgreiflich sein könnte.[13] Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Beklagte im irischen Verfahren erklärt habe, die dort

[6] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 59.

[7] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 60.

[8] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 61, mit Verweis auf EuGH, 8.12.1987, C-144/86 (Slg. 1987, 04861), Rn. 13–18 – *Gubisch/Palumbo*.

[9] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 61, mit Verweis auf EuGH, 8.5.2003, C-111/01 (Slg. 2003 I-04207), Rn. 26 – *Ganter/Basch*.

[10] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 62.

[11] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 62.

[12] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 64–65.

[13] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 66.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gegebenenfalls festzulegenden FRAND-Konditionen als verbindlich anzuerkennen, da nicht ersichtlich sei, dass eine solche Erklärung auch Bindungswirkung im dem LG Düsseldorf vorliegenden Prozess entfalten könne.[14]

Auch das OLG Düsseldorf sah sich an einem Urteil nicht deshalb gehindert, weil eine im Vereinigten Königreich anhängige Klage nach dem Vorbringen der Beklagten auf eine weltweite Auskunft und eine weltweite Lizenzgebühr für alle SEPs der Klägerin gerichtet sei.[15] Dass die Voraussetzungen der EuGVVO für eine Aussetzung vorlägen, vermochte der Senat nicht festzustellen.[16] Es sei weder hinreichend vorgetragen noch ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt die im vorliegenden Rechtsstreit streitgegenständlichen Ansprüche, zu Auskunftserteilung und Schadenersatz bezogen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in dem im Vereinigten Königreich geführten Verfahren anhängig gemacht worden seien.[17]

B. Vorsorgliche Maßnahme gegen eine Anti-Suit Injunction

Mit einem Jurisdiktionskonflikt beziehungsweise Kompetenzkonflikt setzten sich auch die Verfahren über die Zulässigkeit von Anti-Suit, Anti-Anti-Suit Injunctions vor dem LG München I und anschließend dem OLG München auseinander.[18] Gegenstand der Verfahren war der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen einen Antrag für eine US-Anti-Suit Injunction. Nachdem der SEP-Inhaber einen Fahrzeughersteller in insgesamt zehn Patentverletzungsverfahren vor verschiedenen deutschen Gerichten verklagt und der Fahrzeughersteller den Konzerngesellschaften seiner Zulieferin als Nebenintervenienten den Streit verkündet hatte,[19] machte die Zulieferin in Kalifornien eine „Complaint for breach of FRAND commitments and violation of antitrust“ gegen einen den SEP-Inhaber beinhaltenden Patentpool anhängig.[20] Im Rahmen dieses FRAND-Verfahrens beantragte die Zulieferin zudem eine Anti-Suit Injunction gegen den Patentinhaber, mit dem Ziel diesem verbieten zu lassen die deutschen Patentverletzungsverfahren gegen ihren Kunden weiterzuführen bis eine Entscheidung im US-amerikanischen Verfahren ergangen ist.[21] Daraufhin beantragte der SEP-Inhaber den Erlass einer einstweiligen Verfügung *ex parte* vor dem LG München I, wonach der Zulieferin als Antragsgegnerin aufgegeben werden solle, die Beantragung und Weiterverfolgung der Anti-Suit Injunction zu unterlassen und den darauf gerichteten Antrag zurückzunehmen.[22]

Das Gericht erteile die einstweilige Verfügung *ex parte*,[23] und setzte sich anschließend im Widerspruchsverfahren auch mit den Argumenten der Antragsgegnerin auseinander,[24] die in der Zwischenzeit ihren Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction im US-amerikanischen Verfahren unter Vorbehalt der Neustellung zurückgenommen hatte.[25] Im Widerspruchsverfahren stützte das LG München I seine ursprünglich erlassene einstweilige Verfügung *ex parte*.

---

[14] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 66.

[15] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 128 – *Improving Handovers*.

[16] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 128 – *Improving Handovers*.

[17] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 128 – *Improving Handovers*.

[18] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19 – *Anti-Suit-Injunction*; LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19 – *Anti-Suit-Injunction*; 30.8.2019 – 21 O 9512/19; 11.7.2019 – 21 O 9333/19; 11.7.2019 – 21 O 9512/19.

[19] Cf. LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 20–21 – *Anti-Suit-Injunction*.

[20] United States District Court, Case No. 5:2019-cv-02520-LHK (N.D. Cal.).

[21] Motion for anti-suit injunction before the United States District Court, Case No. 5:2019-cv-02520-LHK (N.D. Cal.), Incoming File No. 32, 12 June 2019.

[22] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 38 – *Anti-Suit-Injunction*.

[23] LG München I, 11.7.2019 – 21 O 9333/19; 11.7.2019 – 21 O 9512/19.

[24] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19 – *Anti-Suit-Injunction*.

[25] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 62 – *Anti-Suit-Injunction*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Zunächst sah sich das Landgericht München in örtlicher Hinsicht gemäß §§ 937 und 32 ZPO zuständig, da der Erfolgsort der Anti-Suit Injunction auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Sinne eines sogenannten fliegenden Gerichtsstands vorliege.[26] Dies aus dem Grund, da die aus einer etwaigen Patentverletzung resultierenden Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG aufgrund der Anti-Suit Injunction deutschlandweit nicht durchgesetzt werden könnten, weil eine Rücknahme der Klagen in Düsseldorf und Mannheim und anschließende Klageerhebung am LG München I ebenfalls unterbunden würde.[27]

Weiter bestehe auch ein Unterlassungsanspruch aus § 1004 (analog) in Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB gegen die Antragsgegnerin.[28] Der Erlass der von der Antragsgegnerin begehrten Anti-Suit Injunction würde in geschützte Rechtsgüter des Antragstellers eingreifen, da Patente als sonstige Rechte im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB geschützt seien.[29] Zwar würde der Erlass einer Anti-Suit Injunction den Antragssteller nicht unmittelbar daran hindern, die vorbezeichneten Patentverletzungsverfahren in Deutschland weiter zu betreiben, da diese in Deutschland keine Wirkung entfalten würde mangels in Deutschland vollstreckbaren Inhalts.[30] Jedoch würde ein Fortführen der anhängigen Patentverletzungsverfahren nach Erlass einer Anti-Suit Injunction für den Patentinhaber in den USA weitreichende Folgen haben, da er insbesondere erhebliche wirtschaftliche Nachteile zu befürchten hätte aufgrund der drohenden Strafen bei Nichtbefolgung.[31] Darin liege ein Eingriff in ein absolutes Recht im Sinne einer Beeinträchtigung des Eigentums nach § 1004 BGB, indem der Eigentümer an irgendeiner zulässigen Benutzung der Sache oder einer sonstigen rechtmäßigen Einwirkung auf diese gehindert werde.[32] So sei sogar zu konstatieren, dass das Patentrecht als Ausschließlichkeitsrecht im Sinne von § 9 PatG faktisch wertlos sei, wenn dem Patentinhaber die Möglichkeit genommen werde, sein Ausschließlichkeitsrecht über das allein zur Verfügung stehende staatliche Gewaltmonopol in Form des ordentlichen Gerichtsverfahrens auch durchzusetzen.[33] Daran ändere auch nichts, dass es dem Patentinhaber auch nach der Anti-Suit Injunction unbenommen bleibe, andere als die im US-Verfahren genannten zu verklagen oder Dritten Lizenzen zu erteilen, denn das Ausschließlichkeitsrecht gelte gerade gegenüber jedermann.[34] Das Ausschließlichkeitsrecht beinhalte auch die Befugnis des Patentinhabers zu entscheiden, ob und gegebenenfalls gegen wen er sein Recht durchsetze und gegen wen nicht, worein eine Anti-Suit Injunction in erheblichem Maße eingreife.[35] Das gelte auch und gerade für den vorliegenden Fall, da die Patentverletzungsklagen gerade nicht gegen einen vermeintlich unbedeutende Patentbenutzer gerichtet seien, sondern gegen einen weltweit führenden Fahrzeughersteller.[36] Die vom Gericht unterstellte erhebliche wirtschaftliche Dimension von dessen gerichtlicher Inanspruchnahme zeige, dass es sich – anders als von der Antragsgegnerin behauptet – gerade nicht um eine bloß unbedeutende Beeinträchtigung des jeweiligen Patentrechte handle.[37]

[26] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 92, 99 – *Anti-Suit-Injunction*.

[27] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 97, 99 – *Anti-Suit-Injunction*.

[28] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 102 – *Anti-Suit-Injunction*.

[29] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 103 – *Anti-Suit-Injunction*.

[30] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 104 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 10.1.1996 – 3 VA 11/95.

[31] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 105 – *Anti-Suit-Injunction*.

[32] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 106–08 – *Anti-Suit-Injunction*.

[33] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 109 – *Anti-Suit-Injunction*.

[34] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 110 – *Anti-Suit-Injunction*.

[35] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 110 – *Anti-Suit-Injunction*.

[36] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 110 – *Anti-Suit-Injunction*.

[37] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 110 – *Anti-Suit-Injunction*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Darüber hinaus sei der Eingriff nach dem allein maßgeblichen deutschen Recht auch rechtswidrig, denn grundsätzlich indiziere der Eingriff die Rechtswidrigkeit.[38] Auch folge die Rechtswidrigkeit daraus, dass die Anti-Suit Injunction darauf abziele, den dem Patentinhaber seine Klagebefugnisse im Inland zu nehmen.[39] Dadurch sei ein rechtsstaatlich ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren gefährdet, da dieses nur gewährleistet sei, wenn die Beteiligten ohne jede Beschränkung die nach der Prozesslage notwendigen Anträge stellen könnten, und widerspreche dem eigentumsrechtlichen Zuweisungsgehalt des Patents nach §§ 9 f., 139 ff. PatG.[40]

Die Rechtswidrigkeit werde auch nicht dadurch beseitigt, dass der Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction in den USA ein zulässiger Rechtsbehelf sei.[41] Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit einer Handlung sei allein die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, die ein derartiges Rechtskonstrukt aber nicht kenne bzw. sogar ablehne.[42] In den vom er Antragsteller zitierten Präzedenzfällen waren jeweils nach deutschen Verständnis rechtmäßige Verfahren maßgeblich für den Ausschluss der Rechtswidrigkeit durch die Zulässigkeit eines staatlichen Verfahrens.[43] Aus diesem Grund könnte aus den zitierten Entscheidungen nicht hergeleitet werden, dass jedes nach dem Recht eines Drittstaates zulässige Verhalten/Verfahren automatisch das Placet der deutschen Rechtsordnung erhalte.[44]

Auch habe die Antragsgegnerin die konkrete Gefahr eines rechtswidrigen Eingriffs in die nach § 823 Abs. 1 BGB geschützten Patentrechte des Antragsstellers geschaffen, in dem sie den Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction stellte.[45] Es bestehe eine hinreichend nahe Erstbegehungsgefahr, sodass der Antragssteller nicht die erste rechtswidrige Beeinträchtigung durch den Erlass der Anti-Suit Injunction abwarten brauche.[46] Die Entscheidung darüber sei in das Ermessen des US-amerikanischen Gerichts gestellt, da mit der Stellung des Antrags im US-Verfahren das dortige in Lauf gesetzt worden sei.[47] Weiter entfalle die Erstbegehungsgefahr in diesem Widerspruchverfahren auch nicht dadurch, dass die Antragsgegnerin ihren Antrag nunmehr auf Druck der einstweiligen Verfügung *ex parte* zurückgenommen habe, da sie sich ausdrücklich die erneute Stellung des Antrags vorbehalten habe, sollte die einstweilige Verfügung aufgehoben werden.[48]

Schließlich prüfte das LG München I noch den Einwand der Antragsgegnerin, das Gericht sanktioniere eine von ihm als rechtswidrig betrachtete Anti-Suit Injunction seinerseits mit einem Prozessführungsverbot, was widerrechtlich sei und gegen Völkerrecht, Europarecht und deutsches Verfassungs- und einfaches Bundesrecht verstoße.[49] Dem entgegnete das Gericht, es habe entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin kein Prozessführungsverbot ausgesprochen.[50] Die Anti-Suit Injunction diene der von deutschen Gerichtsentscheidungen ungestörten Prozessführung in den USA, damit sich der Fahrzeughersteller als Kunde der Zulieferin nicht aufgrund der in Deutschland anhängigen Klagen gegen die Antragsgegnerin mit dem Antragssteller zur behaupteterweise non-FRAND Bedingungen

[38] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 111 – *Anti-Suit-Injunction*.

[39] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 112 – *Anti-Suit-Injunction*.

[40] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 112 – *Anti-Suit-Injunction*.

[41] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 113 – *Anti-Suit-Injunction*.

[42] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 113 – *Anti-Suit-Injunction*.

[43] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 117 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf BGH, 13.3.1979 – VI ZR 117/77, BVerfG, 25.2.1987 – 1 BvR 1086/85.

[44] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 117 – *Anti-Suit-Injunction*.

[45] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 119 – *Anti-Suit-Injunction*.

[46] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 119 – *Anti-Suit-Injunction*.

[47] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 119 – *Anti-Suit-Injunction*.

[48] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 112 – *Anti-Suit-Injunction*.

[49] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 122 – *Anti-Suit-Injunction*.

[50] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 123 – *Anti-Suit-Injunction*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

vergleiche.[51] Die durch das LG München I erlassene einstweilige Verfügung gebe jedoch der Antragsgegnerin gerade nicht auf, das US-amerikanische Verfahren zurückzunehmen oder nicht weiter zu betreiben, sondern lediglich alles zu unterlassen, was den Patentinhaber an einer Ausübung seiner patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte in Deutschland hindere.[52] Das Recht der Antragsgegnerin, ihre Klage in den USA weiterzuverfolgen bleibe dadurch unberührt.[53] Anders als bei der Anti-Suit Injunction handle es sich bei der einstweiligen Verfügung nicht um ein gerichtliches Verbot, Prozesse zu führen, sondern es werde der Antragsgegnerin nur untersagt, in einem gerichtlichen Verfahren eine gerichtliche Maßnahme zu erwirken, die dem Antragssteller ein Prozessführungsverbot auferlegt.[54] Im Gegenteil, es bleibe der Antragsgegnerin unbenommen, den Antragsteller mit weiteren Klagen weltweit zu beanspruchen, wobei allein die Beeinträchtigung der Patentrechte durch ein faktisches Verbot der Weiterführung der Verletzungsklagen – innerhalb des weiterhin unangetasteten US-Verfahrens – untersagt werde, womit gerade kein Prozessführungsverbot vorliege.[55]

Ferner verstoße die einstweilige Verfügung auch nicht gegen den völkerrechtlichen Grundsatz *„par in parem non habet imperium“* oder Europarecht.[56] Es liege keine völkerrechtswidrige Einmischung in die Hoheitsrechte eines anderen Staates vor, wenn für die durch das Gericht eines anderen Staates erlassene Maßnahme ein ausreichender Inlandsbezug gemäß dem Territorialitätsprinzip bestehe, wie etwa bei wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen auf inländische Märkte.[57] Gleichfalls sei es zulässig, demjenigen, der im Ausland die Beeinträchtigung/Störung von Eigentumsrechten in Deutschland betreibe, von Gerichts wegen die Unterlassung aufzugeben.[58] Zudem übe das deutsche Gericht auch keine faktische Hoheitsgewalt über das US-amerikanische Gerichtsverfahren aus, da die einstweilige Verfügung nicht die Anti-Suit Injunction selbst verbiete, sondern der Antragsgegnerin aufgebe, keine solche zu erwirken bzw. weiter zu betreiben.[59] Erließen die US-Gerichte eine Anti-Suit Injunction nur auf Betreiben eines Prozessbeteiligten, sei ihre Hoheitsgewalt nicht betroffen, da der Erlass vom Handeln eines Prozessbeteiligten abhängig sei und somit keine umfassende, vom Verhalten Dritter unabhängige Hoheitsgewalt vorliege.[60] Es könne auch kein Verstoß gegen Europarecht konstatiert werden, da einerseits die europarechtlichen Vorschriften mangels eines grenzüberschreitenden, innereuropäischen Sachverhalts bereits nicht einschlägig seien,[61] andererseits der einschlägige Rechtsprechung des EuGH Sachverhalte zugrunde lägen, bei denen die Weiterführung bzw. Erhebung eines eigenständigen Gerichtsverfahrens mittels Anti-Suit Injunction untersagt würden, was in diesem Verfahren genau nicht der Fall sei.[62]

Die einstweilige Verfügung verstoße auch nicht gegen deutsches Verfassungs- oder einfaches Bundesrecht.[63] Selbst wenn man dazu käme, einen Eingriff in die Grundrechte der Antragsgegnerin anzunehmen, etwa in Gestalt von Art. 2 Abs. 1 GG, gegebenenfalls in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 GG, wäre dieser jedenfalls gerechtfertigt und verhältnismäßig. So wären auf der anderen Seite die ebenfalls schützenswerten Interessen des Patentinhabers, namentlich das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG und

[51] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 124–25 – *Anti-Suit-Injunction*.

[52] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 127 – *Anti-Suit-Injunction*.

[53] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 127 – *Anti-Suit-Injunction*.

[54] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 127 – *Anti-Suit-Injunction*.

[55] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 128 – *Anti-Suit-Injunction*.

[56] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 131 – *Anti-Suit-Injunction*.

[57] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 132 – *Anti-Suit-Injunction*.

[58] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 132 – *Anti-Suit-Injunction*.

[59] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 133–34 – *Anti-Suit-Injunction*.

[60] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 134 – *Anti-Suit-Injunction*.

[61] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 136 – *Anti-Suit-Injunction*.

[62] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 138 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf EuGH, 27 April 2004, C-159/02 – *Turner/Grovit*.

[63] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 139 – *Anti-Suit-Injunction*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

der Justizgewährungsanspruch aus Art. 19 Abs. 4 GG zu berücksichtigen.[64] Die Abwägung der Grundrechte gegeneinander führe zu einer Entscheidung zugunsten des Patentinhabers, da er sich nicht nur auf das Grundrecht aus Eigentum, sondern auch auf den Justizgewährungsanspruch berufen könne.[65] Demgegenüber sei fraglich, ob die Antragsgegnerin sich in Bezug auf Art. 19 Abs. 4 GG auch auf ein nach deutschem Verständnis rechtswidrigen Verfahren in einem außereuropäischen Drittstaat berufen könne.[66]

Zu guter Letzt hielt das LG München I fest, dass im vorliegenden Fall eine Entscheidung im Beschlusswege gemäß § 937 Abs. 2 ZPO ausnahmsweise ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin wegen besonderer Dringlichkeit geboten sei.[67] Zwar gebiete der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit, in einem gerichtlichen Verfahren der Gegenseite grundsätzlich vor der Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu gewähren, um auf eine bevorstehende gerichtliche Entscheidung Einfluss zu nehmen.[68] Allerdings sei in den besonderen Verfahrenslagen des einstweiligen Rechtsschutzes eine vorherige Anhörung verzichtbar, wenn sie den Zweck des Verfahren vereiteln würde.[69] Da im vorliegenden Fall der Kammer eine mündliche Verhandlung frühestens acht Tage nach dem Datum des Antrags möglich gewesen wäre, wäre eine Absetzung, Ausfertigung und Zustellung des Urteils an die Antragsgegnerin vor Ablauf der Stellungsnahmefrist der Patentinhaberin im US-Verfahren nicht gesichert gewesen.[70] Da es ab diesem Zeitpunkt dem US-amerikanischen Gericht aber möglich sei, eine Anti-Suit Injunction zu erlassen, liefe der Patentinhaber Gefahr, seiner Rechte verlustig zu werden.[71] Im Übrigen sei zu befürchten gewesen, dass die Antragsgegnerin bei Kenntnis des vorliegenden Verfügungsantrags das US-amerikanische Gericht über das hiesige Geschehen informiere, um einstweilige Maßnahmen gegen das vorliegende Verfügungsverfahren zu beantragen, womit der Patentinhaber Gefahr liefe, dass seine hiesigen Rechte vereitelt würden.[72] Nach alldem sei eine den Beispielfällen des Bundesverfassungsgerichts, wie etwa das Arrestverfahren, die Anordnung von Untersuchungshaft oder Wohnungsdurchsuchungen,[73] vergleichbare Lage gegeben, die den Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne vorherige Anhörung der Antragsgegnerin rechtfertige.[74] Deren Anspruch auf rechtliches Gehör sei in einem etwaigen Widerspruchsverfahren nachzuholen.[75] Auch falle die Interessenabwägung zugunsten des Patentinhabers aus, insbesondere da die Antragsgegnerin, die an den hiesigen Patentverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland weder als Streithelferin noch als Partei beteiligt sei, nicht über ein schützenswertes Interesse verfüge.[76] Weiter sei diesbezüglich zu berücksichtigen, dass die einstweilige Verfügung nicht darauf gerichtet sei (im Gegensatz zur beantragten Anti-Suit Injunction), der Antragsgegnerin ihre Klagerechte zu nehmen, denn die einstweilige Verfügung richte sich gerade nicht gegen die in den USA anhängige Klage.[77]

---

[64] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 142 – *Anti-Suit-Injunction*.

[65] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 142 – *Anti-Suit-Injunction*.

[66] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 142 – *Anti-Suit-Injunction*.

[67] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 145 – *Anti-Suit-Injunction*.

[68] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 146 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf BVerfG, 30.9.2018 – 1 BvR 1783/17, Rn. 15.

[69] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 146 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf BVerfG, 30.9.2018 – 1 BvR 1783/17, Rn. 15.

[70] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 146 – *Anti-Suit-Injunction*.

[71] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 146 – *Anti-Suit-Injunction*.

[72] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 148 – *Anti-Suit-Injunction*.

[73] BVerfG, 30.9.2018 – 1 BvR 1783/17, Rn. 15.

[74] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 149 – *Anti-Suit-Injunction*.

[75] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 149 – *Anti-Suit-Injunction*.

[76] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 152 – *Anti-Suit-Injunction*.

[77] LG München I, 2.10.2019 – 21 O 9333/19, Rn. 153 – *Anti-Suit-Injunction*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Die Zulieferin zog das Urteil des Widerspruchverfahrens weiter vor das Oberlandesgericht München, dass die Berufung mit Urteil vom 12.12.2019 mit leicht angepasstem Tenor zurückwies, und im Ergebnis der Vorinstanz zustimmte.[78]

Das OLG München pflichtete der von der Vorinstanz bejahrten Erstbegehungsgefahr und der Rechtswidrigkeit des drohenden Eingriffs bei.[79] Jedoch vermochte sich der Senat nicht der Begründung der Vorinstanz anschließen soweit das Landgericht die Auffassung vertreten hatte, mit dem Erlass der beantragten Verfügung gehe ein im Hinblick auf das US-Gerichtsverfahren wirkendes Prozessführungsverbot nicht einher, weil die einstweilige Verfügung das dortige Hauptsacheverfahren unberührt lasse und es im Übrigen der Zulieferin und deren Konzernunternehmen unbenommen bleibe, den Patentinhaber mit weiteren Klagen weltweit zu überziehen.[80] Zwar treffe es zu, dass die einstweilige Verfügung keinen – unmittelbaren oder direkten – Einfluss auf das in den USA geführte, auf eine Lizenzierung der Patente zu FRAND-Bedingungen gerichtete Hauptsacheverfahren ausübe.[81] Dies ändere allerdings nichts daran, dass der Zulieferin mit Erlass der einstweiligen Verfügung versagt würde, einen nach US-Recht zulässigen Antrag im Rahmen eines anhängigen Gerichtsverfahrens zu stellen bzw. dort weiterzuverfolgen.[82] Der vom Landgericht vorgenommenen Differenzierung – unzulässige Beeinflussung der Führung des Hauptsacheverfahrens einerseits, zulässige Untersagung eines Antrags im Rahmen des Hauptsacheverfahrens andererseits – könne nicht gefolgt werden.[83] Nach der Rechtsprechung fehle es nicht nur für Klagen, die sich gegen die Prozessführung also solche richteten, am Rechtsschutzbedürfnis, sondern auch für Klagen, die sich gegen andere Maßnahmen im Rahmen von anhängigen gerichtlichen Verfahren (wie etwa Parteivorbringen) richteten.[84] In diesem Sinne handle es sich bei dem Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction bzw. einer Temporary Restraining Order um Anträge im Rahmen der Hauptklage auf Lizenzierung, mit denen der zeitliche Vorrang des Verfahrens auf Lizenzierung gesichert werden solle, damit man dieses ungestört von den zehn in Deutschland anhängigen Patentverletzungsverfahren betreiben könne.[85] Dass es sich bei den „begleitenden Anträgen“ nicht um selbstständige Verfahren handle, sondern diese ein anhängiges Hauptsacheverfahren voraussetzten, rechtfertige nicht die Beurteilung, die vorgenannte Rechtsprechung würde nur das Hauptsacheverfahren ergreifen, nicht aber begleitende Verfahrensanträge in Gestalt eines Antrags auf Erlass einer Anti-Suit Injunction bzw. einer Temporary Restraining Order.[86] Zudem sei auch eine mögliche Unvereinbarkeit der Anordnung eines ausländischen Gerichts mit deutschem Recht unabhängig von der Frage zu beurteilen, ob es dem deutschen Gericht verwehrt sei, auf die Befugnis zur Stellung und Weiterverfolgung von Anträgen einer Partei eines ausländischen Gerichtsverfahrens einzuwirken.[87]

So stehe dem Erlass einer einstweiligen Verfügung auch nicht ein prozessuales Privileg entgegen.[88] Das von der Rechtsprechung entwickelte prozessuale Privileg, wonach dem Prozessgegner ein bestimmtes prozessuales Verhalten einschließlich der Einleitung eines gerichtlichen/behördlichen Verfahrens nicht

[78] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19 – *Anti-Suit-Injunction*.

[79] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 57–59 – *Anti-Suit-Injunction*.

[80] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 61–62 – *Anti-Suit-Injunction*.

[81] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 62 – *Anti-Suit-Injunction*.

[82] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 62 – *Anti-Suit-Injunction*.

[83] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 62 – *Anti-Suit-Injunction*.

[84] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 62 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf BGH, 15.11.2012 – I ZR 128/11, Rn. 12–13 – *Rechtsmissbräuchlicher Zuschlagsbeschluss*, 21.12.2005 – X ZR 72/04, Rn. 14 – *Detektionseinrichtung II*. 15.7.2005 – GSZ 1/04, Rn. 23 – *Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I*, und 27.2.2018 – VI ZR 86/16, Rn. 16–18 – *Kinderwohlgefährdung* m.w.N.

[85] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 63 – *Anti-Suit-Injunction*.

[86] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 63 – *Anti-Suit-Injunction*.

[87] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 64 – *Anti-Suit-Injunction*.

[88] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 65 – *Anti-Suit-Injunction*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

im Wege der Klage/einstweiligen Verfügung untersagt werden könne, beruhe auf der Annahme, dass der Schutz des Prozessgegners regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung gewährleistet werde.[89] Wo dies nicht gewährleistet sei, habe es dagegen beim uneingeschränkten Rechtsgüterschutz zu verbleiben.[90] Diese Rechtsprechung zu dem sog. prozessualen Privileg betreffe – soweit für den Senat ersichtlich – nur Fallgestaltungen, in denen es um prozessbezogene Äußerungen oder Handlungen im Zusammenhang mit inländischen Verfahren gegangen sei, d.h. die Zulässigkeit einer Äußerung oder einer sonstigen prozessbezogenen Handlung sei der Prüfung in einem inländischen gerichtlichen oder behördlichen Verfahren vorbehalten gewesen.[91] Sofern man diese Rechtsprechung auf die vorliegende Fallgestaltung, bei der die Zulässigkeit und die Begründetheit des Antrags auf Erlass einer Anti-Suit Injunction ausschließlich nach dem maßgeblichen US-amerikanischen Recht von dem zuständigen Gericht in Kalifornien geprüft werde, übertragen wolle, wäre zu fordern, dass die Interessen des Antragstellers an der Fortführung der Patentverletzungsverfahren hinreichend gut gewahrt seien, wovon nach dem glaubhaft gemachten Sachvortrag nicht ausgegangen werden könne.[92]

Nach diesen Grundsätzen streite bei Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen zugunsten des Antragstellers dessen grundrechtlich geschütztes eigentumsähnliches Recht an seinen Patenten (in Gestalt der gerichtlichen Durchsetzbarkeit des aus dem Eigentum resultierenden Ausschließlichkeitsrechts gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber dem potentiellen Patentverletzer), welches im Streitfall gegenüber dem Grundrecht der Antragsgegnerin auf allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) Vorrang genieße und den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt gebiete.[93] Der Erlass der einstweiligen Verfügung stelle sich als einzige wirksame Abwehrmaßnahme gegenüber einer Anti-Suit Injunction dar, mittels derer der Antragsteller die Ausübung seiner Rechtsposition als Patentinhaber in den in Deutschland anhängigen Patentverletzungsverfahren bis zum Abschluss des zwischen anderen Parteien geführten US-Verfahrens, dessen Streitgegenstand mit den deutschen Verletzungsverfahren nicht identisch sei, gesichert werden könne.[94] Auch wenn das Hauptsacheverfahren in den USA zur Lizenzierung auf der Grundlage einer Benutzung der Patente des Antragstellers geführt werde, sei weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern der Einwand der Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen nicht in den bereits vor dem US-Verfahren anhängigen Verletzungsverfahren in Deutschland geltend gemacht werden könne, an denen zwei Konzerngesellschaften der Antragsgegnerin als Nebenintervenienten beteiligt seien.[95]

Dem könne die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, der Antragsteller – welcher sich durch seine Teilnahme am US-amerikanischen Markt der dortigen Rechtsordnung bewusst unterworfen habe, und sich daher an dieser festhalten lassen müsste – stünde im Rahmen eines Anti-Suit Injunction-Antrags in den USA hinreichende Möglichkeiten der Rechtsverteidigung einschließlich eines Rechtsmittels zur Verfügung.[96] Die Gewährung des rechtlichen Gehörs zum Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction und die Möglichkeit gegen deren Erlass ein Rechtsmittel einlegen zu können belege nicht, dass die Rechte des Patentinhabers nach den vorstehenden Grundsätzen im Rahmen des Antragsverfahrens hinreichend gewahrt würden.[97] Nach dem Verständnis des Senats stehe bei der

[89] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 67 – *Anti-Suit-Injunction*.

[90] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 67 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf BGH, 15.7.2005 – GSZ 1/04, Rn. 21 – *Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I* m.w.N.

[91] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 67 – *Anti-Suit-Injunction*.

[92] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 68 – *Anti-Suit-Injunction*.

[93] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 70 – *Anti-Suit-Injunction*.

[94] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 70 – *Anti-Suit-Injunction*.

[95] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 70 – *Anti-Suit-Injunction*.

[96] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 71 – *Anti-Suit-Injunction*.

[97] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 71 – *Anti-Suit-Injunction*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Prüfung der „Schutz“ des Hauptsacheverfahrens in Vordergrund, während die Auswirkungen eines Verbots der Fortführung der in Deutschland anhängigen Patentverletzungsverfahren demgegenüber offensichtlich nur insoweit Gegenstand der Prüfung seien, ob die damit einhergehende Berührung einer anderen ausländischen Rechtsordnung als „tolerabel“ angesehen werden könne.[98]

Ferner könne eine mangelnde Schutzbedürftigkeit des Patentinhabers nicht daraus abgeleitet werden, dass nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf eine Anti-Suit Injunction in Deutschland nicht für vollstreckbar erklärt werden könne. Der Antragsteller verweise insofern zurecht darauf, dass er für den Fall der Zuwiderhandlung gegen eine Anti-Suit Injunction in den USA mit der Verhängung einer gegen sie auszusprechenden Strafe rechnen müsste.[99]

Insgesamt müsse bei dieser Sachlage das Interesse der Antragsgegnerin, einen nach US-amerikanischen Recht zulässigen Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction zu stellen, zurücktreten.[100] Die Antragsgegnerin könne sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich der Patentinhaber mit seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung insofern widersprüchlich verhalten würde, als er zum einen ein Abwehrrecht gegen ein potentielles Verbot, seine Patentverletzungsprozesse in Deutschland fortzuführen zu können, beanspruche, zum anderer aber seinerseits die Antragsgegnerin mir einem Prozessführungsverbot in den USA überziehe.[101] Aus den vorherstehenden Gründen liege ein Ausnahmefall vor, der den Erlass einer einstweiligen Verfügung als zwingend gebotene Abwehrreaktion auf eine mögliche Anti-Suit Injunction (in Gestalt einer „Anti-Anti-Suit Injunction“) rechtfertige.[102]

Schließlich ließ sich das OLG München nicht nehmen, in Bezug auf die von der Vorinstanz abgelehnte Völkerrechtswidrigkeit der seiner Ansicht nach zutreffenden Begründung hinzuzufügen, das Völkerrecht stehe gemäß Art. 25 GG als „Bestandteil des Bundesrechts“ im Rang unterhalb des Bundesrechts.[103] Nachdem aus vorstehenden Gründen der Erlass einer einstweiligen Verfügung, wie durch das LG erfolgt, verfassungsrechtlich legitimiert sei, sei eine entgegenstehende Wertung durch das Völkerrecht auch insoweit nicht veranlasst.[104]

[98] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 71 – *Anti-Suit-Injunction*.

[99] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 72 – *Anti-Suit-Injunction*.

[100] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 73 – *Anti-Suit-Injunction*.

[101] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 73 – *Anti-Suit-Injunction*.

[102] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 73 – *Anti-Suit-Injunction*.

[103] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 74 – *Anti-Suit-Injunction*.

[104] OLG München, 12.12.2019 – 6 U 5042/19, Rn. 74 – *Anti-Suit-Injunction*, mit Verweis auf BVerfG, 15.12.2015 – 2 BvL 1/12, Rn. 67 ff. – *Treaty Override*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

II. Erfüllung der Huawei-Obliegenheiten vor, bei oder nach Verfahrensbeginn

Die Frage, ob und welche Schritte des *Huawei*-Verhaltensschemas die Verhandlungspartner bereits vor dem Beginn des gerichtlichen Verfahrens erfüllt haben müssen oder ob eine Vornahme bzw. Nachholung auch nach Verfahrenseinleitung noch möglich ist, wurde vor den deutschen Gerichten weiterhin thematisiert.[105] Grundsätzlich habe das Lizenzangebot vorprozessual zu erfolgen.[106] Wie das LG Düsseldorf darlegte, verlange der EuGH von dem SEP-Inhaber vor Erhebung der Klage, bzw. der gerichtlichen Geltendmachung des SEPs nicht nur einen Hinweis gegenüber dem Verletzer auf die Verletzung des SEPs, sondern bei Lizenzwilligkeit des Verletzers auch die Unterbreitung eines FRAND-konformen Angebots und die Angabe der Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühr.[107] So bezogen sich auch die Worte „vor der gerichtlichen Geltendmachung" in Rn. 61 des EuGH-Urteils[108] auch auf die Verpflichtung zur Angebotsunterbreitung und Begründung, da diese zeitlichen Vorgaben mittels der Worte „zum einen" auf den Verletzungshinweis bezogen seien, sich über die einleitenden Worte „zum anderen" in Rn. 63 des EuGH-Urteils aber auch auf die Verpflichtung zur Abgabe eines FRAND-Angebots bezogen.[109] Nach Ansicht des LG Düsseldorfs sei der insoweit relevante Zeitpunkt der „gerichtlichen Geltendmachung" im deutschen Patentverletzungsprozess die Einreichung der Klage nebst Einzahlung des Kostenvorschusses, denn damit sei die Klage unweigerlich auf den Weg gebracht und der Kläger habe keinen Einfluss mehr auf den zeitlichen Ablauf.[110] Weiter verlangte das OLG Düsseldorf, dass wenn der Lizenzsucher vorprozessual in ernsthafte Lizenzverhandlungen eingetreten sei, selbige grundsätzlich auch vor Klageerhebung erfolglos abgeschlossen sein müssten.[111]

Doch sei eine grundsätzliche, außerprozessuale Nachholbarkeit gegeben.[112] In der Rechtsprechung und Literatur sei umstritten, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen der SEP-Inhaber die ihm obliegenden Pflichten zur Unterbreitung eines FRAND-gemäßen Lizenzangebots auch noch während des laufenden Gerichtsverfahrens nachholen könne.[113] Jedenfalls sei die Nachholbarkeit unstreitig, als der SEP-Inhaber die erhobene Klage zurücknehmen und erneut einreichen könne, wenn

---

[105] Vgl. zu den vor 2017 ergangenen Fällen hierzu *Peter Georg Picht*, „FRAND wars 2.0" – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 7 <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916544>, S. 6.

[106] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 202 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 13.

[107] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 176; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 190; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 316–19 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 267–70 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 315–18; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 268–71, alle mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, erster Leitsatz – *Huawei/ZTE*.

[108] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE.*

[109] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 176; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 190; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 318–19 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 269–70 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 317–18; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 270–71.

[110] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 177; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 191; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 321 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 272 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 320; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 273, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 192.

[111] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 202 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[112] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 179; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 193; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 324 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 323; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 276.

[113] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/19, Rn. 178; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 192; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 323 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 274 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 322; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 275.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

er zwischenzeitlich seine kartellrechtlichen Obliegenheiten erfüllt habe, da der erfolgreich erhobene kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nicht zu einem dauerhaften materiellen Rechtsverlust des SEP-Inhabers führe, sondern die Klage als „derzeit unbegründet" abzuweisen sei.[114]

Strittiger ist jedoch die Frage, ob und in welchem Umfang eine Nachholbarkeit nach der gerichtlichen Geltendmachung gegeben ist.[115] Nach Ansicht des LG Düsseldorf trete, gewissermaßen als *argumentum a fortiori* infolge des oben genannten Grundsatzes selbst bei einer verspäteten, weil eben nicht vor der gerichtlichen Geltendmachung erfolgten Erfüllung der Pflichten „erst recht" kein materieller Rechtsverlust ein.[116] Darüber hinaus ist die Rechtsprechung betreffend die Nachholbarkeit im Prozess, das heißt nach der gerichtlichen Geltendmachung, aber differenzierter.

Auch nach Ansicht des OLG Düsseldorf dürften die nach dem EuGH-Urteil „vor der gerichtlichen Geltendmachung" geforderten Erklärungen grundsätzlich im Rechtsstreit nachholbar sein, weil ein Versäumnis grundsätzlich weder zu einer materiellen noch zu einer prozessualen Präklusion führen dürfe.[117] So sei jedenfalls der erforderliche Verletzungshinweis in der Klageschrift zu sehen.[118] Auch die hohen Anforderungen an die Annahme einer Lizenzverweigerung des Standard-Implementierers – eine solche sei nur anzunehmen sei, wenn seine Erklärungen den sicheren Schluss zuließen, dass der Patentbenutzer in Wahrheit keine Lizenz nehmen möchte, so dass sich die Abgabe eines Angebots durch den Patentinhaber von vornherein erübrige, und das Verhalten des Patentbenutzers als ernsthafte und endgültige Lizenzverweigerung zu bewerten sei (siehe IX.A.2 unten) – führten dazu, das die Lizenzbereitschaft grundsätzlich nachholbar sei.[119] Das darauffolgende Lizenzangebot habe grundsätzlich vorprozessual zu erfolgen, könne aber „aus den bereits angeführten Gründen" ebenfalls im Laufe des Rechtsstreits nachgeholt werden.[120]

Die Abteilung 4a des LG Düsseldorf hielt in den Urteilen vom 13.7.2017 betreffend die Nachholbarkeit des Lizenzvertragsangebots fest, es obliege dem SEP-Inhaber, dem Patentbenutzer ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebot bereits vor der Klage zu unterbreiten, andernfalls er die Unterbreitung eines Angebots während des laufenden gerichtlichen Verfahrens nicht uneingeschränkt nachholen könne.[121] Unter Verweis auf seine vorhergehende Rechtsprechung[122] hielt die Kammer fest, dass in der Vergangenheit hinsichtlich der Verletzungsanzeige eine Nachholung während eines laufenden

---

[114] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 189 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 9.5.2016 – I-15 U 35/16, Rn. 25; LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 179; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 193; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 324 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 323; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 276.

[115] Vgl. LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 178; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 192; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 325 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 276 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 324; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 277.

[116] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 179; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 193; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 324 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 323; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 276.

[117] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 189 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 9.5.2016 – I-15 U 35/16, OLG Karlsruhe, 8.9.2016 – 6 U 58/16 – *Dekodiervorrichtung* und 31.5.2016 – 6 U 55/16; OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 7, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 9.5.2016 – I-15 U 35/16, Rn. 25–30.

[118] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 7.

[119] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 9–10.

[120] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 189 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 9.5.2016 – I-15 U 35/16, OLG Karlsruhe, 8.9.2016 – 6 U 58/16 – *Dekodiervorrichtung* und 31.5.2016 – 6 U 55/16; OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 7, 13.

[121] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 316 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 315; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 268.

[122] LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 203.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Unterlassungsverfahrens im Einzelfall als zulässig erachtet werden konnte, insbesondere in „Übergangsfällen“, d.h. bei Klageerhebung vor Erlass des EuGH-Urteils.[123]

Jedoch spreche nach der bisherigen Rechtsprechung bei „Neufällen“, bei denen die Einreichung der Klage nach der Veröffentlichung des EuGH-Urteils erfolgt sei, einiges dafür, eine Nachholung abzulehnen, so lehne auch das LG Mannheim eine Nachholbarkeit innerhalb des Prozesses ab.[124] Wenn keine Besonderheiten vorlägen, die ausnahmsweise eine Klage vor Unterbreitung des FRAND-Angebots zulässig erscheinen ließen, wie ein „Übergangsfall“, sei eine Nachholung nach Klageerhebung jedenfalls nicht uneingeschränkt zulässig.[125] Sinn und Zweck des vom EuGH ersonnenen Systems würden ausgehebelt, wenn man eine Nachholung unbegrenzt zulasse. Die EuGH-Vorgabe des Angebots „vor der gerichtlichen Geltendmachung“ würde untergraben, wenn man eine Nachholung uneingeschränkt zulasse, insbesondere noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsgericht.[126] Würde man uneingeschränkt zulassen, dass der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erfüllten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens sanktionslos nachhole, so würde der Leitgedanke der Entscheidung des EuGH, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können und während des Verfahrens über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zuließen, ob das unterbreitete Lizenzvertragsangebot FRAND-konform sei oder nicht, verfehlt.[127] Das austarierte System des EuGH solle es den Parteien ermöglichen, ohne den Druck eines Unterlassungsklageverfahrens und damit gleichsam auf Augenhöhe zu verhandeln.[128] Wenngleich der Verletzer auch während des Verfahrens ein nicht FRAND-konformes Lizenzvertragsangebot ablehnen und sich mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand wehren könne, so wirke sich ein laufendes Unterlassungsklageverfahren trotzdem negativ auf seine Verhandlungsposition aus.[129] Aufgrund der Ungewissheit, ob der Einwand durchreifen werde – insbesondere, welche Lizenzgebührenhöhe vom Verletzungsgericht als (noch gerade) FRAND angesehen werde – müsse auch ein an sich lizenzwilliger Verletzer fürchten, am Ende zur Unterlassung verurteilt zu werden, wenn er grenzwertigen Lizenzgebührenforderungen nicht nachgebe.[130] Dies könne ihn dazu verleiten, während eines laufenden Verletzungsverfahrens höhere Lizenzgebühren zu akzeptieren als im Stadium vor der gerichtlichen Geltendmachung.[131] Hinzu komme, dass der Patentbenutzer bei den Verhandlungen zeitlich unter Druck gesetzt werde, um die (Zwischen-) Ergebnisse der Verhandlungen rechtzeitig in

---

[123] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 326 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 277 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 325; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 278; m.w.H. zur Übergangsfallthematik *Peter Georg Picht*, „FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 7 <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916544>, S. 6–10.

[124] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 326 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 277 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 325; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 278, alle mit Verweis auf LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15, Rn. 119.

[125] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 327 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 326; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 279.

[126] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 327 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 326; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 279.

[127] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 328 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 327; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 280, alle mit Verweis auf die gleiche Meinung des LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15, Rn. 119.

[128] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 328 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 327; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 280.

[129] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 328 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 327; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 280.

[130] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 328 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 327; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 280.

[131] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 328 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 327; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 280.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

den Prozess einführen zu können.[132] Dies gehe regelmäßig zu Lasten des Patentverletzers, da wenn der SEP-Inhaber seine Pflichten erfüllt habe, der Patentverletzer unter dem Zeitdruck eines drohenden Unterlassungstitels das Lizenzvertragsangebot des SEP-Inhabers prüfen, ein Gegenangebot machen und die Abrechnung und Sicherheitsleistung vorbereiten müsse, falls er das Angebot nicht annehmen wolle.[133] Zudem spreche gegen eine uneingeschränkte Nachholbarkeit, dass EuGH im Berichtigungsbeschluss vom 15.12.2015 klargestellt habe, dass sich die Worte „vor Erhebung der Klage" sowohl auf die Verletzungsanzeige als auch auf das FRAND-Angebot und die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen würden, und habe so die Bedeutung dieser zeitlichen Vorgabe unterstrichen.[134]

In ihren Urteilen entzog sich die Kammer 4a jedoch ausdrücklich einer Entscheidung, ob man eine Nachholbarkeit generell zulasse, da vorliegend selbst bei Einräumung einer großzügigen Nachholungsmöglichkeit die Angebote der Kläger zu spät bzw. zu spät begründet worden seien.[135] Eine Nachholbarkeit sei nur denkbar, wenn den Parteien (insbesondere dem Verletzer) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung genügend Zeit verbleibe, das vom EuGH vorgesehene Prozedere durchzuführen.[136] FRAND-Angebote, die so spät abgegeben oder begründet würden, dass dies nicht mehr möglich sei, könnten dagegen im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.[137] Die zeitlichen Vorgaben umfassten in sachlicher Hinsicht auch die Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren, denn erst wenn der Verletzer diese Angaben erhalten habe, liege ein Angebot vor, dessen FRAND-Gemäßheit er hinreichend überprüfen und auf das er nach den Vorgaben des EuGH reagieren müsse.[138] Werde das Angebot so spät abgegeben oder die Berechnung der Lizenzgebühren so spät begründet, dass dem Verletzer keine ausreichende Reaktionszeit zur Verfügung stehe, sei das Angebot im laufenden Verfahren unabhängig von seinem Inhalt nicht als FRAND anzusehen.[139] Selbst wenn eine Zurückweisung des Angebots als verspätet aufgrund des Prozessrechts nicht möglich sei (das nationale Prozessrecht dürfte für die Vorgaben des EuGH ohnehin nicht maßgeblich sein), könne das Angebot allenfalls dann berücksichtigt werden, wenn der Gegenseite eine angemessene Reaktion und die Einführung in den laufenden Prozess ohne unangemessenen zeitlichen Druck möglich sei.[140] Nach den Vorgaben des EuGH[141] müsse der Verletzer auf das Angebot des SEP-Inhabers „gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben" reagieren, woraus zwingend folge, dass ihm hierfür die

---

[132] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 328 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 327; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 280.

[133] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 328 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 327; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 280.

[134] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 330 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 281 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 329; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 282.

[135] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 331 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 282 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 330; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 283.

[136] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 332 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 283 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 331; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 284.

[137] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 332 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 283 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 331; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 284.

[138] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 367 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 318 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 366; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 319, alle mit Verweis auf LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15, Rn. 119.

[139] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 334 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 285 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 333; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 286.

[140] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 335 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 286 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 334; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 287, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 9.5.2016 – I-15 U 35/15, Rn. 30.

[141] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, 1. Leitsatz, 2. Spiegelstrich bzw. Rn. 65 – *Huawei/ZTE*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

erforderliche Zeit zur Verfügung gestellt werden müsse, um das Angebot sorgfältig zu prüfen und ein Gegenangebot zu formulieren.[142]

Die Abgabe eines (inhaltlich möglicherweise FRAND-Vorgaben genügenden) Angebots erst kurz vor der mündlichen Verhandlung zur Gewährung des Unterlassungsanspruchs stelle sich vor diesem Hintergrund als missbräuchlich dar, denn der Verletzer stehe in dieser Konstellation unter dem Druck, das Angebot entweder ohne hinreichende Prüfung anzunehmen oder es abzulehnen, bevor er es geprüft und ein Gegenangebot ausgearbeitet habe. Auf diese Weise werde das vom EuGH gewünschte Verhandeln auf Augenhöhe zwischen den Parteien behindert.[143] Je später das Angebot vom SEP-Inhaber abgegeben werde und je geringer damit der zeitliche Abstand zwischen Angebot (bzw. dessen Begründung) und mündlicher Verhandlung sei, desto stärker sei der Druck, dem der Verletzer ausgesetzt sei.[144]

Dementgegen ließ die Kammer 4a den Einwand, der verklagte Patentbenutzer könne auch nach Urteilsverkündung weiterhin das FRAND-Angebot annehmen, um eine Unterlassungsvollstreckung zu vermeiden, nicht gelten.[145] Der EuGH habe dem Patentbenutzer ausdrücklich selbst bei einem FRAND-gemäßen Angebot des SEP-Inhabers das Recht eingeräumt, dieses abzulehnen und seinerseits ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.[146] Auch lehnte das Kammer den Einwand ab, es sei unbillig den Unterlassungsanspruch selbst dann als derzeit unbegründet abzuweisen, wenn sich (ggf. in einem neuen Verfahren) herausstelle, dass ein FRAND-Angebot vom SEP-Inhaber abgegeben worden sei. Durch die späte Abgabe des Angebots missachte der SEP-Inhaber die Vorgaben des EuGH und trage daher das Risiko, dass das Prozedere nicht mehr durchgeführt werden könne.[147] Zudem sei die Folge der Nichtberücksichtigung im Prozess kein endgültiger Rechtsverlust, da die Möglichkeit einer erneuten Klage nach Durchführung des Prozesses weiterhin bestehe.[148]

Auch präzisierte die Kammer betreffend das Urteil des OLG Düsseldorf vom 17.11.2016, wonach die nach dem EuGH-Urteil „vor der gerichtlichen Geltendmachung" geforderten Erklärungen grundsätzlich im Rechtsstreit nachholbar seien, weil ein Versäumnis grundsätzlich weder zu einer materiellen noch zu einer prozessualen Präklusion führen dürfe,[149] die Aussage des OLG insoweit, als dass diese nicht so zu verstehen sei, dass ein FRAND-Angebot noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung abgegeben werden könne.[150] Das OLG habe in diesem Beschluss nur eine Nachholbarkeit im laufenden

[142] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 336 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 287 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 335; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 288.

[143] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 337 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 288 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 336; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 289.

[144] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 337 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 288 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 336; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 289.

[145] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 338 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 289 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 337; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 290.

[146] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 338 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 289 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 337; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 290.

[147] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 339 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 338; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 291, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 9.5.2016 – I-15 U 35/15, Rn. 30.

[148] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 339 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 338; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 291.

[149] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 189 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 7, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 9.5.2016 – I-15 U 35/16, Rn. 25–30.

[150] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 341 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 292 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 340; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 293.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verfahren als möglich angesehen.[151] Ungeachtet, ob man eine Nachholbarkeit generell als zulässig ansehe, sei damit kaum eine unbegrenzte Nachholbarkeit bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung gemeint.[152]

Bis wann eine Nachholung möglich sei, hänge vom Einzelfall ab.[153] Dem Patentbenutzer müsse ausreichend Zeit gegeben werden, um auf das Angebot zu reagieren.[154] Sei ihm dies innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht mehr möglich, so sei das Angebot nicht als FRAND anzusehen.[155] Im vorliegenden Fall beurteilte die Kammer 4a die Einreichung des Angebots elf Tage vor der mündlichen Behandlung und deutlich mehr als ein Jahr nach der gerichtlichen Geltendmachung des Klagepatents als verspätet und nicht mehr berücksichtigungsfähig.[156] Vielmehr stelle der Zeitpunkt des Angebots den Ausdruck einer FRAND-widrigen Lizenzierungspraxis dar,[157] und liege außerhalb der zeitlichen Vorgaben des EuGH.[158] Der Beklagten müsse jeweils die Möglichkeit gegeben werden, den gesamten Vortrag der Klägerin zu prüfen,[159] und ferner müsse die Beklagte nach den EuGH-Vorgaben ein FRAND-gemäßes Angebot nicht annehmen, sondern dürfe hierauf ein Gegenangebot formulieren.[160] Dafür sei ein Zeitraum von elf Tagen, einschließlich zweier Wochenenden und einem Feiertag, erkennbar nicht ausreichend.[161] Auch sei nicht ersichtlich, warum die Klägerin das Angebot nicht früher hätte machen können.[162]

Schließlich sei das Gericht auch nicht dazu verpflichtet, durch Vertagung der mündlichen Verhandlung dafür zu sorgen, dass der SEP-Inhaber seine Pflichten noch während des Prozesses durchführen könne, oder aufgrund der Hinweispflicht aus § 139 ZPO den SEP-Inhaber aufzufordern, ein bestimmtes, FRAND-gemäßes Angebot zu machen.[163] Zweck der Hinweispflicht sei es nicht, die Parteien zu einem bestimmten geschäftlichen Verhalten anzuhalten, wie ein bestimmtes Vertragsangebot abzugeben bzw. anzunehmen oder ihnen für vorprozessuale Obliegenheiten im Prozess mehr Zeit zu

[151] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 341 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 292 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 340; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 293.

[152] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 341 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 292 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 340; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 293.

[153] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 348 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 299 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 347; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 300.

[154] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 348 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 299 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 347; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 300.

[155] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 348 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 299 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 347; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 300.

[156] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 400–01 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 351–52 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 399–400; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 352–53.

[157] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 400 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 351 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 399; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 352.

[158] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 401 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 352 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 400; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 353.

[159] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 402 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 353 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 401; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354.

[160] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 402 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 353 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 401; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354.

[161] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 402 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 353 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 401; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354.

[162] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 404 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 355 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 403; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 356.

[163] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 342 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 293 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 341; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 294.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

verschaffen.[164] Auch der EuGH sehe eine Moderation durch das Gericht nicht vor, sondern vielmehr sollten sich die Parteien vorprozessual einigen und nur wenn dies scheitere, dürfe der Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend gemacht werden.[165] Erst wenn beide Parteien die Vorgaben des EuGH erfüllten und dennoch kein Lizenzvertrag zustande komme, solle ein Dritter zur FRAND-Bestimmung eingeschaltet werden dürfen, wogegen die Mitwirkung eines Dritten bei der Formulierung von Angebot oder Gegenangebot nicht vorgesehen sei.[166]

Auch die Kammer 4c des LG Düsseldorf setzte sich mit der Frage der zeitlichen Anforderungen an das Lizenzvertragsangebot in ihren Urteilen vom 11.7.2018 auseinander.[167] Zur Klärung der Frage, ob eine Nachholung bzw. Nachbesserung des Lizenzangebots im laufenden Prozess möglich sei, setzte sich die Kammer mit der Auffassung des LG Mannheim auseinander.[168] Dies lehne die grundsätzliche Möglichkeit der Nachholung bzw. Nachbesserung eines Lizenzangebots im laufenden Prozess mit der Begründung ab, dass entsprechende Nachholungshandlungen nicht geeignet seien, die Intention des EuGH zu erfüllen, die Verhandlungen unbelastet von der Klage führen zu können.[169] Demgegenüber sei in der Düsseldorfer Rechtsprechung mittlerweile anerkannt, dass eine Nachholung auch mit Wirkung für den bereits laufenden Prozess – jedenfalls im Einzelfall – noch möglich sein solle.[170] Weiter schließt sich die Kammer 4c der Kammer 4a an, und verweist auf Sinn und Zweck des vom EuGH ersonnenen System, das eine drucklose Verhandlung auf Augenhöhe ermöglichen solle.[171]

Jedoch schlägt die Kammer 4c gemäßigtere Töne an, und setzt sich, entgegen der Kammer 4a,[172] mit der generellen Zulässigkeit der Nachholbarkeit auseinander. So folge aus den erwähnten Ausführungen nicht, dem klagenden Patentinhaber absolut, d.h. ohne Ausnahme, eine Nachbesserungsmöglichkeit zu versagen, vielmehr sei ihm eine – die Grenzen der prozessualen Verspätungsvorschriften beachtende – Nachholbarkeit im Einzelfall zuzustehen, da es dem SEP-Inhaber möglich sein müsse, auf – berechtigte – Einwände des Verletzers einzugehen und sein Angebot gegebenenfalls zu modifizieren.[173] Sofern dies rechtzeitig im Laufe eines Verfahrens geschehe, verbleibe der Gegenseite ausreichend Zeit zu reagieren. Zudem würde eine absolute Versagung der Nachbesserungsmöglichkeit der Prozessökonomie zuwiderlaufen, da der Patentinhaber immer gezwungen wäre, die Klage zurückzunehmen und nach Unterbreitung eines Angebots neu zu klagen, was weder im Interesse des Klägers noch des Beklagten wäre.[174]

In den vorliegenden Fällen erschien es der Kammer fraglich, ob ein drittes Lizenzangebot, dass erst mit der Replik und somit fünf Monate nach Erhebung der Unterlassungsklagen überreicht wurde, zu berücksichtigen sei, was das Gericht im Ergebnis aber offen ließ.[175] Dennoch sei zu berücksichtigen, dass vor dem Hintergrund, dass die vorliegend zu entscheidende Unterlassungsklage „erst“ sechs Monate nach Unterbreitung des zweiten Lizenzangebots erhoben wurde, kein Grund dafür ersichtlich

[164] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[165] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[166] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/17, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[167] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17; 11.7.2018 – 4c O 81/17.

[168] LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15.

[169] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 180; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 194.

[170] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 180; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 194, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, 9.5.2016 – I-15 U 35/16 und LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 154/15.

[171] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 181; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 195, vgl. dazu oben S. 3.

[172] Vgl. oben S. 4.

[173] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 184; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 198.

[174] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 184; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 198.

[175] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 185–87; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 199–201.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

sei, wieso die Klägerin den Beklagten nicht vor Erhebung der Unterlassungsklage bereits in modifiziertes (drittes) Lizenzangebot vorgelegt habe.[176] Insoweit spreche vieles dafür, dass die Klägerin ein Verstoß gegen die ihr obliegende Pflicht zur Prozessförderung zur Last zu legen sei mit der Folge, dass das dritte Lizenzangebot der FRAND-Prüfung nicht zu Grunde zu legen wäre.[177]

Auch das LG Mannheim setzte sich mit der Nachholbarkeit der FRAND-Verfahrensschritte auseinander. Im Urteil vom 10.11.2017 hielt das Landgericht fest, die Obliegenheiten des SEP-Inhabers bestünden im Grundsatz jeweils vor der Klageerhebung.[178] Das vom EuGH entwickelte Konzept sei nach dem Verständnis der Kammer von der Intention getragen, dass sich der angebliche Verletzer, ohne dem Druck einer bereits erhobenen Unterlassungsklage ausgesetzt zu sein, im Verhandlungswege entscheiden könne, ob er gewillt sei, die vorgeschlagenen und transparent gemachten Vertragsbedingungen als FRAND entsprechend anzuerkennen und zu diesen Bedingungen Lizenz zu nehmen oder mit einem FRAND-Gegenangebot eine Einigung zwischen den Parteien anzustreben.[179] Die Kammer habe in ihrer bisherigen Rechtsprechung eine Nachholung der an sich vorprozessual zu erfüllenden Obliegenheiten vor diesem Hintergrund nicht zugelassen, wobei es im konkreten Rechtsstreit keiner Entscheidung bedürfe, ob an dieser Spruchpraxis festzuhalten sei.[180]

Bemerkenswerterweise ließ sich die Kammer dennoch nicht nehmen auszuführen, sie werde angesichts des im Prozessrecht grundsätzlich allein maßgeblichen Zeitpunkts des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung für das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen und der die Begründetheit der tragenden Tatsachen sowie angesichts des auch das Unionsrecht tragenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (vgl. Art. 6 EUV i.V.m. Art. 52 Abs. 1 S. 2 GRCh) aber zukünftig zu prüfen haben, ob der bislang eingenommene Standpunkt zur Wahrung der Vorgaben des EuGH erforderlich sei.[181] Um dem vom EuGH konkretisierten Unionsrecht zur praktischen Wirksamkeit zu verhelfen (*effet utile*, Art. 4 Abs. 3 EUV), werde im Falle der Nachholung vorprozessual nicht erfüllter Obliegenheiten im Verlauf des Verletzungsrechtsstreits indes sicherzustellen sein, dass das Gebot vorprozessualer Erfüllung nicht sanktionslos unterlaufen werden könne und dass der Leitgedanke, Lizenzverhandlungen ohne den unmittelbaren Druck eines gerichtlichen Verfahrens auf Augenhöhe auf Grundlage entsprechender Informationen führen zu können, als möglich im Prozess verwirklicht werde.[182] Die Kammer tendiere eingedenk dessen dazu, dass dem SEP-Inhaber, der seine vorprozessualen Obliegenheiten erstmals im Prozess nachzuholen gedenke, obliege eine „drucklose“ Verhandlungssituation mit dem angeblichen Verletzer wiederherzustellen.[183] Eine solche Verhandlungslage biete das Prozessrecht im Rahmen der Ruhendstellung eines Rechtsstreits zum Zwecke von (Vergleichs-) Verhandlungen nach § 251 ZPO i.V.m. § 249 Abs. 1, Abs. 2 ZPO.[184] Danach dürfte der SEP-Inhaber bei Nachholung seiner Informationsobliegenheiten gehalten sein, das Ruhen des Verletzungsrechtsstreits zu beantragen.[185] Der angebliche Verletzer werde sich in dieser Situation dem Ruhensantrag der klagenden Partei anschließen, wenn er lizenzwillig sei, um in „drucklose“ Lizenzverhandlungen zurückzukehren.[186]

[176] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 184; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 198.

[177] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 184; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 198.

[178] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 124 – *Funkstation*.

[179] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 124 – *Funkstation*.

[180] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 125 – *Funkstation*.

[181] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 126 – *Funkstation*.

[182] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 126 – *Funkstation*.

[183] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 126 – *Funkstation*.

[184] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 126 – *Funkstation*.

[185] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 126 – *Funkstation*.

[186] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 126 – *Funkstation*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Im Urteil vom 28.9.2018 konnte das LG Mannheim schließlich auf die Frage zurückkommen.[187] Die Klägerin, die ursprünglich Klage gerichtet auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzverpflichtung erhob, erweiterte die Klage nach fast achtmonatigen Verhandlungen um die Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufanträge.[188] Diesbezüglich führte die Kammer aus, die Klageerweiterung stelle einen Missbrauch nach Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1 GWB dar.[189] Die Klägerin habe der Beklagten vor der Klageerweiterung keine angemessene Frist eingeräumt, um das Angebot zu prüfen und ein Gegenangebot abgeben zu können.[190]

Für die Beurteilung der Angemessenheit der Frist sei auf den Zeitpunkt der Vollständigkeit des Angebots nach den Vorgaben des EuGH abzustellen (zur Vollständigkeit unten XI.B.1).[191] Dabei wäre der Zeitraum von etwa drei Monaten, der der Beklagten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung zur Verfügung stand, zwar grundsätzlich ausreichend gewesen, um der Beklagten eine sorgfältige Prüfung des Angebots zu ermöglichen.[192] Dies ändere jedoch nichts an der Missbräuchlichkeit der Klageerweiterung.[193] Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung des Rechtsstreits sei zwar der Schluss der letzten mündlichen Verhandlung (vgl. § 296a ZPO).[194] Jedoch sei zu berücksichtigen, dass das vom EuGH festgelegte Verhandlungsprogramm deshalb vor Erhebung der Klage auszuführen sei, weil damit vermieden werden solle, dass der angebliche Verletzer unter dem Druck einer drohenden Verurteilung ungünstigen Lizenzbedingungen zustimme.[195] Dieser Druck sei besonders hoch, wenn die Klage auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf bereits erhoben sei, was in besonderem Maße gelte, wenn – wie vorliegend – zwischen Klageerweiterung und mündlicher Verhandlung etwa acht Woche lägen.[196] Eine drucklose Verhandlungssituation sei nicht gewährleistet, wenn die Parteien sich an gerichtlich gesetzte Fristen halten müssten.[197]

Auch eine Moderation durch das Verletzungsgericht könne eine druckfreie Verhandlungssituation nicht sicherstellen, denn die Parteien seien am besten in der Lage, im Rahmen von ernsthaft geführten Verhandlungen eine Einigung darüber zu erzielen, was faire Lizenzbedingungen und Gebührensätze seien.[198] Es möge zwar sein, dass das Gericht durch gerichtliche Hinweise und mit Hilfe von Schriftsatzfristen die Parteien zu zügigem Verhalten anleiten könne, jedoch sei es gerade diese Prozess- bzw. Drucksituation, vor der der mutmaßliche Verletzer geschützt werden solle.[199] Erhebe der SEP-Inhaber Klage, ohne zuvor den aus der FRAND-Verpflichtungserklärung sich ergebenden Obliegenheiten zu genügen, bleibe die Klageerhebung missbräuchlich, wenn und solange sich der SEP-Inhaber nicht um eine drucklose Verhandlungssituation bemühe.[200] Abermals verwies das LG Mannheim daraufhin auf die Ruhendstellung eines Rechtsstreits zum Zwecke von Vergleichsverhandlungen nach § 251 ZPO, mit der das Prozessrecht eine solche Verhandlungslage

[187] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16.

[188] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 13.

[189] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 116.

[190] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 116.

[191] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 117.

[192] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 119.

[193] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 119.

[194] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120.

[195] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120, mit Verweis auf Schlussanträge des Generalanwalts *Wathelet*, 29.11.2014 – C-170/13, Rn. 102, und COM, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten (2017) 712 S. 12.

[196] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120.

[197] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120.

[198] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120, mit Verweis auf COM, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten (2017) 712 S. 7.

[199] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120.

[200] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

biete.[201] Die Klägerin wäre danach gehalten gewesen, das Ruhen des Verfahrens zu beantragen, um zu einer druckfreien Verhandlungssituation zurückzukehren.[202] Dem sei die Klägerin nicht nachgekommen.[203]

[201] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120.

[202] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120, mit Verweis auf LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 126 – *Funkstation*.

[203] LG Mannheim, 28.9.2018 – 165/16, Rn. 120.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

III. FRAND-Verhalten trotzt non-FRAND Reaktion?

Um die Grundsatzfrage, ob eine Partei ihre *Huawei*-Obliegenheiten selbst dann einhalten muss, wenn die andere Partei dies nicht tut, war es seit Ende 2016 eher ruhiger geworden,[204] auch wenn die Frage in den FRAND-Einwand-Entscheiden des BGH wieder aufgeflammt ist.[205] Vereinzelt haben sich die deutschen Gerichte zwischen 2017 und 2019 dazu geäußert, neben den kurzen Bemerkungen des LG Mannheim und dem LG Düsseldorf vor allem das OLG Düsseldorf eingehender.

Das LG Mannheim hat seine bisherige Rechtsprechung diesbezüglich insofern spezifiziert, als nach Ansicht der Kammer der Verletzer auf ein auf konkret dargelegte Tatsachen fußendes Lizenzvertragsangebot agiere müsse, auch wenn es seiner Auffassung nach – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspreche.[206] Eine Ausnahme davon sei nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident nicht als FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstelle (m.w.H. zur Evidenzkontrolle siehe XI.B.1.d)2) unten).[207]

Demgegenüber seien nach Ansicht des OLG Düsseldorf die Verfahrensschritte grundsätzlich konsekutiv festzustellen, abgesehen von der Entbehrlichkeit als einer bloßen Förmelei. Bereits im Beschluss vom 16.1.2016 habe der Senat festgestellt, die Frage, ob die Klägerin ihrer Pflicht zur Abgabe eines FRAND-Lizenzangebots nachgekommen sei, könne nicht etwa mit der Begründung offengelassen werden, dass es jedenfalls an einem FRAND-Gegenangebot der Beklagten bzw. einem FRAND-Verhalten der Beklagten im Übrigen mangele.[208] Vielmehr seien die im Rahmen des vom EuGH vorgegebenen Regimes von wechselseitigen Pflichten/Obliegenheiten vorgegebenen Verfahrensschritte durch die Verletzungsgerichte grds. konsekutiv festzustellen, mit anderen Worten habe der Patentverletzer nur dann in der ihm obliegenden Art und Weise zu reagieren, wenn der SEP-Inhaber zuvor seinerseits seine Pflichten erfüllt habe.[209] Ebenso wie der Patentverletzer seine Lizenzbereitschaft, abgesehen von den Fällen einer Entbehrlichkeit unter dem Aspekt der „bloßen Förmelei", nur nach einem Verletzungshinweis des SEP-Inhabers bekunden müsse, obliege dem Patentverletzer die Abgabe eines FRAND-Gegenangebots erst dann, wenn ihm ein FRAND-Angebot des SEP-Inhabers vorliege.[210]

Das durch den EuGH vorgegebene System knüpfe die dem Patentverletzer obliegenden Maßnahmen/Schritte im Rahmen des Lizenzierungsprocedere, darunter insbesondere die Obliegenheit zur Präsentation eines FRAND-Gegenangebots nämlich an die zwingende Voraussetzung, dass der SEP-Inhaber zuvor seine Pflichten erfüllt habe.[211] So sehe der EuGH für den vorzunehmenden Interessenausgleich ein austariertes Procedere vor und billige im Rahmen dessen dem marktbeherrschenden SEP-Inhaber nur insoweit ein schützenswertes Interesse zu, als dieser – nach der Lizenzwilligkeitsbekundung des Benutzers – entsprechend seiner gegenüber der Standardisierungsorganisation abgegebenen Verpflichtungserklärung ein Lizenzangebot zu FRAND-

[204] Zur diesbezüglichen Debatte vgl. *Peter Georg Picht*, „FRAND wars 2.0" – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 7 <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916544>, S. 10–16.

[205] BGH, 5.5.2020 – KZR 36/17 – FRAND-Einwand I; 24.11.2020 – KZR 35/17 – FRAND-Einwand II, dazu *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>

[206] LG Mannheim, 17.11.2016 – 7 O 19/16, Rn. 80, mit Verweis im Ergebnis auf LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14 und LG Düsseldorf, 3.11.2015 – 4a O 144/14.

[207] LG Mannheim, 17.11.2016 – 7 O 19/16, Rn. 80.

[208] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 200 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[209] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 200 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[210] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 200 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[211] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 201 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Bedingungen unterbreite.[212] Dieses Verständnis der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung gründe sich – entgegen der betreffenden Kritik durch das LG Mannheim[213] – keineswegs allein auf dem Wortlaut der EuGH-Entscheidung, denn neben dem Umstand, dass diverse Passagen in der EuGH-Entscheidung[214] vorhanden seien, die diese Auslegung bestätigten, ergebe sich die entsprechende „Vorleistungspflicht" des SEP-Inhabers vor allem anhand der Überlegung. Dass der EuGH bei der Etablierung der von ihm aufgestellten Reihenfolge für die Verfahrensschritte ganz maßgeblich darauf abgestellt habe, dass erstens von dem SEP-Inhaber wegen seiner FRAND-Zusage gegenüber der Standardisierungsorganisation die Angabe eines FRAND-Angebots erwarteten werden dürfe und zweitens der SEP-Inhaber, wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht seien, in einer besseren Lage sei, um zu überprüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahre, als der angebliche Verletzer.[215] Wäre der andere Teil schon in dem Falle, dass der SEP-Inhaber bloß irgendein formales, FRAND-Anforderungen widersprechendes Angebot unterbreitet habe, zur Abgabe eines FRAND-Gegenangebots gehalten, wäre diese Prämisse des EuGH ihrer Sinnhaftigkeit beraubt.[216] Das vom OLG Düsseldorf befürwortete Verständnis stelle demgegenüber sicher, dass die Parteien zu Angeboten veranlasst und mittelbar gezwungen würden, die nicht bloß formal, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht annahmefähig seien.[217] Eine von einem FRAND-Lizenzangebot unabhängige Obliegenheit des Benutzers, ein FRAND-Gegenangebot zu unterbreiten, lasse sich auch nicht mit der Überlegung rechtfertigen, dass dieser seine Lizenzbereitschaft dokumentieren müsse, da diese der Benutzer bereits zuvor mit der dem Lizenzangebot des SEP-Inhabers vorausgehenden Lizenzierungsbitte hinreichend zum Ausdruck gebracht habe.[218] Solange der SEP-Inhaber darauf nicht mit einem FRAND-Gegenangebot reagiere, müsse der Patentverletzer seine Lizenzbereitschaft nicht durch Abgabe eines FRAND-Gegenangebots erneut unter Beweis stellen.[219]

Weiter äußerte sich auch das LG Düsseldorf diesbezüglich kurz in seinem Urteil vom 11.7.2018, dass es keiner Entscheidung mehr darüber bedürfe, ob ein FRAND-konformes Gegenangebot der Beklagten hätte vorgelegt werden müssen, da sich das Angebot der Klägerin evident als nicht FRAND darstelle.[220]

Schließlich bemerkte das OLG Düsseldorf auch in seinem Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 kurz, dass die Beklagte keine Verpflichtung treffe, zu bloßen Teilaspekten Stellung zu beziehen, da die Klägerin sich betreffend ihr Lizenzvertragsangebot nicht branchenüblich verhalten habe.[221]

---

[212] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 201 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[213] LG Mannheim, 4.3.2016 – 7 O 96/14 – *Informationsaufzeichnungsmedium*.

[214] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE*, wobei das OLG auf Leitsatz 1 („zu diesen Bedingungen"), Rn. 63 („zu FRAND-Bedingungen"). Rn. 64 („ein solches Angebot") und Rn. 71 („zu diesen Regelungen") verweist.

[215] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 201 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 64 – *Huawei/ZTE.*

[216] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 201 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[217] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 201 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 8.9.2016 – 6 U 58/16 – *Dekodiervorrichtung*.

[218] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 201 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[219] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 201 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[220] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 254.

[221] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 27.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

IV. Patentverletzung und Standardessenzialität

Im Urteil vom 30.3.2017 hielt das OLG Düsseldorf fest, dass mit Blick auf die geltend gemachte Standardessenzialität des Klagepatents grundsätzlich zwei Methoden des Nachweises des Klagepatentanspruchs in Betracht kämen, mittelbar oder unmittelbar.[222]

Einerseits könne die Verwirklichung eines standardessenziellen Patents „indirekt", d.h. ohne Abgleich der konkret angegriffenen Ausführungsformen mit den Merkmalen des Patentanspruchs, dadurch belegt werden, dass die jeweilige technische Lehre eines Patentanspruchs mit einem Standard verglichen wird. Dieser mittelbare Nachweis einer Patentverletzung setze voraus, dass (unterstellt) standardgemäß funktionierende Geräte zwingend von der technischen Lehre des betreffenden Patents Gebrauch machten.[223] Werde der betreffende Standard in seiner ganzen Breite angewandt, sei grundsätzlich auch der Standard mit seinem gesamten Inhalt, einschließlich solcher Verhaltensoptionen, die nur unter besonderen Anwendungsbedingungen oder nur als eine von mehreren Alternativen vorgesehen seien, Grundlage der Beurteilung, in welcher technischen Weise bei der Einhaltung des Standards verfahren werde.[224] Sofern dann feststehe, dass ein Benutzer den Standard betrachte, sei im Weiteren gesichert, dass eine mögliche dem Standard entsprechende Vorgehensweise eine Benutzung des Klagepatents darstelle, wobei auch dann eine Patentbenutzung anzunehmen sei, wenn der Umfang der Geschäftstätigkeit des Beklagten oder sonstige von dem klagenden Patentinhaber darzulegende Umstände den sicheren Schluss zuließen, dass die Vorgaben des Standards bei Ausübung der Geschäftstätigkeit in ihrer gesamten Bandbreite ausgeschöpft worden seien.[225]

Machten standardgemäß funktionierende Ausführungsformen hingegen vom jeweiligen Patent entweder gar keinen Gebrauch oder handle es sich um eine bloß optionale Ausführungsvariante des Standards neben weiteren ihrerseits nicht patentverletzenden Varianten, verbleibe es bei dem allgemeinen Grundsatz, dass der Verletzungskläger Merkmal für Merkmal im Rahmen eines Vergleichs der angegriffenen Ausführungsform mit dem Anspruch darzutun und zu beweisen habe, dass die technische Lehre des Patents benutzt werde.[226]

Im Folgenden stellte das OLG fest, dass die Vorinstanz die Verwirklichung der Merkmale des Patentanspruchs nach der erstgenannten Methode zu Recht bejaht habe.[227] So würden sie Merkmale des Standards vollständig umgesetzt und zudem seien die Vorgaben des Standards betreffend die Merkmale zwingend in der Implementierung vorhanden, und nicht bloß optional.[228] Bei dieser Sachlage komme es auf die weiteren Einwände der Beklagten nicht mehr an, insbesondere sei die Benutzung eines Vorrichtungsanspruchs schon dann zu bejahen, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht seien und die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet sei, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen.[229] Wenn dies der Fall sei, so sei unerheblich, ob diese Eigenschaften und Wirkungen regelmäßig, nur in Ausnahmefällen oder nur

[222] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 110–12 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 17.9.2009 – Xa ZR 2/08, Rn. 13–18 – *MP3-Player-Import*, OLG Düsseldorf, 28.1.2010 – I-2 U 129/08; 28.1.2010 – I-2 U 131/08 – *interframe dropping*, LG Mannheim, 4.5.2010 – 2 O 142/08 – *zusätzliche Anwendungssoftware*, LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05 – *Videosignalcodierung I*.

[223] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 111 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[224] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 111 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[225] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 111 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05 – *Videosignalcodierung I*.

[226] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 112 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 9.7.2014 – 6 U 29/11, Rn. 178–83, 279 – *Zugriffskanal*.

[227] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 113 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[228] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 114–22 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[229] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 123–24 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zufällig erreicht würden und ob es der Verletzer darauf absehe, sie herbeizuführen, weshalb die Patentverletzung auch gegeben sei, wenn eine Vorrichtung regelmäßig so bedient werde, dass sie nicht erzielt würden, solange die Nutzung der patentgemäßen Lehre nur objektiv möglich bleibe.[230]

Das LG München I äußerte sich in den Urteilen vom 20.12.2018 zur Darlegungs- und Substantiierungspflicht der Patentverletzung, zwar nicht in direktem Zusammenhang mit einem SEP,[231] jedoch dürften die Erkenntnisse der Urteile auch für SEP-Fälle von besonderer Relevanz sein.

Zum einen schloss sich auch das LG München I der vom OLG Düsseldorf[232] zitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung an, wonach eine Patentverletzung schon dann vorliege, wenn die Merkmale der angegriffenen Ausführungsformen objektiv geeignet seien, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen.[233] Dementsprechend sei eine behauptete Deaktivierung der patentverletzenden Merkmale, die unstreitig nicht irreversibel sei, unbeachtlich, da es mich dem erforderlichen Knowhow und technischen Equipment möglich sei, die Deaktivierung aufzuheben, wobei nicht relevant sei, dass ein Durchschnittsverwender die Deaktivierung nicht aufheben könne.[234]

Zum anderen äußerte sich das Landgericht zu den Anforderungen an substantiierten Klagevortrag. So sei die Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform eine Tatfrage und damit einer Geständnisfiktion nach § 138 Abs. 3 ZPO zugänglich.[235] Sei die Pflicht zum vollständigen Vortrag aus § 138 Abs. 3 ZPO erfüllt, treffe den Gegner eine Erklärungslast aus § 138 Abs. 2 ZPO, wofür ein bloß pauschales Bestreiten grundsätzlich nicht genügt, da abhängig von der Tiefe des Vorbringens der Klägerseite die Beklagtenseite entsprechend tiefen Gegenvortrag erbringen müsse, andernfalls die Geständnisfiktion nach § 138 Abs. 3 ZPO greife.[236] Den Gegner treffe dabei eine Erkundungspflicht zu Vorgängen im Bereich von Personen auch in fremden Unternehmen, die unter Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung der erklärungspflichtigen Partei tätig geworden seien.[237] Ebenso könne die Pflicht bestehen, weitere Hilfsmittel einzusetzen.[238] Auf § 138 Abs. 4 ZPO könne sich die Beklagte aber nicht berufen, wenn sie beispielsweise bei einem Zulieferer Informationen über den Aufbau einer angegriffenen Ausführungsform hätte erfragen können, ihrer Erkundungspflicht aber nicht nachkam.[239]

Hingegen könne einer Partei grundsätzlich nicht die Durchführung eines US-Discovery-Verfahrens abverlangt werden, um ihrer Vortragslast zu genügen, denn das Discovery-Verfahren gehe über die von der ZPO vorgesehene Darlegungs- und Beweislast hinaus, weil es letztlich Ausforschungsmöglichkeiten biete, das die ZPO gerade verhindern wolle.[240] Zudem habe der deutsche Gesetzgeber eine Erklärung nach Art. 23 HBÜ abgegeben, wonach Rechtshilfeersuchen, die auf

[230] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 124 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 13.12.2005 – X ZR 14/02 – *Rangierkatze*, OLG Düsseldorf, 13.2.2014 – I-2 U 93/12 – *Digitalblock*.

[231] Vgl. LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 25, 468, 477; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 25, 465, 474.

[232] Vgl. oben S. 1 betr. OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 123–24 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[233] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 372; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 369.

[234] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 372–73; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 369–70.

[235] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 349; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 346, beide mit Verweis auf BGH, 17.9.2009 – Xa ZR 2/08, Rn. 14 – *MP3-Player-Import*.

[236] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 349; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 346.

[237] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 349; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 346.

[238] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 349; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 346.

[239] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 349; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 346.

[240] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 350; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 347, beide mit Verweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, BT-Drs. 18/11637, S. 4.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

pretrial-discovery-Verfahren gerichtet seien, nicht erledigt werden sollten.[241] Wenn schon keine Rechtshilfeersuchen bearbeitet würden, könne einer vor einem deutschen Gericht klagenden Partei nach dieser Wertentscheidung des deutschen Gesetzgebers erst recht nicht abverlangt werden, ein Discovery-Verfahren durchzuführen, um vortragen zu können.[242] In casu habe die Klägerin alles getan, was sie zu einer Aufklärung beitragen konnte, und weitere prozessuale Möglichkeiten, insbesondere auch nach § 140c PatG und § 142 ZPO, seien ihr nicht zur Verfügung gestanden.[243] Hingegen könne der Klägerin nach dem oben Gesagtem nach § 138 Abs. 1 ZPO gerade nicht auferlegt werden, die Schaltpläne mittels eines US-Discovery-Verfahrens zu erlangen.[244]

Die Beklagte wiederum müsse den klägerischen Vortrag, dass die Architektur der angegriffenen Ausführungsform die Verwirklichung der Merkmale verlange, wirksam bestreiten um diesem entgegenzutreten.[245] Dabei sei Bestreiten, das nicht so tiefgehend ist wie die Erklärung des Gegners, prozessual unbeachtlich und führe zu einer Geständnisfiktion nach § 138 Abs. 3 ZPO.[246] In casu habe die Beklagte dem nicht genügt, und war insbesondere nicht erfolgreich mit dem Einwand, wegen der Geheimhaltungsinteressen des Zulieferers könne sie nicht näher zu der Ausgestaltung vortragen, nach Vorlage der Schaltpläne aus dem US-Discovery-Verfahren würde sich aber zeigen, dass die angegriffene Ausführungsform die Patentmerkmale nicht verwirkliche.[247] Die Beklagte hatte, im Gegensatz zur Klägerin, insbesondere nicht dargelegt, aufgrund welcher technischer Ausgestaltung die angegriffene Ausführungsform gerade den Patentanspruch gerade nicht verwirkliche und wie die angegriffene Ausführungsform stattdessen funktionieren solle.[248] Einfaches Bestreiten durch bloßes negieren des Vorbringens der Klägerin sei unbeachtlich, da ein einfaches Bestreiten nicht ausreichend sei, weil die Klägerin substantiiert dargelegt habe, welche Gründe für das Vorhandensein eines Offsets sprächen.[249] Das Gericht müsse den nicht wirksam bestrittenen Vortrag der Klägerin nach dem Verhandlungs- und Beibringungsgrundsatz für sein Urteil unterstellen, und eine Beweiserhebung auf Basis des noch nicht hinreichenden Vortrags der Beklagtenseite würde Ausforschung gewesen sein.[250] Eine Beweiserhebung auf Basis eines unsubstantiierten Tatsachenvortrags würde die Klägerin in ihren Rechten verletzt haben.[251]

Auch könne dahinstehen, ob § 138 Abs. 4 ZPO auch eingreife, wenn eine Partei durch ein Geschäftsgeheimnis an substantiiertem Sachvertrag gehindert sei, da ein solchen die Beklagtenseite nicht substantiiert vorgebrachte habe, sondern sie sich vielmehr nur pauschal auf Geheimhaltungsinteressen des Zulieferers bezogen habe.[252] Es leuchte jedem Prozessbeteiligten sofort ein, dass Geheimhaltungsinteressen zwischen einer Partei und einem Dritten nicht zu Lasten des Prozessgegners führen könnten.[253]

Eine interessante Bemerkung betreffend Patentverletzung und kausale Schuldanerkenntnis durch Lizenzgebührzahlung führte das LG München I mit Urteil vom 15.3.2018 in einem fast schon

[241] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 350; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 347, beide mit Verweis auf BGBl. II 1979, 781 und § 14 AusfG-HBÜ.

[242] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 350; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 347.

[243] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 351; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 348.

[244] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 352; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 349.

[245] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 353; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 350.

[246] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 354; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 351.

[247] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 355–56; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 352–53.

[248] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 357–58; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 354–55.

[249] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 366; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 363.

[250] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 368; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 365.

[251] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 369; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 366.

[252] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 365; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 362.

[253] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 400; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 397.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

anekdotisch anmutenden Sachverhalt an.[254] Die Klägerin verlangte darin Rückzahlung von ihrer Meinung nach rechtsgrundlos an die Beklagte vierteljährlich bezahlten laufenden Lizenzgebührenzahlungen aufgrund eines Standardlizenzvertrags für Patentlizenzen.[255] Nach neun von der Klägerin übermittelten Lizenzabrechnungen und Leistung der entsprechenden Beträge stellte sich die Klägerin auf den Standpunkt, die streitgegenständlichen Produkte der Klägerin verwendeten die lizenzierte standardisierte Technologie gar nicht, und seien nicht fähig, entsprechende Audiodateien widerzugeben, weshalb die gezahlten Lizenzgebühren zurückzuerstatten seien.[256]

Nach Urteil des LG München I sei die Rückforderung der Lizenzgebühren mit der Begründung, die Produkte unterfielen nicht dem Lizenzvertrag, ausgeschlossen, da die Klägerin ihre Lizenzzahlungspflicht insoweit durch ihre Lizenzabrechnungen anerkannt habe.[257] In den Lizenzabrechnungen mit handschriftlich unterzeichneter Bestätigung der Wahrheit und Richtigkeit der getätigten Zahlungen in den neun Lizenzabrechnungen sei je ein kausales Schuldanerkenntnis zu sehen.[258]

Ohnehin bestehe in dem Maße Unsicherheit auch über die abstrakte Lizenzgebührenzahlungspflicht, wenn aus dem Patentlizenzvertrag nicht hervorgehe, dass über ein bestimmtes Verständnis von dem Schutzbereich des lizenzierten Patents bei Vertragsschluss Konsens bestanden habe, sondern über den Schutzbereich im Rahmen vertretbarer Positionen gestritten werden könne.[259] Die Zahlung von Lizenzgebühren sei ein Umstand, der auf ein zur Zahlungspflicht führendes Schutzbereichsverständnis des Lizenznehmers schließen lasse.[260] Mache der Lizenznehmer an mehreren Gelegenheiten nacheinander deutlich, dass der geleistete Zahlungen nach seinem besten Wissen für inhaltlich gerechtfertigt halte, sei ein Irrtum über das Bestehen eines Rechtsgrunds gerade nicht wahrscheinlich.[261]

[254] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16.

[255] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16, Rn. 1, 8, 22.

[256] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16, Rn. 20, 31.

[257] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16, Rn. 67.

[258] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16, Rn. 68–69.

[259] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16, Rn. 72.

[260] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16, Rn. 72.

[261] LG München I, 15.3.2018 – 7 O 23064/16, Rn. 72.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

V. Marktmacht des Patentinhabers

Das Eingreifen des EU-Wettbewerbsrechts gegen einseitiges Verhalten setzt den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung voraus (vgl. Art. 102 AEUV). Die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers als Anknüpfungspunkt für den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand wurde auch in der FRAND-Einwand-Rechtsprechung des BGH vorausgesetzt.[262] Fraglich ist, ob die FRAND-Erklärung des Patentinhabers eine darüberhinausgehende Verpflichtungszusage unabhängig von einer marktbeherrschenden Stellung enthält.[263]

Anders als Gerichte anderer (ehemaliger) Mitgliedstaaten ist das OLG Düsseldorf in seinem Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 davon ausgegangen, es sei bei der FRAND-Erklärung grundsätzlich vom Willen des Patentinhabers auszugehen, die Lizenzwilligkeit nur für den Fall der tatsächlich gegebenen Marktbeherrschung zu versprechen.[264] Auch nach Ansicht des LG Düsseldorf sei ohne das Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung auch im FRAND Kontext jede Art von Kartellrechtseinwand ausgeschlossen.[265] Danach ist folglich für die Verfügbarkeit des FRAND-Zwangslizenzeinwands der relevante Markt abzugrenzen und dessen Beherrschung durch den SEP-Inhaber zu eruieren.[266]

Nach Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 30.3.2017 sei der Lizenzvergabemarkt mittels Bedarfsmarktkonzept als relevanter Markt abzugrenzen,[267] auf dem der Patentinhaber als Anbieter und der Anwender der patentgeschützten Technik als Nachfrager auftreten.[268] Grundsätzlich führe „jedes Patent zu einem eigenen sachlich relevanten Markt, es sei denn, dass im Einzelfall eine – aus Sicht der Nachfrager – gleichwertige Technologie für dasselbe technische Problem zur Verfügung steht.“[269] Jedoch sei anerkanntermaßen mit der Inhaberschaft von Patenten allein noch keine marktbeherrschende Stellung verbunden, sondern eine solche entstehe erst, wie das OLG Düsseldorf unter Verweis auf die einschlägige EuGH-Rechtsprechung zutreffend feststellt,[270] wenn der Patentinhaber aufgrund hinzutretender Umstände die Möglichkeit erhalte, mittels seiner Monopolstellung wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten Markt (im vorliegenden Fall dem nachgelagerten Produktmarkt für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen) zu verhindern.[271] Das OLG Düsseldorf stütz insofern die Auffassung des LG Düsseldorf, dass der für Marktmacht und kartellrechtliche Zwangslizenz in SEP-Fällen ausschlaggebende Markt nicht der

[262] BGH, 5.5.2020 – KZR 36/17 – FRAND-Einwand I; 24.11.2020 – KZR 35/17 – FRAND-Einwand II, dazu *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>.

[263] Vgl. zu dieser Möglichkeit etwa LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14, Rn. 201; m.w.H. *Peter Georg Picht*, „FRAND wars 2.0“ – Rechtsprechung im Anschluss an die Huawei/ZTE-Entscheidung des EuGH, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 7 <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2916544>, S. 16.

[264] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-U 66/15, Rn. 2.

[265] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 254.

[266] Vgl. etwa OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 148 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[267] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 148 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[268] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 149 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[269] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 149 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[270] Verweis auf EuGH, 6.4.1995, verb. Rs. C-241/91 P und C-242/91 P, Slg. 1995 I-00743, Rn. 50 ff. – *Magill*; 6.12.2012, Rs. C-457/10 P, EU:C:2012:770 – *AstraZeneca*.

[271] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 149 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

jeweilige Einzelmarkt für eine Nutzung/Lizensierung jedes einzelnen SEPs sei, sondern der Markt für die jeweiligen standardbasierten Produkte und Dienstleistungen.[272]

Weiter begründe nach Auffassung des OLG Düsseldorf ein standardessenzielles Patent als solches noch keine hinreichende Begründung für eine Marktbeherrschung.[273] Auch sei auf die Standardessenzialität allein keine (widerlegliche) Vermutung zu stützen,[274] dass der SEP-Inhaber wirksamen Wettbewerb gerade deshalb verhindern könne, weil das SEP aufgrund der Standardessenzialität benutzt werden müsse, um mit dem Standard kompatible Produkte erzeugen zu können.[275] Stattdessen bedürfe es in Bezug auf jedes einzelnes Patent eine auf die Umstände des Einzelfalls abstellende Beurteilung seiner wettbewerblichen Bedeutung für den nachgelagerten Produktmarkt.[276] So sei die marktbeherrschende Stellung auch gegeben, wenn das Patent keine eigentliche Marktzutrittsvoraussetzung begründe, aber aus technischen Gründen die generelle Interoperabilität nicht mehr gesichert wäre, oder nur ein Nischenmarkt verbleiben würde.[277] Hingegen fehle es an einer marktbeherrschenden Stellung, wenn die SEP-Technik für die Mehrzahl der Nachfrager auf dem Produktmarkt allenfalls eine untergeordnete Bedeutung habe.[278]

Eine solche Unerlässlichkeit des standardessentiellen Patents liege nach der Auffassung des LG Düsseldorf vor, wenn ein tatsächlicher oder potentieller Ersatz standardisierter Technologie unmöglich oder unzumutbar sei auch bei gehöriger Anstrengung des Nachfragers.[279] Auch sei die standardessentielle Erfindung unerlässlich, wenn das auf Mobiltelefonen abgespielte Videoformat durch Inhalte-Anbieter bestimmt werde, und Hersteller ihre Produkte deshalb mit der Möglichkeit zur Unterstützung verschiedener Videoformatstandards ausrüsteten.[280] Die Videostandards seinen gerade deshalb nicht austauschbar, da die Unterstützungsmöglichkeit ein Must-Have für die Kunden von Smartphones sei.[281] Auch wenn der AVC-Videostandard keine Marktzutrittsvoraussetzung sei, wären Produkte ohne diesen nicht tatsächlich wettbewerbsfähig.[282]

Keine marktbeherrschende Stellung könne hingegen ein abgelaufenes Klagepatent vermitteln.[283] Dabei müsse für die Frage der Marktbeherrschung auf die Verhältnisse während der Laufzeit des Patents abgestellt werden, wozu die Beklagte vorzutragen habe.[284] Beispielsweise dürfte so die Verbreitung von 7-Kanal-Lautsprechersystemen zu Anfang des von der Klägerin geltend gemachten Zeitraums noch weitaus geringer gewesen sein als zum Zeitpunkt des Verfahrens vor dem LG Düsseldorf.[285]

---

[272] LG Düsseldorf, 26.3.2015 – 4b O 140/13, Rn. 167–68; 19.1.2016 – 4b O 120/14, Rn. 343–44; 19.1.2016 – 4b O 122/14, Rn. 359; 19.1.2016 – 4b O 123/14, Rn. 328.

[273] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 150 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[274] Zu dieser Möglichkeit etwa Schlussanträge *GA Wathelet*, 20.11.2014, Rs. C-170/13 – *Huawei/ZTE*, Rn. 58.

[275] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 150 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[276] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 150 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[277] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 150 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[278] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 150 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[279] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 116; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 129.

[280] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 235–36; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 217; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 223–24.

[281] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 235–36; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 217; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 223–24.

[282] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 235–36; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 217; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 223–24.

[283] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 266.

[284] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 266.

[285] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 266.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Weitergehend bemerkte das LG Düsseldorf, dass Marktbeherrschung sich auch ohne Standardessenzialität alleine aus einer technischen oder wirtschaftlichen Überlegenheit der patentierten Erfindung ergeben könne.[286] Auch wenn diese Rechtsauffassung im Einklang mit der diesbezüglichen EuGH-Auffassung ist, bleibt festzuhalten, dass eine Marktbeherrschung aufgrund technischer oder wirtschaftlicher Überlegenheit der patentierten Erfindung nicht leichthin anzunehmen sein dürfte, da ein Eingriff in den Substitutionsanreiz innerhalb des Schutzbereichs des Patents durch kartellrechtliches Zulassen von Imitationswettbewerb nur angezeigt ist, wenn eine eigentliche Dysfunktionalität des Immaterialgüterrechts festgestellt werden kann. Dementsprechend formulierte das LG München I etwas restriktiver, dass eine Ausweitung des Anspruchs auf Lizenzerteilung auf nicht-standardessentielle Patente nach der EuGH-Rechtsprechung allenfalls dann in Betracht komme, wenn deren Benutzung unabdingbar sei.[287] Maßstab sei die eine marktbeherrschende Stellung vermittelnde „Nicht-Umgehbarkeit" des Patents.[288] Mangels einer solchen unterstrich das LG München I die Bedeutung der aus dem Patent fließenden Rechte und lehnte deren Begrenzung abseits von Marktbeherrschung ab.[289]

Auch das OLG Hamburg hielt betreffend die Marktmacht des SEP-Inhabers fest, die marktbeherrschende Stellung ergebe sich nicht alleine aus der Standardessenzialität der Patente.[290] Die bloße Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums genüge nach der EuGH-Rechtsprechung nicht, um eine marktbeherrschende Stellung zu begründen; sie sei aber geeignet unter bestimmten Umständen eine solche zu schaffen, was im Einzelfall geprüft werden müsse.[291] Sei die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers jedoch im Verfahren unstreitig, seien keine besonderen Feststellungen dazu im Einzelfall zu treffen.[292]

[286] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 286 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 285; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 236.

[287] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 201; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 198.

[288] LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 190; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 187, beide mit Verweis auf EuGH, 6.4.1995, verb. Rs. C-241/91 P und C-242/91 P, Slg. 1995 I-00743, Rn. 50 ff. – *Magill*.

[289] Vgl. LG München I, 20.12.2018 – 7 O 10495/17, Rn. 190 ff.; 20.12.2018 – 7 O 10496/17, Rn. 187 ff.

[290] OLG Hamburg, 16.2.2017 – 3 U 15/15, Rn. 154 – *TV-Untertitel*.

[291] OLG Hamburg, 16.2.2017 – 3 U 15/15, Rn. 155 – *TV-Untertitel*.

[292] OLG Hamburg, 16.2.2017 – 3 U 15/15, Rn. 155 – *TV-Untertitel*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

VI. Poollizenzen

Standardessenzielle Patente verschiedener Patentinhaber können in einem Patentpool gemeinschaftlich organisiert sein, und von einem Lizenzverwalter zentral verwertet werden. Folgendes Kapitel behandelt besondere, aus der Patentinhabermehrheit resultierende Problemfelder, mit denen sich die Rechtsprechung bisher auseinandersetzen musste.

A. Verhaltensanforderungen

Im Rahmen der Verhaltensanforderungen stellen sich vor allem Fragen der Zurechenbarkeit des Verhaltens des Lizenzverwalters zum Patentinhaber. Im Rahmen der Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf betreffend den von der MPEG LA verwalteten Patentpool für den AVC-Videostandard sah der angebotene Standardlizenzvertrag vor, dass die Lizenzverwalterin sich verpflichte den Lizenzsuchern einzelne Lizenzen bzw. Unterlizenzen zu maßvollen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, die von der Patentinhaberin als Klägerin, erteilt werden könnten.[293] Dabei hatte die Lizenzgeberin ihrerseits der MPEG LA eine Lizenz gewährt, um die Lizenzverwaltung zu ermöglichen.[294] Zwar möge im Handeln der MPEG LA ein eigenes Handeln vorliegen, weil sie eine Unterlizenz vergebe. Dennoch stelle dieses Handeln durch Unterlizensierung letztlich nur eine Tätigkeit dar, die die Lizenzverwalterin anstelle der Klägerin (und aller anderer Poolmitglieder) vornehme.[295] Dass diese Verwaltungstätigkeit berechtigt erfolge, ergebe sich aus der Formulierung des Standardlizenzvertrags selbst. Die Standardimplementiererin als Beklagte habe während der gesamten außergerichtlichen Verhandlungen die Berechtigung der Lizenzverwalterin für die Pool-Mitglieder zu handeln nicht in Frage gestellt.[296] Selbst wenn man nicht von einer vorherigen Berechtigung hinsichtlich aller Handlungen, die die Lizensierung des Klagepatents als Bestandteil des Patentpools betrafen, ausgehen wolle, sei jedenfalls in der Klageerhebung eine Genehmigung der Klägerin zu sehen.[297] Die Kammer sehe nicht, warum der vom EuGH vorgesehene Dialog zwischen SEP-Inhaber und Lizenzinteressent empfindlich gestört sein solle, wenn zunächst mit einem Poolverwalter anstelle des einzelnen Pool-Mitglieds verhandelt werde, sei doch augenscheinlich, dass es im Bereich der SEP-Lizensierung üblich sei, dass Unternehmen ihre Patente im Wege einer Poollösung zur Verfügung stellten und es insofern einen Ansprechpartner für den gesamten Pool gebe (zum Handeln durch eine Lizenzverwalterin siehe unten VIII.C).[298]

Zudem sei die Kammer ausgehend vom Leitbild des EuGHs der redlich verhandelnden Parteien im unverfälschten Wettbewerb geneigt anzunehmen, dass Parteien, die tatsächlich an einem Vertragsschluss interessiert seien, ihre konstruktiven Bedenken hinsichtlich gegenseitiger Forderungen nicht „scheibchenweise“ vortragen, sondern den Verhandlungsstoff konzentrieren. Dies umso mehr, denn es um grundlegende Fragestellungen wie die Zusammensetzung des Pools gehe.[299]

[293] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 311; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 269; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 250; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 257.

[294] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 311; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 269; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 250; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 257.

[295] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 312; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 270; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 251; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 258.

[296] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 312; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 270; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 251; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 258.

[297] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 312; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 271; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 251; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 259.

[298] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 312; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 251.

[299] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 335; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 274.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

B. Inhaltserfordernis

Im Rahmen der Organisierung von SEPs in einem Patentpool stellen sich besondere Fragen betreffend den Inhalt des Lizenzvertragsangebots. Diese sollen im Folgenden nach den zwei Prongs von FRAND in Angemessenheit und Diskriminierungsfreiheit gegliedert werden.

1. Angemessenheit

a) Angemessenheit von Pool-Lizenzverträgen im Allgemeinen

Betreffend die FRAND-Gemäßheit vom Anbieten von Poollizenzen als solches im Standardlizenzvertrag hielt das Landgericht Düsseldorf fest, dass dies für sich allein den Vorwurf einer missbräuchlichen Unangemessenheit noch nicht begründe, sondern es im Gegenteil regelmäßig dem Interesse der Lizenzsucher diene durch eine mögliche vereinfachte Nutzung des erfassten Standards.[300] Maßstab sei die angemessene und branchenübliche Behandlung.[301] Ohne das Hinzutreten weiterer Umstände sei eine gewisse Pauschalisierung, die mit der Poollizenz zwingend einhergehe, als solche nicht beanstandungswürdig.[302] Dadurch, dass eine Benutzungserlaubnis für den gesamten Standard aus einer Hand zu einheitlichen Konditionen offeriert werde (sog. „one-stop-shop"-Lösung), würden Lizenzsucher der Notwendigkeit enthoben, bei jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber um eine Lizenz für dessen Patente nachsuchen zu müssen.[303] Des Weiteren gäben auch die Technologietransferleitlinien[304] eine Orientierungshilfe, da diese die wettbewerbsfördernde Wirkung von Technologiepools durch die Senkung von Transaktionskosten, die Beschränkung der Kumulierung von Lizenzgebühren, und die zentrale Lizenzvergabe anerkannten.[305] Einher damit gehe eine bessere Durchsetzungsmöglichkeit der Lizenz für SEP-Inhaber aufgrund der leichteren Kontrolle der Verträge und eine leichtere Verfolgung von Rechtsverstößen.[306] Hingegen sei, im Sinne der Kommission, erst beim Hinzutreten von weiteren Umständen von einer wettbewerbsbeschränkenden Wirkung auszugehen, zum Beispiel wenn ein Pool ausschließlich oder zu einem erheblichen Teil aus substituierbaren Technologien bestehe, die zu kollektiven Kopplungsgeschäften und Preisfestsetzung zwischen den Wettbewerbern führten (Preiskartell), bei Verringerung des Wettbewerbs zwischen den Vertragsparteien, insbesondere wenn sie einen Industriestandard unterstützten oder de facto begründeten, oder bei Beschränkung des Innovationswettbewerbs durch den Ausschluss alternativer

[300] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 332; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 297; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 271; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 305; 9.11.2018 – 4a O 16/17; Rn. 287; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 436; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 358, letztere mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 119 – *Videosignal-Codierung I*.

[301] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 309; 9.11.2018 – 4a O 16/17; Rn. 291.

[302] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 331; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 270.

[303] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 332; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 297; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 271; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 305; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 287; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 436; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 358, letztere mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 119 – *Videosignal-Codierung I*.

[304] COM, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, 28.3.2014 (2014/C 89/03).

[305] COM, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, 28.3.2014 (2014/C 89/03), Rn. 245; LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 332; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 297; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 271; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 306; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 288; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 437; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 359.

[306] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 332; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 297; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 271; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 285.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Technologien oder der Erschwerung des Marktzugangs für neue und verbesserte Technologien.[307] Ein Ausbeutungstatbestand werde regelmäßig dann zu bejahen sein, wenn in einem Pool planmäßig für die Einhaltung des Standards nicht notwendige Schutzrechte Eingang fänden, sodass der Zweck erkennbar werde, die Lizenzgebühr durch die Aufnahme möglichst vieler Patente ungerechtfertigt zu steigern.[308]

Über die Frage, ob das Anbieten eines Poollizenzvertrags als solches FRAND-widrig ist, hinaus setzte sich die Kammer 4a des Landgerichts Düsseldorf mit der Frage auseinander, ob das Beharren auf einer Poollizenz dadurch, dass Poolmitglieder den Abschluss von Individuallizenzen verweigern und den Abschluss einer Standardlizenz anbieten einen Marktmissbrauch darstellt.[309] Dies sei unter Verweis auf die obengenannten Vorzüge einer Poollizenz abzulehnen, da auch keine Schlechterstellung der Lizenznehmer des Pools gegenüber jenen Lizenznehmern, die individualvertraglich Lizenzen mit den jeweiligen Pool-Mitglieder abschließen erfolge, weil die Pool-Mitglieder intern dazu verpflichtet seien, auch alle außerhalb des Patentpools gehaltenen SEPs den Pool-Lizenznehmern ebenfalls zu lizensieren.[310] Insofern habe die Klägerin das Recht, das ihr im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit zustehe, den von ihr favorisierten Standardlizenzvertrag über die Lizenzverwalterin anzubieten.[311] So sei auch die Business-Strategie des Konzerns der Beklagten, die im Abschluss von Kreuzlizenzen liege, kein Umstand, die die SEP-Inhaberin zwinge, eine Individuallizenz anzubieten, da das Meistbegünstigungsprinzip gerade nicht greife.[312] Zudem stehe es den Poolmitgliedern frei, ihre SEPs auch außerhalb des Pools zu lizensieren, was sich aus dem Standardlizenzvertrag ergebe, um vom Safe-Harbour-Bereich der Leitlinien zu profitieren.[313] Würde jedoch die Poolverwaltungspraxis diese Möglichkeit nicht eröffnen, wäre sie allein deswegen kartellrechtswidrig.[314]

Im Folgenden werden zuerst Einzelfragen von Pool-Lizenzverträgen zur Indizwirkung von bereits geschlossenen Pool-Lizenzverträgen für die Angemessenheit besprochen (allgemein siehe XI.B.2 unten). Anschließend werden verschiedene Umstände aufgezeigt mit denen sich das LG Düsseldorf auseinandergesetzt hat, die vorgebracht wurden mit der Behauptung, durch deren Hinzutreten sei die Poollizenzvergabe unangemessen und damit missbräuchlich, was die Indizwirkung bisheriger Lizenzverträge umstoße, insbesondere Lizenzverträge mit Lizenznehmern, die gleichzeitig Poolmitglieder sind, Unterschiede bei der Anzahl der in Kraft stehenden Poolpatenten in einzelnen Ländern, und einer kartellrechtswidrigen Zusammensetzung des Pools.

b) Begründung der Indizwirkung

Fraglich war vor dem LG Düsseldorf welche Unternehmen zu dem Kreis der eine Indizwirkung für die Angemessenheit begründenden Lizenzverträge dazugehörten. Streitig war insbesondere inwiefern

[307] COM, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, 28.3.2014 (2014/C 89/03), Rn. 246, 255; LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 332; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 297; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 271; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 308; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 290; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 439; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 361.

[308] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 332; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 297; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 271; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 458; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 380.

[309] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 404; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 343.

[310] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 405; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 344; für weitere Hinweise zu dieser vertraglich vorgesehenen Drittwirkung siehe unten S. 9.

[311] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 405; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 344.

[312] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 406.

[313] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 409; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 348, beide mit Verweis auf COM, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, 28.3.2014 (2014/C 89/03), Rn. 261.

[314] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 409; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 348.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Unternehmen, die gleichzeitig Lizenznehmer und Poolmitglieder sind zum Vergleich herangezogen werden und eine Indizwirkung begründen können.[315] Betreffend die entstehende Indizwirkung des Standardlizenzvertrags sei jedoch einzig ausschlaggebend, dass auch weitere, auf dem Mobilfunkmarkt tätige Unternehmen zu dem Kreis der Lizenznehmer gehörten, wofür auch die Menge der abgeschlossenen Standardlizenzverträge (über 2000) im Verhältnis zu der Anzahl[316] der Poolmitglieder (36) spreche.[317] Folglich hielt es das LG Düsseldorf im Rahmen der Begründung der Indizwirkung für die Angemessenheit durch Vorlage der Standardlizenzverträge für ausreichend, dass auch andere Unternehmen, die nicht Poolmitglieder sind die Verträge abgeschlossen hatten und setzte sich nicht mit der Frage auseinander, ob dies nicht nur ausreichend, sondern auch notwendig sei.

Anders argumentierte die Abteilung 4b im Parallelverfahren. Im Verfahren vor der Abteilung 4b des LG Düsseldorfs wurde hervorgebracht, der Indizwirkung würde nicht begründet werden können, da keine allgemeine Akzeptanz der Lizenzbedingungen am Markt vorliege, da Vertragsparteien der Standardlizenzverträge zugleich Poolmitglieder seien. So wandte die Lizenzsucherin gegen eine Indizwirkung für die Angemessenheit der Lizenzbedingungen ein, der allgemeinen Akzeptanz der Vertragsbedingungen stehe entgegen, dass nur 2% der Telefone von Lizenznehmern stammen, die nicht zugleich Poolmitglieder seien und die Poolmitglieder Mehrausgaben aufgrund der Lizenzausgaben gleichzeitig mit steigenden Lizenzeinnahmen kompensieren würden.[318] Jedoch konnte die Klägerin die Einwände entkräften, da die generierten Lizenzgebühren anteilmäßig abhängig von den eingebrachten Patenten ausgezahlt würden und es keine Korrelation von Pool-Patenten und Bedeutsamkeit am Markt gebe, sondern vielmehr eine völlige Separierung der Pool-Daten von den Marktdaten erfolge.[319] In der Folge würden Pool-Mitglieder wie jeder andere Lizenznehmer auch behandelt, wobei nicht ersichtlich sei warum die abgeschlossenen Lizenzen kein valides Indiz für die Marktakzeptanz sein sollten.[320] So hätten in casu bereits Unternehmen mit großer Marktmacht, die durchaus in der Lage seien in Lizenzverhandlungen angemessene Bedingungen durchzusetzen, sich auf die Lizenzbedingungen des Standardlizenzvertrags eingelassen ohne einen Gewinn aus der Poolmitgliedschaft zu ziehen.[321] Der Umstand, dass auch diese Lizenzen abgeschlossen haben, spreche dafür, dass die Bedingungen FRAND-gemäß seien.[322] Zudem bestehe mangels objektiver Umstände, die einen Sachverhalt auch nur andeutungsweise aufzeigen, der die Befürchtung der Beklagten stützt, dass sich mehrere große Marktteilnehmer zusammengeschlossen hätten um bestimmte Lizenzbedingungen am Markt durchzusetzen, kein Anlass zur Vorlage der Membership-Verträge der Pool-Mitglieder.[323]

Die Begründungen beider Kammern haben gemeinsam, dass sie sich damit auseinandersetzen, welche Anforderungen an die bereits abgeschlossenen Standardlizenzverträge zu stellen sind, um eine Indizwirkung für die Angemessenheit zu begründen. Methodisch ist wohl die Argumentation der Abteilung 4a zu bevorzugen, da dort für die Begründung der Indizwirkung sämtliche bereits abgeschlossenen Standardlizenzverträge hinzuzählt werden, was auch als Ausgangpunkt für die Prüfung der Diskriminierungsfreiheit zu bevorzugen ist. Der vor der Abteilung 4b geltend gemachte

[315] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 393; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 315.

[316] Interessanterweise nimmt die Abteilung 4a des LG Düsseldorf hier betreffend die Indizwirkung die Anzahl der Lizenzverträge als ausschlaggebendes Kriterium, während die Abteilung 4b betreffend die Widerlegung der Indizwirkung/Unangemessenheit von der Anzahl der verkauften Telefone ausgeht, vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[317] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 393; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 315.

[318] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[319] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[320] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[321] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[322] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[323] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Einwand, der Standardlizenzvertrag sei nicht angemessen, setzt sich vielmehr mit der Widerlegung der Indizwirkung durch mangelnde Akzeptanz am Markt von Nicht-Poolmitgliedern auseinander, was methodisch korrekterweise von der Begründung der Indizwirkung zu trennen ist.

Schließlich stehe der Begründung einer Indizwirkung durch den Standardlizenzvertrag auch nicht entgegen, dass gewisse Lizenznehmer neben Smartphones, wie die Beklagte, auch andere AVC-fähige Produkte anboten, denn auch auf diese würden sich unangemessen hohe Lizenzen […] im Grundsatz nachteilig auswirken[324]

c) Widerlegung der indizierten Angemessenheit durch Unangemessenheit

Die durch Vorlage der abgeschlossenen Standardlizenzverträge begründete Indizwirkung für die Angemessenheit des Standardlizenzvertrags könnte durch eine vom Lizenzsucher darzulegende Unangemessenheit umgestoßen werden.[325] Maßgeblich für die Unangemessenheit dürfte wohl die Branchenüblichkeit sein.[326]

1) Unangemessenheit durch unterschiedliche Anzahl der in Kraft stehenden Poolpatente in einzelnen Ländern

Das Landgericht Düsseldorf hatte in den Urteilen vom 9.11.2018 zu prüfen, ob sich die Unangemessenheit entgegen der Indizwirkung etwa aus dem Umstand ergeben könnte, dass für den chinesischen Markt weniger Poolpatente in Kraft stehen als in anderen Jurisdiktionen.[327] So erkannte die Abteilung 4a an, dass ein solcher Sachverhalt zwar grundsätzlich Anhalt für eine unangemessene Behandlung geben könne, wobei es maßgeblich auf die Branchenüblichkeit ankomme.[328] Jedoch sei zunächst zu beachten, dass die Zahl der in einem Land in Kraft stehenden Schutzrechte nicht überbewertet werden dürfe, weil auch schon ein einziges Patent in der Lage sei, einen Interessenten von dem standarddefinierten Markt fernzuhalten. Ob der Lizenzsucher darüber hinaus noch weitere Lizenzen benötige, um die standardisierte Technologie zu nutzen, spiele dann eine eher untergeordnete Rolle.[329] Schließlich sei beachtlich, dass der Anteil der Poolpatente in China am viertstärksten sei.[330]

Zudem stelle die Tatsache, dass eine Patentdurchsetzung möglicherweise erschwert sei, für sich genommen keinen Grund dar geringere Lizenzraten zu verlangen, da ein Patent schon zu beachten sei, wenn es bestehe.[331] Alles in allem ergebe sich entgegen der Indizwirkung keine Unangemessenheit aus diesen Umständen.[332]

Die Abteilung 4b hatte sich mit demselben Sachverhalt auseinanderzusetzen. Auch sie kam zum Schluss, dass sich eine Unangemessenheit der angesetzten Lizenzgebühr nicht daraus ergebe, dass nur 5% der Poolpatente in der VRC in Kraft stünden.[333] Sie nahm dabei Bezug auf den Hinweisbeschluss des OLG Düsseldorf vom 17.11.2016, wonach Fairness und Angemessenheit fraglich sei, wenn eine

[324] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 393; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 315.

[325] Vgl. LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 428; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 350.

[326] Vgl. LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 429; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 351, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[327] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 428; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 350.

[328] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 429; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 351, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[329] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 430; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 352, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 11.9.2008 – 4b O 78/07, Rn. 102 – *Videosignal-Codierung III*.

[330] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 430; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 352.

[331] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 431; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 353.

[332] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 428¸9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 350.

[333] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 401; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 340.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gleich hohe Lizenzgebühr auch für lizenzpflichtige Handlungen in einem Land gefordert werde, in dem nur ein einziges SEP/Patent in Kraft stehe und benutzt werde.[334] Es bedürfe näherer Erläuterungen dazu, dass eine solche Klausel, etwa weil sie in frei ausgehandelten Lizenzverträgen branchenüblich sei, FRAND-gemäß sei, wobei andernfalls eine Klausel notwendig sein könnte, mit der die Höhe der Lizenzgebühr an die Anzahl benutzten Patente gekoppelt werde, die auf dem jeweiligen Vertriebsmarkt erteilt und gültig seien.[335] Dabei gehe es aber beim vor der Abteilung 4b stehenden Sachverhalt gerade nicht um die vom OLG Düsseldorf geschilderte Sondersituation, dass eine Gebühr auch für eine lizenzpflichtige Handlung in einem Land gefordert werde, in dem nur ein einziges SEP in Kraft stehe und benutzt werde, sondern es stünden im vorliegenden Sachverhalt 5% aller Poolpatente in der VRC in Kraft.[336] Hingegen sei die gegensätzliche Ansicht des Landgerichts Düsseldorf[337] heranzuziehen, dass die Zahl der in einem Land in Kraft stehenden Schutzrechte nicht überbewertet werden dürfe, weil anderseits auch bereits ein Patent ausreiche einen Interessenten von dem standarddefinierten Markt fernzuhalten.[338] Ob daneben auch weitere Schutzrechte für den lokalen Markt lizensiert werden müssten, um die standardisierte Technologie im betreffenden Vertriebsgebiet vermarkten zu können, könne für das Interesse des Lizenzsuchers, einen legalen Marktzutritt zu erlangen, dann nur eine untergeordnete Rolle spielen.[339] Diese Pauschalisierung sei ein Stück weit für den Vorteil, die standardessentielle Technik weltweit nutzen zu können, hinzunehmen, wobei der Umstand hinzutrete, dass es sich bei der VRC um die viertstärkste Nation bezogen auf den Anteil an Poolpatenten handle.[340]

2) Unangemessenheit durch kartellrechtswidrige Zusammensetzung des Pools

i) Unangemessenheit durch zwingende Kombination von verschiedenen Profilen und technische Bandbreite

Die Abteilung 4a des LG Düsseldorf behandelte die Frage, ob sich eine Unangemessenheit aus der zwingenden Kombination von verschiedenen Optionen des Standards ergebe. Die Indizwirkung widerlegende Umstände ergäben sich jedoch nicht daraus, dass Mobilfunkanbieter typischerweise lediglich eines der im Wesentlichen vier durch den Standard bereitbestellten Profile („Baseline“, „Extended“. „Main“, High“) und von diesen auch lediglich bestimmte Merkmale nutzten.[341] Die Beklagte wendete ein, aufgrund der Tatsache, dass der AVC Videostandard aus im Wesentlichen vier verschiedenen Profilen bestehe, wobei jedes Profil bestimmte Merkmale („Features“) aufweise, Hersteller von Mobilfunkgeräten jedoch im Allgemeinen lediglich einige ausgewählte Profile, und auch dann nur bestimmte Merkmale dieser Profile nutzten, seien Mobilfunkanbieter mit einer exzessiven Lizenz belastet.[342] Das LG Düsseldorf hielt zunächst fest, dass dieser Einwand grundsätzlich geeignet sein könne, eine Unangemessenheit der Lizenzgebühren darzutun, und mit Fällen vergleichbar sei, in denen nicht sämtliche Patente eines Pools genutzt würden.[343] Jedoch könnten im beurteilten Fall gegen eine unbillige Behinderung sachliche Gründe angeführt werden.[344]

---

[334] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[335] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[336] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 402–03; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 341–42.

[337] LG Düsseldorf, 11.9.2008 – 4b O 78/07, Rn. 102 – *Videosignal-Codierung III*.

[338] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 403; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 342.

[339] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 403; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 342, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 11.9.2008 – 4b O 78/07, Rn. 102 – *Videosignal-Codierung III*.

[340] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 403; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 342.

[341] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 443; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 365.

[342] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 444; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 366.

[343] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 445; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 367.

[344] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 445; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 367.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

So gehe mit der Etablierung eines Patentpools für die Nutzung eines Standards stets eine gewisse Pauschalisierung einher, wobei eine solche insbesondere bei einem Patentpool wie dem vorliegenden, von mehr als 5000 Patenten, nicht vermeidbar erscheine.[345] Jedoch verkenne die Kammer nicht, dass mit der Pauschalisierung als solcher noch keine Aussage über den Umfang der Pauschalisierung, aus dem die Unangemessenheit gerade erwachsen kann, verbunden sei.[346] Insoweit sei jedoch in dem vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass Ausgangspunkt der Lizenzgewährung die Einräumung der rechtlichen Möglichkeit des Angebots und des Vertriebs „AVC-fähiger" Produkte sei, die den Standard in seiner Gesamtheit wahrnehmen können.[347] In den dargestellten vertraglichen Regelungen finde die Erwartungshaltung des Marktes an ein AVC-fähiges Produkt Ausdruck, wobei diese insbesondere darin begründet sei, dass die technischen Nutzungsmöglichkeiten des Standards nicht primär zur Wahl des Smartphone-Herstellers stünden, sondern durch den Ersteller der Videos festgelegt würden.[348]

Zudem spreche für das zur Verfügung stellen der technischen Bandbreite vorliegend auch, dass die Klägerin vorgetragen habe, dass die angegriffenen Geräte Ausführungsformen in der Lage seien, mehr als nur ein Profil abzuspielen, wobei auch dem Beklagtenvorbringen nicht zu entnehmen sei, dass die (aktuellen) Mobilfunkgeräte technisch nicht dazu in der Lage seien diese Profile umzusetzen, woraus folge, dass das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung insoweit im Grundsatz ausgewogen sei.[349] Für eine enge Verknüpfung der unterschiedlichen Profile aus Marktsicht spreche schließlich auch, dass die Abgrenzung unterschiedlicher Produkttypen ohnehin immer weniger trennscharf sei, weil beispielsweise durch die angegriffenen Smartphones mehr und mehr Funktionen des Digital TVs oder von Videokameras übernehmen könnten und Computer-Funktionalitäten aufweisen würden.[350] Auch führe der Umstand, dass die Gebührenstruktur des Nachfolgestandards ein Differenzierung nach Profilnutzungen vorsehe nicht ohne weiteres zu der Annahme, dass ein Vertragskonstrukt, bei dem es an einer solchen Differenzierung fehle, FRAND-widrig sei.[351]

Auch die Kammer 4b hatte im Parallelverfahren den Einwand der Beklagten zu beurteilen, der Standardlizenzvertrag differenziere nicht zwischen den verschiedenen Profilen und Merkmalen des AVC-Standards und sei daher nicht FRAND, mit dem gleichen Ergebnis. Die Beklagte argumentierte aber vorwiegend mit einem Gleichbehandlungsargument. Sie war insofern der Auffassung, der AVC-Standard begründe quasi Substandards, die sämtliche in einer Poollizenz gebündelt seien, wodurch der hinsichtlich der Lizenzhöhe nicht zwischen verschiedenen Profilen differenzierende Standardlizenzvertrag Unternehmen mit Geräten, die von sämtlichen Profilen Gebrauch machten gegenüber Anbietern von mobilen Endgeräten profitieren lasse.[352] Dem vermochte die Düsseldorfer Kammer nicht zu folgen. Die mit dem Standardlizenzvertrag vorgenommene einheitliche Lizensierung von den AVC-Standard betreffenden Schutzrechten ohne Differenzierung zwischen den einzelnen Profilen und deren Merkmalen stelle eine zulässige Pauschalisierung dar, die im Streitfall nicht zur Unangemessenheit der Lizenz oder Diskriminierung der Beklagten gegenüber anderen Lizenznehmern führe.[353] Bei der einheitlichen Lizenzierung handle es sich um eine zulässige Pauschalisierung der Lizenzbedingungen und -sätze, weil die Differenzierung im Hinblick auf jedes einzelne Profil mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden wäre, was erst recht für die einzelnen Merkmale der Profile

[345] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 446; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 368; beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 11.9.2008 – 4b O 78/07, Rn. 101 – *Videosignal-Codierung III*.

[346] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 446; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 368.

[347] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 447; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 369.

[348] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 452; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 374.

[349] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 453; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 375.

[350] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 453; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 375.

[351] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 455; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 377.

[352] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 392; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 331.

[353] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 393; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 332.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gelte.[354] Es müsste für jeden Gerätetyp nachgehalten werden, welche Profile und Merkmale unterstützt wird, und Software-Updates, die mit einer Änderung der Profil-Kompatibilität einhergingen, wären für einen Lizenzgeber ohnehin nicht nachvollziehbar.[355] Soweit daher Lizenznehmer verschiedene Typen mobiler Endgeräte in ihrem Produktportfolio hätten, die die unterschiedlichen Profile zur Verfügung stellen, sei die vom Standardlizenzvertrag vorgenommene Vereinheitlichung hinzunehmen, zumal sie die Möglichkeit biete, mit der Entwicklung neuer mobiler Endgeräte mit noch höherer Leistung auch im unteren Segment Profile wie „Main" und „High" zu verwenden, ohne einen neuen Lizenzvertrag abschließen zu müssen.[356] Letztlich biete der Standardlizenzvertrag eine einheitliche Lizenz für die im Markt übliche Nutzung des AVC-Standards: Während die Nutzung anfangs aufgrund beschränkter Rechenleistung der Geräte überwiegend auf die Verwendung der einfachen Profile beschränkte, ergab sich durch Geräte mit höherer Rechenleistung die Möglichkeit der Benutzung anderer Profile.[357] Es könne aber nicht davon ausgegangen werden, dass mit Fortschreiten der Technologie zwingend höhere Lizenzsätze verbunden seien, selbst wenn die verschiedenen technologischen Möglichkeiten in einem Standard festgelegt seien.[358] So sei bezüglich die geltend gemachte mangelnde Differenzierung davon auszugehen, dass beispielsweise gerade weil sich die Profile jenseits von „High-10" an professionelle Anwender richten, sie im hier relevanten Markt allenfalls in so kleinem Umfang genutzt würden, dass sich eine Differenzierung in dieser Hinsicht aus den oben genannten Gründen als unangemessen erweise.[359] Auch könne nicht von einer Diskriminierung gegenüber den Anbietern anderer Produkte wie Kameras, Fernsehern oder dergleichen gesprochen werden, da sie schon nicht den in diesem Fall relevanten Markt der mobilen Endgeräte betrafen, und ihre Lizensierung mit den grundlegen Profilen nicht ins Gewicht falle und eine Pauschalisierung so gerechtfertigt sei.[360]

ii) Unangemessenheit durch zwingende Kombination von standardessenziellen und nicht-standardessenzielle Patenten

Weiter setzte sich die Abteilung 4a des LG Düsseldorf betreffend den AVC Videostandard mit dem Argument auseinander, der Patentpool sei kartellrechtswidrig zusammengesetzt, weil dieser standardessentielle und nicht-standardessentielle Patente enthalte.[361] So entschied das Landgericht zwar könne grundsätzlich mit einer derartigen Zusammensetzung eine unangemessene Behandlung des Lizenzsuchers einhergehen.[362] Ein Ausbeutungstatbestand werde regelmäßig dann zu bejahen sein, wenn in einen Pool planmäßig für die Einhaltung des Standards nicht notwenige Schutzrechte Eingang in den Lizenzvertrag fänden, so dass der Zweck erkennbar werde, die Lizenzgebühren durch die Aufnahme möglichst vieler Patente ungerechtfertigt zu steigern.[363] Im vorliegenden Fall ließe sich dies dem Beklagtenvorbringen nicht hinreichend entnehmen,[364] das aufgrund einer stichprobenartigen Essenzialitätsanalyse eines Beratungsunternehmens geltend machte, ein Teil der

[354] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 394; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 333.

[355] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 394; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 333.

[356] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 394; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 333.

[357] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 395; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 334.

[358] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 395; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 334.

[359] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 396; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 335.

[360] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 397; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 336.

[361] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 457; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 379.

[362] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 458; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 380, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 132 – *Videosignal-Codierung I*.

[363] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 458; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 380, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 130, 132 – *Videosignal-Codierung I.*

[364] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 459; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 381.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

eingebrachten Patente sei nicht standardwesentlich,[365] ohne eine eigentliche Begründung dieses Ergebnisses in Bezug auf bestimmte Poolpatente zu enthalten.[366]

Weiter berechtige auch die Tatsache, dass die auf den der Kammer 4a vorliegenden Fall anwendbaren ISO/ITU/IEC Regeln – anders als bei dem ETSI – keine Vorkehrungen dafür vorsahen, um das „Aufblähen" des SEP Portfolios anhand tatsächlich nicht essenzieller Patente zu verhindern enthalten nicht zu der Annahme, der streitgegenständige Pool enthalte nicht-essenzielle Patente. So erfolge unabhängig von den Regularien der jeweiligen Organisation auch eine Prüfung durch unabhängige Sachverständige, was nach Randziffer 248 der Leitlinien[367] bei der Einordnung eines Pools als wettbewerbsbeschränkend bzw. -fördernd zu berücksichtigen sei.[368] Vor diesem Hintergrund spielten die Regularien bei der Standardisierungsorganisation keine erhebliche Rolle.[369]

Außerdem könne der Beklagten als Verletzer der abgemahnte Kartellrechtsverstoß nur dann zugutekommen, wenn sie von denjenigen Lizenzschutzrechten, die durch den Standard nicht geschützt werden, keinen Gebrauch mache.[370] Zu einem rechtserheblichen Verteidigungsvorbringen gehöre deshalb nicht nur die Behauptung, bestimmte (konkret zu bezeichnende) Lizenzvertragsschutzrechte lägen außerhalb des Standards, sondern auch, dass von keinem dieser Rechte Gebrauch gemacht werde.[371].

Dennoch befasste sich die Kammer 4a weiter mit der Frage, ob der Poolinhaber wiederholt und systematisch schutzunfähige Patente in diesen aufgenommen hatte.[372] Ein Patentanteil von zufolge einer von der Beklagten in Auftrag gegebenen Analyse ca. 12% im Verhältnis zur Patentmenge des gesamten Pools könne nicht ohne weiteres zur Annahme eines planmäßigen Einlagerns von nicht-standardwesentlichen Patenten führen.[373] Vielmehr bemängelte das Landgericht, dass sich keine weiteren Umstände, die die von der Beklagten dargestellten Lebenssachverhalte als Teil eines missbräuchlichen systematischen Vorgehens erscheinen ließen, aus einer Gesamtschau des Beklagtenvorbringens ergäben.[374] Zudem stünde gegen eine Wertung der vorgetragenen Konstellation als systematisches Vorgehen in diesem Zusammenhang auch, dass die Lizenzgebühr mit Erhöhung der Poolpatente nicht angestiegen sei, und der Lizenzverwalterin ein Erhöhung aufgrund der Erweiterung des Patentpools aufgrund der vertraglichen Regelung im Standardlizenzvertrag auch nicht möglich sei.[375]

Die Kammer 4b hielt diesbezüglich fest, der geltend gemachte Kartellverstoß reüssiere ohnehin nicht, weil die Zahlen der Essenzialitätsanalyse gerade nicht belegten, dass insgesamt erheblich mehr nichtessenzielle Patente Bestandteil des Patentpools seien als SEPs. Denn selbst nach ihrer Untersuchung befänden sich insgesamt 51% SEPs im streitgegenständlichen Pool, wobei zu guter Letzt

[365] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 461–62; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 383–84; zur Essenzialitätsanalyse vgl. auch unten S. 13.

[366] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 463; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 385.

[367] COM, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen, 28.3.2014 (2014/C 89/03).

[368] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 465; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 387; vgl. auch LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 127 – *Videosignal-Codierung I*.

[369] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, 338; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 277.

[370] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 466; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 388; mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 136 – *Videosignal-Codierung I.*

[371] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 466; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 388.

[372] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 467; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 389.

[373] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 468; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 390.

[374] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 471; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 393.

[375] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 471; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 393.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

auch der Einwand bleibe, dass das Ergebnis auf einer Stichprobe fuße und eben gerade nicht alle Poolpatente untersucht worden seien.[376]

Weiter fügte die Kammer an, es trete hinzu, dass jedes Pool-Mitglied sich bei Eintritt in den Patentpool verpflichtet habe, alle SEPs einzubringen.[377] Sofern ein Mitglied SEPs außerhalb des Patentpool halte und einen Lizenznehmer des Patentpools damit in Anspruch nehme, könne der Lizenznehmer auch diesem (non-pool-)SEP die Standardlizenz am Patentpool entgegenhalten.[378] Die Standardlizenz entfalte dann sozusagen eine Drittwirkung gegenüber dem außerhalb des Patentpools gehaltenem SEP, was ebenfalls gegen einen systematischen Missbrauch spreche.[379]

iii) Gesamtbelastung: Unangemessenheit durch die Erforderlichkeit zusätzlicher Lizenzen von weiteren Patentinhabern neben den streitgegenständlichen Schutzrechten

Gemäß der Kammer 4a des Landgerichts Düsseldorf ergebe sich eine kartellrechtswidrige Zusammensetzung des Pools schließlich auch nicht dadurch, dass die Gesamtlizenzbelastung AVC-fähiger Produkte unangemessen hoch sei, weil neben den in den streitgegenständlichen Pool eingelagerten Schutzrechten Lizenzen von weiteren, außerhalb des Pools stehenden Patentinhabern bezogen werden müssten.[380] So führe der Umstand, dass es auch weitere – ggf. für den streitgegenständlichen Standard essentielle – Patente außerhalb des Pools gebe, nicht zu der zwingenden Annahme eines Ausbeutungstatbestands.[381] Denn auch eine Poollizenz, die nicht alle standardwesentlichen Patente erfasse, bringe den Vorteil mit sich, dass der Lizenzsucher nicht mit jedem einzelnen Patentinhaber eine individualvertragliche Regelung abschließen müsse.[382] Die Grenze zur Wettbewerbsbeschränkung sei erst dann erreicht, wenn das die Standardfunktionen nutzende Produkt in der Gesamtheit der abzuführenden Gebühren tatsächlich derart belastet sei, dass eine gewinnbringende Vermarktungsmöglichkeit nicht mehr bestehe.[383] Eine bloß theoretische Kumulierung führe hingegen noch nicht zur Unangemessenheit der Lizenzgebühr.[384]

Dem fügte die Kammer 4b an, der Umstand, dass es vereinzelte Unternehmen gebe, die weder Poolmitglieder seien noch Lizenznehmer des Patentpools und gegebenenfalls dennoch AVC-standardessenzielle Patente hielten, spreche für sich nicht gegen den FRAND-Charakter des Standardlizenzvertrages.[385]

2. Diskriminierungsfreiheit

Im einem der Verfahren zum AVC Videostandard vor der Kammer 4a des Düsseldorfer Landgerichts machte die Beklagte geltend, es liege eine missbräuchliche Ungleichbehandlung vor durch die Lizenznahme von Poolpatentinhabern selbst, beziehungsweise deren interne Ausgleichszahlungen durch ein Membership Agreement. Desbezüglich hatte die Klägerin substantiiert vorgetragen, dass mit Poolpatentinhabern derselbe Standardlizenzvertrag wie mit den nicht am Pool beteiligten

[376] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 339; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 278.

[377] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 340; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 279.

[378] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 340; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 279.

[379] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 340; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 279.

[380] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 473; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 395.

[381] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 474; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 396.

[382] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 474; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 396.

[383] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 474; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 396.

[384] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 474; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 396, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 50.

[385] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 407; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 346.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenznehmern abgeschlossen werde.[386] Jedoch sei auch ein Membership Agreement mit internen Regelungen zwischen den Poolmitgliedern abgeschlossen worden, was die Beklagte als Anknüpfungspunkt dafür vermutete, dass etwaige von den Poolmitgliedern zu erbringende Lizenzzahlungen durch eine interne Verteilung der Lizenzgebühren kompensiert werde, jedoch ohne diese Behauptungen zu substantiieren.[387] Das LG Düsseldorf hielt diesbezüglich fest, dass aus der Tatsache der Verteilung der Lizenzgebühren allein noch kein eine kartellrechtswidrige Ungleichbehandlung begründendes Verhalten folge.[388] Vielmehr werde den jeweiligen Poolpatentinhabern damit im Grundsatz ein Ausgleich als Gegenleistung für die von ihnen erbrachte Leistung, die Patente in den Pool einzubringen, gewährt.[389] Dafür, dass die Verteilung der Lizenzen nach einem Schlüssel, in dem die unterschiedliche Beteiligung an dem Pool zum Ausdruck komme, und damit ohne eine Überkompensation der gezahlten Lizenzgebühren nicht erfolge, spreche schon, dass jeder an dem Patentpool beteiligte Patentinhaber ein erhebliches Eigeninteresse an einer Verteilung entsprechend seiner Beteiligung am Pool habe.[390] So sei vor dem Hintergrund des Gesagten die Klägerin nicht gehalten, die Membership Agreements vorzulegen.[391]

3. Darlegungs- und Beweislast bei Poollizenzen

Weiter setzte sich das Landgericht Düsseldorf in den Verfahren zum AVC Videostandard mit den Besonderheiten für Poollizenzen bei der Darlegungs- und Beweislast auseinander. Erforderlich sei zur Feststellung eines fairen und angemessenen Lizenzangebots für einen Pool zunächst substantiierter Sachvortrag zu Benutzung der Patente aus dem Pool.[392] Insoweit sei jedoch kein an § 286 ZPO gemessener Überzeugungsgrad, der eine persönliche Gewissheit, die Zweifeln Schweigen gebiete, ohne sie völlig auszuschließen, verlange.[393] Stattdessen sei § 287 Abs. 2 ZPO anwendbar, der – in Herabsetzung des Beweismaßes des § 286 ZPO – eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichen lasse.[394] Ein entsprechender Sachvortrag geschehe grundsätzlich über die Vorlage von Claim Charts für ausgewählte Portfolio-Patente (sog. «proud list»), die die konkret einschlägigen Passagen des maßgeblichen Standards den jeweiligen SEPs zuordne,[395] sofern diese branchenüblich sei.[396]Dabei hat die Kammer 4a das Zugänglichmachen sog. Cross Reference Charts mit Bezug auf einschlägige Standardabschnitte, denen die Poolpatente zuzuordnen sind, über die Website der Lizenzverwalterin als ausreichend beurteilt um erkennbar zu machen, woraus sich die Standardessenzialität der Poolpatente ergeben soll.[397] Demgegenüber urteilte die Kammer 4b, es könne dahinstehen, ob man die im Internet einsichtsfähigen Cross Reference Charts bereits als Claim-Charts ansehen mochte, da sie die konkret einschlägigen AVC-Standard-Passagen sämtlichen Pool-Patenten zuordnen, wie die von der Kammer 4a gehalten.[398] Es erscheine in mehrfacher Hinsicht lebensfern, dass die mit IP-Fragen

[386] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 488; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 410.

[387] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 488; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 410.

[388] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 489; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 411.

[389] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 489; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 411.

[390] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 489; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 410.

[391] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 491; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 413.

[392] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 334; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 273, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.

[393] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 433; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 355.

[394] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 433; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 355, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.

[395] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 434; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 356, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 27.

[396] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 334; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 273, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.

[397] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 460; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 382.

[398] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 334; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 273.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

befasste Abteilung im Konzern der Beklagten nicht in der Lage gewesen sein solle, die Frage der Standardessenzialität zu prüfen.[399] So verfüge der Konzern der Beklagten zum einen unstreitig über eine der größten Patentabteilungen in der Volksrepublik China, zum anderen erscheine es wenig plausibel, dass die Beklagte mit der dem Klagepatent zugrundeliegenden AVC-Technik nicht vertraut sein solle, wenn eben jene Technik in ihren Produkten Anwendung finde, wie der zugrundeliegende Fall zeige.[400] Schließlich erkläre sich auch nicht, dass die Muttergesellschaft der Beklagten erst nach über fünf Jahren der Verhandlung erstmalig Claim Charts anfragte, und offensichtlich tausende andere Lizenznehmer sich in der Lage sahen, anhand der Cross Reference Charts die Standardessenzialität zu prüfen.[401] Auffällig sei ebenfalls, dass die Frage der Überdeklarierung in den vorgerichtlichen Verhandlungen überhaupt kein Thema gewesen sei.[402]

Weiter sei es an der Lizenzbenutzerin substantiiert darzulegen, dass besondere Umstände, die das Angebot einer Poollizenz als wettbewerbsbeschränkend erscheinen ließen vorlägen, wenn es grundsätzlich durch die Vorlage der bereits abgeschlossenen Standardlizenzverträge als angemessen und branchenüblich erscheine die Lizenzen nicht beschränkt auf das Portfolio einzelner Patentinhaber sondern durch den gesamten Pool zu vergeben.[403]

Betreffend Essenzialitätsanalysen äußerte sich die Kammer 4b eher kritisch. Die Beklagte legte im betreffenden Fall eine Essenzialitätsanalyse eines IP Beratungsunternehmens nebst dazugehöriger Erläuterung vor, wonach gewisse Poolpatente der Klägerin nicht standardessentiell sein sollten.[404] Dabei handle es sich um das Ergebnis einer stichprobenartigen Untersuchung, wobei nicht zu entnehmen sei, welche Pool-Patente konkret untersucht worden seien und welche Defizite genau im Hinblick auf den Standard vorlägen, und zudem sei die Auswahl der Patente nicht nachvollziehbar.[405] Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen würde, dass die Untersuchung repräsentativ sei und unzweifelhaft eine realistische Verteilung darlege, könne sich im Hinblick auf die eingebrachten Pool-Patente der Klägerin die Verteilung nur auf die Höhe der angebotenen Lizenz auswirken.[406] Deren Branchenakzeptanz und Angemessenheit sei jedoch als solche von der Beklagten bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht bestritten worden.[407] Doch auch dann bliebe jedenfalls die Frage offen, ob die Freiheit, pauschal mehrere tausend Patente rechtmäßig zu nutzen und sich im Rahmen der „one-stop-shop“ Lösung frei innerhalb des AVC-Standards bewegen zu können, eine Monetarisierung in gewisser Höhe rechtfertige, auch wenn ein Risiko bestehe, dass sich unter diesen Patenten nichtessentielle Patente befänden.[408]

[399] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 334; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 273.

[400] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 334; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 273.

[401] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 334; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 273.

[402] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 334; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 273.

[403] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 298; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 286; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 309; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 291.

[404] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 337; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 276.

[405] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 337; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 276.

[406] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 337; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 276.

[407] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 337; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 276.

[408] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 337; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 276.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

VII. Übertragung des SEP

A. Übergang der FRAND-Obliegenheiten auf den Erwerber

Verschiedentlich mussten sich die deutschen Gerichte damit auseinandersetzen, inwiefern die Pflichten aus der FRAND-Erklärung auf einen Erwerber des SEP-Portfolios übergehen.

Das OLG Düsseldorf hielt im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 grundsätzlich fest, der SEP-Erwerber sei jedenfalls im Wege des Sukzessionsschutzes an Lizenzvereinbarungen, die der vorhergehende SEP-Inhaber mit Lizenznehmern getroffen habe, gebunden, mithin erstrecke sich der Inhalt der Darlegungspflicht des SEP-Erwerbers zur FRAND-Gemäßheit (siehe dazu allgemein XI.B.1.c)2)iv) unten) auch auf den Inhalt der vorgehenden Lizenzvereinbarungen.[409] Der für die Wahrung der FRAND-Kriterien jedenfalls sekundär darlegungsbelastete SEP-Erwerber könne sich im Prozess insoweit grundsätzlich nicht mit Erfolg darauf berufen, einem konkreten Sachvortrag zum Inhalt anderer Lizenzvereinbarungen (oder der Vorlage der Lizenzvereinbarung) stünden Geheimhaltungsinteressen Dritter entgegen und/oder er habe sich gegenüber Lizenznehmern zur Geheimhaltung verpflichtet.[410]

Auch das LG Mannheim setzte sich im Urteil vom 28.9.2018 mit einem Sachverhalt auseinander, in dem das Patentportfolio von der ursprünglichen Patentinhaberin, die die FRAND-Erklärung abgegeben hatte, auf die Klägerin übertragen wurde.[411] Das LG verwies zunächst auf die Clause 6.1 der ETSI Policy, die lautet „FRAND licensing undertakings […] shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest“ und dass „[t]he undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents”.[412] Aus der Regelung ergebe sich eine Vermutung für eine Bindung des Erwerbers des Patents.[413] Da die Klägerin selbst davon ausgehe, dass sie die FRAND-Obliegenheiten zu erfüllen habe, bedürfe es keines weiteren Vortrags der Beklagten.[414]

Doch auch wenn die Klägerin eine entsprechende Verpflichtung nicht übernommen haben würde, ergäben sich aus der FRAND-Selbstverpflichtung ihrer Rechtsvorgängerin kartellrechtliche Verhaltenspflichten, denn die FRAND-Selbstverpflichtung solle sicherstellen, dass die für eine Standardisierungsnorm wesentliche patentierte Technologie deren Anwendern zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen zugänglich sei.[415] Dabei verwies das LG auf die Horizontalleitlinien, nach denen eine Normenorganisation der Einhaltung von Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB bereits dadurch genüge, dass sie FRAND-Erklärungen der Patentinhaber einhole und diese verpflichte, dass Unternehmen, an die die Rechte des geistigen Eigentums übertragen werden, an diese Verpflichtung gebunden würden.[416] Vor diesem Hintergrund missbrauche der Rechtsnachfolger des SEP-Inhabers seine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich in Kenntnis der FRAND-Selbstverpflichtung seines Rechtsvorgängers weigere, die sich daraus ergebenden Pflichten und Obliegenheiten zu erfüllen, denn die Geltendmachung des SEP – eines Sperrpatents – führe in diesem

[409] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 24.

[410] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 25, mit dem weiteren Hinweis, dass gegenüber nicht am Prozess Beteiligten die Wahrung etwaiger Geschäftsgeheimnisse mittels der nach GVG möglichen Schutzanordnungen erfolgen könne; siehe dazu unten XI.B.1.c)3)iii).

[411] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 108.

[412] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 110.

[413] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 111.

[414] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 111.

[415] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 112.

[416] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 112, mit Verweis auf COM, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 14.1.2011 (2011/C 11/01), Rn. 285, 288.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Fall zu einer von der Rechtsordnung nicht hinzunehmenden Wettbewerbsbeschränkung.[417] Ein Missbrauch im Sinne des § 19 Abs. 1 GWB sei deshalb zu bejahen, weil das Vorgehen des SEP-Inhabers sich in diesem Fall im Lichte der Wertungen des Kartellrechts als nicht mehr Interessengerecht darstelle.[418] Der Patenterwerber wolle die Vorteile der Standardisierung für sich in Anspruch nehmen, ohne dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Aufnahme der patentierten Technologie in den Standard ohne die Selbstverpflichtung seines Rechtsvorgängers aus Gründen des Kartellrechts nicht möglich gewesen wäre.[419]

Auch das OLG Düsseldorf wertete die mehrfache Übertragung eines SEP-Portfolios ohne explizite vertragliche Regelung des Übergangs der FRAND-Erklärung unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten als unbedenklich, und die solche verstoße weder gegen Art. 102 AEUV noch gegen Art. 101 AEUV.[420]

So gehe der Einwand, die mehrfache Übertragung des Klagepatents sei jeweils ohne gleichzeitige Weitergabe der Verpflichtungen aus der FRAND-Erklärung geschehen, was zur Nichtigkeit der Übertragungsakte wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung führe, schon im rechtlichen Ansatz ins Leere, weil der SEP-Erwerber – auch ohne ausdrückliche oder konkludente Erklärung – unmittelbar und unabdingbar an die FRAND-Zusage seines Rechtsvorgängers gebunden sei.[421] Es liege in der Natur der Sache, dass die Standardsetzung technologischen Wettbewerb unterbinde, weil jede konkurrierende technische Lösung, die nicht in den Standard aufgenommen werde, im Wettbewerb auf dem Produktmarkt mangels Kompatibilität chancenlos sei.[422] Die freiwillige Bereitschaft aller durch die Standardsetzung privilegierten SEP-Inhaber, Konkurrenz dadurch zu ermöglichen, dass jedem, an der standardessentiellen Technik Interessierten eine Benutzungserlaubnis zu FRAND-Bedingungen eingeräumt werde, stelle von daher eine tragende Säule der technischen Standardsetzung und ihrer rechtlichen Zulässigkeit dar, denn sie kompensiere den unvermeidlichen Ausschluss von Wettbewerb auf der Technologieebene, indem freier Wettbewerb innerhalb des technischen Standards und bei seiner geschäftlichen Verwertung eröffnet werde.[423] Die FRAND-Erklärung schaffe weiterhin bei den Nachfragern der mit dem Standard vereinheitlichten Technologie ein berechtigtes Vertrauen darauf, dass die standardessentiellen Patente künftig – entsprechend der mit der FRAND-Erklärung gegebenen Zusage – freiwillig zu FRAND-Bedingungen lizenziert würden.[424] Aus Sicht des SEP limitiere die Lizenzierungszusage damit die von Hause aus umfassenden Monopol- und Verbietungsrechte des Patentinhabers, indem ihm fortan kein gegen jedermann wirkendes und bedingungslos durchsetzbares Ausschließlichkeitsrecht mehr zustehe, sondern dessen Befugnisse als Folge der FRAND-Erklärung dadurch begrenzt seien, dass er auf Anfordern jedermann eine Benutzung seines SEP und damit eine gleichbleibende Teilhabe am Standard zu FRAND-Bedingungen gestatten müsse.[425] Diesem Zugeständnis komme ganz erhebliche Bedeutung zu, weil es zu den prägenden Kennzeichen der mit einem Patent verbundenen Monopolrechte gehöre, dass der Schutzrechtsinhaber nach seiner freien Entscheidung von einer Lizenzerteilung absehen und somit jeden Dritten kategorisch von einer Benutzung seines Patents ausschließen könne.[426] Die Freiheit zur Nichtlizenzierung, die eine wesentliche Folge der gesetzlichen Ausschließlichkeitsbefugnisse aus dem Patent sei, opfere der SEP-Inhaber um der Aufnahme der

[417] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 112.

[418] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 112.

[419] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 112.

[420] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 165 – *Improving Handovers*.

[421] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 166 – *Improving Handovers.*

[422] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 167 – *Improving Handovers.*

[423] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 167 – *Improving Handovers.*

[424] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 167 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE.*

[425] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 167 – *Improving Handovers.*

[426] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 167 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

technischen Lehre seines Patents in den technischen Standard willen.[427] Weil die FRAND-Zusage die Rechte aus dem Patent in der geschilderten Weise – unwiderruflich und gleichsam dinglich – beschränke und definiere, könne das Patent notwendigerweise nur noch in eben dieser beschränkten, durch die FRAND-Zusage inhaltlich modifizierten Form auf den Erwerber übergehen, denn niemand könne durch ein Übertragungsgeschäft mehr Rechte erwerben als seinem Vorgänger selbst im Zeitpunkt der Veräußerung zugestanden hätten.[428]

Dem entgegenstehende rechtliche Bedenken ergäben sich in diesem Zusammenhang auch nicht daraus, dass es außerhalb der Rechtsmacht des Schutzrechtsinhabers liege, das ihm durch einen staatlichen Verleihungsakt zugewiesene Monopolrecht durch seine Lizenzierungszusage substanziell zu verändern.[429] Denn selbst wenn dem so sein sollte, habe er in jedem Fall die rechtliche Macht, von einer bestimmten Ausübung seiner Ausschließlichkeitsbefugnisse abzusehen, indem er von seinem Recht zur Nichtlizenzierung der Erfindung keinen Gebrauch mache.[430]

Auch von der Rechtsfolgenseite sei allein ein solches Ergebnis, dass die FRAND-Verpflichtung mit dem Patenterwerbt selbsttätig übergehe, nach Ansicht des OLG angebracht.[431] Gänzlich unangemessene Folgen hätte demgegenüber die mögliche alternative rechtliche Lösung, eine Patentübertragung, in deren Rahmen die FRAND-Zusage des Veräußerers nicht schuldrechtlich an den Erwerber weitergegeben worden sei, als kartellrechtswidrig nach Art. 102 AEUV zu beurteilen, womit die Patentübertragung als Ganzes unwirksam wäre.[432] Fundamentaler Inhalt der Eigentumsgarantie des Patentinhabers sei seine Befugnis, das ihm erteilte Schutzrecht nach seinem Belieben zu veräußern, wobei grundrechtlichen Schutz nicht nur die Übertragbarkeit des Schutzrechts als solche genieße, sondern genauso die Person des Erwerbers, der vom Veräußerer frei gewählt werden könne.[433] Die aus der Standardsetzung resultierende Sondersituation verlange und rechtfertige insoweit keinerlei Beschränkungen, weil sich die mit dem SEP verbundenen Rechte nicht durch die Person seines Inhabers änderten, sondern davon völlig unabhängig seien.[434] Sie bestimmten sich wesentlich nach dem Inhalt des Schutzrechts, und weiterhin sei wesentlich, dass mit der Patentübertragung die Bindungen bzw. Beschränkungen des ursprünglichen Patentinhabers aus seiner FRAND-Erklärung nicht verloren gingen, sondern den Erwerber in gleicher Weise verpflichteten wie seine Rechtsvorgänger.[435] Wenn dies als Folge des automatischen Übergangs der FRAND-Verpflichtung mit dem übertragenen Patent, für das die FRAND-Erklärung abgegeben wurde, gewährleistet sei, gebe es keinen Grund, so das OLG Düsseldorf, eine Patentübertragung zu unterbinden oder zu limitieren, denn das Ziel, welches mit der FRAND-Zusage erreicht werden solle, verwirkliche sich ohne weiteres mit dem selbsttätigen Übergang der FRAND-Verpflichtung auf den Patenterwerber.[436] Für eine derart weitreichende Konsequenz wie die Unwirksamkeit der Patentübertragung durch Kartellrechtsverstoß bestehe indessen kein Anlass, weil nicht die Übertragbarkeit und/oder die Übertragung eines SEP in irgendeiner Weise problematisch sein könne, sondern Vorsorge allein dafür getroffen werden müsse, dass infolge der Schutzrechtsübertragung die aus Gründen des Kartellrechts (Art. 101 AEUV) dauerhaft gebotene FRAND-Bindung bei der Durchsetzung des SEP aufrechterhalten bleibe.[437] Diesem Ziel sei durch den

[427] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 167 – *Improving Handovers.*
[428] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 167 – *Improving Handovers.*
[429] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 168 – *Improving Handovers.*
[430] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 168 – *Improving Handovers.*
[431] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 169 – *Improving Handovers.*
[432] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 170 – *Improving Handovers.*
[433] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 169 – *Improving Handovers.*
[434] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 169 – *Improving Handovers.*
[435] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 169 – *Improving Handovers.*
[436] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 169 – *Improving Handovers.*
[437] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 170 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

selbstständigen und unabdingbaren Übergang der FRAND-Zusage gemeinsam mit dem SEP vollauf Genüge getan.[438]

Gegen eine schuldrechtliche Weitergabe der FRAND-Verpflichtung wären im Übrigen selbst dann Einwände zu erheben, wenn sie pflichtgemäß zwischen Verkäufer und Erwerber vereinbart worden wäre, denn es bedürfte besonderer rechtlicher Konstruktionen wie der Rechtsfigur eines drittbegünstigenden Vertrages (die möglicherweise nicht in allen Mitgliedstaaten zur Verfügung ständen und deren Tragfähigkeit sich im Vorhinein auch kaum zuverlässig abschätzen ließen), um sicherzustellen, dass sich der an dem Übertragungsgeschäft überhaupt nicht beteiligte Lizenzsucher erfolgreich auf die nur dem Veräußerer gegenüber abgegebene Zusage des Erwerbers berufen könne.[439] Begreife man hingegen die FRAND-Zusage als inhaltliche Selbstbeschränkung der Ausschließlichkeits(ausübungs)rechte aus dem SEP, tauchten dergleichen Anwendungsschwierigkeiten nicht auf und es bestehe für alle Seiten die erforderliche Rechtsklarheit.[440]

Inhaltlich bestehe die Bindung des Patenterwerbers an die FRAND-Zusage seines Rechtsvorgängers nicht nur „dem Grunde nach", d.h. insoweit, als es um die Pflicht zur Vergabe einer FRAND-Lizenz überhaupt gehe, sondern darüber hinaus auch „der Höhe und dem Inhalt nach", nämlich insoweit, als der Erwerber im Rahmen seiner Verpflichtung zur fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Lizenzierung an diejenige Lizenzierungspraxis gebunden sei, die auf seinen Rechtsvorgänger zurückgehe.[441] Denn in der Lizenzierungspraxis konkretisiere sich die FRAND-bedingte Beschränkung der Ausschließlichkeitsrechte aus dem SEP, die demzufolge im Anschluss an eine Patentübertragung auch von dem Erwerber zu betrachten seien.[442] Dass dies so sein müsse, folge schon aus der Tatsache, dass die im Zeitpunkt des Patenterwerbs bestehenden Lizenzverhältnisse durch die Patentübertragung nicht fortfielen oder sonst wie beeinträchtigt würden, sondern in demselben Umfang und mit demselben Inhalt bestehen blieben und gegenüber dem Erwerber fortwirkten (§ 15 Abs. 3 PatG), der dem Lizenznehmer folglich eine Benutzung der Erfindung nicht untersagen könne.[443] Selbst wenn der Erwerber – was von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein möchte – mit dem Patenterwerb nicht automatisch anstelle des Veräußerers als Vertragspartei in die beim Inhaberwechsel bestehenden Lizenzverträge eintreten sollte, sondern es dazu eines besonderen dreiseitigen Rechtsgeschäfts unter Beteiligung des Veräußerers, des Erwerbers und des Lizenznehmers bedürfte, blieben die Nutzungskonditionen für die Bestands-Lizenznehmer dennoch dieselben, da sich an der Pflichtenlage nicht ändere und die vertraglichen Ansprüche (z.B. auf Rechnungslegung und Lizenzvergütung) regelmäßig auch dem SEP-Erwerber zuständen, weil in der Patentübertragung im Zweifel eine konkludente Abtretung der besagten Lizenzvertragsansprüche an ihn zu sehen sei.[444] Unabhängig von der genauen dogmatischen Rechtskonstruktion, die unterschiedlich sein möge, bleibe daher in jedem Fall festzuhalten, dass die Übertragung eines bereits lizenzierten SEP mit FRAND-Erklärung bestehende Lizenzverhältnisse nicht beseitige.[445] Die Nutzungsrechte für den Lizenznehmer blieben genauso unverändert erhalten wie seine lizenzvertraglichen Pflichten insbesondere zur Lizenzzahlung dieselben blieben.[446] Rein wirtschaftlich betrachtet lasse sich deshalb die Feststellung treffen, dass die vom Veräußerer erteilten Lizenzen auf den Erwerber übergingen, so dass die bisherigen Lizenznehmer des Veräußerers fortan eigene Lizenznehmer des SEP-Erwerbers seien und

[438] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 170 – *Improving Handovers.*
[439] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 170 – *Improving Handovers.*
[440] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 170 – *Improving Handovers.*
[441] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 171 – *Improving Handovers.*
[442] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 171 – *Improving Handovers.*
[443] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 171 – *Improving Handovers.*
[444] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 171 – *Improving Handovers.*
[445] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 171 – *Improving Handovers.*
[446] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 171 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

infolgedessen notwendigerweise auch denjenigen Lizenzierungsrahmen absteckten, demgegenüber eine Diskriminierung verboten sei. Bei jeder von ihm vergebenen Lizenz habe der Erwerber daher nicht nur diejenigen Lizenznehmer im Blick zu behalten, denen er während seiner Inhaberschaft selbst eine Nutzungsbefugnis eingeräumt habe, sondern er habe gleichermaßen solche Lizenznehmerverhältnisse zu berücksichtigen, die als Folge des Patenterwerbs von seinem Rechtsvorgänger auf ihn übergegangen seien.[447] Somit müsse der SEP-Erwerber die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers im Rahmen des Diskriminierungsverbots gegen sich gelten lassen.[448]

Dementsprechend schulde der Erwerber auch im Rahmen der Pflicht zur nachvollziehbaren Darlegung Vortrag zur bisherigen Lizenzierungspraxis des Veräußerers insofern, dass das Lizenzangebot den Lizenzsucher entweder gleich oder weshalb es ihn in welcher Hinsicht ungleich behandle, und im Rahmen der Pflicht zur verständlichen und inhaltlich ausreichend fundierten Begründung dazu, wieso die mit der Erstlizenz in Ansatz gebrachte Lizenzvergütung ihrer Höhe nach FRAND, nämlich zumutbar („fair, reasonable“) sei.[449] Soweit es um Lizenzerteilungen durch Rechtsvorgänger des Klägers gehe, bestehe eine eben solche Mitteilungspflicht im Hinblick auf deren Lizenzierungsverhalten, weil der SEP-Erwerber – wie dargelegt – in die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers einrücke und im Zuge der Patentübertragung die rechtliche Möglichkeit habe, sich Einblick in bestehende oder gewesene Lizenzverträge zu sichern.[450] Um die Diskriminierungsfreiheit seiner Lizenzangebote an die Beklagte zu rechtfertigen, sei es deshalb Sache des Erwerbers, sämtliche Lizenzerteilungen, die das Klagepatent beträfen oder einschließen, zu offenbaren und sich argumentativ damit auseinanderzusetzen, ob der Beklagten entweder wirtschaftlich inhaltsgleiche Bedingungen angeboten würden oder, sofern dies nicht der Fall sei, warum eine in bestimmter Hinsicht ungleiche Behandlung der Beklagten gegenüber zeitlich früher berechtigten Lizenznehmern des Veräußerers sachlich gerechtfertigt sei.[451]

Zeitlich relevant seien dabei nur solche Lizenzverhältnisse, die im Zeitpunkt der rechtlich gebotenen Lizenzofferte (schon und noch) in Kraft ständen, währen zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufene Lizenzverträge, weil sie keine Auswirkungen auf die Wettbewerbslage der Konkurrenten haben könnten, außer Betracht zu bleiben hätten.[452] Gehe es um den Unterlassungsanspruch, entscheide der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, weshalb es auf die in diesem Moment aktiven Lizenzverträge ankomme; stehe der Schadenersatz und Rechnungslegungsanspruch in Rede, sei derjenige Zeitraum zu betrachten, für den vom Kläger voller Schadenersatz und umfassende Rechnungslegung begehrt werde.[453]

Für die Zukunft seien Lizenzverträge unter Diskriminierungsgesichtspunkten (dazu allgemein XI.B.1.c)4)iii) unten sowie XI.B.3 unten) ferner dann unbeachtlich, wenn und sobald sie wirksam gekündigt seien und die feste Vertragslaufzeit abgelaufen sei.[454] So möge es sein, dass sich namentlich bei umfangreichen Portfolios ein für alle Lizenzen gleicher Beendigungszeitpunkt nur mit erheblichem logistischem Aufwand umsetzen lasse, woraus indessen nicht folge, dass eine Bindung des Rechtsnachfolgers an die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers unangemessen sei und nicht stattfinden dürfe, sondern mache – umgekehrt – nur die besondere Bedeutung deutlich, die ein sorgfältiges Ausloten der Lizenzbedingungen unter Geltung des Ausbeutungsverbots habe.[455] Der SEP-

[447] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 171 – *Improving Handovers.*
[448] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 321 – *Improving Handovers.*
[449] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*
[450] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*
[451] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 321 – *Improving Handovers.*
[452] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 172 – *Improving Handovers.*
[453] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 172 – *Improving Handovers.*
[454] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers*.
[455] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 320 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Inhaber werde daher mit umso größerer Sorgfalt die Bedingungen seiner Erstlizenz abzuwägen haben, wenn er an sie auf längere Sicht unter Diskriminierungsgesichtspunkten gebunden sein werde.[456]

Jede andere, von einer Bindung an die Lizenzierungspraxis des Rechtsvorgängers absehende Handhabung hätte zur Folge, dass sich der SEP-Inhaber nach Belieben seinen Pflichten insbesondere zur diskriminierungsfreien Behandlung aller Lizenzinteressenten dadurch entziehen könnte, dass er sein Patent, um sich der aus bereits erfolgten Lizenzierungen ergehenden Handlungsbeschränkungen zu entledigen, auf einen Dritten übertragen würde.[457] Das widerspräche nicht nur der Tatsache, dass die Verpflichtung zu fairen und diskriminierungsfreien Lizenzerteilung nicht personen-, sondern sachgebunden sei, nämlich gegenständlich auf dem SEP laste, sondern würde auch dem Sinn und Zweck der FRAND-Zusage zuwiderlaufen, der darin bestehe, dass jeder Lizenzinteressent nicht nur in der Lage sei, das SEP überhaupt zu benutzen, sondern ein Recht zur Benutzung des SEP zu ihn gegenüber anderen Benutzern nicht diskriminierenden finanziellen Konditionen erhalte.[458] Denn jede Lizenzgebühr, die für ein SEP aufgebracht werden müsse, repräsentiere einen Kostenfaktor für die Preisbildung auf dem nachgelagerten Produktmarkt und sei damit potentiell geeignet, die Position des Anbieters im Wettbewerb zu beeinträchtigen.[459] Würde der SEP-Erwerber die bisherige Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers abstreifen können, würde für die Lizenzsucher abhängig von dem möglicherweise rein zufälligen Zeitpunkt ihrer Lizenznahme ganz unterschiedliche Lizenzbedingungen gelten, womit eine diskriminierungsfreie Teilhabe am Standard nicht mehr gesichert wäre, weil die Höhe der Lizenzgebühren und der damit verbundene preisbildende Kostenaufwand für den Lizenznehmer danach variieren könnte, von welchem Patentinhaber die Lizenz genommen worden sei.[460] Auf dem Produktmarkt würden unterschiedliche Lizenznehmergruppen – solche, die ihr Benutzungsrecht noch von dem ursprünglichen SEP-Inhaber zu vergleichsweise günstigen Konditionen erworben hätten und die ihre Preise dementsprechend mit günstigen Lizenzkosten kalkulieren könnten, mit solchen, die einen Lizenzvertrag erst mit dem Patenterwerber abgeschlossen hätten und die bei prinzipiell unveränderter Lizenzierungslage höhere Lizenzentgelte in die Preisbildung einfließen lassen müssten – konkurrieren.[461] Eine derartige Ungleichbehandlung gleicher Sachverhalte sei mit den wirtschaftlichen Zielen einer FRAND Erklärung unvereinbar.[462]

B. Informationspflicht des Veräußerers und Geheimnisschutz

Aus Vorhergehendem folgt eine Informationspflicht des SEP-Veräußerers. Weil sich die Lizenzofferte des Erwerbers diskriminierungsfrei in die Lizenzierungspraxis des Veräußerers einfügen müsse und der Erwerber gegenüber einem Lizenzsucher diejenigen Umstände zu benennen habe, die die von ihm offerierten Lizenzbedingungen als FRAND auswiesen (dazu unten XI.B.1.b)), habe sich sein Lizenzangebot zu sämtlichen bisherigen Lizenzerteilungen, soweit sie in zeitlicher Hinsicht relevant seien, auch denjenigen des Veräußerers, zu verhalten.[463] Um dies leisten zu können, sei der SEP-Inhaber darauf angewiesen, über diejenigen Lizenzverträge in Kenntnis gesetzt zu werden, die der Veräußerer währen seiner Inhaberschaft abgeschlossen habe.[464] Eine dahingehende Informationspflicht treffe den Veräußerer unmittelbar aus seiner vertrauensbildenden Zusage, sein SEP diskriminierungsfrei zu lizenzieren.[465] Sein Versprechen zu diskriminierungsfreien Lizenzerteilung

[456] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 172 – *Improving Handovers.*
[457] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 173 – *Improving Handovers.*
[458] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 173 – *Improving Handovers.*
[459] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 173 – *Improving Handovers.*
[460] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 173 – *Improving Handovers.*
[461] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 173 – *Improving Handovers.*
[462] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 173 – *Improving Handovers.*
[463] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers.*
[464] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers.*
[465] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

äußere sich sobald er das SEP übertragen habe in der Pflicht, den als Lizenzgeber an seine Stelle getretenen Erwerber durch entsprechende Unterrichtung in den Stand zu versetzen, dem für das übertragene SEP abgegebenen Versprechen zur diskriminierungsfreien Lizenzierung nachzukommen.[466] Um das erworbene SEP durchsetzbar zu machen, liege es daher im ureigensten Interesse des SEP-Erwerbers, im Übertragungsvertrag Vorkehrungen für einen Wissenstransfer in Bezug auf bereits erfolgte Lizenzerteilungen und deren Inhalt zu treffen, was in der Praxis durchaus üblich sei, weil der Erwerber mit dem Schutzrecht zugleich die daran erteilten Lizenzen übernehme, was aus Gründen der wirtschaftlichen Vernunft geradezu zwingend gebiete, sich über die Person der Lizenznehmer und die Bedingungen der ihnen erteilten Benutzungsrechte einen dedizierten Überblick zu verschaffen.[467] Andernfalls könne der Erwerber weder überblicken, welche vertraglichen Pflichten ihn gegen den übernommenen Lizenznehmern träfen, noch sei er imstande, seine vertraglichen Rechte und Ansprüche ihnen gegenüber durchzusetzen.[468] Ferner habe der Erwerber – was ebenfalls direkte Konsequenz der vom Veräußerer für das SEP abgegebenen FRAND-Zusage sei – Vorsorge dafür zu treffen, dass der Rechtsvorgänger daran mitwirke, dass die von ihm erteilten Lizenzen erforderlichenfalls (z.B. in einem Rechtsstreit) offengelegt werden könnten, um eine (insbesondere gerichtliche FRAND-Prüfung) zu erlauben.[469]

Rechtlich relevant könnte allenfalls der Einwand sein, der Veräußerer (in casu als Streithelfer beigetreten) sei durch vertragliche Geheimhaltungsvereinbarungen mit ihren Lizenznehmern auch im Hinblick auf notwendige Darlegungen in einem Rechtsstreit um das lizenzierte Schutzrecht daran gehindert, die Vertragsinhalte offenzulegen.[470] Um solches beachtlich geltend zu machen, hätte die Klägerin und/oder ihr Streithelfer den Inhalt der angeblichen Vertraulichkeitsklauseln im Einzelnen, d.h. mit dem genauen Wortlaut und unter Darlegung sämtlicher auslegungsrelevanter Umstände, mitteilen müssen, weil der betreffende Sachvortrag nur so für den Prozessgegner einlassungsfähig und einer gerichtlichen Prüfung daraufhin zugänglich sei, ob die getroffenen Geheimhaltungsabsprachen tatsächlich so weit reichten wie die Klägerin behaupte.[471] Mangels vorliegend entsprechendem Sachvortrags der Klägerin sei unklar, ob die Vertraulichkeitsklauseln nicht einer sinnvollen, weil objektiv interessensgerechten Interpretation dahingehend zugänglich seien, dass dem Streithelfer eine Offenbarung der Lizenzinhalt in dem Maße gestattet sei, in dem er einer rechtlich unumgänglichen Pflicht hierzu aus der FRAND-Zusage unterliege.[472] Von einer Unmöglichkeit könne überdies nur dann ausgegangen werden, wenn das Leistungshindernis von der Klägerin nicht ausgeräumt werden könnte, was im vorliegenden Zusammenhang verlange, dass der Streithelfer und vor allem deren Lizenznehmer trotz nachdrücklicher Anfrage endgültig nicht bereit seien, auf eine Einhaltung der Vertraulichkeitsvereinbarung im Rahmen und für die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits zu verzichten.[473]

Letztlich könnten die vorgenannten Bedenken aber sogar dahinstehen, denn für diesen Fall bleibe festzuhalten, dass sich der Veräußerer die Erfüllung seiner kartellrechtlichen Pflicht aus der FRAND-Zusage mit einer umfassenden Vertraulichkeitsvereinbarung schuldhaft unmöglich gemacht habe, weswegen er mit seinem Einwand mangelnder Leistungsfähigkeit zum Prozessvortrag nicht mehr gehört werden könne.[474] Wer als Beweispflichtiger seine eigenen Beweise vernichte oder sonst wie vereitele, bleibe anerkanntermaßen beweisfällig und habe die daraus resultierenden Prozessfolgen zu

[466] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers.*
[467] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers.*
[468] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers.*
[469] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers.*
[470] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*
[471] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*
[472] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*
[473] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*
[474] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

tragen.[475] Dasselbe gelte für die der Beweislast vorgelagerte Darlegungslast; wer sich zu einem erforderlichen Prozessvortrag schuldhaft außerstande setze, bleibe darlegungsfällig und unterliege im Rechtsstreit, wenn die darlegungspflichtigen Tatsachen den eingeklagten Anspruch begründeten.[476] Da der Patenterwerber rechtlich nicht besser dastehen könne als der Veräußerer des Rechts, teile die Klägerin notwendigerweise das prozessrechtliche Schicksal ihres Streithelfers.[477]

Auch verstoße die Verpflichtung zur Offenlegung der abgeschlossenen Lizenzverträge nicht gegen Art. 101 AEUV.[478] Innerhalb eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion seien sehr wohl Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen möglich.[479] Neben den im GVG vorgesehenen, die Öffentlichkeit betreffenden gerichtlichen Anordnungen gehe es vor allem um Vertraulichkeitsvereinbarungen, die demjenigen abverlangt werden könnten, demgegenüber ein Geschäftsgeheimnis offenzulegen sei, wofür freilich Bedingung sei, dass derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information identifiziere, sondern außerdem konkret darzutun habe, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstelle, was substanziellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen verlange, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet hätten, und erfordere des Weiteren ebenso substanzielle verifizierbare Angaben dazu, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Information mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohten.[480] Gelinge dies und weigere sich der Gegner, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung zu treffen, so könne sich der SEP-Inhaber zur Rechtfertigung seines Lizenzangebotes auf pauschale, andeutende Angaben beschränken, die seine Geschäftsgeheimnisse schützten, und wären als prozessual ausreichend und das darauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu behandeln.[481] Als nicht ausreichend erachtete das OLG dabei weitgehend theoretische Erörterungen darüber, welche Reglungsinhalte in irgendwelchen abgeschlossenen Lizenzverträgen angeblich Geschäftsgeheimnisse enthalten sollten ohne nähere Erläuterung, sondern verlangte stattdessen eine Begründung in Bezug auf die für das Klagebegehren im maßgeblichen Zeitraum aktiven Lizenzverträge, inwiefern die zur Rechtfertigung der Diskriminierungsfreiheit des Beklagten unterbreiteten Lizenzangebotes erforderlichen Ausführungen schützenswerte Geschäftsgeheimnisse des Veräußerers offenlegen würden, und einen wenigstens andeutenden Vortrag zur Erläuterung des den betreffenden Lizenzverträgen zugrundeliegenden Lizenzierungskonzepts.[482]

Dementgegen ließ das OLG Düsseldorf auch den Einwand mangelnder faktischer Möglichkeit den vorstehend dargelegten Verpflichtungen nachzukommen nicht gelten.[483] Selbstverständlich seien Sachverhaltskonstellationen, insbesondere bei mehrfacher, sukzessiver Schutzrechtsübertragung, konstruierbar, angesichts derer die geforderten Darlegungen zur Einhaltung des Diskriminierungsverbots immer schwieriger und aufwändiger würden.[484] Rechtliche Relevanz könne dem indessen nur zugemessen werden, wenn es sich bei den von der Klägerin ins Feld geführten Konstellationen einer wiederholt weiteren Aufspaltung des erworbenen Portfolios im Zuge nachfolgender Verkäufe und ihrer Lizenzierung, ggf. unter zusätzlichem Einschluss anderweitig

[475] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*

[476] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*

[477] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers.*

[478] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers.*

[479] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers.*

[480] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[481] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[482] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers.*

[483] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 177 – *Improving Handovers.*

[484] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 179 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

erworbener weiterer Schutzrechte, nicht bloß um theoretische Gedankenspiele, sondern um Sachverhalte mit ernsthafter praktischer Relevanz handeln würde, wofür der Sachvortrag der Klägerin im konkreten Fall keine Anhaltspunkte lieferte.[485] Abgesehen davon bleibe es in jedem Fall die freie Entscheidung des SEP-Veräußerers, ob er mit einer unter bereits verwickelten Umständen vorgenommenen weiteren Patentübertragung diejenigen verschärften Anforderungen auf sich nehmen wolle, die damit in Bezug auf die Diskriminierungsfreiheit seines Lizenzangebotes verbunden seien.[486] Dass die aufzubringenden Mühen mit der Komplexität der Übertragungs- und Lizenzierungssachverhalte zunähmen, sei eine unausweichliche Folge des rechtlich zu beurteilenden Sachverhaltes und seiner Eigenart, beschränke aber weder in unzulässiger Weise die grundsätzliche Freiheit zur Patentübertragung noch liefere die gegebenenfalls erhebliche Mühewaltung bei einer FRAND-Lizenzierung einen hinreichenden Grund dafür, den Patenterwerber von der Einhaltung des gesetzlichen Diskriminierungsverbots kurzerhand freizustellen.[487] Die insoweit zu leistenden Darlegungen repräsentierten vielmehr denjenigen „Preis", der bei der gegebenen Sach- und Rechtslage im Falle einer (weiteren) Schutzrechtsübertragung zu entrichten sei.[488] Ihn einzufordern begegne umso weniger Bedenken, als – und darin liege die zutreffende Lösung des Problems – der Darlegungsmaßstab angemessen auf diejenigen tatsächlichen Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen habe, die sich im Einzelfall aus der einfachen, ggf. aber auch besonders komplizierten Übertragungs- und Lizenzierungsfolge ergäben.[489]

C. Bestimmung des Diskriminierungsmaßstabs: Bewertung eines Teilportfolios

Eine weitere interessante Bemerkung stellte das OLG Düsseldorf betreffend den Diskriminierungsmaßstab bei der Übertragung nur eines Teilportfolios an. Sei Gegenstand der Lizenzvergabe des Veräußerers wie im vorliegenden Fall ein umfassendes Schutzrechtsportfolio gewesen, das er zu einem (größeren) Teil in seinem eigenen Besitz gehalten (oder anderweitig veräußert) und zu (geringeren) Teilen auf den klagenden Erwerber übertragen habe, so dass das bisher gesamthaft lizenzierte Patentportfolio auf mehrere Inhaber aufgespalten worden sei, so bestimme sich der Diskriminierungsmaßstab nicht nach der bloßen Zahl der Schutzrechte in den Teilportfolios, sondern es sei in einer wertenden Betrachtung zu ermitteln, welcher Bruchteil der für das bisherige Gesamtschutzrechtspaket vereinbarten Lizenzgebühr im Verhältnis zueinander den Teilschutzrechtsportfolios zuzuweisen sei.[490]

Maßgeblich für die vorzunehmende Aufteilung sei, welche technische Bedeutung den im jeweiligen Teilportfolio enthaltenen Patenten für den Standard zukomme und welche Wichtigkeit für den nachgelagerten Produktmarkt und die dortigen Absatzchancen denjenigen Wirkungen und Eigenschaften zuzusprechen sei, die von den jeweiligen Schutzrechten verantwortet würden.[491] Es verstehe sich von selbst, dass dies nicht mit mathematischer Genauigkeit geschehen könne, sondern letztlich auf eine bloß überschlägige Abschätzung hinauslaufe, die dem Recht in vielfacher Weise geläufig sei (so z.B. § 254 BGB. § 287 ZPO, Bestimmung des Kausalanteils beim Verletzergewinn) und die deshalb auch vorliegend den rechtlichen Maßstab bilden könne.[492] Mangels anderer Behauptung der Klägerin und deren Streithelfers liege es nach der Lebenserfahrung auf der Hand, dass ein übertragenes Schutzrechtsportfolio nicht beliebig und rein zufällig zusammengesetzt sei, sondern seine Bestückung bestimmten, nachvollziehbaren Regeln folge, etwa der Überlegung, welche Technik

[485] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 179 – *Improving Handovers.*
[486] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 179 – *Improving Handovers.*
[487] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 179 – *Improving Handovers.*
[488] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 179 – *Improving Handovers.*
[489] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 179 – *Improving Handovers.*
[490] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 180 – *Improving Handovers.*
[491] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 180 – *Improving Handovers.*
[492] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 180 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

(verkörpert in bestimmten Schutzrechten und Schutzrechtsfamilien) in der Hand des Veräußerers verblieben und welche Technik (verkörpert in bestimmten Schutzrechten und Schutzrechtsfamilien) an den Erwerber übergehen solle.[493] Bei der Auswahl und Zuordnung werde die Werthaltigkeit des einen (behaltenen) und des anderen (abgegebenen) Schutzrechtsbestandes eine wesentliche Rolle spielen, anhand ihrer sich jeder vernünftige Veräußerer in Zusammenhang mit dem Patentverkauf konkrete Vorstellungen über die von ihm für die Schutzrechtsüberlassung beanspruchte Gegenleistung machen werde.[494] Erfolge der Verkauf – wie vorliegend – nicht an ein produzierendes Unternehmen, sondern an einen Erwerber, dessen Geschäftstätigkeit sich auf die Patentverwertung durch Lizenzvergabe beschränke, würden sich die Preisvorstellungen beider Seiten sinnvollerweise an denjenigen Ertragserwartungen orientieren, die dem Erwerber durch das verkaufte Portfolio voraussichtlich vermittelt werden können.[495] Dafür sprächen wiederum zwei Faktoren eine maßgebliche Rolle, nämlich die Bedeutung der zur Übertragung vorgesehenen Schutzrechte für den technischen Standard einerseits und für die Wettbewerbsfähigkeit des Verkaufsproduktes auf dem nachgelagerten Markt standardgemäßer Erzeugnisse andererseits, denn beides sei für die Umsatz- und Gewinnerwartungen derjenigen Lizenzsucher bedeutsam, die von dem Patenterwerber als (Lizenz-)Kunden angesprochen und gewonnen werden sollten.[496] Für die Preisfindung bei der Patentübertragung seien damit exakt diejenigen Faktoren ausschlaggebend, die für die Aufteilung der bisherigen Lizenz für das Gesamtportfolio auf die durch den Schutzrechtsverkauf entstehenden Teilportfolios heranzuziehen seien.[497] Weil dem so sei, handele es sich bei den Bewertungskriterien um objektive Umstände, die typischerweise bereits im Zusammenhang mit der Schutzrechtsveräußerung bedacht würden, die dementsprechend als solche benannt, von den Parteien diskutiert und einer gerichtlichen Plausibilitätskontrolle unterzogen werden könnten und die deswegen einen nicht nur geeigneten, sondern von der Klägerseite ohne weiteres leistbaren Sachvortrag repräsentierten.[498]

Der dargestellte Prüfungs-, Bewertungs- und Aufteilungsmaßstab tauge, mehrfach angewendet, auch dann, wenn der Patenterwerber das übernommene Portfolio nicht unverändert (isoliert), sondern in der Weise lizenzieren wolle, dass dem übernommenen Portfolio weitere SEP aus anderweitigen Zukäufen oder eigenen Beständen hinzugefügt würden.[499] Seien auch sie Gegenstand einer vorhergehenden Portfoliolizenzierung des Veräußerers oder Erwerbers gewesen, so sei derjenige Lizenzgebührenanteil, der auf die übertragenen oder im eigenen Bestand befindlichen SEP entfalle, in der gleichen wertenden Weise zu bestimmen, wie dies gerade für die Teilportfolioübertragung besprochen worden sei, und könne anschließend dem Teillizenzwert für das erste Teilportfolio hinzugerechnet werden.[500]

Auch gehe der Verweis der Klägerin auf Komplikationen resultierend aus vorgenommenen Kreuzlizenzierungen oder Vereinbarungen über anderweitige geldwerte Gegenleistungen, die in der Person des diskriminierungsfrei zu behandelnden Lizenzsuchers nicht infrage kämen, weil er z.B. über keine seinerseits lizenzierungsfähigen Schutzrechte verfüge oder weil der Lizenzgeber mangels produzierenden Geschäftsbetriebs an einer Lizenznahme kein Interesse habe, schon im Ansatz fehl.[501] Die heterogene Leistungsfähigkeit der Lizenzaspiranten sei eine Problemlage, die sich bei jeglicher Lizenzerteilung ergeben könne und die den Patentinhaber deshalb nicht nur in Übertragungsfällen,

[493] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 181 – *Improving Handovers.*
[494] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 181 – *Improving Handovers.*
[495] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 182 – *Improving Handovers.*
[496] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 182 – *Improving Handovers.*
[497] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 182 – *Improving Handovers.*
[498] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 182 – *Improving Handovers.*
[499] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 183 – *Improving Handovers.*
[500] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 183 – *Improving Handovers.*
[501] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

sondern genauso, wenn sämtliche Schutzrechte in seiner Hand verblieben, vor der Aufgabe einer Einhaltung des Diskriminierungsverbots stelle.[502] Hätte der Veräußerer Teile seines Portfolios nicht an die Klägerin veräußert, sondern in seinem eigenen Besitz behalten, so hätte sich der Veräußerer notwendigerweise Gedanken darüber machen müssen, wie er sich vor dem Hintergrund von seinen bereits vergebenen Kreuzlizenzen diskriminierungsfrei gegenüber einem Lizenzsucher verhalten wolle, der entweder ebenfalls über für ihn interessante Schutzrechte verfüge oder aber solche nicht aufzuweisen habe.[503]

Das Gleiche gelte für den Umstand, dass sich der zu lizenzierende Schutzrechtsbestand im Laufe der Zeit, z.B. durch Schutzrechtsabläufe oder Neuerteilungen (zur Anpassungsklausel unten XI.B.2.c)3)), verändere oder sich die Wichtigkeit einzelner technischer Features für den Produktmarkt verschiebe.[504] Auch solche Geschehensabläufe stellten sich unabhängig von einer Patentübertragung ein und seien von jedem durch eine FRAND-Erklärung gebundenen Patentinhaber diskriminierungsfrei zu bewältigen.[505] Dies geschehe zweckmäßigerweise indem die Lizenzierungspraxis einem *vorher* überdachten Lizenzierungskonzept folge, welches von vornherein überdenke, mit welchem sachgerechten „Lizenzgebührenrabatt“ solche Lizenzsucher bedacht werden sollten, die z.B. Kreuzlizenzen – in kleinerem oder größerem Umfang – anbieten könnten.[506] Innerhalb eines solchen Lizenzierungskonzepts werde sich die Diskriminierungsfreiheit eines aktuellen Lizenzangebots vordringlich in Bezug auf diejenige Lizenznehmergruppe bestimmen, die sich in derselben Ausgangssituation befunden habe.[507]

Mit Blick auf einen Lizenzsucher ohne eigenen Schutzrechtsbestand seien daher nicht Kreuzlizenzverträge von Bedeutung, sondern diejenigen Lizenzen, bei denen Benutzungsrechte nur in Richtung auf den Verletzer vergeben worden seien und die Lizenzvergütung ausschließlich in Geld bestimmt sei.[508] Dass es solche, mit den Verhältnissen des Streitfalls vergleichbaren Verträge des Veräußerers nicht gebe, sei weder ersichtlich noch geltend gemacht.[509] Irgendwelche Komplikationen, die sich aus abgeschlossenen Kreuzlizenzen ergeben könnten, seien deshalb vorliegend auszuschließen.[510]

D. SEP-Übertragung als wettbewerbsbeschränkende Abrede (Art. 101 AEUV)

Mit den Patentübertragungen sah das OLG Düsseldorf auch keinen Verstoß gegen Art. 101 AEUV verbunden.[511] Austauschverträge wie vorliegend die entgeltliche Übertragung eines Patentportfolios unterfielen als solche nicht dem Anwendungsbereich von Art. 101 AEUV, da sie auf einen Leistungsaustausch zwischen den vertragsbeteiligten Unternehmen gerichtet und mit diesem Inhalt per se nicht geeignet seien, wettbewerbsbeschränkende Wirkungen zu entfalten.[512] Um den Anwendungsbereich des Kartellverbots zu eröffnen, bedürfe es deshalb einer mindestens objektiv wettbewerbsbeschränkenden Nebenabrede innerhalb des für sich kartellrechtsneutralen Austauschvertrags, wobei die Nebenabrede über dasjenige hinausgehen müsse, was erforderlich sei,

[502] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[503] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[504] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[505] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[506] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[507] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[508] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[509] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[510] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*
[511] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 185 – *Improving Handovers.*
[512] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf BGH, 26.1.2016 – KVR 11/15 – *Laborchemikalien.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

um den Hauptzweck des Austauschvertrages zu verwirklichen.[513] Entscheidend sei dabei, ob die vereinbarte Wettbewerbsbeschränkung sachlich erforderlich und zeitlich, räumlich sowie gegenständlich darauf beschränkt sei, den mit dem Austauschvertrag verfolgten Zweck zu erreichen.[514] Sei dies der Fall, komme ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV auch mit Blick auf die Nebenabrede nicht in Betracht, gehe jedoch die Wettbewerbsklausel über das Maß des Erforderlichen hinaus, sei eine zur Vertragsnichtigkeit führende kartellrechtswidrige Wettbewerbsbeeinträchtigung denkbar, wobei allerdings in Fällen eines bloß zeitlichen Übermaßes eine geltungserhaltende Reduktion zulässig sei.[515]

In casu enthalte weder das Master Sale Agreement noch die Patentübertragungsvereinbarungen irgendeine wettbewerbsbeschränkende oder -verfälschende Nebenabrede, die den Anwendungsbereich des Art. 101 AEUV eröffnen könnte.[516]

Einerseits bezog sich die Beklagte auf eine Einlassung des Veräußerers, die Übertragung seines Patentportfolios sei zu dem Zweck und in der Erwartung geschehen, höhere Lizenzeinnahmen durchzusetzen, als ihm selbst in den Verhandlungen mit Patentbenutzern möglich gewesen wäre.[517] Das OLG Düsseldorf sah darin jedoch eine bloße Motivationslage für die Patentübertragungen, aber nicht eine die vertragliche Rechte- und Pflichtenlage regelnde Klausel im Sinne einer Nebenabrede, derer es als Anknüpfungspunkt für das Kartellverbot bedürfe.[518] Andererseits seien, davon abgesehen, die Patenterwerber, wie bereits ausgeführt, sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach in gleicher Weise an die FRAND-Zusage gebunden wie es der Veräußerer gewesen sei, womit der Vorwurf, die Patentübertragungen seien dazu geeignet, Lizenzgebühren zu erzielen, die wegen ihrer unangemessenen Höhe un-FRAND seien, auch einer sachlichen Grundlage entbehre.[519]

Gleichermaßen bedeutungslos sei unter Wettbewerbsgesichtspunkten das Argument, die Klägerin sei auf dem nachgelagerten Produktmarkt für standardbenutzende Erzeugnisse selbst nicht operativ tätig, weshalb sie im Rahmen ihrer Lizenzverhandlungen mit einem Patentbenutzer auch keine Rücksicht darauf nehmen müsse, von diesem aus seinem eigenen SEP-Portfoliobestand angegriffen zu werden.[520] Doch unterliege die Frage, ob das Lizenzangebot des klagenden Schutzrechtsinhabers FRAND-Kriterien genüge und insbesondere das mit dem Lizenzangebot verlangte Benutzungsentgelt der Höhe nach angemessen und diskriminierungsfrei sei, im Patentverletzungsprozess der uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle, wobei es bereits im Vorfeld dieser Prüfung Sache des Patentinhabers sei, für den Adressaten nachvollziehbar zu begründen, weshalb das mit der Lizenzofferte unterbreitete Regelwerk als Ganzes und namentlich die darin vorgesehene Lizenzgebühr fair, zumutbar und diskriminierungsfrei (=FRAND) sein solle.[521] Erst wenn diese inhaltliche Rechtfertigung geleistet und die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebotes zugunsten des Schutzrechtsinhabers geklärt sei, komme eine Verurteilung in Betracht, die weitergehen in die Rechtsposition des Verletzers eingreifen würde als es die jedem SEP-Benutzer ohnehin obliegende Pflicht beinhalte, den Gebrauch des fremden geistigen Eigentums durch eine FRAND-Lizenzgebühr und eine dem vorausgehende Rechnungslegung zu entgelten.[522] Eine Verschärfung der Haftung sei unter den besagten Umständen aber auch vollkommen gerechtfertigt, weil die Verurteilung wegen

[513] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers.*

[514] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf BGH, 26.1.2016 – KVR 11/15 – *Laborchemikalien.*

[515] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers.*

[516] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 187 – *Improving Handovers.*

[517] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 188 – *Improving Handovers.*

[518] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 188 – *Improving Handovers.*

[519] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers.*

[520] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers.*

[521] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[522] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Patentverletzung ihre Ursache allein darin habe, dass der Verletzer das – auch unter Berücksichtigung der vom Rechtsvorgänger vergebenen Lizenzen – FRAND-Bedingungen genügende Lizenzangebot des SEP-Inhabers unberechtigt ausgeschlagen habe, auf das er hätte eingehen müssen.[523] Aus dem gerichtlichen Prüfungsvorbehalt folge des Weiteren, dass eine Wettbewerbsbeschränkung noch nicht damit verbunden sein könne, dass der SEP-Inhaber unberechtigte Lizenzforderungen erhebe, die mit den dargelegten FRAND-Grundsätzen im Falle eines Patenterwerbs nicht in Einklang ständen.[524]

Auch sei keine wettbewerbsbeschränkende Vertragsklausel insoweit erkennbar und damit kartellrechtlich belanglos, als der Veräußerer einen Teil des standardessenziellen Patentportfolios weiter in seinem Besitz gehalten habe.[525] Selbstverständlich stehe es dem Veräußerer frei, für die Benutzung des bei ihm verbliebenen SEP-Bestandes Lizenzgebühren einzufordern, denn da er dabei den formellen (Pflicht zum Lizenzangebot) und sachlichen (FRAND-Gemäßheit der Lizenzofferte) Beschränkungen aus seiner Lizenzierungszusage unterliege, liefen Benutzer des Gesamt-Portfoliobestandes nicht Gefahr, zu einer gesetzlich nicht geschuldeten, weil unangemessen hohen Lizenzgebühr verpflichtet zu werden.[526] Denn wegen der FRAND-Bindung sowohl des Erwerbers als auch des Veräußerers setzten die FRAND-Kriterien auch für die Benutzung des kompletten SEP-Bestandes die Obergrenze für jede finanzielle oder sonstige Lizenzbelastung eines SEP-Benutzers.[527] Dass es dem Veräußerer wegen der gegebenen Rahmenbedingungen selbst aus tatsächlichen Gründen nicht möglich gewesen sei, den rechtlich zulässigen Spielraum einer FRAND-Lizenzgebühr in Vertragsverhandlungen mit Verletzern auszuschöpfen, möge sein, habe kartellrechtlich jedoch keine Bedeutung, denn das Kartellrecht diene nicht dazu, einen Patentverletzer davor in Schutz zu nehmen, für die Benutzung fremden geistigen Eigentums in demjenigen Umfang zur Zahlung von Lizenzgebühren herangezogen zu werden, der von Gesetzes wegen zulässig sei.[528] Soweit der Veräußerer bereits – zu seinem eigenen Nachteil wirtschaftlich unzulängliche – Lizenzen vergeben habe, sei auch der Erwerber als Rechtsnachfolger über das Diskriminierungsverbot an die bisher praktizierte Lizenzierungspraxis des Veräußerers gebunden, und von der der Veräußerer selbst – und folgerichtig auch sein Rechtsnachfolger – nur dann und nur insoweit abweichen könne, wie sachliche Unterschiede in den Lizenzierungssachverhalt dies rechtfertigten.[529]

Weiter äußerte das OLG sich betreffend ein Drängen des Veräußerers – worauf jedoch im Tatsächlichen keinerlei Anhaltspunkte erkennbar seien – im Zuge der Patentübertragung darauf, dass der Erwerber die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch nehme, dahingehend, dass auch daraus kartellrechtlich nichts zu beanstanden sei.[530] In einem Rechtsstaat stelle es das gute Recht jedes Patentinhabers dar, seine vermeintlichen Ansprüche vor Gericht durchzusetzen, und gerade weil der Veräußerer als Streithelfer über eine prozentuale Beteiligung an den vom Patenterwerber erzielten Lizenzgebühren partizipiere, stelle es im Gegenteil ein völlig legitimes Interesse dar, dass der Erwerber notfalls auch mit Mitteln einer Verletzungsklage Vorsorge dafür treffe, dass sich die Beklagte ihrer Verpflichtung zur Zahlung von FRAND-Lizenzgebühren nicht entziehe.[531] Wegen des in Deutschland geltenden Kostenerstattungsprinzips laufe die Beklagte in diesem Zusammenhang auch nicht Gefahr, im Falle eines Obsiegens mit finanziellen Nachteilen belastet zu bleiben.[532] Soweit andernorts abweichende Kostenregelungen existieren sollten, gelte nichts anderes, denn bei einer derartigen

[523] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers.*
[524] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers.*
[525] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers.*
[526] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers.*
[527] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers.*
[528] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers.*
[529] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers.*
[530] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers.*
[531] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers.*
[532] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Rechtslage entspreche es dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers und könne deshalb nicht als kartellrechtsrelevanter Umstand gewertet werden, dass eine Prozesspartei trotzt ihres Obsiegens im Rechtsstreit die Kosten ihrer Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selber zu tragen habe.[533]

Ob die Rechtslage anders zu beurteilen sein könnte, wenn ein umfangreiches SEP-Portfolio regelrecht „atomisiert" werde, indem das Gesamtpaket auf eine unüberschaubare Vielzahl von Einzelinhabern aufgespaltet werde, mit denen allen sich der Lizenzsucher bei seinen Lizenzverhandlungen auseinandersetzen müsse, bedürfe im Streitfall keiner Entscheidung, denn ein derartiger Sachverhalt sei im Streitfall nicht einmal ansatzweise gegeben.[534]

Auch kartellrechtlich unbedenklich sei die Vereinbarung, dass in bestimmten Sachverhaltskonstellationen Bemessungsgrundlagen für den an den Veräußerer abzuführenden Lizenzgebührenanteil nicht die vom Erwerber tatsächlich erzielten Lizenzeinnahmen seien, sondern stattdessen einen vereinbarten Mindestlizenzbetrag, der als Rechengröße sicherstelle, dass der Veräußerer für den Fall, dass der Erwerber nicht ausreichende Lizenzeinnahmen generiere, eine angemessene Vergütung für sein übertragenes geistiges Eigentum erhalte.[535] Gegen diese Art der Entgeltvereinbarung sei unter Geltung der Privatautonomie nichts zu erinnern, auch im Hinblick darauf, dass der Mindestlizenzbetrag mittelbar einen Anreiz für den Erwerber bieten möge, tunlichst keine niedrigeren Lizenzentgelte zu vereinbaren, weil er den dem Veräußerer geschuldeten Lizenzanteil ansonsten zum Teil aus eigenen finanziellen Mitteln zusteuern müsste.[536] Der Sache nach handele es sich jedoch um keine andere Situation als sie bestehen würde, wenn für den Portfolioerwerb – was unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten völlig unbedenklich wäre – ein fester Kaufpreis vereinbart worden wäre, der den Erwerber, je höher der vereinbarte Kaufpreis gewesen sei, ebenfalls in die wirtschaftliche Notwendigkeit gebracht hätte, tunlichst lukrative Lizenzvertragsabschlüsse zu tätigen.[537] Hinzu komme, dass der Anreiz für eine bestimmte Mindestlizenzvergütung innerhalb des FRAND-Rahmens alle Lizenzinteressenten gleichermaßen betreffen würde, so dass nicht ersichtlich sei, inwiefern die Vergütungsregelung im Master Sale Agreement zu einer Wettbewerbsbehinderung der Nachfrager auf dem Lizenzvergabemarkt führen könnte.[538]

[533] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers.*

[534] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 192 – *Improving Handovers.*

[535] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers.*

[536] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers.*

[537] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers.*

[538] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

VIII. Verletzungsanzeige des Patentinhabers

A. Zweck

Der SEP-Inhaber hat dem Standard-Implementierer die Verletzung anzuzeigen.[539] Nach dem OLG Düsseldorf sei Zweck des Hinweises durch den Patentinhaber, (nur) einem etwaigen Informationsdefizit auf Seiten des angeblichen Verletzers zu begegnen, dem möglicherweise in Anbetracht der Vielzahl von SEP im Standard die Benutzung jedes einzelnen SEP nicht positiv bekannt sei.[540] Ausgehend davon bestehe keine Anzeigepflicht, wenn aufgrund der Umstände mit Sicherheit davon auszugehen sei, dass der angebliche Verletzer Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents habe und sein Einwand, der Kläger habe ihm dies nicht angezeigt, als Rechtsmissbrauch erscheine.[541] Die Verletzungsanzeige könne unter dieser Voraussetzung als bloße Förmelei unterbleiben.[542]

Auch das LG Düsseldorf nahm die Rechtsprechung des OLG an, ließ jedoch auch Worte der Begrenzung walten. Die Verletzungsanzeige diene dazu, dem hinsichtlich des Schutzbereichseingriffs gegebenenfalls noch gutgläubigen Benutzer die Gelegenheit zu geben, um Erteilung einer aufgrund der FRAND-Erklärung jedem Interessenten zugesagten Benutzungserlaubnis nachzufragen.[543] Die Pflicht zur Selbstanzeige sei jedoch kein Selbstzweck, und deshalb dort entbehrlich, wo sie sich nur als nutzlose Förmelei darstelle, weil aufgrund der Gesamtumstände mit Sicherheit davon ausgegangen werden könne, dass der Verletzungsbeklagte Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform habe und sein Berufen darauf, der Kläger habe ihm dies nicht angezeigt, als Rechtsmissbrauch erscheine.[544] An das Vorliegen eines solchen Tatbestandes seien jedoch hohe Anforderungen zu stellen.[545]

B. Inhalt und Zeitpunkt

1. Inhalt

Inhaltlich verlange die Verletzungsanzeige nach Meinung des OLG Düsseldorf zumindest, dass das einschlägige SEP unter Angabe der Veröffentlichungsnummer zu nennen und anzugeben sei, in welcher konkreten Handlung die Verletzung bestehen solle, wobei Letzteres die Bezeichnung der Art der Benutzungshandlung sowie der angegriffenen Ausführungsform(en) erfordere.[546] Der Hinweis erfordere keine detaillierten technischen und/oder rechtlichen Erläuterungen des Verletzungsvorwurfs, sondern der Patentbenutzer müsse nur in die Lage versetzt werden, sich selbst (ggf. mit sachverständiger Hilfe und/oder unter Einholung von Rechtsrat) ein Bild von der Berechtigung

[539] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 61 – *Huawei/ZTE.*

[540] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 62 – *Huawei/ZTE.*

[541] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem*; LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 288; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 246; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 227; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 234.

[542] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem;* im Ansatz so auch schon OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 5.

[543] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 233; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 214; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 217.

[544] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 233; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 214; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 217.

[545] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 233; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 214; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 217.

[546] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 172 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

des ihm unterbreiteten Vorwurfs machen zu können.[547] Ausreichend, aber nicht notwendig, sei die Erläuterung des Benutzungsvorwurfs anhand von Claim-Charts.[548] Unbeantwortet ließ der Senat die Frage, ob die Nennung der/des einschlägigen Standards zwingend erforderlich sei.[549]

Nicht erforderlich sei, dass der Hinweis in Gestalt einer Abmahnung erfolge.[550] Auch erfordere die Hinweispflicht keine detaillierte inhaltliche Begründung, weshalb die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht seien und aus welchen Gründen rechtlich eine Haftung bestehen solle.[551] Auch müssten die im Rechtsstreit angegriffenen Ausführungsformen nicht konkret bezeichnet sein, wenn hinreichend deutlich hervorgehe, dass sich der Vorwurf auf sämtliche weltweit vertriebenen, standardgemäßen Geräte erstrecke.[552] So ließ es das OLG Düsseldorf auch den bloß pauschalen Verweis auf „wireless devices" als Bezeichnung der Ausführungsform genügen, da sich keine durchschlagenden Bedenken gegen die ordnungsgemäße Erfüllung der Hinweispflicht daraus ergäben, dass die seinerzeit genannten Geräte nicht identisch mit den angegriffenen Ausführungsformen des laufenden Rechtsstreits seien.[553] Aufgrund des Hinweises auf „wireless devices" als Gegenstand der Beanstandung müsse der Beklagten klar sein, dass die konkret bezeichneten Modelle nicht abschließend gemein gewesen seien.[554] Da die Klägerin unwidersprochen dargetan habe, dass die Beklagten sehr häufig Modellaktualisierungen vornähmen, könne es der Klägerin nicht zum Nachteil gereichen, dass ursprünglich von ihrem vorprozessualen Hinweis erfasste Ausführungsformen inzwischen Aktualisierungen in Bezug auf die Modellbezeichnungen erfahren hätten.[555] Da dem betreffenden Hersteller/Benutzer in dieser Situation bewusst sein müsse, dass auch entsprechend aktualisierte Modelle nach Auffassung des SEP-Inhabers patentverletzend seien, sei nach dem Sinn und Zweck des vom EuGH entwickelten Hinweiserfordernisses (Schutz des gutgläubigen Benutzers) eine permanente Aktualisierung des Hinweises in Bezug auf die erfassten Ausführungsformen nicht erforderlich.[556] Abweichendes möge gelten, wenn nicht bloße Aktualisierungen erfolgten, sondern grundlegende technische Änderungen, die den Schutzbereich des jeweiligen SEP tangierten, vorgenommen würden.[557]

Auch die Kammern 4c und 4a des LG Düsseldorf verlangten zur Erfüllung der Hinweispflicht die Bezeichnung des fraglichen SEPs im Verletzungshinweis zuzüglich der Angabe, auf welche Weise es verletzt worden sein soll.[558] Dies erfordere zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, der angegriffenen Ausführungsform und der vorgeworfene(n) Benutzungshandlung(en)

---

[547] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 172 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14 – *Hochfrequenzanteil*, nach Ansicht des OLG Düsseldorf wohl weitergehend LG Mannheim, 29.1.2016 – 7 O 66/15.

[548] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 172 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Hinweis auf die seiner Meinung nach wohl andere Ansicht des LG Mannheim, 29.1.2016 – 7 O 66/15; OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 5.

[549] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 180 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf die dies bejahende Ansicht des LG Mannheim, 29.1.2016 – 7 O 66/15.

[550] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 172 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Hinweis auf die seiner Meinung nach wohl andere Ansicht des LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14 – *Stochastisches Rauschen*.

[551] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 178 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[552] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 6.

[553] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 179 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[554] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 179 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[555] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 179 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[556] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 179 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[557] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 179 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[558] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 159; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 172.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

im Sinne von §§ 9 f. PatG gegenüber dem Verletzer.[559] Da die Verletzungsanzeige nur in die Lage versetzen müsse, gegebenenfalls unter Bemühung sachverständiger Hilfe den Verletzungsvorwurf zu prüfen, bedürfe es entgegen der vorhergehenden Ansicht des LG Mannheim keines Hinweises auf die Standardessenzialität des geltend gemachten Patents und/oder der Vorlage von Claim Charts.[560] Die inhaltlichen Anforderungen an die Verletzungsanzeige dürften nicht derart überspannt werden, dass der Patentinhaber zu diesem frühen Zeitpunkt der Auseinandersetzung schon verpflichtet werde, detailliert zu begründen, wodurch die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht würden, und seine Ansprüche rechtlich herzuleiten, da es zunächst Sache des Verletzers sei, den Verletzungsvorwurf inhaltlich zu überprüfen.[561]

Lediglich pauschale Angaben im Verletzungshinweis – in casu die Bezeichnung der Ausführungsformen als „mobile Handapparat- und Tablet-Produkte" und der verletzten Schutzrechte in Form des Hinweises auf „das AVC-Patentportfolio" mit „mehr als 1000 essentiellen AVC-Patenten von 25 Patentinhabern" ließ das LG Düsseldorf als ausnahmsweise ausreichend gelten.[562] Die Veröffentlichungsnummer konkreter Patente aus dem umfangreichen Pool waren im Verletzungshinweis ebenso wenig genannt wie die konkrete Bezeichnung vermeintlicher Verletzungsprodukte.[563] Dieser Inhalt sei jedoch vor dem Hintergrund der Vorkorrespondenz zwischen der Muttergesellschaft der Beklagten und der Lizenzverwalterin sowie dem Verhalten der Muttergesellschaft nach dem Verletzungshinweis ausnahmsweise ausreichend.[564] Die Beklagte stelle nicht in Abrede, dass die Muttergesellschaft Kenntnis von den Poolpatenten sowie davon gehabt habe, dass der Standardlizenzvertrag bereits mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern abgeschlossen worden sei.[565] Dies sei auch deshalb naheliegend, weil auf der Internetseite der Patentverwertungsgesellschaft Informationen sowohl zu der Poolzusammensetzung mit einer Liste der Patentinhaber nebst zugehöriger Patente und zu den Lizenznehmern vorgehalten würden.[566] Für die Annahme des Bewusstseins der Muttergesellschaft über die Verwendung der Lehre des Klagepatents in den angegriffenen Mobiltelefonen und Tablets spreche eine Reihe von Anhaltspunkten.[567] Es bestehe bereits seit zwölf Jahren Kontakt im Hinblick auf den Standardlizenzvertrag zwischen der Rechtsabteilung des Konzerns und der Lizenzverwalterin, in dessen Verlauf derselbe dem Konzern auch mehrfach zur Kenntnis gemacht worden sei.[568] Zudem erwarb die Muttergesellschaft ihrerseits circa ein Jahr nach dem Verletzungshinweis in den Pool eingelagerte Patente, was eine gewisse Marktbeobachtung auch bereits im Vorfeld dieser Kaufentscheidung voraussetze.[569] Ein weiterer Anhaltspunkt ergebe sich schließlich daraus, dass die Muttergesellschaft auch im Rahmen der sich über vier Jahre anschließenden Lizenzvertragsverhandlungen nicht erkennbar weitergehende

[559] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 200; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 159; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 172, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem* und LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14.

[560] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 200; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 159; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 172, alle mit Verweis auf LG Mannheim, 29.1.2016 – 7 O 66/15.

[561] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 200; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 159; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 172.

[562] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 254–55; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 236–37; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 332–33; 9.11.20018 – 4a O 63/17, Rn. 254–255.

[563] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 254; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 236; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 332; 9.11.20018 – 4a O 63/17, Rn. 254.

[564] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 255; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 237; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 333; 9.11.20018 – 4a O 63/17, Rn. 255, zur Rolle der Muttergesellschaft siehe unten IX.A.1.a).

[565] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 256; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 238.

[566] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 256; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 238.

[567] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 257; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 239.

[568] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 257; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 239.

[569] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 257; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 239.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Informationen zur Ermittlung der Verletzungsfrage mehr angefordert habe.[570] In einer Gesamtschau ließen die Umstände die Annahme zu, dass die Muttergesellschaft in Kenntnis des Patentpools als solchem gewesen sei und um die Notwendigkeit einer Lizenznahme gewusst habe.[571]

Auch in den Parallelverfahren gegenüber einer anderen Implementiererin ließ das LG Düsseldorf in Anbetracht der Umstände eine gewisse Kulanz beim Kriterium der Verletzungsanzeige erkennen. Als maßgebliches Kriterium zog das LG Düsseldorf heran, dass die Beklagte neben den in einem Schreiben mit gleichem Inhalt wie im Parallelverfahren genannten Informationen keiner weiteren Angaben mehr bedurfte, um eine Entscheidung im Hinblick auf ihre grundsätzliche Lizenzwilligkeit zu treffen.[572] Der Inhalt des Schreibens sei vor dem Hintergrund der Vorkorrespondenz zwischen der Muttergesellschaft der Beklagten und der Patentverwalterin sowie dem Verhalten der Muttergesellschaft nach dem Verletzungshinweis ausnahmsweise ausreichend.[573] Zugleich spreche das Kommunikationsverhalten der Muttergesellschaft dafür, dass in der einschlägigen Branche offenkundig sei, dass der streitgegenständliche Standard bei der Nutzung der angegriffenen Geräte verwendet werde.[574] Die Muttergesellschaft hatte trotz Interessenbekundungen keine weitergehenden Informationen zu diesem angefordert, und damit zu erkennen gegeben, dass ihr eine Beurteilung ihrer Lizenzwilligkeit auf der Grundlage des bereits bestehenden Wissens möglich sei.[575]

Auch das LG Mannheim verlangte vom Patentinhaber einen Hinweis auf die dem Implementierer vorgeworfene Patentverletzung mittels Bezeichnung des SEP und der Angabe, auf welche Weise es verletzt sei.[576] Dabei müsse der Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbstständig prüfen zu können, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von externem oder internem technischen Sachverstand.[577] Die Kammer erachte als grundsätzlich ausreichend zur Erfüllung der Hinweispflicht die Vorlage von Claim-Charts, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellten, ohne dass dabei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssten.[578]

2. Zeitpunkt

In zeitlicher Hinsicht hat der Verletzungshinweis grundsätzlich vor der gerichtlichen Geltendmachung zu erfolgen.[579] Unschädlich für die Erfüllung der kartellrechtlichen Obliegenheiten des SEP-Inhabers sei auch, wenn der Verletzungshinweis gleichzeitig mit dem FRAND-Angebot stattfinde, wobei dem Patentbenutzer dann eine längere Reaktionsfrist eingeräumt werden müsse.[580] Auch wenn bei einem solchem Vorgehen die Lizenzierungsbitte übersprungen werde obwohl der EuGH grundsätzlich wechselseitig zu erfüllende Obliegenheiten vorsehe, erscheine es zulässig, wenn Verletzungsanzeige und FRAND-Angebot vom SEP-Inhaber zeitgleich an den Patentbenutzer übermittelt würden.[581] Der SEP-Inhaber bringe damit zum Ausdruck, dass er von einer Lizenzierungsbereitschaft ausgehe,

[570] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 257; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 239.

[571] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 258; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 240.

[572] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 345; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 267.

[573] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 255; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 237; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 333; 9.11.20018 – 4a O 63/17, Rn. 255

[574] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 347; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 269.

[575] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 346; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 268.

[576] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 122.

[577] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 122.

[578] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 122.

[579] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 61 – *Huawei/ZTE.*

[580] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 161; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 174.

[581] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 161; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 174.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

jedenfalls aber die Erklärung nicht abwarten möchte.[582] Sollte der Patentbenutzer tatsächlich lizenzwillig sein, spare ein solches Vorgehen unter Gewährung einer längeren Reaktionsfrist zur Prüfung der Verletzungsanzeige und des FRAND-Angebots nur Zeit ein.[583] Sei der Patentinhaber tatsächlich nicht lizenzwillig, so gehe es nur zu Lasten des SEP-Inhabers, wenn dieser ein tatsächlich gar nicht geschuldetes Lizenzvertragsangebot abgebe.[584]

Sogar weiter geht die kursorische Äußerung des OLG Düsseldorf im Urteil vom 22.3.2019, in einer Linie mit seinem früheren Hinweisbeschluss aus dem Jahr 2016.[585] Spätestens in der Klageerhebung liege die von der Klägerin geschuldete Verletzungsanzeige und in der Klageerwiderung, mit der die Beklagten in casu einen Anspruch auf Einräumung einer FRAND-Lizenz für sich reklamiert hätten, die Bitte um Lizenzerteilung.[586] Im Ergebnis setzte das OLG daher ohne weitere Umschweife mit der Obliegenheit der Klägerin auseinander, ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.[587] Ursprünglich begründete das OLG seine Rechtsprechung damit, dass die nach dem EuGH-Urteil „vor der gerichtlichen Geltendmachung" geforderten Erklärungen grundsätzlich im Rechtsstreit nachholbar sein dürften, weil ein Versäumnis grundsätzlich weder zu einer materiellen noch zu einer prozessualen Präklusion führen dürfe (siehe zu diesem Argument oben II).[588]

Der Verletzungshinweis könne nach Ansicht des LG Düsseldorf vom 11.7.2018 auch mittels Geltendmachung einer parallelen Schadenersatzklage stattfinden.[589] Es komme nicht darauf an, dass eine entsprechende Anzeige vor Erhebung jeglicher Klagen erfolgt sein müsse, sondern allein darauf, dass sie, wohl in gewissen Widerspruch zur Rechtsprechung des OLG, vor Erhebung der Unterlassungsklage ergehe.[590] Das vom EuGH aufgestellte Verfahrensprocedere solle die (ersten) Lizenzverhandlungen von dem Druck befreien, der von der gerichtlichen Geltendmachung des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs und einer etwaigen und gegebenenfalls mit schwerwiegenden wirtschaftlichen und unternehmerischen Folgen behafteten Verurteilung auf der Beklagtenseite laste.[591] Im vorliegenden Schadenersatzverfahren gehe es aber auf Grund der in casu kürzeren Restlaufzeit des Klagepatents in erster Linie um Ansprüche für die Vergangenheit, und zudem würde, wenn man auf den Zeitpunkt der Erhebung der Schadenersatzklage abstellen würde, der im deutschen Prozessrecht geltende Grundsatz der Unabhängigkeit der einzelnen Verfahren und die jeweilige Folge für die An- und Rechtshängigkeit mehrerer Klagen unterlaufen.[592]

Zuletzt bleibt zu bemerken, dass der Zugang einer den Anforderungen des EuGH genügenden Verletzungsanzeige vom SEP-Inhaber dargelegt und ggf. bewiesen werden müsse.[593]

C. Handeln durch einen Dritten

Die Verletzungsanzeige kann (wie auch das FRAND-Angebot) sowohl durch den SEP-Inhaber als auch durch eine verbundenen Konzerngesellschaft erfolgen.[594] Wie das LG Düsseldorf entschied, spiele es für die Erfüllung der FRAND-Obliegenheiten auf Seiten des SEP-Inhabers keine Rolle, ob die

[582] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 161; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 174.

[583] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 161; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 174.

[584] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 161; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 174.

[585] Vgl. OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 7.

[586] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 311 – *Improving Handovers*.

[587] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 312 – *Improving Handovers*.

[588] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 7, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 9.5.2016 – 15 U 35/16.

[589] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 163; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 176.

[590] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 163; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 176.

[591] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 163; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 176.

[592] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 163; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 176.

[593] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 162; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 175.

[594] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 160; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 173.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verletzungsanzeige oder das FRAND-Angebot vom Patentinhaber selbst oder von einer verbundenen Konzerngesellschaft komme, insbesondere wenn es sich dabei um die Muttergesellschaft handele.[595] Gerade bei kartellrechtlichen Fragestellungen sei es sinnvoll und anerkannt, Konzerne als Einheit anzusehen.[596]

In den verschiedenen Verfahren betreffend den AVC-Videostandard setzen sich die Kammern des LG Düsseldorf mit der Erbringung des Verletzungshinweises nicht durch den Patentinhaber selbst, sondern durch eine Lizenzverwalterin, der MPEG LA, auseinander. Dabei sei davon auszugehen, dass die Lizenzverwalterin Rechtshandlung im Zusammenhang mit der Gewährung von Lizenzen an dem Patentpool vornehmen könne.[597]

Die Kammer 4a stellte für die Herleitung der Kompetenz der MPEG LA zur Vornahme des Verletzungshinweises auf den gelebten Vertragsinhalt und ein Wissen der Beklagten (bzw. deren Mutterkonzern) ab. Der Vertragsinhalt des Standardlizenzvertrags regle in casu zwar das Vertragsverhältnis der MPEG LA und der jeweiligen Poolpatentinhaber nicht unmittelbar, da Reglungsgegenstand vielmehr das Vertragsverhältnis zwischen der MPEG LA und dem jeweiligen Lizenznehmer sei, er gebe jedoch einen Hinweis auf die Handlungsmöglichkeiten der MPEG LA im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe am Standard, und werde zudem auch gelebt.[598] Auch sei das Prozessverhalten des Infragestellens der Übertragung der kartellrechtlichen Pflichten auf die MPEG LA prozessual unbeachtlich, da der Mutterkonzern von einer der beiden Beklagten selbst Poolpatentinhaberin geworden sei, und mithin um die Handlungsmöglichkeiten der MPEG LA im Rahmen der Lizenzierung des Standards, insbesondere um die Einräumung eines Rechts zur Unterlizenzvergabe an die MPEG LA durch die Poolpatentinhaber, wisse.[599] Die Muttergesellschaft der anderen Beklagte sei über mehrere Jahre mit der MPEG LA zu Verhandlungszwecken in Kontakt gestanden, woraus eine Annahme der Beklagten spreche, dass die MPEG LA zu einer Lizenzvergabe rechtlich in der Lage sei.[600] Weiter würde es sich, das vielfache in Erscheinung Treten der MPEG LA im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe an dem streitgegenständlichen Standard berücksichtigend, als treuwidrig erweisen, wenn etwaige Patentinhaber sich im Verhältnis zu den Lizenznehmern auf die fehlende Handlungsmöglichkeit der MPEG LA berufen würden, und in Übereinstimmung mit der Lizenzierungspraxis berufe sich die Klägerin halt Poolpatentinhaberin im vorliegenden Verfahren auch gerade auf die Handlungsbefugnis der MPEG LA.[601]

Differenzierter argumentierte die Kammer 4b im Parallelverfahren. Zunächst sei das Bestreiten mit Nichtwissen im Grundsatz zulässig, da die Klägerin bei einer etwaigen Vollmachtserteilung bzw. Lizenzerteilung der Patentinhaberin an die Patentverwalterin nicht anwesend und insofern der Vorgang ihrer Wahrnehmung entzogen gewesen sei.[602] Dennoch war die Kammer nach § 286 Abs. 1 und §§ 371 ff. ZPO nach dem in weiten Teilen unstreitigen Parteivortrag der Überzeugung, dass die MPEG LA Lizenznehmerin der Klägerin sei und mit deren Zustimmung gehandelt habe oder zumindest die Klägerin spätestens mit Klageeinreichung das Handeln der Patentverwalterin genehmigt habe.[603] Die Berechtigung der Patentverwalterin ergebe sich bereits aus dem Text des übersendeten

[595] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 160; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 173.

[596] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 160; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 173.

[597] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 204; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 244; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 226; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 309; 9.11.2018 – 4ab O 63/17, Rn. 230.

[598] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 251–52; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 233–34; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 316–20; 9.11.2018 – 4ab O 63/17, Rn. 238–39.

[599] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 253; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 235.

[600] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 316; 9.11.2018 – 4ab O 63/17, Rn. 238.

[601] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 321; 9.11.2018 – 4ab O 63/17, Rn. 243.

[602] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 293; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 232.

[603] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 294; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 251; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 233; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 238.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Standardlizenzvertrages, wonach der Lizenzgeber (Klägerin) dem Lizenzverwalter eine Lizenz gewähre, um ihr die Lizenzverwaltung zu ermöglichen.[604] Auch habe keine der Konzerngesellschaften der Beklagten im Rahmen der vorgerichtlichen Lizenzverhandlungen jemals die Berechtigung der Lizenzverwalterin in Zweifel gezogen oder hinterfragt.[605] An die Lizenzverwalterin seien in casu auch die Lizenzgebühren zu entrichten und es werde deutlich, dass die Lizenzverwalterin im Interesse der Klägerin gehandelt habe und ihre Verwaltungstätigkeit auch die Anbahnung des Lizenzverhältnisses umfasse.[606] Zudem sei die Klägerin im Internet als Poolmitglied öffentlich genannt, so dass in den einschlägigen Industriekreisen bekannt gewesen sei, dass über die Poolverwalterin Lizenzen für die klägerischen SEPs erhalten werden könnten, weshalb keinerlei Anhaltspunkte bestehe, dass die Lizenzverwalterin nicht mit Wissen und in Kenntnis der Klägerin für diese in der Lizenzvergabe tätig sei.[607] Erschwerend komme bei einer der Beklagten in dem Parallelverfahren hinzu, dass deren Muttergesellschaft selbst seit langem Poolmitglied sei und diesbezüglich mit derselben Lizenzverwalterin in Kontakt stand und um deren Rolle und Handlungsbefugnisse im Rahmen der Lizenzierung des streitgegenständlichen Standards wusste, da die Lizenzverwalterin auch für sie selbst tätig geworden sei.[608] Spätestens mit der Klageeinreichung und mit ihrem Vortrag im Prozess hat die Klägerin das Handeln der Lizenzverwalterin genehmigt, da es sich damit deren Handeln zu eigen gemacht habe.[609] Insofern seien Handlungen eines Pool-Lizenzverwalters im Rahmen von Lizenzverhandlungen als solche der SEP-Inhaber, welche Mitglieder des Pools seien, anzusehen, und es bestünden nach § 286 ZPO nicht die geringsten Zweifel, dass die Lizenzverwalterin berechtigterweise für die Klägerin gehandelt habe.[610]

Schließlich war auch die Kammer 4c der Auffassung, die MPEG LA sei als Lizenzverwalterin berechtigt gewesen, Rechtshandlungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Lizenzen am Patentpool vorzunehmen, insbesondere den Abschluss von Lizenzverträgen und diesen vorbereitende notwendige Schritte.[611] Aus dem EuGH-Urteil ergebe sich kein einschränkendes Verständnis dahingehend, dass neben dem SEP-Inhaber nicht auch ein Dritter für diesen die rechtlich relevanten Handlungen vornehmen dürfe.[612] Auch wenn diese Möglichkeit in der Entscheidung nicht ausdrücklich vorgesehen sei, seien indes keine Gründe festzustellen, die gegen eine solche Handlungsvariante sprächen.[613] Denn im Ergebnis verbleibe es dabei, dass ein dem Patentinhaber zuzurechnendes und wirksames Tätigwerden vorliege und nur der Patentinhaber berechtigt und verpflichtet werde.[614] Schützenswerte Interessen des Lizenzsuchers würden dabei nicht beeinträchtigt, jedenfalls dann und solange, wie der Lizenzverwalter zu erkennen gebe, dass er nicht selbst Patentinhaber sei, sondern hinter ihm Patentinhaber stehen würden, für die er handle.[615] Dabei komme es auf die konkrete rechtliche Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Patentinhaber und dem Dritten/Lizenzverwalter nicht an, zumal verschiedene rechtliche Wege der Ausgestaltung denkbar seien, wie Treuhand oder Vertretung.[616] So könne die Fragestellung, ob eine Stellvertretung durch die Lizenzverwalterin in casu

[604] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 295; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 234; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 239.

[605] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 235.

[606] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 251; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 239.

[607] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 235.

[608] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 252; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 240.

[609] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 294, 297; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 233, 236.

[610] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 298; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 237.

[611] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 204.

[612] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 207.

[613] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 207.

[614] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 207.

[615] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 208.

[616] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 208.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

an den Vorschriften des deutschen Zivilrechts (§§ 164 ff. BGB, insb. an § 167 BGB) zu messen sei – wogegen bereits der Umstand sprechen dürfte, dass die die Stellvertretung begründenden Handlungen nicht in Deutschland stattfanden – gleichfalls offen bleiben.[617]

Im Übrigen liefere der Standardlizenzvertrag nähere Anhaltspunkte zur Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses zwischen der Klägerin als Patentinhaberin und der MPEG LA.[618] Anhand der Vertragspassagen[619] stehe fest, dass es sich bei der MPEG LA um einen Lizenzverwalter handele, der beauftragt worden sei, die im Pool befindlichen Patente im Wege einer Unterpoollizenz an interessierte Lizenznehmer bereitzustellen.[620] Unabhängig von einer abschließenden rechtlichen Klärung, auf welche Weise die MPEG LA tätig geworden sei, lasse sich die Klägerin an das abgegebene Lizenzangebot binden, und die MPEG LA habe ein Angebot unterbreitet, wie es von Anfang an dem Willen der Klägerin entsprochen habe.[621] Für die Abgabe eines wirksamen, (auch) der Klägerin zurechenbaren Angebots sei nur maßgeblich, dass überhaupt eine Verbindung zum Patentinhaber hergestellt werden könne.[622] Dies sei auch die entscheidende Ratio des EuGH-Urteils.[623]

Im Übrigen spreche vorliegend für die Zurechnung des Verhaltens der MPEG LA an die jeweiligen Patentinhaber auch die Vertragsregelung, worin es heiße, dass jeder Lizenzgeber verpflichtet sei, zu maßvollen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen Lizenzen zu erteilen.[624] Durch die aufgelisteten Adjektive würden gerade die FRAND-Bedingungen unmittelbar und ausdrücklich Gegenstand des Lizenzvertrags,[625] und ferner sei die Rolle der MPEG LA als Lizenzverwalterin in der Lizenz- und Elektronikbranche bekannt, weil darin gerade deren unternehmerische Zweck liege.[626]

Darüber hinaus verhalte sich die Beklagte treuwidrig, wenn sie sich auf die fehlende Handlungsbefugnis der MPEG LA berufe, und dürfe sich daher im Hinblick auf eine Befugnis der MPEG LA gemäß § 138 Abs. 4 ZPO nicht mit Nichtwissen erklären.[627] Es sei nicht mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift, der darin liege, die aufgrund der Unkenntnis unterlegene Position des Gegners zu verbessern, zu vereinbaren, der Gegenseite um jeden Preis ihre mangelnde Kenntnis zugutekommen zu lassen.[628] Vielmehr sei die Grenze dort zu ziehen, wo der Grundsatz von treugemäßem Verhalten nicht mehr gewahrt werde, was vorliegend der Fall sei, da der Konzern der Beklagten sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren auf Lizenzverhandlungen mit der MPEG LA eingelassen habe.[629] Durch den über Jahre hinweg aufrechterhaltenen Geschäftskontakt sei zugunsten der MPEG LA ein Vertrauenstatbestand dahingehend geschaffen worden, dass die gewechselte Korrespondenz tatsächlich in einen Vertragsschluss münden würde, da keine Zweifel an der Legitimation der MPEG LA bestanden hätten.[630] Die Beklagte dürfe sich aufgrund dessen nicht mehr auf solche Zweifel berufen, die erstmals im vorliegenden Verfahren geäußert worden seien.[631]

---

[617] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 208.

[618] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 209.

[619] Vgl. LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 210–15.

[620] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 216.

[621] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 217.

[622] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 217.

[623] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 218.

[624] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 219.

[625] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 219

[626] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 220.

[627] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 221, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 20.12.2017 – I-2 U 39/16, Rn. 143 und LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17.

[628] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 222.

[629] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 222–23.

[630] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 225.

[631] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4c O 12/17, Rn. 225.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

D. Adressat im Konzern

Verschiedentlich wurde vor den deutschen Gerichten diskutiert, ob die Hinweispflicht auch gegenüber einer Konzerngesellschaft der Beklagten erfüllt werden kann.

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf komme ein SEP-Inhaber seiner Hinweispflicht schon dann hinreichend nach, wenn der Hinweis gegenüber dem Mutterkonzern des angeblichen Verletzers erfolgte und – was regelmäßig der Fall sei – damit zu rechnen sei, dass dieser die betreffenden Tochtergesellschaften in den einzelnen Ländern, in denen das SEP benutzt werde, über die behauptete Patentverletzung informiere.[632] Ausgehend vom Zweck des Hinweises (siehe oben VIII.A) treffe den Patentinhaber keine Anzeigepflicht, wenn aufgrund der Umstände mit Sicherheit davon auszugehen sei, dass der angebliche Verletzer Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents habe und sein Einwand, der Kläger habe ihm dies nicht angezeigt, als Rechtsmissbrauch erscheine.[633] Unter diesen Voraussetzungen könne die Anzeige als bloße Förmelei unterbleiben.[634] Weise der Patentinhaber die Muttergesellschaft auf die Patentverletzung hin, so könne er mangels konkreter gegenteiliger Anhaltspunkte erwarten, dass letztere die Informationen an sämtliche Tochtergesellschaften weiterleite, die auf Märkten tätig seien, in denen nach der Behauptung des Patentinhabers mit angegriffenen Ausführungsformen angezeigte SEP benutzt, und sie auf diese Weise über die mögliche Patentverletzung in Kenntnis gesetzt würden.[635] Überdies sei diese Beurteilung auch deshalb interessengerecht, weil andernfalls zwischenzeitliche Veränderungen in der internen Organisationsstruktur des Konzerns, die dazu führten, dass eine andere Tochtergesellschaft vermeintlich patentverletzend tätig werde als die darauf bereits hingewiesene, zu Lasten des Patentinhabers gehen könnten, wenn die neue oder neu zuständige Tochtergesellschaft sich eventuell mit Erfolg darauf berufen könnte, dass ihr persönlich gegenüber kein Hinweis ergangen sei.[636]

Auch die Kammer 4c des LG Düsseldorf schloss sich dieser Ansicht mit den Entscheiden vom 11.7.2018 an. Gerade bei kartellrechtlichen Fragestellungen sei es sinnvoll und anerkannt, Konzerne als Einheit anzusehen.[637] Daraus folge auch, dass der Adressat der Verletzungsanzeige nicht zwingend die später verklagte Gesellschaft sein müsse, sondern es reiche im Allgemeinen aus, sich an die Konzernmuttergesellschaft zu wenden.[638]

Dem stimmten auch die Kammern 4a und 4b in den Parallelverfahren zu. Es sei unschädlich, dass die relevanten Schreiben zwischen der Lizenzverwalterin und der Muttergesellschaft der Beklagten ausgetauscht worden seien.[639] Sofern auf Seiten des Patentbenutzers sichergestellt sei, dass eine der Muttergesellschaft übersandte Verletzungsanzeige konzernintern an die jeweils betroffenen Tochtergesellschaften weitergeleitet werde, bedürfe es keiner formalen Benachrichtigung an sämtliche Tochtergesellschaften.[640] Bereits die Konzernzugehörigkeit begründe in Ermangelung gegenteiliger Anhaltspunkte die berechtigte Annahme, dass die betroffenen Tochtergesellschaften

---

[632] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[633] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[634] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem*; im Ansatz so auch schon OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 5.

[635] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[636] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 175 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[637] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 160; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 173.

[638] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 160; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 173; 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 227, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem* und LG Düsseldorf, 4.11.2015 – 4a O 93/14.

[639] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 235; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 216.

[640] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 236; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 217; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 298; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 220, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

informiert würden.[641] Im Übrigen rechtfertige vorliegend aber auch die Vorkorrespondenz der Parteien das Vertrauen darauf, dass Lizenzierungsfragen betreffende Informationen innerhalb des Konzerns der Beklagten weitergeleitet würden.[642] Der Mutterkonzern habe durch Kommunikation bzw. Anscheinserweckung eines konzernzuständigen IPR-Managers als Ansprechpartner das Vertrauen darauf geschürt, dass die Lizenzverwalterin mit dem für die Verhandlung einer Konzernlizenz richtigen Ansprechpartner in Kontakt stehe.[643]

In Übereinstimmung mit der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung bestehe gar keine Anzeigepflicht, wenn aufgrund der Umstände mit Sicherheit davon auszugehen sei, dass der angebliche Verletzer Kenntnis von der Benutzung des Klagepatents habe und sein Einwand, der Kläger habe ihm dies nicht angezeigt, als Rechtsmissbrauch erscheine, wobei regelmäßig davon ausgegangen werden könne, dass die Muttergesellschaft ihre Tochtergesellschaften informiere.[644] Von der gleichen Sachlage müsse (betreffend eine der beiden Beklagten) ausgegangen werden, wenn eine Tochtergesellschaft bzw. ein bestimmter Mitarbeiter ebendieser in jahrelangen Lizenzverhandlungen eine führende Rolle eingenommen und in erster Linie mit den entsprechenden Ansprechpartnern auf der Klägerseite verhandelt habe.[645] Betreffend die andere Beklagte zeige sich, dass die Weiterleitung der Kommunikation grundsätzlich stattgefunden habe bereits darin, dass sich auf eine an die Muttergesellschaft gerichtete E-Mail der zuständige IPR-Manager im Konzern der Beklagten gemeldet habe.[646] Insofern könne die hinweisende Partei davon ausgehen, dass die Muttergesellschaft die für Verhandlungen der Konzernlizenz richtige Ansprechpartnerin gewesen sei und die Muttergesellschaft ihre 100%-igen Tochter- und Vertriebsgesellschaften entsprechend informierte.[647]

[641] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 236; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 217; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 298; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 220, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[642] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 237; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 218; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 299; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 221.

[643] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 241–42; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 222–23; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 299–307; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 221–229.

[644] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 288; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 246; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 227; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 234, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[645] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 288; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 227; 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 227.

[646] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 247; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 235.

[647] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 247; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 235.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

IX. Lizenzbereitschaftserklärung des Standard-Implementierers

A. Inhalt und Zeitpunkt

1. Lizenzbereitschaft

a) Inhalt

Nach dem OLG Düsseldorf im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 genüge zur Annahme der Lizenzbereitschaft des Standard-Implementierers eine pauschale Erklärung, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen nehmen zu wollen.[648] Enthalte die Erklärung des Implemenierers Angaben zu begehrten Lizenzbedingungen, dürften diese die erklärte Lizenzbereitschaft nur dann entkräften, wenn sie den sicheren Schluss zuließen, dass der Patentbenutzer in Wahrheit keine Lizenz nehmen wolle, so dass sich die Abgabe eines Angebots durch den Patentinhaber vor vornherein erübrige (dazu unten IX.A.2).[649]

Im Entscheid vom 30.3.2017 bestätigte das OLG Düsseldorf seine im Hinweisbeschluss angedeutete Rechtsprechung. Inhaltlich seien an die Lizenzierungsbitte keine hohen Anforderungen zu stellen.[650] Es genüge eine formlose und pauschale Erklärung des Lizenzsuchers, in der seine Lizenzwilligkeit eindeutig zum Ausdruck komme, wobei selbst schlüssiges Handeln je nach Lage des Einzelfalls ausreichen könne.[651] Insbesondere müsse der Lizenzsucher in diesem Stadium des Lizenzierungsprocedere (noch) keine Ausführungen zum Inhalt der von ihm gewünschten Lizenz machen.[652]

Das LG Mannheim hielt weitergehend fest, selbst wenn im Zuge der Verhandlungen zwischen den Parteien vereinzelt eine Zahlung von Lizenzgebühren in einzelnen Aussagen gegenüber der Klägerin abgelehnt worden sein sollte, so habe sich die Patentbenutzerin nicht gänzlich lizenzunwillig gezeigt, da sie in einer Vielzahl von Treffen einen möglichen Lizenzvertrag diskutiert habe.[653] Zudem sei aus Sicht der Kammer zu berücksichtigen, dass die Beklagte bzw. ihre Muttergesellschaft – wenngleich erst nach Klageerhebung – ein Gegenangebot unterbreitet und einen namhaften Betrag hinterlegt habe, der nahezu das Dreifache des Betrages abdecke, der sich auf der Grundlage der gleichfalls geleisteten Rechnungslegung und des Gegenangebots ergebe.[654] Maßgeblich sei, dass das Gesamtverhalten der Beklagten und ihrer Muttergesellschaft nicht den Schluss zulasse, es handele sich um einen von vornherein lizenzunwilligen Verhandlungspartner, dem gegenüber keine Verpflichtung bestehe darzulegen, aus welchen tatsächlichen Gründen die Angebote des SEP-Inhabers FRAND-Grundsätzen entsprächen.[655]

Mit Entscheid vom 11.7.2018 wendete auch das LG Düsseldorf die zuvor vom OLG entwickelten Kriterien an.[656] So beständen in casu keine Zweifel an der Einhaltung der Anforderungen an die Lizenzwilligkeit der Beklagten, auch wenn keine expliziten Lizenzbereitschaftserklärungen für das Klagepatent abgegeben worden seien.[657] Indem die Beklagte bereits ihre generelle Lizenzbereitschaft

[648] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 9.

[649] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 9.

[650] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 183 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14 – *Hochfrequenzanteil.*

[651] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 183 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[652] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 183 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[653] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 131 – *Funkstation*.

[654] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 131 – *Funkstation*.

[655] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 131 – *Funkstation*.

[656] Vgl. Wortlaut von LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 166; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 179.

[657] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 169; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 182.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

im Hinblick auf andere Patente erklärt und zudem das von der Klägerin geforderte Gegenangebot abgegeben und Sicherheit geleistet habe, sei ausreichend zu erkennen gegeben, dass an dem Abschluss einer Lizenz auch am Klagepatent Interesse bestehe, was die Klägerin auch nicht in Zweifel gezogen habe.[658] Darüber hinaus seien in der Folgezeit keine Umstände zutage getreten, die einen zwischenzeitlichen Wegfall der Lizenzwilligkeit der Beklagten annehmen ließen, sondern die Beklagte habe durchgehend ihren Willen zum Ausdruck gebracht, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abschließen zu wollen.[659] Durch Unterbreitung eines Gegenangebots und der Sicherheitsleistung im Parallelverfahren habe die Beklagte die Ernsthaftigkeit ihrer Lizenzbereitschaft bekräftigt.[660] Ob das Gegenangebot der Beklagten ihrerseits FRAND sei, könne dahinstehen, da die Klägerin insoweit vorleistungspflichtig sei.[661] Abweichungen der Beklagten von FRAND-Grundsätzen seien allenfalls dann beachtlich, wenn sich daraus die ernsthafte und endgültige Weigerung, eine Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, ableiten ließe, was vorliegend nicht der Fall sei.[662]

Weiter begründe der Vorwurf der vermeintlichen Verweigerung zur Unterzeichnung einer angemessenen Geheimhaltungsvereinbarung keine Zweifel an der fortdauernden Lizenzbereitschaft der Beklagten (zu Mitwirkungobliegenheiten allgemein siehe unten IX.C), denn es fehle bereits an Darlegungen der Klägerin, dass es für die Vorlage der Vergleichslizenzverträge einer Geheimhaltungsvereinbarung bedürfe und die Klägerin auf den Abschluss einer solchen angewiesen sei (vgl. dazu unten XI.B.1.c)3)).[663] Die Beklagten hätten auf diesen Umstand mehrfach schriftsätzlich hingewiesen, so dass ihnen einen etwaige unterstellte Weigerung des Abschlusses einer Geheimhaltungsvereinbarung, welche eine erhebliche Vertragsstrafe zum Gegenstand habe, nicht vorgeworfen werden könne.[664]

Auch lasse das Infragestellen der Berechtigung der Klägerin zur Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit im Parallelverfahren die Lizenzbereitschaft nicht entfallen, da das Bestreiten von Aktivlegitimation ein zulässiges prozessuales und rechtliches Mittel darstelle, wenn sich für die Beklagte die Berechtigung der Klägerin nicht unweigerlich aus ihren Darlegungen folgern lasse.[665] Gleiches gelte auch für den Umstand, dass die Beklagte gegen die Klägerin vor dem irischen High Court in Dublin Klage eingereicht habe, mit der sie die Feststellung begehre, dass das vorhergehende Angebot kein FRAND-Angebot gewesen sei und das Gegenangebot ihrerseits FRAND-Bedingungen entsprochen habe.[666] Unabhängig davon, dass dem irischen Verfahren bereits aus dem Umstand, dass es das aktuelle Lizenzvertragsangebot nicht zum Verfahrensgegenstand habe, für den hiesigen Rechtsstreit keine Bedeutung zukomme, zeige die Einleitung des irischen Verfahrens gerade, dass die Beklagte Interesse an einer Lizenz zu FRAND Bedingungen habe.[667]

Das LG Düsseldorf griff die Rechtsprechung des OLG auch im Entscheid vom 9.11.2018 auf, und so entschied die Kammer 4a, dass an die Lizenzbereitschaftserklärung inhaltlich keine hohen Anforderungen zu stellen seien, sie pauschal sowie formlos geschehen könne, das Verhalten des

[658] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 169; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 182.

[659] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 170; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 183.

[660] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 184.

[661] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 184.

[662] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 184, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[663] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 172, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16 – *Kommunikationsvorrichtung*.

[664] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 172.

[665] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 171; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 185, mit Verweis auf OLG Düsseldorf 18.7.2017 – I-2 U 23/17.

[666] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 186.

[667] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 186.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Patentbenutzers jedoch den eindeutigen Willen zur Lizenznahme erkennen lassen müsse.[668] Von der Lizenzbereitschaftserklärung dürfe in Folge nicht abgewichen werden, so dass diese auch noch dann Bestand haben müsse, wenn der Patentinhaber sein FRAND-Angebot abzugeben habe.[669] Inhaltliche Ausführungen, derer es nicht bedürfe, könnten sich dann als schädlich erweisen, wenn der Patentinhaber auf ihrer Grundlage annehmen müsse, dass eine Bereitschaft zur Lizenznahme nur unter ganz bestimmten, nicht verhandelbaren Bedingungen bestehe, die nicht FRAND seien und auf die sich der Schutzrechtsinhaber deshalb nicht einlassen müsse.[670] Jedoch seien an die Feststellung eines solchen Tatbestandes hohe Anforderungen zu stellen, und die Angabe zu begehrten Lizenzbedingungen entkräfte die Annahme der Lizenzbereitschaft nur dann, wenn sie den sicheren Schluss zulasse, dass der Patentbenutzer in Wahrheit keine Lizenz nehmen möge (siehe IX.A.2).[671] Dabei sei der Gesamtkontext zu berücksichtigen.[672]

Das LG Düsseldorf zog für dessen Beurteilung auch die Erkennbarkeit der Lizenzbereitschaft für die Lizenzverwalterin (im Namen der Klägerin) heran.[673] Danach sei bereits ausreichend, dass der Benutzer, der mit der Lizenzverwalterin bereits im Vorfeld der als Verletzungsanzeige verstandenen E-Mail in Verhandlungen gewesen sei, die weitere Besprechung der Angelegenheit anregte, was dahingehend zu verstanden werden müsse, dass die bereits begonnenen Verhandlungen fortgeführt werden sollten.[674] Auch zog das LG die Wahrnehmung und das Handeln der Lizenzverwalterin insofern heran, als diese selbst das Verhalten des Mutterkonzerns offenbar nicht als endgültige Lizenzverweigerung verstanden haben könne.[675] Dies komme darin zum Ausdruck, dass obwohl der Mutterkonzern nur einzelne, unternehmensbezogene Lizenzen (statt einer konzernweiten Lizenz) und Sonderkonditionen für den chinesischen Markt verlangt habe, die Lizenzverwalterin gerade ein konkretes Vertragsangebot für die Lizenzierung des Standards in Richtung der Muttergesellschaft versandt habe und sich Lizenzierungsgespräche über zwei Jahre anschlossen hätten.[676]

Das LG Düsseldorf lies beispielsweise in den Entscheiden vom 12.12.2018 bereits die Bitte um ein Telefonat als Rückantwort auf die Verletzungsanzeige als schlüssiges Handeln, da eine Lizenzbereitschaft signalisierend, gelten.[677]

b) Zeitpunkt

In zeitlicher Hinsicht müsse die Lizenzbereitschaft nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf ohne Verzögerung erfolgen, sei jedoch grundsätzlich nachholbar.[678] Weil es dem Benutzer untersagt sei, den Abschluss eines Lizenzvertrages mittels einer Verzögerungstaktik hinauszuschieben, müsse er – unter Verweis auf die angemessene Reaktionsfrist nach dem EuGH-Urteil[679] gewissermaßen als *argumentum*

[668] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 349; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 271, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 183 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[669] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 349; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 271, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 195 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[670] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 349; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 271, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 197 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[671] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 349; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 271, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 9.

[672] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 351; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 273, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[673] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 350; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 272.

[674] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 352; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 274.

[675] Vgl. LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 353; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 275.

[676] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 353; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 275.

[677] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 308; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 247.

[678] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 10.

[679] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 65 – *Huawei/ZTE.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

a fortiori erst recht – binnen angemessener Frist auf den Verletzungshinweis des Patentinhabers reagieren.[680] Die maßgebliche Frist sei nicht starr zu bestimmen, sondern es seien vielmehr die Umstände des Einzelfalls entscheidend, wobei die Reaktionsfrist namentlich vom Grad der Detaillierung des Verletzungshinweises abhängen könne.[681] Ein Hinweis mit überobligatorisch umfangreichen Ausführungen und Erläuterungen zu den Einzelheiten des mutmaßlichen Verletzungstatbestandes könne unter Umständen dem Adressaten bzw. seinen Konzerngesellschaften eine schnellere Reaktion abverlangen, weil deren eigener Prüfungsaufwand dadurch gegebenenfalls geringer ausfallen könne.[682] Auch im Fall, dass sich der SEP-Inhaber im Rahmen seines Hinweises lediglich auf die Angabe des absolut Notwendigen beschränke, sei – jedenfalls in aller Regel – ein Zeitablauf von mehr als drei Monaten (vgl. LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14 – *Stochastisches Rauschen*) oder gar von fünf Monaten (vgl. LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14 – *Hochfrequenzanteil*) nicht mehr angemessen, so dass dem Patentinhaber kein längeres Zuwarten mehr zumutbar sei und er folglich in einer solchen Situation unmittelbar (scil. ohne vorheriges FRAND-Angebot) Klage erheben könne, ohne befürchten zu müssen, dass die Klageerhebung als solche als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV bewertet werden würde.[683]

Auch wenn das OLG Düsseldorf die Lizenzbereitschaftserklärung grundsätzlich innert angemessener Frist verlangt, legte es für die Beurteilung, ob eine hinreichende Lizenzbereitschaftserklärung vorliegt, den Zeitpunkt der Klageerhebung zugrunde.[684] Die betreffende Reaktion der Beklagten (in casu erst etwa ein Jahr nach der erstmaligen Verletzungsanzeige der Klägerin) genüge zwar nicht den erläuterten zeitlichen Anforderungen an die Lizenzwilligkeit des vermeintlichen Patentverletzers, was umso mehr gelte, als nicht dargelegt sei, dass und warum es der Beklagten nicht möglich oder zumutbar gewesen sein solle, die Verletzung der Patente des Portfolios und ihren Willen zur Lizenznahme deutlich früher zu klären.[685] Im Ergebnis sei dies gleichwohl unschädlich, da der nicht fristgerechte Vollzug eines notwendigen Schrittes einer Partei keine materielle Präklusion nach sich ziehe (siehe dazu oben II).[686] Dies gelte gerade auch für die Lizenzwilligkeit des Patentverletzers, da die materiell-rechtliche Pflicht des SEP-Inhabers gemäß Art. 102 AEUV i.V.m. seiner FRAND-Zusage von einer zögerlichen Erklärung der Lizenzwilligkeit unangetastet bleibe.[687] Die Säumnis führe nicht zu einem (erst recht nicht dauerhaften) Verlust des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes.[688] Wenn daher der Implementierer zwar außerhalb der an sich angemessenen Reaktionsfrist, aber noch vor Klageerhebung die Erklärung seiner Lizenzbereitschaft nachhole, sei das außerprozessuale Lizenzierungsprocedere folglich fortzusetzen und damit der SEP-Inhaber nunmehr wieder verpflichtet, seinerseits den nächsten Schritt des Lizenzierungsprocedere voranzugehen und dem Benutzer ein FRAND-Lizenzangebot zu machen.[689]

Sogar einen Schritt weiter ging das OLG Düsseldorf, gewissermaßen spiegelbildlich zur Verletzungsanzeige, in seinem Entscheid vom 22.3.2019. Danach könne die Lizenzierungsbitte auch in

[680] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 182 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[681] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 182 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[682] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 182 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14 – *Hochfrequenzanteil*.

[683] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 182 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[684] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 184 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[685] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 187 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[686] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 187–89 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[687] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 190 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[688] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 190 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[689] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 190 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

der Klageerwiderung selbst liegen, indem die Beklagten einen Anspruch auf Einräumung einer FRAND-Lizenz für sich reklamiert hätten.[690]

In zeitlicher Hinsicht führte das LG Düsseldorf außerdem im Entscheid vom 11.7.2018 aus, dass es dem Benutzer untersagt sei, den Abschluss eines Lizenzvertrages mittels einer Verzögerungstaktik hinauszuschieben und er daher – dem Gedanken des willigen und redlichen Lizenznehmers folgend – binnen angemessener Frist auf den Verletzungshinweis zu reagieren habe.[691] Dabei verwies das LG auf den Wortlaut des OLG Urteils vom 30.3.2017.[692]

Im Rahmen der Betrachtung des Gesamtverhalten der Beklagten zog das LG Mannheim im Entscheid vom 10.11.2017 auch Umstände zur Beurteilung der Lizenzbereitschaft heran, die sich erst nach Klageerhebung ergeben hatten. Im vorliegenden Fall hatte die Muttergesellschaft erst nach Klageerhebung ein Gegenangebot unterbreitet und einen namhaften Betrag hinterlegt.[693] Zwar lägen diese Umstände nach Klageerhebung, indes werte die Kammer das Verhalten als Indiz auch für die grundsätzliche Lizenzwilligkeit jedenfalls in einem solchen Maße, dass die nähere Erläuterung der kaufmännischen Bedingungen des FRAND-Angebots der Patentbesitzerin, insbesondere zur Höhe der verlangten Lizenzgebühr, nicht obsolet gewesen wäre.[694]

2. Grenze zur Lizenzverweigerung

Nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf sei die Grenze zur Lizenzverweigerung trotz formeller Lizenzbereitschaftserklärung bei gleichzeitiger Abgabe eines FRAND-Angebots des Lizenzsuchers dort zu ziehen, wenn die durch den Benutzer begehrten Lizenzbedingungen den sicheren Schluss zuließen, dass der Patentbenutzer in Wahrheit keine Lizenz nehmen möchte.[695] Für die Feststellung einer in diesem Fall lediglich formal erklärten Lizenzbereitschaft gälten hohe Anforderungen, die regelmäßig nur erfüllt sein dürften, wenn das Verhalten des Patentbenutzers als ernsthafte und endgültige Lizenzverweigerung zu bewerten sei.[696]

Im Urteil vom 30.3.2017 hatte das OLG dann die Chance, seine Anforderungen an die Grenze zur Lizenzverweigerung zu präzisieren. Fraglich war, ob die zuvor festgestellte Lizenzwilligkeit des Benutzers zwischenzeitlich wieder weggefallen sei, indem der Benutzer sie unter die Bedingung einer rechtskräftigen Entscheidung zur Verletzung und/oder zum Rechtsbestand des SEP gestellt habe.[697] Zwar dürfe der Benutzer seine Lizenzwilligkeit unter solch eine Bedingung nicht stellen.[698] Doch auch wenn eine Äußerung der Beklagten objektiv so verstanden werden könne, als stelle sie damit in diesem Sinne unzulässige Bedingungen auf, lasse sich daraus gleichwohl nicht ableiten, dass die Beklagte schlechthin nicht lizenzwillig sei.[699] Die betreffende Äußerung (in casu eine E-Mail) dürfe nämlich nicht isoliert, sondern müsse in einem Gesamtkontext betrachtet werden wobei das gesamte Verhalten der Beklagten im Rahmen des Lizenzierungsprocedere zu würdigen sei und auch der weitere Verlauf der

[690] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 311 – *Improving Handovers*. Jedoch findet sich entgegen der gleichen Bemerkung betreffend die Verletzungsanzeige keine Entsprechung für die Lizenzbereitschaftserklärung bereits in OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15.

[691] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 165; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 178.

[692] Vgl. LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 165; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 178.

[693] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 131 – *Funkstation.*

[694] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 131 – *Funkstation.*

[695] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 9.

[696] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 9.

[697] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 195 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[698] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 197 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14 – *Hochfrequenzanteil.*

[699] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 197–98 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verhandlungen im Anschluss an die betreffende E-Mail einbezogen werden müsse.[700] Insofern ergebe sich, dass die betreffenden Ausführungen in der E-Mail nach dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont gerade nicht als das „letzte Wort" der Beklagten aufzufassen gewesen seien und die Klägerin folglich keinen Anlass zur Annahme gehabt habe, dass die Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebots ohnehin keine Aussicht mehr auf eine Annahme durch die Beklagte hätte.[701] Dass die Beklagte weiterhin lizenzwillig sei, ergebe sich aus dem nachfolgenden E-Mailverkehr.[702] Zuletzt habe die Beklagte noch einmal ihre Lizenzbereitschaft dadurch bekräftigt, dass sie der Klägerin per Schriftsatz ein neues Gegenangebot unterbreitet habe.[703] Ob dieses neuerliche Gegenangebot und/oder die früheren (überobligatorischen) Gegenangebote ihrerseits FRAND seien/gewesen seien, könne dahinstehen, weil die Klägerin insoweit „vorleistungspflichtig" sei (siehe dazu unten XI.C.2).[704] Abweichungen der Beklagten von den FRAND-Grundsätzen wären allenfalls dann beachtlich, wenn sich daraus eine ernsthafte und endgültige Weigerung (vgl. § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB), eine Lizenzvereinbarung zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, ableiten ließe.[705] Dafür reiche es nicht aus, dass einzelne Verhandlungspositionen der Beklagten möglicherweise nicht FRAND seien.[706]

Auch die Kammer 4a des LG Düsseldorf kam auf die Rechtsprechung des OLG zurück. Anhand der vom OLG entwickelten Kriterien sei der Gesamtkontext zu berücksichtigen.[707] Es sei bereits ausreichend, dass der Benutzer, der mit der Patentinhaberin bereits im Vorfeld der als Verletzungsanzeige verstandenen E-Mail in Verhandlungen war, die weitere Besprechung der Angelegenheit anregte und die bereits begonnenen Verhandlungen fortgeführt werden sollten.[708] Das LG zog für die Beurteilung der Lizenzbereitschaft auch das Verständnis der Lizenzverwalterin bei (zu subjektiven Elementen bereits oben). Dass auch die Lizenzverwalterin das Verhalten der Benutzerin, insbesondere deren Bestreben zum Abschluss nur einzelner, unternehmensbezogener Lizenzen bzw. für Sonderkonditionen hinsichtlich des chinesischen Marktes bis dahin nicht so verstand, dass diese schlechthin lizenzunwillig sei, komme auch darin zum Ausdruck, dass die Lizenzverwalterin trotz der Forderungen ein konkretes Vertragsangebot für die Lizenzierung des Standards versandt habe und sich daran über ein Jahr lang Lizenzierungsgespräche angeschlossen hätten.[709]

Auch die Kammer 4b wandte mit Entscheid vom 12.12.2018 die Kriterien des OLG Düsseldorf zur Lizenzverweigerung an, ließ das Ergebnis aber dahinstehen mangels eines Gegenangebots der Muttergesellschaft (siehe dazu unten XII.B.2.)[710] Immerhin artikulierte die Kammer erhebliche Zweifel an der Lizenzwilligkeit der Muttergesellschaft, da ein einem Zeitraum von ca. vier Jahren überhaupt keine Lizenzwilligkeit erkennbar gewesen sei.[711] Auch wenn keine hohen Anforderungen an die Lizenzierungsbitte zu stellen seien, könne eine erklärte Lizenzbereitschaft entkräftet werden, wenn

[700] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[701] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[702] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[703] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[704] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem*, wobei dieser Grundsatz in der *FRAND-Einwand*-Rechtsprechung des BGH differenziert worden ist, vgl. dazu *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>.

[705] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[706] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[707] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 351; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 273, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 198 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[708] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 352; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 274.

[709] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 353; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 275.

[710] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 256; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 244.

[711] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 256; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 244.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

das Verhalten des Verletzers den sicheren Schluss zulasse, dass er in Wahrheit keine Lizenz nehmen möchte, so dass eine ernsthafte und endgültige Lizenzverweigerung vorliege.[712]

Nach diesen Grundsätzen trete ein über Jahre hinweg ambivalentes Verhalten der Verletzerin zu Tage.[713] Dem anfänglichen Andeuten von Lizenzwilligkeit sei eine jahrelange, einseitig geführte Korrespondenz seitens der Lizenzverwalterin letztlich ohne Austausch von Sachargumenten, und ein Beginn inhaltlicher Gespräche erst nach mehr als vier Jahren gefolgt.[714] So habe die Muttergesellschaft selbst nach Eintritt in den Patentpool als Lizenzgeberin auch nach wiederholten Aufforderungen der Lizenzverwalterin gerade keine Lizenz genommen, so dass sogar die Mitglieder des Patentpools die Statuten dahingehend änderten, dass Lizenzzahlungen gegenüber Mitgliedern einbehalten würden, die nicht selbst eine Lizenz am Patentpool nähmen.[715] Die Muttergesellschaft habe Meetings scheitern lassen wegen Terminkollisionen, und habe Umstrukturierungen und Zuständigkeitswechsel angeführt, wobei monatelang keine Korrespondenz erfolgt sei und die Lizenzverwalterin mehrfach nachfassen und erinnern haben müsse, bis sie irgendeine Rückantwort erhalten habe, weshalb die Kammer in diesem Zeitraum keine ernsthaften Verhandlungen erkennen könne.[716] Auffällig sei, dass die ganze Zeit über nicht in der Sache verhandelt worden sei, und aus den E-Mails werde deutlich, dass die Muttergesellschaft offenbar zunächst nur einige Produktgruppen und dann jedenfalls die Produktgruppen getrennt zu verhandeln beabsichtigt habe.[717] Schließlich habe die Muttergesellschaft erst nach neuem Start der Verhandlungen fast fünf Jahre nach dem Verletzungshinweis und erstem Angebot (wieder) ernsthafte Anstalten in Lizenzverhandlungen zu treten gezeigt.[718] Es lasse sich darüber hinaus nicht mit dem Bild der redlich verhandelnden Vertragsparteien – als Maßstab des EuGH Urteils – in Übereinstimmung bringen, wenn im Rahmen der Korrespondenz bestimmte angebliche Vorbehalte überhaupt nicht angesprochen würden, sondern das erste Mal im Rechtsstreit Erwähnung fänden.[719] Der vorliegende Einzelfall stelle letztlich eine über Jahre praktizierte Lizenzverweigerung dar.[720]

Vor dem Hintergrund des angestrebten Zustandes, dass ernsthafte vorprozessuale Verhandlungen zwischen den Parteien stattfinden sollten, habe die Kammer große Zweifel, dass das Verhalten der Muttergesellschaft überhaupt als ausreichend Lizenzwillig angesehen werden könne.[721] Denn faktisch bewege sich die Muttergesellschaft seit der Verletzungsanzeige fünf Jahre frei im Standard ohne Lizenzen abzuführen.[722] Dabei handele es sich bereits um einen Zeitraum, der in vergleichbaren Fällen die Laufzeit eines Lizenzvertrages abdecke.[723] Inwieweit die Erklärung der Lizenzwilligkeit nach Erhebung der Klage nachgeholt werden könne erscheine fraglich, da sie im vorliegend entschiedenen Fall offensichtlich erst durch den Druck des gerichtlichen Vorgehens gegen die Beklagte erfolgt sei.[724]

[712] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 257; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 245, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 9.

[713] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 258; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 246.

[714] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 258; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 246.

[715] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 262–63; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 250–51.

[716] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 263; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 251.

[717] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 264; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 252.

[718] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 253.

[719] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 258; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 246.

[720] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 259; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 247.

[721] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 266; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 254.

[722] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 266; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 254.

[723] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 266; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 254.

[724] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 266; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 254.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Letztlich könne die Frage der Lizenzwilligkeit aber dahinstehen, da es gleichsam auch an einem Gegenangebot der Beklagten, das FRAND-Grundsätzen entspreche, fehle.[725]

Schließlich bemerkte das LG Mannheim am Rande seines Entscheides vom 28.9.2018, eine fehlende Reaktion der Beklagten auf das Lizenzvertragsangebot des SEP-Inhabers, das mangels Einräumung einer angemessenen Reaktionszeit zur Prüfung und Formulierung eines Gegenangebots nicht den zeitlichen Anforderungen an FRAND entspreche (dazu unten XI.A.4), rechtfertige nicht die Annahme, dass die Erklärung der Lizenzbereitschaft nicht ernst gemeint gewesen sei und die Beklagte beziehungsweise ihre Muttergesellschaft eine Verzögerungstaktik verfolge.[726]

B. Lizenzbereitschaftserklärung im Konzern

Betreffend die Lizenzbereitschaftserklärung im Konzern genüge es nach dem OLG Düsseldorf, wenn im Fall einer Verletzungsanzeige gegenüber dem Konzern sich entweder die das SEP benutzende(n) Tochtergesellschaft(en) oder die Muttergesellschaft lizenzwillig zeige und sich aus der Lizenzbereitschaftserklärung ergebe, dass der Wille zur Lizenznahme die Tochtergesellschaften einschließe und auch die Benutzung des Klagepatents umfasse.[727] In casu legte das OLG den objektiven Inhalt des E-Mailverkehrs mit der Muttergesellschaft der Beurteilung zugrunde, ob auch eine Lizenzwilligkeit der Tochtergesellschaft bestand.[728]

Auch das LG Mannheim legte die beklagte Tochter- und ihre Muttergesellschaft für die Lizenzbereitschaftserklärung ohne weiteren Kommentar als Einheit zugrunde.[729]

C. Weitere Mitwirkungsobliegenheiten des Patentbenutzers?

Fraglich bleibt, ob den Standard-Implementierer weitergehende Mitwirkungsobliegenheiten treffen, beziehungsweise eine Verweigerung der Mitwirkung als Lizenzverweigerung zu sehen wäre. Das LG Düsseldorf hielt im Entscheid vom 13.7.2017 diesbezüglich fest, eine Verzögerungstaktik des Verletzers in der Zeit zwischen der Lizenzbereitschaftserklärung des Patentbenutzers und der Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebots durch den SEP-Inhaber erlaube grundsätzlich nicht den Schluss, dass eine Lizenzbereitschaftserklärung nicht wirksam sei.[730] Vielmehr seien solche Gesichtspunkte bei der Beurteilung des Angebots des SEP-Inhabers zu berücksichtigen nachdem dieses unterbreitet worden sei, denn nach der Erklärung seiner Lizenzbereitschaft gerate der Verletzer erst nach Erhalt eines FRAND-Angebots wieder unter Zugzwang.[731] Bis zur Unterbreitung des Angebots könnten den Patentbenutzer neben der Lizenzbereitschaftserklärung aber weitere Mitwirkungsobliegenheiten treffen, sofern solche Handlungen für die Formulierung des FRAND-Angebots und dessen Begründung zwingend erforderlich seien.[732] So könne unter Umständen geboten sein, dass der Verletzer ein

[725] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 266; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 254.

[726] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 116, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 88 – *Huawei/ZTE.*

[727] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 185 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[728] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 186 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[729] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 131 – *Funkstation*, vgl. auch schon Rn. 123.

[730] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 305 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 256 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 304; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 257.

[731] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 305 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 256 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 304; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 257.

[732] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 306 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 305; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 258.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Geheimhaltungsabkommen unterzeichne (siehe dazu unten XI.B.1.c)3)iv)) oder dem SEP-Inhaber Informationen mitteile, die er für die Erstellung des Angebots benötige.[733]

Eine verzögerte oder mangelhafte Mitwirkung des Verletzers führe aber grundsätzlich nicht dazu, dass er entgegen seiner Lizenzbereitschaftserklärung als lizenzunwillig angesehen werden könne, so dass ihm der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand verwehrt bleibe.[734] Wirke der Verletzer nicht oder nur zögernd oder mangelhaft mit, habe der SEP-Inhaber ein FRAND-Angebot zu machen, so gut es ihm möglich sei.[735] Nach der Lizenzbereitschaftserklärung seien Verstöße des Patentbenutzers gegen Mitwirkungsobliegenheiten oder verzögernde Verhaltensweisen grundsätzlich erst bei der Frage von Bedeutung, ob das vorgelegte Angebot als FRAND-Gemäß anzusehen sei, denn nach der Konzeption des EuGH habe auf die Lizenzbereitschaftserklärung ein FRAND-Angebot zu folgen – erst auf dieses müsse der Verletzer ohne Verzögerungstaktik reagieren.[736]

Weiter brachte das LG eine interessante Bemerkung zu einem gewissen „Selbstverschulden" der Patentinhaberin an der Verzögerungstaktik an. So hätte die Klägerin eine behauptete vorprozessuale Verzögerungstaktik der Beklagten unterbinden können, indem sie dieser bereits früher vor Klageerhebung ein FRAND-Angebot unterbreitet und – sofern die Beklagte nicht gemäß den Vorgaben des EuGH-Urteils reagiert hätte – anschließend Klage erhoben hätte.[737] Ein solches Angebot hätte die Klägerin ohne weiteres bereits früher unterbreiten können, nachdem bereits über drei Jahre vor Klageerhebung ein Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen worden sei, was es ihr auch ermöglicht habe, der Beklagten die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darzulegen.[738] Dass der Klägerin zur Erstellung eines FRAND-Angebots Angaben der Beklagten fehlten, sei nicht ersichtlich, womit vorprozessual alle Voraussetzungen zur Abgabe eines solchen Angebots vorlägen, ein solches jedoch nicht abgegeben worden sei.[739]

[733] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 306 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 305; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 258.

[734] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 307 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 258 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 306; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 259.

[735] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 307 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 258 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 306; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 259.

[736] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 307 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 258 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 306; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 259.

[737] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 308 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 259 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 307; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 260.

[738] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 308 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 259 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 307; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 260.

[739] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 308–09 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 259–60 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 307–08; X13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 260–61.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

X. Vorbemerkungen zu den FRAND-Angeboten von Patentinhaber und -benutzer

Bevor die einzelnen Angebote der Verhandlungsparteien näher betrachtet werden, sind ein paar allgemeine Worte zum Verhandlungsprocedere und den Vertragsangeboten angebracht, die Vertragsangebot und Gegenangebot gleichsam betreffen. Zum einen stehen beide Verhandlungsseiten unter dem Leitbild williger Vertragsparteien und sind gehalten, FRAND-Angebote abzugeben (bzw. zu akzeptieren).[740] Die Parteien werden sich wohl, zumindest wenn der Sachverhalt seinen Weg in den Gerichtssaal findet, nicht einig sein, welche Anforderungen durch die FRAND-Bedingungen gestellt werden.[741] Der SEP-Inhaber hat in einer solchen Konstellation besondere Anforderungen zu erfüllen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleistet werden soll, wobei den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falles gebührend Rechnung zu tragen ist.[742] Den Standardimplementierer trifft auf demgegenüber die Pflicht, auf das ihm unterbreitete Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben zu reagieren, und bei Nichtannahme ein schriftlich-konkretes FRAND-Gegenangebot zu unterbreiten, wenn er sich weiter auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen will.[743] Unabhängig davon, ob man FRAND-Bedingungen als „Range“ oder als „Dot“ verstehen möchte, ist wohl zuzugestehen, dass schlussendlich der Konsens als Ergebnis erfolgreicher Vertragsverhandlungen den (zumindest normativ) gleichen Vertragsinhalt für beide Parteien produziert. Insofern nähern sich die Verhandlungsparteien mit ihren Angeboten im „Verhandlungs-Ping-Pong“ dem gleichen Vertragsinhalt zu FRAND-Bedingungen. Daraus folgt, dass FRAND in inhaltlicher Hinsicht („content component“) für beide Parteien das Gleiche heißt, sich die Parteien durch Angebot und Gegenangebot einem FRAND-Inhalt nähern sollen, da die gegenüberliegende Partei sonst das Ausschließlichkeitsrecht bzw. den Zwangslizenzeinwand geltend machen kann. Die Streitigkeit betreffend den Inhalt entsteht in der Regel darin, dass die Parteien jeweils über die Anforderungen an die FRAND-Bedingungen streiten.[744] Folglich sind inhaltlich bei einem FRAND-Angebot bei gleichem Sachverhalt die gleichen Anforderungen an das Gegenangebot des Lizenzsuchers zu stellen. Die Angebotsobliegenheiten der Parteien dürften sich jedoch aufgrund der außergewöhnlichen Umstände[745] hinsichtlich des Conduct-Requirements und der Schaffung der gemeinsamen Informationsbasis (im Gerichtsverfahren Darlegungs- und Substantiierungslast) unterscheiden, wobei die wettbewerbsrechtlichen und prozessrechtlichen Pflichten insofern in Wechselwirkung stehen dürften, dass der SEP-Inhaber (auch außerhalb eines Prozesses) im Rahmen seiner Angebotspflicht zur umfassenden Darlegung- und Substantiierung der FRAND-Gemäßheit verpflichtet ist, während der Lizenzsucher nach Treu und Glauben zumindest in seinem Gegenangebot aufgrund der vom SEP-Inhaber geschaffenen Informationsbasis darlegen und substantiieren muss, wieso die angebotenen Lizenzbedingungen für ihn nicht FRAND seien. Da die gemeinsamen inhaltlichen Anforderungen auch aufgrund der Indizwirkung von bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen für die inhaltliche FRAND-Gemäßheit der Vertragsbedingungen eng mit der Darlegung- und Substantiierung der jeweiligen Standpunkte in Angebot und Gegenangebot verwoben sind, und der SEP-inhaber die ursprüngliche Informationslast trägt, werden sowohl die inhaltlichen als auch die prozessrechtlichen Anforderungen in dieser Aufstellung der FRAND-Rechtsprechung beim

[740] Vgl. EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 63, 65–66 – *Huawei/ZTE*, vgl. diesbezüglich in Lichte der nachfolgenden FRAND-Einwand-Rechtsprechung *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>.

[741] Siehe auch EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 54 – *Huawei/ZTE.*

[742] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 55–56, 59 – *Huawei/ZTE.*

[743] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 65, 66 – *Huawei/ZTE*

[744] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 54 – *Huawei/ZTE.*

[745] Vgl. EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 47 – *Huawei/ZTE.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Angebot des Patentinhabers tiefergehend behandelt, und allenfalls beim Kapitel zum Gegenangebot per Verweis erwähnt.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

XI. Lizenzvertragsangebot des Patentinhabers

A. Verhaltensanforderungen („conduct requirement“)

1. Angebotshandlung

Das LG Düsseldorf verlangte eine Zusendung des Vertrages als Angebotshandlung, damit eine Annahme möglich ist. Die bloße Abrufbarkeit des Standardlizenzvertrags über die Internetseite der Lizenzverwalterin stelle noch keine Angebotshandlung dar, sondern das Bereithalten des Vertragsdokuments zur Einsichtnahme durch Lizenzinteressierte diene vielmehr der Information über die Lizenzbedingungen.[746] In casu war die Angebotshandlung durch Zusendung des Standardlizenzvertrags gegenüber der Muttergesellschaft der Beklagten zur konzernweiten Lizenzierung erfolgt, worauf die Beklagte Tochtergesellschaft den Vertrag in eigenem Namen unterschrieben als „angenommen“ der Lizenzverwalterin zugeschickt hatte.[747] Die Zusendung des Standardlizenzvertrags, die als Angebotshandlung verstanden werden könne, sei aber allein an die Muttergesellschaft der Beklagten erfolgt.[748] Die von der beklagten Tochtergesellschaft unterzeichneten Standardlizenzverträge seien daher als (mangels nicht-konzernweiter Lizenzierung nicht FRAND-gemäßes, dazu unten XII.B.2) Gegenangebot zu werten, nicht hingegen könne darin die Annahme eines von der Lizenzverwalterin unterbreiteten Angebots erblickt werden.[749]

Auch die Kammer 4b vom 12.12.2018 beurteilte den diesbezüglich selben Sachverhalt gleich. Die von der Lizenzverwalterin übermittelten von der beklagten Tochtergesellschaft unterzeichneten Standardlizenzverträge stellten ein Gegenangebot und nicht die Annahme des klägerischen Angebots dar.[750] Die bloße Bereitstellung im Internet sei kein Angebot, sondern allenfalls eine *invitatio ad offerendum*, und das klägerische Angebot sei wiederum allein an die Muttergesellschaft der Beklagten erfolgt.[751]

2. Adressat der Lizenzvertragsangebots

Mit der Frage, ob das Lizenzvertragsangebot nicht an die Beklagte Tochtergesellschaft, sondern auch an deren Muttergesellschaft gerichtet werden könne, setze sich das LG Düsseldorf in den Entscheiden vom 9.11.2018 auseinander. So sei es für die Tauglichkeit der Angebotshandlung unschädlich, dass dieses in Form der Zusendung des Standardlizenzvertrags nicht an die Beklagte, sondern an die in dem Konzern der Beklagten mit den Lizenzverhandlungen betraute Person gerichtet worden sei, denn es stand der Abschluss einer Konzernlizenz in Rede und die zuständige Person habe per E-Mail ausdrücklich um Zusendung der Unterlagen an seine Person gebeten.[752]

Der Annahme einer auch die beklagte Tochtergesellschaft erfassenden Angebotshandlung in Form der Zusendung des Standardlizenzvertrags an die Muttergesellschaft stehe weder entgegen, dass damit eine Lizenzierung der Tochtergesellschaften noch nicht unmittelbar verbunden gewesen sei, noch dass gemäß Standardlizenzvertrag eine Lizenzierung von Vertriebshandlungen gegenüber Endkunden, nicht aber gegenüber Groß- und Einzelhändlern – wie von der Beklagten praktiziert – erfolge.[753] Es entspreche grundsätzlich einem FRAND-gemäßen Vorgehen, dass der Patentinhaber etwaige Lizenzverhandlungen vorbereite, indem er der Muttergesellschaft eines Konzernverbundes eine

[746] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 312; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 294.
[747] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 311; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 293.
[748] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 312; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 294.
[749] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 312; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 294.
[750] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 303; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 291.
[751] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 303; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 291.
[752] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 275; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 257.
[753] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 276; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 258.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verletzungsanzeige zukommen lasse (siehe dazu oben VIII.D) und anschließend Vertragsverhandlungen mit dieser führe.[754] Daraus folge, dass grundsätzlich auch für die Beurteilung der Erfolgsaussichten eines späteren kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes auf diese Kommunikation zwischen Patentinhaber und Muttergesellschaft abzustellen sei.[755]

Etwas anderes möge gelten, wenn – was die Kammer vorliegend nicht zu entscheiden habe – entweder in den die Vertragsverhandlungen vorbereitenden Handlungen bzw. im Rahmen der Vertragsverhandlungen selbst bereits zum Ausdruck komme, dass konzernverbundene Tochtergesellschaften von dem der Muttergesellschaft unterbreiteten Vertragsangebot von vornherein nicht erfasst sein könnten.[756] So liege der zu beurteilende Fall indes nicht, da das der Muttergesellschaft vorgelegte Vertragsangebot eine Lizenzierung auch der Tochterunternehmen gerade nicht von vornherein ausschließe.[757] Die Lizenzierungsgesellschaft habe vielmehr das Bedürfnis der Lizenzierung sämtlicher Konzernunternehmen zum Ausdruck gebracht, wenngleich die konkrete Ausgestaltung einer alle Konzerngesellschaften erfassenden Lizenz erst im Rahmen der Vertragsverhandlungen zu klären gewesen sei (zum Inhalt des Lizenzangebots für bestimmte Vertriebsstufen siehe unten XI.B.2.c)1)).[758] Maßgeblich sei, dass der branchenübliche Ausgangspunkt der Vertragsverhandlungen vorliegend die Kommunikation mit der Muttergesellschaft sei, deren Benutzungshandlungen von dem Standardlizenzvertrag abgedeckt würden.[759] Die Frage der Einbeziehung der Benutzungshandlungen der Tochtergesellschaften sei dann Gegenstand der sich an das Angebot anschließenden Vertragsverhandlungen.[760] Im Rahmen von Vertragsverhandlungen wäre dann auch die Frage der Lizenzierung von Vertriebshandlungen gegenüber gewerblichen Abnehmern zu erörtern gewesen, während die Muttergesellschaft vorliegend diesen Gesichtspunkt nicht in die Vertragsverhandlungen eingebracht habe, was zu erwarten gewesen wäre, wenn sie in diesem einen Hinderungsgrund für den Abschluss eines Lizenzvertrags ausgemacht hätte.[761] Die gelte umso mehr, als nur sie – anders als die Lizenzverwalterin – die für den Abschluss des Lizenzvertrags beachtlichen Konzernstrukturen im Detail gekannt habe.[762]

Auch die Kammer 4b des LG Düsseldorf hielt in den Entscheiden vom 12.12.2018 unter Verweis auf die Ausführungen im Rahmen der Verletzungsanzeige (siehe oben VIII.D) fest, es handele sich bei der Muttergesellschaft der Beklagten um die richtige Adressatin für das Lizenzvertragsangebot.[763] Der übersendete Standardlizenzvertrag sei als Angebot der Klägerin an den Konzern der Beklagten zu verstehen.[764] Es sei unschädlich, dass der Standardlizenzvertrag an die Muttergesellschaft und den dort zuständigen Mitarbeiter gerichtet worden sei, da es um den Abschluss einer Konzernlizenz gegangen sei und die betreffende Person ausdrücklich die Zusendung der Unterlagen an seine Person erbeten habe.[765]

[754] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 259.

[755] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 259.

[756] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 278; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 260.

[757] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 279–80; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 261–62.

[758] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 262.

[759] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.

[760] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.

[761] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.

[762] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.

[763] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 310; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 249; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 256.

[764] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 311; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 269; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 250; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 257.

[765] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 272; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 260.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

3. Angebotsobliegenheit auch ohne Informationsgefälle

Das LG Düsseldorf setzte sich im Entscheid vom 8.1.2019 mit der Frage auseinander, ob das aufgestellte Prüfregime und insbesondere die Obliegenheit des Patentinhabers, zuerst ein Lizenzangebot abzugeben, nur in dem Fall gelten solle, wenn ein offensichtliches Informationsgefälle auf Seiten des Lizenzsuchers vorliege, es mithin weder öffentlich zugängliche Lizenzverträge noch Standardlizenzverträge gebe.[766] Unter eine solche Bedingung sei die zeitliche Abfolge jedoch nicht gestellt, da das Erfordernis eines primären Lizenzangebots durch den Patentinhaber zumindest nicht ausschließlich auf einem etwaigen Informationsdefizit des Lizenzsuchers beruhe, sondern zum einen darauf, dass das Klagepatent für einen von einer Standardorganisation normierten Standard essentiell sei, und zum anderen eine unwiderrufliche Verpflichtungszusage des Inhabers bestehe, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizenzen zu erteilen.[767] Gerade mit diesen Aspekten verknüpfe der EuGH den besonderen, für den Patentinhaber aufgestellten Pflichtenkatalog, wie Rn. 51 des EuGH-Urteils entnommen werden könne.[768] Aufgrund der abgegebenen Verpflichtungserklärung vertrauten Dritte darauf, eine Lizenz zu angemessenen, diskriminierungsfreien Bedingungen zu erhalten, weshalb auch in der Literatur die FRAND-Erklärung als Abgrenzungskriterium klar benannt werde.[769]

Eine weitergehende Abgrenzung der so beschriebenen Ausgangssituation zu Fällen, in denen eine bestehende Lizenzierungspraxis bestehe, sei dem EuGH-Urteil nicht zu entnehmen, insbesondere auch nicht aus Rn. 64 des Urteils.[770] Im letzten Satz des Absatzes werde dort verdeutlicht, dass es grundsätzlich der Patentinhaber sei, dem die Einschätzung, ob ein unterbreitetes Angebot diskriminierungsfrei sei, leichter als dem Lizenzsucher falle und es dieses Informationsgefälle es rechtfertige, zunächst vom Patentinhaber die Abgabe eines Lizenzangebotes zu fordern.[771] Wie die sprachliche Einleitung des Satzes mit dem Wort „außerdem“ aber zeige, handele es sich dabei lediglich um eine weitere und nicht um die einzige Begründung für die gewählte Reihenfolge, und markiere lediglich ein zusätzliches Argument für die Ansicht, dass der Patentinhaber in Richtung des Abschlusses eines Lizenzvertrages initiativ werden müsse.[772] Auch ohne diesen letzten Satz besage Rn. 64 schon, dass vom Patentinhaber die Abgabe eines Lizenzangebotes erwartet werden könne, weshalb nicht zu erkennen sei, dass der EuGH ein weiteres Abgrenzungskriterium schaffen wollte.[773] Weiter unterstreiche zudem die systematische Stellung der Ausführungen im Zusammenhang mit der Darstellung der Obliegenheiten des Patentinhabers, die sich gerade aus den beschriebenen Besonderheiten ergebe, dass lediglich ein zusätzliches Argument für diese Obliegenheiten, nicht aber ein neues Unterscheidungskriterium präsentiert werden sollte.[774] Insbesondere unter Berücksichtigung der Randnummern 48 ff. ergebe sich, dass es für den EuGH bei der Beantwortung der Vorlagefrage maßgeblich auf die Art des Patentes sowie die Selbstverpflichtung zur Lizensierung angekommen sei, und dass die „Ratio“ der Entscheidung nicht unbedingt auf existierende Lizenzverträge abstelle.[775] Explizit heiße es in Rn. 48, dass das zugrundeliegende Verfahren gegenüber anderen Verfahren *Besonderheiten* aufweise.[776] Diese konkretisiere der EuGH in den folgenden Absätzen zum einen dahingehend, dass ein für einen von einer Standardisierungsorganisation

[766] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 192.

[767] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 193.

[768] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 193, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 51 – *Huawei/ZTE* und LG Düsseldorf, 9.11.2018 + 4a O 17/17.

[769] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 193.

[770] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 194.

[771] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 194.

[772] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 194.

[773] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 194.

[774] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 194, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17.

[775] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 195.

[776] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 195.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

normierten Standard essentielles Patent in Streit stehe, zum anderen stelle der Unionsgerichtshof auf die unwiderrufliche Verpflichtungszusage des Patentinhabers gegenüber der Standardisierungsorganisation ab.[777] Das (Nicht-)Vorhandensein von bereits erteilten, ggf. sogar branchenbekannten Lizenzverträgen sei dabei nicht als Kriterium herangezogen worden, um die Besonderheit eines Verfahrens herauszustellen.[778] Hinzu komme, dass die Auffassung, wonach eine etablierte Lizenzvertragspraxis aus den vom EuGH aufgestellten Grundsätzen hinausführe, auch zu praktischen Abgrenzungsproblemen führe, ab wann von einer solchen Konstellation auszugehen sei.[779]

4. Zeitpunkt der Unterbreitung

Verschiedentlich setzten sich die deutschen Gerichte mit den zeitlichen Anforderungen an das FRAND-Lizenzvertragsangebot auseinander.

Nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf habe das Lizenzangebot grundsätzlich vorprozessual zu erfolgen, könne aber ebenfalls im Laufe des Rechtsstreits nachgeholt werden.[780] Wenn der Lizenzsucher vorprozessual in ernsthafte Lizenzverhandlungen eingetreten sei, müssten selbige grundsätzlich auch vor Klageerhebung erfolglos abgeschlossen seien.[781]

Auch das LG Düsseldorf hielt in den Entscheiden vom 13.7.2017 fest, es obliege dem SEP-Inhaber, der Patentbenutzerin ein FRAND-gemäßes Angebot bereits vor Erhebung der Klage zu unterbreiten.[782] Tue er dies nicht, könne er die Unterbreitung eines FRAND-Angebots während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens jedenfalls nicht zeitlich uneingeschränkt nachholen.[783] Der Zeitpunkt der „gerichtlichen Geltendmachung“ liege vor, wenn die Klage eingereicht und der Kostenvorschuss eingezahlt worden sei, selbst wenn die Zustellung noch nicht erfolgt sei, denn mit der Einzahlung des Kostenvorschusses sei die Klage unweigerlich auf den Weg gebracht.[784] Die zeitlichen Vorgaben für die Abgabe des Angebots gälten auch für die Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren (dazu unten XI.B.1), denn erst wenn der Verletzer diese Angaben erhalten habe, liege ein Angebot vor, dessen FRAND-Gemäßheit er hinreichend überprüfen und auf das er nach den Vorgaben des EuGH reagieren müsse.[785]

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit sei, dass der Patentbenutzerin eine angemessene Reaktionsfrist verbleibe, und sie gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagieren könne.[786] Die Benutzerin müsse die Möglichkeit haben, das Angebot des SEP-Inhabers gemäß den geschäftlichen Gepflogenheiten sorgfältig zu prüfen und darauf zu

---

[777] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 195.

[778] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 195.

[779] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 195.

[780] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 202 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 13.

[781] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 202 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[782] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 316 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 315; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 268.

[783] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 316 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 315; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 268.

[784] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 321 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 272 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 320, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 192; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 273.

[785] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 367 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 318 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 366; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 319, alle mit Verweis auf LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15, Rn. 119.

[786] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 312, 336 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 263, 287 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 311, 335; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 264, 288, alle mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 65 – *Huawei/ZTE.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

reagieren.[787] Ferner dürfe die Benutzerin nach den EuGH-Vorgaben ein FRAND-gemäßes Gegenangebot formulieren, wofür ein ausreichender Zeitraum verbleiben müsse.[788]

Als Kriterien für die Rechtzeitigkeit zog das LG Düsseldorf dabei einerseits die Komplexität des Angebots, und andererseits den zeitlichen Druck auf die Benutzerin heran.[789] Ein Zeitraum von elf Tagen einschließlich zweier Wochenenden und einem Feiertag erachtete die Kammer zur Prüfung des Angebots und der Formulierung eines Gegenangebots als erkennbar nicht ausreichend.[790] Auch werde die Prüfung dadurch erschwert, dass der Patentinhaber offenbar zwei Versionen des Angebots eingereicht habe ohne darzustellen, wie sich das aktuelle Angebot vom vorherigen Angebot unterscheide.[791] Die Taktik des Patentinhabers, kurz vor der mündlichen Verhandlung neuen Vortrag und ein neues Angebot einzureichen, vereitele eine ausreichende Prüfung seiner Angebote durch die Benutzerin.[792] Aufgrund der kurz darauf folgenden mündlichen Verhandlung werde die Beklagte unter ungebührlichen Druck gesetzt, das neueste Angebot zu prüfen und darauf zu reagieren.[793] Ein missbräuchlicher zeitlicher Druck entstehe, wenn der Verletzer das Angebot entweder ohne hinreichende Prüfung annehmen oder ablehnen müsse, bevor er es geprüft und ein Gegenangebot ausgearbeitet habe.[794] Durch diesen Druck würden die vom EuGH gewünschten Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen den Parteien behindert.[795] Je später das Angebot vom SEP-Inhaber abgegeben werde und je geringer damit der zeitliche Abstand zwischen Angebot (bzw. dessen Begründung) und mündlicher Verhandlung sei, umso stärkerem Druck sei die Verletzerin ausgesetzt.[796] Schließlich berücksichtigte das Gericht weiter, dass es nicht ersichtlich sei, warum der Patentinhaber das Angebot nicht früher hätte machen können.[797]

Als Konsequenz eines in zeitlicher Hinsicht nicht FRAND-gemäßen Angebots sei das verspätete Angebot nicht zu berücksichtigen, und mangels eines anderen FRAND-gemäßen Angebots die Klage als derzeit unbegründet abzuweisen.[798] Doch bemerkte die Kammer auch, dass selbst wenn das Angebot auch in

---

[787] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 335, 402 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 286, 353 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 334, 401; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 287, 354.

[788] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 335, 402 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 286, 353 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 334, 401; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 287, 354.

[789] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 402–03 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 353–54 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 401–02; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354–55.

[790] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 402 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 353 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 401; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354.

[791] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 403 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 354 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 402; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354.

[792] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 403 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 354 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 402; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354.

[793] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 403 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 354 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 402; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 354.

[794] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 337 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 288 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 336; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 288.

[795] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 337 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 288 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 336; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 288.

[796] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 337 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 288 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 336; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 288.

[797] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 404 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 355 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 403; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 356.

[798] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 339 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 338; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 290.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zeitlicher Hinsicht FRAND-Angaben entspreche, würde dies nicht den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand hindern, sondern nur die Pflicht des Patentbenutzers ausgelöst, ein FRAND-gemäßes Gegenangebot zu machen, wenn das Angebot nicht angenommen werde.[799]

Auch in den Entscheiden vom 11.7.2018 hielt das LG Düsseldorf fest, es obliege dem Patentbenutzer nach den Vorgaben des EuGH, ein FRAND-gemäßes Angebot vor Erhebung der Klage zu unterbreiten.[800] Wie schon im Entscheid vom 13.7.2017 verwies das LG auf Rn. 61 und 63 des EuGH-Urteils betreffend Vollständigkeit des Angebots und Einreichung der Klage nebst Einzahlung des Kostenvorschusses als Zeitpunkt der gerichtlichen Geltendmachung.[801] Nebst weiteren Ausführen zur Nachholung des Angebots während eines laufenden Gerichtsverfahrens führte das Gericht aus, dürfe durch den Zeitpunkt der Unterbreitung der Sinn und Zweck des vom EuGH ersonnenen Systems nicht ausgehebelt werden, insbesondere der Leitgedanke der EuGH-Entscheidung, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können, und während des Verfahrens über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zuließen, ob das unterbreitete Lizenzvertragsangebot FRAND-konform sei oder nicht.[802] Maßgeblich sei abermals, dass der Gegenseite ausreichend Reaktionszeit verbleibe.[803] Wiederum bemerkte das LG, sei kein Grund dafür ersichtlich, wieso der Patentinhaber der Verletzerin nicht vor Erhebung der Unterlassungsklage bereits das weitere, später unterbreitete Lizenzangebot vorgelegt habe.[804] Insofern spreche vieles dafür, dass dem Patentinhaber ein Verstoß gegen die ihm obliegende Pflicht zur Prozessförderung zu Last zu legen sei, mit der Folge, dass das letzte Lizenzangebot der FRAND-Prüfung nicht zu Grunde zu legen wäre, was mangels inhaltlicher FRAND-Gemäßheit des Angebots in casu aber dahinstehen könne.[805]

Das LG Mannheim führte in die gleiche Richtung aus, die vom EuGH vorgesehene Möglichkeit des Verletzers, innerhalb einer kurzen Frist ein konkretes Gegenangebot auf das Angebot der SEP-Inhaberin zu machen, das FRAND-Bedingungen entspreche, impliziere, dass dem angeblichen Patentverletzer vor Erhebung der Klage die Möglichkeit gegeben werden müsse, innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf das Angebot der Patentinhaberin zu reagieren.[806] Unter diesen Voraussetzungen sah das LG Mannheim das infrage stehende Angebot der SEP-Inhaberin als nicht FRAND-gemäß und damit missbräuchlich nach Art. 102 AEUV bzw. § 19 Abs. 1 GWB an, da der Klägerin der Beklagten vor der Klageerweiterung keine angemessene Frist eingeräumt habe, das Angebot zu prüfen und ein Gegenangebot abgeben zu können.[807]

Für die Angemessenheit der Frist sei auf den Zeitpunkt abzustellen, zu dem das Angebot der Patentinhaberin nach den Vorgaben des Unionsgerichtshofs vollständig sei, insbesondere die Patentinhaberin die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so angegeben habe, dass deutlich werde, aus welchen darzulegenden Gründen sie von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgehe (siehe unten XI.B.1.c)).[808] Erst durch Zurverfügungstellung der relevanten Informationen werde die

[799] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 416 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 367 – *Mobiles Kommunikationssystem;* 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 415; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 368.

[800] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 175; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 189.

[801] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 176–77; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 190–91, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14; 13.7.2017 – 4a O 154/15 und EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 61, 63 – *Huawei/ZTE.*

[802] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 181; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 195, beide mit Verweis auf LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15.

[803] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 184; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 198.

[804] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 186; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 200.

[805] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 186–87; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 200–01.

[806] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 113.

[807] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 116.

[808] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15, 19.8.2016 – 7 O 19/16 und 10.11.2017 – 7 O 28/16 – *Funkstation*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Reaktionspflicht innert angemessener Frist ausgelöst.[809] Eine Frist von nicht einmal vier Wochen sah das LG Mannheim dabei als nicht ausreichend an, um der Beklagten die sorgfältige Überprüfung des Lizenzvertragsangebot zu ermöglichen.[810] Konkret seien der Beklagten drei Drittlizenzverträge zur Verfügung gestellt worden, die sie darauf untersuchen müsse, ob die Konditionen von den ihr angebotenen Konditionen abwichen und ob dafür ein sachlicher Grund bestehe.[811] Insbesondere sei ein Vergleich der jeweils lizenzierten Patente erforderlich gewesen, was bei 44 Patentfamilien einen erheblichen Zeitaufwand bedeute.[812] Nach der Analyse habe es einer konzerninternen Abstimmung und der Einbindung der maßgeblichen Entscheidungsträger im Entscheidungsprozess bedurft, wofür bei objektiver Betrachtung der Zeitraum vom 22 Werktagen bei weitem nicht ausreiche, während ein weiteres Zuwarten der Klägerin auch zumutbar gewesen sei.[813] Wie die Verhandlungshistorie zeige, habe die Klägerin selbst einige Zeit benötigt, um das vorliegende Angebot vorzulegen, das rund zehn Monate nach den vorherigen Angebot und fünf Monate seit dem Datum der relevanten Lizenzverträge mit Dritten erfolgt sei.[814] Auch die Verfasser des Angebots vom Februar 2018 seien offensichtlich davon ausgegangen, dass die Prüfung des Vertrags einige Zeit in Anspruch nehme, so heiße es im Schedule B, die darin enthaltenen Tabellen seien „conditional upon execution of the Agreement as of June 30, 2018“.[815]

5. Form des Angebots

Betreffend die Form, in der das Lizenzvertragsangebot abzugeben ist, hielt das OLG Düsseldorf im Entscheid vom 17.11.2016 fest, das Angebot müsse in schriftlicher Form als geschlossenes Vertragswerk erfolgen, mit sämtlichen Punkten, die üblicherweise Reglungsgegenstand eines Lizenzvertrages seien.[816] Bezüglich der vom EuGH geforderten Angaben zur Art und Weise der Berechnung dürfte es genügen, wenn diese in einem Begleitschreiben mitgeteilt würden.[817] Auch im Entscheid vom 30.3.2017 verlangte das OLG abermals, das Angebot sei als geschlossenes Vertragswerk mit sämtlichen Punkten, die üblicherweise Regelungsgegenstand eines Lizenzvertrags seien, vorzulegen.[818] Ein Telefax oder eine E-Mail genügten dem Schriftlichkeitserfordernis.[819] Es müsse konkret in dem Sinne sein, dass die Lizenzgebühr und die einschlägigen Berechnungsparameter (maßgebliche Bezugsgröße, anzuwendender Lizenzsatz, ggf. Abstaffelung) sowie die Art und Weise der Berechnung anzugeben sei.[820] Dies sei nicht der Fall, wenn lediglich optionale Vorschläge zur Höhe der Lizenzgebühren und einigen weiteren Lizenzbedingungen, wie Bankgarantie und Abschlussgebühr enthalten seien.[821]

Das LG Düsseldorf führte zu den formellen Anforderungen des EuGH-Urteils an das vom SEP-Inhaber zu unterbreitende Angebot in den Entscheiden vom 13.7.2017 und 11.7.2018 aus, es müsse zum einen konkret und schriftlich erfolgen, zum anderen müsse die Art und Weise der Berechnung der verlangten

[809] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.
[810] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.
[811] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.
[812] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.
[813] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.
[814] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.
[815] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.
[816] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 13.
[817] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 13.
[818] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 245 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[819] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[820] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem*
[821] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 245 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzgebühr angegeben werden.[822] Letzteres könne auch in einem Begleitschreiben oder ähnlichem erfolgen, sofern es gleichzeitig mit dem Angebot übermittelt werde.[823]

In den Entscheiden vom 9.11.2018 und 12.12.2018 führte das LG in Übereinstimmung mit dem OLG weiter aus, das schriftlich zu verfassende Angebot müsse darüber hinaus konkret in dem Sinne sein, dass daraus die Lizenzgebühr und die einschlägigen Berechnungsparameter, wie maßgebliche Bezugsgröße, anzuwendender Lizenzsatz und gegebenenfalls eine Staffelung, sowie die Art und Weise der Berechnung an sich, hervorgingen.[824] Punkte, die üblicherweise Regelungsgegenstand von Lizenzverträgen seien, müssten in das Angebot in Form von aussagekräftigen Bestimmungen aufgenommen werden.[825] So könne auch die Zusendung eines Standardlizenzvertrag-Dokuments diese Anforderungen erfüllen.[826] Die Zusendung des Standardlizenzvertrags sei ihrem objektiven Erklärungswert nach eine hinreichend konkrete Angebotshandlung, und der daraus erkennbare Vertragsinhalt sei insbesondere auch geeignet, die Benutzungshandlungen des Patentverletzers zu legitimieren.[827] Die Muttergesellschaft habe durch die Zusendung des Standardlizenzvertrags sowie die Informationen einer E-Mail erkennen können, dass die Lizenzverwalterin ihr den Abschluss einer Lizenz zu den Konditionen des Standardlizenzvertrags angedient habe.[828] In der Zusendung der postalisch zugesandten Schriftstücke trat gegenüber einer der beiden Beklagten nach Hinweis per E-Mail die Funktion der Zusendung als Angebotshandlung die Absicht der Lizenzverwalterin zum Vertragsschluss offen zu tage.[829] Auch betreffend die andere der beiden Beklagten handele es sich bei dem zugesandten Standardvertragsdokument erkennbar um einen Vertrag, der nicht gezielt auf die Muttergesellschaft zugeschnitten, sondern – im Sinne eines Standardvertrags – für eine Vielzahl von Lizenzwilligen gelten solle.[830] Dies werde erkennbar beispielsweise daran, dass das Datum des Vertragsschlusses sowie der Name des Lizenznehmers in das Vertragsdokument einzusetzen seien, es sich im Übrigen aber um eine in sich geschlossene Struktur handele.[831] Daran, dass die Lizenzverwalterin das Dokument unterschreiben würde, habe die Muttergesellschaft mithin keine begründeten Zweifel haben müssen.[832] Schließlich lasse der Standardvertrag auch die für die

[822] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 198; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 212; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 356 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 307 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 355; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 308, alle mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 63 – *Huawei/ZTE.*

[823] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 356 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 307 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 355; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 308, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 252, OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. [13].

[824] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 266; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 248; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 256; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 278, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[825] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 266; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 248; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 256; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 278.

[826] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 267; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 249; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 257; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 279.

[827] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 313; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 273; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 252; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 261; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 268; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 250.

[828] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 269; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 251.

[829] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 272; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 254; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 362; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 284.

[830] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 275; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 254; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 263; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 360; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 282.

[831] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 360; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 282.

[832] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 360; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 282.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzberechnung erforderlichen Parameter, insbesondere die Berechnungsfaktoren für eine Stücklizenz, erkennen.[833]

6. Zulässigkeit einer Änderungskündigung

Das OLG Düsseldorf machte im Entscheid vom 22.3.2019 im Kontext einer SEP-Übertragung (dazu oben VII) Ausführungen dazu, inwiefern eine Änderungskündigung von Lizenzverträgen möglich sei. Grundsätzlich rücke der SEP-Erwerber in die bestehende Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers ein und sei an diese gebunden, insbesondere im Rahmen des Diskriminierungsverbots.[834]

Vertragsbeendigungen könnten dem SEP-Inhaber neue Verhandlungsspielräume bei der Lizenzvergabe eröffnen, da Lizenzverträge unter Diskriminierungsgesichtspunkten (vgl. dazu unten XI.B.3) für die Zukunft unbeachtlich würden, wenn und sobald sie gekündigt seien.[835] Gelinge es dem Patentinhaber, zu einem bestimmten Zeitpunkt *sämtliche* Lizenzverträge in rechtlich, insbesondere kartellrechtlich, zulässiger Weise zu beenden, könne er (oder sein Rechtsnachfolger) allein unter Beachtung des Ausbeutungsverbots zu einem neuen, gegenüber dem bisherigen geänderten Lizenzierungskonzept wechseln, das ihn lediglich fortan unter Diskriminierungsgesichtspunkten binde.[836]

Maßgeblich für die Beurteilung, ob noch eine Bindung an die bisherige Lizenzierungspraxis bestehe, sei jeweils der Zeitpunkt der Lizenzofferte.[837] Für die Unwirksamkeit der bisherigen Praxis im Rahmen des Diskriminierungsverbots komme es dabei nicht auf den Zeitpunkt der Kündigungserklärung, sondern des Wirksamwerdens der Kündigung, mithin den Ablauf der Kündigungsfrist bzw. das Ende der festen Vertragslaufzeit an.[838] Ein gleichzeitiges Auslaufen der Lizenzverträge ließe sich zum Beispiel sicherstellen, indem von Anfang an ein fester Vertragsendzeitpunkt im Blick behalten werden, mithin für den ersten Lizenzvertrag das besagte Enddatum vereinbart werde und dieses Datum das Vertragsende für alle nachfolgend abgeschlossenen Lizenzverträge markiere.[839] Betreffend etwaige praktische Schwierigkeiten bemerkte das OLG, es möge durchaus sein, dass sich namentlich bei umfangreichen Portfolios ein für alle Lizenzen gleicher Beendigungszeitpunkt nur mit erheblichem logistischem Aufwand umsetzen lasse.[840] Wenn dem so sein sollte, folge daraus indessen nicht, dass eine Bindung des Rechtsnachfolgers an die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers unangemessen sei und nicht stattfinden dürfe, sondern dies mache umgekehrt nur die besondere Bedeutung deutlich, die ein sorgfältiges Ausloten der Lizenzbedingungen unter Geltung des Ausbeutungsverbots habe.[841] Der SEP-Inhaber werde mit umso größerer Sorgfalt die Bedingungen seiner Erstlizenz abzuwägen haben, wenn er an sie auf längere Sicht unter Diskriminierungsgesichtspunkten gebunden sein werde.[842]

Dass infolgedessen alle dem ersten Lizenznehmer nachfolgenden Lizenzsucher nur noch in den Genuss einer ihrer Verzögerung beim Vertragsschluss entsprechend verkürzten Lizenzdauer gelangten, sei rechtlich bedenkenfrei, weil auch der Marktbeherrscher seine Geschäftspolitik grundsätzlich frei umordnen könne und das Interesse des Patentinhabers, nach einer gewissen Zeit die

[833] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 274; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 254; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 364; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 286.

[834] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers*.

[835] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[836] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[837] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[838] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[839] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[840] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 320 – *Improving Handovers.*

[841] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 320 – *Improving Handovers.*

[842] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 320 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzbedingungen im Rahmen des FRAND-Spielraums neu auszuloten, einen sachlich gerechtfertigten Grund repräsentiere, wobei die aufeinander abgestimmten Laufzeiten gewährleisteten, dass jeder Lizenznehmer zu jedem Zeitpunkt mit denselben Lizenzkonditionen wie seine Wettbewerber zurechtkommen müsse.[843] Dies allein sei unter Diskriminierungsgesichtspunkten maßgeblich (siehe unten XI.B.3), und nicht, dass der spätere Lizenznehmer dieselbe Anzahl von Jahren mit bestimmten bei Vertragsschluss geltenden Lizenzbedingungen rechnen könne.[844] Sähen die neuen Lizenzen signifikant höhere Lizenzvergütungen vor, bedürfe es angesichts der in der Vergangenheit praktizierten, milderen Lizenzbedingungen allerdings näheren Vortrags des Patentinhabers dazu, weshalb die erhöhten Entgelte ebenfalls „fair“ und „reasonable“ seien.[845]

B. Sachlich-inhaltliche Anforderungen („content requirement“)

Wie das LG Düsseldorf in seinen Entscheiden vom 11.7.2018 prägnant zusammenfasste, soll das Angebot des SEP-Inhabers inhaltlich fair, angemessen und nicht-diskriminierend (= FRAND) sein.[846] Dies umfasst Vorgaben einerseits zur absoluten Höhe der Lizenzgebühren, die fair und angemessen sein muss (FR-Prong, dazu unten XI.B.2), andererseits zu der relativen Höhe der Lizenzgebühren verglichen mit anderen Lizenznehmern, wo ein Diskriminierungsverbot besteht (ND-Prong, dazu unten XI.B.3).[847] Gleiches gilt neben der Höhe auch für die anderen Lizenzbedingungen des Angebots.[848] Im Folgenden sollen zuerst in einem generellen Teil Ausführungen zu den inhaltlichen Anforderungen an das Lizenzangebot gemacht werden (siehe sogleich), bevor die Rechtsprechung zu den beiden Prongs, Fairness/Angemessenheit und Diskriminierungsverbot, genauer aufgeführt wird.

1. Konkretes Lizenzvertragsangebot mit Art und Weise der Berechnung

a) Art und Weise der Berechnung allgemein

Das FRAND-Angebot muss nach Ansicht des OLG Düsseldorf Angaben zu sämtlichen Punkten enthalten, die üblicherweise Reglungsgegenstand eines Lizenzvertrags seien.[849] Prüfungsmaßstab sei nicht nur, ob das Angebot die *essentialia negotii* einer Lizenzvertrages enthalte und nicht evident FRAND-widrig sei (zur negativen Evidenzkontrolle unten XI.B.1.d)2)), sondern es sei positiv festzustellen, dass es sich um ein Angebot zu FRAND-Bedingungen handele.[850] Es könne nach Ansicht des OLG allerdings mehrere Vertragsgestaltungen mit unterschiedlichen Lizenzbedingungen und insbesondere einen Bereich von Lizenzgebühren geben, die als fair, angemessen und nicht-diskriminierend zu qualifizieren seien.[851]

Insbesondere habe das schriftliche und konkrete Angebot die Lizenzgebühr und die Art und Weise der Berechnung anzugeben.[852] Nach Rechtsprechung des OLG Düsseldorf habe das Angebot konkret in dem Sinne zu sein, dass es die Lizenzgebühr und die einschlägigen Berechnungsparameter (wie maßgebliche Bezugsgröße, anzuwendender Lizenzsatz, ggf. Staffelung) sowie die Art und Weise der Berechnung enthalten müsse.[853] Dazu müssten zu allen Punkten, die üblicherweise Reglungsgegenstand von Lizenzverträgen in der jeweiligen Branche seien, aussagekräftige

[843] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[844] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[845] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 319 – *Improving Handovers.*

[846] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 191; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 205, beide mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 63 – *Huawei/ZTE.*

[847] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 191; 11.7.2018 – 4c O 81/17.

[848] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 191; 11.7.2018 – 4c O 81/17.

[849] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 13.

[850] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 14.

[851] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 14, mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 8.9.2016 – 6 U 58/16.

[852] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 312 – *Improving Handovers.*

[853] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Bestimmungen vorgesehen werden.[854] Das Angebot müsse ein geschlossenes Vertragswerk sein, das nicht nur optionale Vorschläge zur Höhe der Lizenzgebühren und einigen weiteren Lizenzbedingungen wie Bankgarantie und Abschlussgebühr enthalte.[855]

Das LG Düsseldorf führte weiter aus, die vom SEP-Inhaber zur Art und Weise ihrer Berechnung im Rahmen des Angebots zu machenden Angaben entsprächen inhaltlich dem, was er als Kläger in einem Verletzungsverfahren vortragen müsse, um die FRAND-Gemäßheit seiner Angebots gegenüber dem Gericht ausreichend darzulegen (m.w.H. zu den Anforderungen an Substantiierung und Darlegung des Angebots siehe unten XI.B.1.c)2)).[856] Dabei sei Vortrag insbesondere zu bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und zu relevanten Gerichtsentscheidungen erforderlich.[857] Die Art und Weise der Berechnung erfordere nicht zwingend eine streng mathematische Herleitung, sondern sofern dies im konkreten Fall möglich sei, sei es erforderlich und regelmäßig hinreichend, die Akzeptanz der verlangten Lizenzverträge am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[858] Die Darlegung der Art und Weise der FRAND-Gemäßen Lizenzgebühren über bereits geschlossene Lizenzverträge sei vorrangig, da über das Ergebnis verschiedener, schon erfolgter, tatsächlicher Lizenzverträge sich die FRAND-Gemäßheit einfacher belegen und sicherer feststellen ließe, als über den Vortrag der einzelnen Faktoren, die in Lizenzvertragsverhandlungen jeweils eine näher zu bestimmende, mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen könnten oder sollten, und welche der Verletzer und das Gericht jeweils erst zu einer Lizenzgebührenhöhe „zusammensetzen" müssten.[859]

Schließlich müsse das Angebot auch in Bezug auf die weiteren Vertragsbedingungen FRAND sein, also etwa hinsichtlich des Umfangs der lizenzierten Schutzrechte und der territorialen Reichweite, wobei insbesondere auch die Branchenüblichkeit relevant sei (dazu unten XI.B.2).[860]

Durchaus fragwürdige Anreize setzend argumentierte das LG im Entscheid vom 13.7.2017, indem es ein Entgegenkommen des SEP-Inhaber bei der inhaltlichen Bewertung der FRAND-Bedingungen gegen ihn auslegte. So spreche nach Ansicht des LG der Umstand, dass die Klägerin sich veranlasst gesehen habe, die geforderten Lizenzgebühren in einem späteren Angebot deutlich zu senken dafür, dass die ursprünglichen Bedingungen selbst aus der Sicht der Klägerin FRAND-Vorgaben nicht genügten.[861] Da das Angebot laut der Klägerin den neuen Entwicklungen bei der Klägerin selbst Rechnung tragen sollte,

[854] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[855] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 245 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[856] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 201; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 215; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 358 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 309 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 357; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 310.

[857] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 201; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 215; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 358 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 309 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 357; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 310.

[858] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 287; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 269; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 367; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 289; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[859] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 204; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 218; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 360 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 311 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 359; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 312.

[860] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 197; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 211; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 355 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 306 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 354; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 307.

[861] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 399 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 350 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 398; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 351.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

sei davon auszugehen, dass die Klägerin selbst Zweifel an der FRAND-Gemäßheit des ursprünglichen Angebots habe.[862]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 zog das LG Düsseldorf als maßgebliches Kriterium heran, dass die *essentialia negotii* der Lizenzierung durch das Lizenzangebot bestimmt seien,[863] und in der Zusendung des Standardlizenzvertrages aufgrund ihres objektiven Erklärungswerts eine hinreichend konkrete Angebotshandlung zu sehen sei (m.w.H. zum Angebot durch Standardlizenzvertrag in formeller Hinsicht oben XI.A.5, in inhaltlicher Hinsicht unten XI.B.1.d)1)).[864] Der Beklagten sei ein vollständiges Vertragsdokument vorgelegen, aus dem sämtliche Vertragsbedingungen für eine Lizenz an den standardessentiellen Patenten hervorgingen, insbesondere ließen sich die erforderlichen Parameter der Lizenzberechnung entnehmen und enthalte der Vertrag die Gewährung der Lizenz für die implementierenden Produkte.[865]

Das LG Mannheim äußerte sich im Entscheid vom 10.11.2017 dahingehend, das FRAND-Angebot des SEP-Inhabers erfordere zum einen, dass die vertragswesentlichen Bedingungen enthalten seien, das Vertragsangebot also annahmefähig sei.[866] Zum anderen sei der Angebotsempfänger in die Lage zu versetzen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum das unterbreitete Angebot – bei objektiver Betrachtung aus der Perspektive des Patentinhabers – FRAND-Kriterien entspreche.[867] Dafür sei insbesondere die Lizenzgebühr anzugeben und die Art und Weise der Berechnung transparent zu machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus denen die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet werde, bspw. aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt werde, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasse.[868] Der Umfang der gebotenen Darlegung im Einzelfall werde dabei von der konkreten Lizenzierungssituation abhängen.[869] Die bloße Mitteilung von Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebühr zugrunde lägen (vgl. zur Substantiierung des Angebots unten XI.B.1.c)2)), sei nach alledem nicht ausreichend, wenn es dem Angebotsempfänger anhand dieser Parameter noch nicht möglich sei zu beurteilen, ob das Angebot – innerhalb des zuzugestehenden Entscheidungsspielraums bei objektiver Betrachtung – FRAND sei, und darauf gegebenenfalls ein FRAND-Gegenangebot zu machen, weil es dem Lizenzsucher, wie der Gerichtshof ausführe, regelmäßig gerade an den dazu benötigten Informationen über den Lizenzmarkt fehle, über welche der SEP-Inhaber aber verfüge.[870]

Auch im Entscheid vom 28.9.2018 hielt das LG Mannheim fest, der Patentinhaber habe die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass darin deutlich werde, aus welchen darzulegenden (dazu unten XI.B.1.b)) Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgehe.[871] Insoweit müsse er, wie schon im Entscheid vom 10.11.2017 erwähnt, den Betrag gegenüber dem

[862] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 399 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 350 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 398; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 351.

[863] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 314; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 253.

[864] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 313–14; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 273–74; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 252–53; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 261–62.

[865] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 313–14; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 273–74; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 252–53; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 261–62.

[866] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

[867] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

[868] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

[869] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

[870] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

[871] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim 1.7.2016 – 7 O 209/15, 19.8.2016 – 7 O 19/16, 16.12.2016 – 7 O 29/16 und 10.11.2017 – 7 O 28/16 – *Funkstation*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent bzw. plausibel machen.[872] Um dem angeblichen Patentverletzer eine Überprüfung zu ermöglichen, dass der SEP-Inhaber seiner Pflicht zur Gleichbehandlung genüge, sei darüber hinaus erforderlich, dass konkret zu den mit Dritten geschlossenen Lizenzverträgen vorgetragen werde.[873] Diese Angaben hätten nicht nur den Zweck, den Patentbenutzer in die Lage zu versetzen, einzuschätzen, ob das Angebot tatsächlich FRAND sei, vielmehr erhöhe die Transparenz die Chance, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kämen und konstruktiv über die Frage der Lizenzhöhe diskutieren könnten.[874]

Betreffend die Fristenwirkung der Art und Weise der Berechnung führte das LG Mannheim weiter aus, erst die Zurverfügungstellung der relevanten Informationen löse eine Reaktionspflicht der Implementiererin innert angemessener Frist aus.[875]

b) Begründung der angebotenen Bedingungen als FRAND-gemäß

Das OLG Düsseldorf formulierte im Entscheid vom 30.3.2017 die Anforderung an das Angebot des SEP-Inhabers, es müsse Erläuterungen zu den wesentlichen Gründen enthalten, weshalb er die von ihm vorgeschlagenen Vergütungsparameter für FRAND halte.[876] Habe der SEP-Inhaber zuvor bereits Lizenzen an Dritte vergeben, habe er je nach den Umständen des Einzelfalls mehr oder weniger substantiiert insbesondere zu begründen, warum die von ihm vorgesehene Lizenzvergütung gerade vor diesem Hintergrund FRAND sei.[877] Üblicherweise werde die Begründung durch Verweis auf die bisherige Lizenzierungspraxis erfolgen (siehe dazu unten XI.B.1.c)2)iv)).

Auch das LG Düsseldorf griff das Erfordernis der Begründung der FRAND-Gemäßheit auf, wonach der SEP-Inhaber über die Angabe der Höhe der Lizenzgebühr und ihrer Berechnung hinaus auch dem Verletzer konkret und für diesen nachvollziehbar erläutern müsse, warum die vorgesehenen Lizenzgebühren FRAND seien.[878] Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt, beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte, werde im Regelfall keine weiteren Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein (ausführlich zur sog. Indizwirkung unten XI.B.1.c)2)iv)(a)).[879] Grundsätzlich müsse auch die Berechnungserläuterung ebenso wie das Angebot

[872] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

[873] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 22 und Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM(2017) 712 S. 12.

[874] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim, 16.12.2016 – 7 O 32/16.

[875] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.

[876] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf die wohl andere Ansicht des LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14 – *Stochastisches Rauschen*.

[877] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[878] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 317; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 277; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 256; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 265; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 287; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 269; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 367; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 289; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 199; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 213; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 357 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 308 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 356; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 309 alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 19, LG Mannheim, 8.1.2016 – 7 O 96/14, Rn. 76, 17.11.2016 – 7 O 19/16, Rn. 85.

[879] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 317; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 277; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 256; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 265; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

selbst so rechtzeitig erfolgen, dass dem Verletzer eine ausreichende Reaktionszeit verbleibe (zur zeitlichen Komponente des Angebots oben XI.A.4).[880]

Eine gewisse dynamische Komponente in das Begründungskriterium hineininterpretierend führte das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 weiter aus, sofern zum Zeitpunkt der Angebots aufgrund der angesprochenen Einzelfallumstände das Bedürfnis von konkreteren Erläuterungen noch nicht vorliege, könne dieses auch während des Prozesses entstehen, wenn einzelne materielle FRAND-Voraussetzungen substantiiert vom Verletzer bestritten würden, sodass jedenfalls dann sämtliche Berechnungsfaktoren konkret darzulegen seien.[881] Die konkreten Angaben dürften sich freilich nicht zu den ursprünglichen allgemeineren Angaben in Widerspruch setzen, ansonsten sei das Angebot mangels vorliegender FRAND-Bedingungen als missbräuchlich anzusehen.[882]

c) Substantiierung der Art und Weise der Berechnung und der FRAND-Gemäßheit

1) Verteilung der Darlegungs- und Substantiierungslast

Die Darlegungs- und Beweislast für die FRAND-Gemäßheit des Lizenzvertragsangebots ist eng verknüpft mit der Darlegung der Art und Weise der Berechnung des FRAND-Angebots und der Begründung, wieso der SEP-Inhaber sein Angebot für FRAND hält. Der Darlegung kommt dabei im Gerichtsverfahren doppelte Bedeutung zu. Zu einen hat die Darlegung als Anforderung des FRAND-Angebots (unabhängig von einem Gerichtsverfahren) selbst zu erfolgen, damit das Angebot als FRAND gilt, was dadurch gerechtfertigt wird, dass der Implementierer nur so die FRAND-Gemäßheit des Angebots nachvollziehen kann. Zum anderen hat der SEP-Inhaber im Gerichtsverfahren nach den einschlägigen prozessrechtlichen Bestimmungen seine Standpunkte, nämlich die FRAND-Gemäßheit seines Lizenzangebots, darzulegen und zu substantiieren.

Das Diskriminierungsverbot betreffend führte das OLG Düsseldorf vom 30.3.2017 aus, darlegungs- und beweispflichtig (für die Ungleichbehandlung) sei der Lizenzsucher, was aus Art. 2 der Kartellverfahrensordnung[883] folge, wonach in allen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Verfahren zur Anwendung der Art. 81 und 82 des EWG-Vertrages (welche Art. 101, 102 AEUV entsprächen), die Beweislast für eine Zuwiderhandlung gegen Art. 81 Abs. 1 oder Art. 82 des EWG-Vertrags der Partei obliege, die diesen Vorwurf erhebe.[884] Die FRAND-Erklärung des SEP-Inhabers ändere an dieser Darlegungs- und Beweislast grundsätzlich nichts, weil er mit seiner Zusage, Lizenzen diskriminierungsfrei zu vergeben, lediglich den gesetzlichen Anforderungen aus Art. 102(2)(c) AEUV nachkomme, dem Lizenzsucher aber keine im Vergleich dazu bessere Rechtsposition einräumen wolle (vgl. dazu unten XI.B.3).[885]

Da der Lizenzsucher regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers besitze, insbesondere vom Inhalt der übrigen, von diesem mit anderen Lizenznehmern abgeschlossenen Lizenzverträge, während der SEP-Inhaber diese Kenntnis habe und ihm auch nähere

[880] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 317; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 277; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 256; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 265; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 211; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 225; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 367 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 318 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 366; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 319.

[881] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 317; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 277; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 256; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 265, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 19 und LG Düsseldorf, 13.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 254.

[882] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 317; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 277; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 256; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 265.

[883] Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln.

[884] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[885] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Angaben zumutbar seien treffe den SEP-Inhaber jedoch eine sekundäre Darlegungslast.[886] Dies umfasse Angaben dazu, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Bedingungen eine Lizenz genommen hätten (ausführlich zur Reichweite der sekundären Darlegungslast unten XI.B.1.c)1)).[887] Artikel 2 der Kartellverfahrensordnung stehe dem nicht entgegen, weil er die Anwendung mitgliedstaatlicher Regelungen über die Beibringung von Tatsachen, die in der Sphäre der nicht beweispflichtigen Partei liege, nicht hindere.[888]

Ferner sei der Patentinhaber (primär) darlegungs- und beweispflichtig dafür, dass er einen hinreichenden sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung habe.[889] Dies folge daraus, dass Art. 2 der Kartellverfahrensverordnung nur eine Regelung der Beweislast für die Zuwiderhandlung, nicht aber für deren Rechtfertigung enthalte und nach allgemeinen Grundsätzen derjenige, der sich auf einen Rechtfertigungsgrund berufe, das Vorliegen der Voraussetzungen der Rechtfertigung darlegen und beweisen müsse.[890]

In den Urteilen vom 13.7.2017 und 11.7.2018 führte auch das LG Düsseldorf aus, im Rahmen des Diskriminierungsverbots trage die Darlegungs- und Beweislast für eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung (Diskriminierung) der Verletzer, wobei den SEP-Inhaber eine sekundäre Darlegungslast treffe, was Angaben zu den anderen Lizenznehmern und den mit diesen vereinbarten Bedingungen umfasse, die der SEP-Inhaber vortragen müsse.[891] Sofern eine Ungleichbehandlung vorliege, sei der SEP-Inhaber für deren Rechtfertigung darlegungs- und beweispflichtig.[892]

Abermals führte das LG Düsseldorf in den Entscheiden vom 9.11.2018 und 12.12.2018 aus, der Lizenzsucher sei darlegungs- und beweispflichtig für eine Ungleichbehandlung bzw. das Vorliegen eines Ausbeutungstatbestandes.[893] Jedoch sei dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Lizenzsucher regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers, insbesondere über mit Dritten bestehende Lizenzverträge und deren Reglungsgehalt, besitze.[894] Dies rechtfertige es, dem SEP-Inhaber, der naturgemäß in Kenntnis der Vertragsverhältnisse mit anderen Lizenznehmern sei, und dem nähere Angaben dazu auch zumutbar seien, insoweit eine sekundäre Darlegungslast aufzuerlegen.[895] Stehe eine Ungleichbehandlung fest, so obliege es dem Patentinhaber

[886] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis m.w.N. zur sekundären Darlegungslast auf BGH, 8.1.2014 – I ZR 169/12 – *BearShare*.

[887] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[888] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[889] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf EuG, 17.9.2007 – T201/04 (Slg 2007 II-3601), EU:T:2007:289, Rn. 1144 – *Microsoft/Kommission*.

[890] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[891] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 195; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 209; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 354 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 305 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 353; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 306.

[892] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 195; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 209; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 354 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 305 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 353; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 306.

[893] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 326; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 292; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 297; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 279; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 376; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 298, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem* und LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 58/05, Rn. 140 – *Videosignal-Codierung I*.

[894] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 326; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 292; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 297; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 279; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 376; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 298.

[895] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 326; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 292; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 297; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 279;

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

etwaige die unterschiedliche Behandlung rechtfertigende Umstände darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen.[896]

Weiter führte das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 aus, sei die Benutzerin darlegungsbelastet, die von der Klägerin substantiierte Angemessenheit zu widerlegen. Die Klägerin habe substantiiert dargelegt, dass die angebotene Standardlizenz am Markt akzeptiert worden und bereits tausendfach abgeschlossen worden sei, wie die Vorlage der Lizenzverträge zeige.[897] Dieses Indiz habe die insoweit darlegungsbelastete Beklagte nicht zu erschüttern vermocht.[898] Ihrem Vortrag lasse sich weder eine Unangemessenheit der Lizenzbedingungen entnehmen, noch habe sie einen sachlichen Grund aufgezeigt, warum nur für sie andere Lizenzbedingungen in Betracht kämen, noch, dass sie mit Lizenznehmern vergleichbar wäre, die ebenfalls nicht den Standardlizenzvertrag zu den ersichtlichen Konditionen abgeschlossen hätten.[899]

2) Darlegungs- und Beweislast des Patentinhabers

i) Rolle der Substantiierung im Rahmen der beiden Prongs

Wie das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 und 11.7.2018 implizierte, komme der Substantiierung der FRAND-Gemäßheit im Rahmen der beiden Prongs von FRAND eine doppelte Bedeutung zu:

Zum einen (betreffend den ND-Prong) könne durch die Vorlage bereits abgeschlossener Lizenzverträge über das Klageschutzrecht oder ein Portfolio, welches dieses beinhalte, der Verletzer nur so feststellen, ob das Angebot tatsächlich diskriminierungsfrei (non-discriminatory) sei, da der Verletzer ansonsten üblicherweise keine Möglichkeit habe, Kenntnis von von anderen Unternehmen gezahlten Lizenzgebühren zu erlangen.[900]

Zum andern (betreffend den FR-Prong) könne über bereits abgeschlossene Lizenzverträge oftmals die Akzeptanz der verlangten Lizenzgebühren am Markt belegt werden und damit, dass diese fair und angemessen (Fair/Reasonable) seien.[901] Ob die Vorlage von anderen Lizenzverträgen alleine ausreiche, um die Angemessenheit der Lizenzgebühren zu belegen, hänge vom Einzelfall und insbesondere von der Zahl der abgeschlossenen Lizenzverträge ab (ausführlich unten XI.B.1.c)2)iv)).[902]

9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 376; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 298, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[896] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 326; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 292; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 297; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 279; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 376; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 298, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[897] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[898] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[899] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[900] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[901] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 219.

[902] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

ii) Substantiierung der Patentverletzung

Zum Vortrag der Patentbenutzung bereits im Verletzungshinweis siehe oben VIII.B; zu den Methoden zum Nachweis der Patentbenutzung siehe oben IV.

Das OLG Düsseldorf hielt im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 fest, die Feststellung eines „fairen und angemessenen" Lizenzangebotes erfordere substantiierten Sachvortrag zur Benutzung der Patente aus dem Portfolio.[903] Im Zusammenhang mit einem SEP bedürfe es neben einer Zuordnung zu konkret einschlägigen Passagen des maßgeblichen Standards mindestens der Vorlage sog. Claim-Charts (mit denen die Patentansprüche in Merkmale gegliedert und jeweils den konkreten Passagen im Standard gegenüber gestellt würden).[904] Ferner sei anzugeben, dass diese Merkmale entweder nach dem Standard zwingend verwendet würden oder – Im Falle einer bloßen Option – durch die konkret angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht seien.[905] Im Hinblick auf die Anforderungen an die Feststellung der Benutzung der Portfolio-Patente dürfte § 287 Abs. 2 ZPO anwendbar sein.[906] Für das einschlägige Beweismaß bedeute dies, dass für die tatrichterliche Feststellung keine Überzeugung im Sinne von § 286 ZPO vonnöten sei, sondern eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreiche.[907]

Die Parteien hätten übereinstimmend erklärt, es sei branchenüblich, zum Einstieg in die Verhandlungen eine sogenannte „proud list" (ca. 10-15 ausgewählte Portfolio-Patente mit dazugehörigen Claim-Charts) vorzulegen.[908] Die Auswahl der in die „proud list" aufzunehmenden Patente sei nachvollziehbar zu erläutern.[909] Ergänzende Darlegungen könnten für einzelne Patente aus einer Patentfamilie erforderlich werden, wenn sie abweichende Anspruchswortlaute aufweisen würden und die Beklagten konkret darlegten, dass und warum sich daraus erheblich abweichende Schutzbereiche ergäben, die dazu führen würden, dass sie diese Patente nicht benutzten und dies einen spürbaren Umfang der insgesamt lizenzpflichtigen Benutzungshandlungen betreffe.[910]

Näherer Vortrag der Klägerin zur Rechtsbeständigkeit der Patente des Portfolios dürfte nicht erforderlich sein, da es allein auf die Gültigkeit des jeweiligen Erteilungsaktes ankommen dürfte.[911] Dies bedeute, dass die Klägerin für solche Portfolio-Patente eine Lizenzgebühr verlangen dürfe, sobald sie erteilt und solange sie nicht widerrufen oder vernichtet worden seien.[912]

Darlegungs- und beweisbelastet für die Voraussetzungen des rechtsvernichtenden Einwandes der Erschöpfung seien zwar grundsätzlich die Beklagten.[913] Die Klägerin dürfte jedoch aufgrund in casu konkreter Anhaltspunkte für den Eintritt der Erschöpfung (aufgrund einer Presseerklärung) eine sekundäre Darlegungslast treffen, denn die Beklagten hätten in den konkreten Inhalt der Lizenzvereinbarungen zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der anderen Lizenznehmerin keinen Einblick, während es der Klägerin möglich und zumutbar sein dürfte, diesen vorzutragen und erforderlichenfalls auch einen Auskunftsanspruch gegen ihre Rechtsvorgängerin geltend zu machen.[914]

[903] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.
[904] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.
[905] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.
[906] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.
[907] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 26.
[908] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 27.
[909] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 28.
[910] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 29.
[911] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 31.
[912] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 31.
[913] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 34.
[914] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 34.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

iii) Substantiierung der FRAND-Gemäßheit des Angebotsinhalts

Offenbar von einer gewissen Flexibilität bei der Substantiierung der Begründung der FRAND-Gemäßheit ausgehend hielt das OLG Düsseldorf im Entscheid *Mobiles Kommunikationssystem* fest, falls der SEP-Inhaber zuvor bereits Lizenzen an Dritte vergeben habe, habe er je nach den Umständen des Einzelfalls mehr oder weniger substantiiert insbesondere zu begründen, warum die von ihm vorgesehene Lizenzvergütung gerade vor diesem Hintergrund FRAND sei.[915]

In den Urteilen vom 13.7.2017 und 11.7.2018 führte das LG Düsseldorf aus, als „Art und Weise der Berechnung" verlange der EuGH nicht nur die Angabe der Höhe der Lizenzgebühr und ihrer Berechnung.[916] Vielmehr müsse der SEP-Inhaber dem Verletzer konkret und für diesen nachvollziehbar erläutern, warum die vorgesehenen Lizenzgebühren FRAND seien.[917] Die vom SEP-Inhaber zur „Art und Weise der Berechnung" im Rahmen des Angebots zu machenden Angaben entsprächen inhaltlich dem, was er als Kläger in einem Verletzungsverfahren vortragen müsse, um die FRAND-Gemäßheit seines Angebots gegenüber dem Gericht ausreichend darzulegen.[918] Hierbei sei Vortrag insbesondere zu bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und zu relevanten Gerichtsentscheidungen erforderlich.[919]

Das OLG Düsseldorf führte im Entscheid *Improving Handovers* aus, nach dem vom EuGH vorgesehenen Wechselspiel der beiderseitigen Pflichten obliege es unter den bereits diskutierten Umständen der SEP-Inhaberin als Klägerin, den beklagten Benutzerinnen für das Klagepatent ein schriftliches und konkretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten, das insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben habe, sowie sachlich-inhaltlich sowohl diskriminierungs- als auch ausbeutungsfrei sein müsse.[920] Die inhaltlichen Anforderungen an Ausbeutungs- und Diskriminierungsverbot hätten unmittelbare Konsequenzen für die Vortragslast des SEP-Inhabers, der nach der EuGH-Rechtsprechung in *Huawei/ZTE* im Zusammenhang mit seinem Lizenzangebot Ausführungen zu der „Art und Weise der Berechnung" der von ihm eingeforderten Lizenzgebühr schulde.[921] Weil das Lizenzangebot – jedenfalls ganz vordringlich – künftige Benutzungshandlungen zu regeln habe, deren Umfang und Intensität nicht absehbar sei und für die deswegen im Vornhinein vernünftigerweise auch keine feste Vergütungssumme eingesetzt werden könne, sei mit den Angaben zur „Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung" notwendigerweise etwas anderes gemeint, nämlich die Erläuterung derjenigen Umstände, die die vertraglich z.B. nach Bezugsgröße und Lizenzsatz zu bezeichnenden Vergütungsfaktoren als diskriminierungs- und ausbeutungsfrei (= FRAND) auswiesen.[922] Der Patentinhaber habe also konkret darzutun, weshalb er

[915] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[916] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 199; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 213; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 357 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 308 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 356; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 309.

[917] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 199; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 213; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 357 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 308 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 356; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 309, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 19; LG Mannheim, 8.1.2016 – 7 O 96/14, Rn. 76; 17.11.2016 – 7 O 19/16, Rn. 85.

[918] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 201; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 215; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 358 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 309 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 357; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 310.

[919] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 201; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 215; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 358 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 309 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 357; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 310.

[920] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 312 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE*.

[921] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 317 – *Improving Handovers.*

[922] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 317 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2017 – I-15 U 66/15; 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

glaube, dass die in sein Angebot aufgenommenen Vergütungsparameter (Bezugsgröße und Lizenzsatz) und die sich daraus ergebende Lizenzvergütung zu einer den Lizenzsucher gegenüber anderen nicht diskriminierenden und auch nicht ausbeutenden Benutzungsgebühr führten.[923] Dahingehender Angaben bedürfe es nicht zuletzt deshalb, weil für den Lizenzsucher nur in Kenntnis der die bisherige Lizenzierungspraxis betreffenden Umstände eine sinnvolle Diskussion des ihm unterbreiteten Lizenzangebotes im Hinblick auf seine FRAND-Gemäßheit möglich sei.[924]

Habe der Patentinhaber oder sein Rechtsvorgänger bereits Lizenzen vergeben, so müsse für den Gegner nachvollziehbar dargelegt werden, dass das Lizenzangebot ihn entweder gleich oder weshalb es ihn in welcher Hinsicht ungleich behandele.[925] Im Zusammenhang mit der Lizenzofferte sei deswegen – was der Lizenzsucher naturgemäß auch nicht wissen könne – offenzulegen, ob es weitere Lizenznehmer gebe und, wenn ja, welchen Inhalt die mit ihnen abgeschlossenen Lizenzverträge hätten, insbesondere welchem einheitlichen Lizenzierungskonzept (sofern es ein solches gebe) die Verträge folgen würden.[926] Denn die besagten aktiven Vertragsinhalte würden den rechtlichen Maßstab für das den SEP-Inhaber treffende Verbot einer Diskriminierung bei der Lizenzvergabe setzen.[927] Seien über die Zeit voneinander abweichende Lizenzvertragsinhalte verabredet worden, so stelle sich die Frage nach einer unsachlichen und damit widerrechtlichen Ungleichbehandlung des konkreten Lizenzsuchers grundsätzlich im Verhältnis zu jedem einzelnen der divergierenden Lizenzverträge, es sei denn, ein bestimmter Vertrag sei schon wegen Ausbeutungsmissbrauchs unwirksam.[928] Darüber hinaus schulde der SEP-Inhaber eine aus sich heraus verständliche und inhaltlich ausreichend fundierte Begründung dafür, wieso die von ihm – namentlich mit der Erstlizenz – in Ansatz gebrachte Lizenzvergütung ihrer Höhe nach FRAND, nämlich zumutbar („fair, reasonable“) sei.[929]

Im Entscheid *Funkstation* vom 10.11.2017 führte das LG Mannheim aus, der Angebotsempfänger sei in die Lage zu versetzen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum das unterbreitete Angebot bei objektiver Betrachtung aus der Perspektive des Patentinhabers – FRAND-Kriterien entspreche.[930] Hierfür seien insbesondere die Lizenzgebühr anzugeben und die Art und Weise der Berechnung transparent zu machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus denen die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet werde, bspw. aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt werde, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasse.[931] Der Umfang der dargebotenen Darlegungen im Einzelfall werde dabei von der konkreten Lizenzierungssituation abhängen.[932] Maßstab sei, dass es dem Angebotsempfänger möglich sei zu beurteilen, ob das Angebot – innerhalb des zuzustehenden Entscheidungsspielraums bei objektiver Betrachtung – FRAND sei, und hierauf gegebenenfalls ein FRAND-Gegenangebot zu machen, weil es dem Lizenzsucher, wie der Gerichtshof ausführe, regelmäßig gerade an den hierzu benötigten Informationen über den Lizenzmarkt fehle, über welche der SEP-Inhaber aber verfüge.[933]

Im konkreten Fall habe die Klägerin im Parallelverfahren eingeräumt, ein mit einer anderen Lizenznehmerin abgeschlossener Lizenzvertrag gründe auf einer Pauschalzahlung, welche auch die

[923] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 317 – *Improving Handovers.*
[924] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 317 – *Improving Handovers.*
[925] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*
[926] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*
[927] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*
[928] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*
[929] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*
[930] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.
[931] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.
[932] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.
[933] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

künftige Nutzung des standardrelevanten Portfolios abdecke.[934] Angesichts dieser Sachlage habe die Klägerin zumindest nicht transparent aufgezeigt, dass die in ihrem Angebot geforderte Lizenzgebührenhöhe auch FRAND unter dem Gesichtspunkt „non-discriminatory" sei.[935] Aufgrund der mit einer Lizenznehmerin getroffenen Pauschallizenzabgeltung könne vorliegend nicht ausgeschlossen werden, dass die gewährten Konditionen erheblich günstiger seien als das Lizenzvertragsangebot gegenüber der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft und dass hiernach die Klägerin ihre Lizenznehmer / Lizenzsucher ohne sachliche Rechtfertigung ungleich behandele.[936] Die im Rahmen eines fairen Verfahrens der Klägerin obliegende transparente Erläuterung der Lizenzvertragsbedingungen zum Zwecke ihrer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit als FRAND-Gemäß erfordere bei einer solchen Sachlage jedenfalls weitergehende belastbare Angaben zu den konkreten anderweitig gewährten Lizenzbedingungen und den Sachgründen einer etwaigen Ungleichbehandlung der Lizenznehmern / Lizenzsucher.[937] Dem SEP-Inhaber sei solches schon deshalb zumutbar und abzuverlangen, weil ihn im Hinblick auf das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot nach Art. 102 Abs. 1, Abs. 2 lit. c AEUV ohnehin eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich einer Gleichbehandlung der Lizenzsucher und die (primäre) Darlegungs- und Beweislast für einen hinreichenden sachlichen Grund einer Ungleichbehandlung treffen würden.[938] Der nicht weiter konkretisierte Hinweis der Klägervertreter, die Klägerin habe bei der Vereinbarung der Pauschalzahlung die künftigen Absatzzahlen der begünstigten Lizenznehmerin erheblich unterschätzt, genüge den Erfordernissen einer transparenten Erläuterung in keinem Fall.[939]

Das LG Mannheim vom 28.9.2018 stellte an die Substantiierung durch den Patentinhaber die Anforderungen, der Patentinhaber habe die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich werde, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgehe.[940] Insoweit müsse er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent bzw. plausibel machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet werde, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für den Patentpool von Dritten gezahlt werde, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasse.[941] Um dem angeblichen Patentverletzer die Überprüfung zu ermöglichen, dass der SEP-Inhaber seiner Pflicht zur Gleichbehandlung genüge, sei darüber hinaus erforderlich, dass konkret zu den mit Dritten geschlossenen Lizenzverträgen vorgetragen werde.[942] Diese Angaben hätten nicht nur den Zweck, den Patentbenutzer in die Lage zu versetzen, einzuschätzen, ob das Angebot tatsächlich FRAND sei, vielmehr erhöhe die Transparenz die Chance, dass die Parteien miteinander ins Gespräch kämen und konstruktiv über die Frage der

[934] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 130 – *Funkstation.*

[935] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 130 – *Funkstation.*

[936] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 130 – *Funkstation.*

[937] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 130 – *Funkstation.*

[938] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 130 – *Funkstation*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-U 66/15, Rn. 178 – *Mobiles Kommunikationssystem* zur Darlegungs- und Beweislast.

[939] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 130 – *Funkstation.*

[940] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim, 1.7.2016 – 7 O 209/15, 19.8.2016 – 7 O 19/16, 19.8.2016 – 7 O 238/15, 16.12.2016 – 7 O 29/16, 16.12.2016 – 6 U 32/16, 10.11.2017 – 7 O 28/16 – *Funkstation*.

[941] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, – *Funkstation*.

[942] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 22 und Kommission Europäische Kommission, Mitteilung über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten, COM(2017) 712.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzierungshöhe diskutieren könnten.[943] Erst die Zurverfügungstellung der Drittlizenzverträge löse wiederum eine Reaktionspflicht der Beklagten ihrerseits in angemessener Frist aus.[944]

Zum Zeitpunkt der Substantiierungsobliegenheit siehe oben XI.A.4.

iv) Vortrag zu bestehenden Vereinbarungen

(a) Konkreter Sachvortrag zu bestehenden Vereinbarungen

Zum Geheimnisschutz bestehender Vereinbarungen siehe unten XI.B.1.c)3).

Bereits im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 führte das OLG Düsseldorf aus, die Feststellung eines nicht-diskriminierenden Lizenzangebotes, insbesondere im Hinblick auf die Höhe des Lizenzsatzes, erfordere konkreten Sachvortrag zu den bestehenden Vereinbarungen mit Dritten.[945] Dies umfasse Angaben dazu, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Bedingungen eine Lizenz genommen hätten.[946] Wohl eine gewisse Nachfrage-, bzw. Verhandlungsobliegenheit implizierend führte das OLG weiter aus, nachdem die Beklagten bestritten hätten, dass der Inhalt der den Beklagten unterbreiteten Angebot dem entspreche, was die Klägerin mit Dritten vereinbart habe, dürfe der pauschale Hinweis der Klägerin auf einen „Standardlizenzvertrag“ nicht mehr genügen.[947] Denn daraus ergebe sich nicht, in welchem Umfang tatsächlich dieselben Bedingungen – insbesondere dieselbe Stücklizenz – mit Dritten vereinbart worden sei, und dass der vermeintliche „Standardlizenzvertrag“ auch tatsächlich in der Praxis „gelebt“ werde.[948] Daher dürfe es erforderlich sein, eine entsprechende Lizenzpraxis konkret zu belegen, wobei bspw. der Nachweis von Lizenzverträgen zu diesen Bedingungen mit in der Branche namhaften Unternehmen ausreichend sein dürfe.[949]

Auch im Entscheid *Mobiles Kommunikationssystem* vom 30.3.2017 führte das OLG aus, habe der SEP-Inhaber zuvor bereits Lizenzen an Dritte vergeben, habe er (je nach den Umständen des Einzelfalls mehr oder weniger substantiiert) insbesondere zu begründen, warum die von ihm vorgesehene Lizenzvergütung gerade vor diesem Hintergrund FRAND sei.[950] Die sekundäre Darlegungslast des SEP-Inhabers umfasse im Rahmen des Diskriminierungsverbots Angaben dazu, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Bedingungen eine Lizenz genommen hätten.[951] Artikel 2 der Kartellverfahrensordnung stehe dem nicht entgegen, weil der die Anwendung mitgliedstaatlicher Regelungen über die Beibringung von Tatsachen, die in der Sphäre der nicht beweispflichtigen Partei liegen würden, nicht hindere.[952]

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 und 11.7.2018 führte aus, die sekundäre Darlegungslast des SEP-Inhabers zu Darlegung und Beweis der ungerechtfertigten Ungleichbehandlung (Diskriminierung) umfasse Angaben zu den anderen Lizenznehmern und den mit diesen vereinbarten Bedingungen, die der SEP-Inhaber vortragen müsse, insbesondere bereits abgeschlossene Lizenzverträge (nebst

[943] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim, 16.12.2016 – 7 O 32/16.

[944] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 118.

[945] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 22.

[946] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 23.

[947] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 23.

[948] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 23.

[949] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 23.

[950] OLG Düsseldorf, 22.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 203 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[951] OLG Düsseldorf, 22.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[952] OLG Düsseldorf, 22.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

relevanten Gerichtsentscheidungen).[953] Dem Vortrag zu bestehenden Vereinbarungen kommt dabei im Rahmen der beiden Prongs jeweils eine eigene Bedeutung zu (dazu bereits oben XI.B.1.c)2)i)).

Die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfordere nicht zwingend eine streng mathematische Herleitung.[954] Sofern dies im konkreten Fall möglich sei, sei es erforderlich und regelmäßig hinreichend, die Akzeptanz der verlangten (Standard-)Lizenzverträge am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[955] Habe der SEP-Inhaber bereits Lizenzverträge über das Klageschutzrecht oder ein Portfolio, welches dieses beinhalte, abgeschlossen, so müsse er zu diesen Verträgen konkret vortragen.[956] Zum einen könne der Verletzer nur so feststellen, ob das Angebot tatsächlich diskriminierungsfrei (non-discriminatory) sei, denn der Verletzer habe ansonsten üblicherweise keine Möglichkeit, Kenntnis von von anderen Unternehmen gezahlten Lizenzgebühren zu erlangen.[957] Zum anderen könne über bereits abgeschlossene Lizenzverträge oftmals die Akzeptanz der verlangten Lizenzgebühren auf dem Markt belegt werden und damit, dass diese fair und angemessen (fair / reasonable) seien.[958] Ob die Vorlage von anderen Lizenzverträgen alleine ausreiche, um die Angemessenheit der Lizenzgebühren zu belegen, hänge vom Einzelfall und insbesondere von der Zahl der abgeschlossenen Lizenzverträge ab.[959] Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt (beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte), würden im Regelfall keine weiteren Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein.[960]

Die Darlegung der Art und Weise der FRAND-gemäßen Lizenzgebühren über bereits geschlossene Lizenzverträge sei vorrangig.[961] Über das Ergebnis verschiedener, schon erfolgter, tatsächlicher Lizenzverträge lasse sich die FRAND-Gemäßheit einfacher belegen und sicherer feststellen, als über den Vortrag einzelner Faktoren, die in Lizenzvertragsverhandlungen jeweils eine näher zu

[953] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 201; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 215; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 354, 358 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 305, 309 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 353, 357; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 306, 310.

[954] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[955] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 253.

[956] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[957] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[958] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 219.

[959] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[960] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[961] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 204; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 218; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 360 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 311 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 359; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 312.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

bestimmende, mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen können oder sollen würden, und welcher der Verletzer und das Gericht jeweils erst zu einer Lizenzgebührenhöhe „zusammensetzen" müssten.[962] Maßstab sei, ob die Beklagte auf Grundlage des Vortrags der Klägerin die Möglichkeit habe, die Richtigkeit von deren Aussagen zu prüfen und ein FRAND-Gegenangebot zu unterbreiten.[963]

Um die Höhe der Lizenzgebühren rechtfertigen zu können müsse der SEP-Inhaber grundsätzlich zu allen wesentlichen Lizenzverträgen vortragen – andernfalls bestehe stets die Gefahr, dass selektiv nur solche Verträge vorgelegt würden, die die geforderte Lizenzgebührenhöhe stützen würden.[964] Auch eine Diskriminierungsfreiheit lasse sich nur nachprüfen, wenn zu allen Lizenzverträgen Angaben gemacht würden.[965]

Auch lasse sich über die Vorlage aller bereits abgeschlossener Lizenzverträge auch die Diskriminierungsfreiheit der angebotenen Lizenzvertragsbedingungen aufzeigen.[966] Zum Nachweis eines nicht-diskriminierenden Lizenzvertragsangebots sei konkreter Sachvortrag zu den bestehenden Vereinbarungen mit Dritten erforderlich.[967] Seien bislang noch keine Lizenzverträge über das Klageschutzrecht abgeschlossen worden, so reiche für den Beleg der Diskriminierungsfreiheit aus, dass der SEP-Inhaber ankündige, vergleichbare Lizenzbedingungen auch bei zukünftigen Lizenzierungen von anderen Unternehmen zu verlangen.[968] Die Vorlage bloß einer Auswahl der abgeschlossenen Lizenzverträge ließ das LG nicht genügen, denn eine FRAND-widersprechende Diskriminierung könne bereits dann vorliegen, wenn einem Marktteilnehmer ohne sachlichem Grund deutlich günstigere Konditionen eingeräumt würden.[969] Insofern bedürfe es zur Feststellung der Diskriminierungsfreiheit grundsätzlich des Vortrags zu allen bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen, die dasselbe SEP und/oder das gleiche Portfolio beträfen.[970] Die Diskriminierungsfreiheit lasse sich so nicht feststellen.[971] Der Vortrag der Klägerin, ein bloßer Ausreißer könne nicht zu einer sachwidrigen Ungleichbehandlung führen, lasse vermuten, dass einer der abgeschlossenen Lizenzverträge deutlich

[962] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 204; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 218; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 360 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 311 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 359; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 312.

[963] Vgl. LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 382–83 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 333–34 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 381–82; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 334–35.

[964] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 205; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 219; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 361 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 312 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 360; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 313.

[965] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 205; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 219; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 361 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 312 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 360; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 313.

[966] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 366 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 317 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 365; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 318.

[967] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 366 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 317 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 365; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 318, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 22.

[968] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 366 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 317 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 365; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 318.

[969] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 396 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 347 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 395; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 348.

[970] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 396 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 347 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 395; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 348.

[971] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 396 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 347 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 395; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 348.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

abweichende Bedingungen enthalte.[972] Entgegen der Auffassung der Klägerin könne bereits durch einen einzelnen, ungerechtfertigt günstigeren Lizenzvertragsschluss die gesamte Lizenzierungspraxis als missbräuchlich anzusehen sein.[973] Würden einem Mobiltelefonhersteller ungerechtfertigt günstigere Lizenzgebühren angeboten, so habe dieser Hersteller einen dauerhaften Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern, die insoweit höhere Herstellungskosten hätten.[974]

Schließlich bemerkte das LG weiter, die Klägerin gehe selbst davon aus, dass sie in der Replik nicht vollständig die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung dargelegt habe.[975] Denn sie trage in einem späteren Schriftsatz erneut umfangreich zur FRAND-Gemäßheit vor, wobei sie auch vorher nicht vorgetragene Lizenzverträge erwähnte.[976] Damit gebe sie zu erkennen, dass ihr bisheriger Vortrag nicht vollständig sei.[977]

Das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 und 12.12.2018 entschied, die Angabe zu den Lizenznehmern habe vollständig zu erfolgen, und dürfe nicht auf einige namhafte Unternehmen der Branche reduziert werden.[978] Der Vortrag habe auch Angaben dazu zu enthalten, welche – konkret zu bestimmenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Konditionen eine Lizenz genommen hätten.[979]

Zur Substantiierung der negativen Behauptung, dass eben keine weiteren Lizenzverträge bestehen würden, führte das LG weiter aus, nach dem die Beklagte einige Verträge als fehlend angeführt habe und die Klägerin erwidert habe, dass es solche nicht gebe, sei weiterer Vortrag zu diesen Negativtatsachen in dem vorliegend zu Rede stehendem Zusammenhang nicht möglich.[980]

In *Improving Handovers* führte das OLG Düsseldorf aus, im Zusammenhang mit der Lizenzofferte sei – was der Lizenzsucher naturgemäß nicht wissen könne – offenzulegen, ob es weitere Lizenznehmer gebe und, wenn ja, welchen Inhalt die mit ihnen abgeschlossenen Lizenzverträge hätten, insbesondere welchem einheitlichen Lizenzierungskonzept (sofern es ein solches gebe) die Verträge folgen würden.[981] Denn die besagten aktiven Vertragsinhalte würden den rechtlichen Maßstab setzen für das den SEP-Inhaber treffende Verbot einer Diskriminierung bei der Lizenzvergabe.[982] Seien über die Zeit voneinander abweichende Lizenzvertragsinhalte verabredet worden, so stelle sich die Frage nach einer unsachlichen und damit widerrechtlichen Ungleichbehandlung des konkreten Lizenzsuchers

[972] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 410 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 361 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 409; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 362.

[973] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 410 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 361 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 409; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 362.

[974] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 410 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 361 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 409; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 362.

[975] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 397 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 348 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 396; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 349.

[976] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 397 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 348 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 396; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 349.

[977] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 397 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 348 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 396; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 349.

[978] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 326; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 292; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 279; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 376; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 298.

[979] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 326; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 292; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 297; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 279; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 376; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 298, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 212 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[980] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 402; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 324.

[981] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*

[982] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

grundsätzlich im Verhältnis zu jedem einzelnen der divergierenden Lizenzverträge, es sei denn, ein bestimmter Vertrag sei schon wegen Ausbeutungsmissbrauchs unwirksam.[983]

In *Funkstation* urteilte das LG Mannheim, die bloße Angabe der Multiplikatoren sei nach Auffassung der Kammer nicht annähernd ausreichend, um die Vorgaben der Entscheidung des Unionsgerichtshofs zu erfüllen.[984] Auch der pauschale Verweis auf weitere Lizenznehmer ohne nähere Erläuterung der Lizenzbedingungen sowie der gleichfalls pauschale Verweis auf ein anderes Portfolio sowie ein nicht zugänglich gemachtes Sachverständigengutachten aus einem anderen Verfahren hätten die Beklagte vorprozessual nicht in die Lage versetzt, valide zu prüfen, ob das Angebot der Klägerin FRAND sei und nicht hinreichend plausibel gemacht, warum die Klägerin meine, der Auffassung sein zu dürfen, die von ihr geforderten Konditionen entsprächen FRAND.[985]

In seiner Entscheidung vom 28.9.2018 führte das LG Mannheim aus, der Patentinhaber müsse die Höhe der von ihm geforderten Lizenzgebühr gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent bzw. plausibel machen, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus dem die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet werde, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis von Dritten gezahlt werde, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasse.[986] Um dem angeblichen Patentverletzer die Überprüfung zu ermöglichen, dass der SEP-Inhaber seiner Pflicht zur Gleichbehandlung genüge, sei darüber hinaus erforderlich, dass konkret zu den mit Dritten geschlossenen Lizenzverträgen vorgetragen werde.[987]

(b) Sukzessionsschutz

Die bisherigen Lizenzverträge gehen auf den Erwerber eines SEP-Portfolios über, wie bereits ausgeführt wurde (siehe oben VII.A). Diesbezüglich hielt das OLG Düsseldorf im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 fest, der Senat gehe davon aus, dass die Klägerin jedenfalls im Wege des Sukzessionsschutzes an Lizenzvereinbarungen, die ihre Einzelrechtsvorgängerin mit Lizenznehmern getroffen habe, gebunden sei, so dass sie die Darlegungspflicht auch auf den Inhalt dieser Lizenzvereinbarungen erstrecke.[988]

In *Improving Handovers* führte das OLG Düsseldorf aus, soweit es um Lizenzerteilungen durch Rechtsvorgänger des Klägers gehe, bestehe eine eben solche Mitteilungspflicht im Hinblick auf deren Lizenzierungsverhalten, weil der SEP-Erwerber in die Lizenzierungspraxis seines/seiner Rechtsvorgänger/s einrücke und im Zuge der Patentübertragung die rechtliche Möglichkeit habe, sich Einblick in bestehende oder gewesene Lizenzverträge zu sichern.[989]

Ausführlich zum Übergang der FRAND-Obliegenheit und der bisherigen Lizenzverträge siehe oben VII.B; zum Einwand, einem solchen Vortrag ständen Geheimhaltungsinteressen Dritter entgegen, siehe unten XI.B.1.c)3)v).

[983] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*

[984] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 128 – *Funkstation*.

[985] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 128 – *Funkstation.*

[986] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16 – *Funkstation*.

[987] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 117, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I.15 U 66/15, Rn. 22.

[988] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 24.

[989] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

v) Vortrag zu Gerichtsentscheiden

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 führte aus, es sei insbesondere Vortrag zu bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und zu relevanten Gerichtsentscheidungen erforderlich.[990] Neben den bereits geschlossene Lizenzverträgen müsse der SEP-Inhaber zum Nachweis der Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren zudem etwaige Gerichtsentscheidungen vorlegen, die sich mit den abgeschlossenen Lizenzverträgen befassten.[991] Denn gerichtliche Entscheidungen oder Hinweise zur Angemessenheit [sic!] der vorgeschlagenen Lizenzbedingungen seien jedenfalls als neutrale und sachverständige Stellungnahmen zu berücksichtigen.[992] Der Verletzer habe ein legitimes Interesse an solchen Entscheidungen, während es dem SEP-Inhaber obliege, solche relevanten Aspekte transparent zu machen.[993]

So rügte die Kammer, die Klägerin versäume es weiterhin, das OLG-Urteil in der Parallelsache vorzulegen.[994] Insofern sei der schlichte Hinweis unzureichend, das jetzige Angebot unterscheide sich von dem Angebot, welches vom OLG Düsseldorf als missbräuchlich angesehen worden sei.[995] Der Klägerin habe es oblegen, detailliert darzustellen, weswegen das OLG Düsseldorf das dortige Angebot der Klägerin als nicht FRAND angesehen habe und worin sich konkret das vorliegende Angebot unterscheide und wie diese Unterschiede die Kritik des OLG Düsseldorf überwinden würden.[996] Dies habe sie jedoch unterlassen.[997] Es sei auch nicht ersichtlich, warum bezüglich solcher allgemeiner Informationen Geheimhaltungsverpflichtungen der Klägerin dem Vortrag entgegenständen (dazu unten XI.B.1.c)3)).[998] Die Klägerin habe in der mündlichen Verhandlung zudem zwar ausgeführt, das Urteil sei noch nicht veröffentlicht – sie habe jedoch nicht dargelegt, dass sie sich in dem betreffenden Verfahren, in dem sie selbst Klägerin sei, ausreichend um eine zeitnahe (ggf. teilweise geschwärzte) Offenlegung bemüht habe.[999]

[990] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 201; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 215; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 358 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 309 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 357; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 310.

[991] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 207; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 221; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 362 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 313 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 361; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 314.

[992] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 207; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 221; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 362 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 313 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 361; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 314.

[993] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 207; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 221; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 362 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 313 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 361; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 314.

[994] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 408 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 359 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 407; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 360.

[995] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 408 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 359 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 407; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 360.

[996] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 408 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 359 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 407; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 360.

[997] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 408 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 359 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 407; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 360.

[998] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 408 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 359 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 407; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 360.

[999] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 408 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 359 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 407; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 360.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Zumindest wenn keine oder eine nicht ausreichende Anzahl von Lizenzverträgen abgeschlossen worden ist, müsse der SEP-Inhaber auch sonstige Entscheidungen zur Verletzung und zum Rechtsbestand des oder der zu lizenzierenden Schutzrechte vorlegen.[1000]

Das LG Düsseldorf schränkte die Verwertung ausländischer Gerichtsentscheide eines anderen Sachverhalts im Entscheid vom 12.12.2018 jedoch ein. Der pauschale Verweis auf ein englisches Urteil und der Angemessenheit eines 50%-Abschlags für Verkäufe in der VRC erkläre nicht, wieso nur eine dementsprechend reduzierte Lizenz im Gegensatz zur streitgegenständlichen Lizenzstaffelung FRAND sein solle.[1001] Die Erkenntnisse, die das englische Gericht nach umfassender Sachverhaltsaufklärung gewonnen haben solle, werde nicht mitgeteilt.[1002] Insofern würden auch Zweifel bestehen, inwiefern Ergebnisse, die einen gänzlich anderen Fall mit einem anderen Standard und andere Verhandlungsmodalitäten betreffen würden und nach einer völlig anderen Prozessordnung erhalten worden seien, ohne weiteres auf den vorliegenden Fall in einer anderen Gerichtsbarkeit übertragbar seien.[1003] Letzterem Argument könne sich auch die Beklagte nicht verschließen, da sie in anderem Zusammenhang den Prüfungs- und Beweisumfang, der im US-Verfahren vorherrscht, mit Nichtwissen bestreitet.[1004]

Im Entscheid *Improving Handovers* führte das OLG Düsseldorf betreffend die Diskriminierungsfreiheit [sic!] aus, gerichtlich herbeigeführte Lizenzkonditionen würden keinen Sachverhalt darstellen, der dem SEP-Inhaber als Diskriminierungsverhalten vorgeworfen werden könne, weil es insoweit an einer (freien) unternehmerischen Entscheidung fehle.[1005] Allerdings begründeten sie, wenn die gerichtlichen Vorgaben im Widerspruch zu einer vorherigen Lizenzierungspraxis stehen würden, auch keine Rechtfertigung dafür, sich mit nachfolgenden Lizenzierungen die dem Urteilsspruch folgten, dazu in Widerspruch zu setzen.[1006] Maßgeblich für den Diskriminierungsvorwurf bleibe vielmehr diejenige Lizenzierungspraxis, die der SEP-Inhaber und seine Rechtsvorgänger in freier unternehmerischer Verantwortung ins Werk gesetzt hätten, während die hiervon abweichenden, gerichtlich herbeigeführten Konditionen für sich betrachtet keinen Diskriminierungsvorwurf rechtfertigen würden, weil angesichts des gerichtlichen Klageverfahrens ein sachlicher Grund bestanden habe, sich auf sie einzulassen.[1007]

Betreffend den Gerichtsentscheid eines ausländischen Verfahrens führte das OLG weiter aus, die pauschale Bezugnahme auf die Darstellung der Lizenzierungspraxis der Streithelferin, die in einem anderen Rechtsstreit von anderen anwaltlichen Vertretern eingereicht worden sei, lasse einen konkreten Bezug zu denjenigen Tatsachen, die für den vorliegenden Prozess bedeutsam sein könnten, nicht erkennen und werde von der Klägerin und ihrer Streithelferin auch nicht erläutert.[1008] Genauso unbeachtlich seien Bemerkungen zu dem, was das britische Verletzungsgericht bei der Bestimmung der FRAND-Lizenz im ausländischen Parallelverfahren unternommen habe.[1009] Da der Senat sich selbst eine Überzeugung von der Diskriminierungsfreiheit der streitbefangenen Lizenzangebote machen

[1000] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 208; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 222; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 363 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 314 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 362; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 315.

[1001] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 390; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 329.

[1002] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 390; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 329.

[1003] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 390; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 329.

[1004] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 390; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 329.

[1005] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 315 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf BGH, 4.11.2003 – KZR 2/02 – *Depotkosmetik im Internet*; OLG Düsseldorf, 23.10.2013 – VI-U (Kart) 36/13 – *Frankiermaschinen II;* 14.3.2018 – VI-U (Kart) 7/16 – *Mitbenutzung von Kabelkanalanlagen.*

[1006] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 315 – *Improving Handovers.*

[1007] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 315 – *Improving Handovers.*

[1008] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 321 – *Improving Handovers.*

[1009] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 321 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

müsse, seien die maßgeblichen Tatsachen im Einzelnen dem Senat vorzutragen, was nicht geschehen sei und wozu nach der unveränderten Willensbekundung der Klägerin auch keine Bereitschaft bestehe.[1010] Infolgedessen ließen die an die Beklagten adressierten Lizenzofferten nicht in der gebotenen Weise die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung erkennen, womit die Privilegierung der Beklagten dahingehend, für die Benutzung des Klagepatents nicht mehr als eine FRAND-Lizenzgebühr zu schulden, fortbestehe.[1011]

vi) Vortrag zu anderen Berechnungen und Multiplikatoren und weitere Angaben

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 und 11.7.2018 führte aus, die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfordere nicht zwingend eine streng mathematische Herleitung.[1012] Die Darlegung der Art und Weise der FRAND-gemäßen Lizenzgebühren über bereits geschlossene Lizenzverträge sei vorrangig (ausführlich oben XI.B.1.c)2)iv)).[1013]

Ob neben den vorzutragenden, bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und ggf. Gerichtsentscheidungen zusätzlich noch weitere Angaben zwingend erforderlich seien, hänge davon ab, ob mit den vorgelegten Verträgen die FRAND-Gemäßheit schon nachgewiesen werden könne, was vorrangig von der Anzahl und ggf. der Reichweite der abgeschlossenen Lizenzverträge abhänge.[1014] Sei dies nicht der Fall, müsse der SEP-Inhaber zum Nachweis der angemessenen Lizenzgebührenhöhe etwa zu ihm bekannten vergleichbaren Lizenzverträgen (möglichst im selben oder einem vergleichbaren technischen Gebiet) vortragen.[1015] Auch seien nähere Erläuterungen des Portfolios und dessen Auswirkungen auf die Gebührenhöhe erforderlich, wenn das Klagepatent nicht einzeln lizenziert werde.[1016] Was konkret vorzutragen sei, sei eine Frage des Einzelfalls – letztlich müsse der SEP-Inhaber darlegen, wie er die Lizenzgebührenhöhe festgelegt habe und warum die festgelegte Höhe angemessen sei.[1017]

Das LG Mannheim vom 10.11.2017 hielt betreffend die Bekanntgabe von Multiplikatoren fest, die bloße Mitteilung von Multiplikatoren, die der Berechnung der Lizenzgebühr zugrunde lägen, sei nach den allgemeinen Anforderungen an die Substantiierung (bereits oben XI.B.1.b)) nicht ausreichend, wenn es dem Angebotsempfänger anhand dieser Parameter noch nicht möglich sei zu beurteilen, ob das Angebot – innerhalb des zuzugestehenden Entscheidungsspielraums bei objektiver Betrachtung – FRAND sei, und hierauf gegebenenfalls ein FRAND-Gegenangebot zu machen, weil es dem

[1010] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 321 – *Improving Handovers.*

[1011] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 321 – *Improving Handovers.*

[1012] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[1013] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 204; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 218; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 360 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 311 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 359; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 312.

[1014] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 209; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 223; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 364 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 315 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 363; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 316.

[1015] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 210; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 224; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 365 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 316 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 364; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 317.

[1016] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 210; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 224; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 365 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 316 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 364; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 317.

[1017] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 210; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 224; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 365 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 316 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 364; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 317.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzsucher, wie der Gerichtshof ausführe, regelmäßig gerade an den hierzu benötigten Informationen über den Lizenzmarkt fehle, über welche der SEP-Inhaber aber verfüge.[1018]

Weiter führte das LG aus, die Klägerin habe betreffend ihre Informationsobliegenheit maßgeblich auf ein Privatgutachten eines Professors gestützt und angeführt, dieser habe die von der Klägerin abgeschlossenen Lizenzverträge einsehen können, doch würden intersubjektiv nachvollziehbare Angaben zu anderen Lizenzverträgen fehlen.[1019]

3) Confidentiality: Geheimhaltung und Akteneinsichtsrecht

Die SEP-Inhaberin hat schon bereits wegen des Diskriminierungsverbots im Rahmen des FRAND-Angebots nach der Ansicht der deutschen Gerichte zu sämtlichen relevanten bisher abgeschlossenen Lizenzverträgen vorzutragen. Die Anforderungen an die Substantiierung und die Darlegung sind dabei beim Angebot die gleichen, wie im gerichtlichen Verfahren (siehe oben XI.B.1.c)1)). Fraglich ist jedoch, ob sich die Klägerin mit etwaigen Geheimhaltungsinteressen dieser Vortragspflicht entziehen könnte, oder diesen zumindest unter die Bedingung des Abschlusses eines Geheimhaltungsabkommens stellen darf.[1020]

Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage ist das Akteneinsichtsrecht der Parteien, dass einerseits den Einwand des Geheimhaltungsinteresses zur Verweigerung des Vortrags im Prozess verbietet (dazu sogleich), beziehungsweise den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens verlangt und bei Verweigerung sanktioniert. Das Akteneinsichtsrecht scheint dabei insofern zum vorprozessualen FRAND-Angebot durch, als der SEP-Inhaber zur Substantiierung „nur“ dasselbe wie im gerichtlichen Verfahren vortragen muss, und somit auch schon im Voraus den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung verlangen darf (dazu unten XI.B.1.c)3)iv)(c)).

i) Ausgangspunkt: Vortrag zu bestehenden Vereinbarungen

Wie bereits oben ausgeführt, hat der SEP-Inhaber insbesondere im Rahmen des Diskriminierungsverbots zur Substantiierung der FRAND-Gemäßheit zu allen bestehenden Vereinbarungen vorzutragen. Das Kapitel Confidentiality setzt sich mit dem Thema auseinander, inwiefern der SEP-Inhaber eigene Geschäftsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse Dritter oder Geheimhaltungsvereinbarungen mit Dritten geltend machen kann, um seine Substantiierungslast zu erleichtern. Ziel für den nach Treu und Glauben handelnden SEP-Inhaber würde demnach sein, seiner Darlegungs- und Substantiierungslast bei der Anweise der Art und Weise der Berechnung und der Begründung der FRAND-Gemäßheit in seinem FRAND-Angebot und im Gerichtsverfahren zu genügen, und gleichzeitig eigene und fremde Geschäftsgeheimnisse und Geheimhaltungsvereinbarungen zu schützen.

Da aufgrund des Akteneinsichtsrechts (§ 299 Abs. 1 ZPO) und dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG) die Entscheidgrundlage für das Gericht bzw. die Gerichtsakte für Gericht und Lizenzsucherin (Beklagte) identisch sein muss (siehe dazu unten), stellt sich die Frage, inwiefern der SEP-Inhaber bei Schaffung einer genügenden Entscheidgrundlage die berechtigten Geheimnisinteressen schützen kann. Dies kann durch Verminderung der Darlegungs- und Substantiierungslast, prozessrechtliche Mittel wie Geheimhaltungsanordnungen (dazu unten

[1018] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 123 – *Funkstation*.

[1019] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 129 – *Funkstation.*

[1020] Vgl. zum Geheimnisschutz auch *Peter Georg Picht*, Geheimnisschutz in SEP/FRAND-Verfahren, das GeschGehG und die Patentrechtsreform, Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 14 <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3430926>, sowie *Peter Georg Picht*, Confidentiality in SEP/FRAND Cases – A Critical Overview of Recent Legal Developments, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-08 <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3428272>.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

XI.B.1.c)3)iii)), oder ein Geheimhaltungsabkommen mit der Lizenzsucherin (unten XI.B.1.c)3)iv)) erfolgen.

Das OLG Düsseldorf hielt im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 fest, die für die Wahrung der FRAND-Kriterien jedenfalls sekundär darlegungsbelastete Klägerin könne sich im Prozess insoweit grundsätzlich nicht mit Erfolg darauf berufen, einem konkreten Sachverhalt zum Inhalt anderer Lizenzvereinbarungen (oder der Vorlage der Lizenzvereinbarung) ständen Geheimhaltungsinteressen Dritter entgegen und/oder sie habe sich gegenüber Lizenznehmern zur Geheimhaltung verpflichtet.[1021] Gegenüber nicht am Prozess Beteiligten könne die Wahrung etwaiger Geschäftsgeheimnisse mittels der nach GVG möglichen Schutzanordnungen erfolgen.[1022]

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 führte diesbezüglich aus, es könne dem Verletzer obliegen, ein Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, um dem SEP-Inhaber den Vortrag zu anderen Lizenzverträgen etc. zu ermöglichen.[1023] Verweigere der Verletzer den berechtigten Wunsch des SEP-Inhabers, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, entbinde dies den SEP-Inhaber aber grundsätzlich nicht von der Verpflichtung, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren und abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[1024] Dabei obliege es dem SEP-Inhaber, den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens (d.h. vor Abgabe des Angebots) frühzeitig in die Wege zu leiten.[1025] Weigere sich der Verletzer vollständig, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, führe dies regelmäßig nicht dazu, ihn als lizenzunwillig anzusehen, sondern sei vielmehr bei der Bewertung der FRAND-Gemäßheit des Angebots zu berücksichtigen (dazu ausführlich unten XI.B.1.c)3)iv)(e)).[1026] Im Regelfall werde die fehlende Mitwirkung dazu führen, dass der SEP-Inhaber die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren etwas weniger konkret darlegen müsse und tatsächlich geheimhaltungsbedürftige Informationen anonymisieren oder weglassen dürfe.[1027] Doch könne sich der SEP-Inhaber im Prozess grundsätzlich nicht mit Erfolg pauschal darauf berufen, einem konkreten Sachvortrag zum Inhalt anderer Lizenzvereinbarungen stünden Geheimhaltungsinteresse Dritter entgegen und/oder er habe sich gegenüber Lizenznehmern zur Geheimhaltung verpflichtet.[1028]

Im Entscheid *Improving Handovers* hielt das OLG Düsseldorf vom 22.3.2019 fest, zum einen habe der Erwerber – was direkte Konsequenz der vom Veräußerer für das SEP abgegebenen FRAND-Zusage sei – im Rahmen einer SEP-(Portfolio-)Übertragung Vorsorge dafür zu treffen, dass der Rechtsvorgänger daran mitwirke, dass die von ihm erteilten Lizenzen erforderlichenfalls (z.B. in einem Rechtsstreit) offengelegt werden könnten, um eine (insbesondere gerichtliche) FRAND-Prüfung zu erlauben (dazu ausführlich unten XI.B.1.c)3)v)).[1029]

[1021] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 25.

[1022] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 25.

[1023] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 368 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 319 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 367; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 320.

[1024] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 368 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 319 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 367; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 320, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 25.

[1025] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 373 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 324 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 372; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 325.

[1026] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 370 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 321 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 369; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 322.

[1027] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 371 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 322 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 370; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 323.

[1028] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1029] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Weiter setzte sich das OLG mit dem (nicht gemachten) Einwand auseinander, dass die Streithelferin durch vertragliche Geheimhaltungsvereinbarungen mit ihren Lizenznehmern auch im Hinblick auf notwendige Darlegungen in einem Rechtsstreit um das lizenzierte Schutzrecht daran gehindert sei, die Vertragsinhalte offenzulegen.[1030] Um solches beachtlich geltend zu machen, hätte die Kläger (und/oder ihre Streithelferin) den Inhalt der angeblichen Vertraulichkeitsklauseln im Einzelnen (d.h. mit dem genauen Wortlaut und unter Darlegung sämtlicher auslegungsrelevanter Umstände) mitteilen müssen, weil der betreffende Sachvortrag nur so für den Prozessgegner einlassungsfähig und einer gerichtlichen Prüfung daraufhin zugänglich sei, ob die getroffenen Geheimhaltungsabsprachen tatsächlich so weit reichen würden, wie die Klägerin behaupte (dazu unten XI.B.1.c)3)iv)(a)).[1031] Mangels entsprechenden Sachvortrags der Klägerin sei deswegen unklar, ob die Vertraulichkeitsklauseln nicht einer sinnvollen weil objektiv interessengerechten Interpretation dahingehen zugänglich seien, dass der Streithelferin eine Offenbarung der Lizenzinhalte in dem Maße gestattet sei, in dem sie einer rechtlich unumgänglichen Pflicht hierzu aus der FRAND-Zusage für das Lizenzschutzrecht) unterliege.[1032] Von einer Unmöglichkeit könne überdies nur dann ausgegangen werden, wenn das Leistungshindernis von der Klägerin nicht ausgeräumt werden könne, was im vorliegenden Zusammenhang verlange, dass die Streithelferin und vor allem deren Lizenznehmer trotz nachdrücklicher Anfrage endgültig nicht bereit seien, auf eine Einhaltung der Vertraulichkeitsvereinbarung im Rahmen und für die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits zu verzichten.[1033]

Letztlich könnten die vorgenannten Bedenken aber sogar dahinstehen und könne zugunsten der Klägerin von deren – unzureichend substantiierten – Behauptungen zur Verschwiegenheitspflicht der Streithelferin ausgegangen werden.[1034] Für diesen Fall bleibe nämlich festzuhalten, dass sich die Streithelferin die Erfüllung ihrer kartellrechtlichen Pflicht aus der FRAND-Zusage mit einer umfassenden Vertraulichkeitsvereinbarung schuldhaft unmöglich gemacht habe, weswegen sie mit ihrem Einwand mangelnder Leistungsfähigkeit zum Prozessvortrag nicht mehr gehört werden könne.[1035] Wer als Beweispflichtiger seine eigenen Beweise vernichte oder sonst wie vereitele, bleibe anerkanntermaßen beweisfällig und habe die daraus resultierenden Prozessfolgen zu tragen.[1036] Dasselbe gelte für die der Beweislast vorgelagerte Darlegungslast; wer sich zu einem erforderlichen Prozessvortrag schuldhaft außerstande setze, bleibe darlegungsfällig und unterliege im Rechtsstreit, wenn die darlegungspflichtigen Tatsachen den eingeklagten Anspruch begründeten.[1037] Da der Patenterwerber rechtlich besser nicht dastehen könne als der Veräußerer des Rechts, teile die Klägerin notwendigerweise das prozessrechtliche Schicksal ihrer Streithelferin.[1038]

Die Verpflichtung zur Offenlegung der abgeschlossenen Lizenzverträge verstoße auch nicht gegen Art. 101 AEUV.[1039] Die gegenteilige Auffassung der Streithelferin beruhe maßgeblich auf der Prämisse, dass die das unterbreitete Lizenzangebot erläuternden Bemerkungen zur bisherigen Lizenzierungspraxis den SEP-Inhaber und seinen Rechtsvorgänger zwingen würden, potentiellen Wettbewerbern Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren, was kartellrechtlichen Grundsätzen zuwiderlaufe.[1040] Doch sei

[1030] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1031] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1032] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1033] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1034] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1035] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1036] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1037] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1038] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1039] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.
[1040] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

bereits die Ausgangsthese falsch.[1041] Denn es sei in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass innerhalb eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion sehr wohl Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen möglich seien.[1042] Neben den im GVG vorgesehenen, die Öffentlichkeit betreffenden gerichtlichen Anordnungen gehe es vor allem um Vertraulichkeitsvereinbarungen, die demjenigen abverlangt werden könnten, dem gegenüber ein Geschäftsgeheimnis offenzulegen sei.[1043] Bedingung hierfür sei freilich, dass derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun habe, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstelle, was substantiellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen verlange, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet hätten, und erfordere des Weiteren ebenso substanzielle verifizierbare Angaben dazu, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Information mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohen würden.[1044] Gelinge dies und weigere sich der Gegner, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung zu treffen, so könne sich der SEP-Inhaber zur Rechtfertigung seines Lizenzangebotes auf pauschale, andeutende Angaben beschränkten, die seine Geschäftsgeheimnisse schützen würden; sie seien als prozessual ausreichend und das hierauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu behandeln.[1045]

Statt sich der Mühe zu unterziehen, in Bezug auf die für das vorliegende Klagebegehren relevanten (weil im maßgeblichen Zeitraum aktiven) Lizenzverträge zu begründen, inwiefern die zur Rechtfertigung der Diskriminierungsfreiheit ihres den Beklagten unterbreiteten Lizenzangebotes erforderlichen Ausführungen schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Streithelferin offenlegen würden, und, soweit dem so sein sollen würde, in einem wenigstens andeutenden Vortrag das den betreffenden Lizenzverträgen zugrundeliegende Lizenzierungskonzept zu erläutern, erschöpfe sich der Sachvortrag der Klägerin und ihrer Streithelferin in weitgehend theoretischen Erörterungen darüber, welche Reglungsinhalt in irgendwelchen von ihr abgeschlossenen Lizenzverträgen angeblich Geschäftsgeheimnisse enthalten sollten, wobei selbst dies nicht in der gebotenen Weise näher erläutert werde.[1046]

ii) Grundsatz: Akteneinsichtsrecht und rechtliches Gehör

(a) Akteneinsichtsrecht und „Vorsorgeobliegenheit“ zu Geheimhaltung

Das OLG Düsseldorf beschäftigte sich im Entscheid vom 25.4.2018 mit der sofortigen Beschwerde der Streithelferin einer Beklagten in einem FRAND-Verfahren, in dem die Vorinstanz (LG Düsseldorf, 15.2.2018 – 4c O 81/17) der Streithelferin der Beklagten die von ihr beantragte Akteneinsicht hinsichtlich bestimmter Dokumente sowie bestimmter Ausführungen in den Schriftsätzen der Klägerin und der Beklagten versagt hatte.[1047] Diese Verweigerung könne keinen Bestand haben, da das Landgericht keine Feststellungen zu schützenswerten Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen getroffen habe und ohne den Nachweis solcher Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der Streithelferin der Beklagten eine (vollständige) Einsicht in die Akten des Rechtsstreits nicht verweigert werden könne.[1048]

[1041] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1042] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1043] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1044] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[1045] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[1046] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1047] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 1.

[1048] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 1.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Gemäß § 299 Abs. 1 ZPO habe jede Partei ein – an keine weiteren Bedingungen geknüpftes – Recht auf Einsicht in die Akten ihres Verfahrens.[1049] Der Anspruch diene der Gewährleistung des rechtlichen Gehörs, weil die Partei nur bei voller Kenntnis des dem Gericht unterbreiteten Akteninhalts zu einer umfassenden und angemessenen Rechtsverteidigung in der Lage sei.[1050]

Weil die Parteien nach § 299 Abs. 1 ZPO ohne weitere Voraussetzungen und ohne Einschränkungen Einsicht in die Akten ihres Verfahrens verlangen könnten, habe die betreffende Partei vor einem ihre Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenlegenden Sachvortrag Vorsorge dafür zu treffen, dass mit dem einsichtsberechtigten Prozessgegner eine ihrem Vertraulichkeitsinteresse genügende Geheimhaltungsvereinbarung zustande gekommen sei.[1051] Wer als Kläger oder Beklagter ohne entsprechende Sicherungsvorkehrungen frühzeitig vortrage, nehme deshalb in Kauf, dass seine Geheimnisse dem Gegner ungeschützt im Wege der Akteneinsicht bekannt würden.[1052]

Ein eventuelles Geheimhaltungsinteresse der Partei sei entgegen der Auffassung des Landgerichts für das Akteneinsichtsrecht des Prozessgegners nach § 299 Abs. 1 ZPO grundsätzlich irrelevant.[1053] Die Partei müsse bei Einreichung von Schriftsätzen und anderen Unterlagen deswegen damit rechnen, dass diese den anderen Verfahrensbeteiligten zur Verfügung gestellt würden.[1054] Das in Art. 103 Abs. 1 GG verankerte Gebot rechtlichen Gehörs verlange, dass eine Prozesspartei sich zum gesamten dem Gericht zur Entscheidung unterbreiteten Vortrag des Prozessgegners äußern könne.[1055] Dies setze voraus, dass ihr die Angriffs- und Verteidigungsmittel des Gegners auch vollständig zugänglich gemacht würden.[1056] Der Prozessgegner habe demgemäß grundsätzlich ein Einsichtsrecht in sämtliche Dokumente.[1057] Glaube eine Partei, einen Anspruch auf Geheimnisschutz reklamieren zu können, so habe sie sich deshalb vorab um das Zustandekommen einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Prozessgegner zu kümmern.[1058]

Der Geheimnisträger sei durch dieses Prozedere nicht benachteiligt, weil er von einem seine Geheimnisse aussparenden Sachvortrag keinen Nachteil erleide.[1059] Seine insoweit pauschalen Angaben seien nämlich als prozessual ausreichend und das hierauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu behandeln, wenn letzterer sich weigere, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung mit dem Prozessgegner zu treffen.[1060] Die betreffende Partei sei in einem solchen Fall zwar nicht gänzlich von ihrer Darlegungspflicht entlastet, ihr sei es aber gestattet, im Rahmen ihrer Ausführungen und Erläuterungen diejenigen Umstände in einer Detailliertheit auszulassen, dass ihr Geschäftsgeheimnis in Gefahr sei.[1061] Sie müsse nur vortragen, was sie ohne Gewährung ihrer berechtigten Geheimhaltungsbelange zu offenbaren imstande sei.[1062] In FRAND-Fällen habe eine zu Unrecht verweigerte Vertraulichkeitszusage deshalb zur Konsequenz, dass dem Verletzungskläger nähere, seine Lizenzkonditionen rechtfertigende Erläuterungen gegenüber

[1049] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 6.

[1050] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 6.

[1051] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 7.

[1052] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 7.

[1053] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 8.

[1054] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 8.

[1055] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 8.

[1056] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 8, mit Verweis auf OLG München, 8.11.2004 – 29 W 2601/04; OLG Düsseldorf, 24.9.2008 – 2 W 57/08 und 14.12.2016 – I-2 U 31/16.

[1057] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 8.

[1058] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 8.

[1059] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.

[1060] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.

[1061] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.

[1062] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

dem Verletzungsbeklagten in dem Umfang (aber nicht darüber hinaus!) erlassen seien, wie dies zur Wahrung seiner berechtigten Geheimhaltungsinteressen erforderlich sei.[1063] Statt detaillierter Informationen seien daher gegebenenfalls bloß andeutende Bemerkungen zu machen.[1064] Eine aus Gründen des Geheimnisschutzes lückenhafte Argumentationskette müsse der Verletzungsbeklagte als ausreichende Erläuterung einer FRAND-Gemäßheit des gegnerischen Lizenzangebotes gegen sich gelten lassen.[1065] Da ein entsprechender Vortrag unter den vorgenannten Umständen ausreiche und ein hierauf bezogenes Bestreiten des Gegners unbeachtlich sei, erleide der Verletzungskläger im Prozess keinen Nachteil.[1066] Auf die beschriebene Weise bleibe das Akteneinsichtsverfahren von (ggf. diffizilen) Erwägungen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse befreit, in welches sie – wegen § 299 Abs. 1 ZPO – thematisch auch nicht gehörten.[1067]

Aufgrund der Erwägungen hob das OLG den angefochtenen Beschluss auf und verwies die Sache nach § 572 Abs. 3 ZPO zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurück, was zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts geboten sei und den Beteiligten zugleich Gelegenheit zu ergänzendem Vortrag gebe.[1068] Das Landgericht werde im Rahmen des weiteren Verfahrens zu prüfen haben, ob sich die Klägerin in Bezug auf die in Rede stehenden Anlagen und die in Rede stehenden Textpassagen in den Schriftsätzen der Parteien (und zwar in Bezug auf jede einzelne von ihnen) auf schützenswerte Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse berufen könne.[1069] Darauf würde es nur dann nicht ankommen, wenn sich die Streithelferin von der von ihr mit der Klägerin abgeschlossenen Vertraulichkeitsvereinbarung nicht durch ihr Verhalten losgesagt habe (dazu unten XI.B.1.c)3)iv)(d)).[1070] Gegebenenfalls werde das LG bei seiner erneuten Entscheidung über das weitergehende Akteneinsichtsgesuch der Streithelferin auch zu prüfen haben, ob die Klägerin der Streithelferin durch die von ihr bekundete Übermittlung der Replik nicht bereits bestimmte Informationen offenbart habe.[1071]

(b) Akteneinsichtsrecht des Streithelfers

Wie das OLG Düsseldorf im Beschluss vom 25.4.2018 ausführte, stehe der „Partei“ der Streithelfer gleich.[1072] Obgleich er nicht selbst Partei im formellen Sinne werde, könne der Streithelfer Prozesshandlungen mit der Wirkung vornehmen, als ob die Hauptpartei selbst gehandelt hätte (§ 67 ZPO).[1073] Daher stehe auch ihm das Informationsrecht in Form der Akteneinsicht nach § 299 Abs. 1 ZPO zu.[1074] Folglich gelte für den Streithelfer, dessen einsichtsbegründender Beitritt bei Offenlegung der Geheimnisse bereits erfolgt oder zuverlässig erkennbar sei.[1075]

Eine Ausnahme von der Belanglosigkeit etwaiger Geheimhaltungsinteressen im Akteneinsichtsverfahren sei allein für denjenigen Streithelfer zu machen, der zu einem Zeitpunkt beitrete, zu dem die Partei ihre geheimhaltungsbedürftigen Informationen, geschützt durch eine mit dem Prozessgegner zustande gekommene Geheimhaltungsvereinbarung, bereits zum Prozess- und

[1063] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1064] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1065] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 18.7.2017 – 2 U 23/17.
[1066] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1067] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1068] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 31.
[1069] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 32.
[1070] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 32.
[1071] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 32.
[1072] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 6.
[1073] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 6.
[1074] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 6.
[1075] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 10.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Akteninhalt gemacht habe.[1076] Hier sei der Streithelfer nicht allein deswegen, weil die Hauptpartei sich zur Vertraulichkeit verpflichtet habe, ebenfalls und unabhängig von der Existenz schützenswerter Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zu einer gleichlautenden Verschwiegenheitsverpflichtung gehalten, so dass ihr eine Akteneinsicht solange zu verweigern sei, wie die fragliche Verpflichtung von ihr nicht eingegangen sei.[1077] Zwar dürfe sich der Streithelfer nicht in Widerspruch zum Prozessverhalten der unterstützten Hauptpartei setzen (§ 67 Abs. 1 ZPO); andererseits sei aber auch die Hauptpartei nicht befugt, den berechtigten Anspruch des Streithelfers auf Gewährung rechtlichen Gehörs zu verkürzen.[1078] Im Akteneinsichtsverfahren des Streithelfers sei deshalb der Frage, ob der Gegner schützenswerte Geheimnisse hinreichend substantiiert dargetan habe, die die eingeforderte Sicherungsmaßnahme erfordern und rechtfertigen würden, unabhängig davon nachzugehen, ob sich die Hauptpartei dem betreffenden Ansinnen des Gegners gebeugt habe.[1079]

Seien beachtliche Geheimhaltungsbelange zu verneinen, sei deshalb dem Streithelfer (uneingeschränkt) Akteneinsicht zu gewähren, auch wenn er selbst zu keiner Geheimhaltungszusage bereit sei.[1080] Aus der Tatsache einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den Prozessparteien könne nicht ohne weiteres auf ihre sachliche Notwendigkeit und Berechtigung geschlossen werden.[1081] Denn die Beklagte, der sich einem entsprechenden Verlangen des Klägers widerspruchslos beuge, könne dazu aus ganz besonderen Umständen motiviert sein, z.B. dadurch, dass er selbst Inhaber von SEP sei, so dass er bei nächster Gelegenheit in umgekehrter Parteirolle in Gerichtsverfahren involviert sei, in dem er von seinem Gegner eine gleich gelagerte Verschwiegenheitszusage einfordern wolle, weswegen er jetzt kein Interesse an einer gerichtlichen Klärung habe, die ihm demnächst in anderer Rolle als Kläger schade.[1082]

Seien beachtliche Geheimhaltungsbelange der Partei hingegen zu bejahen, komme nur eine eingeschränkte, die Geheimnisse aussparende Akteneinsicht des Streithelfers in Betracht, weil die Folgen einer vom Streithelfer ohne triftigen Grund verweigerten Geheimhaltungszusage diesen treffen müssten.[1083] Zwar sei der Streithelfer am Prozessgeschehen zu beteiligen (§ 71 Abs. 3 ZPO), andererseits müsse jedoch im Interesse des sich offenbarenden Prozessgegners ein Geheimnisschutz auch im Verhältnis zu ihm sichergestellt werden.[1084] Da der Verletzungsbeklagte nicht für das Verhalten seines Streithelfers verantwortlich sei, auf das er im Zweifel keinerlei Einfluss habe, sei es ausgeschlossen, ihm (dem Verletzungsbeklagten) die Weigerung seines Streithelfers anzulasten.[1085] Die Folgen einer vom Streithelfer ohne triftigen Grund verweigerten Geheimhaltungszusage müssten daher nach dem Verursacherprinzip den Streithelfer treffen.[1086] Den rechtlichen Ansatzpunkt hierfür biete der Grundsatz, dass sich der Streithelfer nicht in Widerspruch zu dem Prozessverhalten der unterstützten Partei setzen dürfe (§ 67 ZPO).[1087] Das schließe ein, dass sich der Streithelfer einem berechtigten Geheimhaltungsverlangen nicht widersetze, dem die unterstützte Hauptpartei im Interesse ihrer Prozessführung im Verletzungsrechtsstreit Rechnung zu tragen gewillt sei.[1088] Daraus und aus dem gleichzeitigen Erfordernis eines Geheimnisschutzes auch gegenüber dem Streithelfer sei

[1076] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 11.
[1077] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 11.
[1078] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 11.
[1079] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 11.
[1080] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 12.
[1081] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 12.
[1082] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 12.
[1083] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1084] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1085] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1086] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1087] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1088] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zu folgern, dass der Streithelfer im Prozess von den geheimhaltungsbedürftigen Informationen, deren Vertraulichkeit er grundlos nicht zusichern wolle, ausgeschlossen bleiben müsse.[1089] Der Anspruch des Streithelfers auf rechtliches Gehör erleide mithin in dem Umfang eine Einschränkung, in dem er sich den berechtigten Geheimhaltungsbelangen der Prozessparteien widersetze.[1090] Das habe zur Konsequenz, dass entsprechende Informationen auch von seinem Akteneinsichtsrecht nach § 299 Abs. 1 ZPO ausgenommen seien.[1091]

Zwar nehme der Kläger, der ohne entsprechende Sicherungsvorkehrungen Dokumente in deinen Zivilprozess einreiche, grundsätzlich in Kauf, dass diese dem Beklagten und dessen Streithelfer zur Verfügung gestellt würden.[1092] Damit, dass Dokumente, die er geschützt durch eine mit dem Beklagten getroffene Geheimhaltungsvereinbarung zum Prozess- und Akteninhalt gemacht habe, einem dem Rechtsstreit auf Seiden des Beklagten beigetretenen Streithelfers, der sich ohne triftigen Grund weigere, selbst eine Geheimhaltungsvereinbarung mit ihm abzuschliessen, unabhängig von der Existenz schützenswerter Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht würden, müsse der Kläger aber nicht in Kauf nehmen.[1093]

Begehre ein dem Rechtsstreit auf Verletzerseite beigetretener Streithelfer, der – anders als die unterstützte Hauptpartei – nicht bereit sei, eine ausreichend strafbewehrte Geheimhaltungsverpflichtungserklärung abzugeben, Akteneinsicht, komme es für deren Gewährung darauf an, ob und inwieweit vom Prozessgegner (sic: der anderen Hauptpartei) schützenswerte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse hinreichend dargetan und nachgewiesen seien (vgl. dazu unten bei der Weigerung XI.B.1.c)3)iv)(e)).[1094] Entsprechendes habe für den Fall zu gelten, dass ein Streithelfer vorwerfbar gegen eine von ihm übernommene Schweigeverpflichtung verstoße und/oder sich ernsthaft von ihr lossage (dazu unten XI.B.1.c)3)iv)(d)), wobei im letzteren Fall freilich eine Versagung der Akteneinsicht nur insoweit in Betracht komme, als die betreffenden Informationen dem Streithelfer nicht bereits zuvor offenbart worden seien.[1095] Soweit es hiernach auf schützenswerte Betriebs- oder Geschäftsheimnisse ankomme, habe derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Geschäftsgeheimnis darstelle.[1096]

Voraussetzung für eine Ablehnung der Akteneinsicht sei für diesen Fall aber, dass es sich bei den in Rede stehenden Anlagen und den diesbezüglichen Ausführungen in den Schriftsätzen der Parteien tatsächlich um schützenswerte Betriebs oder Geschäftsgeheimnisse der Klägerin handele, was nach den unten beschriebenen Kriterien (siehe unten XI.B.1.c)3)iv)(e)) zu beurteilen sei.[1097] Hierzu habe das Landgericht in dem angefochtenen Beschluss keinerlei Feststellungen getroffen und hierzu habe die Klägerin auf den Akteneinsichtsantrag der Streithelferin sowie im Beschwerdeverfahren auch nichts konkretes vorgetragen.[1098] Schon aus diesem Grunde könne die den Akteneinsichtsantrag der Streithelferin zum Teil zurückweisende Entscheidung des Landgerichts keinen Bestand haben.[1099]

[1089] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1090] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1091] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 13.
[1092] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 14, mit Verweis auf OLG Hamburg, 15.11.2016 – 14 W 70/16.
[1093] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 14.
[1094] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 17.
[1095] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 17.
[1096] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1097] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 23.
[1098] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 23.
[1099] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 23.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

iii) Geheimnisschutz durch Schutzanordnungen und andere prozessrechtliche Mechanismen

(a) Schutzanordnung nach GVG

Das Geheimnis kann durch die Schutzanordnungen nach GVG mittels Ausschlusses der Öffentlichkeit, wenn ein wichtiges Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzt würden, nach § 174 Abs. 3 GVG durch Geheimhaltungsanordnung abgesichert werden, um zu verhindern, dass die Anwesenden das Know-how nach der Verhandlung weitergeben.[1100] Jedoch bestehen große Lücken des Schutzes in zeitlicher inhaltlicher Hinsicht. Zeitlich kann die Geheimhaltungsanordnung frühestens in der mündlichen Verhandlung erfolgen, währendem das Geheimnis, wie regelmäßig im FRAND-Verfahren der Fall sein wird, aber möglicherweise bereits in der Klageschrift offengelegt werden muss oder sogar schon als Teil des FRAND-Angebotes, um den Anforderungen an das Diskriminierungsverbot zu genügen. Inhaltlich bestehen Lücken insoweit, dass „wichtiges Geheimnis“ und „schutzwürdiges Interesse“ (§ 172 Nr. 2 GVG) strenge Anforderungen an die Information und das Interesse des Petenten stellt, und zugleich die Geheimhaltungsanordnung ihrem Wortlaut nach nur die Weitergabe der Informationen untersagt, nicht aber die eigene Nutzung (§ 174 Abs. 3 GVG). Unter anderem aus diesen Gründen wird in FRAND-Verfahren regelmäßig weitergehender Geheimnisschutz durch andere Mittel verlangt, wie Geheimhaltungsabkommen (dazu zuletzt unten XI.B.1.c)3)iv)), geschwärzter Vortrag (dazu sogleich), Blackbox- oder in-camera-Verfahren oder ein (abgewandeltes?) Düsseldorfer Verfahren (zu alledem unten XI.B.1.c)3)iii)(c)).

Gelegentlich verwiesen die deutschen Gerichte betreffend Geheimhaltung auf den Behelf der Schutzanordnung nach GVG, insbesondere § 172 Nr. 2 i.V.m.§ 174 Abs. 3 GVG.

Das OLG Düsseldorf hielt per Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 fest, die für die Wahrung der FRAND-Kriterien jedenfalls sekundär darlegungsbelastete Klägerin könne sich im Prozess insoweit grundsätzlich nicht mit Erfolg darauf berufen, einem konkreten Sachvortrag zum Inhalt anderer Lizenzvereinbarungen (oder der Vorlage der Lizenzvereinbarungen) würden Geheimhaltungsinteressen Dritter entgegen stehen und/oder sie habe sich gegenüber Lizenznehmern zur Geheimhaltung verpflichtet.[1101] Gegenüber nicht am Prozess Beteiligten könne die Wahrung etwaiger Geschäftsgeheimnisse mittels der nach GVG möglichen Schutzanordnungen erfolgen.[1102]

Ebenfalls das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 erwähnte die gerichtlichen Geheimnisschutzanordnungen als Mittel zum Geheimnisschutz.[1103]

Auch das OLG Düsseldorf vom 22.3.2019 erwähnte die Schutzanordnung nach GVG als Mittel zum Geheimnisschutz. So nannte es als Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen innerhalt eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion neben Vertraulichkeitsvereinbarungen die im GVG vorgesehenen, die Öffentlichkeit betreffenden gerichtlichen Anordnungen.[1104]

(b) Anonymisierter oder teilweise geschwärzter Vortrag

Zunächst besteht die Möglichkeit, gegenüber Lizenzsucher und Gericht anonymisiert oder teilweise geschwärzt vorzutragen. Dies steht jedoch in offensichtlichem Spannungsverhältnis einerseits zur umfangreichen Darlegungs- und Substantiierungslast bzw. Pflicht zur konkreten Darlegung der Art und

[1100] *Mary-Rose McGuire*, Know-how: Stiefkind, Störenfried oder Sorgenkind? GRUR 2015, 424.

[1101] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 25.

[1102] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 25.

[1103] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1104] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Weise der Berechnung aus der FRAND-Obliegenheit des SEP-Inhabers, sollte er sich entscheiden, dem Lizenzsucher nur einen solchen Vortrag/ein solches Angebot zu übermitteln. Grundsätzlich dürfte der SEP-Inhaber den FRAND-Anforderungen bei einem solchen Vortrag nur dann genügen, wenn der Lizenzsucher die berechtigte Forderung des SEP-Inhabers nach einem Geheimhaltungsabkommen verweigert oder sich von der Vereinbarung losgesagt hat (dazu unten XI.B.1.c)3)iv)(e)).

Andere verfahrensrechtliche Konstrukte, bei denen dem Gericht oder einem Dritten ungeschwärzt vorgetragen wird, gegenüber dem Lizenzsucher aber nur geschwärzt, werden unten (XI.B.1.c)3)iii)(c)) diskutiert.

Die Möglichkeit, teilweise geschwärzte Fassungen zu übermitteln, erwähnte beispielsweise das OLG Düsseldorf im Beschluss vom 14.12.2016. So führte der Senat aus, könne die Klägerin ein teilgeschwärztes Formular einreichen, wobei nur die daraus ersichtlichen Darlegungen dementsprechend auch für die gerichtliche Entscheidung von Interesse wären.[1105] Die Klägerin habe Vorsorge dafür zu tragen, dass in Bezug auf amtswegig zuzustellende Schriftsätze, die Vertrauliches enthielten, kein nachträglicher Geheimnisschutz mehr stattfinde, weil die erklärende Partei vor Einreichung ihrer Schriftsätze dafür Sorge zu tragen habe, dass der begehrte Geheimnisschutz auch dann gewahrt bleibe, wenn der Schriftsatz prozessordnungsgemäß dem Gegner zugestellt werde.[1106] Namentlich könne die Klägerin dadurch ausreichend Vorsorge tragen, dass sie den Beklagten (und ihren Streithelfern) lediglich teilgeschwärzte Fassungen ihrer Berufungserwiderung zustelle und eine weitergehende Information ausdrücklich von einer vorherigen gerichtlichen Geheimhaltungsanordnung abhängig mache.[1107]

Auch das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 wägte sich im Spannungsfeld zwischen Schwärzung und Anonymisierung als Mittel zur Geheimniswahrung und als Grund für nicht-FRAND-gemäßen Vortrag. So reiche der Vortrag der Klägerin mit der eingereichten, teilweise geschwärzten Fassung nicht aus, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren zu begründen.[1108] Die Beklagte habe auf dieser Grundlage keine Möglichkeit, die Richtigkeit der Aussage, die angebotenen Lizenzsätze entsprächen der Standard Rate bzw. der Compliant Rate, zu prüfen.[1109] So bemängelte die Kammer, in der Replik finde sich kein (ungeschwärzter) Vortrag zu den anderen Lizenzverträgen, welche die Klägerin bereits abgeschlossen habe.[1110] Ohne feststellbar FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin sie die Beklagte weder dazu verpflichtet, noch ausreichend dazu in der Lage, ein FRAND-Gegenangebot abzugeben, geschweige denn es innerhalb der gesetzten Schriftsatzfristen in das hiesige Verfahren einzuführen.[1111]

Die Klägerin könne den unzureichenden Vortrag zur Lizenzgebührenberechnung zumindest deshalb nicht erfolgreich mit einer Verzögerungstaktik der Beklagten entschuldigen, weil ihr selbst ohne Geheimhaltungsabkommen näherer Vortrag zur FRAND-Gemäßheit der geforderten Lizenzgebühren möglich gewesen sei.[1112] Gegenüber Dritten könne das Gericht Geheimnisschutzanordnungen

[1105] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 3.

[1106] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 4, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 24.9.2008 – 2 W 57/08.

[1107] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 4.

[1108] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 381 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 332 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 380; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 333.

[1109] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 382 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 333 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 381; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 334.

[1110] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 382 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 333 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 381; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 334.

[1111] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 383 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 334 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 382; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 335.

[1112] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

erlassen.[1113] Die Klägerin hätte anonymisiert zu den abgeschlossenen Lizenzverträgen vortragen können.[1114] Dagegen habe die Klägerin den Vortrag zu diesem Punkt größtenteils geschwärzt.[1115] Unabhängig von der Reichweite eines marktüblichen Geheimhaltungsabkommens könne die Klägerin im gerichtlichen Verfahren nicht Vortrag mit der pauschalen Begründung weglassen, ihre Geheimhaltungsinteressen seien betroffen.[1116]

Die vorgenommenen Schwärzungen seien zu einem großen Teil nicht durch Geheimhaltungsinteressen gerechtfertigt gewesen, wie sich nach Freigabe der geschwärzten Passagen der Replik zeige.[1117] Es sei unter FRAND-Gesichtspunkten bedenklich, wenn die Klägerin ohne Rechtfertigung Vortrag als geheimhaltungsbedürftig zurückhalte, der keine vertraulichen Informationen enthalte, so dass die Beklagte darauf erst kurz vor der mündlichen Verhandlung reagieren könne.[1118]

So sei etwa nicht nachvollziehbar, warum die Klägerin ihre generellen „Erwägungen bei der Bestimmung der Lizenzgebühr“ geschwärzt habe.[1119] Diese enthielten keine geheimhaltungsbedürftigen Informationen, sondern nur die klägerische Auffassung, wie man Lizenzgebühren errechnen müsse.[1120] Worin das Geheimhaltungsinteresse der Klägerin an öffentlich zugänglichen Preisen von Tablets liegen solle, sei ebenfalls nicht ersichtlich, und gleiches gelte für einen zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag, der der Beklagten ohnehin bekannt sei.[1121]

Auch die zunächst geschwärzte Darstellung der durch das Portfolio erfassten Standards und deren Kurzbeschreibung seien offensichtlich nicht geheim; die abgedeckten Standards würden von der Klägerin auf deren Homepage veröffentlicht.[1122] Da der Standard öffentlich sei und auch die Schutzrechte veröffentlicht würden, erscheine weiterhin ein Geheimhaltungsbedürfnis an Claim Charts fraglich – welche ja nur die Patentansprüche mit bestimmten Standardstellen verbinden würden.[1123] Zur Durchsetzung der Schutzrechte müsse die Klägerin ohnehin diese Informationen vorlegen.[1124] Auf ihrer Homepage teile sie Klägerin zudem mit, welche Patente zu ihrem Portfolio

[1113] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1114] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1115] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1116] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1117] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 387 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 338 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 386; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 339.

[1118] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 387 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 338 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 386; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 339.

[1119] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 388 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 339 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 387; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 340.

[1120] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 388 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 339 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 387; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 340.

[1121] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 388 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 339 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 387; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 340.

[1122] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 389 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 340 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 388; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 341.

[1123] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 389 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 340 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 388; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 341.

[1124] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 389 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 340 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 388; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 341.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gehörten und welche Standards sie abdecken würden, wobei sie auch die konkreten Standardspezifikationen nenne.[1125]

Insgesamt könne aus dem bisherigen, geschwärzten Vortrag eine Diskriminierungsfreiheit nicht festgestellt werden.[1126]

Auch betreffend einen anderen Schriftsatz führte das LG aus, der Schriftsatz sei schon deshalb nicht ausreihen, um die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren darzulegen, da er zu einem großen Teil geschwärzt sei.[1127] Damit gebe die Klägerin zu erkennen, dass weiterer Vortrag zur Begründung der FRAND-Gemäßheit erforderlich (und vorbereitet) sei, dieser aber derzeit nicht übermittelt werde.[1128] Damit sei auch aus Sicht der Beklagten klar, dass eine endgültige Prüfung des Angebots nicht möglich sei und auch ein Gegenangebot nicht vorbereitet werden könne.[1129] Solange die Klägerin Teile ihres Vortrages schwärze, laufe das Prozedere damit schlicht nicht weiter.[1130]

Den fehlenden bzw. geschwärzten Vortrag könne die Klägerin auch nicht mit dem Fehlen eines Geheimhaltungsabkommens rechtfertigen (dazu oben XI.B.1.c)3)ii)(a) sowie unten XI.B.1.c)3)iv)(a)).[1131]

(c) Andere verfahrensrechtliche Möglichkeiten?

Diskutiert wurden weiter verschiedene andere verfahrensrechtliche Mechanismen, die die Geheimhaltungsinteressen des SEP-Inhabers oder Dritter wahren könnten, namentlich Blackbox-Verfahren, in-camera-Verfahren oder ein gewissermaßen „umgekehrtes“ Düsseldorfer Verfahren.

Betreffend dem Blackbox-Verfahren, bei dem ein Sachverständiger unabhängig vom Gericht über den vertraulichen Inhalt entscheidet, dürfte ein solcher wohl in einem Spannungsverhältnis zum Unmittelbarkeitsgrundsatz (§ 128 Abs. 1 und § 355 Abs. 1 ZPO) stehen, wonach rechtliche Schlussfolgerungen nicht einem Dritten überlassen werden dürfen, und Wertungen und Beweiswürdigungen dem Gericht vorbehalten werden müssen. Auch dürften sich Schwierigkeiten mit dem Akteneinsichtsrecht und dem Grundsatz der Gewährung rechtlichen Gehörs ergeben.

In diese Richtung führte das LG Mannheim in *Funkstation* aus, soweit sich die Klägerin betreffend ihre Informationsobliegenheit in ihren erstmals im Prozess gemachten Erläuterungen maßgeblich auf das Privatgutachten eines Professors stütze und anführe, dieser habe die von der Klägerin abgeschlossenen Lizenzverträge einsehe können, weise die Beklagte in ihrem Schriftsatz letztlich darauf hin, dass in diesem Gutachten und auch sonst im Klägervorbringen schon intersubjektiv nachvollziehbare Angaben zu mindestens einem Lizenzvertrag fehlen würden.[1132]

[1125] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 389 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 340 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 388; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 341.

[1126] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 409 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 360 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 408; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 361.

[1127] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 413 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 364 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 412; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 365.

[1128] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 413 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 364 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 412; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 365.

[1129] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 413 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 364 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 412; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 365.

[1130] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 413 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 364 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 412; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 365.

[1131] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 414 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 365 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 413; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 366.

[1132] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 129 – *Funkstation*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Bei einem in-camera-Verfahren würde die zu schützende Information dem Gericht vollständig offenbart, dem Prozessgegner dagegen vorenthalten. Die Parteien hätten mithin keine Möglichkeit, die Schlussfolgerung des Gerichts zu überprüfen.

Im Beschluss vom 14.12.2016 setzte sich das OLG Düsseldorf mit einem Geheimhaltungsantrag der Klägerin auseinander, der darauf gerichtet war, die beklagten Parteien und deren Streithelferin von bestimmten, vertraulichen Informationen abzuschneiden, und diese nur deren Prozessbevollmächtigten zukommen zu lassen.[1133] Konkret gehe es bei den vertraulichen Informationen um Angaben, die die Klägerin im Zusammenhang mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand und der Ermittlung einer FRAND-Gebühr zur Rechtsverfolgung der Beklagten und ihrer Streithelferin im Prozess vorgetragen habe.[1134] Die betreffenden Tatsachen sollten gemäß dem Antrag allein den Prozessbevollmächtigten der Beklagten und ihrer Streithelferin zugänglich sein, wobei die Anwälte gerichtlich zur Verschwiegenheit gegenüber der eigenen Partei verpflichtet werden sollten.[1135]

Doch biete für eine derartige Geheimhaltungsanordnung das geltende Rechte keine Grundlage, und eine solche werde von der Klägerin auch nicht benannt.[1136] Sie laufe darauf hinaus, dass den Beklagten und ihrer Streithelferin zu bestimmtem Prozessvortrag der Klägerin – entgegen Art. 103 GG) – das rechtliche Gehör vorenthalten würde (zum Recht auf Akteneinsicht und rechtliches Gehör oben XI.B.1.c)3)i)).[1137] Da die Partei selbst einen Anspruch auf Teilhabe am Prozess habe, sein ein Gehörsverstoß nicht dadurch ausgeräumt, dass bloß ihr anwaltlicher Vertreter von dem gegnerischen Prozessvorbringen Kenntnis erhalte, dieses Vorbringen (wegen der gerichtlichen Geheimhaltungsanordnung) jedoch nicht mit der vertretenen Prozesspartei erörtern könne.[1138]

Eine Verschwiegenheitsanordnung könne bei der gegebenen verfassungsrechtlichen Sachlage allenfalls dann in Betracht kommen, wenn die von der Geheimhaltungsmaßnahme betroffene Partei ausdrücklich auf ihren verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch auf (eigene) Teilhabe am Prozessgeschehen verzichte (wie dies im Düsseldorfer Besichtigungsverfahren bei umgekehrter Konstellation durch eine entsprechende Antragsstellung seitens des Besichtigungsgläubigers geschehe).[1139] Eine dahingehende Prozesserklärung hätten die Beklagten aber verweigert, weshalb allein deswegen die von der Klägerin begehrte Geheimhaltungsmaßnahme nicht in Betracht komme.[1140]

Das gelte auch im Hinblick auf die Streithelferin der Beklagten, die allerdings für ihre Person einen Verzicht auf die Gewährung rechtlichen Gehörs erklärt habe.[1141] Als einfache Nebenintervenientin sei die Streithelferin lediglich dazu befugt, die Beklagten bei ihrer Rechtsverteidigung zu unterstützen, weshalb es ihr untersagt sei, sich mit ihrem Prozessverhalten in Widerspruch zu demjenigen, der den Rechtsstreit führenden Beklagten zu setzen (§ 67 ZPO).[1142] Weil das Gericht seiner Entscheidung immer nur einen Prozessvortrag zu Grunde legen könne, müsse die Bestimmung darüber, welcher Vortrag dies sei, bei der Prozesspartei liegen.[1143] Nachdem sich die Beklagten – was ihr gutes Recht sei – dafür entschieden hätten, ihrem Ausschluss vom Prozessgeschehen zu widersprechen, so dass nur der um

[1133] Vgl. OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1134] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1135] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1136] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1137] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1138] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1139] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1140] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1141] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 2.

[1142] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 2.

[1143] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 2.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

die vertraulichen Informationen bereinigte Sachvortrag der Klägerin für den Rechtsstreit relevant sei, könne die Streithelferin keinen anderen, darüber hinausgehenden Prozessvortrag zur gerichtlichen Entscheidungsgrundlage machen.[1144]

Dass im Hinblick auf den FRAND-Vortrag keine Geheimhaltungsanordnung ergehen könne, habe zur Folge, dass die Klägerin vor der Wahl stehe, entweder ihre Geheimhaltungsbelange zurückzustellen, was bedeute, dass die zur Gerichtsakte gereichte Berufungserwiderung Teil 2/2 nebst vertraulicher Anlagen in vollem Umfang Aktenbestandteil bleibe und somit vom Gericht bei seiner Entscheidung in Erwägung gezogen werden könne, die Beklagte und ihre Streithelferin allerdings auf denselben Kenntnisstand zu bringen seien, um ihnen eine Erwiderung zu ermöglichen.[1145] Sofern die Klägerin hierzu nicht bereit sei, sei die vollständige Berufungserwiderung Teil 2/2, die momentan noch Aktenbestandteil sei, gegen ein teilgeschwärztes Exemplar auszutauschen sei, wie es bislang allein den Beklagten und ihrer Streithelferin überlassen worden sei, wobei dann nur die daraus ersichtlichen Darlegungen dementsprechend auch für die gerichtliche Entscheidung von Interesse wären.[1146]

So setzte das OLG der Klägerin eine dreiwöchige Frist, um mitzuteilen, in welcher Weise sie zu verfahren gedenke.[1147] Dieses Wahlrecht stehe auch nicht der Rechtsprechung entgegen, dass in Bezug auf amtswegig zuzustellende Schriftsätze, die Vertrauliches enthielten, kein nachträglicher Geheimnisschutz mehr stattfinde, weil die erklärende Partei vor Einreichung ihrer Schriftsätze bei Gericht dafür Sorge zu tragen habe, dass der begehrte Geheimnisschutz auch dann gewahrt bleibe, wenn der Schriftsatz prozessordnungsgemäß dem Gegner zugestellt werde.[1148] Vorliegend habe die Klägerin nämlich ausreichende vorsorge dadurch getragen, dass sie den Beklagten und ihrer Streithelferin lediglich eine teilgeschwärzte Fassung ihrer Berufungserwiderung zugestellt und eine weitergehende Information ausdrücklich von einer vorherigen gerichtlichen Geheimhaltungsanordnung abhängig gemacht habe.[1149]

Anschließend verwies das OLG die Klägerin auch auf die Regeln des BGH in der Entscheidung *Umweltengel für Tragetasche*, wonach im Interesse eines Geheimnisschutzes in Betracht komme, dass sich die Beklagten und ihre Streithelferin angemessen strafbewehrt verpflichten müssten, die ihnen von der Klägerin zugänglich gemachten vertraulichen Informationen ausschließlich zu Prozesszwecken und nicht außerhalb des Rechtsstreits zu verwenden und gegenüber jedwedem Dritten geheim zu halten (dazu sogleich).[1150]

Innert der dreiwöchigen Frist, nach der die Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme erhielten, habe die Klägerin die fraglichen Informationen konkret zu identifizieren und beide Seiten hätten einen Vorschlag zur Vertragsstrafenhöhe zu unterbreiten.[1151] Nach Überlassung der vertraulichen Informationen würden die Beklagte und ihre Streithelferin dann eine kurze Frist erhalten, binnen derer sie abschließend darlegen könnten, welche vertraulichen Informationen aus welcher Quelle bereits vorher und seit wann bekannt gewesen seien.[1152] Anschließend führte das OLG im Beschluss vom 17.1.2017, welchen Vertragsinhalt des Unterlassungsvertrags (wohl ein Vorschlag der Beklagten) es

[1144] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 2.

[1145] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 3.

[1146] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 3.

[1147] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 4.

[1148] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 4, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 24.9.2008 – 2 W 57/08.

[1149] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 4.

[1150] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 5.

[1151] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 6.

[1152] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 6.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

für angebracht halte, und räumte der Klägerin eine Frist von zwei Wochen ein, um das ihr unterbreitete Vertragsangebot anzunehmen.[1153]

iv) Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens und Konsequenzen bei Weigerung

(a) Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens allgemein

Das OLG Düsseldorf führte im Beschluss vom 14.12.2016 aus, im Interesse eines Geheimnisschutzes komme nach den Regeln der BGH-Entscheidung *Umweltengel für Tragetasche* in Betracht, dass sich die Beklagten (und ihre Streithelferin) angemessen strafbewehrt verpflichten müssten, die ihnen von der Klägerin zugänglich gemachten vertraulichen Informationen ausschließlich zu Prozesszwecken und nicht außerhalb des Rechtsstreits zu verwenden und gegenüber jedwedem Dritten geheim zu halten.[1154] Eine derartige Verpflichtungszusage dürfe dem Benutzer eines SEP in aller Regel abzuverlangen sein, weil auch er gehalten sei, die FRAND-Vertragsverhandlungen nach Kräften zu fördern, was einschließe, dass auf berechtigte Geheimhaltungsbelange des Schutzrechtsinhabers eingegangen werde.[1155] Mit Rücksicht auf die Beweisschwierigkeiten im Falle eines Verstoßes gegen die Unterlassungserklärung werde im Zweifel eine empfindliche Vertragsstrafe angebracht sein.[1156]

Um Urteil vom 13.7.2017 entschied das LG Düsseldorf, es könne dem Verletzer obliegen, ein Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, um dem SEP-Inhaber den Vortrag zu anderen Lizenzverträgen etc. zu ermöglichen.[1157] Verweigere der Verletzer den berechtigten Wunsch des SEP-Inhabers, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, entbinde dies den SEP-Inhaber aber grundsätzlich nicht von der Verpflichtung, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren und abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[1158]

Ein solches Geheimhaltungsabkommen könne verlangt werden, da der Verletzer eines SEP gehalten sei, die FRAND-Vertragsverhandlungen zu fördern, was ihn auch dazu verpflichte, auf berechtigte Geheimhaltungsbelange des SEP-Inhabers einzugehen.[1159] Der Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens sei in „freien" Lizenzverhandlungen üblich und stehe regelmäßig am Anfang der Diskussion – wie es auch im vorliegenden Fall erfolgt sei.[1160]

Auch das OLG Düsseldorf vom 25.4.2018 führte aus, da der Prozessgegner grundsätzlich ein Einsichtsrecht in sämtliche Dokumente des Verfahrens habe (dazu oben XI.B.1.c)3)ii)), habe sich die Partei, die glaube einen Anspruch auf Geheimnisschutz reklamieren zu können sich vorab um das Zustandekommen einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Prozessgegner zu kümmern.[1161]

[1153] Vgl. OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16.

[1154] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 5, mit Verweis auf BGH, 19.2.2014 – I ZR 230/12 – *Umweltengel für Tragetasche*.

[1155] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 5.

[1156] OLG Düsseldorf, 14.12.2016 – I-2 U 31/16, Rn. 5

[1157] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 368 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 319 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 367; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 320.

[1158] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 368 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 319 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 367; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 320, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I.15 U 66/15, Rn. 25.

[1159] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 369 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 320 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 368; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 321, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16.

[1160] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 369 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 320 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 368; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 321.

[1161] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 8.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Gleiches gelte prinzipiell auch für den Streithelfer, dessen einsichtsbegründender Beitritt bei Offenlegung der Geheimnisse bereits erfolgt oder zuverlässig absehbar sei.[1162] Auch ihm gegenüber habe der Verletzungskläger Vorkehrungen zum Geheimnisschutz zu treffen, bevor er seine Geheimnisse zum Akteninhalt mache.[1163] Eine Ausnahme von der Belanglosigkeit etwaiger Geheimhaltungsinteressen im Akteneinsichtsverfahren sei allein für denjenigen Streithelfer zu machen, der zu einem Zeitpunkt beitrete, zu dem die Partei ihre geheimhaltungsbedürftige Information, geschützt durch eine mit dem Prozessgegner zustande gekommene Geheimhaltungsvereinbarung, bereits zum Prozess- und Akteninhalt gemacht habe (dazu oben XI.B.1.c)3)ii)(b)).[1164] Hervorzuheben bleibt, dass aus der Tatsache einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den Prozessparteien nicht ohne weiteres auf ihre sachliche Notwendigkeit und Berechtigung geschlossen werden könne.[1165] Denn der Beklagte, der sich einem entsprechenden Verlangen der Klägers widerspruchslos beuge, könne dazu aus ganz besonderen Umständen motiviert sein, z.B. dadurch, dass er selbst Inhaber von SEP sei, so dass er bei nächster Gelegenheit in umgekehrter Parteirolle in ein Gerichtsverfahren involviert sei, in dem er von seinem Gegner eine gleich gelagerte Verschwiegenheitszusage einfordern solle, weswegen er jetzt kein Interesse an einer gerichtlicher Klärung habe, die ihm demnächst in anderer Rolle als Kläger schade.[1166]

Weiter führte das OLG aus, soweit es bei Verweigerung, Verstoß oder Lossagung (des Streithelfers) von der Schweigeverpflichtung auf schützenswerte Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ankomme, habe derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Geschäftsgeheimnis darstelle.[1167] Dies verlange substanziellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet hätten, und erfordere des Weiteren ebenso substantielle verifizierbare Angaben, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Informationen (und zwar jeder einzelnen) mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohten.[1168] Relevant seien selbstverständlich nur solche Umstände, die rechtlich billigenswert seien.[1169] Bezüglich der Substantiierungslasten gälten im Prinzip die gleichen Anforderungen wie im gerichtlichen Besichtigungsverfahren.[1170] Die besagten Anforderungen würden nicht nur bestehen, aber vor allem im Interesse des Prozessgegners.[1171] Dieser müsse, ebenso wie sein Streithelfer, beizeiten zuverlässig beurteilen können, ob für sie eine Pflicht zur vertraglichen, im Zweifel vertragsstrafegesicherten Geheimhaltung gegenüber dem Kläger bestehe.[1172] Denn sowohl der grundsätzliche Anlass für die Abgabe einer Verschwiegenheitszusage als auch die angesichts des konkreten Schutzbedürfnisses erforderliche Höhe einer im Falle ihrer Missachtung fälligen Vertragsstrafe seien sinnvoll überhaupt nur einzuschätzen, wenn die eingangs benannten Einzelheiten aus dem Geschäftskreis des Klägers bekannt seien.[1173] Es verstehe sich angesichts dessen von selbst, dass die notwendigen Einlassungen zum Betriebsgeheimnis nicht ihrerseits unter Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse verweigert werden dürften.[1174]

[1162] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 10.
[1163] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 10.
[1164] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 11.
[1165] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 12.
[1166] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 12.
[1167] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1168] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1169] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1170] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1171] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1172] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1173] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1174] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Gehe es im Klägervortrag um Lizenzverträge, die auf Grundlage der abgegebenen FRAND-Erklärung bereits abgeschlossen worden seien und die deshalb auch den Maßstab für die Lizenzerteilung an den Beklagten bilden sollten, so bedürfe ein Geheimnisschutz im Allgemeinen ganz besonderer Begründung und Rechtfertigung.[1175] Die Zusage, fair und diskriminierungsfrei zu lizenzieren, erfordere schon vom Grundsatz her eine Transparenz der kraft Lizenzerteilung geltenden Lizenzierungsbedingungen für den Interessentenkreis.[1176] Denn wie solle der interessierte Dritte sonst in Erfahrung bringen, wie die bereits praktizierten Lizenzbedingungen aussähen, um wirkungsvoll seine Rechte im Verletzungsprozess wahrzunehmen?[1177] Angesichts seiner Pflicht zur Gleichbehandlung Aller sei jedenfalls nicht ohne weiteres ersichtlich, welches rechtlich billigenswerte Interesse der Lizenzgeber daran haben könne, seine praktizierten Lizenzkonditionen, mit denen er eine gleiche Behandlung schulde, vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.[1178] Das gelte umso mehr, als diverse Lizenzierungspools (z.B. MPEG) ihre Lizenzverträge im Internet bereitstellen würden.[1179]

Im Entscheid *Improving Handovers* führte auch das OLG Düsseldorf aus, Bedingung ein Geheimhaltungsabkommen abzuverlangen zu können sei freilich, dass derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun habe, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstelle, was substantiellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen verlange, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet hätten, und erfordere des Weiteren ebenso substanzielle verifizierbare Angaben dazu, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Information mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohen würden.[1180]

(b) Inhalt des Geheimhaltungsabkommens

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 hielt fest, grundsätzlich könne dem Verletzer eines SEP abverlangt werden, die von dem SEP-Inhaber zugänglich gemachten, vertraulichen Informationen nur für die Überprüfung der FRAND-Gemäßheit und für Prozesszwecke zu verwenden, aber nicht außerhalb dieser Bereiche.[1181] Ferner könne grundsätzlich verlangt werden, dass der Verletzer solche Informationen gegenüber Dritten geheim halte.[1182]

Zu erwähnen bleibt, dass die Geheimhaltungsbedürftigkeit bei der Frage der Vortragspflichten des SEP-Inhabers strenger zu verstehen sei als im Rahmen eines Geheimhaltungsabkommens, welches der SEP-Inhaber berechtigterweise fordern könne (ausführlich dazu unten XI.B.1.c)3)iv)(e)).[1183] Anders ausgedrückt: Nicht jede Information, die von einem marktüblichen Geheimhaltungsabkommen umfasst werden würde, könne im Gerichtsverfahren weggelassen werden, ohne dass dies die Vollständigkeit der Darlegung der Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfolgreich in Frage

[1175] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.

[1176] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.

[1177] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.

[1178] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.

[1179] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.

[1180] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[1181] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 369 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 320 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 368; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 321.

[1182] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 369 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 320 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 368; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 321.

[1183] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

stellen könne.[1184] Denn auch ohne Mitwirkung beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens liege die Darlegungslast, dass das unterbreitete Angebot FRAND-Grundsätzen entspreche, weiterhin beim SEP-Inhaber.[1185] Daraus folgt, dass der SEP-Inhaber ein Geheimhaltungsabkommen fordern kann, dass vertrauliche Informationen schützt, die darüber hinausgehen, was er bei Weigerung des Lizenzsuchers weniger vortragen müsste.

Das OLG Düsseldorf beschloss mit Beschluss vom 17.1.2017, es halte den von der Beklagten vorgeschlagenen Unterlassungsvertrag für angebracht, wonach sich die Beklagte verpflichte, gewisse als STRENG gekennzeichnete Lizenzverträge, sowie diejenigen Teile der Berufungserwiderung der Klägerin, die sich mit dem Inhalt dieser Unterlagen beschäftigten, ausschließlich zu Prozesszwecken im vorliegenden Rechtsstreit zu verwenden und ansonsten gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren.[1186] Innerhalb ihres Unternehmens sah der Entwurf vor, dürfe die Beklagte die vorbezeichneten vertraulichen Informationen nur an maximal vier – von ihr namentlich zu benennende und bezüglich ihrer Funktion im Geschäftsbetrieb zu identifizierenden – Mitarbeiter weitergeben.[1187] Darüber hinaus dürfe die Beklagte nach dem Vertragsentwurf die vertraulichen Informationen solchen mit Namen und Anschrift zu benennenden Sachverständigen zugänglich zu machen, die sie im Rechtsstreit unterstützen sollten.[1188] Weiter stelle die Beklagte in geeigneter Weise sicher, dass diejenigen Mitarbeiter und diejenigen Sachverständigen, denen sie vertrauliche Informationen weitergegeben habe, ihrerseits Stillschweigen bewahrten, was in Bezug auf die Mitarbeiter der Beklagten auch für die Zeit nach deren Ausscheiden aus ihren Diensten.[1189]

Weiter verpflichte sich nach dem für angebracht befundenen Vertragsentwurf die Beklagte, für jeden Verstoß gegen die vorbezeichnete Geheimhaltungspflicht an der Klägerin eine Vertragsstrafe von 1 Million EUR zu zahlen.[1190] Für jeden Verstoß eines von ihr eingeweihten Mitarbeiters oder Sachverständigen hafte die Beklagte wie für eigene Zuwiderhandlungen.[1191]

Nach dem Vertragsentwurf seien solche Informationen von der Vertraulichkeitspflicht ausgenommen, die der Beklagten bereits vor der Mitteilung durch die Klägerin im Rechtsstreit bekannt gewesen seien, der Beklagten nachträglich ohne eigenen Rechtsverstoß von dritter Seite zugänglich gemacht worden seien, oder für die Beklagte nachträglich aus öffentlich zugänglichen Quellen verfügbar geworden seien, wobei in letzteren beiden Fällen die Pflicht zur Vertraulichkeit in dem Moment entfalle, in dem die betreffende Information der Beklagten von dritter Seite zugetragen bzw. für die Beklagte zugänglich geworden sei.[1192] Der Einwand anderweitiger Kenntnis der Beklagten stehe zur Beweislast der Beklagten.[1193] Mit ihm könne die Beklagte nur gehört werden, wenn sie binnen einer Frist von drei Wochen nach Zustellung der Berufungserwiderung gegenüber dem Gericht unter Angabe ihrer Informationsquelle diejenigen Informationen konkret benenne, für die eine Vorkenntnis geltend gemacht werden solle, beziehungsweise innerhalb einer Frist von drei Wochen seit der nachträglichen Kenntniserlangung durch die Beklagte gegenüber dem Gericht unter Angabe ihrer Informationsquelle und des Zeitpunktes der Kenntniserlangung diejenigen vertraulichen Informationen konkret benenne,

[1184] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1185] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1186] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.1.

[1187] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.1.

[1188] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.1.

[1189] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.2.

[1190] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.4.

[1191] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.3.

[1192] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.5.

[1193] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.6.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

die ihr nachträglich bekannt geworden seien.[1194] Die Anzeige habe nach dem Vertragsentwurf auch dann zur Gerichtsakte zu erfolgen, wenn der Rechtsstreit zum fraglichen Zeitpunkt bereits abgeschlossen sei.[1195]

Schließlich hielt das OLG fest, die Beklagte erhalte eine Frist von drei Wochen, innerhalb der sie der Klägerin ein entsprechendes Angebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrages unterbreiten könne.[1196] Anschließend erhalte die Klägerin eine Frist von zwei Wochen, um das ihr unterbreitete Vertragsangebot anzunehmen.[1197]

(c) Zeitpunkt des Abschlusses

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 hielt fest, soweit der SEP-Inhaber den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens vom Verletzer fordern könne, habe er dies frühzeitig in die Wege zu leiten.[1198] Regelmäßig werde der SEP-Inhaber mit dem Verletzungshinweis den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens initiieren müssen.[1199] Es obliege dem SEP-Inhaber zeitgleich mit dem Angebot die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darzulegen (siehe oben XI.B.1.a)).[1200] Wenn er sich hierzu nur in der Lage sehe, falls der Verletzer zuvor ein Geheimhaltungsabkommen mit ihm abschließe, so müsse er sich hierum kümmern und dafür Sorge tragen, dass er im Zeitpunkt des Angebots bereits vertrauliche Informationen an den Verletzer übermitteln könne.[1201] Dies entspreche im Übrigen der im Geschäftsverkehr üblichen Praxis, ein Geheimhaltungsabkommen an den Beginn der Lizenzvertragsverhandlungen zu stellen.[1202]

(d) Weigerung, Verzögerung des Abschlusses oder Lossagung vom Geheimhaltungsabkommen

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 führte aus, dass wenn der Verletzer den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens – etwa durch unnötig langsame Reaktionen oder immer neue Forderungen - verzögere, so gelte grundsätzlich Entsprechendes wie bei der vollständigen Verweigerung eines berechtigten Geheimhaltungsabkommens: der SEP-Inhaber werde von der Darlegungslast nicht entbunden, er dürfe aber geheimhaltungsbedürftige Informationen zunächst zurückhalten und nachliefern, sobald ein solches Abkommen geschlossen sei, wobei ich dies – wie gesehen – nicht von der Obliegenheit eines ansonsten möglichst umfassenden Vortrags befreie und nur punktuelle Schwärzungen und Auslassungen möglich seien.[1203]

[1194] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.6.

[1195] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. II.6.

[1196] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Tenor Ziff. III.

[1197] OLG Düsseldorf, 17.1.2017 – I-2 U 31/16, Rn. 1.

[1198] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 373 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 324 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 372; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 325.

[1199] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 373 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 324 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 372; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 325.

[1200] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 374 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 325 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 373; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 326.

[1201] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 374 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 325 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 373; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 326.

[1202] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 374 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 325 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 373; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 326.

[1203] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 375 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 326 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 374; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 327.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Bei Informationen, die der SEP-Inhaber zunächst zurückgehalten habe, könne sich der Verletzer nicht auf eine Verspätung oder mangelnde Zeit zur Prüfung berufen, sofern die Verzögerung auf seinem eigenen Verhalten beruhe.[1204]

Werde ein Geheimhaltungsabkommen zu spät abgeschlossen, weil einerseits der SEP-Inhaber ein solches zu spät initiiert habe und andererseits der Verletzer den Vertragsschluss unangemessen lang verzögert habe, gehe dies grundsätzlich zunächst zu Lasten des SEP-Inhabers: Dieser könne nur dann damit gehört werden, er habe geheimhaltungsbedürftige Informationen nicht rechtzeitig vortragen können, wenn er darlegen könne, dass auch bei frühzeitiger Initiierung der Geheimhaltungsabrede das entsprechende Abkommen zu spät abgeschlossen worden wäre.[1205]

Dementsprechend könne sich die Klägerin nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss des Geheimhaltungsabkommens berufen, da sie dieses zu spät initiiert habe.[1206] Es sei davon auszugehen, dass bei rechtzeitiger Initiierung ein Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen worden wäre, dass der Klägerin ausreichenden Vortrag ermöglich haben würde.[1207] Es könne dahingestellt bleiben, ob die Beklagte unangemessene Forderungen gestellt habe und den Abschluss des letztlich vereinbarten Geheimhaltungsabkommens verzögert habe.[1208] Letztlich sei ein Geheimhaltungsabkommen geschlossen worden, dass es der Klägerin ermöglicht habe, auch den zunächst geschwärzten Vortrag in der Replik zur Begründung des Angebots freizugeben.[1209] Es sei davon auszugehen, dass der Klägerin dies schon zum Zeitpunkt des Ablaufs der Replikfrist möglich gewesen wäre, wenn sie den Abschluss des Geheimhaltungsabkommens rechtzeitig initiiert haben würde.[1210] Denn letztlich sei in weniger als fünf Monaten ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen worden.[1211]

Hingegen habe die Klägerin nach Kündigung des vorprozessualen Geheimhaltungsabkommens erst mit Schreiben vom 5.1.2017 den Abschluss eines neuen Vertrags angeboten.[1212] Vorprozessual habe die Klägerin aber unmittelbar nach der ersten Kontaktaufnahme mit der Beklagten im Schreiben vom 4.12.2012 den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens initiiert.[1213] Ihr sei also schon weit vor Klageerhebung bekannt gewesen, dass aus ihrer Sicht ein Geheimhaltungsabkommen für einen vollständigen FRAND-Vortrag erforderlich sei.[1214]

[1204] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 376 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 327 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 375; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 328.

[1205] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 376 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 327 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 375; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 328.

[1206] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 391 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 342 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 390; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 343.

[1207] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 391 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 342 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 390; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 343.

[1208] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 391 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 342 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 390; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 343.

[1209] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 391 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 342 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 390; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 343.

[1210] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 391 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 342 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 390; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 343.

[1211] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 391 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 342 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 390; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 343.

[1212] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 392 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 343 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 391; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 344.

[1213] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 392 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 343 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 391; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 344.

[1214] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 392 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 343 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 391; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 344.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Dass zum Ablauf der Replikfrist am 13.7.2017 kein Geheimhaltungsabkommen vorgelegen habe, liege schließlich im Verantwortungsbereich der Klägerin.[1215] Der Beklagten könne nicht zur Last gelegt werden, dass sie auf den mit Schreiben vom 5.1.2017 überreichten Entwurf eines Geheimhaltungsabkommens nicht innerhalb der von der Klägerin bis zum 12.3.2017 gesetzten Frist reagiert habe.[1216] Die Reaktion der Beklagten mit Schreiben vom 26.1.2017, d.h. drei Wochen später, sei in zeitlicher Hinsicht nicht als Verzögerungstaktik zu beanstanden.[1217] Die gesetzliche Frist von einer Woche sei deutlich zu kurz gewesen.[1218] Der Entwurf des klägerischen Geheimhaltungsabkommens sei an den deutschen Prozessbevollmächtigten der Beklagten gegangen, der wiederum die Beklagte als seine Mandantin informieren müssen habe, die wiederum – wie die Prozessbevollmächtigte selbst – den Entwurf prüfen und intern abstimmen haben müsse.[1219] Selbst bei schnellstmöglicher Reaktion seien hierfür mindestens zwei bis drei Wochen akzeptabel.[1220] Hinzu komme, dass die Replikfrist ursprünglich auf den 9.12.2016 festgesetzt gewesen sei, weshalb die Klägerin Anlass gehabt hätte, den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens noch früher in die Wege zu leiten.[1221]

Schließlich könne sich die Klägerin auch deshalb nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens berufen, da ihr Vortrag auch dann, wenn man annehme, die Replik sei schon am 13.1.2017 ungeschwärzt eingereicht worden, nicht ausreiche, um die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren zu begründen (vgl. dazu unten XI.B.1.c)3)iv)(e)).[1222]

Auch betreffend ein weiteres Angebot vom 19.5.2017 habe die Klägerin ein Geheimhaltungsabkommen zu spät initiiert und könne so nicht ihren fehlenden bzw. geschwärzten Vortrag rechtfertigen.[1223] Auch wenn das Angebot, das zu spät erfolgt sei (dazu oben XI.A.4), berücksichtigt werden würde, habe die Klägerin auch erst am Tag nach der Angebotsunterbreitung (dem 19.5.2017) eine Erweiterung der abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung in die Wege geleitet.[1224] Warum die entsprechenden Informationen nicht schon vorher Gegenstand der Verhandlungen über das Geheimhaltungsabkommen gewesen und in die Listen der abgeschlossenen Fassung aufgenommen worden seien, sei nicht ersichtlich.[1225]

[1215] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 394 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 345 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 393; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 346.

[1216] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 394 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 345 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 393; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 346.

[1217] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 394 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 345 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 393; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 346.

[1218] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 394 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 345 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 393; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 346.

[1219] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 394 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 345 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 393; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 346.

[1220] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 394 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 345 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 393; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 346.

[1221] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 394 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 345 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 393; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 346.

[1222] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 395 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 346 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 394; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 347.

[1223] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 415 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 366 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 414; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 367.

[1224] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 415 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 366 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 414; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 367.

[1225] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 415 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 366 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 414; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 367.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Das OLG Düsseldorf vom 25.4.2018 führte betreffend das Vorliegen einer Lossagung aus, da der Patentinhaber nach Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung keinen Anspruch darauf habe, dass der Gegner ein regelmäßiges, wiederholendes Bekenntnis zu seiner Verpflichtung ablege, könne von einem „Lossagen" nur dann die Rede sein, senn – verbal oder durch tatsächliches Handeln – eine mit einem bereits vorgenommenen Verstoß ungefähr vergleichbare Gefährdungslage für das Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis geschaffen werde, das Verhalten des Geheimhaltungsverpflichteten also praktisch die Erstbegehungsgefahr für einen Geheimnisbruch schaffe.[1226] Insoweit handele es sich um eine reine Tatfrage, für die in einer Gesamtabwägung alle Umstände des Einzelfalls abzuwägen seien.[1227] Selbst wenn daher von Seites des Geheimhaltungsverpflichteten rechtliche Argumente (anfängliche Nichtigkeitsgründe für die Vertraulichkeitsabsprache oder deren spätere Kündigung) eingewandt würden, könne das Betriebsgeheimnis auch dann – faktisch – in Gefahr sein, wenn die Gründe nur vorgeschoben oder unschlüssig seien; denn maßgeblich sie die tatsächliche Gefährdungsgrundlage, die bei stichhaltigem Unwirksamkeitsgründen eher gegeben sein könnten, aber auch ansonsten (bei rechtlich fehlerhafter Argumentation) bestehen könne.[1228]

Im konkreten Fall erachtete es der Senat als sinnvoll und sachgerecht, dass die Vorinstanz die Frage der Lossagung unter Berücksichtigung der vom OLG aufgestellten Kriterien nochmals prüfe und sodann erneut darüber entscheide, denn dass die Streithelferin der Beklagten die Vertraulichkeitsvereinbarung und deren Reglungsgehalt offensichtlich nicht in Zweifel stelle, lasse sich derzeit jedenfalls nicht feststellen.[1229]

Zwar schienen die Klägerin und die Streithelferin der Beklagten nunmehr von einem übereinstimmenden Verständnis der sogenannten Abstimmungsklausel der (zwischen ihnen abgeschlossenen) Vertraulichkeitsvereinbarung, mit deren Auslegung sich die Vorinstanz befasst habe, auszugehen.[1230] Zu beachten sei allerdings auch, dass die Streithelferin mit Schriftsatz ausdrücklich und ohne Vorbehalt geltend gemacht habe, dass es sich bei der von ihr unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung um Allgemeine Geschäftsbedingungen der Klägerin handele und mehrere Vertragsklauseln, wie insbesondere die Vertragsstrafenklausel, gegen § 307 BGB verstoßen würden.[1231] Soweit ersichtlich, sei sie von diesem Standpunkt bislang nicht, jedenfalls aber nicht ausdrücklich, abgerückt.[1232] Soweit die Streithelferin geltend mache, bei ihren entsprechenden Ausführungen handele es sich um reine Rechtsausführungen über Rechtsfragen, ändere dies nichts daran, dass sie hiermit zum Ausdruck gebracht habe, dass sie wesentliche Klauseln der Vertraulichkeitsvereinbarung für unwirksam halte.[1233] Die Streithelferin habe der Klägerin auch keine neue, von ihr selbst verfasste und von ihr für unbedenklich erachtete Vertraulichkeitsvereinbarung vorgelegt.[1234]

Auf die Nachfrage des Kammervorsitzenden, ob sie – die Streithelferin – die zwischen ihr und der Klägerin geschlossene Vertraulichkeitsvereinbarung als rechtlich verbindlich erachte, habe die Streithelferin der Beklagten mit Schriftsatz lediglich mitgeteilt, dass sie die Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet und diese weder gekündigt noch angefochten habe, was die Streithelferin in der Folge nochmals wiederholt habe.[1235] Dass die Streithelferin die von ihr

[1226] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 16.
[1227] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 16.
[1228] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 16.
[1229] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 24–25.
[1230] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 26.
[1231] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 27.
[1232] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 27.
[1233] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 27.
[1234] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 27.
[1235] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 28.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung nicht angefochten und auch nicht gekündigt habe, treffe zwar zu und sei zwischen den Parteien auch unstreitig.[1236] Soweit die Streithelferin der Beklagten auf dem Standpunkt stehe, dass die Vertraulichkeitsvereinbarung unwirksam sei, bedürfe es allerdings aus ihrer Sicht auch weder einer Kündigung noch einer Anfechtung dieser Vereinbarung.[1237]

Dass sie die Vertraulichkeitsvereinbarung als verbindlich erachte, habe die Streithelferin auch in der Folgezeit nicht klargestellt.[1238] Wie sich aus einer Anlage in der Gerichtsakte ergebe, habe ihr Prozessbevollmächtigter auf die E-Mail des Prozessbevollmächtigten der Klägerin, in der unter anderem davon die Rede sei, der Prozessbevollmächtigten der Streithelferin habe im Akteneinsichtsverfahren erklärt, die Vertraulichkeitsvereinbarung als verbindlich anzusehen, vielmehr mit einer E-Mail vom selben Tag eingewandt, dass die „unterstellte Aussage“ unzutreffend sei.[1239] Soweit die Streithelferin in diesem Zusammenhang vorbringe, der betreffende Satz beziehe sich allein auf die „Formulierung der Klägerin des sich gebunden Fühlens“ werde diese Formulierung in der unmittelbar vorausgegangenen E-Mail des Prozessbevollmächtigten der Klägerin, die auf die der Prozessbevollmächtigten der Streithelferin mit der in Rede stehenden Mitteilung geantwortet habe, überhaupt nicht verwendet.[1240]

Hinzu komme, dass die Klägerin und die Streithelferin der Beklagten möglicherweise auch über die Reichweite der Vertraulichkeitsvereinbarung uneins seien.[1241] Die Klägerin habe vorgetragen, dass sie den Prozessbevollmächtigten der Streithelferin zunächst ein ungeschwärztes Exemplar ihrer Replik vom 19.2.2018 per E-Mail und sodann nebst den in der Replik angeführten Anlagen auch auf dem Postwege in Papierform habe zukommen lassen.[1242] Wie sich aus dem zu den Akten gereichten Schriftverkehr der Beteiligten ergebe, habe die Prozessbevollmächtigte der Streithelferin – vor dem Zugang der Unterlagen in Papierform – auf die die Übersendung einer Papierkopie ankündigende E-Mail des Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 20.2.2018 noch am selben Tag per E-Mail unter anderem geantwortet, dass er etwaige jetzt noch eingehende Unterlagen ungeöffnet wieder zurücksenden werde.[1243] In der Folge sei der Prozessbevollmächtigte der Streithelferin von dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin mit E-Mail vom 19.3.2018 unter anderem dazu aufgefordert worden, die auf dem Postweg übersandte Replik vom 19.2.2018 nebst Anlagen ungeöffnet zurückzusenden.[1244] Hierauf habe der Prozessbevollmächtigte der Streithelferin mit Schreiben vom 29.3.2018 geantwortet.[1245] In diesem Schreiben habe der Prozessbevollmächtigte der Streithelferin zwar unter anderem ausgeführt, dass er, soweit der Prozessbevollmächtigte der Klägerin ihm in den letzten Tagen Unterlagen zugeschickt habe, auf die abgeschlossene Geheimhaltungsvereinbarung verweise.[1246] Mit weiterem Schreiben vom 3.4.2018 habe er dies jedoch wieder relativiert.[1247] In dem besagten Schreiben führe er zunächst aus, dass er irrtümlich zu den Unterlagen der letzten Tage Stellung genommen habe.[1248] Er sei davon ausgegangen, dass inzwischen die „Drittlizenzen“ zugesandt worden seien, was aber nicht der Fall sei.[1249] Im Anschluss hieran heiße es in dem in Rede stehenden

[1236] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 28.
[1237] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 28.
[1238] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 29.
[1239] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 29.
[1240] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 29.
[1241] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1242] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1243] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1244] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1245] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1246] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1247] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1248] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.
[1249] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Schreiben, dass der „Schriftsatz etc." natürlich nicht unter die Vertraulichkeitsvereinbarung („NDA") falle.[1250] Soweit sich diese Aussage auf die Replik der Klägerin vom 19.2.2018 beziehe, welche nach dem hier angefochtenen Beschluss der Vorinstanz offenbar relevante Ausführungen zu den Vergleichslizenzen enthalte, weil die Vorinstanz zahlreiche Passagen dieses Schriftsatzes von der Akteneinsicht ausgenommen habe, scheine die Streithelferin damit offenbar auf dem Standpunkt zu stehen, dass die Vertraulichkeitsvereinbarung nicht für im vorliegenden Rechtsstreit eingereichte Schriftsätze, die sich mit den von der Klägerin als geheim eingestuften Drittlizenzen befassten, gelte.[1251] Wäre dem so, sei die Vertraulichkeitsvereinbarung für die Klägerin praktisch wertlos.[1252]

(e) Rechtsfolge bei Weigerung, Verzögerung oder vorwerfbarem Verstoß gegen das Geheimhaltungsabkommen: Reduzierung der Darlegungslast

Das LG Düsseldorf führte in den Urteilen vom 13.7.2017 aus, dass auch wenn der Verletzer den berechtigten Wunsch des SEP-Inhabers, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, verweigere, entbinde dies den SEP-Inhaber aber grundsätzlich nicht von der Verpflichtung, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren und abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[1253] Weigere sich der Verletzer vollständig, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, führe dies regelmäßig nicht dazu, diesen als lizenzunwillig anzusehen, sondern sei vielmehr bei der Bewertung der FRAND-Gemäßheit des Angebots zu berücksichtigen.[1254]

Im Regelfall werde eine fehlende Mitwirkung am Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens bei einem ansonsten lizenzwilligen Verletzer dazu führen, dass der SEP-Inhaber die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren etwas weniger konkret darlegen müsse und tatsächlich geheimhaltungsbedürftige Informationen anonymisieren oder weglassen dürfe.[1255] Der Verletzer, der den Abschluss eines angemessenen Geheimhaltungsabkommens verweigere oder bewusst verzögere, riskiere damit, dass der SEP-Inhaber auch ohne vollständige Angaben zu anderen Lizenzverträgen seiner Darlegungslast ausreichend nachkomme.[1256]

Die FRAND-widrige, mangelnde Mitwirkung des Verletzers entbinde den SEP-Inhaber jedoch nicht davon, soweit wie ohne Geheimhaltungsabkommen zumutbar, die Art und Weise der Berechnung der FRAND-Lizenzgebühren darzulegen und nachzuweisen.[1257] Dabei sei zu beachten, dass die Geheimhaltungsbedürftigkeit bei der Frage der Vortragspflichten des SEP-Inhabers strenger zu verstehen seien als im Rahmen eines Geheimhaltungsabkommens, welches der SEP-Inhaber berechtigterweise fordern könne.[1258] Anders ausgedrückt: Nicht jede Information, die von einem marktüblichen Geheimhaltungsabkommen umfasst werden würde, könne im Gerichtsverfahren

[1250] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.

[1251] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.

[1252] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 30.

[1253] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 368 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 319 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 367; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 320, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I.15 U 66/15, Rn. 25.

[1254] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 370 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 321 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 369; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 322.

[1255] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 370 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 321 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 369; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 322.

[1256] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 371 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 322 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 370; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 323.

[1257] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1258] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

weggelassen werden, ohne dass dies die Vollständigkeit der Darlegung der Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfolgreich in Frage stellen könne.[1259] Denn auch ohne Mitwirkung beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens liege die Darlegungslast, dass das unterbreitete Angebot FRAND-Grundsätzen entspreche, weiterhin beim SEP-Inhaber.[1260] Dieser könne sich im Prozess grundsätzlich nicht mit Erfolg pauschal darauf berufen, einem konkreten Sachvortrag zum Inhalt anderer Lizenzvereinbarungen stünden Geheimhaltungsinteressen Dritter entgegen und/oder er habe sich gegenüber Lizenznehmern zur Geheimhaltung verpflichtet.[1261] Der SEP-Inhaber dürfe vielmehr nur das zur Geheimhaltung absolut Notwendige unter Darlegung der Gründe dafür weglassen, aber nicht pauschal jeden Vortrag zu anderen Lizenzverträgen verweigern.[1262] Ein FRAND-gemäßes Verhalten gebiete ein großes Maß an Transparenz.[1263] Den bestehenden und potentiellen Lizenznehmern des SEP müsse es möglich sein, die Diskriminierungsfreiheit des Lizenzvertrages festzustellen.[1264] So könnten abgeschlossene Lizenzverträge beispielsweise anonymisiert vorgelegt werden.[1265]

Verzögere der Verletzer den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens – etwa durch unnötig langsame Reaktionen oder immer neue Forderungen – , so gelte grundsätzlich Entsprechendes wie bei der vollständigen Verweigerung eines berechtigten Geheimhaltungsabkommens: Der SEP-Inhaber werde von der Darlegungslast nicht entbunden, er dürfe aber geheimhaltungsbedürftige Informationen zunächst zurückhalten und nachliefern, sobald ein solches Abkommen geschlossen sei, wobei ihn dies – wie gesehen – nicht von der Obliegenheit eines ansonsten möglichst umfassenden Vortrags befreie und nur punktuelle Schwärzungen und Auslassungen möglich seien (dazu oben XI.B.1.c)3)iii)(b)).[1266]

Im konkret vorliegenden Fall könne die Klägerin sich nicht mit Erfolg darauf berufen, ihr sei ein ausreichender Vortrag nicht rechtzeitig möglich gewesen, weil die Beklagte durch unangemessene Forderungen den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens verzögert habe.[1267] Selbst wenn man eine Verzögerung durch die Beklagte annehme, führe dies vorliegend nicht dazu, dass man die FRAND-Gemäßheit des Angebots der Klägerin unterstellen könne bzw. der Beklagten die Berufung auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand insgesamt verwehrt sei.[1268]

Die Klägerin könne den unzureichenden Vortrag zur Lizenzgebührenberechnung zumindest deshalb nicht erfolgreich mit einer Verzögerungstaktik der Beklagten entschuldigen, weil ihr selbst ohne Geheimhaltungsabkommen näherer Vortrag zur FRAND-Gemäßheit der geforderten Lizenzgebühren

---

[1259] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1260] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1261] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1262] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1263] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1264] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1265] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 372 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 323 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 371; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 324.

[1266] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 375 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 326 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 374; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 327.

[1267] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 384 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 335 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 383; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 336.

[1268] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 384 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 335 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 383; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 336.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

möglich gewesen sei.[1269] Gegenüber Dritten könne das Gericht Geheimnisschutzanordnungen erlassen (vgl. oben XI.B.1.c)3)iii)(a)).[1270] Dagegen habe die Klägerin den Vortrag zu diesem Punkt größtenteils geschwärzt.[1271] Unabhängig von der Reichweite eines marktüblichen Geheimhaltungsabkommens könne die Klägerin im gerichtlichen Verfahren nicht Vortrag mit der pauschalen Begründung weglassen, ihre Geheimhaltungsinteressen seien betroffen.[1272]

Die vorgenommenen Schwärzungen seien zu einem großen Teil nicht durch Geheimhaltungsinteressen gerechtfertigt, wie sich nach Freigabe der geschwärzten Passagen in der Replik zeige.[1273] Es sei unter FRAND-Gesichtspunkten bedenklich, wenn die Klägerin ohne Rechtfertigung Vortrag als geheimhaltungsbedürftig zurückhalte, der keine vertraulichen Informationen enthalte, so dass die Beklagte hierauf erst kurz vor der mündlichen Verhandlung reagieren könne.[1274]

Außerdem wäre selbst bei rechtzeitig abgeschlossenem Geheimhaltungsabkommen der Vortrag der Klägerin nicht ausreichend gewesen.[1275] Die Klägerin selbst trage vor, sie habe eine Reihe von Lizenzverträgen zu dem gegenständlichen Portfolio abgeschlossen, von denen sie nur eine Auswahl präsentiere.[1276] Zur Feststellung der Diskriminierungsfreiheit bedürfe es aber grundsätzlich Vortrags zu allen bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen, die dasselbe SEP und/oder das gleiche Portfolio beträfen (siehe oben XI.B.1.c)2)iv)).[1277] Neben abweichenden Zahlen mit den dargelegten Lizenzverträgen im Parallelverfahren gehe die Klägerin im übrigen selbst davon aus, dass sie in der Replik nicht vollständig die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung dargelegt habe, denn sie trage in einem darauffolgenden Schriftsatz erneut umfangreich zur FRAND-Gemäßheit vor, wobei sie auch den zuvor nicht erwähnten Lizenzvertrag erwähne.[1278] Auch insofern könne sie sich nicht auf das Fehlen eines Geheimhaltungsabkommens berufen, da sie ohne weiteres schon in der Replik zu diesem Lizenzvertrag (ggf. zunächst geschwärzt) hätte vortragen können.[1279]

Mit Beschluss vom 18.7.2017 führte das OLG Düsseldorf aus, dass selbst wenn die Verfügungsbeklagte unberechtigt den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung verweigert haben sollte, sei die Folge davon keinesfalls, dass die Verfügungsklägerin ihrer (somit auch gerichtlich nicht weiter verifizierbaren) Pflicht enthoben wäre, der Verfügungsbeklagten ein FRAND-Lizenzangebot zu

---

[1269] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1270] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1271] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1272] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 386 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 337 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 385; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 338.

[1273] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 387 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 338 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 386; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 339.

[1274] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 387 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 338 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 386; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 339.

[1275] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 395 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 346 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 394; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 347.

[1276] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 396 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 347 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 395; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 348.

[1277] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 396 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 347 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 395; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 348.

[1278] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 396, 397 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 347, 348 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 395, 396; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 348, 349.

[1279] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 397 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 348 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 396; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 349.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

unterbreiten und dessen sachliche Berechtigung („Art und Weise der Lizenzberechnung“) zu erläutern.[1280] Eine zu Unrecht verweigerte Vertraulichkeitszusage des Lizenzsuchers hätte allenfalls zur Konsequenz, dass der Verfügungsklägerin nähere, ihre Lizenzkonditionen rechtfertigende Erläuterungen gegenüber der Verfügungsbeklagten in dem Umfang (aber nicht darüber hinaus!) erlassen seien, wie dies zur Wahrung ihrer berechtigten Geheimhaltungsinteressen erforderlich sei.[1281] Statt detaillierter Informationen seien daher gegebenenfalls bloß andeutende Bemerkungen zu machen.[1282] Eine aus Gründen des Geheimnisschutzes lückenhafte Argumentationskette müsse die Verfügungsbeklagte demnach als ausreichende Erläuterung einer FRAND-Gemäßheit des gegnerischen Lizenzangebotes gegen sich gelten lassen.[1283]

Das OLG Düsseldorf vom 25.4.2018 hielt weiter fest, der Geheimnisträger sei durch die Obliegenheit, sich vorab um das Zustandekommen einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Prozessgegner kümmern zu müssen, nicht benachteiligt, weil er von einem seine Geheimnisse aussparenden Sachvortrag keinen Nachteil erleide.[1284] Seine insoweit pauschalen Angaben seien nämlich als prozessual ausreichend und das hierauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu behandeln, wenn letzterer sich weigere, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung mit dem Prozessgegner zu treffen.[1285] Die betreffende Partei sei in einem solchen Fall zwar nicht gänzlich von ihrer Darlegungspflicht entlastet.[1286] Ihr sei es aber gestattet, im Rahmen ihrer Ausführungen und Erläuterungen diejenigen Umstände in einer Detailliertheit auszulassen, dass ihr Geschäftsgeheimnis nicht in Gefahr sei.[1287] Sie müsse nur vortragen, was sie ohne Gefährdung ihrer berechtigten Geheimhaltungsbelange zu offenbaren imstande sei.[1288] Unter Verweis auf die bisherige Senatsrechtsprechung führte das OLG daher aus, in FRAND-Fällen habe eine zu Unrecht verweigerte Vertraulichkeitszusage deshalb zur Konsequenz, dass dem Verletzungskläger nähere, seine Lizenzkonditionen rechtfertigende Erläuterungen gegenüber dem Verletzungsbeklagten in dem Umfang (aber nicht darüber hinaus!) erlassen würden, wie dies zur Wahrung seiner berechtigten Geheimhaltungsinteressen erforderlich sei.[1289] Statt detaillierter Informationen seien daher gegebenenfalls bloß andeutende Bemerkungen zu machen.[1290] Eine aus Gründen des Geheimnisschutzes lückenhafte Argumentationskette müsse der Verletzungsbeklagte als ausreichende Erläuterung einer FRAND-Gemäßheit des gegnerischen Lizenzangebotes gegen sich gelten lassen.[1291] Da ein entsprechender Vortrag unter den vorgenannten Umständen ausreiche und ein hierauf bezogenes Bestreiten des Gegners unbeachtlich sei, erleide der Verletzungskläger im Prozess keinen Nachteil.[1292] Auf die beschriebene Weise bleibe das Akteneinsichtsverfahren von (gegebenenfalls diffizilen) Erwägungen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse befreit, in welches sie – wegen § 299 Abs. 1 ZPO – thematisch auch nicht gehörten.[1293]

Betreffend eine Lossagung des Geheimhaltungspflichtigen von der Vereinbarung führte das OLG aus, habe der Verletzungskläger seine geheimhaltungsbedürftigen Daten unter Schutz von

[1280] OLG Düsseldorf, 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.
[1281] OLG Düsseldorf, 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.
[1282] OLG Düsseldorf, 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.
[1283] OLG Düsseldorf, 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.
[1284] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1285] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1286] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1287] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1288] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1289] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1290] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1291] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 18.7.2017 – 2 U 23/17.
[1292] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.
[1293] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 9.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verschwiegenheitsabsprachen schriftsätzlich oder durch Vorlage von Dokumenten preisgegeben und verstoße der Geheimhaltungspflichtige danach vorwerfbar gegen seine Pflicht zur Verschwiegenheit oder sage er sich von seiner Schweigepflicht los, reduziere sich fortan (d.h. für weitere, bisher noch nicht preisgegebene Geheimnisse), unabhängig von einer möglichen Sanktionierung des vorgefallenen Verstoßes, erneut die Vortragslast des Verletzungsklägers auf das, was er ohne Beeinträchtigung seiner berechtigten Geheimhaltungsinteressen vortragen könne.[1294] Der Vortrag des Verletzungsklägers zur Gerichtsakte habe also wieder so zu erfolgen, dass keine schutzbedürftigen Geheimnisse mitgeteilt würden.[1295] Er müsse der Gegenseite mithin keine weiteren Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse mehr offenbaren, sondern könne sich fortan (wieder) auf einen pauschalen Sachvortrag zurückziehen, wie er ihm ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung gestattet sei.[1296] In Anbetracht der durch Verhalten dokumentierten Unzuverlässigkeit des Anderen sei der Verletzungskläger somit nicht darauf zu verweisen, sehendes Auges (weitere) Geheimnisse preiszugeben und den absehbaren Verrat des Gegners lediglich im Nachhinein zu sanktionieren.[1297]

Soweit es bei Verweigerung, Verstoß oder Lossagung (des Streithelfers) von der Schweigeverpflichtung auf schützenswerte Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse ankomme, habe derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Geschäftsgeheimnis darstelle.[1298] Dies verlange substanziellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet hätten, und erfordere des Weiteren ebenso substantielle verifizierbare Angaben, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Informationen (und zwar jeder einzelnen) mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohten.[1299] Relevant seien selbstverständlich nur solche Umstände, die rechtlich billigenswert seien.[1300] Bezüglich der Substantiierungslasten gälten im Prinzip die gleichen Anforderungen wie im gerichtlichen Besichtigungsverfahren.[1301] Die besagten Anforderungen würden nicht nur bestehen, aber vor allem im Interesse des Prozessgegners.[1302] Dieser müsse, ebenso wie sein Streithelfer, beizeiten zuverlässig beurteilen können, ob für sie eine Pflicht zur vertraglichen, im Zweifel vertragsstrafegesicherten Geheimhaltung gegenüber dem Kläger bestehe.[1303] Denn sowohl der grundsätzliche Anlass für die Abgabe einer Verschwiegenheitszusage als auch die angesichts des konkreten Schutzbedürfnisses erforderliche Höhe einer im Falle ihrer Missachtung fälligen Vertragsstrafe seien sinnvoll überhaupt nur einzuschätzen, wenn die eingangs benannten Einzelheiten aus dem Geschäftskreis des Klägers bekannt seien.[1304] Es verstehe sich angesichts dessen von selbst, dass die notwendigen Einlassungen zum Betriebsgeheimnis nicht ihrerseits unter Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse verweigert werden dürften.[1305]

Gehe es im Klägervortrag um Lizenzverträge, die auf Grundlage der abgegebenen FRAND-Erklärung bereits abgeschlossen worden seien und die deshalb auch den Maßstab für die Lizenzerteilung an den Beklagten bilden sollten, so bedürfe ein Geheimnisschutz im Allgemeinen ganz besonderer

[1294] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 15.
[1295] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 15.
[1296] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 15.
[1297] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 15.
[1298] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1299] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1300] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1301] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1302] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1303] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1304] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.
[1305] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 18.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Begründung und Rechtfertigung.[1306] Die Zusage, fair und diskriminierungsfrei zu lizenzieren, erfordere schon vom Grundsatz her eine Transparenz der kraft Lizenzerteilung geltenden Lizenzierungsbedingungen für den Interessentenkreis.[1307] Denn wie solle der interessierte Dritte sonst in Erfahrung bringen, wie die bereits praktizierten Lizenzbedingungen aussähen, um wirkungsvoll seine Rechte im Verletzungsprozess wahrzunehmen?[1308] Angesichts seiner Pflicht zur Gleichbehandlung Aller sei jedenfalls nicht ohne weiteres ersichtlich, welches rechtlich billigenswerte Interesse der Lizenzgeber daran haben könne, seine praktizierten Lizenzkonditionen, mit denen er eine gleiche Behandlung schulde, vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.[1309] Das gelte umso mehr, als diverse Lizenzierungspools (z.B. MPEG) ihre Lizenzverträge im Internet bereitstellen würden.[1310]

Im konkreten Fall entschied das OLG, komme eine (teilweise) Versagung der Akteneinsicht zwar in Betracht, wenn sich die Streithelferin von der mit der Klägerin getroffenen Vertraulichkeitsvereinbarung ernsthaft „losgesagt" hätte.[1311] Voraussetzung für eine Ablehnung der Akteneinsicht sei für diesen Fall aber, dass es sich bei den in Rede stehenden Anlagen und den diesbezüglichen Ausführungen in den Schriftsätzen der Parteien tatsächlich um schützenswerte Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse der Klägerin handele.[1312] Hierzu habe die Vorinstanz in dem angefochtenen Beschluss keinerlei Feststellungen getroffen und hierzu habe die Klägerin auf den Akteneinsichtsantrag der Streithelferin sowie im Beschwerdeverfahren auch nichts Konkretes vorgetragen.[1313] Schon aus diesem Grunde könne die den Akteneinsichtsantrag der Streithelferin zum Teil zurückweisende Entscheidung des Landgerichts keinen Bestand haben.[1314]

Im Rahmen des weiteren Verfahrens (das OLG hatte die Sache nach § 572 Abs. 3 ZPO zurückverwiesen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts und Gelegenheit zu ergänzendem Vortrag der Parteien)[1315] werde die Vorinstanz zu prüfen haben, ob sich die Klägerin in Bezug auf die in Rede stehenden Anlagen und die in Rede stehenden Textpassagen in den Schriftsätzen der Parteien (und zwar in Bezug auf jede einzelne von ihnen) auf schützenswerte Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse berufen könne.[1316] Hierauf käme es nur dann nicht an, wenn sich die Streithelferin von der von ihr mit der Klägerin abgeschlossenen Vertraulichkeitsvereinbarung nicht durch ihr Verhalten losgesagt habe (dazu oben XI.B.1.c)3)iv)(d)).[1317] Gegebenenfalls werde die Vorinstanz bei seiner erneuten Entscheidung über das weitergehende Akteneinsichtsgesuch der Streithelferin auch zu prüfen haben, ob die Klägerin der Streithelferin durch die von ihr bekundete Übermittlung der Replik (zum Sachverhalt oben XI.B.1.c)3)ii)(a)) nicht bereits bestimmte Informationen offenbart habe.[1318]

Das OLG Düsseldorf vom 22.3.2019 führte aus in seinem Entscheid *Improving Handovers* betreffend den Einwand der Veräußerin eines SEP-Portfolios, sie könne der Erwerberin im Zuge des Patenterwerbs keine Einzelheiten zu den bestehenden Lizenzverträgen mitteilen, rechtlich erheblich könne allenfalls der Einwand sein, dass die Streithelferin durch vertragliche Geheimhaltungsvereinbarungen mit ihren Lizenznehmern auch im Hinblick auf notwendige Darlegungen in einem Rechtsstreit um das lizenzierte

[1306] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.
[1307] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.
[1308] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.
[1309] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.
[1310] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 19.
[1311] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 23.
[1312] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 23.
[1313] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 23.
[1314] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 23.
[1315] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 31.
[1316] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 32.
[1317] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 32.
[1318] OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18, Rn. 32.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Schutzrecht daran gehindert sei, die Vertragsinhalte offenzulegen.[1319] Um solches beachtlich geltend zu machen, hätte die Kläger (und/oder ihre Streithelferin) den Inhalt der angeblichen Vertraulichkeitsklauseln im Einzelnen (d.h. mit dem genauen Wortlaut und unter Darlegung sämtlicher auslegungsrelevanter Umstände) mitteilen müssen, weil der betreffende Sachvortrag nur so für den Prozessgegner einlassungsfähig und einer gerichtlichen Prüfung daraufhin zugänglich sei, ob die getroffenen Geheimhaltungsabsprachen tatsächlich so weit reichen würden, wie die Klägerin behaupte.[1320] Mangels entsprechenden Sachvortrags der Klägerin sei deswegen unklar, ob die Vertraulichkeitsklauseln nicht einer sinnvollen weil objektiv interessengerechten Interpretation dahingehen zugänglich seien, dass der Streithelferin eine Offenbarung der Lizenzinhalte in dem Maße gestattet sei, in dem sie einer rechtlich unumgänglichen Pflicht hierzu aus der FRAND-Zusage für das Lizenzschutzrecht) unterliege.[1321] Von einer Unmöglichkeit könne überdies nur dann ausgegangen werden, wenn das Leistungshindernis von der Klägerin nicht ausgeräumt werden könne, was im vorliegenden Zusammenhang verlange, dass die Streithelferin und vor allem deren Lizenznehmer trotz nachdrücklicher Anfrage endgültig nicht bereit seien, auf eine Einhaltung der Vertraulichkeitsvereinbarung im Rahmen und für die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits zu verzichten.[1322]

Letztlich könnten die vorgenannten Bedenken aber sogar dahinstehen und könne zugunsten der Klägerin von deren – unzureichend substantiierten – Behauptungen zur Verschwiegenheitspflicht der Streithelferin ausgegangen werden.[1323] Für diesen Fall bleibe nämlich festzuhalten, dass sich die Streithelferin die Erfüllung ihrer kartellrechtlichen Pflicht aus der FRAND-Zusage mit einer umfassenden Vertraulichkeitsvereinbarung schuldhaft unmöglich gemacht habe, weswegen sie mit ihrem Einwand mangelnder Leistungsfähigkeit zum Prozessvortrag nicht mehr gehört werden könne.[1324] Wer als Beweispflichtiger seine eigenen Beweise vernichte oder sonst wie vereitele, bleibe anerkanntermaßen beweisfällig und habe die daraus resultierenden Prozessfolgen zu tragen.[1325] Dasselbe gelte für die der Beweislast vorgelagerte Darlegungslast; wer sich zu einem erforderlichen Prozessvortrag schuldhaft außerstande setze, bleibe darlegungsfällig und unterliege im Rechtsstreit, wenn die darlegungspflichtigen Tatsachen den eingeklagten Anspruch begründeten.[1326] Da der Patenterwerber rechtlich besser nicht dastehen könne als der Veräußerer des Rechts, teile die Klägerin notwendigerweise das prozessrechtliche Schicksal ihrer Streithelferin.[1327]

Die Verpflichtung zur Offenlegung der abgeschlossenen Lizenzverträge verstoße auch nicht gegen Art. 101 AEUV.[1328] Die gegenteilige Auffassung der Streithelferin beruhe maßgeblich auf der Prämisse, dass die das unterbreitete Lizenzangebot erläuternden Bemerkungen zur bisherigen Lizenzierungspraxis den SEP-Inhaber und seinen Rechtsvorgänger zwingen würden, potentiellen Wettbewerbern Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren, was kartellrechtlichen Grundsätzen zuwiderlaufe.[1329] Doch sei bereits die Ausgangsthese falsch.[1330] Denn es sei in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass innerhalb eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion sehr wohl

[1319] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1320] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1321] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1322] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1323] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1324] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1325] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1326] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1327] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1328] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.
[1329] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.
[1330] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen möglich seien.[1331] Neben den im GVG vorgesehenen, die Öffentlichkeit betreffenden gerichtlichen Anordnungen (dazu oben XI.B.1.c)3)iii)(a)) gehe es vor allem um Vertraulichkeitsvereinbarungen, die demjenigen abverlangt werden könnten, dem gegenüber ein Geschäftsgeheimnis offenzulegen sei.[1332] Bedingung hierfür sei freilich, dass derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun habe, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstelle, was substantiellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen verlange, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet hätten, und erfordere des Weiteren ebenso substanzielle verifizierbare Angaben dazu, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen Information mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohen würden.[1333] Gelinge dies und weigere sich der Gegner, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung zu treffen, könne sich der SEP-Inhaber zur Rechtfertigung seines Lizenzangebotes auf pauschale, andeutende Angaben beschränkten, die seine Geschäftsgeheimnisse schützen würden; sie seien als prozessual ausreichend und das hierauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu behandeln.[1334] Statt sich der Mühe zu unterziehen, in Bezug auf die für das vorliegende Klagebegehren relevanten (weil im maßgeblichen Zeitraum aktiven) Lizenzverträge zu begründen, inwiefern die zur Rechtfertigung der Diskriminierungsfreiheit ihres den Beklagten unterbreiteten Lizenzangebotes erforderlichen Ausführungen schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Streithelferin offenlegen würden, und, soweit dem so sein sollen würde, in einem wenigstens andeutenden Vortrag das den betreffenden Lizenzverträgen zugrundeliegende Lizenzierungskonzept zu erläutern, erschöpfe sich der Sachvortrag der Klägerin und ihrer Streithelferin in weitgehend theoretischen Erörterungen darüber, welchen Reglungsinhalt in irgendwelchen von ihr abgeschlossenen Lizenzverträgen angeblich Geschäftsgeheimnisse enthalten sollten, wobei selbst dies nicht in der gebotenen Weise näher erläutert werde.[1335]

v) Geheimnisschutz bei SEP-(Portfolio-)Übertragung

Zur Übertragung allgemein, siehe oben VII.

Das OLG Düsseldorf hielt bereits in seinem Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 fest, der Senat gehe davon aus, dass die SEP-Inhaberin jedenfalls im Wege des Sukzessionsschutzes an Lizenzvereinbarungen, die ihre Einzelrechtsvorgängerin mit Lizenznehmern getroffen habe, gebunden sei, so dass sich ihre Darlegungspflicht auch auf den Inhalt dieser Lizenzvereinbarungen erstrecke.[1336] Auch betreffend weitergehende Darlegungen zum Erschöpfungseinwand der Beklagten führte das OLG aus, es dürfte der Klägerin möglich und zumutbar sein, zum Inhalt der Lizenzvereinbarungen zwischen der Rechtsvorgängerin und den anderen Lizenznehmern vorzutragen und erforderlichenfalls auch einen Auskunftsanspruch gegen die Rechtsvorgängerin geltend zu machen.[1337]

Wiederum im Entscheid *Improving Handovers* führte das OLG Düsseldorf aus, weil sich die Lizenzofferte des Erwerbers diskriminierungsfrei in die Lizenzierungspraxis seines Rechtsvorgängers einfügen müsse und der SEP-Erwerber im Rahmen seiner Angebotspflicht gegenüber einem Lizenznehmer diejenigen Umstände zu benennen habe, die die von ihm offerierten Lizenzbedingungen

[1331] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1332] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1333] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[1334] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[1335] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1336] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 24.

[1337] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 34.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

als FRAND auswiesen, habe sich sein Lizenzangebot zu sämtlichen Lizenzerteilungen, soweit sie in zeitlicher Hinsicht relevant seien, auch denjenigen des Rechtsvorgängers, zu verhalten (dazu bereits oben VII.A).[1338] Um dies leisten zu können, sei der SEP-Erwerber darauf angewiesen, über diejenigen Lizenzverträge in Kenntnis gesetzt zu werden, die der Veräußerer während seiner Inhaberschaft abgeschlossen habe.[1339] Eine dahingehende Informationspflicht treffe den Veräußerer unmittelbar aus seiner vertrauensbildenden Zusage, sein SEP diskriminierungsfrei zu lizenzieren.[1340] Solange er selbst Schutzrechtsinhaber sei, äußere sich die Pflicht darin, dass er bei seiner eigenen Lizenzerteilung jede Diskriminierung zu unterlassen habe, sobald er das SEP übertragen habe, äußere sich das Versprechen zu diskriminierungsfreier Lizenzerteilung in der Pflicht, den als Lizenzgeber an seine Stelle getretenen Erwerber durch entsprechende Unterrichtung in den Stand zu versetzen, dem für das übertragene SEP abgegebenen Versprechen zur diskriminierungsfreien Lizenzierung nachzukommen.[1341] Um das erworbene SEP durchsetzen zu können, liege es daher im ureigensten Interesse des SEP-Erwerbers, im Übertragungsvertrag Vorkehrungen für einen Wissenstransfer in Bezug auf bereits erfolgte Lizenzerteilungen und deren Inhalt zu treffen.[1342] Sie seien in der Praxis aber durchaus üblich, weil der Patenterwerber mit dem Schutzrecht zugleich die daran erteilten Lizenzen übernehme, was es aus Gründen der wirtschaftlichen Vernunft geradezu zwingend gebiete, sich über die Person der Lizenznehmer und die Bedingungen der ihnen erteilten Benutzungsrechte einen dedizierten Überblick zu verschaffen.[1343] Andernfalls könne der Erwerber weder überblicken, welche vertraglichen Pflichten ihn gegenüber den übernommenen Lizenznehmer treffen würden, noch sei er imstande, seine vertraglichen Rechte und Ansprüche ihnen gegenüber durchzusetzen.[1344] Ferner habe der Erwerber – was ebenfalls direkte Konsequenz der vom Veräußerer für das SEP abgegebenen FRAND-Zusage sei – Vorsorge dafür zu treffen, dass der Rechtsvorgänger daran mitwirke, dass die von ihm erteilten Lizenzen erforderlichenfalls (z.B. in einem Rechtsstreit) offengelegt werden könnten, um eine (insbesondere gerichtliche) FRAND-Prüfung zu erlauben.[1345]

Vor den geschilderten Hintergrund könne dahinstehen, ob die Einlassung der als Streithelferin beigetretenen Veräußerin glaubhaft sei, die Klägerin im Zuge des Patenterwerbs keine Einzelheiten zu den bestehenden Lizenzverträgen mitgeteilt zu haben.[1346] Rechtlich relevant könne ohnehin allenfalls der Einwand sein, dass die Streithelferin durch vertragliche Geheimhaltungsvereinbarungen mit ihren Lizenznehmern auch im Hinblick auf notwendige Darlegungen in einem Rechtsstreit um das lizenzierte Schutzrecht daran gehindert sei, die Vertragsinhalte offenzulegen.[1347] Um solches beachtlich geltend zu machen, hätte die Kläger (und/oder ihre Streithelferin) den Inhalt der angeblichen Vertraulichkeitsklauseln im Einzelnen (d.h. mit dem genauen Wortlaut und unter Darlegung sämtlicher auslegungsrelevanter Umstände) mitteilen müssen, weil der betreffende Sachvortrag nur so für den Prozessgegner einlassungsfähig und einer gerichtlichen Prüfung daraufhin zugänglich sei, ob die getroffenen Geheimhaltungsabsprachen tatsächlich so weit reichen würden, wie die Klägerin behaupte.[1348] Mangels entsprechenden Sachvortrags der Klägerin sei deswegen unklar, ob die Vertraulichkeitsklauseln nicht einer sinnvollen weil objektiv interessengerechten Interpretation dahingehen zugänglich seien, dass der Streithelferin eine Offenbarung der Lizenzinhalte in dem Maße

[1338] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1339] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1340] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1341] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1342] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1343] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1344] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1345] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 174 – *Improving Handovers*.
[1346] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1347] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1348] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gestattet sei, in dem sie einer rechtlich unumgänglichen Pflicht hierzu aus der FRAND-Zusage für das Lizenzschutzrecht) unterliege.[1349] Von einer Unmöglichkeit könne überdies nur dann ausgegangen werden, wenn das Leistungshindernis von der Klägerin nicht ausgeräumt werden könne, was im vorliegenden Zusammenhang verlange, dass die Streithelferin und vor allem deren Lizenznehmer trotz nachdrücklicher Anfrage endgültig nicht bereit seien, auf eine Einhaltung der Vertraulichkeitsvereinbarung im Rahmen und für die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits zu verzichten.[1350]

Letztlich könnten die vorgenannten Bedenken aber sogar dahinstehen und könne zugunsten der Klägerin von deren – unzureichend substantiierten – Behauptungen zur Verschwiegenheitspflicht der Streithelferin ausgegangen werden.[1351] Für diesen Fall bleibe nämlich festzuhalten, dass sich die Streithelferin die Erfüllung ihrer kartellrechtlichen Pflicht aus der FRAND-Zusage mit einer umfassenden Vertraulichkeitsvereinbarung schuldhaft unmöglich gemacht habe, weswegen sie mit ihrem Einwand mangelnder Leistungsfähigkeit zum Prozessvortrag nicht mehr gehört werden könne.[1352] Wer als Beweispflichtiger seine eigenen Beweise vernichte oder sonst wie vereitele, bleibe anerkanntermaßen beweisfällig und habe die daraus resultierenden Prozessfolgen zu tragen.[1353] Dasselbe gelte für die der Beweislast vorgelagerte Darlegungslast; wer sich zu einem erforderlichen Prozessvortrag schuldhaft außerstande setze, bleibe darlegungsfällig und unterliege im Rechtsstreit, wenn die darlegungspflichtigen Tatsachen den eingeklagten Anspruch begründeten.[1354] Da der Patenterwerber rechtlich besser nicht dastehen könne als der Veräußerer des Rechts, teile die Klägerin notwendigerweise das prozessrechtliche Schicksal ihrer Streithelferin.[1355]

Die Verpflichtung zur Offenlegung der abgeschlossenen Lizenzverträge verstoße auch nicht gegen Art. 101 AEUV.[1356] Die gegenteilige Auffassung der Streithelferin beruhe maßgeblich auf der Prämisse, dass die das unterbreitete Lizenzangebot erläuternden Bemerkungen zur bisherigen Lizenzierungspraxis den SEP-Inhaber und seinen Rechtsvorgänger zwingen würden, potentiellen Wettbewerbern Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren, was kartellrechtlichen Grundsätzen zuwiderlaufe.[1357] Doch sei bereits die Ausgangsthese falsch.[1358] Denn es sei in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass innerhalb eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion sehr wohl Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen möglich seien.[1359] Neben den im GVG vorgesehenen, die Öffentlichkeit betreffenden gerichtlichen Anordnungen (dazu oben XI.B.1.c)3)iii)(a)) gehe es vor allem um Vertraulichkeitsvereinbarungen (dazu oben XI.B.1.c)3)iv)), die demjenigen abverlangt werden könnten, dem gegenüber ein Geschäftsgeheimnis offenzulegen sei.[1360] Bedingung hierfür sei freilich, dass derjenige, der Schutzmaßnahmen für sich reklamiere, nicht nur die vertrauliche Information zu identifizieren, sondern außerdem konkret darzutun habe, dass und warum die betreffende Information ein auf die begehrte Weise zu schützendes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstelle, was substantiellen Vortrag zu denjenigen Maßnahmen verlange, die bisher ihre Vertraulichkeit gewährleistet hätten, und erfordere des Weiteren ebenso substanzielle verifizierbare Angaben dazu, welche Nachteile genau aus einem Bekanntwerden der fraglichen

[1349] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1350] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1351] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1352] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1353] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1354] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1355] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 175 – *Improving Handovers*.
[1356] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.
[1357] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.
[1358] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.
[1359] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.
[1360] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Information mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit drohen würden.[1361] Gelinge dies und weigere sich der Gegner, eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung zu treffen, so könne sich der SEP-Inhaber zur Rechtfertigung seines Lizenzangebotes auf pauschale, andeutende Angaben beschränkten, die seine Geschäftsgeheimnisse schützen würden; sie seien als prozessual ausreichend und das hierauf bezogene Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu behandeln.[1362] Statt sich der Mühe zu unterziehen, in Bezug auf die für das vorliegende Klagebegehren relevanten (weil im maßgeblichen Zeitraum aktiven) Lizenzverträge zu begründen, inwiefern die zur Rechtfertigung der Diskriminierungsfreiheit ihres den Beklagten unterbreiteten Lizenzangebotes erforderlichen Ausführungen schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Streithelferin offenlegen würden, und, soweit dem so sein sollen würde, in einem wenigstens andeutenden Vortrag das den betreffenden Lizenzverträgen zugrundeliegende Lizenzierungskonzept zu erläutern, erschöpfe sich der Sachvortrag der Klägerin und ihrer Streithelferin in weitgehend theoretischen Erörterungen darüber, welche Reglungsinhalt in irgendwelchen von ihr abgeschlossenen Lizenzverträgen angeblich Geschäftsgeheimnisse enthalten sollten, wobei selbst dies nicht in der gebotenen Weise näher erläutert werde.[1363]

Schließlich führte das OLG betreffend eine geltend gemachte „praktische Unmöglichkeit“ dieser Anforderungen aus, soweit die Klägerin und ihre Streithelferin darauf verweisen würden, es sei für den Veräußerer eines Teiles seines lizenzierten Portfolios faktisch unmöglich, den sich aus vorstehenden Darlegungen ergebenden Verpflichtungen nachzukommen, rechtfertige dies keine abweichende, auf die Einhaltung des Diskriminierungsverbots verzichtende Beurteilung (dazu bereits oben im Kapitel zur Übertragung VII.B).[1364]

4) Darlegungs- und Beweislast des Lizenzsuchers

i) Allgemein

Wie bereits oben im Kapitel zur Verteilung der Darlegungs- und Substantiierungslasten ausgeführt, trifft den Lizenzsucher einerseits die primäre Last für die Darlegung und Substantiierung für die Unangemessenheit bzw. die Ungleichbehandlung, was aber in der Praxis durch die dem SEP-Inhaber auferlegte sekundäre Darlegungslast stark relativiert wird (siehe dazu oben XI.B.1.c)1)).

ii) Vortrag zur Angemessenheit

Das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 führte aus, die Benutzerin sei darlegungsbelastet, die von der Klägerin substantiierte Angemessenheit zu widerlegen. Die Klägerin habe substantiiert dargelegt, dass die angebotene Standardlizenz am Markt akzeptiert worden und bereits tausendfach abgeschlossen worden sei, wie die Vorlage der Lizenzverträge zeige.[1365] Dieses Indiz habe die insoweit darlegungsbelastete Beklagte nicht zu erschüttern vermocht.[1366] Ihrem Vortrag lasse sich weder eine Unangemessenheit der Lizenzbedingungen entnehmen, noch habe sie einen sachlichen Grund aufgezeigt, warum nur für sie andere Lizenzbedingungen in Betracht kämen, noch, dass sie mit

[1361] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[1362] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 25.4.2018 – I-2 W 8/18.

[1363] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[1364] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 177 – *Improving Handovers*.

[1365] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1366] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenznehmern vergleichbar wäre, die ebenfalls nicht den Standardlizenzvertrag zu den ersichtlichen Konditionen abgeschlossen hätten.[1367]

Nicht genügen ließ das LG dabei insbesondere bloß pauschale Vorträge ohne weitere Belege.[1368] Auch rügte das Gericht an anderer Stelle, es sei nicht ersichtlich, warum die abgeschlossenen Lizenzen kein valides Indiz für die Marktakzeptanz sein sollten.[1369] Auch die Beklagte habe dem nichts mehr substantiiert entgegenzuhalten.[1370] Insgesamt sei es der Beklagten nicht gelungen, für den hiesigen Rechtsstreit relevante Unterschiede der vorgelegten, bereits abgeschlossenen Lizenzverträge aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die Kammer an der grundsätzlichen FRAND-Gemäßheit zweifele.[1371]

iii) Vortrag zum Diskriminierungsverbot

In den Entscheiden vom 9.11.2018 führte das LG Düsseldorf aus, die Richtigkeit des Vortrags der Beklagten, wonach die MPEG LA Lizenzverträge mit Unternehmen unter Aussparung der Lizenzvergabe auch an deren Muttergesellschaften geschlossen habe, unterstelle, komme grundsätzlich ein diskriminierendes Verhalten der MPEG LA in Betracht.[1372] Dem Vortrag der Beklagten fehle es jedoch an Substanz, um diesen Einwand in erheblicher Weise darzulegen.[1373] So verweise sie auf Firmen, mit denen sie sich jedoch auf die Lizenznahme an einem anderen Standard beziehe.[1374] Hinsichtlich einer anderen Lizenznehmerin, die die Beklagte anführe, habe die Klägerin jedoch die Lizenzierungspraxis der MPEG LA dahingehend konkretisierend beschrieben, dass gesonderte Lizenzen an einzelne Konzernunternehmen nur dann vergeben würden, wenn sich die patentrechtlich relevanten Benutzungshandlungen auf diese konkreten Konzernunternehmen einschränken ließen.[1375] Dass dies gleichermaßen auf den Konzern der Beklagten zutreffe, habe die Beklagte nicht dargetan.[1376]

Das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 hielt fest, die Beklagte habe in Auseinandersetzung mit den vorgelegten Lizenzverträgen nicht aufgezeigt, dass es entsprechend ihrer Behauptung andere Lizenznehmer gebe, die geringere Lizenzgebühren für Verkäufe in der VRC abführen würden.[1377] Sofern sie auf ein angebliches diskriminierendes Verhalten der Lizenzverwalterin rekurriere, weil Lizenzen unter Aussparung der Muttergesellschaften geschlossen worden seien, sei auch ein solches Verhalten der Lizenzverwalterin in Bezug auf den streitgegenständlichen AVC-Standard nicht hinreichend dargetan.[1378] Die Lizenzierungspraxis im Hinblick auf eines der Unternehmen habe die Klägerin insoweit konkretisiert, als dass gesonderte Lizenzen an Konzernunternehmen nur dann vergeben würden, wenn sich die patentrechtlichen Benutzungshandlungen auf dieses konkrete Konzernunternehmen einschränken ließen.[1379] Die Beklagte habe demgegenüber nicht dargetan, dass

[1367] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1368] Vgl. dazu LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 383, 390; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 322, 329.

[1369] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[1370] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 363; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 302.

[1371] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 364; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 303.

[1372] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 496; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 418.

[1373] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 497; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 419.

[1374] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 497; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 419.

[1375] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 498; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 420.

[1376] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 498; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 420.

[1377] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 319.

[1378] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 319.

[1379] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 319.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

bei ihrem Konzern eine vergleichbare Situation vorliege, vielmehr agiere der Konzern der Beklagten unstreitig weltweit, wie sich auch aus der Übersicht der Verkaufseinheiten unzweifelhaft ergebe.[1380]

d) Diverses

1) Standardlizenzvertrag als hinreichende Darlegung der Art und Weise der Berechnung?

In den Entscheiden vom 9.11.2018 hatte das LG Düsseldorf zu entscheiden, ob die Zusendung eines Standardlizenzvertrags bereits eine hinreichend konkrete Angabe der Art und Weise der Berechnung darstellen könne.[1381] Eine der beiden Beklagten hatte dabei als Poolmitglied des betreffenden Pools bereits „Spezialwissen" über die Art und Weise der Berechnung, während die andere Beklagte über kein solches „Spezialwissen" verfügte.

Auch wenn der zugesandte Standardlizenzvertrag selbst keine Ausführungen zur Art und Weise der Berechnung im dargelegten Sinn enthalte, könne insoweit jedoch auf das Wissen der Muttergesellschaft der Benutzerin, dass es sich bei dem Vertragsdokument um ein Standardlizenzvertrag handele, welcher bereits durch eine Vielzahl von Lizenznehmern abgeschlossen worden sei, abgestellt werden.[1382] Die Vorlage der einzelnen abgeschlossenen Lizenzverträge selbst sei hingegen im Rahmen des Vertragsangebots nicht zu verlangen, da eine solche Branchenüblichkeit weder vorgetragen noch erkennbar sei.[1383] Jedenfalls sei betreffend eine der beiden Beklagten davon auszugehen, dass die Muttergesellschaft spätestens zu dem Zeitpunkt, als sie selbst die Stellung einer Poolpatentinhabers erhalten habe, über hinreichend Wissen über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren verfügt habe.[1384]

Betreffend die andere Beklagte, die nicht Poolmitglied geworden war, berief sich das LG dennoch auf ihr „Spezialwissen".[1385] Von einem solchen Wissen der Muttergesellschaft der anderen Beklagten könne einerseits aufgrund der Ausgestaltung des Vertragsdokuments selbst ausgegangen werden, andererseits sei der Konzern der Beklagten bereits seit längerer Zeit mit der Lizenzverwalterin in Kontakt gestanden, und sei eine Liste der Lizenznehmer über die Internetseite der Lizenzverwalterin abrufbar gewesen.[1386] Dass der Konzern der Beklagten nicht ohne Kenntnis etwaiger Lizenznehmer gewesen sei, werde weiter auch aus der vorgelegten E-Mail Korrespondenz deutlich, in deren Verlauf die Muttergesellschaft, um ihrem Verlangen nach einer nur einzelne Tochterunternehmen betreffenden Lizenz Nachdruck zu verleihen, die Lizenzverwalterin mehrfach darauf verwiesen habe, dass es Lizenznehmer gebe, bei denen nur einzelne Konzerngesellschaften lizenziert seien.[1387] Weiter fügte das LG hinzu, spreche schließlich auch der Umstand, dass die Muttergesellschaft weitere Informationen im Zusammenhang mit der Vorlage des Standardlizenzvertrags nicht verlangt habe und sich dennoch in Vertragsverhandlungen begeben habe, dafür, dass weitergehende Informationen nicht branchenüblich seien.[1388]

[1380] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 319.

[1381] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 289; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 271; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 369; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 291.

[1382] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 289; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 271; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 369; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 291.

[1383] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 292; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 274; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 371; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 293.

[1384] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 293; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 275.

[1385] Vgl. LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 370; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 292.

[1386] Vgl. LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 370; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 292.

[1387] Vgl. LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 370; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 292.

[1388] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 372; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 294.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Nach dieser Maßgabe sei die Art und Weise der Berechnung im Zusammenhang mit der Zusendung des Standardlizenzvertrags hinreichend dargelegt worden.[1389]

In den Entscheiden vom 12.12.2018 kam das LG Düsseldorf auf seine Rechtsprechung zur Darlegung der Art und Weise der Berechnung mittels Standardlizenzvertrag zurück. Auch wenn derselbe Standardlizenzvertrag wie schon in den Entscheiden vom 9.11.2018 selbst keine Ausführungen zur Art und Weise der Berechnung der Lizenz enthalte, seien solche im konkreten Einzelfall nach den zuvor aufgestellten Maßstäben entbehrlich.[1390] Die Klägerin habe einen Standardlizenzvertrag vorgelegt, den sie mit den gleichen Bedingungen einer Vielzahl von Lizenznehmern angeboten habe.[1391] Je mehr abgeschlossene Lizenzverträge mit gleichartigen Lizenzbedingungen abgeschlossen worden seien, umso stärker sei die Vermutung, dass die geforderten Lizenzgebühren FRAND seien.[1392] Vorliegend handele es sich um einen Standardlizenzvertrag, wie es sich bereits aus dem vorformulierten Vertragstext ergebe, der dem zuständigen Verhandlungsführer des Konzerns der einen der beiden Beklagten aus jahrelangen Verhandlungen zuvor bereits im Wesentlichen bekannt gewesen sei.[1393] Abgesehen davon, dass die Liste der Lizenznehmer, welche den Vertrag bereits abgeschlossen hätten, im Internet abrufbar sei, kannte die zuständige Person ausweislich einer E-Mail Lizenznehmer, die den Vertrag – allerdings nicht konzernweit – abgeschlossen hätten.[1394] Insofern habe die Konzerngesellschaft bereits alle Informationen, um sich auf die Verhandlungen einzulassen, die sie dann auch mit der Begründung weitergeführt habe, dass sie ebenso wie diese Unternehmen nur einzelne Konzerngesellschaften lizenzieren lassen wolle.[1395] Betreffend die andere Beklagte führte die Kammer 4b, wie schon die Kammer 4a im Parallelverfahren, aus, es sei jedenfalls davon auszugehen, dass deren Muttergesellschaft spätestens als sie Pool-Mitglied geworden sei, hinreichende Kenntnis über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren erlangt habe.[1396] Hinzu trete, dass die Beklagte die Berechnung der Lizenzhöhe als solche bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht in Frage gestellt habe.[1397] Schließlich, wie schon die Kammer 4a bemerkte, beständen auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass eine weitere Erläuterung der Berechnungsparameter oder die Vorlage der geschlossenen Lizenzverträge selbst üblicherweise im Rahmen des Vertragsangebots erfolgten.[1398] Eine dahingehende Branchenüblichkeit sei weder vorgetragen noch ersichtlich.[1399]

Eine solche bestehende Branchenüblichkeit potentiell relativierende Argumentation ablehnend führte die Kammer 4b weiter aus, der allgemeine Einwand (unter Verweis auf Kurtz/Straub, GRUR 2018, 136), es handele sich schon nicht um ein taugliches Indiz, weil diese Verträge, und somit auch die bisherige

[1389] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 288; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 270; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 368; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 290.

[1390] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 318; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 257; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 266.

[1391] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 318; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 257; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 266.

[1392] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 318; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 257; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 266, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 219.

[1393] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 318; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 257.

[1394] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 319; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 258.

[1395] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 319; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 258.

[1396] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 266.

[1397] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 319; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 258; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 266.

[1398] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 320; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 279; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 259; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 267.

[1399] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 320; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 279; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 259; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 267.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Branchenüblichkeit, den Anschein eines Ausnutzens der Marktmacht per se in sich trügen, verfange schon deswegen nicht, weil zusätzlich zur Vorlage der Verträge ebenfalls die Darlegung der Akzeptanz am Markt notwendig sei, die sich insbesondere aus einer Vergleichbarkeit der Lizenznehmer und der Lizenzsucher ergeben könne.[1400]

2) Tatrichterliche Feststellung oder negative Evidenzkontrolle?

Per Hinweisbeschluss äußerte sich das OLG Düsseldorf zu der Frage, ob die Feststellung der FRAND-Gemäßheit lediglich summarisch im Sinne einer negativen Evidenzkontrolle oder als tatrichterliche Feststellung zu erfolgen habe. Prüfungsmaßstab sei nicht nur, ob das Angebot die *essentialia negotii* eines Lizenzvertrages enthalte und nicht evident FRAND-widrig sei, vielmehr sei positiv festzustellen, dass es sich um ein Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen handele.[1401] Dabei könnte es allerdings mehrere Vertragsgestaltungen mit unterschiedlichen Lizenzbedingungen und insbesondere einen Bereich von Lizenzgebühren geben, die als fair, angemessen und nicht-diskriminierend zu qualifizieren seien.[1402] Das OLG führte mit Entscheid vom 30.3.2017 diesbezüglich weiter aus, wie der Senat bereits entschieden habe, dürfe sich das Verletzungsgericht nicht auf eine bloß summarische Prüfung im Sinne einer „negativen Evidenzkontrolle“ beschränken, sondern es müsse abschließend tatrichterlich feststellen, ob das Angebot des SEP-Inhabers FRAND sei.[1403] Im dem OLG vorliegenden Fall wirke sich die Streitfrage allerdings nicht entscheidungserheblich aus, denn die Lizenzangebote der Klägerin stellten sogar eine im vorgenannten Sinne „evidente“ Diskriminierung der Beklagten dar, so dass sie selbst unter Zugrundelegung des für die Klägerin günstigeren Prüfungsmaßstabs nicht FRAND seien.[1404]

Das LG Düsseldorf nahm das Thema in den Entscheiden vom 13.7.2017 und 11.7.2018 wieder auf. Es sei umstritten, ob das Verletzungsgericht das Vorliegen eines FRAND-Angebots nur summarisch im Sinne einer negativen Evidenzkontrolle prüfen oder ob es tatrichterlich feststellen müsse, dass ein Angebot FRAND sei.[1405] Aber auch wenn man eine tatrichterliche Feststellung und nicht nur eine Evidenzkontrolle verlange, so bestehe zumindest ein richterlicher Beurteilungsspielraum,[1406] da es regelmäßig nicht eine bestimmte Lizenzgebührenhöhe, die FRAND sei, gebe, sondern eine Bandbreite nicht ausbeuterischer Gebühren (dazu bereits oben XI.B.1.a)).[1407]

[1400] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277.

[1401] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 14.

[1402] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 14, mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 8.9.2016 – 6 U 58/16

[1403] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 204 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 13.1.2016 – I-15 U 66/15, OLG Karlsruhe, 31.5.2016 – 6 U 55/16, 8.9.2016 – 6 U 58/16, und die andere Ansicht des LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14 – *Stochastisches Rauschen*, 17.11.2018 – 7 O 19/16.

[1404] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 204 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1405] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 189; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 203; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 350 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 301 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 349; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 302, mit Verweis pro negative Evidenzkontrolle auf LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14 – *Stochastisches Rauschen*, und pro tatrichterliche Feststellung OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 14 und OLG Karlsruhe, 31.5.2016 – 6 U 55/16, Rn. 32 – *Dekodiervorrichtung*.

[1406] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 189; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 203; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 350 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 301 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 349; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 302, mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 31.5.2016 – 6 U 55/16, Rn. 32 – *Dekodiervorrichtung.*

[1407] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 350 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 301 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 349; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 302, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 14.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Letztlich ließ aber auch das LG in den Entscheiden vom 13.7.2017 die erforderliche Prüfungstiefe des Gerichts dahingestellt, denn es liege in casu ein FRAND-Angebot schon deshalb nicht vor, weil ein solches nicht rechtzeitig abgegeben und ausreichend begründet worden,[1408] beziehungsweise nicht fair und diskriminierungsfrei sei.[1409] Jedenfalls solche eher formalen Anforderungen an das Verhalten des SEP-Inhabers habe das Verletzungsgericht vollumfänglich zu prüfen.[1410] Im Entscheid vom 11.7.2018 hielt das LG hingegen fest, bedürfe es auch keiner Entscheidung mehr darüber, ob ein FRAND-konformes Gegenangebot der Beklagten hätte vorgelegt werden müssen, da das Angebot der Klägerin entsprechend der vorstehenden Ausführungen evident nicht FRAND sei.[1411]

Im Ergebnis scheinen die Ansätze insofern zu konvergieren, als bei evident nicht FRAND-gemäßen Angeboten auch die Gerichte, die eine negative Evidenzkontrolle dogmatisch ablehnen, lediglich eine solche praktizieren da FRAND eine materiellrechtliche Unschärfe beinhaltet.

3) Doppelte Prüfung und Spannungsfeld

Methodisch ist jeder Angebotspunkt sachlich-inhaltlich sowohl auf seine Angemessenheit als auch auf seine Diskriminierungsfreiheit zu prüfen.[1412]

Zum Zusammenspiel zwischen Angemessenheit und Diskriminierungsverbot nach der späteren *FRAND-Einwand* Rechtsprechung des BGH vgl. *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>.

Zwischen der Prüfung der Angemessenheit und des Diskriminierungsverbots kann sich dabei durchaus ein Spannungsfeld ergeben. So springt in den Entscheiden des LG Düsseldorf vom 9.11.2018 beispielsweise die doppelte Rolle, die der räumlichen Dimension des Lizenzvertragsangebot zukommen kann, ins Auge. Einerseits habe sich das Vertragsangebot im Hinblick auf die Vertragsbedingungen, wie die lizenzpflichtigen Schutzrechte und das Lizenzgebiet als angemessen zu erweisen.[1413] Andererseits umfasse das Diskriminierungsverbot für das marktbeherrschende Unternehmen eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem es Handelspartnern, die sich in gleicher Lage befänden, dieselben Preise und Geschäftsbedingungen einräumen müsse.[1414] So stelle sich in casu die räumliche Erstreckung des Lizenzvertrags auch auf den chinesischen Markt weder unter dem Aspekt der selektiven Durchsetzung der Patentrechte als eine kartellrechtswidrige Diskriminierung dar (dazu unten XI.B.3.c)), noch sei die Höhe der Lizenzgebühren unangemessen, weil sich nicht zwischen einzelnen regionalen Märkten, insbesondere im Hinblick auf eine Lizenz für Benutzungshandlungen auf dem chinesischen Markt, differenziere (dazu unten XI.B.2.c)1)).[1415]

Dass ein gewisses Spannungsfeld zwischen Angemessenheit und Diskriminierungsfreiheit bestehen könnte, zeigt sich darin, dass einerseits das Angemessenheitskriterium eine gewisse Differenzierung verlangt, während das Diskriminierungsverbot eine solche potenziell verbietet. Ursprung der potenziellen Verwerfung ist, dass das Angemessenheitskriterium im Kern einen individuellen, auf das

[1408] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 351 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 302 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 350; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 303.

[1409] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 189; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 203.

[1410] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 351 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 302 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 350; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 303

[1411] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 254.

[1412] Vgl. OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 312 – *Improving Handovers;* LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 299; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 281.

[1413] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296.

[1414] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 375; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 297.

[1415] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 378; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 300.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

fragliche Unternehmen bezogenen Betrachtungswinkel einnimmt, während das Diskriminierungsverbot eine holistische, relative Perspektive zum Ausgangspunkt nimmt.

Dabei steht und fällt das Gleichbehandlungsgebot damit, was als gleich und als unterschiedlich kategorisiert wird, mithin was als sachlicher Rechtfertigungsgrund für eine Ungleichbehandlung gelten darf. Je tiefer man die Schwelle für den sachlichen Rechtfertigungsgrund einer Ungleichbehandlung ansetzt, desto individualisierter wird die Gleichbehandlung, bis zu dem Fall, das jeder Patentbenutzer sich aufgrund individueller Begebenheiten in einer eigenen Gleichbehandlungskategorie befinden würde, was das Gleichbehandlungsgebot im Ergebnis zur Bedeutungslosigkeit unterlaufen würde. Setzt man die Schwelle allerdings hoch an, werden potenziell unterschiedliche Marktteilnehmer gleichbehandelt, und würden damit im Ergebnis indirekt diskriminiert. Das kollektive Kriterium der Diskriminierungsfreiheit wird somit durch die sachlichen Rechtfertigungsgründe zu einem gewissen Grad den individuellen Begebenheiten zugänglich gemacht.

Das Angemessenheitskriterium als von einer individuellen Perspektive ausgehend wird hingegen zu einem gewissen Grad kollektiviert, indem die Branchenüblichkeit als Maßstab für die Angemessenheit gilt, und bereits abgeschlossene Lizenzverträge eine Angemessenheit indizieren (siehe dazu sogleich). Die ad absurdum führend wäre unter Umständen dem SEP-Inhaber gar kein FRAND-Angebot möglich, definiere man die FRAND-Kriterien so, dass die Angemessenheit eine individualisierende Ungleichbehandlung verlangt, das Diskriminierungsverbot eine solche allerdings verbietet und somit FRAND-widrig machen würde. Dies illustriert, dass, um zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen, Angemessenheit und sachliche Rechtfertigungsgründe in praktische Konkordanz zu bringen sind.

2. Fairer und angemessener Inhalt (FR)

a) Generelles zum FR-Prong

Das Angebot des SEP-Inhabers muss fair und angemessen sein.[1416] Dies ist nach dem OLG Düsseldorf so zu verstehen, dass dem Lizenzwilligen lediglich keine die marktbeherrschende Stellung ausnutzenden Bedingungen angeboten werden dürften.[1417] Die Bedingungen müssten zumutbar und dürften nicht ausbeuterisch sein.[1418]

Dementsprechend führte das LG Düsseldorf in seinen Entscheiden vom 13.7.2017 und 11.7.2018 aus, der FR-Prong umfasse Vorgaben zur absoluten Höhe der Lizenzgebühren, im Gegensatz zur relativen Höhe der Lizenzgebühren, wo das Diskriminierungsverbot greife.[1419] Das Angebot dürfe nicht ausbeuterisch, sondern müsse „fair“ und „reasonable“ sein.[1420] Es liege kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vor, wenn der Patentinhaber Vertragsbedingungen anbiete, die auch ohne seine marktbeherrschende Stellung zustande gekommen wären.[1421] Gleiches gelte neben der

[1416] Vgl. EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 63 – *Huawei/ZTE.*

[1417] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 15.

[1418] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 15.

[1419] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 191; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 205; 13.7.2018 – 4a O 16/16, Rn. 352 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 303 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 351; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 304.

[1420] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 193; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 207; 13.7.2018 – 4a O 16/16, Rn. 353 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 304 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 352; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 305.

[1421] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 193; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 207; 13.7.2018 – 4a O 16/16, Rn. 353 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 304 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 352; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 305.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Höhe der Lizenzgebühren auch für die anderen Inhalte des Angebots.[1422] Insbesondere sei die Branchenüblichkeit relevant, denn was marktüblich sei verstoße nicht gegen FRAND, es sei denn, die Umstände des Einzelfalls ließen eine Abweichung erforderlich erscheinen.[1423]

Weiter erfordere die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung nicht zwingend eine streng mathematische Herleitung, sondern sofern dies im konkreten Fall möglich sei, sei es erforderlich und regelmäßig hinreichend, die Akzeptanz der verlangten (Standard-)Lizenzsätze am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[1424] Über bereits abgeschlossene Lizenzverträge könne oftmals die Akzeptanz der verlangten Lizenzgebühren auf dem Markt belegt werden und damit, das diese fair und angemessen seien.[1425] Ob die Vorlage von anderen Lizenzverträgen alleine ausreiche, um die Angemessenheit der Lizenzgebühren zu belegen, hänge vom Einzelfall und insbesondere der Zahl der abgeschlossenen Lizenzverträge ab.[1426] Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt (beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte) würden im Regelfall keine weiteren Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein.[1427]

Auch in den Entscheiden vom 9.11.2018 und 12.12.2018 kam das LG Düsseldorf auf die allgemeine Definition von fair und angemessen zurück. Unter Verweis auf die oberlandesgerichtliche Rechtsprechung führte das LG abermals aus, als faire und angemessene Vertragsbedingungen seien solche zu verstehen, die dem Lizenzwilligen nicht unter Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung angeboten würden, die Vertragsbedingungen mithin zumutbar und nicht ausbeuterisch seien.[1428] Weiter könne sich ein Angebot insbesondere dann als unfair bzw. unangemessen erweisen, wenn eine Lizenzgebühr verlangt werde, die den hypothetischen Preis, der sich bei wirksamem Wettbewerb auf dem beherrschten Markt gebildet hätte, erheblich überschreite, es sei denn, es gebe eine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Preisbildung.[1429] Handele es sich um ein

[1422] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 191; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 205; 13.7.2018 – 4a O 16/16, Rn. 352 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 303 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 351; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 304.

[1423] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 197; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 211; 13.7.2018 – 4a O 16/16, Rn. 355 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 306 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 354; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 307, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 220.

[1424] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 253.

[1425] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 219.

[1426] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[1427] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 203; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 217; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 359 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 310 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 358; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[1428] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296; alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 15.

[1429] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277;

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

standardgebundenes Schutzrecht, könne sich eine Unangemessenheit ferner daraus ergeben, dass sich im Falle einer Lizenzforderung auch für die übrigen Standard-Schutzrechte eine kumulative Gesamtlizenzbelastung ergeben würde, die wirtschaftlich nicht tragbar sei (m.w.H. zur angemessenen Lizenzhöhe siehe unten XI.B.2.b)).[1430] Das Vertragsangebot habe sich des Weiteren auch im Hinblick auf die übrigen Vertragsbedingungen als angemessen zu erweisen.[1431]

Zur Methodik bei der Überprüfung der Angemessenheit des Angebots führte das LG Düsseldorf in den Entscheiden vom 9.11.2018 weiter aus, dass eine mathematisch genaue Herleitung einer FRAND-gemäßen Lizenzgebühr nicht zu erfolgen habe, sondern vielmehr eine annäherungsweise Entscheidung, die auf Wertungen und Schätzungen beruhe, vorzunehmen sei.[1432] Vergleichbare Lizenzverträge könnten dabei ein gewichtiges Indiz für die Angemessenheit der angebotenen Lizenzbedingungen sein.[1433] Beständen für den in Rede stehenden Schutzrechtsbestand bereits Lizenzvereinbarungen, könnten diese unter Rückgriff auf das Vergleichsmarktkonzept eine tatsächliche Vermutung für die Angemessenheit der Lizenzbedingungen entfalten.[1434] Diese Indizwirkung erfasse grundsätzlich auch den Umfang der Lizenz.[1435] Dabei schien die Kammer die Begründung der Indizwirkung jeweils auf den konkreten Einwand zu beziehen.[1436] Schließlich beständen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Standardlizenzverträge unter Missbrauch von Marktmacht zustande gekommen seien.[1437]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 schlug das LG Düsseldorf die gleiche Richtung ein, wonach eine streng mathematische Herleitung nicht erforderlich sei.[1438] Die Rechtsprechung der Kammer 4a wiederholend führte die Abteilung 4b aus, es sei – sofern möglich – hinreichend, die Akzeptanz der verlangten Lizenzsätze am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[1439] Darüber hinaus sei die Darlegung über bereits abgeschlossene Lizenzverträge vorrangig, da sich über das Ergebnis verschiedener, schon erfolgreicher, tatsächlicher Lizenzverträge die FRAND-Gemäßheit einfacher belegen und sicherer feststellen lasse, als über den Vortrag der einzelnen Faktoren, die in Lizenzvertragsverhandlungen jeweils eine näher zu bestimmende, mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen könnten oder sollten.[1440] Der allgemeine Einwand (unter Verweis auf Kurtz/Straub, GRUR 2018, 136), es handele sich schon nicht um ein taugliches Indiz, weil diese Verträge den Anschein eines

9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14, Rn. 225.

[1430] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296.

[1431] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 324; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 290; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 263; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 278; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296.

[1432] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296,

[1433] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14, Rn. 225.

[1434] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 389; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 311.

[1435] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 389; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 311.

[1436] Vgl. LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 393; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 315.

[1437] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 394; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 316.

[1438] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277.

[1439] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[1440] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277; alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 312.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Ausnutzen der Marktmacht per se in sich trügen, verfange schon deswegen nicht, weil zusätzlich zur Vorlage der Verträge ebenfalls die Darlegung der Akzeptanz am Markt notwendig sei, die sich insbesondere aus einer Vergleichbarkeit der Lizenznehmer und der Lizenzsucher ergeben könne.[1441]

Gemessen an diesen Maßstäben habe die Klägerin substantiiert dargelegt, dass die angebotene Standardlizenz im Markt akzeptiert, und bereits tausendfach abgeschlossen worden sei, wie die Vorlage der Lizenzverträge zeige.[1442] Dieses Indiz habe die insoweit darlegungsbelastete Beklagte nicht zu erschüttern vermocht, da sich aus ihrem Vortrag keine Unangemessenheit der Lizenzbedingungen entnehmen lasse.[1443]

Diese Entscheidpraxis illustriert die Methodik, die das LG Düsseldorf anwendet, und nach der die Struktur dieses Unterkapitels aufgebaut werden soll. Liegen bereits mehrere vergleichbare, abgeschlossene Lizenzverträge vor, indizieren diese die Branchenüblichkeit und damit die Angemessenheit der Vertragsbedingungen. Diese Indizwirkung kann umgestoßen werden durch den Implementierer, indem er darlegt, inwiefern diese Bedingungen für ihn unangemessen sind.

Das OLG Düsseldorf setzte sich im Entscheid vom 22.3.2019 weiter damit auseinander, inwiefern Referenzverträge im Rahmen der Angemessenheit zu berücksichtigen sind, und votierte für eine strenge Bindung an die Angemessenheit des ersten Lizenzvertrags im Rahmen des Diskriminierungsverbots. Mit dem allerersten Lizenzgeschäft müsse sich der SEP-Inhaber für ein bestimmtes Lizenzierungskonzept entscheiden, das ihn im Weiteren rechtlich binde, weil ein Abrücken von dem einmal praktizierten Modell nur dann und nur in dem Umfang möglich sei, wie sich daraus keine unzulässige Diskriminierung der späteren oder früheren Lizenznehmer ergebe (zum Diskriminierungsverbot unten XI.B.3).[1444] Bei der Erstvergabe stehe mithin das Gebot, „fair“ und „reasonable“ zu lizenzieren im Vordergrund, während sich die Frage einer Diskriminierung (im Vergleich zu was auch?) mangels Vorliegen eines Referenzvertrages nicht stelle.[1445] Trügen die bei der Erstvergabe gewählten Lizenzbedingungen den Anforderungen an einen ausbeutungsfreien Inhalt Rechnung, rücke für alle weiteren Lizenzierungen das Diskriminierungsverbot in den Mittelpunkt der Betrachtung, und umreiße damit ganz maßgeblich denjenigen Verhandlungsspielraum, der dem SEP-Inhaber bei nachfolgenden Lizenzverhandlungen noch verbleibe.[1446] Das Verbot sachlich nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung gelte folglich auch dann, wenn bei der Erstlizenzierung der an sich mögliche FRAND-Gebührenrahmen – gegebenenfalls sogar deutlich – nicht ausgeschöpft worden sei und die später geänderte Lizenzierungspraxis darauf abziele, die Lizenzvergütung (was anfänglich möglich gewesen wäre) in den oberen Bereich des unter Ausbeutungsgesichtspunkten rechtlich Zulässigen zu führen.[1447] Denn das rein subjektive Verhandlungsversagen oder bewusste Nachgeben des SEP-Inhabers könne nicht als Sachgrund dafür anerkannt werden, dass spätere Lizenzsucher sich im Wettbewerb mit finanziell schlechteren Benutzungsbedingungen abfinden müssten.[1448]

Eine solche enge Bindung an das Diskriminierungsverbot, wie vom OLG Düsseldorf vertreten, schränkt die Angemessenheitsprüfung nachfolgender Lizenzverträge insofern ein, als selbst angemessene spätere Lizenzverträge nach dem Diskriminierungsverbot unzulässig wären, wenn sie vom ersten

---

[1441] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277.

[1442] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1443] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1444] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers*.

[1445] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers.*

[1446] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers.*

[1447] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers.*

[1448] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzvertrag in unsachlicher Weise abweichen würden. Zulässig wären hingegen betreffend die Angemessenheit (einzig?) die Argumente, die Lizenzierungspraxis sei von Beginn an unangemessen gewesen oder es beständen sachliche Gründe für eine Andersbehandlung im Rahmen des Diskriminierungsverbots. Zieht man allerdings die Rechtsprechung des LG Düsseldorf heran, wonach bereits abgeschlossene Lizenzverträge die Angemessenheit indizierten und über diese sich zudem die Akzeptanz am Markt darlegen lasse, dürfte eine Umstoßung der Angemessenheit der bisherigen Lizenzierungspraxis insgesamt nur beschränkt möglich sein. In der Praxis dürfte sich die strenge Bindung der Angemessenheit an das Diskriminierungsverbot aber insofern relativieren, als regelmäßig praktische Schwierigkeiten bestehen werden, die Bedingungen vergleichbarer Lizenznehmer tatsächlich zu vergleichen, bspw. durch Kreuzlizenzierung (dazu jedoch unten XI.B.3.b)2)). Insgesamt stellte sich in den meisten Verfahren allerdings die Frage, inwiefern gewisse, teils persönliche, Einwände der Beklagten die Indizwirkung der Angemessenheit vergleichbarer Lizenzverträge durchbrechen, und so unangemessen wirken. Dies wiederum lässt aber allgemeine Rückschlüsse auf den allgemeinen Gehalt der Angemessenheit, auch für den ersten „Referenzlizenzvertrag“, zu.

Betreffend den potenziellen Einwand, dass bereits dieser erste Referenzlizenzvertrag zu unangemessenen Bedingungen zustande gekommen sei, führte das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 aus, es beständen in casu keine Anhaltspunkte dafür, dass die Standardlizenzverträge ihrerseits unter Missbrauch von Marktmacht zustande gekommen seien.[1449] Vielmehr trage die Klägerin unbestritten vor, dass sich der Patentpool ohne Zwang etabliert habe.[1450]

Schließlich sei darlegungs- und beweispflichtig für das Vorliegen eines Ausbeutungstatbestandes der Lizenzsucher, wobei dem Umstand Rechnung zu tragen sei, dass der Lizenzsucher regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers, insbesondere über mit Dritten bestehende Lizenzverträge und deren Reglungsgehalt besitze, was rechtfertige, dem SEP-Inhaber insoweit eine sekundäre Darlegungslast aufzuerlegen (ausführlich XI.B.1.c)1)).[1451]

b) Angemessene Höhe

Die angemessene Höhe der Lizenzgebühr soll zugleich Ausgangspunkt und Begrenzung der Prüfung der Angemessenheit sein, da die weiteren Lizenzbedingungen wohl üblicherweise (zumindest theoretisch) in einen gewissen monetären Gegenwert umgewandelt werden können, die wettbewerbsrechtliche Kontrolle hier aber auch am stärksten ins Spannungsfeld der verpönten staatlich-regulatorischen Preiskontrolle rückt. Da bei einer indizierten Angemessenheit bestehender Lizenzverträge sich eine Unangemessenheit in der Regel nur schwer über rein nummerische Gegenleistungen und Kostenunterschiede rechtfertigen lassen wird, und im allgemeinen im EU-Kartellrecht im Vergleich zum Behinderungsmissbrauch hohe Hürden für einen Ausbeutungsmissbrauch bestehen, hat sich der Großteil der deutschen FRAND-Rechtsprechung auf die Angemessenheit der weiteren Lizenzbedingungen konzentriert (XI.B.2.c)), die sich wiederum rechnerisch indirekt in der Höhe der Lizenzgebühr niederschlagen.

Wie bereits im generellen Teil zur Angemessenheit ausgeführt, sei nach dem OLG Düsseldorf vom 17.11.2016 unter „fair und angemessen“ nur zu verstehen, dass dem Lizenzwilligen keine die marktbeherrschende Stellung ausnutzenden Bedingungen angeboten werden dürften.[1452] Die angemessene Höhe dürfte dabei gemäß § 287 Abs. 2 ZPO zu schätzen sein.[1453] Bei bereits existierenden

[1449] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 394; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 316, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14.

[1450] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 394; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 316.

[1451] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 326; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 292; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 265; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 297; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 279; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 376; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 298.

[1452] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 15.

[1453] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 16.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzen über das Klagepatent, die von der Klägerin oder dessen Rechtsvorgängerin erteilt worden seien, dürfte das sogenannte Vergleichsmarktkonzept zugrunde zu legen sein.[1454] Weiter könne ein Vergleich der Lizenzrate des Patentportfolios mit Lizenzraten von anderen Lizenzprogrammen im Bereich drahtlose Kommunikation nur dann ein Indiz für die FRAND-Konformität der angebotenen Lizenzgebühr sein, wenn das Portfolio der Klägerin mit den anderen Lizenzportfolios nach Qualität und Umfang vergleichbar sei.[1455] Dafür sei in casu Vortrag zum technischen Wert des Portfolios notwendig.[1456] Schließlich sei eine unzumutbare Gesamtbelastung der Beklagten im vorliegenden Fall nicht ersichtlich gewesen, weil dafür nur die tatsächlich bestehenden sowie die vom Patentinhaber oder von Dritten geforderten Lizenzgebühren zu berücksichtigen seien.[1457] Eine bloß theoretisch mögliche Kumulierung zu einer unzumutbaren Gesamtbelastung führe somit noch nicht zur Unangemessenheit der Lizenzgebühr.[1458] Der Einwand der Beklagten könne daher allenfalls beachtlich sein, wenn sie konkret darlege, in welchem Umfang sie für die angegriffenen Ausführungsformen Lizenzgebühren an andere Lizenzgeber zu entrichten habe.[1459] Unter dem Gesichtspunkt von „fair und angemessen“ könnte zudem eine vertragliche Regelung in Erwägung gezogen werden, die gewährleiste, dass der Patentbenutzer im Falle weiterer berechtigter Lizenzforderungen anderer Inhaber standardgebundener Schutzrechte nicht übermäßig belastet werde.[1460] Sofern auf eine solche Klausel verzichtet werde, seien die Gründe dafür näher darzulegen.[1461]

Weitere Ausführungen zur angemessenen Lizenzhöhe traf das LG Düsseldorf in seinen Entscheiden vom 9.11.2018. Wie bereits oben erwähnt, könne ein Angebot des Lizenzgebers sich insbesondere dann als unfair/unangemessen erweisen, wenn eine Lizenzgebühr verlangt werde, die den hypothetischen Preis, der sich bei wirksamem Wettbewerb auf dem beherrschenden Markt gebildet hätte, erheblich überschreite, es sei denn, es gebe eine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Preisbildung.[1462] Handele es sich um ein standardgebundenes Schutzrecht, könne sich die Unangemessenheit ferner daraus ergeben, dass sich im Falle einer Lizenzforderung auch für die übrigen Standard-Schutzrechte eine kumulative Gesamtlizenzbelastung ergeben würde, die wirtschaftlich nicht tragbar sei.[1463] Zu beachten sei in diesem Zusammenhang, dass eine mathematisch genaue Herleitung einer FRAND-gemäßen Lizenzgebühr nicht zu erfolgen habe, vielmehr sei eine annäherungsweise Entscheidung, die auf Wertungen und Schätzungen beruhe, vorzunehmen.[1464] Vergleichbare Lizenzverträge könnten dabei ein gewichtiges Indiz für die Angemessenheit der dargebotenen Lizenzbedingungen sein.[1465]

Beständen für den in Rede stehenden Schutzrechtsbestand bereits Lizenzvereinbarungen, könnten diese unter Rückgriff auf das sogenannte Vergleichsmarktkonzept eine tatsächliche Vermutung für die Angemessenheit der Lizenzbedingungen entfalten, wobei die Indizwirkung grundsätzlich auch den

[1454] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 16.

[1455] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 40.

[1456] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 40.

[1457] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 50.

[1458] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 50, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 13.2.2007 – 4a O124/05.

[1459] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 50.

[1460] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 44.

[1461] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 44.

[1462] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14, Rn. 225.

[1463] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296.

[1464] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296.

[1465] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14, Rn. 225.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Umfang der Lizenz erfasse.[1466] Diese Indizwirkung (in casu mehr als 1400 abgeschlossene Standardlizenzverträge) bilde einen gewichtigen Anhaltspunkt dafür, dass die vergleichbaren Lizenzverträge branchenüblich seien.[1467]

Nicht als inhaltlichen Unterschied, der einer Begründung der Indizwirkung bereits abgeschlossener Lizenzverträge entgegenstehe, ließ das LG die Ausführungen der Beklagten betreffend einer Zusatzvereinbarung mit einem Lizenznehmer aus einer anderen Branche gelten.[1468] Da es sich bei dem Lizenznehmer um einen deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender handele, der die Lizenz zur Programmverarbeitung mit Hilfe eines professionellen Ausstrahlungsencoders abgeschlossen habe, sei insoweit schon nicht erkennbar, inwiefern der abgeschlossene Vertrag überhaupt den vorliegend maßgeblichen Mobilfunkgerätemarkt betreffe, mithin überhaupt die vorliegend maßgebliche Indizwirkung mit begründe, da der Lizenznehmer nicht als Anbieter von Mobilfunkgeräten, sondern vielmehr als Fernsehveranstalter sowie Anbieter von Telemediendiensten bekannt sei.[1469]

Auch Umstände, die die bestehende Indizwirkung für die Angemessenheit der Lizenzgebühr entfallen lassen würden, vermochte das LG Düsseldorf nicht festzustellen.[1470] So böten die Beklagtenvorbringen insbesondere keinen Anhalt dafür, dass die Lizenzgebühren nicht mehr unter Wahrung eines ausreichenden Eigengewinns auf Seiten des Lizenznehmers bestritten werden könnten.[1471] Die festgelegten Stücklizenzgebühren von 0,20 $ bzw. 0,10 $ allein ließen dies jedenfalls nicht vermuten.[1472] Auch betreffend einer umsatzbezogenen Betrachtung, die das Verhältnis des Verkaufspreises pro Einheit zu der vom Pool eingenommenen Lizenzgebühr analysiere, habe die Beklagte nicht aufgezeigt, dass bei einer solchen Betrachtung der Gebührenanteil bei chinesischen Vertriebshandlungen (zur geographischen Reichweite unten XI.B.2.c)1)) so hoch sei, dass dieser einem wirtschaftlich vernünftig handelnden Lizenznehmer nicht mehr zugemutet werden könne.[1473] Betreffend den Verweis der Beklagten, dass sofern weitere Inhaber von für den vorliegenden Standard essentiellen Patenten in derselben Art und Weise verfahren würden, eine exzessive Gesamtlizenzbelastung entstehe, führte das LG aus, der Tatsachenvortrag der Beklagten lasse schon nicht erkennen, dass eine solche tatsächlich auch bestehe, was aber für die Feststellung einer Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung nach oberlandesgerichtlicher Rechtsprechung erforderlich wäre.[1474] Insoweit sei gerade auch zu beachten, dass dem streitgegenständlichen Pool bereits circa 40 Poolinhaber von standardwesentlichen Patenten angehörten, und der Beklagtenvorwurf diesbezüglich offenlasse, welcher weiteren Lizenzen es für die Nutzung des Standards darüber hinaus noch bedürfe.[1475]

Weiter ergebe sich, so das LG, die Unangemessenheit der in dem Standardlizenzvertrag angesetzten Lizenzgebühr entgegen der bestehenden Indizwirkung auch nicht daraus, dass für den chinesischen Markt weniger Poolpatente in Kraft ständen, auch wenn der damit in Bezug genommene Sachverhalt

[1466] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 389; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 311.

[1467] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 392; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 314.

[1468] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 395, 406–08; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 317, 328–30.

[1469] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 408; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 330.

[1470] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 420; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 342.

[1471] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 421; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 343.

[1472] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 421; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 343.

[1473] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 422–26; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 344–48.

[1474] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 426; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 348, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 50.

[1475] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 426; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 348.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zwar grundsätzlich Anhalt für eine unangemessene Behandlung geben könne, wobei es jedoch auch insoweit maßgeblich auf die Branchenüblichkeit ankomme (ausführlich VI.B.1.c)1), XI.B.2.c)1)).[1476]

Auch könne nicht festgestellt werden, dass der Patentpool in kartellrechtswidriger Weise zusammengesetzt sei (ausführlich oben).[1477] Zudem erweise sich die im Standardlizenzvertrag angebotene Lizenzhöhe auch nicht deshalb als unangemessen, weil in dem Vertrag eine Anpassungsklausel nicht vorgesehen sei (dazu unten XI.B.2.c)3)).[1478] Weiter führe das Anbieten nur einer konzernweiten Lizenz nicht zur Unangemessenheit des Lizenzvertragsangebots (dazu unten XI.B.2.c)1)).[1479]

Schließlich ließen auch quantitative Unterschiede im Hinblick auf die Seitenanzahl der vorgelegten Vertragsdokumente nicht einen zwingenden Rückschluss von den differierenden Seitenzahlen auf erhebliche inhaltliche Änderungen zu, während eine solche inhaltliche Auseinandersetzung für das Entkräften der Indizwirkung erforderlich wäre.[1480] Auch lasse sich der gewachsene Umfang des Standards in casu plausibel erklären.[1481]

Auch die Kammer 4b des LG Düsseldorf wiederholte die allgemeinen Anforderungen an die Angemessenheitsprüfung, wonach „faire und angemessene“ Vertragsbedingungen solche seien, die dem Lizenzwilligen nicht unter Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung angeboten würden.[1482] Die Vertragsbedingungen müssten zumutbar und nicht ausbeuterisch sein.[1483] Ein Angebot könne sich insbesondere dann als unfair/unangemessen erweisen, wenn eine Lizenzgebühr verlangt werde, die den hypothetischen Preis, der sich bei wirksamem Wettbewerb auf dem beherrschten Markt gebildet hätte, erheblich überschreite, es sei denn, es gebe eine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Preisbildung.[1484] Eine streng mathematische Herleitung sei nicht erforderlich, hinreichend sei – sofern möglich – die Akzeptanz der verlangten Lizenzsätze am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen.[1485] Die Darlegung über bereits abgeschlossene Verträge sei vorrangig (dazu XI.B.1.a)).[1486] Über das Ergebnis verschiedener, schon erfolgreicher, tatsächlicher Lizenzverträge lasse sich die FRAND-Gemäßheit einfacher belegen und sicherer feststellen, als über den Vortrag der einzelnen Faktoren, die in Lizenzverhandlungen jeweils eine näher zu bestimmende, mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen könnten oder sollten.[1487]

[1476] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 428–29; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 350–51, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[1477] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 432–74; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 354–96.

[1478] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 510–16; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 433–39.

[1479] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 517–18; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 440–41.

[1480] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 404; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 326.

[1481] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 404; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 326.

[1482] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277.

[1483] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 15.

[1484] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14, Rn. 225.

[1485] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 311.

[1486] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277.

[1487] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 312.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Der allgemeine Einwand (unter Verweis auf Kurtz/Straub, GRUR 2018, 136), es handele sich bei den vorbestehenden Verträgen schon nicht um ein taugliches Indiz für die Angemessenheit, weil diese Verträge den Anschein eines Ausnutzen der Marktmacht per se in sich trügen, verfange schon deswegen nicht, weil zusätzlich zur Vorlage der Verträge ebenfalls eine Darlegung der Akzeptanz am Markt notwendig sei, die sich insbesondere aus einer Vergleichbarkeit der Lizenznehmer und Lizenzsucher ergeben könne.[1488]

Die Klägerin habe substantiiert dargelegt, dass die angebotene Standardlizenz im Markt akzeptiert und bereits tausendfach abgeschlossen worden sei, wie die Vorlage der Lizenzverträge zeige.[1489] Auch, dass der weit überwiegende Anteil der Lizenznehmer gleichzeitig Pool-Mitglieder sei, lasse die Kammer nicht an der Marktakzeptanz zweifeln (dazu bereits oben VI.B.1.b)).[1490]

Dieses Indiz vermöge die insoweit darlegungsbelastete Beklagte in casu nicht zu erschüttern, da sich ihrem Vortrag keine Unangemessenheit der Lizenzbedingungen entnehmen lasse.[1491] Die Kammer habe weder eine kartellrechtswidrige Zusammensetzung des Pools feststellen können (ausführlich oben VI.B.1.c)2)), noch dass die Lizenzhöhe aufgrund einer fehlenden Anpassungsklausel unangemessen sei (ausführlich unten XI.B.2.c)3)).[1492] Wie schon von der Kammer 4a in den Parallelverfahren festgestellt, lasse auch die Abänderung des Standardlizenzvertrags in der Lizenzhöhe für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter die Indizwirkung nicht entfallen, da es sich bei der Fernsehanstalt augenscheinlich um einen Fernsehveranstalter und Anbieter von Telemediendiensten handele.[1493] Daher sei dieser kein mit der Beklagten vergleichbarer Lizenznehmer, so dass der Vertrag keinen Hinweis auf eine Ungleichbehandlung begründe, der die Indizwirkung entfallen lasse.[1494] Auch andere Lizenznehmer hätten nicht mit diesem abgeänderten Vertrag vergleichbare Lizenzverträge abgeschlossen, was die Indizwirkung hinsichtlich der Lizenznehmer, die Mobilfunkgeräte anböten mangels Vergleichbarkeit nicht erschüttere.[1495]

Auch befand die Kammer die sogenannte „royalty-cap"-Klausel als Kappungsgrenze nicht für unangemessen.[1496] Die fragliche Regelung des Standardlizenzvertrages sah eine Freilizenz für die ersten 100000 verkauften Einheiten ebenso wie eine Kappungsgrenze ab einer bestimmten gezahlten Lizenzhöhe vor.[1497] Die Beklagte hatte geltend gemacht, die „royalty caps" seien nicht angemessen und diskriminierend (dazu unten XI.B.3.b)2)), weil Multiproduktanbieter durch ihre breitere Produktpalette eher in den Genuss der Kappungsgrenze kämen.[1498] So könnten Unternehmen, die standardimplementierende Produkte aus verschiedenen Sparten der Elektrobranche anböten ihre Produkte möglicherweise quersubventionieren, da sie schneller die Kappungsgrenze erreichten als ein

[1488] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 323; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 289; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 262; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 277.

[1489] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1490] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 357; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 296.

[1491] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1492] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1493] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 365; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 304.

[1494] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 365; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 304.

[1495] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 366; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 305.

[1496] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 329, 341; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 296; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 268, 280; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 284.

[1497] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 344; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 283.

[1498] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 342; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 281.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Ein-Produkt-Hersteller.[1499] Eine Diskriminierung scheide in casu mangels einer unterschiedlichen Behandlung bereits aus.[1500]

Zunächst setze die Kappungsgrenze einen wirtschaftlichen Anreiz, hohe Stückzahlen zu verkaufen, um bei hohem Umsatz lizenzfrei zu werden, wodurch der natürliche Wettbewerb gerade gefördert werde.[1501] Eine Wettbewerbsförderung habe gleichzeitig eine gute Durchsetzung des Standards zur Folge.[1502] Es entspreche natürlichen Markt- und Wettbewerbsverhältnissen, dass Unternehmen mit gewissen Marktanteilen und einer gewissen Marktpräsenz belohnt würden.[1503] So sei der Mechanismus der Rabattierung – denn nichts anderes passiere bei Erreichen der Kappungsgrenze – bei großen Stückzahlen ein gängiges Mittel der Wirtschaft.[1504] Das Erreichen hoher Verkaufszahlen liege nicht allein an der Auswahl der Produkte, sondern sei auch auf das individuelle Geschäftsgebaren des jeweiligen Wettbewerbers zurückzuführen, wobei gutes Marketing und eine gute Markenpflege, ausgebaute Infrastrukturen und zuverlässige Vertriebsnetze eine Rolle spielten.[1505] Der wirtschaftliche Erfolg eines Produkts fuße so auf zahlreichen Gründen.[1506]

Auch dass der Standardlizenzvertrag das Kodieren und Dekodieren von standardkonformen Videos und somit verschiedene nachgelagerte Märkte erfasse (mobile Endgeräte, Fernseher, etc.), auf denen diese Technik zum Einsatz komme, stelle keine unzulässige Kopplung (Bundling) dar.[1507] Es werde die Technologie des Videoformats lizenziert, unabhängig in welcher Einrichtung oder auf welchem Endgerät sie Anwendung finde.[1508] Schon die Kopplung sei nicht ersichtlich, weil die Verwendung des Videoformats gerade einheitlich zur entgeltlichen Nutzung bereitgesellt werde.[1509]

Diese ganzen Faktoren führten nach Entscheid des LG dazu, dass die Kappungsgrenze letztlich keinen kartellrechtlichen Missbrauch durch Unangemessenheit darstelle und die Folge einer Quersubventionierung, die bei einem am Markt erfolgreichen Unternehmen auftreten könne, hinzunehmen sei.[1510] Schließlich habe die Kammer auch nicht feststellen können, dass die durch die im Mobilfunkbereich geschlossenen Standardlizenzverträge indizierte FRAND-Gemäßheit widerlegt werde durch eine weltweite Lizenz unter Einschluss der Volksrepublik China.[1511] Eine weltweite Lizenz unter Einschluss der Volksrepublik China sei weder unter dem Aspekt der selektiven Schutzrechtsdurchsetzung eine kartellrechtswidrige Diskriminierung (dazu unten XI.B.3.c)), noch sie die Lizenzgebührenhöhe unter Einbeziehung der Volksrepublik (dazu VI.B.1.c)1), XI.B.2.c)1)) und unter Einbeziehung sämtlicher Standard-Profile (dazu oben VI.B.1.c)2)i)) unangemessen hoch.[1512]

Die deutsche FRAND-Rechtsprechung setzte sich auch vereinzelt mit der Angemessenheit in Bezug auf die zeitlichen Modalitäten der Lizenzgebühr und der jeweiligen Darlegung der Art und Weise von deren Berechnung auseinander.

[1499] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 345; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 284.
[1500] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 343; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 282.
[1501] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1502] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1503] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1504] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1505] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 348; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 287.
[1506] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 348; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 287.
[1507] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 347; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 286.
[1508] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 347; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 286.
[1509] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 347; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 286.
[1510] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 349; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 288.
[1511] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 356; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 295.
[1512] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 356; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 295.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Das Angebot einer pauschalen Lizenzgebühr für die Vergangenheit, ohne jeglichen Angaben zur Art und Weise der Berechnung, sei nach Meinung des OLG Düsseldorf nicht nachvollziehbar und eine Feststellung der Angemessenheit scheitere deshalb.[1513]

Auch das LG Düsseldorf hatte sich in den Entscheiden vom 11.7.2018 mit Lizenzgebühren für die Vergangenheit auseinanderzusetzen. So genüge das Lizenzangebot nicht den Anforderungen an ein FRAND-konformes Angebot, da es eine „Release Royalty" aufweise, die eine abschließende Abgeltung für Zahlungsansprüche für die Vergangenheit beinhalte, ohne dass sie die Möglichkeit einer Ausnahme und/oder Rückvergütung biete.[1514] Die fragliche Klausel sah vor, dass der Lizenzsucher eine Freistellungsgebühr in Bezug auf die Freistellung von früheren Verpflichtungen als einmalige Zahlung zu leisten habe, wobei die Berechnung dieser auf der Grundlage des Lizenzgebührensatzes multipliziert mit dem Gesamterlös aus den Teilnehmergebühren für den Zeitraum ab dem 1. März 2008 bis zum Datum des Inkrafttretens erfolgen sollte.[1515] Eine solche Klausel sei im vorliegenden Fall aus Sicht verständiger Lizenzvertragsparteien nicht fair und daher auch nicht nachvollziehbar, insbesondere auch, da sich die Parteien im parallelen Schadenersatzverfahren über die Frage streiten würden, ob die Klägerin für solche Ansprüche in der Vergangenheit, die vor der Eintragung in das Register entstanden und bei Patentübertragung abgetreten worden seien, als Zessionarin aktivlegitimiert sei.[1516] Bei Abschluss des vorgelegten Lizenzangebots müsse sie Beklagte jedoch unabhängig davon, ob die Klägerin überhaupt zur Geltendmachung der Ansprüche ab März 2008 berechtigt sei, Lizenzgebühren für diesen Zeitraum zahlen.[1517] Vernünftige Vertragsparteien würden für diesen Fall auf eine entsprechende Klausel verzichten oder jedenfalls einen Mechanismus vorsehen, der einen Vergütungsanspruch der Klägerin für den Fall entfallen lasse, dass die Kammer bzw. die Berufungsinstanz im Parallelverfahren zum Ergebnis kommen sollte, dass die Klägerin für die Ansprüche nicht aktivlegitimiert sei.[1518]

Dieser Umstand sei bereits deswegen nicht nachvollziehbar, da die Beklagte dem Risiko ausgesetzt sei, dass die Ansprüche nicht wirksam an die Klägerin abgetreten worden seien und einer Zahlung dementsprechend dann auch kein schuldbefreiender Charakter zuerkannt werden könne.[1519] Dies bedeute, dass die Beklagte dem tatsächlichen Berechtigten weiterhin Vergütung für die Vergangenheit schulden und zugleich das Risiko tragen würde, die gezahlte Summe von der Klägerin nicht zurückzuverlangen bzw. zunächst einen Rechtsstreit über die Rückerstattung führen zu müssen.[1520]

Auch der Abschluss von Vergleichslizenzverträgen vermöge die derzeit berechtigte Unsicherheit über die Anspruchsinhaberschaft der Klägerin zur Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit nicht zu beseitigen, denn die Berechtigung der Klägerin sei zwischen den Parteien der Vergleichslizenzverträge zu keinem Zeitpunkt in Streit gestanden mit der Folge, dass der Abschluss der Verträge keinen Anhaltspunkt für die Berechtigung darstellen könne.[1521] Gleiches gelte im Übrigen für die Behauptung, die Unsicherheiten bei der Aktivlegitimation seien bei der Festlegung des Lizenzsatzes berücksichtigt worden.[1522] Es sei weder konkret dargelegt, wie die Klägerin die Unsicherheit betragsmäßig bestimmt habe, noch welche Faktoren sie dabei mit einbezogen habe.[1523] Was die

[1513] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 19.

[1514] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 237; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 251.

[1515] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 239; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 253.

[1516] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 240; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 254.

[1517] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 240; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 254.

[1518] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 241; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 255.

[1519] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 241; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 255.

[1520] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 241; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 255.

[1521] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 243; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 257.

[1522] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 243; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 257.

[1523] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 243; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 257.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Attribute fair & reasonable angehe, habe die Klägerin deswegen entweder darzutun, dass die herangezogenen Vergleichslizenzen missbrauchsfrei seien (und deshalb direkt übertragen werden könnten) oder aber zwar unter Marktmissbrauch zustande gekommen seien, im Lizenzangebot allerdings hinreichende Abschläge zugunsten des Verletzers berücksichtigt seien, die die angebotene Lizenz ausbeutungsfrei machen würden.[1524]

Nach Ansicht des OLG Düsseldorf sei für die Darlegung der Art und Weise der Berechnung einer zukünftigen Lizenzgebühr die Benennung allein der maßgeblichem Bezugsgröße und des anzuwendenden Lizenzsatzes mit Staffelung nicht ausreichend.[1525] Es dürften vielmehr darüber hinausgehend sämtliche Berechnungsfaktoren konkret darzulegen seien, die zum Zustandekommen der angebotenen Lizenzgebühr beitragen würden, und aus denen sich ergebe bzw. anhand derer nachgeprüft werden könne, dass das konkrete Angebot weder diskriminierend noch ausbeuterisch sei (vgl. zur Art und Weise der Berechnung ausführlich oben XI.B.1).[1526] Im dem OLG vorliegenden Fall dürfe dies insbesondere eine Erläuterung erfordern, wie sich der zukünftige Lizenzsatz und die für die Vergangenheit geforderte Pauschallizenzgebühr – etwa nach verschiedenen Märkten und/oder nach der Marktbedeutung der enthaltenen Patente – konkret zusammensetzten.[1527]

c) Weitere Angebotsmodalitäten

Neben der Lizenzhöhe hat das Vertragsangebot auch im Hinblick auf die übrigen Vertragsbedingungen angemessen sein.[1528] Auch wenn sich die übrigen Lizenzmodalitäten wohl letztlich in Vertragsverhandlungen in der Höhe der Lizenzgebühr widerspiegeln werden, wurde die Angemessenheit von weiteren Modalitäten in der deutschen Rechtsprechung verschiedentlich thematisiert.

1) Bestehen auf konzern- oder weltweite Lizenz

Die deutsche Rechtsprechung setzte sich mit der Angemessenheit des Angebots einer konzern- und weltweiten Lizenz auseinander. Im folgenden Abschnitt soll der Aspekt der konzernweiten Lizenz mit dem der weltweiten Lizenz gemeinsam behandelt werden, da dies auch in der Rechtsprechung meistens so vorgenommen wurde und sich die Aspekte mitunter nur schwer trennen lassen, da die unternehmensorganisatorischen Grenzen oft anhand geographischer Begebenheiten verlaufen.

Das OLG Düsseldorf hielt im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 pauschal fest, gegen das Angebot einer konzern- und weltweiten Lizenz beständen grundsätzlich keine Bedenken.[1529] Fraglich könnte jedoch in geographischer Hinsicht sein, ob es „fair und angemessen“ sei, wenn eine gleich hohe Lizenzgebühr, die sämtliche Patentfamilien des Portfolios umfasse, auch für lizenzpflichtige Handlungen in einem Land gefordert werde, in dem nur ein einziges SEP/Patent in Kraft stehe und benutzt werde.[1530] Es bedürfe näherer Erläuterungen dazu, dass eine solche Klausel, etwa weil sie in frei ausgehandelten Lizenzverträgen der jeweiligen Branche üblich seien, FRAND-gemäß sei.[1531] Andernfalls könne eine Klausel notwendig sein, mit der die Höhe der Lizenzgebühr an die Zahl der benutzten Patente

[1524] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 243; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 257.

[1525] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 19.

[1526] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 19.

[1527] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 19.

[1528] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 324; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 263; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 278; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 290; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 295; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 277; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 374; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 296.

[1529] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 21.

[1530] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[1531] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gekoppelt werde, die auf dem jeweiligen Vertriebsmarkt erteilt und gültig seien.[1532] Weiter sei für die Beurteilung, ob eine uneingeschränkte weltweite Lizenz wegen eingetretener Erschöpfung nicht FRAND-gemäß sei, unter anderem der Umfang der behaupteten Erschöpfung von Bedeutung, weshalb es der Beklagten obliege dazu konkret vorzutragen.[1533]

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 und 11.7.2018 hielt fest, das Angebot müsse auch etwa hinsichtlich des Umfangs der lizenzierten Schutzrechte und der territorialen Reichweite FRAND sein.[1534] Bei der Frage, ob eine weltweite Portfolio-Lizenz FRAND-Vorgaben entspreche, sei insbesondere auch die Branchenüblichkeit relevant (dazu bereits oben XI.B.2.a), VI.B.1).[1535] Würden auf dem relevanten Markt üblicherweise weltweite Konzernlizenzverträge für ganze Schutzrechtsportfolios geschlossen, verstoße ein entsprechendes Vertragsangebot nicht gegen FRAND, es sei denn die Umstände des Einzelfalls ließen eine Abweichung erforderlich erscheinen, etwa wenn der Verletzer nur auf einem geographischen Markt tätig sei.[1536]

Auch in den Verfahren zum AVC-Videostandard vom 9.11.2018 setzte sich das LG Düsseldorf mit der Frage der Angemessenheit einer konzern- bzw. weltweiten Lizenz auseinander. Dass die Lizenzverwalterin nach dem Standardlizenzvertrag eine Lizenzierung sämtlicher Konzerngesellschaften anstrebe, erweise sich weder unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit (dazu sogleich) noch bei der Berücksichtigung des Diskriminierungsverbots (dazu unten XI.B.3) als missbräuchlich.[1537] Im Elektronik- und Mobilfunkbereich seien konzernweite Lizenzverträge gebräuchlich, und insoweit entfalte auch die Vielzahl der bereits abgeschlossenen Standardlizenzverträge eine erhebliche Indizwirkung für die Branchenüblichkeit einer konzernweiten Lizenz.[1538] Auch stelle die Muttergesellschaft die angegriffenen Ausführungsformen her und vertreibe diese durch Tochtergesellschaften weltweit, so dass die Poolpatentinhaber auch vor diesem Hintergrund ein besonderes Interesse an der Vergabe einer konzernweiten Lizenz hätten.[1539] Denn nur so könne eine Vermischung von lizenzierten und nicht lizenzierten Produkten innerhalb eines Konzerns vermieden werden, die ansonsten dazu führen würde, dass eine effektive Rechtsdurchsetzung in Ermangelung einer Trennbarkeit der berechtigt vertriebenen von patentverletzenden Produkten nicht mehr möglich wäre.[1540]

In den Parallelverfahren machte die Kammer spezifischere Ausführungen dazu, inwiefern keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür beständen, dass die Stücklizenz des Standardlizenzvertrags deshalb unangemessen hoch sei, weil diese unabhängig von dem Gebiet, in dem das Lizenzprodukt veräußert werde, einheitlich festgelegt werde, und insbesondere für den chinesischen Markt keine niedrigere Stücklizenz vorgesehen sei.[1541] Insoweit sei zunächst die erhebliche Indizwirkung der über

[1532] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[1533] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 49.

[1534] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 197; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 211; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 355 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 306 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 354; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 307.

[1535] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 197; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 211; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 355 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 306 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 354; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 307.

[1536] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 197; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 211; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 355 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 306 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 354; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 307, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 220.

[1537] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 299; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 281.

[1538] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 300; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 282.

[1539] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 301; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 283.

[1540] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 301; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 283.

[1541] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 386; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 308.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

2000 von der Klägerin vorgelegten Lizenzverträge beachtlich, die unter Rückgriff auf das Vergleichsmarktkonzept eine tatsächliche Vermutung für die Angemessenheit der Lizenzbedingungen entfalten würden (vgl. oben VI.B.1.b)).[1542] Diese Indizwirkung erfasse grundsätzlich auch den Umfang der Lizenz.[1543] Habe der Patentinhaber bereits Lizenzen an dem angebotenen SEP-Portfolio für vergleichbare Produkte erteilt, spreche der Anschein dafür, dass die Zusammenstellung von Schutzrechten interessengerecht sei.[1544] Das Vorbringen der Klägerin biete einen gewichtigen Anhaltspunkt dafür, dass weltweit einheitliche Lizenzgebühren branchenüblich seien.[1545]

Die umsatzbezogene Betrachtung, die das Verhältnis des Verkaufspreises pro Einheit zu der vom Pool eingenommenen Lizenzgebühr in den Blick nehme, zeige auch nicht, dass der auf den Pool entfallende Wertanteil bei Verkäufen aus China unangemessen größer sei als bei Verkäufen in andere Ländern.[1546] Zunächst ständen die tatsächlichen Verkaufspreise den von der Beklagten pauschal vorgetragenen erheblichen Unterschieden in den Verkaufspreisen auf dem chinesischen Markt entgegen.[1547] Unbeschadet dessen habe die Beklagte auch nicht aufgezeigt, dass bei einer solchen Betrachtung der Gebührenanteil bei chinesischen Vertriebshandlungen so hoch sei, dass dieser einem wirtschaftlich vernünftig handelndem Lizenznehmer nicht mehr zugemutet werden könnte.[1548] Das tatsächliche Bestehen einer exzessiven Gesamtlizenzbelastung sei nicht vorgetragen, was aber für die Feststellung eines Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung erforderlich wäre.[1549]

Es ergebe sich keine der bestehenden Indizwirkung entgegenstehende Unangemessenheit daraus, dass für den chinesischen Markt weniger Poolpatente in Kraft ständen.[1550] Ein solcher Sachverhalt könne zwar grundsätzlich Anhalt für eine unangemessene Behandlung geben, wobei es jedoch auch insoweit maßgeblich auf die Branchenüblichkeit ankomme.[1551]

In diesem Zusammenhang sei zunächst zu beachten, dass die Zahl der in einem Land in Kraft stehenden Schutzrechte nicht überbewertet werden dürfe, weil auch schon ein einziges Patent in das Lage sei, einen Interessenten von dem standarddefinierten Markt fernzuhalten.[1552] Ob der Lizenzsucher darüber hinaus noch weitere Lizenzen benötige, um die standardisierte Technologie zu nutzen, spiele dann eine eher untergeordnete Rolle.[1553] Weiter sei beachtlich, dass in casu der Anteil der Poolpatente in China am viertstärksten sei.[1554]

Die Tatsache, dass eine Patentdurchsetzung möglicherweise erschwert sei, stelle für sich genommen keinen Grund dar, geringere Lizenzraten zu verlangen, da ein Patent schon dann zu beachten sei, wenn es bestehe.[1555]

[1542] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 388–89; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 310–11.

[1543] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 389; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 311.

[1544] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 389; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 311, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14, Rn. 226.

[1545] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 392; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 314.

[1546] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 422; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 344.

[1547] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 423–25; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 345–47.

[1548] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 426; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 348.

[1549] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 426; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 348, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 50.

[1550] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 428; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 350.

[1551] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 429; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 351, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 42.

[1552] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 430; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 352.

[1553] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 430; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 352, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 11.9.2008 – 4b O 78/07, Rn. 102.

[1554] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 430; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 352.

[1555] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 431; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 353.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Auch in den Parallelverfahren zum AVC-Videostandard vom 12.12.2018 befand die Kammer 4b des LG Düsseldorf ein Angebot, das eine konzernweite Lizenz beinhalte für nicht unangemessen.[1556] Eine konzernweite Lizenz werde dem globalen Mobilfunkmarkt und den verschiedenen Konzernstrategien gerecht und sei mit geringeren Transaktionskosten verbunden.[1557] Insoweit würden auch die vorgelegten Standardlizenzverträge eine Indizwirkung für die Branchenüblichkeit entfalten.[1558] Da die Muttergesellschaft die angegriffene Ausführungsform herstelle und durch die Tochtergesellschaften weltweit vertreibe, sei das besondere Interesse der Klägerin an einer konzernweiten Lizenz auch unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt.[1559] Damit werde eine Vermischung von lizenzierten und nicht lizenzierten Produkten innerhalb eines Konzerns vermieden, die ansonsten dazu führen würde. Dass eine effektive Rechtsdurchsetzung verhindert werde.[1560]

2) Erschöpfung und Beschränkungen in der Vertriebskette

i) Doppellizenzierung und Erschöpfung

Wird eine Lizenzgebühr für Produkte erhoben, bei denen bereits Erschöpfung eingetreten ist, wird die Vertriebskette mit einer Doppellizenzierung belastet. Allgemein führte das LG Düsseldorf aus, Erschöpfung im patentrechtlichen Sinne bedeute, dass die Ausschließungsrechte der Patentinhaberin verbraucht seien, was heiße, dass der Gegenstand der patentgemäßen Erfindung von jedem Dritten in Verkehr gebracht, angeboten und benutzt werden könne.[1561] Alle diese Tathandlungen unterlägen nicht mehr dem Verbietungsrecht aus dem Patent.[1562] Der Einwand des Verbrauchs bzw. der Erschöpfung sei nach deutschem Recht begründet, wenn die Patentinhaberin selbst oder ein mit ihrer Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Vertragsstaaten der Europäischen Union in Verkehr gebracht habe.[1563]

Diesbezüglich hielt das OLG Düsseldorf vom 17.11.2016 fest, wenn und soweit Erschöpfung in Bezug auf den Chip eingetreten sei, könne wie im deutschen Recht möglicherweise auch nach ausländischem Recht für die vertriebenen Geräte keine Lizenzgebühr verlangt werden, weil die Erfindung in den Chipsätzen vollständig umgesetzt werde.[1564] Darlegungs- und beweisbelastet für die Voraussetzungen des rechtsvernichtenden Einwandes der Erschöpfung sei zwar grundsätzlich die Beklagte, jedoch dürfe die Klägerin aufgrund der vorgelegten Presseerklärung, aus der sich konkrete Anhaltspunkte für den Eintritt einer Erschöpfung nach dem einschlägigen ausländischen Patentgesetz ergäben, eine sekundäre Darlegungslast treffen.[1565] Denn die Beklagte habe in den konkreten Inhalt der Lizenzvereinbarungen mit dem Chiphersteller keinen Einblick, während es der Klägerin möglich und zumutbar sein dürfe, diesen vorzutragen und erforderlichenfalls auch einen Auskunftsanspruch gegen ihre Einzelrechtsvorgängerin diesbezüglich geltend zu machen.[1566]

Weiter sei, sofern eine Lizenzierung zwischen der Lizenznehmerin und dem Lizenznehmer auf der vorgelagerten Stufe der Wertschöpfungskette festgestellt werden könne, gegebenenfalls zu klären, ob

[1556] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 299; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 287.

[1557] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 300; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 288.

[1558] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 300; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 288.

[1559] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 300; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 288.

[1560] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 300; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 288, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17.

[1561] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 227; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 241.

[1562] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 227; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 241.

[1563] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 227; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 241.

[1564] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 33.

[1565] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 34.

[1566] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 34.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

eine etwaige weitere Vereinbarung zwischen diesen, wonach auf nachgeordneten Wirtschaftsstufen keine Erschöpfung eintrete, wie im deutschen Recht keine dingliche Wirkung entfalten würde oder stattdessen nach ausländischen Recht wirksam wäre.[1567] Dabei seien im Hinblick auf die genannten Aspekte Erläuterungen zum anwendbaren ausländischen Recht nach § 293 ZPO hilfreich und dienten der Prozessförderung.[1568]

Für ein FRAND-gemäßes Angebot dürfte es nach dem OLG grundsätzlich erforderlich sein, dass in einem Lizenzvertrag eine – in spürbarem Umfang tatsächlich eingetretene – Erschöpfung berücksichtigt werde, sofern der potenziell betroffene Markt zu den Faktoren gehöre, die für die Berechnung der Lizenzgebühr herangezogen worden seien.[1569] Gegebenenfalls könnte eine ausreichende Berücksichtigung der Erschöpfung in einer diesbezüglichen Anpassungsklausel gesehen werden.[1570]

Eine „Drittbestimmungsklausel" dürfte nicht zum notwendigen Inhalt eines FRAND-gemäßen Angebots gehören.[1571] Darüber hinaus dürfte sie sich, wenn sie in einem Lizenzvertragsangebot enthalten sei, nur dann als FRAND-konform erweisen, wenn gleichwohl ein konkretes Angebot (dazu oben XI.A.5, XI.B.1) angegeben werde.[1572]

Zur Berücksichtigung von Erschöpfung und Doppellizenzierung traf das LG Düsseldorf in seinen Entscheiden vom 11.7.2018 weitergehende Ausführungen. Folge des grundsätzlich anerkannten Erschöpfungsgedankens sei, dass Lizenzangebote einem möglichen Erschöpfungseinwand grundsätzlich Rechnung tragen müssten, um FRAND zu sein.[1573] Denn ein solches Angebot sei nur dann „fair und angemessen", wenn die Patentinhaberin dem potentiellen Lizenznehmer keine Bedingungen unterbreite , die im Ergebnis auf die Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung hinausliefen.[1574] Die Einbeziehung der Erschöpfung und damit zugleich der Wertschöpfungsproblematik sei insbesondere in den Fällen erforderlich, wo – wie vorliegend – mehrstufiger Vertrieb und Leistungsketten üblich seien.[1575]

Diesen Anforderungen werde eine Klausel nicht gerecht, die zwar grundsätzlich das Recht des Lizenznehmers vorsehe, eine angemessene Verringerung der Lizenzrate zu verlangen, soweit die lizenzvertraglich erteilten Rechte an den lizenzierten Patenten erschöpft oder an den Lizenznehmer lizenziert seien.[1576] Falls aber sich Lizenzgeber und -nehmer nicht auf eine solche Verringerung einigen könnten, solle nach der Vertragsklausel diese Verringerung von zuständigen Gerichten bestimmt werden, wobei der Lizenznehmer die Beweislast für seinen Anspruch auf angemessene Vergütung trage.[1577] Die Klausel sei schon deshalb nicht fair, weil sie unbestimmte Rechtsbegriffe ohne Anknüpfungstatsachen beinhalte und dem Lizenznehmer die Darlegungs- und Beweislast für eine angemessene Verringerung der Lizenzgebühr aufbürde.[1578] Dadurch werde der Lizenznehmer im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung von vornherein einem unangemessenen Verlustrisiko

[1567] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 35.

[1568] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 36.

[1569] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 37.

[1570] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 37.

[1571] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 38.

[1572] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 38.

[1573] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 228; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 242.

[1574] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 228; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 242, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15.

[1575] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 228; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 242.

[1576] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 229–30; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 243–44.

[1577] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 230; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 244.

[1578] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

ausgesetzt.[1579] Die Regelung, der Lizenznehmer müsse das Vorliegen der Erschöpfung als solcher darlegen und nötigenfalls beweisen, um eine Reduzierung des Lizenzsatzes zu erreichen, entspreche auf den ersten Blick zwar der allgemeinen Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für den als Einwand ausgestalteten Grundsatz der Erschöpfung.[1580] Praktisch werde dem Lizenznehmer dieser Nachweis aber häufig nur schwer gelingen, denn bei den zur Erschöpfung führenden Tatsachen handele es sich um interne, auf das Unternehmen der Lizenzgeberin bezogene Daten.[1581] Nur sie habe Kenntnis davon, über welche Produkte und mit welchen Unternehmen Lizenzverträge geschlossen worden seien.[1582] Für den Lizenznehmer sei es faktisch unmöglich, derart fundierte Kenntnisse zu erlangen, so dass hinreichend substantiierter schriftsätzlicher Vortrag im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung gelingen könnte.[1583]

An diesen Ergebnis ändere sich auch dann nichts, wenn der Lizenzgeberin eine sekundäre Darlegungslast auferlegt würde, denn Voraussetzung dafür, dass sie dieser nachkommen müsse, sei zumindest, dass die Lizenznehmerin überhaupt von weiteren abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen Kenntnis erlange, die sie in einem gerichtlichen Verfahren pauschal vortragen könne.[1584] Erst dieser Vortrag würde die sekundäre Darlegungslast der Lizenzgeberin auslösen.[1585] Dabei dürfte aber schon diese bloße Kenntniserlangung überwiegend vom Zufall abhängen, wenn nicht gar gänzlich ausgeschlossen sein, da es sich in dem Bereich standardessenzieller Lizenzen üblich sein dürfte, in solchen Lizenzverträgen eine Geheimhaltungsklausel zu vereinbaren, wodurch den Vertragspartnern die Mitteilung über den Abschluss eines Lizenzvertrages untersagt sei.[1586]

Hinsichtlich der Höhe der anzusetzenden Reduzierung bestehe für den Lizenznehmer das weitere Risiko, ohne gerichtliche Auseinandersetzung eine solche überhaupt nicht durchsetzen zu können.[1587] Bei dem insoweit in der Regelung des Lizenzangebotes verwendeten Begriff „angemessen“ handele es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff.[1588] Zwar sei grundsätzlich zulässig, dass ein Gericht unter Berücksichtigung des Einzelfalls diesen unbestimmten Rechtsbegriff ausfülle, namentlich hier die „Angemessenheit“ beziffere.[1589] Allerdings bestehe für den Lizenznehmer mit dieser Regelung die Gefahr, dass die Lizenzgeberin eine außergerichtlich vorgeschlagene Reduzierung nicht für angemessen erachte und den Lizenznehmer somit in ein gerichtliches Verfahren drängen könne, welches zugleich mit einer erheblichen Kostenrisiko einhergehe.[1590] Diese Gefahr bestehe umso mehr, weil weder die oben zitierte Klausel noch andere Passagen des Lizenzangebotes Anhaltspunkte oder Kriterien vorgäben, an denen sich das Maß der Reduzierung orientieren könne.[1591] Dass gegen eine komplikationslose außergerichtliche Einigung eine gewisse Wahrscheinlichkeit spreche, ergebe sich nicht zuletzt aus dem vorliegenden Rechtsstreit, in welchem nämlich die verschiedenen Ansichten der Parteien bezüglich der „richtigen“ Bemessung dargelegt würden.[1592] Die Bestimmung der Angemessenheit dem Gericht zu überlassen, sei für den Lizenznehmer im Übrigen auch deshalb nicht angemessen, weil ihm während der Dauer eines Gerichtsverfahrens praktisch keine andere Wahl

[1579] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1580] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1581] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1582] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1583] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1584] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1585] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1586] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 231; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 245.
[1587] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 232; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 246.
[1588] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 232; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 246.
[1589] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 232; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 246.
[1590] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 232; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 246.
[1591] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 232; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 246.
[1592] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 232; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 246.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

bleiben dürfte, als den bisherigen Lizenzsatz, gegebenenfalls unter Vorbehalt, weiterhin zu zahlen, da für eine verringerte Lizenzzahlung keine hinreichende Rechtssicherheit bestehe.[1593]

So bedingten die vorstehenden Ausführungen, so das LG, dass das Problem der Doppellizenzierung im Vertragsangebot nur unangemessen berücksichtigt werde.[1594] Die Patentinhaberin wäre nämlich aufgrund der oben dargestellten Klausel in der Lage, Lizenzen von den jeweiligen Herstellern für die Netzwerkkomponenten zu verlangen und außerdem noch Lizenzen von den Netzbetreibern für den Verkauf entsprechender Komponenten zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.[1595] Sie würde damit Lizenzgebühren für die Vorrichtungen mehrfach erhalten und zwar unabhängig von der Frage, ob mit der Erschöpfung der Vorrichtung auch eine Erschöpfung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolge.[1596] Genau dies widerspreche jedoch den Grundsätzen der patentrechtlichen Erschöpfungslehre.[1597] Dabei sei der Patentinhaberin das nicht nur theoretische Problem der Doppellizenzierung aber auch bekannt, denn sie wisse um die Tatsache, dass die Beklagten für die Bereitstellung der DSL-Leistungen Komponenten anderer Hersteller benutzen würden, die ihrerseits möglicherweise aus dem Lager der Klägerin schon lizenziert worden seien.[1598] Dieses Bewusstsein der Klägerin äußere sich in den streitgegenständlichen Klageanträgen, da aus dem Unterlassungsanspruch gezielt Verfahren bzw. Vorrichtungen, die mit Komponenten von unter anderem des vorlizenzierten Chipherstellers durchgeführt würden, ausgenommen worden seien, um eine Beweisaufnahme, wie sie im parallelen Schadenersatzfeststellungsverfahren von der Kammer als notwendig erachtet worden sei, zu umgehen.[1599] Unter Berücksichtigung vorstehender Ausführungen sei das frühere Lizenzangebot der Patentinhaberin erst recht nicht FRAND, da dieses keinerlei Regelungen zur Erschöpfungsproblematik beinhalte.[1600]

ii) Beschränkung auf bestimmte Geschäftsfelder und Teile der Vertriebskette

Die verschiedenen Kammern des LG Düsseldorf setzten sich jeweils mit der Angemessenheit der im Lizenzangebot vorgesehenen Vertragsbedingungen auseinander, dass nur bestimmte Geschäftsfelder lizenziert bzw. nicht lizenziert wurden.

So hatte das LG Düsseldorf vom 11.7.2018 zu entscheiden, ob eine Klausel im Lizenzvertragsangebot, die das Großhandelsgeschäft der Beklagten (sog. „Whole-Sale-Geschäft“) von der Lizenzierung ausnehmen würde, dieses entgegen der Indizwirkung unangemessen machen würde.[1601] Die fragliche Klausel des Lizenzangebots habe gelautet, die Lizenz umfasse lediglich die Geschäftstätigkeiten des Lizenznehmerparteien mit gewerblichen und nicht gewerblichen Endkunden, das heiße, sie erstrecke sich nicht auf das Großhandelsgeschäft der Lizenznehmerparteien.[1602] Konkret sei damit derjenige Geschäftsbereich der Beklagten von der Lizenzierung ausgeschlossen, der die Bereitstellung von DSL-Vorleistungen an Großabnehmer betreffe.[1603] Die Beklagte ermögliche dabei Großabnehmern, auf die von der Beklagten genutzte Infrastruktur und die DSL-Netzwerkkomponenten zuzugreifen, wodurch es den Großabnehmern ermöglicht werde, ebenfalls DSL-Leistungen gegenüber potentiellen Endkunden

[1593] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 232; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 246.
[1594] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 233; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 247.
[1595] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 233; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 247.
[1596] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 233; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 247.
[1597] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 233; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 247.
[1598] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 234; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 248.
[1599] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 234; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 248.
[1600] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 235; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 249.
[1601] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 245–51; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 259–64.
[1602] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 247; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 261.
[1603] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 248; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 262.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

anzubieten.[1604] Die Klägerin habe diese Gestaltung des Lizenzangebots damit verteidigt, dass es ihr unbenommen sei, auf welcher Vertriebsstufe Lizenzverträge in welchem Umfang geschlossen würden.[1605]

Nach Auffassung der Kammer führe dieses Argument jedoch nicht dazu, dass das Angebot als FRAND-konform zu bewerten sei.[1606] Zwar sei es einer Patentinhaberin zuzugestehen, die Vertriebsstufe frei auswählen zu dürfen, auf der sie Lizenzverträge zu schließen beabsichtige, denn auch für die Patentinhaberin gelte der Grundsatz der vertraglichen Privatautonomie, wonach sie ihre Vertragspartner auswählen könne.[1607] Der vorliegende Fall liege allerdings anders, denn die Klägerin als Inhaberin eines standardessentiellen Patents, die sich zu dem auch zur Erteilung von Lizenzen verpflichtet habe, habe der Beklagten den Marktzutritt zu fairen Bedingungen zu gewähren.[1608] Zu diesem Markt gehöre für die Beklagte als Netzbetreiberin aber nicht nur der Markt der Endkunden, vielmehr beruhe nach deren Vorbringen ein erheblicher Teil ihres Umsatzes als Netzbetreiberin auf Geschäften mit Drittanbietern von Kommunikationsdienstleistungen, also gerade mit Großabnehmern, welchen sie ihre Netzinfrastruktur zur Verfügung stelle.[1609] Dieses Geschäftsfeld als Teil des DSL-Geschäfts müsse deshalb in die Betrachtung, ob der Marktzutritt fair sei, einfließen und dürfe der Beklagten nicht durch Verweigerung eines Lizenzangebots faktisch abgeschnitten werden.[1610]

Darüber hinaus sei im vorliegenden Fall erschwerend zu berücksichtigen, dass das Whole-Sale-Geschäft der Beklagten nicht vom Streitgegenstand der Unterlassungsklage ausgenommen worden sei, so dass sich die Beklagte dem Risiko des Verlusts eines Teil ihres Geschäftsfelds ausgesetzt sähe ohne überhaupt die Möglichkeit zu haben, diese Gefahr durch Abschluss eines Lizenzvertrags abzuwenden.[1611] Ohne Einbeziehung des Whole-Sale-Geschäfts in den Lizenzvertrag mit der Klägerin bestehe für die Beklagte zudem die erhebliche Gefahr, gegenüber ihren Großabnehmern schadenersatzpflichtig zu werden, denn ab Vertragsschluss dürfte die Beklagte ihren Abnehmern keine DSL-Leistungen mehr zur Verfügung stellen, da dies dann rechtswidrig wäre.[1612] Gleichzeitig liege darin aber ein Verstoß gegen vertragliche Pflichten im Verhältnis zu den Abnehmern, da diesen gegenüber Erfüllung, also Bereitstellung von DSL-Leistungen, geschuldet sei.[1613]

In den Entscheiden vom 9.11.2018 setzte sich die Schwesterkammer 4a des LG Düsseldorf mit der Frage auseinander, inwiefern die Beschränkung der Lizenz auf eine gewisse Vertriebsstufe unangemessen sei. Innerhalb der Lizenzierung konzernverbundener Unternehmen sei (bei einer weltweiten Lizenz, dazu oben XI.B.2.c)1)) eine Lizenznahme allein der Muttergesellschaft bereits ausreichend, sofern andere Konzernunternehmen lediglich als Vertriebsgesellschaften der Muttergesellschaft fungierten, da der Vertrieb der Töchtergesellschaften über den Erschöpfungsgrundsatz legitimiert sei.[1614]

Doch auch die Tatsache, dass der Standardlizenzvertrag Vertriebshandlungen an Groß- und Einzelhändler – wie von der beklagten Tochtergesellschaft vorgenommen – nicht erfasse, stehe einer

[1604] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 248; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 262.
[1605] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 249; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 263.
[1606] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 249; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 263.
[1607] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 250; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 264.
[1608] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 250; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 264.
[1609] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 250; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 264.
[1610] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 250; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 264.
[1611] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 251; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 264.
[1612] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 251; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 264.
[1613] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 251; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 264.
[1614] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 281; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 263.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

tauglichen Angebotshandlung nicht entgegen.[1615] Das der Muttergesellschaft vorgelegte Vertragsangebot schließe eine Lizenzierung auch der Tochterunternehmen gerade nicht von vornherein aus, und die konkrete Ausgestaltung einer alle Konzerngesellschaften erfassenden Lizenz wäre erst im Rahmen der Vertragsverhandlungen zu klären gewesen.[1616] Etwas andere möge dann gelten, wenn – was vorliegend nicht zu entscheiden sei – entweder in den die Vertragsverhandlungen vorbereitenden Handlungen bzw. im Rahmen der Vertragsverhandlungen selbst bereits zum Ausdruck komme, das konzernverbundene Tochtergesellschaften von dem der Muttergesellschaft unterbreiteten Vertragsangebot von vornherein nicht erfasst sein könnten, was gerade nicht der Fall sei.[1617] Unbeschadet dessen, dass die Beklagte jedenfalls auch Angebotshandlungen gegenüber Endkunden vornehme, sei zwischen den Parteien nunmehr unstreitig, dass auch Vertriebshandlungen gegenüber Groß- und Einzelhandelskunden zumindest über den Erschöpfungsgrundsatz legitimiert seien.[1618] Dass dies für die Muttergesellschaft im Zeitpunkt der Angebotshandlung nicht erkennbar gewesen sei, sei unschädlich.[1619]

Auch in diesem Zusammenhang sei maßgeblich, dass der branchenübliche Ausgangspunkt der Vertragsverhandlungen vorliegend die Kommunikation mit der Muttergesellschaft sei, deren Benutzungshandlungen unstreitig vom Standardlizenzvertrag abgedeckt würden.[1620] Die Frage der Einbeziehung der Benutzungshandlungen der Töchtergesellschaften sei dann Gegenstand der Vertragsverhandlungen, die sich an das an die Muttergesellschaft gerichtete Angebot anschlössen.[1621] In diesem Rahmen wäre dann auch die Frage der Lizenzierung von Vertriebshandlungen gegenüber gewerblichen Abnehmern mit dem hier bereits dargestellten Ergebnis zu erörtern gewesen.[1622] Vorliegend habe die Muttergesellschaft diesen Gesichtspunkt aber nicht in die Vertragsverhandlungen eingebracht, was zu erwarten gewesen wäre, wenn sie in diesem einen Hinderungsgrund für den Abschluss eines Lizenzvertrags ausgemacht hätte, was umso mehr gelte, als nur sie – anders als die verantwortliche Lizenzverwalterin – die für den Abschluss des Lizenzvertrags beachtlichen Konzernstrukturen im Detail gekannt habe.[1623]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 führte die Kammer 4b aus, die Tatsache, dass der Standardlizenzvertrag Vertriebshandlungen an Groß- und Einzelhändler, wie sie die Beklagte praktiziere, nicht erfasse, einer tauglichen Angebotshandlung nicht entgegen.[1624] Nach Vorlage der Lizenzverträge sei mittlerweile unstreitig, dass das Geschäftsmodell der Vertriebshandlungen an Groß- und Einzelhandelskunden von der Lizenz erfasst werde.[1625] Dass dies für die Muttergesellschaft im Zeitpunkt der Angebotshandlung nicht erkennbar gewesen sei, sei unschädlich, da dieser Gesichtspunkt typischerweise Gegenstand von sich dem Angebot anschließenden Vertragsverhandlungen sei und dort zu erörtern gewesen wäre.[1626] Nach den Maßstäben von Treu und Glauben und anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten wäre zu erwarten gewesen, dass die Muttergesellschaft diese Frage in den Verhandlungen adressiert hätte, zumal wenn die Frage für sie so zentral sei, dass sie einen Hinderungsgrund für den Abschluss des Vertrages darstelle.[1627] Schließlich

[1615] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 283; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 265.
[1616] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 280; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 262.
[1617] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 278–79; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 260–61.
[1618] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 284; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 266.
[1619] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 284; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 266.
[1620] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.
[1621] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.
[1622] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.
[1623] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 285; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 267.
[1624] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 285; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 273.
[1625] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 285; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 273.
[1626] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 285; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 273.
[1627] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 285; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 273.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

sei es auch die Muttergesellschaft, die ihre eigenen Konzernstrukturen kenne und der Lizenzverwalterin mitteilen könne, welche Besonderheiten für sie wichtig seien.[1628] Abgesehen davon hätte die Lizenzverwalterin die irrige Rechtsansicht der Muttergesellschaft aufklären können und es hätte sich – wie die Beklagte nunmehr selbst festgestellt habe, herausgestellt, dass das Geschäftsmodell des Konzerns der Beklagten durchaus von dem Standardlizenzvertrag erfasst werde.[1629]

3) Anpassungsklausel und nachträgliche Veränderung des Portfolios durch Ungültigkeit, Erschöpfung und Ablauf

i) Anpassungsklausel generell

Verschiedentlich verlangten die deutschen Gerichte, das FRAND-Angebot müsse eine Anpassungsklausel enthalten, um nachträgliche Veränderungen im Patentportfolio zu berücksichtigen.[1630] Eine Veränderung im Schutzrechtsbestand kann sich dabei durch den Ablauf der Schutzdauer von Portfoliopatenten, der rechtskräftigen Vernichtung von Portfoliopatenten, der Neuanmeldung von Patenten und dem Erwerb bzw. der Veräußerung von Portfoliopatenten ergeben. Zu bemerken ist, dass dabei von einer Mehrzahl von Patenten im Portfolio des SEP-Inhabers ausgegangen wird, wobei das Portfolio von einem einzelnen Patentinhaber gehalten werden kann oder von einem Patentpool (dazu oben VI). Die Anpassungsthematik ergibt sich in beiden Konstellationen.

Das OLG Düsseldorf erwähnte so in seinem Hinweisbeschluss vom 17.11.2016, ein FRAND-Angebot dürfte erfordern, dass eine Anpassungsklausel in den Lizenzvertrag aufzunehmen sei, die (in beide Richtungen) eine Preiskorrektur ermögliche, wenn sich spürbare Änderungen in Bezug auf den Schutzrechtsbestand ergäben.[1631] Grundsätzlich zeigte sich das OLG anderen Mechanismen zur Berücksichtigung spürbarer Veränderungen in Bezug auf den Schutzrechtsbestand offen, sofern diese in gleicher Weise wie durch eine Anpassungsklausel kompensiert würden.[1632]

Daran anschließend führte das LG Düsseldorf in den Urteilen vom 9.11.2018 aus, die im Standardlizenzvertrag angebotene Lizenzhöhe erweise sich nicht als unangemessen, weil in dem Vertrag eine Anpassungsklausel nicht vorgesehen sei.[1633] Eine solche Anpassungsklausel werde zur Herbeiführung der FRAND-Gemäßheit eines sich auf einen Patentpool erstreckenden Angebots als adäquates Mittel erachtet, um ein mögliches Ungleichgewicht zwischen der festgeschriebenen Lizenzgebühr und dem variablen Schutzgegenstand in dem Fall auszugleichen, in dem sich der Bestand des Pools verändere, beispielsweise durch Ablauf der Schutzdauer von Poolpatenten oder rechtskräftiger Vernichtung derselben.[1634] Es sei jedoch auch möglich, eine in der Variabilität des Schutzrechtsbestands angelegte unangemessene Höhe der Lizenzgebühren auch durch andere Mechanismen zu kompensieren.[1635]

Auch das LG Mannheim rügte das Fehlen einer Anpassungsklausel insofern, als es eine Beurteilung des Angebots als fair und angemessen nicht zulassen würde, wenn zwischen den Parteien Einigkeit bestehe, dass es für die Verpflichtung zur Zahlung der vollen Lizenzgebühr genüge, wenn nur eines der

[1628] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 285; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 273.

[1629] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 285; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 273.

[1630] Dazu auch *Peter Georg Picht*, Post-Signing Adjustment Of SEP/FRAND Licenses, les Nouvelles June 2018, 99–108.

[1631] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

[1632] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

[1633] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 510; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 433.

[1634] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 511; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 434, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

[1635] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 511; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 434, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Portfoliopatente rechtsbeständig sei und benutzt werde.[1636] Damit werde in unangemessener Weise der Patentbenutzerin das Risiko der Rechtsbeständigkeit der Patente auferlegt.[1637]

ii) Anpassungsklausel bei Ablauf der Schutzdauer

Mit Blick auf den Ablauf von Patenten hielt das OLG Düsseldorf vom 17.11.2016 fest, es dürfte insoweit eine Anpassungsklausel erforderlich sein.[1638] Sofern der Patentinhaber keine derartige Klausel in sein Angebot aufnehme, müsse er näher begründen, warum dies nicht erforderlich sei.[1639] Es dürfte allerdings dann FRAND-gemäß sein für den Ablauf einzelner Patente bzw. Patentfamilien keine Anpassungsklausel vorzusehen, wenn dies in der Branche üblich sei, der angebotene Lizenzvertrag auf einen kurzen Zeitraum befristet sei und die Höhe der Lizenzgebühr auf die gesamte Vertragsdauer betrachtet deshalb FRAND-gemäß sei, weil sie den Ablauf von Patenten währen der Vertragslaufzeit angemessen berücksichtige.[1640]

iii) Einer Anpassungsklausel gleichwertige, andere Mechanismen

Bereits das OLG Düsseldorf im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 implizierte, dass wenn hinreichend belegt werde, dass durch andere Mechanismen spürbare Veränderungen in Bezug auf den Schutzrechtsbestand in gleicher Weise wie durch eine Anpassungsklausel kompensiert würden, das Angebot wohl als FRAND anzusehen wäre.[1641] Betreffend eine zeitliche Befristung der Gültigkeit des Lizenzvertrags auf drei Jahre sei durch die Klägerin in diesem Zusammenhang nicht hinreichend dargetan, dass diese Vertragsgestaltung eine Anpassungsklausel entbehrlich mache.[1642]

Sofern die Klägerin keine derartige Klausel in ihr Angebot aufnehme, müsse sie näher begründen, warum dies nicht erforderlich sei.[1643] Es dürfte allenfalls dann FRAND-gemäß sein, für den Ablauf einzelner Patente bzw. Patentfamilien keine Anpassungsklausel vorzusehen, wenn dies in der Branche üblich sei, der Lizenzvertrag nur auf einen kurzen Zeitraum befristet sei und die Höhe der Lizenzgebühr auf die gesamte Vertragsdauer betrachtet deshalb FRAND-gemäß sei, weil sie den Ablauf von Patenten während der Vertragslaufzeit angemessen berücksichtige.[1644]

In den Entscheiden vom 9.11.2018 befand das LG Düsseldorf auch die Lizenzhöhe eines Vertrages, der keine Anpassungsklausel vorgesehen hatte, als nicht unangemessen.[1645] Eine solche Anpassungsklausel werde zur Herbeiführung der FRAND-Gemäßheit eines sich auf einen Patentpool erstreckenden Angebots als adäquates Mittel erachtet, um ein mögliches Ungleichgewicht zwischen der festgeschriebenen Lizenzgebühr und dem variablen Schutzgegenstand in dem Fall auszugleichen, in dem sich der Bestand des Pool verändere, beispielsweise durch Ablauf der Schutzdauer von Poolpatenten oder rechtskräftiger Vernichtung derselben.[1646] Es sei jedoch auch möglich, eine in der Variabilität des Schutzrechtsbestandes angelegte Unangemessene Höhe der Lizenzgebühren auch

[1636] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 115.

[1637] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 115, mit Verweis auf LG Mannheim, 23.5.2017 – 2 O 98/16.

[1638] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 43.

[1639] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 43.

[1640] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 43.

[1641] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

[1642] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

[1643] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 43.

[1644] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 43.

[1645] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 510; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 433.

[1646] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 511; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 434, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

durch andere Mechanismen zu kompensieren.[1647] So sei es vorliegend, wenn die Vertragsklausel die Lizenzgebühren unabhängig von der Anzahl der Poolpatente festschreibe.[1648] Konkret sehe die Vertragsklausel vor, dass die Lizenzgebühren nicht deshalb steigen oder fallen sollten, weil die Anzahl der lizensierten Portfoliopatente steige oder falle oder weil die Preise der lizenzierten Produkte steige oder falle.[1649] Der Klausel wohne inne, dass der Lizenzgeber das Risiko des Anstiegs der Poolpatente und der Lizenznehmer das Risiko einer Minimierung derselben übernehme.[1650] Die Klausel trage der zeitlichen Entwicklung des Patentpools Rechnung, wonach insbesondere am Anfang und am Ende der Laufzeit eine geringere Anzahl von Patenten zu erwarten sei, während im Übrigen eine größere Patentanzahl in den Pool eingelagert sei.[1651] Dass es sich dabei um einen interessengerechten Kompensationsmechanismus handele, finde zum einen darin Ausdruck, dass der Standardlizenzvertrag in dieser Form von den Lizenznehmern angenommen worden sei, zum andere darin, dass sich das damit verteilte Risiko bisher nur hinsichtlich des Lizenzgebers realisiert habe.[1652] Denn die Lizenzgebühren seien seit Aufnahme des Pools im Jahre 2004 nicht angehoben worden, obwohl die Anzahl der Patente von anfänglich 41 auf nunmehr über 5000 Patente angestiegen sei.[1653]

Betreffend den gleichen Standard hielt auch das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 fest, die im Standardlizenzvertrag angebotene Lizenzhöhe erweise sich nicht deshalb als unangemessen, weil keine Anpassungsklausel vorgesehen sei.[1654] Der Standardlizenzvertrag schreibe den Preis gerade unabhängig vom Anstieg und Fallen der Anzahl der lizensierten AVC-Portfoliopatente fest.[1655] Im Tatsächlichen hätten sich die Lizenzgebühren trotz wachsendem Poolportfolios von aktuell über 5000 Patenten bislang nicht zuungunsten der Lizenznehmer verändert, lediglich die Kappungsgrenze nach oben sei in unregelmäßigen Jahresabständen hochgesetzt worden.[1656] Sofern die Beklagte anführe, dass sich die Nicht-Essenzialitätsrate verändert habe, sei dies zu einen nicht substantiiert genug belegt und zum anderen habe die Veränderung noch keinen Grad angenommen, der die Lizenz als unangemessen erscheinen lasse.[1657] Im Hinblick auf den wirtschaftlichen Wert des Standards sei nicht ersichtlich, dass seine Bedeutung so dermaßen abgenommen hätte, dass eine Lizenzreduktion angezeigt sei.[1658] So behaupte die Beklagte auch nicht, dass die streitgegenständliche Technologie vollständig vom Nachfolgestandard abgelöst worden sei.[1659]

Abgesehen davon halte der vorliegende Standardlizenzvertrag für solche sich verändernden Umstände weitere Anpassungsmöglichkeiten bereit, wie ein ordentliches Kündigungsrecht innerhalb einer Frist von 30 Tagen und andernfalls eine Laufzeit von 5 Jahren, wobei die automatische Verlängerung seitens der Lizenzverwalterin unter die Bedingung gestellt werden könne, dass angemessene Vertragsänderungen vorgenommen werden könnten.[1660] Veränderungen könnten vorherrschende Marktbedingungen, Änderungen im Technologieumfeld und die verfügbaren handelsüblichen

[1647] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 511; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 434, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 32.

[1648] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 512–15; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 435–38.

[1649] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 514; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 437.

[1650] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 515; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 438.

[1651] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 515; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 438.

[1652] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 516; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 439.

[1653] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 516; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 439.

[1654] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 350; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 289.

[1655] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 352; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 291.

[1656] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 352; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 291.

[1657] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 352; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 291.

[1658] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 352; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 291.

[1659] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 352; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 291.

[1660] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 353; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 292.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Produkte berücksichtigen.[1661] Es sei nicht ersichtlich, dass sich die Lizenzverwalterin einer Kündigung verschließe, wenn die Lizenznehmer den einseitigen Vertragsänderungen der Lizenzverwalterin widersprächen, wobei sich auch nichts anderes aus den vorgelegten Verlängerungsmitteilungen ergebe, die standardisiert an alle Lizenznehmer versenden seien worden und Vertragsänderungen beinhalteten.[1662] Insofern sei gewährleistet, dass der Standardlizenzvertrag die Schutzrechtslage zeitgemäß und wirklichkeitsgetreu abbilde.[1663] Schließlich sei auch der jedenfalls tausendfache Abschluss des Vertrages ein Indiz dafür, dass die vorhandene Kompensation als branchenüblich anzusehen sei.[1664]

iv) Veränderung des Schutzrechtsbestands und Diskriminierungsverbot

Das OLG Düsseldorf vom 22.3.2019 führte betreffend Veränderungen im Schutzrechtsbestand und Diskriminierungsverbot aus, der Patentinhaber müsse sich notwendigerweise Gedanken darüber machen, wie er sich diskriminierungsfrei gegenüber einem Lizenzsucher verhalten wolle, wenn sich der zu lizenzierende Schutzrechtsbestand im Laufe der Zeit, z.B. durch Schutzrechtsabläufe oder Neuerteilungen, verändere oder sich die Wichtigkeit einzelner technischer Features für den Produktmarkt verschiebe.[1665] Zweckmäßigerweise geschehe dies in der Weise, dass die Lizenzierungspraxis einem vorher überdachten Lizenzierungskonzept folge, welches von vornherein überdenke, mit welchem sachgerechten „Lizenzgebührenrabatt“ solche Lizenzsucher bedacht werden sollten.[1666] Innerhalb eines solchen Lizenzierungskonzepts werde sich die Diskriminierungsfreiheit eines aktuellen Lizenzangebots vordringlich in Bezug auf diejenige Lizenznehmergruppe bestimmen, die sich in derselben Ausgangssituation befunden habe.[1667]

v) Weitere Bemerkungen

Der deutschen Rechtsprechung ist bezüglich der Notwendigkeit einer Anpassungsklausel wohl eine gewisse Gespaltenheit zu entnehmen, da einerseits vertreten wird, eine solche sei grundsätzlich erforderlich, während an anderem Ort wiederum davon ausgegangen wird, den Interessen des Lizenzgebers könnte auch durch „andere Mechanismen“ Rechnung getragen werden. Dabei wäre nach dem Grund für eine potenzielle Anpassung zu differenzieren.

Der Ablauf der Schutzdauer von Patenten, im Gegensatz zur Rechtsbeständigkeit, ist ein objektiv sicher eintretendes Ereignis – das Ausschließlichkeitsrecht ist insofern befristet – und kann daher von beiden Vertragsparteien aufgrund der festen Laufdauer der Patente basierend auf der gleichen Informationsbasis bewertet und bei der kommerziellen Beurteilung berücksichtigt werden. Hingegen ist die Risikobeurteilung für nachträgliche Änderungen des Schutzrechtsbestandes, also der potentiellen Vernichtung des Schutzrechts, aufgrund der Informationsasymmetrie betreffend die Qualität des Patents und laufenden oder sich anbahnenden Nichtigkeitsverfahren zugunsten des Patentinhabers in einem Ungleichgewicht, sofern diese von der in der betreffenden Branche allgemein üblichen Nichtigkeitsrate abweichend ist. Dadurch ist der Patentbenutzer bei der Beurteilung dieser schwer kalkulierbaren Risikofaktoren und deren angemessener preislichen Beurteilung im Rahmen des Lizenzverhandlungen strukturell benachteiligt gegenüber dem Patentinhaber, was eine Anpassungsklausel bei fehlender Vorhersehbarkeit der Veränderung verlangen könnte.

[1661] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 353; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 292.

[1662] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 353; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 292.

[1663] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 354; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 293.

[1664] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 354; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 293.

[1665] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers*.

[1666] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*

[1667] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 184 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

4) Diverse weitere Bestimmungen

Die Relevanz weiterer Bestimmungen im Lizenzvertragsangebot des SEP-Inhabers im Rahmen des Angemessenheitskriteriums beleuchtete das OLG Düsseldorf schemenhaft im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016.

So könne unter dem Gesichtspunkt „fair und angemessen" eine vertragliche Regelung in Erwägung gezogen werden, die gewährleiste, dass der Patentbenutzer in Falle weiterer berechtigter Lizenzforderungen anderer Inhaber standardgebundener Schutzrechte nicht übermäßig belastet werde (zur Unangemessenheit infolge zu hoher Gesamtbelastung bereits oben XI.B.2.b)).[1668] Sofern auf eine solche Klausel verzichtet werde, seien die Gründe dafür näher darzulegen.[1669]

Weiter begegne das Verlangen einer Bankgarantie für zukünftig fällig werdende Lizenzgebühren Bedenken.[1670] Ohne weitere Erläuterungen sei nicht ersichtlich, dass und warum eine solche Klausel FRAND-gemäß sei.[1671]

3. Diskriminierungsfreier Inhalt (ND)

a) Rahmen

Neben dem Angemessenheitsgebot haben sich die deutschen Gereichte ausführlich mit dem ND-Prong von FRAND auseinandergesetzt. Zuerst soll der von der Rechtsprechung aufgestellte allgemeine Rahmen für das Diskriminierungsverbot beleuchtet werden, bevor die spezifischen Gleichbehandlungsanforderungen thematisiert werden.

Das OLG Düsseldorf hielt im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 allgemein fest, „nicht-diskriminierend" heiße im Rahmen von FRAND, dass der Patentinhaber den Lizenzwilligen im Vergleich zu anderen Lizenznehmern gleichbehandele, mithin eine Lizenz zu vergleichbaren Konditionen anbiete, oder im Falle einer Ungleichbehandlung dafür triftige Gründe vorlägen, die nachvollziehbar darzulegen seien.[1672]

Weiter hielt das OLG im Beschluss vom 30.3.2017 allgemein fest, es sei nach Art. 102 Abs. 2c AEUV einem marktbeherrschenden Unternehmen verboten, unterschiedliche Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber seinen Handelspartnern anzuwenden, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt würden.[1673] Zweck dieser Regelung sei es, zu verhindern, dass marktbeherrschende Unternehmen durch wettbewerblich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlungen ihrer Handelspartner Eingriffe in die Marktstrukturen vor- oder nachgelagerter Marktstufen vornehmen würden, die Wettbewerbsverfälschungen hervorrufen würden, indem einzelne Handelspartner benachteiligt würden.[1674] Das Diskriminierungsverbot normiere für das marktbeherrschende Unternehmen eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem er Handelspartnern, die sich in gleicher Lage befänden, dieselben Preise und Geschäftsbedingungen einräumen müsse.[1675] Das Gleichbehandlungsgebot erstrecke sich dabei allerdings nur auf Sachverhalte, die vergleichbar seien; eine Rechtspflicht zu schematischer Gleichbehandlung aller Handelspartner bestehe nicht.[1676] Vielmehr sei es auch dem marktbeherrschenden Unternehmen nicht

[1668] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 44.
[1669] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 44.
[1670] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 45.
[1671] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 45.
[1672] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 15.
[1673] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 207 – *Mobiles Kommunikationssystem*.
[1674] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 207 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1675] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1676] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

verwehrt, auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert zu reagieren.[1677] Eine Ungleichbehandlung sei daher zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt sei.[1678]

Dabei würde bei gewerblichen Schutzrechten grundsätzlich ein weiter Spielraum für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung gelten, weil eine Differenzierung bei der Gestaltung der Benutzung ein wesentliches Element der Ausschließungswirkung des Rechts selbst sei.[1679] Dies gelte auch, wenn der Patentinhaber marktbeherrschend sei, weil das Patent im Interesse der Technologieförderung gerade auch das in einer Erfindung verkörperte Potential schütze, die formale Ausschließlichkeitsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu können.[1680] Höhere Anforderungen an die sachliche Rechtfertigung der Ungleichbehandlung gälten, wenn neben der marktbeherrschenden Stellung zusätzliche Umstände hinzutreten würden, die dazu führten, dass die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährde.[1681] Diese Voraussetzung sei erfüllt, wenn der Zugang zu einem nachgeordneten Produktmarkt von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig sei (unter Verweis auf BGH, 13.7.2004 – KZR 40/02 – *Standard-Spundfass* m.w.N.) oder wenn – wie in der vorliegenden FRAND-Konstellation – das Produkt erst bei Benutzung des Patents wettbewerbsfähig sei.[1682] Ob eine Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt sei, bestimme sich in diesem Fall anhand einer Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Interessen, die sich am Zweck des AEUV orientiere, zur Entwicklung eines wirksamen, unverfälschten Wettbewerbs beizutragen (ausführlich zur sachlichen Rechtfertigung unten XI.B.3.b)3)).[1683]

Diese Rechtsprechung zum Diskriminierungsverbot dürfte bei dem Düsseldorfer Oberlandesgericht und Landgericht als gefestigt gelten, und wurde insbesondere in einer Vielzahl von Verfahren durch das LG bestätigt und angewendet (dazu ausführlich unten).[1684]

Darüber hinaus äußerte sich das OLG am 22.3.2019 zur Weichreite des Diskriminierungsverbots, und vertrat eine enge Bindung des SEP-Inhabers. Mit dem allerersten Lizenzgeschäft müsse sich der SEP-Inhaber für ein bestimmtes Lizenzierungskonzept entscheiden, dass ihn und seine Rechtsnachfolger im Weiteren rechtlich binde, weil ein Abrücken von dem einmal praktizierten Modell nur dann und nur in dem Umfang möglich sei, wie sich daraus keine unzulässige Diskriminierung bzw. Schlechterbehandlung der späteren oder früheren Lizenznehmer ergebe.[1685] Bei der Erstvergabe stehe mithin das Gebot, „fair“ und „reasonable“ zu lizenzieren im Vordergrund, während sich die Frage nach einer Diskriminierung (im Vergleich zu was auch?) mangels Vorliegens eines Referenzvertrages nicht stelle.[1686] Trügen die bei der Erstvergabe gewählten Lizenzbedingungen den Anforderungen an einen ausbeutungsfreien Inhalt Rechnung, rücke für alle weiteren Lizenzierungen das

[1677] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1678] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 19.3.1996 – KZR 1/95 – *Pay-TV-Durchleitung* (zu § 19 GWB); 12.4.2016 – KZR 30/15 – *NetCologne* (zu § 20 GWB).

[1679] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1680] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1681] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1682] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1683] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 210 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 13.7.2004 – KZR 40/02 – *Standard-Spundfass*; 12.4.2016 – KZR 30/15 – *NetCologne*.

[1684] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 325; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 291; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 264; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 279; 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 296; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 278; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 375; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 297; 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 195; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 209; 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 354 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16; Rn. 305 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 353; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 306.

[1685] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers*.

[1686] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Diskriminierungsverbot in den Mittelpunkt der Betrachtung.[1687] Es verbiete und verhindere, dass – sofern keine dementsprechend unterschiedlichen Lizenzierungssachverhalte gegeben seien – von dem durch die Erstlizenzierung festgeschriebenen Lizenzniveau nach oben oder unten in wettbewerbsrelevanter Weise abgewichen werde, und umreiße damit ganz maßgeblich denjenigen Verhandlungsspielraum, der dem SEP-Inhaber bei nachfolgenden Lizenzverhandlungen noch verbleibe.[1688] Das Verbot sachlich nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung gelte dabei ohne jede Ausnahme und folglich auch dann, wenn bei der Erstlizenzierung der an sich mögliche FRAND-Gebührenrahmen – ggf. sogar deutlich – nicht ausgeschöpft worden sei und die später geänderte Lizenzierungspraxis darauf abziele, die Lizenzvergütung (was anfänglich möglich gewesen wäre) in den oberen Bereich des unter Ausbeutungsgesichtspunkten rechtlich Zulässigen zu führen.[1689] Denn das rein subjektive Verhandlungsversagen oder bewusste Nachgeben des SEP-Inhabers bei der Erstlizenzierung könne nicht als Sachgrund dafür anerkannt werden, dass spätere Lizenzsucher sich im Wettbewerb mit finanziell schlechteren Benutzungsbedingungen abfinden müssten.[1690]

Allenfalls beachtlich wären zwingende wirtschaftliche Gründe für eine Anhebung der Lizenzvergütung, wobei erforderlich wäre, dass sämtliche Lizenzverträge gleichermaßen entsprechend abgeändert würden.[1691] Dies wiederum setze voraus, dass die bestehenden, günstigen Verträge entsprechende Öffnungsklauseln enthielten bzw. gesetzliche Möglichkeiten für eine nachträgliche Änderung der Lizenzgebühren (z.B. wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage) beständen und der Lizenzgeber von ihnen tatsächlich Gebrauch mache.[1692] Zur Zulässigkeit einer Änderungskündigung der bestehenden Lizenzverträge siehe oben XI.A.6.

Auch wenn es für die Gleich- oder Ungleichbehandlung der Lizenznehmer auf eine rein wettbewerblich-wirtschaftliche Betrachtungsweise ankomme, bedeute das Diskriminierungsverbot vielfach dennoch, dass das anfänglich präferierte Lizenzmodell nachträglich nicht mehr zugunsten eines anderen umgestellt werden könne.[1693] Denn mit dem Berechnungskonzept würden sich die grundlegenden Regeln der Vergütungsbestimmung ändern, womit im Zweifel unabsehbar werde, ob das andere Vergütungsmodell – was hinzunehmen wäre – zu einer bloß marginalen oder – was unter Diskriminierungsgesichtspunkten zu beanstanden wäre – zu einer weitreichenderen, weil mehr als nur unerheblichen Begünstigung/Verschlechterung in den Lasten der neuen Lizenznehmer führe.[1694]

Die Gleichbehandlung muss einerseits bei der Lizenzgewährung stattfinden (dazu sogleich), und andererseits bei der Rechtsdurchsetzung (dazu unten XI.B.3.c)). Zur Weitergeltung des Diskriminierungsverbots bei Übertragung des SEP(-Portfolios), vgl. oben VII; zur Darlegungs- und Substantiierungslast vgl. oben XI.B.1.c)1).

b) Gleichbehandlung betreffend Lizenzbedingungen

Das Diskriminierungsverbot verlangt eine Gleichbehandlung vergleichbarer Lizenzsucher bei den im Angebot des SEP-Inhabers vorgeschlagenen Lizenzbedingungen.

Diesbezüglich hielt das OLG Düsseldorf in seinem Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 fest, "nicht-diskriminierend" heiße, dass der Patentinhaber den Lizenzwilligen im Vergleich zu anderen Lizenznehmern gleichbehandele, mithin eine Lizenz zu vergleichbaren Konditionen anbiete, oder im

[1687] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers*.
[1688] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers*.
[1689] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers*.
[1690] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 313 – *Improving Handovers*.
[1691] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 314 – *Improving Handovers*.
[1692] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 314 – *Improving Handovers*.
[1693] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 316 – *Improving Handovers*.
[1694] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 316 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Falle einer Ungleichbehandlung dafür triftige Gründe vorlägen, die nachvollziehbar dazulegen seien.[1695]

1) Gesamtbetrachtung von Vergleichbarkeit, Ungleichbehandlung und sachlicher Rechtfertigung

Das OLG Düsseldorf vom 30.3.2017 hielt fest, das Diskriminierungsverbot normiere für das marktbeherrschende Unternehmen eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem es Handelspartnern, die sich in der gleichen Lage befänden, dieselben Preise und Geschäftsbedingungen einräumen müsse.[1696] Das Gleichbehandlungsgebot erstrecke sich dabei allerdings nur auf Sachverhalte, die vergleichbar seien.[1697] Eine Rechtspflicht zur schematischen Gleichbehandlung aller Handelspartner bestehe nicht.[1698] Vielmehr sei es auch dem marktbeherrschenden Unternehmen nicht verwehrt, auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert zu reagieren.[1699] Eine Ungleichbehandlung sei daher zulässig, wenn sich sachlich gerechtfertigt sei (dazu unten XI.B.3.b)3)).[1700] Bei gewerblichen Schutzrechten bestehe grundsätzlich ein weiter Spielraum für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung, weil eine Differenzierung bei der Gestaltung der Benutzung ein wesentliches Element der Ausschließungswirkung des Rechts selbst sei.[1701] Dies gelte auch, wenn der Patentinhaber marktbeherrschend sei, weil das Patent im Interesse der Technologieförderung gerade auch das in einer Erfindung verkörperte Potential schütze, die formale Ausschließlichkeitsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu können.[1702] Höhe Anforderungen an die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung würden jedoch gelten, wenn neben der marktbeherrschenden Stellung zusätzliche Umstände hinzutreten würden, die dazu führten, dass die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährde.[1703] Diese Voraussetzung sei erfüllt, wenn der Zugang zu einem nachgeordneten Produktmarkt von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig sei (unter Verweis auf BGH, 13.7.2004 – KZR 40/02 – *Standard-Spundfass* m.w.N.) oder wenn – wie in der vorliegenden FRAND-Konstellation – das Produkt erst bei Benutzung des Patents wettbewerbsfähig sei.[1704]

Ob eine Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt sei, bestimmte sich in diesem Fall anhand einer Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Interessen, die sich am Zweck des AEUV orientiere, zur Entwicklung eines wirksamen, unverfälschten Wettbewerbs beizutragen.[1705] Maßgebend seien dabei Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung.[1706] Deren Zulässigkeit richte sich insbesondere danach, ob die relative Schlechterbehandlung der betroffenen Unternehmen als wettbewerbskonformer, durch das jeweilige Angebot im Einzelfall bestimmter Interessenausgleich erscheine oder auf Willkür oder Überlegungen und Absichten beruhe, die wirtschaftlich oder

---

[1695] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 15.

[1696] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1697] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1698] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1699] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1700] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 208 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 19.3.1996 – KZR 1/95 – *Pay-TV-Durchleitung* (zu § 19 GWB); 12.4.2016 – KZR 30/15 – *NetCologne* (zu § 20 GWB).

[1701] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1702] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1703] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1704] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 209 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1705] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 210 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 13.7.2004 – KZR 40/02 – *Standard-Spundfass*; 12.4.2016 – KZR 30/15 – *NetCologne* zu §§ 19, 20 GWB.

[1706] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 210 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

unternehmerisch vernünftigem Handeln fremd seien.[1707] Angesichts des dem Patentinhaber insoweit zustehenden erheblichen Beurteilungsspielraums sei nicht bereits jeder Unterschied in den Konditionen als Ausdruck einer missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung anzusehen.[1708] Der Unterschied müsse vielmehr mehr als nur unerheblich sein, um einen mit einem Unwerturteil verbundenen Missbrauch zu bejahen.[1709] Daneben sei allerdings im Auge zu behalten, dass die durch die Ungleichbehandlung betroffenen Unternehmen nicht durch die Ausübung der Macht des marktbeherrschenden Unternehmens in ihrer Wettbewerbsfähigkeit untereinander beeinträchtigt werden sollten.[1710] Die vorstehenden Grundsätze gälten gleichermaßen in Bezug auf einen SEP-Inhaber, der eine FRAND-Erklärung abgegeben habe.[1711] Ungeachtet der Frage, ob diese Erklärung konstitutiver oder deklaratorischer Natur sei und die aus ihr resultierenden Verpflichtungen des Patentinhabers auch dann greifen würden, wenn er keine marktbeherrschende Stellung besitze, folge aus ihr jedenfalls kein abweichender Maßstab beim Diskriminierungsverbot.[1712] Der SEP-Inhaber nehme mit der darin enthaltenen Zusage, Lizenzsucher nicht zu diskriminieren, vielmehr auf Art. 102 c) AEUV Bezug und wolle sich im Hinblick auf die Lizenzbedingungen erkennbar (lediglich) exakt in dem Umfang binden, wie das gesetzliche Verbot der Ungleichbehandlung es von ihm verlange.[1713] Dementsprechend sei sein Lizenzangebot und dann „nicht-diskriminierend", wenn er den Lizenzsucher im Vergleich zu anderen Lizenznehmern gleich behandele oder wenn im Falle einer Ungleichbehandlung dafür triftige sachliche Gründe vorlägen.[1714]

Vorliegend diskriminieren der Lizenzvertrag der Klägerin mit einer anderen Lizenznehmerin die Beklagten nach diesen Grundsätzen, da sie im Vergleich erheblich unterschiedlich behandelt würden.[1715] Die Klägerin habe diesem Unternehmen weit bessere Konditionen gewährt als sie den Beklagten anbiete, und die exorbitante Ungleichbehandlung sachlich nicht hinreichend gerechtfertigt.[1716]

Davon ausgehend könne dahinstehen, ob die Beklagten darüber hinaus auch durch den Inhalt der Lizenzverträge A bis C (mit weiteren Lizenznehmern) diskriminiert würden.[1717] Entgegen der Ansicht der Klägerin folge aus den vorstehend dargelegten Grundsätzen nicht, dass einzelne „Ausreißer" generell noch nicht zu einer sachwidrigen Ungleichbehandlung führten.[1718] Richtig sei zwar, dass es keine allgemeine Verpflichtung zur Meistbegünstigung gebe, die das marktbeherrschende Unternehmen generell zwinge, allen die gleichen günstigen Bedingungen einzuräumen.[1719] Das Recht auch des marktbeherrschenden Unternehmens, auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert zu reagieren, stehe jedoch insoweit ebenfalls unter dem Vorbehalt der sachlichen Rechtfertigung der

[1707] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 210 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 13.7.2004 – KZR 40/02 – *Standard-Spundfass*; 12.4.2016 – KZR 30/15 – *NetCologne.*

[1708] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 210 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1709] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 210 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 12.4.2016 – KZR 30/15 – *NetCologne.*

[1710] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 210 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BBGH, 13.7.2004 – KZR 40/02 – *Standard-Spundfass.*

[1711] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 211 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1712] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 211 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 19.1.2016 – 4b O 123/14.

[1713] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 211 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1714] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 211 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1715] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 214 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1716] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 214 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1717] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1718] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1719] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Ungleichbehandlung.[1720] Nur in diesem Rahmen könne daher auch die Durchsetzbarkeit unterschiedlicher Konditionen gegenüber verschiedenen Handelspartnern ein triftiger Grund sein.[1721] Ergebe sich dabei, dass eine Differenzierung als solche grundsätzlich zulässig sei, beurteile sich die sachliche Rechtfertigung sodann wiederum nach Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung.[1722] Stelle sich heraus, dass ein relevanter Wettbewerber unsachlich bevorzugt werde, so sei dies bereits als relevante Diskriminierung der übrigen Unternehmen auf dem Markt zu bewerten.[1723]

Nach Betrachtung der im dem OLG Düsseldorf vorliegenden Fall von der Klägerin vorgebrachten Rechtfertigungsgründe ergebe sich im Rahmen der notwendigen Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des AEUV, dass das Lizenzangebot der Klägerin die Beklagte gegenüber der bevorzugten Lizenznehmerin diskriminiere.[1724] Im Hinblick auf das Ausmaß der exorbitant großen Ungleichbehandlung habe die Klägerin keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine sachliche Rechtfertigung angeführt.[1725] Soweit eine Sonderstellung der bevorzugten Lizenznehmerin als Referenzkunde auf dem spezifischen Markt, die spezifische Risikoverteilung im dortigen Lizenzvertrag und die unterschiedliche prozessuale Situation prinzipiell sachliche Gründe darstellen könnten, sei dies jedenfalls im Hinblick auf die extrem unterschiedlich hohen Lizenzgebühren nicht mehr der Fall.[1726] Dies gelte sowohl für jeden einzelnen der genannten Aspekte als auch bei der gebotenen Gesamtbetrachtung. Aus den Ausführungen zu den einzelnen sachlichen Gründen ergebe sich, dass jeder dieser Gründe für sich betrachtet allenfalls geringe Bedeutung besitze.[1727] Infolgedessen hätten sie auch gemeinsam kein Gewicht, dass die Unterschiede bei den Lizenzsätzen und die daraus resultierende Mehrbelastung der Beklagten um bis zu zehn Mal höheren Lizenzgebühren rechtfertige.[1728]

Das gelte umso mehr, als es sich bei der bevorzugten Lizenznehmerin weltweit um einen unmittelbaren Wettbewerber des Konzerns, dem die Beklagte angehöre, handele, der jährlich mehrere Millionen Mobilfunkgeräte absetzt.[1729] Die Ungleichbehandlung sei aufgrund dieser erheblichen Bedeutung der bevorzugten Lizenznehmerin auf dem Markt geeignet, die Marktposition der Beklagten tatsächlich zu verschlechtern, indem im Falle eines Lizenzvertragsabschlusses auf Basis des Angebots der Klägerin die exorbitanten Unterschiede bei den Lizenzgebühren dazu führen könnten, dass die bevorzugte Lizenznehmerin in der Lage sei, die Mobilfunkgeräte günstiger anzubieten als die Beklagte und letztere dadurch Wettbewerbsnachteile erleiden würde.[1730]

Das LG Düsseldorf führte betreffend Diskriminierung aus, Art. 102 AEUV könne eine allgemeine Verpflichtung zur Meistbegünstigung nicht entnommen werden.[1731] Danach sei auch ein

---

[1720] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 12.4.2016 – KZR 30/15 – *NetCologne*.

[1721] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1722] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 19.3.1996 – KZR 1/95 – *Pay-TV-Durchleitung*.

[1723] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 19.3.1996 – KZR 1/95 – *Pay-TV-Durchleitung.*

[1724] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 258 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1725] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 258 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1726] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 259 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1727] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 259 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1728] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 259 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1729] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 260 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1730] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 260 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1731] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 343; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 282; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425, letztere mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 23.3.2011 – 6 U 66/19, Rn. 166 – *FRAND Grundsätze*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

marktbeherrschendes Unternehmen nicht gezwungen, allen die gleichen – günstigen – Marktbedingungen, insbesondere Preise zu gewähren.[1732] Ihm könne nicht verwehrt werden, auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert zu reagieren.[1733] Eine unzulässige Diskriminierung ergebe sich deshalb schon nicht daraus, dass mit der Marktgegenseite abgeschlossene Verträge nicht in jedem Fall zu einem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis führten.[1734] Maßgeblich für die Frage der Diskriminierung sei vielmehr, ob eine unterschiedliche Gestaltung der Konditionen auf Willkür oder sachfremden Erwägungen beruhe.[1735] Entscheidend seien Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung, sowie ob sich eine relative Schlechterstellung eines Unternehmens gegenüber einem anderen als wettbewerbskonformer Interessenausgleich oder auf Willkür/auf sachfremden Erwägungen beruhend darstelle.[1736]

2) Insbesondere Vergleichbarkeit und Ungleichbehandlung

Das OLG Düsseldorf stellte eine Ungleichbehandlung fest, da die der Beklagten angebotenen Lizenzgebühren exorbitant höher seien als die im Lizenzvertrag mit einem anderen Lizenznehmer vereinbarten, so dass eine deutlich mehr als unerhebliche Ungleichbehandlung vorliege.[1737] Im Verhältnis zum sogenannten Standardlizenzvertrag, den die Klägerin auf ihrer Internetseite veröffentliche, sehe ihr Lizenzangebot für den Mutterkonzern der Beklagten weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft einen Rabatt vor.[1738] Der Lizenzvertrag mit einem der anderen Lizenznehmer sehe eine (wohl pauschale) Lizenzgebühr vor, der eine Rabattierung für Vergangenheit und Zukunft gegenüber den Standardlizenzvertrag gleichkomme.[1739] Tatsächlich sei (aufgrund im Urteil geschwärzter Ausführungen) davon auszugehen, dass der Rabatt für die Vergangenheit sogar noch deutlich größer sei.[1740] Anders ausgedrückt müsse die Beklagte im Falle der Annahme des Lizenzangebots im Vergleich zu einem der anderen Lizenznehmer mehr als zehn Mal höhere Lizenzgebühren für die Vergangenheit und etwa fünf Mal höhere Lizenzgebühren für die Zukunft entrichten.[1741]

Im Rahmen der Gesamtbetrachtung (dazu oben XI.B.3.b)1)) prüfte das OLG die Vergleichbarkeit anhand verschiedener Faktoren, die es im Hinblick auf den vorgebrachten sachlichen Rechtfertigungsgrund für die Ungleichbehandlung als aussagekräftig zu erachten scheint. So hielt es fest, ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung sei umso weniger erkennbar, als die Klägerin keine markt- oder unternehmensbezogenen Aspekte aufgezeigt habe, welche eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.[1742] Im Gegenteil seien die Beklagte und die bevorzugte

[1732] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425, beide mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 23.3.2011 – 6 U 66/19, Rn. 166 – *FRAND Grundsätze*.

[1733] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 343; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 282; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425, letztere mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 23.3.2011 – 6 U 66/19, Rn. 166 – *FRAND Grundsätze*.

[1734] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 343; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 282; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425, letztere mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 23.3.2011 – 6 U 66/19, Rn. 166 – *FRAND Grundsätze*.

[1735] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425.

[1736] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425, beide mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 23.3.2011 – 6 U 66/19, Rn. 166 – *FRAND Grundsätze*.

[1737] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 216 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1738] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 217 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1739] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 218 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1740] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 219 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1741] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 219 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1742] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenznehmerin Handelspartner der Klägerin, die sich in einer vergleichbaren Lage befänden.[1743] Beide würden drahtlose Mobilfunkgeräte anbieten, die sie über Händler an Endverbraucher verkaufen würden, so dass sie in derselben Wirtschaftsstufe auf demselben nachgelagerten Produktmarkt tätig seien.[1744] Darüber hinaus seien beide Unternehmen deswegen sehr ähnlich, weil sowohl die bevorzugte Lizenznehmerin als auch der Mutterkonzern der Beklagten in Europa vorrangig im Niedrigpreissektor agierten.[1745] Vor allem aber sei der Mutterkonzern der Beklagten ebenso wie die bevorzugte Lizenznehmerin ein ressourcenstarkes Unternehmen aus demselben Land, das weltweit mit Milliardenumsatz operiere, und daher im Falle einer Lizenzierung ebenso ein Signal an den länderspezifischen Markt aussenden würde und andere Unternehmen in diesem Land zur Lizenznahme animieren könne.[1746]

Betreffend einer rechtlichen gegenüber einer tatsächlichen Ungleichbehandlung führte das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 aus, das Lizenzsystem des Patentpools tauge grundsätzlich als objektiver Anknüpfungspunkt für eine Rabattgewährung, da es eine Stücklizenzvorsehe, wodurch das Erreichen der vertraglichen Höchstgrenze der zu entrichtenden Jahresgebühr von der Verkaufskraft des jeweiligen Unternehmens abhänge.[1747] Doch nebst der sachlichen Rechtfertigung einer solchen Höchstgrenze als Ausdruck wettbewerblichen Handelns (dazu unten XI.B.3.b)3)i)), sei bei den im Standardlizenzvertrag enthaltenen Royalty Caps auch zu beachten, dass die Begrenzung nach der vertraglichen Konzeption jedem Lizenznehmer zu Gute komme, mithin „im Rechtlichen“ eine Ungleichbehandlung nicht vorliege.[1748] Der Einwand der Beklagten habe seinen Bezugspunkt vielmehr „im Tatsächlichen“.[1749] Dass die Höchstgrenze vorliegend aber gerade so bemessen sei, dass diese – was für sachfremde Erwägungen sprechen würde – faktisch nur auf ein bestimmtes Unternehmen bzw. eine geringe Anzahl von Unternehmen Anwendung finde, bringe die Beklagte nicht vor.[1750]

Sofern die Beklagte in diesem Zusammenhang einwende, dass die Höchstgrenze insbesondere Multiproduktanbieter gegenüber „reinen“ Smartphone-/Tablet-PC-Anbietern unzulässig begünstige, sei gegen diese Pauschalisierung nichts einzuwenden, denn Ausgangspunkt der Lizenzvergabe sei es gerade, das Anbieten und Vertreiben von (video-)standardfähigen Produkten zu ermöglichen.[1751] Auch die Beklagte habe die Kappungsgrenzen beispielsweise in den Jahren 2014 und 2016 die Kappungsgrenzen erreicht.[1752] Es bestehe kein struktureller Unterschied in den wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Multiproduktanbieters und denjenigen eines (ausschließlichen) Smartphoneanbieters, der die Kappungsgrenze ebenfalls erreiche.[1753] Dass es daneben auch Anbieter geben möge, die die Kappungsgrenzen nicht erreichen würden, knüpfe an betriebswirtschaftliche Sonderbedingungen einzelner Wettbewerber an, die bei der hiesigen Bewertung außer Betracht zu bleiben hätten.[1754] Abzustellen sei im Rahmen einer objektiven Betrachtungsweise vielmehr auf die auf dem jeweiligen Markt typischen Produktions- und Vertragsbedingungen.[1755]

[1743] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1744] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1745] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1746] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1747] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 504; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 426.

[1748] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 504–05; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 426–27.

[1749] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 505; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 427.

[1750] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 505; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 427.

[1751] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 506; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 428.

[1752] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 508; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 431.

[1753] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 508; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 431.

[1754] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 509; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 432.

[1755] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 509; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 432, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 11.9.2008 – 4b O 78/07. Rn. 141.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Schließlich hatte sich das Landgericht Düsseldorf in den Entscheiden vom 9.11.2018 damit auseinanderzusetzen, ob Ratenzahlung oder Anrechnungsvereinbarungen eine missbräuchliche Ungleichbehandlung darstellen.[1756] Jedoch stellten solche Regelungen bloß Zahlungsmodalitäten dar, die die nach dem Standardvertrag der Höhe nach zu entrichtenden Gebühren im Grundsatz nicht berührten.[1757] So werde die Möglichkeit zu Ratenzahlungen nach Erklärung der Klägerin jedem eingeräumt.[1758] Betreffend Anrechnungsvereinbarungen falle eine Ungleichbehandlung außer Betracht, weil es sich lediglich um eine Kompensation etwaiger von dem Lizenznehmer bereits erbrachter Leistungen handle und insofern ein sachlicher Rechtfertigungsgrund vorliege.[1759]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 führte das LG Düsseldorf betreffend die Kappungsgrenze im gleichen Standardlizenzvertrag aus, die Kappungsgrenze ab einer bestimmten gezahlten Lizenzhöhe ebenso wie eine Freilizenz für die ersten 100000 verkauften Einheiten sei unter dem Nicht-Diskriminierungsaspekt nicht bedenklich.[1760] Die mögliche Quersubventionierung bei Unternehmen, die standardkonforme Produkte aus verschiedenen Sparten der Elektronikbranche anböten und so durch ein diversifiziertes Produktsortiment schneller die Kappungsgrenze erreichen würden als Ein-Produkt Hersteller, sei weder Folge einer Ungleichbehandlung noch lasse sich die Klausel deswegen als unangemessen qualifizieren (dazu bereits oben XI.B.2.b)).[1761]

Es liege in casu auch keine Ungleichbehandlung von Ein-Produkt-Herstellern im Vergleich zu Multi-Produkt-Herstellern vor, da eine Ungleichbehandlung voraussetze, dass beide Herstellergruppen überhaupt vergleichbar seien.[1762] Dies sei vorliegend nicht der Fall, weil durch die Lizenzierung eines standardkonformen Produkts verschiedene nachgelagerte Produktmärkte erfasst würden, wobei die Produkte untereinander nicht substituierbar seien (Fernseher und Handy).[1763] Insofern biete die Klägerin allen Herstellern die gleichen Kappungsgrenzen an, eine Pflicht zur Differenzierung bestehe nicht.[1764] Sofern die Beklagte Multi-Produkt-Hersteller als Beispiel einer überproportionalen Begünstigung heranziehe, lasse sie zudem außer Acht, dass die Multi-Produkthersteller auch schneller den Bereich der lizenzfreien Herstellung der ersten 100000 Einheiten verlassen würden.[1765] Die festgesetzte Kappungsgrenze gelange ebenfalls für Ein-Produkt-Hersteller, deren Vertriebstätigkeit auf mobile Endgeräte beschränkt sei, zur Anwendung.[1766] Das Erreichen hoher Verkaufszahlen liege nicht allein in der Auswahl der Produkte, sondern sei auch auf das individuelle Geschäftsgebaren des jeweiligen Wettbewerbers zurückzuführen.[1767] So fuße der wirtschaftliche Erfolg eines Produktes auf zahlreichen Gründen, und spielten ein gutes Marketing und eine gute Markenpflege, ausgebaute Infrastrukturen und zuverlässige Vertriebsnetze eine Rolle.[1768] Diese ganzen Faktoren führten dazu, dass die streitgegenständliche Klausel letztlich keinen kartellrechtlichen Missbrauch darstelle und die

[1756] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 493; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 415.

[1757] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 412; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 351; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 493; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 415.

[1758] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 495; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 417.

[1759] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 412; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 351; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 494; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 416.

[1760] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 344; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 283.

[1761] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 345; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 284.

[1762] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 347; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 286.

[1763] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 347; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 286.

[1764] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 347; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 286.

[1765] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 347; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 286.

[1766] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 348; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 287.

[1767] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 348; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 287.

[1768] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 348; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 287.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Folge einer Quersubventionierung, die bei einem am Markt erfolgreichen Unternehmen auftreten könne, hinzunehmen sei.[1769]

Dazu, was in die Vergleichbarkeitsprüfung mit einbezogen werden müsse, führte das OLG Düsseldorf vom 22.3.2019 aus, für die Zukunft seien Lizenzverträte unter Diskriminierungsgesichtspunkten dann unbeachtlich, wenn und sobald sie wirksam gekündigt seien (zur Änderungskündigung bereits oben XI.A.6).[1770] Gerichtlich herbeigeführte Lizenzkonditionen stellten keinen Sachverhalt dar, der dem SEP-Inhaber als Diskriminierungsverhalten vorgeworfen werden könne, weil es insoweit an einer (freien) unternehmerischen Entscheidung fehle.[1771] Allerdings begründeten sie, wenn die gerichtlichen Vorgaben im Widerspruch zu einer vorherigen Lizenzierungspraxis ständen, auch keine Rechtfertigung dafür, sich mit nachfolgenden Lizenzierungen, die dem Urteilsspruch folgten, in Widerspruch zu setzen.[1772] Maßgeblich für den Diskriminierungsvorwurf bleibe vielmehr diejenige Lizenzierungspraxis, die der SEP-Inhaber und seine Rechtsvorgänger in freier unternehmerischer Verantwortung ins Werk gesetzt hätten, während die davon abweichenden, gerichtlich herbeigeführten Konditionen für sich betrachtet keinen Diskriminierungsvorwurf rechtfertigten, weil angesichts des gerichtlicher Klageverfahrens ein sachlicher Grund bestanden habe, sich auf die einzulassen.[1773]

Im Zusammenhang mit der Darlegungs- und Substantiierungslast des SEP-Inhabers (dazu oben XI.B.1.c)2)) führte das OLG weiter aus, die aktiven Vertragsinhalte, ob es weitere Lizenznehmer gebe und, wenn ja, welchem einheitlichen Lizenzierungskonzept (sofern es ein solches gebe) die Verträgen folgen würden, setzten den rechtlichen Maßstab für das den SEP-Inhaber treffende Verbot einer Diskriminierung bei der Lizenzvergabe.[1774] Seien über die Zeit voneinander abweichende Lizenzvertragsinhalte verabredet worden, so stelle sich die Frage nach einer unsachlichen und damit widerrechtlichen Ungleichbehandlung des konkreten Lizenzsuchers grundsätzlich im Verhältnis zu jedem einzelnen der divergierenden Lizenzverträge, es sei denn, ein bestimmter Vertrag sei schon wegen Ausbeutungsmissbrauchs unwirksam.[1775]

Zum Einrücken des SEP-Erwerbers in die Rechtsposition des Rechtsvorgängers bei der SEP-Übertragung und der damit einhergehenden Bindungswirkung im Rahmen des Diskriminierungsverbots siehe oben VII.

3) Insbesondere sachliche Rechtfertigung

Nachdem eine Ungleichbehandlung festgestellt wurde, muss diese sachlich gerechtfertigt werden, um dem Nicht-Diskriminierungsverbot gerecht zu werden. Im Folgenden sollen die Ausführungen der Gerichte zu verschiedenen hervorgebrachte Rechtfertigungsgründen aufgeführt werden. Generell dürfte sich die sachliche Rechtfertigung, so das OLG Düsseldorf, nach Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung beurteilen.[1776] Sämtliche Umstände seien in einer Gesamtwürdigung einzubeziehen (dazu bereits oben XI.B.3.b)1)).[1777] Als Maßstab verlangte das OLG, die Ungleichbehandlung müsse nachvollziehbar sein.[1778] Dabei bedürfe es Sachvortrag zum Angebot und

[1769] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 349; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 288.

[1770] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 314 – *Improving Handovers*.

[1771] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 315 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf BGH, 4.11.2003 – KZR 2/02 – *Depotkosmetik im Internet*; OLG Düsseldorf, 23.10.2013 – VI-U (Kart) 36/13 – *Frankiermaschinen II;* 14.3.2018 – VI-U (Kart) 7/16 – *Mitbenutzung von Kabelkanalanlagen*.

[1772] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 315 – *Improving Handovers.*

[1773] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 315 – *Improving Handovers.*

[1774] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*

[1775] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 318 – *Improving Handovers.*

[1776] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 215 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1777] Vgl. OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 229 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1778] Vgl. OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 250 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zu den Gründen, die die Patentinhaberin dazu bewogen hätten, unterschiedliche Konditionen anzubieten.[1779]

Das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 führte zu den Anforderungen an die sachliche Rechtfertigung unter Berufung auf die Rechtsprechung zur Gesamtwürdigung des OLG Karlsruhe aus (ausführlich oben XI.B.3.b)1)), eine unzulässige Diskriminierung ergebe sich nicht schon daraus, dass mit der Marktgegenseite abgeschlossene Verträge nicht in jedem Fall zu einem wirtschaftlich gleichen Ergebnis führen würden.[1780] Maßgeblich für die Frage der Diskriminierung sei vielmehr, ob eine unterschiedliche Gestaltung der Konditionen auf Willkür oder sachfremden Erwägungen beruhe.[1781] Entscheidend sei Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung, sowie ob sich eine relative Schlechterstellung eines Unternehmens gegenüber einem anderen als wettbewerbskonformer Interessenausgleich oder auf Willkür/auf sachfremden Erwägungen beruhend darstelle.[1782]

i) Branchenübliche Rabatte

Rabatte oder der teilweise Verzicht auf Lizenzzahlungen bezeichnete das OLG Düsseldorf im Entscheid vom 30.3.2017 zwar als grundsätzlich nicht beanstandenswert, soweit branchenüblich.[1783] Im vorliegenden Fall habe die Klägerin aber gar nicht behauptet, dass auch Rabatte für zukünftige Benutzungshandlungen in dieser Größenordnung ebenfalls üblich seien.[1784] Auch sei im Hinblick auf vergangene Benutzungshandlungen nicht nachvollziehbar, warum die Klägerin in Anbetracht der behaupteten Branchenüblichkeit keinen mit dem einem der Lizenznehmer gewährten Nachlass vergleichbar hohen Rabatt gewährt habe.[1785] Die Klägerin habe keine Unterschiede aufgezeigt, die insofern eine Differenzierung rechtfertigen würden.[1786] Insbesondere mache sie nicht geltend, dass sie wegen frühzeitigen Vertragsschlusses einen Early Bird-Rabatt gewährt habe und dies ein sachlicher Grund für eine unterschiedliche Behandlung gegenüber der Beklagten wäre.[1787] Für eine derartige Vergünstigung habe auch hätte Anlass bestanden, da der Lizenzvertrag mit dem fraglichen Lizenznehmer erst nach Beendigung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens und Klageerhebung in der Hauptsache abgeschlossen worden sei.[1788] Bei dieser Sachlage vermöge eine Branchenüblichkeit von erheblichen Rabatten indes die Ungleichbehandlung der Beklagten gegenüber der einen Lizenznehmerin nicht zu rechtfertigen.[1789]

Außerdem sei zu beachten, dass die Einräumung von erheblichen Rabatten für die Vergangenheit und sogar ein Verzicht auf Lizenzzahlungen, die bei einigen Patentportfolios für bestimmte Zeiträume praktiziert worden seien, als solches im Rahmen des Diskriminierungsverbots nicht zu beanstanden seien.[1790] Je höher ein Rabatt sei, desto größere Bedeutung habe allerdings eine Gleichbehandlung aller Lizenznehmer und desto höhere Anforderungen gälten für die Rechtfertigung einer

[1779] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 254 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1780] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425, beide mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 23.3.2011 – 6 U 66/19, Rn. 166 – *FRAND Grundsätze.*

[1781] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425.

[1782] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 503; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 425, beide mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 23.3.2011 – 6 U 66/19, Rn. 166 – *FRAND Grundsätze.*

[1783] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 224 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1784] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 223 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1785] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 223 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1786] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 223 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1787] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 223 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1788] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 223 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1789] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 223 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1790] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 224 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Ungleichbehandlung.[1791] Insbesondere bei sehr hohen Rabatten müsse das marktbeherrschende Unternehmen deshalb dafür Sorge tragen, dass sie Lizenznehmern nach den gleichen Kriterien gewährt würden, und diese Kriterien zudem das Ausmaß der Ungleichbehandlung hinreichen sachlich begründen würden.[1792] Denn werde ein derartiger Rabatt einigen Lizenznehmern zugebilligt und anderen nicht, so könne dies zu erheblich unterschiedlichen Belastungen von Wettbewerbern mit Lizenzgebühren führen und dadurch eine Verfälschung des Wettbewerbs auf dem nachgeordneten Produktmarkt nach sich ziehen.[1793] Infolgedessen beständen aber die mit Hilfe des Diskriminierungsverbots zu vermeidende Gefahr, dass die betroffenen Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit untereinander beeinträchtigt würden.[1794] So sei es vorliegend, da die Klägerin mit Blick auf die behauptete Branchenüblichkeit kein Kriterium nenne, in welchem sich die rabattierte Lizenznehmerin und die Beklagte unterscheiden würden und sie unabhängig davon auch keinen spezifischen, in Besonderheiten des Lizenzvertrages mit der rabattierten Lizenznehmerin liegenden triftigen Grund anführe, der das exorbitante Ausmaß der Ungleichbehandlung rechtfertige.[1795]

In den Entscheiden vom 13.7.2017 führte das LG Düsseldorf aus, die Argumentation der Klägerin, ein SEP vermittele keine echte marktbeherrschende Stellung, so dass man gezwungen sei, Rabatte einzuräumen, lasse zumindest den Verdacht aufkommen, dass Klägerin hier versuche, eine diskriminierende Lizenzierungspraxis zu rechtfertigen.[1796] Dass in den USA und in China der Unterlassungsanspruch nicht zwangsläufige Folge einer Patentverletzung sei, vermöge diskriminierend günstige Lizenzgebühren nicht zu rechtfertigen.[1797] Dass es leichter sei, Lizenzverträge mit günstigen Lizenzgebühren und Rabatten abzuschließen, erlaube es ersichtlich nicht, solche guten Konditionen nur selektiv anzubieten.[1798] Aus dem Vortrag der Klägerin sei nicht ersichtlich, warum sie einem Lizenznehmer (möglicherweise) sehr günstige Konditionen angeboten habe, weiteren aber nicht.[1799]

Das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 führte betreffend die Einführung einer jährlichen „Royalty Cap“ für die Stücklizenzen aus, eine solche tauge grundsätzlich als objektiver Anknüpfungspunkt für eine Rabattgewährung.[1800] Das Erreichen der Höchstgrenze der zu entrichtenden Jahresgebühr hänge von der Verkaufskraft des jeweiligen Unternehmens ab.[1801] Diese sei in erster Linie Ausdruck des wettbewerblichen Handelns der auf dem Markt tätigen Unternehmen sowie unternehmerischer Entscheidungen.[1802] Erweise sich ein Wettbewerber danach, weil er sich einen weitergehenden Markt als sein Wettbewerber erschlossen habe, als (im Hinblick auf die veräußerte Stückzahl) „stärker“, erscheine es nicht von vornherein unangemessen (dazu bereits oben XI.B.2.b)), damit eine Rabattierung zu verbinden.[1803]

[1791] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 224 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1792] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 224 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1793] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 224 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1794] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 224 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1795] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 224 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1796] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 411 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 362 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 410; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 363.

[1797] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 411 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 362 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 410; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 363.

[1798] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 411 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 362 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 410; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 363.

[1799] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 411 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 362 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 410; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 363.

[1800] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 504; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 426.

[1801] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 504; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 426.

[1802] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 504; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 426.

[1803] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 504; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 426.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Insofern sei weiter auch zu beachten, da diese Begrenzung jedem Lizenznehmer zu Gute komme, und somit nur eine tatsächliche und keine rechtliche Ungleichbehandlung vorliege (dazu bereits oben).[1804] Dass die Höchstgrenze vorliegend aber gerade so bemessen sei, dass diese – was für sachfremde Erwägungen sprechen würde (vgl. oben XI.B.3.b)2)) – faktisch nur auf ein bestimmtes Unternehmen bzw. eine geringe Anzahl von Unternehmen Anwendung finde, bringe die Beklagte nicht vor.[1805] Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang einwende, dass die Höchstgrenze insbesondere Multiproduktanbieter gegenüber „reinen" Smartphone/Tablet-PC-Anbietern unzulässig begünstige, sei gegen diese Pauschalisierung nichts einzuwenden, denn Ausgangspunkt der Lizenzvergabe sei gerade, das Anbieten und Vertreiben eines (video-)standardfähigen Produkts zu ermöglichen.[1806]

Auch das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 führte betreffend die gleiche Klausel im Standardlizenzvertrag aus, die Kappungsgrenze setze zunächst einen wirtschaftlichen Anreiz, hohe Stückzahlen zu verkaufen, um bei hohem Umsatz lizenzfrei zu werden.[1807] So werde aber der natürliche Wettbewerb gerade gefördert, und eine Wettbewerbsförderung habe gleichzeitig eine gute Durchsetzung des Standards zur Folge.[1808] Es entsprechen natürlichen Markt- und Wettbewerbsverhältnissen, dass Unternehmen mit gewissen Marktanteilen und einer gewissen Marktpräsenz belohnt würden.[1809] So sei der Mechanismus der Rabattierung – nichts anderes passiere beim Erreichen der Kappungsgrenze – bei großen Stückzahlen ein gängiges Mittel in der Wirtschaft.[1810]

ii) Sonderstellung als Referenzkunde

Nach dem OLG Düsseldorf in *Mobiles Kommunikationssystem* stelle die Sonderstellung des begünstigten Lizenznehmers als Referenzkunde weder für sich betrachtet noch im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtwürdigung eine hinreichende sachliche Rechtfertigung für das vorliegende extreme Ausmaß der Ungleichbehandlung dar.[1811] Die Klägerin hatte argumentiert, die bevorzugte Lizenznehmerin sei als Referenzkunde für die Einführung der Lizenzierung des Wireless-Portfolios auf dem spezifischen Markt gewesen.[1812] Eine Rechtfertigung der Ungleichbehandlung lasse sich in casu allein schon deshalb nicht feststellen, da die Klägerin für die behauptete Sonderstellung beweisfällig geblieben sei.[1813] Doch auch wenn man zu Gunsten der Klägerin annehme, die bevorzugte Lizenznehmerin sei auf dem entsprechenden Markt die erste Lizenznehmerin gewesen, mit der sie einen Lizenzvertrag über das Wireless-Portfolio abgeschlossen habe, fehle es jedenfalls an Sachvortrag, der die extrem hohen Unterschiede bei der Höhe der Lizenzgebühren rechtfertige.[1814]

Es sei im Grundsatz nicht zu beanstanden, wenn ein SEP-Inhaber versuche, zum Zwecke des Eintritts in einen neuen Markt Referenzkunden zu gewinnen und ihnen günstigere Konditionen anbiete als anderen Lizenznehmern, um einen zusätzlichen Anreiz für den Abschluss eines Lizenzvertrages zu schaffen.[1815] Es möge tatsächlich durchaus eine „Sogwirkung" entstehen, wenn ein großes Unternehmen auf einem bisher vom SEP-Inhaber noch nicht erschlossenen Markt eine Lizenz nehme, weil andere Unternehmen davon ausgehen würden, dass es die Notwendigkeit einer Lizenzierung mit

[1804] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 505; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 427.
[1805] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 505; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 427.
[1806] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 506; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 428.
[1807] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1808] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1809] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1810] Vgl. LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 346; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 285.
[1811] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 229 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1812] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 230 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1813] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 230 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1814] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 231 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1815] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 232 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Blick auf die Standardessenzialität und die Benutzung des Patents geprüft habe, und dies dem SEP-Inhaber den Abschluss von weiteren Lizenzverträgen für diesen Markt erleichtere.[1816] Bei der Wohl des oder der Referenzkunden sei dem SEP-Inhaber ebenfalls ein weiter Beurteilungsspielraum zuzubilligen.[1817]

Die Klägerin habe zur Begründung für die Bevorzugung der einen Lizenznehmerin gegenüber der Beklagten angeführt, aufgrund der Rahmenbedingungen auf dem spezifischen Markt sei die Präzedenzwirkung einer Lizenznahme durch diese Lizenznehmerin ungleich grösser.[1818] Es sei nicht ersichtlich, dass diese Überlegungen willkürlich oder unternehmerisch vernünftigen Handeln fremd seien.[1819] Gleichwohl rechtfertige der Markteintritt über einen Referenzkunden bei standardessentiellen Patenten eines marktbeherrschenden Unternehmens regelmäßig nur in begrenztem Umfang die Einräumung günstigerer Konditionen im Vergleich zu anderen Lizenznehmern.[1820] Dies folge daraus, dass jedes Unternehmen, das den maßgeblichen Standard benutze, eine Lizenz nehmen müsse.[1821] Auch wenn dies nicht dazu führe, dass jedes Unternehmen ohne Weiteres sofort einen Lizenzvertrag abzuschließen bereit sei, und dieser Umstand faktisch keine 100%-ige Lizenzvertragsabschlussquote nach sich ziehe, so könne nicht außer Acht gelassen werden, dass ein redliches Unternehmen in der gegebenen Situation rechtlich keine Wahl und tatsächlich dazu keine Alternative habe.[1822] Dementsprechend habe ein solcher SEP-Inhaber keine Wettbewerber.[1823] Deswegen bestehe grundsätzlich keine Notwendigkeit, sich in der Weise um Lizenznehmer auf einem neuen Markt zu bemühen, dass der SEP-Inhaber sie mit besonders günstigen Lizenzbedingungen „ködere".[1824] Vielmehr müssten sich diese auch auf solche Lizenzverträge einlassen, die ihnen im Vergleich zu anderen Lizenznehmern keine hohen Rabatte gewährten.[1825] Umgekehrt könne auch von einem SEP-Inhaber zwecks Wahrung eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem nachgelagerten Produktmarkt verlangt werden, dass er einem auf einen hohen Rabatt gerichteten Ansinnen des Lizenzsuchers nicht nachgebe.[1826] Dementsprechend seien die Anbieter von Mobilfunkgeräten, die standardessentielle Patente der Klägerin aus den Wireless-Portfolio nutzten, die eine marktbeherrschende Stellung vermitteln würden dazu gezwungen, eine Lizenz an diesen Patenten zu nehmen.[1827] Das gelte ohne Unterschied für sämtliche Unternehmen, die etwa auf dem deutschen und/oder europäischen Markt tätig sein wollten.[1828] Diese rechtliche Verpflichtung möge zwar Bemühungen auch des marktbeherrschenden SEP-Inhabers um einen tatsächlichen Zugang zu bisher nicht erschlossenen räumlichen Märkten nicht entbehrlich machen, weil die faktische Durchsetzung von Patenten in der Praxis mit Schwierigkeiten verbunden sein könne, deren Art und Umfang zudem je nach Markt unterschiedlich seien.[1829] Der Zwang zur Lizenznahme der Anbieter auf dem nachgelagerten Produktmarkt führe aber aus den genannten Gründen in der Regel dazu, dass diesem

[1816] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 232 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1817] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 232 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1818] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 232 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1819] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 232 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1820] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1821] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1822] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1823] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1824] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1825] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1826] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1827] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1828] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1829] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Gesichtspunkt keine hervorgehobene Bedeutung zukomme und daher jedenfalls erhebliche Abweichungen bei den gewährten Lizenzbedingungen nicht rechtfertige.[1830]

Das Vorbringen der Klägerin führe im Streitfall nicht ausnahmsweise zu einer anderen Beurteilung.[1831] Zu einen sei mangels hinreichend substantiierten Sachvortrag schon nicht ersichtlich, dass gegenüber der bevorzugten Lizenznehmerin als – nach der Behauptung der Klägerin – erstem Kunden des Wireless-Portfolios im fraglichen Land tatsächlich keine höheren Lizenzgebühren durchsetzbar gewesen wäre.[1832] Es fehle der erforderliche konkrete Bezug zu einer Rechtfertigung der exorbitant unterschiedlichen Lizenzgebühren.[1833] Zum anderen sei auch in diesem Zusammenhang besonders zu berücksichtigen, dass die durch die Ungleichbehandlung betroffenen Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit untereinander beeinträchtigt würden, da die Lizenzierungskosten ein Preisbildungsfaktor seien.[1834] Beständen insoweit große Unterschiede, werde ein Referenzkunde dauerhaft in die Lage versetzt, auf dem nachgeordneten Produktmarkt vergleichbare Produkte günstiger anzubieten als andere Unternehmen, die nicht von der bevorzugten Behandlung durch das marktbeherrschende Unternehmen profitieren würden.[1835] Dies führe bei einer weltweiten Lizenz insbesondere auch deshalb zu eine sachlich nicht gerechtfertigten Benachteiligung, weil dies nicht nur für die räumlichen Referenzmarkt gelte, sondern auch für alle anderen räumlichen Märkte.[1836] Dort genieße der Referenzkunde schließlich gleichermaßen deutlich günstigere Konditionen, obwohl er nicht der erste Lizenznehmer gewesen sei.[1837] So sei es auch im vorliegenden Fall, da die Beklagte nicht nur auf dem spezifischen Ländermarkt benachteiligt werde, sondern die extrem unterschiedlichen Konditionen weltweit gelten würden, obwohl die bevorzugte Lizenznehmerin außerhalb des spezifischen Ländermarktes kein Referenzkunde sei.[1838] Die immens hohen Unterschiede bei den Lizenzgebühren führten indes tendenziell dazu, dass die bevorzugte Lizenznehmerin ihre Mobilfunkgeräte weltweit auf Dauer günstiger anbieten könne.[1839] Die anderen Anbieter erlitten dadurch Wettbewerbsnachteile, zumal es sich bei der bevorzugten Lizenznehmerin um ein ressourcenstarkes Unternehmen handele, das jährlich mehrere Millionen Mobilfunkgeräte absetze.[1840] Die Ungleichbehandlung wäre daher aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der bevorzugten Lizenznehmerin im Falle eines Lizenzvertragsschlusses auf Basis des Lizenzangebots der Klägerin geeignet, die Marktposition der Beklagten tatsächlich spürbar zu verschlechtern.[1841]

Ein sachlicher Grund dafür sei umso weniger erkennbar, als die Klägerin keine markt- oder unternehmensbezogenen Aspekte aufgezeigt habe, welche eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.[1842] Im Gegenteil seien die Beklagte und die bevorzugte Lizenznehmerin Handelspartner der Klägerin, die sich in einer vergleichbaren Lage befänden.[1843] Beide würden drahtlose Mobilfunkgeräte anbieten, die sie über Händler an Endverbraucher verkaufen würden, so dass sie in derselben Wirtschaftsstufe auf demselben nachgelagerten Produktmarkt tätig seien.[1844] Darüber hinaus seien

[1830] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1831] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 233 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1832] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 234 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1833] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 234 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1834] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1835] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1836] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1837] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1838] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1839] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1840] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1841] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 235 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1842] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1843] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1844] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

beide Unternehmen deswegen sehr ähnlich, weil sowohl die bevorzugte Lizenznehmerin als auch der Mutterkonzern der Beklagten in Europa vorrangig im Niedrigpreissektor agierten.[1845] Vor allem aber sei der Mutterkonzern der Beklagten ebenso wie die bevorzugte Lizenznehmerin ein ressourcenstarkes Unternehmen aus demselben Land, das weltweit mit Milliardenumsatz operiere, und daher im Falle einer Lizenzierung ebenso ein Signal an den länderspezifischen Markt aussenden würde und andere Unternehmen in diesem Land zur Lizenznahme animieren könne.[1846] Deswegen sei auch nicht nachvollziehbar, warum die Klägerin den Mutterkonzern der Beklagten in ihrem ersten an den Mutterkonzern der Beklagten adressierten Lizenzangebot im Jahr 2014 kein Angebot unterbreitet habe, dass Vorzugskonditionen als Referenzkunde enthalten habe, obwohl dieser damals der erste Kunde in diesem Land gewesen wäre und im Falle eines Vertragsschlusses sogar in Jahr früher als mit der bevorzugten Lizenznehmerin in Markteintritt erfolgt wäre.[1847]

iii) Spezifische Risikoverteilung des Lizenzvertrages

Nach dem OLG Düsseldorf in *Mobiles Kommunikationssystem* stelle auch die spezifische Risikoverteilung des Lizenzvertrages weder für sich betrachtet noch im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtwürdigung eine hinreichende sachliche Rechtfertigung für das vorliegende extreme Ausmaß der Ungleichbehandlung dar.[1848] Ohnehin beziehe sich dieser Aspekt nur auf die zukünftigen Verkäufe, weshalb er von vornherein nicht geeignet sei, den exorbitant hohen Rabatt für die Vergangenheit zu rechtfertigen.[1849]

Im Übrigen rechtfertige die vorgenommene Risikoverteilung zwar dem Grunde nach die Einräumung eines Rabatts für die Zukunft.[1850] Es sei das Ergebnis eines Interessenausgleichs im Einzelfall und daher kartellrechtlich im Grundsatz unbedenklich, wenn der Lizenznehmer als Gegenleistung für die vertragliche Übernahme der Risiken sowohl eines verminderten als auch eines erhöhten Absatzes nur eine reduzierte Lizenzgebühr zu entrichten habe.[1851] Dabei sei zudem aufgrund des auch im Rahmen einer FRAND-Erklärung geltenden Maßstabs, ob eine missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung vorliege, nicht nur ein bestimmter (geringer) Rabatt zulässig, sondern dem SEP-Inhaber ein erheblicher Beurteilungsspielraum zuzubilligen.[1852]

Die Klägerin habe indes nicht nachvollziehbar dargelegt, dass die spezifische Risikoverteilung das Ausmaß der Ungleichbehandlung, den exorbitant hohen Rabatt für die Zukunft, rechtfertige.[1853] Wie groß das Risiko des Lizenznehmers und der mit der Risikoverteilung verbundene Vorteil für den Lizenzgeber sei, richte sich nach den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhandenen Erwartungen zur Absatzentwicklung.[1854] Werde prognostiziert, dass sich die Verkaufszahlen so entwickelten wie im Vertrag zugrunde gelegt, sei das Risiko des Lizenznehmers gering.[1855] Ebenso sei es, wenn die Erwartung eines höheren Absatzes bestehe, weil der Lizenznehmer dann zwar für die zusätzlich verkauften Einheiten weitere Lizenzgebühren zu entrichten habe, dies aber in seinem Interesse liege, weil er dann auch höhere Erlöse erziele.[1856] Demgegenüber sei sein Risiko groß und das Interesse des

[1845] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1846] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1847] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1848] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 229 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1849] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 238 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1850] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 239 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1851] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 239 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1852] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 239 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1853] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 240 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1854] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 240 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1855] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 240 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1856] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 240 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzgebers an der Zahlung einer Mindestlizenzgebühr erheblich, wenn die Parteien einen geringeren Absatz erwarteten, und beides sei umso größer, je niedriger ihre Prognose ausfalle.[1857] Hier könne dem Vorbringen der Klägerin allerdings nicht entnommen werden, dass die Risikoverteilung für sie bei Vertragsschluss einen hohen Wert gehabt habe, insbesondere keinen, der einen Rabatt in der veranschlagten Größenordnung rechtfertigen könne.[1858] Die (im Entscheid geschwärzten) Vertragszahlen veranschaulichten deutlich, dass die Risikoverteilung gemessen am Volumen des gesamten Lizenzvertrages nur eine untergeordnete Bedeutung und damit bloß einen geringen Wert für die Klägerin gehabt habe.[1859]

Die Klägerin habe der Beklagten eine solche Risikoverteilung zu keinem Zeitpunkt angeboten, geschweige denn mit den Nachlässen, die sich in derselben Größenordnung bewegen würden, wie sie der bevorzugten Lizenznehmerin zugutegekommen seien.[1860] Die dafür von ihr angeführten Gründe hätten wiederum nicht überzeugt.[1861]

Daran anknüpfend vermöge auch das weitere Vorbringen der Klägerin nicht überzeugen, wonach der Mobilfunkmarkt extrem volatil und die Vorhersehbarkeit der Absatzentwicklung daher sehr schwierig sei, so dass der Lizenznehmer ihr mit der Vereinbarung von Pauschalzahlungen ein hohes Risiko abnehme, für das im Gegenzug ein erheblicher Rabatt gerechtfertigt sei.[1862] Auch insoweit sei zunächst zu konstatieren, dass diese Ausgangslage im Grundsatz bei allen potentiellen Lizenznehmern und damit ebenso bei der Beklagten bestehe.[1863] Dies gelte ebenso im Hinblick auf die von ihr besonders hervorgehobenen praktischen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Patenten sowie der Gefahr eines Ausstiegs aus dem Mobilfunkgeschäft oder eines Zahlungsausfalls.[1864] Die Klägerin habe nicht geltend gemacht, dass insoweit zwischen der bevorzugten Lizenznehmerin und dem Mutterkonzern der Beklagten Unterschiede beständen, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigten.[1865] Gleichwohl habe sie der Beklagten einen Pauschallizenzvertrag, der diese Risikoaspekte in vergleichbarem Umfang wie im Lizenzvertrag mit der bevorzugten Lizenznehmerin berücksichtige, nicht unterbreitet.[1866] Abgesehen davon habe die Klägerin konkret im Hinblick auf den in Rede stehenden Lizenzvertrag mit der bevorzugten Lizenznehmerin nicht dargelegt, dass die Risiken hoch seien und deshalb einen sachlichen Grund für den immens hohen Rabatt für zukünftige Benutzungshandlungen in diesem Ausmaß darstellen würden.[1867]

iv) Fehlendes Interesse des Lizenzsuchers an den nicht-diskriminierenden Lizenzbedingungen

Weiter führte das OLG Düsseldorf in *Mobiles Kommunikationssystem* aus, könne sich die Klägerin weiter nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die Beklagte kein Interesse an der Vereinbarung eines Lizenzvertrags auf der Basis von Pauschalzahlungen gezeigt habe.[1868] Insoweit sei in Erinnerung zu rufen, dass es zunächst Sache der Klägerin als SEP-Inhaberin sei, ein FRAND-konformes Lizenzangebot

[1857] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 240 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1858] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 240 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1859] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 240 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1860] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 241 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1861] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 241 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1862] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 242 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1863] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 242 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1864] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 242 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1865] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 242 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1866] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 242 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1867] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 242 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1868] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 243 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

abzugeben.[1869] Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte Pauschallizenzzahlungen generell ablehne und ein Angebot mit einem solchen Inhalt daher von vornherein sinnlos – und somit entbehrlich – wäre (zu den Anforderungen an Annahme einer Lizenzverweigerung siehe oben IX.A.2), beständen nicht.[1870] Die Beklagte habe sich vielmehr lizenzwillig gezeigt und zudem ausdrücklich erklärt, dass grundsätzlich Bereitschaft dazu bestehe, einen Pauschallizenzvertrag zu vereinbaren, und dies lediglich eine Frage der Höhe sei.[1871]

Aus dem Umstand, dass die Beklagten die früheren Angebote der Patentinhaberin, die teilweise Pauschallizenzzahlungen vorgesehen hätten, nicht angenommen habe, könne ebenso wenig der Schluss auf die generelle Ablehnung einer Pauschallizenz gezogen werden.[1872] Dies verbiete sich schon aus dem Grunde, weil beide Lizenzangebote – wie bereits im Hinweisbeschluss des Senats vom 17.11.2016 ausgeführt worden sei – mangels jedweder Darlegung der Art und Weise der Berechnung der pauschalen Lizenzgebühren nicht den vom EuGH aufgestellten Anforderungen genügt hätten (dazu oben XI.B.1.a)).[1873] Zudem sei eines der Vertragsangebote der Klägerin per E-Mail deswegen nicht FRAND-konform gewesen, weil es kein geschlossenes Vertragswerk mit Angaben zu sämtlichen Punkten darstelle, die üblicherweise Reglungsgegenstand eines Lizenzvertrags seien, sondern lediglich optionale Vorschläge zur Höhe der Lizenzgebühren und einige weitere Lizenzbedingungen wie Bankgarantie und Abschlussgebühr enthalten habe.[1874]

Abgesehen davon hätten beide früheren Angebote die Beklagte ebenfalls gegenüber der bevorzugten Lizenznehmerin ungleich behandelt, ohne dass eine sachliche Rechtfertigung dafür ersichtlich wäre.[1875] Eine generell fehlende Bereitschaft, Pauschalzahlungen zu akzeptieren lasse sich zuletzt auch nicht daraus herleiten, dass die Beklagte selbst in ihrem Gegenangebot keine Pauschalzahlungen, sondern eine Stücklizenz auf Grundlage der konkreten Verkaufszahlen offeriert habe.[1876] Auch insoweit liege vielmehr auf der Hand, dass es der Beklagten letztlich entscheidend auf die Höhe der Lizenzgebühren angekommen sei, weshalb aus dem Umstand, dass ihr Gegenangebot eine bestimmte Art von Lizenzgebühren vorsehe, nicht der Schluss gezogen werden könne, sie würde andere Berechnungsarten generell nicht akzeptieren.[1877]

v) Unterschiedliche prozessuale Situation

Nach dem OLG Düsseldorf in *Mobiles Kommunikationssystem* stelle auch die unterschiedliche prozessuale Situation der beiden Lizenznehmer in Deutschland weder für sich betrachtet noch im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtwürdigung eine hinreichende sachliche Rechtfertigung für das vorliegende extreme Ausmaß der Ungleichbehandlung dar.[1878] So hatte die Klägerin vorgebracht, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit der bevorzugten Lizenznehmerin sei die prozessuale Situation in Deutschland nicht vorteilhaft gewesen, weil nach der Aufhebung der einstweiligen Verfügung gegen die bevorzugte Lizenznehmerin keine landgerichtliche Entscheidung zu ihren Gunsten vorgelegen habe.[1879]

[1869] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 244 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1870] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 244 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1871] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 244 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1872] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 245 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1873] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 245 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1874] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 245 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1875] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 246 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1876] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 255 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1877] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 255 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1878] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 229 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1879] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 256 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Der Klägerin sei zwar zuzugestehen, dass insofern ein Unterschied bestehe, als dem gegenüber im Zeitpunkt des Lizenzangebots gegenüber der Beklagten ein Urteil des Landgerichts und die mündliche Einschätzung des Senats im ersten Verhandlungstermin am 17.11.2016 vorgelegen habe, wonach die Beklagte das Klagepatent benutze.[1880] Unterschiedliche Erfolgsaussichten bei der Durchsetzung eines Patents, die etwa in mehreren gerichtlichen Verfahren gegen verschiedene angebliche Verletzer beständen, dürften sich durchaus in inhaltlichen Abweichungen bei den jeweils angebotenen Lizenzbedingungen niederschlagen.[1881] Im Streitfall sei allerdings weder ersichtlich noch von der Klägerin konkret vorgetragen worden, dass dieser Umstand bei ihr tatsächlich zu einer wesentlich anderen Risikoeinschätzung geführt und daher die unterschiedlichen Lizenzbedingungen mitgeprägt habe.[1882] Dazu habe objektiv auch kein Anlass bestanden, weil erhebliche Unterschiede tatsächlich nicht bestehen würden.[1883] So habe das Kammergericht im Falle der bevorzugten Lizenznehmerin die einstweilige Verfügung gegen die bevorzugte Lizenznehmerin wegen mangelnden Verfügungsgrundes und nicht aufgrund fehlender Patentverletzung aufgehoben, so dass aus dem Berufungsurteil kein Rückschluss auf bloß geringe Erfolgsaussichten im damals ebenfalls vor dem LG Düsseldorf anhängigen Hauptsacheverfahren gezogen werden könne.[1884] Umgekehrt habe der Senat die Zwangsvollstreckung aus dem angefochtenen landgerichtlichen Urteil eingestellt und mit Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 darauf hingewiesen, dass die bisherigen Lizenzangebote der Klägerin nicht FRAND-konform gewesen sein dürften, weshalb im Zeitpunkt des Lizenzangebots vom 20.12.2016 aus Sicht der Klägerin ein überwiegendes Obsiegen in diesem Rechtsstreit ungewiss gewesen sei.[1885] Dementsprechend habe sie eingeräumt, dass die „Sogwirkung", die sie sich von dem Lizenzvertrag mit der bevorzugten Lizenznehmerin im Hinblick auf einen Vertragsschluss mit weiteren Unternehmen versprochen habe, tatsächlich aufgrund der Einstellung der Zwangsvollstreckung nicht eingetreten sei.[1886] Vielmehr würden deswegen nach ihren Angaben sämtliche Verhandlungen mit zahlreichen potentiellen Lizenznehmern ruhen, womit nicht vereinbar sei, von einer unterschiedlichen Prozesssituation bei der bevorzugten Lizenznehmerin und der Beklagten auszugehen, die einen mehr als nur geringen Einfluss auf den Inhalt der Lizenzbedingungen habe.[1887]

vi) Behördliche Einflussnahme auf Lizenzkonditionen als besondere Begleitumstände

Schließlich setze sich das das OLG Düsseldorf damit auseinander, dass die Klägerin besondere Begleitumstände der Verhandlungen und des Lizenzvertrags mit der rabattierten Lizenznehmerin geltend gemacht habe.[1888] Es beständen bereits Zweifel, ob auf Grundlage des Vorbringens der Klägerin konkrete Feststellungen zu solchen „Begleitumständen" und einer unzulässigen (wohl behördlichen) Einflussnahme auf die Lizenzbedingungen getroffen werden könne.[1889] Dies bedürfe letztlich jedoch keiner weiteren Aufklärung, da die von der Klägerin vorgebrachten Begleitumstände bereits im Ansatz keine sachliche Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der Beklagten dazustellen vermögen würden.[1890] Würde man durch behördliche Einflussnahme hervorgerufene Ungleichbehandlungen mit Verweis auf ihr Zustandekommen rechtfertigen, liefe diese Rechtfertigung im Ergebnis darauf hinaus,

[1880] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1881] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1882] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1883] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1884] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1885] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1886] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1887] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 257 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1888] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 227 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1889] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 227 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1890] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 228 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

dass solche Maßnahmen, die – was hier zu Argumentationszwecken unterstellt werde – dem deutschen und europäischen Wettbewerbsrecht fremd seien, die Wettbewerbsfreiheit in der EU einschränken würden.[1891] Denn die Vorteile, die dieses Unternehmen infolge der behördlichen Einflussnahme aufgrund der im Vergleich zu Wettbewerbern exorbitant niedrigeren Lizenzgebühr genieße, wirkten sich bei der vorliegend gegebenen Vereinbarung einer weltweiten Lizenz nicht allein im spezifischen Land aus.[1892] Vielmehr würden sie gleichermaßen auf dem deutschen und europäischem Markt bestehen, so dass Wettbewerber dieses Unternehmens auch im Inland sowie innerhalb der Europäischen Union Wettbewerbsnachteile erlitten, indem ihre Produkte mit deutlich höheren Lizenzgebühren belastet seien.[1893] Eine derartige Einflussnahme stelle indes eine dem Zweck des AEUV zuwiderlaufende Verfälschung des Wettbewerbs aus nicht sachlichen Gründen dar.[1894] Deren Folgen würden zudem perpetuiert und vertieft, wenn die „erzwungenen" Lizenzbedingungen für andere Wettbewerber unter dem Aspekt der Diskriminierung unbeachtlich blieben.[1895]

vii) Aussparung der Lizenzvergabe an die Muttergesellschaften

Das LG Düsseldorf führte in den Entscheiden vom 9.11.2018 aus, die Richtigkeit des Vortrags der Beklagten unterstellt, wonach die Lizenzverwalterin Lizenzverträge mit Unternehmen unter Aussparung der Lizenzvergabe auch an deren Muttergesellschaften geschlossen habe, komme grundsätzlich ein diskriminierendes Verhalten der Lizenzverwalterin in Betracht.[1896] Zum einen fehle es dem Vortrag der Beklagten jedoch an Substanz, um diesen Einwand in erheblicher Weise darzulegen.[1897] Zum anderen habe die Klägerin betreffend eines der angeführten Unternehmen die Lizenzierungspraxis der Lizenzverwalterin dahingehend konkretisierend beschrieben, dass gesonderte Lizenzen an einzelne Konzernunternehmen nur dann vergeben würden, wenn sich die patentrechtlich relevanten Benutzungshandlungen auf diese konkreten Konzernunternehmen einschränken ließen.[1898] Dass dies gleichermaßen auf der Konzern der Beklagten zutreffe, habe die Beklagte nicht dargetan.[1899]

viii) Diskriminierungskonstellationen bei Patentpools

Zu Diskriminierungskonstellationen, die spezifisch für Patentpools diskutiert wurden, siehe bereits oben VI.B.2.

c) Gleichbehandlung betreffend Rechtsdurchsetzung

Die selektive Rechtsdurchsetzung als Aspekt des Diskriminierungsverbots wurde verschiedentlich mit der Vergabe einer Freilizenz gleichgesetzt. Damit fällt auch die selektive Rechtsdurchsetzung in das gleiche Beurteilungsraster von Ungleichbehandlung und sachlicher Rechtfertigung, wie das Gleichbehandlungsgebot betreffend Lizenzbedingungen.[1900] Sie wird hier dennoch als eigenständiges Kapitel behandelt, da für sie insbesondere die Unzumutbarkeit der SEP-Inhaberin als sachlicher Rechtfertigungsgrund gelten kann und ein gestaffeltes Vorgehen möglich sein soll. Zu bemerken bleibt, dass die selektive Rechtsdurchsetzung als Diskriminierungstatbestand vor allem bei geringer Restlaufdauer der Patente von Bedeutung sein dürfte, da die Ansprüche der Vergangenheit in Lizenzverhandlungen durchaus auch noch im Nachhinein geltend gemacht werden könnten,

[1891] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 228 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1892] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 228 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1893] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 228 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1894] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 228 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1895] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 228 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[1896] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 496; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 418.
[1897] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 497; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 419.
[1898] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 498; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 420.
[1899] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 498; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 420.
[1900] Vgl. etwa LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 382; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 304.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

währenddessen der Patentinhaber nach Ablauf auf die Geltendmachung als Schadensersatzanspruch verwiesen ist.

Betreffend Diskriminierung durch selektive Rechtsdurchsetzung hielt das OLG Düsseldorf im Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 fest, dass es auch unabhängig von einer FRAND-Zusage unter dem Aspekt der Diskriminierung missbräuchlich i.S.v. Art. 102 AEUV sein könne, wenn ein Patentinhaber in marktbeherrschender Stellung selektiv gegen einzelne Verletzer (gerichtliche) Maßnahmen ergreife, während er andere Verletzer insoweit gewähren lasse, jedenfalls bedürfe eine solche Selektion einer im Einzelnen vom Patentinhaber zu belegenden Rechtfertigung.[1901]

Das LG Düsseldorf nahm diese Diskriminierungsform wieder auf in den Entscheiden vom 11.7.2018. Eine tatbestandliche Diskriminierung im kartellrechtlichen Sinne begründende Ungleichbehandlung liege nicht nur vor, wenn die marktbeherrschende Patentinhaberin einzelnen Lizenznehmern vertragliche Sonder- bzw. Vorzugskonditionen einräume, die sie anderen Lizenznehmern verweigere, sondern gleichermaßen dann, wenn sie ihre Verbietungsrechte aus dem SEP selektiv durchsetze.[1902] Eine solche selektive Durchsetzung sei anzunehmen, wenn die Patentinhaberin gegen einzelne Wettbewerber Verletzungsklage erhebe, um sie in einen Lizenzvertrag zu zwingen, andere Wettbewerber hingegen bei der Benutzung ihres Schutzrechts frei gewähren lasse.[1903] In ihrer faktischen Folge bedeute eine solche Prozessstrategie nichts anderes, als dass einem Teil der Wettbewerber eine Freilizenz gewährt werde, während der andere Teil ein Lizenzentgelt zahlen müsse.[1904]

Nicht jede selektive Durchsetzung der Rechte durch Erhebung einer bzw. über einen gewissen Zeitraum objektiv unterlassenen Verletzungsklage begründe jedoch einen kartellrechtswidrigen Missbrauch der Stellung als SEP-Inhaber.[1905] Ein solcher Missbrauch setze vielmehr voraus, dass es sei bei den verschonten Konkurrenten um einen der Schutzrechtsinhaberin bekannten oder lediglich infolge Verletzung der Marktbeobachtungspflicht unbekannten Verletzer handele, gegen den die vorzugehen der Patentinhaber nach den gesamten Umständen – zu denen beispielsweise der Umfang der Benutzungshandlungen und die Rechtsschutzmöglichkeiten im Verfolgungsland zählten – zuzumuten sei.[1906] Im Interesse der kartellrechtlich gebotenen Gleichbehandlung sei die Zumutbarkeitsschwelle freilich nicht allzu hoch anzusetzen.[1907] Zu berücksichtigen sei allerdings, dass der Patentinhaber gerade in der Anfangsphase einer Etablierung des Standards in seinen finanziellen und personellen Mitteln beschränkt und deswegen auch bei gutem Willen außerstande sein könne, gleichzeitig gegen eine Vielzahl von aus dem Markt auftretenden Verletzern vorzugehen.[1908] Hier könne es durchaus sinnvoll und gerechtfertigt sein, seine Kräfte zu konzentrieren und Verbietungsrechte zunächst gegen marktstarke Verletzer durchzusetzen, nicht zuletzt auch in der Erwartung, dass nach erfolgter gerichtlicher Klärung kleinere Verletzer außergerichtlich einlenken würden.[1909]

Im vorliegenden Fall sei das Verhalten der Klägerin deswegen nicht FRAND-konform, da sie die Beklagten durch ihre (Prozess-)Strategie in Form der selektiven Rechtsdurchsetzung gegenüber

[1901] OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 41.

[1902] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 215; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 229.

[1903] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 215; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 229.

[1904] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 215; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 229.

[1905] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 216; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 230.

[1906] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 216; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 230.

[1907] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 216; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 230, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05 – *Videosignal-Codierung I*.

[1908] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 216; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 230.

[1909] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 216; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 230.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

anderen Unternehmen diskriminiere.[1910] Das Verhalten der Klägerin, die Erhebung von Verletzungsklagen gegen die Beklagten und ihre beiden Hauptkonkurrenten sowie die Nichterhebung von Verletzungsklagen gegen die übrigen Wettbewerber bzw. Lieferanten, stelle eine Diskriminierung dar.[1911] Zwar dürfe der Umstand, dass die Klägerin zunächst nur Verletzungsklagen gegen die drei größten nationalen Netzbetreiber erhoben habe, für sich genommen zunächst nicht zu beanstanden sein, da es der Klägerin aus finanziellen und personellen Gründen nicht zuzumuten sein dürfte, gleichzeitig eine Vielzahl von großen (Wirtschafts-)Unternehmen zu verklagen.[1912] Insoweit erscheine es nachvollziehbar, zunächst die größten Netzbetreiber zu verklagen.[1913] Jedoch entbinde die gewählte Prozessstrategie die Klägerin unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten nicht davon, gegen die zunächst verschonten Unternehmen – gegebenenfalls nach Abschluss der hiesigen Verfahren – vorzugehen und sie jedenfalls bereits zum jetzigen Zeitpunkt um den Abschluss eines Lizenzvertrages zu ersuchen.[1914] Ein solches Vorgehen wäre der Klägerin auch zuzumuten, da weder Umstände ersichtlich, noch solche vorgetragen seien, die ein Vorgehen allein gegen die aktuell verklagten Unternehmen rechtfertigen könne.[1915] Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass dem Klagepatent eine nur noch begrenzte Restlaufzeit zukomme und ein Vorgehen nach Abschluss des hiesigen Verfahrens schon wegen Auslaufs des Patentschutzes evident ausscheide.[1916] Insoweit sei von der Klägerin zum jetzigen Zeitpunkt zu fordern, das FRAND-Procedere gegenüber den übrigen Wettbewerbern der Beklagten mittels Übermittlung des Verletzungshinweises zu starten.[1917] Dass die Klägerin die bislang noch nicht in Anspruch genommenen Unternehmen derart über eine Verletzung informiert habe, habe sie nicht vorgetragen.[1918]

Soweit sich die Klägerin zur Begründung der Nichtdiskriminierung auf dem Umstand berufe, dass es sich bei den ausgenommenen Unternehmen um Investoren der Klägerin beziehungsweise Mandanten ihrer hiesigen Prozessbevollmächtigten handele, würden diese Konstellationen eine Verschonung der Unternehmen nicht zu rechtfertigen.[1919] Denn soweit sich die Klägerin auf die Investoreneigenschaft einiger ausgenommener Unternehmen berufe, habe sie bereits nicht substantiiert vorgetragen, welche Unternehmen mit welchen Beträgen an der Klägerin beteiligt sein sollten und welche Gegenleistung sie für die Nutzung der geschützten Lehre entrichteten.[1920] Ein solcher Vortrag oblag jedoch der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin, da die Beklagte die Investoreneigenschaft in zulässiger Weise mit Nichtwissen im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO bestritten habe und insoweit nicht festzustellen sei, ob die ausgenommenen Unternehmen überhaupt eine finanzielle Gegenleistung für die faktische Einräumung einer Freilizenz zahlen würden.[1921]

Von vornherein abwegig sei die Argumentation der Klägerin, eine Inanspruchnahme der ausgenommenen Unternehmen scheitere an dem Umstand, dass es sich bei diesen Unternehmen um Mandanten ihrer Prozessbevollmächtigten handele.[1922] Selbst wenn diese pauschale Behauptung zutreffend wäre, würde die Mandanteneigenschaft ein Vorgehen gegen diese Unternehmen nicht

[1910] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 218; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 232.
[1911] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 218; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 232.
[1912] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 219; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 233.
[1913] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 219; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 233.
[1914] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 219; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 233.
[1915] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 219; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 233.
[1916] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 219; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 233.
[1917] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 219; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 233.
[1918] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 219; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 233.
[1919] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 220; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 234.
[1920] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 220; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 234.
[1921] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 220; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 234.
[1922] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 221; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 235.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

ausschließen.[1923] So wäre es der Klägerin ohne weiteres möglich, die entsprechenden Unternehmen unter Beauftragung anderer Prozessbevollmächtigter in Anspruch zu nehmen, so dass die hiesigen Prozessvertreter keine standesrechtlichen Probleme bekämen.[1924] Dass dies beabsichtigt sei, sei auch trotz Hinweises in der mündlichen Verhandlung nicht behauptet worden.[1925]

Schließlich stelle das (prozess-)strategische Verhalten der Klägerin auch insoweit eine Diskriminierung dar, als die Klägerin den Streithelfern der Beklagten trotz unstreitig erfolgter Lizenzierungsbitte kein Lizenzangebot gemacht habe und stattdessen selektiv Klage gegen die hiesigen Beklagten erhoben habe.[1926] Die Streithelferin beliefere die in Deutschland tätigen Festnetz-Provider und auch die Beklagten mit DSL-Transceivern und DSL-Boards, mithin Vorrichtungen, die im jeweiligen Netz eingesetzt würden, um einen Dienst nach den vorliegend relevanten Standards im Netz zu unterhalten.[1927] Nicht nachzuvollziehen sei, wieso die Klägerin den Beklagten eine Lizenz gewähren wolle, ihren Zulieferern aber nicht, wobei die Klägerin eine Begründung für diese Verhaltensweise nicht gegeben habe.[1928]

Auch in den Entscheiden vom 9.11.2018 setzte sich das LG Düsseldorf mit der Diskriminierung durch selektive Rechtsdurchsetzung auseinander. Die Beklagte habe geltend gemacht, das Angebot der Klägerin, welches eine Lizenzierung auch des chinesischen Markts vorsehe, laufe FRAND-Bedingungen zuwider, weil die Lizenzverwalterin bisher noch mit keinem chinesischen Hersteller von Mobilfunkgeräten, der auf dem chinesischen Markt tätig sei, Lizenzen für eben diesen Markt vergeben habe.[1929] Auch wenn aufgrund Vorlage der abgeschlossenen Standardlizenzverträge anzunehmen sei, dass bereits ein erheblicher Teil der auf dem chinesischen Markt tätigen Anbieter Lizenzen genommen habe, bleibe unstreitig, dass danach noch eine Handvoll Unternehmen keinen Lizenzvertrag abgeschlossen habe.[1930] Daraus ergebe sich zwar unter dem Aspekt der selektiven Rechtsdurchsetzung zunächst ein Anknüpfungspunkt für eine Ungleichbehandlung, die die Klägerin jedoch sachlich rechtfertige.[1931]

Wie schon die Kammer vom 11.7.2018 führte auch die Kammer 4a aus, eine Ungleichbehandlung liege tatbestandlich nicht nur dann vor, wenn der marktbeherrschende Patentinhaber einzelnen Lizenzsuchern vertragliche Vorzugskonditionen einräume, sondern gleichermaßen dann, wenn er seine Verbietungsrechte aus dem Patent selektiv durchsetze, indem er gegen einzelne Wettbewerber vorgehe, um sie in den Lizenzvertrag zu zwingen, andere Wettbewerber hingegen bei der Benutzung des Schutzrechts gewähren lasse.[1932] In ihrer faktischen Auswirkung bedeute eine solche Strategie nichts anderes, als dass einem Teil der Wettbewerber unentgeltlich, einem anderen Teil der Wettbewerber hingegen nur entgeltliche Lizenzen eingeräumt würden.[1933]

Die Klägerin habe im Zusammenhang mit den vorliegend in Streit stehenden Gesichtspunkten vorgebracht, dass sie versuche, auch die noch nicht lizenzierten Unternehmen zu einer Lizenznahme

[1923] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 221; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 235.

[1924] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 221; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 235.

[1925] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 221; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 235.

[1926] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 223; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 237.

[1927] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 223; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 237.

[1928] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 223; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 237.

[1929] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 380; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 302.

[1930] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 381–82; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 303–04.

[1931] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 382; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 304.

[1932] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 383; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 305, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15, Rn. 41, LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 170 – *Videosignal-Codierung I*.

[1933] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 383; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 305, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 30.11.2006 – 4b O 508/05, Rn. 170 – *Videosignal-Codierung I*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zu bewegen.[1934] Dieser Vortrag werde dadurch bestätigt, dass sie gegen eine andere Patentbenutzerin ein Klageverfahren eingereicht habe, dass auch vor dem LG Düsseldorf anhängig sei.[1935] Diese Erklärung schließe die Annahme einer Diskriminierung aus.[1936] Etwas anderes gelte auch nicht deshalb, weil die Klägerin bisher neben der einen anderen Patentbenutzerin keine weiteren der näher bekannten nichtlizenzierten Unternehmen gerichtlich in Anspruch genommen habe.[1937] Der Klägerin sei eine differenzierte gerichtliche Geltendmachung schon wegen des damit verbundenen Kostrisikos zuzugestehen.[1938] Hinzu komme, dass die Klägerin ihre Auswahlentscheidung, für die ihr ohnehin ein Ermessen einzuräumen sei, nachvollziehbar auch damit begründet habe, dass sie ihre Rechte zunächst gegenüber einem bedeutenden Marktteilnehmer gerichtlich wahrnehmen wolle, weil dort der aufgrund der ausgebliebenen Lizenzierung zu erwartende Schaden am umfangreichsten sei und um auf diese Weise gegebenenfalls auch einen Abschreckungseffekt gegenüber anderen Unternehmen erzielen zu können.[1939]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 setzte sich die Kammer 4b mit der Diskriminierung durch selektive Rechtsdurchsetzung auseinander. Die weltweite Erstreckung des Standardlizenzvertrags unter Einschluss des chinesischen Marktes stelle sich vorliegend nicht unter dem Gesichtspunkt der selektiven Rechtsdurchsetzung als kartellrechtswidrige Diskriminierung dar.[1940] Eine selektive Rechtsdurchsetzung liege dann vor, wenn ein Patentinhaber in marktbeherrschender Stellung selektiv gegen einzelne Verletzer (gerichtliche) Maßnahmen ergreife, währen der andere Verletzer insoweit gewähren lasse, sofern er die Selektion nicht rechtfertigen könne.[1941] Dabei handele es sich um eine Diskriminierung, wenn bestimmten Wettbewerbern ohne sachlichen Grund eine unentgeltliche Benutzung erlaubt sei, anderen wiederum nicht.[1942]

Zunächst sei nach Vortrag der Klägerin (mangels erheblichen Bestreitens seitens der Beklagten) zugestanden, dass ein großer Teil der auf dem chinesischen Markt tätigen Anbieter Lizenzen auch für die VRC genommen habe.[1943] Die Klägerin habe weiter dargelegt, dass die Lizenzverwalterin bemüht sei, die bislang unstreitig nicht lizenzierten großen chinesischen Unternehmen ebenfalls zu lizenzieren.[1944] So habe sie insbesondere vorgetragen, dass alle vier großen chinesischen, nicht-lizenzierten Wettbewerber Lizenzen mit der gleichen Begründung abgelehnt hätten, nämlich dass die jeweiligen Wettbewerber sich ebenfalls lizenzfrei im chinesischen Markt aufhalten würden.[1945] Eine Woche vor der hiesigen mündlichen Verhandlung habe sich die Klägerin bzw. dessen Lizenzverwalterin noch mit Vertretern eines dieser Unternehmen getroffen, welche mitgeteilt hätten, dass sie den Ausgang des Verfahrens in Düsseldorf abwarten wollen würden und erst gegebenenfalls dann zum Abschluss der Standardlizenz bereit seien.[1946]

Diesem Vortrag sei die Beklagte nicht mehr entgegengetreten, und die Kammer sei zu der Überzeugung gelangt, dass die Klägerin beziehungsweise ihre Lizenzverwalterin mit anderen

[1934] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 384; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 306.

[1935] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 384; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 306.

[1936] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 384; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 306.

[1937] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 385; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 307.

[1938] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 385; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 307.

[1939] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 385; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 307.

[1940] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 373; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 312.

[1941] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 374; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 313, beide mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.11.2016 – I-15 U 66/15.

[1942] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 374; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 313.

[1943] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 375; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 314.

[1944] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 315.

[1945] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 315.

[1946] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 315.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

chinesischen Unternehmen in Verhandlungen gestanden sei und weiterhin stehe.[1947] Auch sei der Kammer aus dem parallel verhandelten Verfahren der Klägerin gegen ein anderes der nicht-lizenzierten Unternehmen bekannt, dass dort ebenfalls bis zum anhängigen Rechtsstreit der Abschluss eines Standardlizenzvertrages durch deren Muttergesellschaft abgelehnt worden sei.[1948] Diese Umstände bestätigten aber den Vortrag, dass die Klägerin sich bemühe, auch die anderen noch nicht lizenzierten chinesischen Unternehmen zum Abschluss einer Lizenz zu bewegen.[1949]

Dass die Klägerin neben der im Parallelverfahren Beklagten keine weiteren der näher benannten nicht lizensierten Unternehmen gerichtlich in Anspruch genommen habe, führe zu keiner anderen Beurteilung.[1950] Der Klägerin sei eine differenzierte Geltendmachung aufgrund des damit verbundenen Kostenrisikos zuzugestehen.[1951] Insoweit habe die Klägerin die Auswahl plausibel damit begründet, dass sie ihre Rechte zunächst gegen den größten Marktteilnehmer – die Beklagte – mit den meisten Stückzahlen durchsetzen wolle.[1952] Abgesehen davon, dass es sich dabei um den größten Schaden handele, verspreche sich die Klägerin einen Abschreckungseffekt gegenüber den anderen Unternehmen.[1953] Dies erscheine vor dem Hintergrund, dass die größten chinesischen Hersteller nicht nur eine Lizenz für die VRC, sondern weltweit mit dem Hinweis auf die jeweils anderen lizenzfrei tätigen Unternehmen verweigerten, insoweit nicht als kartellrechtswidriges, sondern als probates Mittel zu fungieren, um ein solches Verhalten zu durchbrechen, dass eher den Eindruck einer Verzögerungstaktik erwecke, um sich ernstzunehmenden Verhandlungen verschließen zu können.[1954]

C. Rechtsfolgen des Lizenzvertragsangebots

1. Rechtsfolge bei FRAND-gemäßem Angebot

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 führte bezüglich Rechtsfolge bei FRAND-gemäßem Angebot aus, selbst wenn man – wie nicht – davon ausgehen sollte, dass das Angebot der Klägerin feststellbar FRAND-Vorgaben entspreche, und die Klägerin die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren ausreichend dargelegt hätte, würde der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand durchgreifen.[1955] Durch die Abgabe eines FRAND-Angebots werde nur die Pflicht des Patentbenutzers ausgelöst, ein FRAND-gemäßes Gegenangebot zu machen, wenn das Angebot nicht angenommen werde.[1956] Auch wenn diese Reaktion ohne Verzögerungstaktik erfolgen müsse, sei dem Verletzer gleichwohl ein angemessener Zeitraum für die Prüfung und Formulierung des Gegenangebotes einzuräumen (vgl. oben zu den zeitlichen Anforderungen an das Angebot und die Konsequenzen für die Nachholbarkeit XI.A.4, II).[1957] Bis zur mündlichen Verhandlung am 30.5.2017 habe die Beklagte ausgehend vom

[1947] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 377; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 316.

[1948] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 377; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 316.

[1949] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 377; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 316.

[1950] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 378; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 317.

[1951] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 378; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 317, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4b O 17/17.

[1952] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 378; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 317.

[1953] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 378; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 317.

[1954] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 378; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 317.

[1955] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 416 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 367 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 415; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 368.

[1956] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 416 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 367 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 415; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 368.

[1957] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 416 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 367 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 415; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 368.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Angebot am 19.5.2017 hierfür schlicht nicht ausreichend Zeit gehabt, und auf die Zeit nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung könne dagegen bei der Entscheidung nicht abgestellt werden.[1958]

2. *Keine Pflicht zum Gegenangebot und Ablehnung der Verletzungsklage als „derzeit unbegründet"*

Vgl. insb. zur dem dargestellten Fallrecht nachfolgenden *FRAND-Einwand* Rechtsprechung des BGH auch *Erik Habich*, Die Suche nach dem gerechten Interessenausgleich zwischen Safe Harbour und Missbrauchsverbot in FRAND/SEP-Lizenzverhandlungen, WuW 2021, 282–8, <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3820812>

Betreffend die Rechtsfolgen eines nicht-FRAND-konformen Lizenzvertragsangebots bemerkte das OLG Düsseldorf in *Improving Handovers*, dass nur ein in jeder Hinsicht einwandfreies Lizenzangebot Handlungspflichten des Patentbenutzers auslöse, aus deren Missachtung der Verletzungskläger Rechte für sich herleiten könne (vgl. auch III).[1959]

Umgekehrt formuliert führte das OLG Düsseldorf im Entscheid *Mobiles Kommunikationssystem* vertiefter aus, der begründete kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand wirke sich in Verbindung mit der FRAND-Zusage der Klägerin so aus, dass die Ansprüche auf Unterlassung und Rückruf aus der Vertriebswegen gerichtlich nicht durchsetzbar seien, solange der SEP-Inhaber sich nicht entsprechend seiner FRAND-Zusage gegenüber der Standardisierungsorganisation verhalte.[1960] Die genannten Ansprüche seien aufgrund des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes zwar nicht dauerhaft ausgeschlossen, jedoch stehe ihnen eine dilatorische Einrede entgegen, solange der SEP-Inhaber seinen Verpflichtungen nicht nachkomme.[1961] Die Situation sei vergleichbar mit einer nicht fälligen Forderung.[1962] Erfülle der SEP-Inhaber seine Verpflichtungen nicht spätestens bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung, sei die Klage insoweit als derzeit unbegründet abzuweisen.[1963] Es entspreche – soweit ersichtlich – zu Recht einhelliger Auffassung, dass Vorstehendes für die Erhebung einer Klage auf Vernichtung patentbenutzender Erzeugnisse (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG) entsprechend gelte.[1964] Da die Klägerin bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung vor dem Senat kein FRAND-Angebot abgegeben habe, sei die Klage teilweise in Abänderung des angefochtenen Urteils des Landgerichts als derzeit unbegründet abzuweisen.[1965]

Auch das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 traf Ausführungen zu den Rechtsfolgen des erfolgreich erhobenen Zwangslizenzeinwandes. Zunächst sei die Beklagte ohne feststellbar FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin weder dazu verpflichtet, noch ausreichend dazu in der Lage, ein FRAND-Gegenangebot abzugeben, geschweige denn es innerhalb der gesetzten Schriftsatzfristen in das hiesige Verfahren einzuführen.[1966] Weiter führe der erfolgreich erhobene Zwangslizenzeinwand zur

---

[1958] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 416 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 367 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 415; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 368.

[1959] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – 2 U 31/16, Rn. 312 – *Improving Handovers*.

[1960] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 261–63 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 72 – *Huawei/ZTE.*

[1961] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 263 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1962] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 263 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1963] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 263 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 31.5.2016 – 6 U 55/16.

[1964] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 263 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf die weiteren Ausführungen bei LG Düsseldorf, 19.1.2016 – 4b O 120/14.

[1965] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 264 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1966] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 383 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 334 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 382; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 335.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

(vorläufigen) Abweisung der auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichteten Anträge.[1967] Der Anspruch auf Schadenersatz sowie derjenige auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung würden aufgrund des erfolgreichen kartellrechtlichen Einwandes zwar eine inhaltliche Beschränkung erfahren, beständen aber dem Grunde nach (dazu unten XIII).[1968] Der Anspruch der Klägerin auf Unterlassung aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG sei als derzeit unbegründet abzuweisen, da die Beklagte erfolgreich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhoben habe.[1969] Die Klägerin habe die aus dem EuGH-Urteil folgenden Vorgaben nicht – jedenfalls nicht rechtzeitig – erfüllt.[1970] Solange dies nicht der Fall sei, sei der Anspruch auf Unterlassung nicht durchsetzbar.[1971] Erfülle die Klägerin aber – rechtzeitig – ihre Obliegenheiten, während die Beklagte sich nicht FRAND-gemäß verhalte, seien diese Ansprüche wieder durchsetzbar.[1972]

Auch der aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG folgende Rückrufanspruch sei als derzeit nicht durchsetzbar abzuweisen.[1973] Die für den Unterlassungsanspruch geltenden, kartellrechtlichen Beschränkungen seien auch auf den Rückrufanspruch anwendbar.[1974]

Schließlich sei auch der Anspruch auf Vernichtung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG aufgrund des erfolgreich von der Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands als derzeit unbegründet abzuweisen.[1975] Die vom EuGH für den Unterlassungs- und Rückrufanspruch explizit vorgesehenen, kartellrechtlichen Einschränkungen würden nach allgemeiner Auffassung ebenfalls für den Vernichtungsanspruch gelten.[1976] Denn auch die Geltendmachung des Vernichtungsanspruchs sei geeignet, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprächen, auf den Markt gelangen würden oder auf dem Markt blieben.[1977]

Auch im Entscheid vom 9.11.2017 führte das LG Düsseldorf aus, wenn der Patentinhaber kein den FRAND-Vorgaben genügendes Lizenzierungsangebot mache, stehe der Durchsetzung seines Patents gegen den vermeintlichen Verletzer ein „dilatorisches Durchsetzungshindernis“, nämlich der FRAND-Einwand als kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand entgegen.[1978]

[1967] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 417 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 416.

[1968] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 417 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 416.

[1969] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 418 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 417.

[1970] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 418 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 417.

[1971] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 418 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 417, beide mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 52, 73 – *Huawei/ZTE*.

[1972] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 418 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 417, beide mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 31.5.2016 – 6 U 55/16.

[1973] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 419 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 418.

[1974] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 419 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 418, beide mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 73 – *Huawei/ZTE*.

[1975] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 420 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 419.

[1976] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 421 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 420, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 181.

[1977] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 421 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 420.

[1978] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 26, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 65/15.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Schließlich kam das LG Düsseldorf am 11.7.2018 abermals zum Schluss, der erfolgreich erhobene Zwangslizenzeinwand führe zur (vorläufigen) Abweisung der auf Unterlassung gerichteten Klage.[1979] Der Anspruch der Klägerin auf Unterlassung aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG sei damit als derzeit unbegründet abzuweisen, da die Beklagten erfolgreich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhoben hätten.[1980] Die Klägerin habe die aus dem EuGH-Urteil folgenden Vorgaben nicht erfüllt, und solange dies nicht der Fall sei, sei der Anspruch auf Unterlassung nicht durchsetzbar.[1981] Erfülle die Klägerin aber ihre Obliegenheiten, während die Beklagten sich nicht FRAND-gemäß verhielten, seien diese Ansprüche wieder durchsetzbar.[1982]

3. Rechtfolgen bei abgelaufenem Klagepatent

Das OLG Düsseldorf hatte sich in *Mobiles Kommunikationssystem* damit auseinanderzusetzen, dass ein Patent bereits abgelaufen war.[1983] Es hielt fest, der Ablauf des Klagepatents ändere nichts daran, dass es hinsichtlich der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen entscheidend auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten ankomme und die Klage daher insoweit als derzeit unbegründet abzuweisen sei.[1984] Der Wegfall einer Patents führe nicht gleichzeitig auch zu einer Erledigung der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen, vielmehr beständen diese Ansprüche im Hinblick auf diejenigen Erzeugnisse, die der angebliche Verletzer bis zu diesem Zeitpunkt bereits im Besitz und/oder Eigentum gehabt habe bzw. die bis dahin hergestellt und geliefert worden seien, grundsätzlich fort.[1985] Da die insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Beklagten auch nicht geltend gemacht hätten, dass die Ansprüche wegen Unverhältnismäßigkeit gemäß § 140a Abs. 4 PatG ausgeschlossen seien und konkrete Anhaltspunkte dafür auch sonst wie nicht ersichtlich seien, seien im Streitfall die Ansprüche der Klägerin auf Vernichtung und Rückruf nicht erledigt.[1986]

Den demzufolge nach wie vor bestehenden klägerischen Ansprüchen könnten die Beklagten auch weiterhin den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenhalten.[1987] Das Urteil des EuGH lasse diesen Einwand beim gerichtlich geltend gemachten Rückrufanspruch ohne Einschränkungen zu.[1988] Tatsächlich greife auch nach Ablauf des Patents der vom EuGH hervorgehobene Aspekt, dass der SEP-Inhaber mit dem Rückrufanspruch verhindern könne, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprächen, auf dem Markt blieben.[1989] Eine ähnliche Zielrichtung verfolge der Vernichtungsanspruch, der dafür Sorge trage, dass derartige Produkte nicht mehr auf den Markt gelangen würden.[1990] Bezüglich der konkreten Erzeugnisse, die von einer Vernichtung oder einem Rückruf betroffen seien, wirkten sich die Maßnahmen des SEP-Inhabers mithin auch dann noch

[1979] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 252; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 265.

[1980] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 252; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 265.

[1981] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 252; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 265, beide mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 52, 73 – *Huawei/ZTE*.

[1982] LG Düsseldorf, 11.7.2018 – 4c O 77/17, Rn. 252; 11.7.2018 – 4c O 81/17, Rn. 265, beide mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 31.5.2016 – 6 U 55/16.

[1983] Vgl. OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 2, 265 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1984] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 265 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1985] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 266 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Hamburg, 30.4.2009 – 315 O 72/08.

[1986] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 266 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1987] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[1988] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 44 et seq. – *Huawei/ZTE.*

[1989] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 52, 73. – *Huawei/ZTE.*

[1990] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zum Nachteil des angeblichen Verletzers aus, wenn das Patent abgelaufen sei.[1991] Würde der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand in diesem Fall nicht mehr geltend gemacht werden können, liefe dies darauf hinaus, dass ein marktbeherrschender SEP-Inhaber, der entgegen seiner Zusage kein FRAND-gemäßes Lizenzangebot unterbreitet habe, (allein) in Bezug auf solche Produkte, die bereits vor dem Wegfall des Patents hergestellt und geliefert worden seien, zu Lasten des Lizenzwilligen in den Markt eingreifen können würde.[1992] Dies sei indes weder interessengerecht noch entspreche es dem Zweck des Fortbestehens der Ansprüche aus § 140a Abs. 1 und 3 PatG nach dem Wegfall des Schutzrechts.[1993] Dieser bestehe darin, Nachwirkungen einer rechtswidrig geschaffenen Störungszustands zu beseitigen. Da dem Verletzer der durch eine Rechtsverletzung erlangte Vorteil nicht verbleiben solle, weil er andernfalls einen Anreiz hätte, einen Wettbewerbsvorsprung, der durch die Rechtsverletzung geschaffen worden sei, zu bewahren.[1994] Diese Situation treffe aber auf einen Lizenzwilligen, dem während der Laufzeit des Patents der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand zugestanden habe, von vornherein nicht zu.[1995] Es existierten in diesem Fall kein rechtswidriger Störungszustand und keine ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteile, die es zu beseitigen gelte.[1996] Daher gebe es keinen Grund, den SEP-Inhaber hinsichtlich der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nach dem Wegfall des Schutzrechts besser zu stellen als vorher.[1997]

Demgegenüber bleibe die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auch Auskunft/Rechnungslegung sowie Schadenersatz dem Grunde nach unberührt (ausführlich unten XIII).[1998]

4. Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch bei nur mittelbarer Patentverletzung

Das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 hielt fest, der Unterlassungsanspruch bei FRAND-Verhalten des Patentinhabers beruhe auf Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG, die die Benutzung des Erfindungsgegenstandes ohne Berechtigung erfolge.[1999] Es sei auch hinsichtlich der nur mittelbaren Patentverletzung des Verfahrensanspruch durch die angegriffenen Ausführungsformen (siehe oben IV) ein Schlechthin-Verbot zu verhängen.[2000] Ein Schlechthinverbot sei regelmäßig zu erlassen, wenn das streitgegenständliche Mittel nur patentverletzend einsetzbar sei.[2001] Bei einem Mittel, das sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden könne, bestimmten sich dagegen die vom Anbieter oder Lieferant des Mittels zu treffenden Vorsorgemaßnahmen nach Abwägung aller Umstände im Einzelfall.[2002] Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssten, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern, andererseits den Vertrieb des Mittels zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise

[1991] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1992] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1993] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1994] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1995] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1996] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1997] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 267 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1998] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 269 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[1999] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 320; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 302; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 540; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 463.

[2000] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 321; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 303; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 541; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 464.

[2001] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 321; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 303; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 541; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 464.

[2002] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 321; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 303; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 541; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 464.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

behindern dürften.[2003] Als im Vergleich zum Schlechthinverbot mildere Maßnahmen zur Verhinderung von Patentverletzungen seien insbesondere Warnhinweise oder – subsidiär, fall ein Warnhinweis nicht ausreiche – der Abschluss von Unterlassungsverpflichtungs-Vereinbarungen (ggf. mit Strafbewehrung) mit Abnehmern vorrangig zu prüfen.[2004]

Zwar könnten die angegriffenen Ausführungsformen auch jenseits der Nutzung der geschützten Lehre des Klagepatents wirtschaftlich sinnvoll verwendet werden.[2005] Gleichwohl sei ein Schlechthinverbot zu verhängen.[2006] Mildere Mittel als ein Schlechthin-Verbot seien hier nicht geeignet, eine patentverletzende Nutzung der angegriffenen Ausführungsformen zu verhindern; insbesondere erschienen ein Warnhinweis oder die Verpflichtung, strafbewehrte Unterlassungsvereinbarungen mit den Kunden der angegriffenen Ausführungsformen abschließen zu müssen, hier ungeeignet.[2007] Die angegriffenen Ausführungsformen würden letztlich regelmäßig von Endverbrauchern für private Zwecke verwendet.[2008] Diesen Kunden würde die Nutzung des Klagepatents nach § 11 Nr. 1 PatG im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken nicht zu verbieten sein.[2009] Weiterhin lasse sich bei Mobiltelefonen wie den angegriffenen Ausführungsformen praktisch nicht kontrollieren, ob die geschützte Lehre verwendet werde.[2010]

Im Übrigen könne bei einer patentfreien Verwendungsmöglichkeit ein Schlechthinverbot insbesondere auch deshalb begründet sein, wenn der angegriffene Gegenstand ohne Weiteres derart abgeändert werden könne, dass er den Vorgaben des Patents nicht mehr entspreche, seine Eignung zur patentfreien Verwendung aber gleichwohl nicht einbüße.[2011] In solchen Fällen bedürfe es der patentgemäßen Ausbildung des Mittels zur Gewährleistung eines gemeinfreien Gebrauchs außerhalb des Patentes nicht; derjenige, der das Mittel anbiete oder vertreibe, könne an ihr deswegen auch kein schützenswertes Interesse haben.[2012]

Die Beklagte sei dem Vortrag der Klägerin zur Abwandelbarkeit nicht entgegen getreten.[2013] Es sei auch nicht ersichtlich, welche technischen Schwierigkeiten dabei bestehen können würden, die Nutzung der

---

[2003] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 321; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 303; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 541; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 464, alle mit Verweis auf BGH, 9.1.2007 – X ZR 173/02 – *Haubenstretchautomat* m.w.H.

[2004] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 321; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 303; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 541; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 464, alle mit Verweis auf BGH, 9.1.2007 – X ZR 173/02 – *Haubenstretchautomat* m.w.H.

[2005] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 322; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 304; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 542; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 465.

[2006] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 322; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 304; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 542; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 465.

[2007] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 322; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 304; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 542; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 465.

[2008] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 322; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 304; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 542; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 465.

[2009] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 322; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 304; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 542; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 465.

[2010] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 322; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 304; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 542; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 465.

[2011] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 323; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 305; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 543; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 466, alle mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 29.3.2012 – I-2 U 137/10, Rn. 83 und LG Düsseldorf, 23.6.2005 – 4 O 297/97.

[2012] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 323; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 305; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 543; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 466.

[2013] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 324; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 306; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 544; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 467.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

patentgemäßen Lehre zu unterbinden.[2014] Soweit die Abwandelbarkeit dadurch erschwert werde, dass wegen der Standardessenzialität des Klagepatents eine Nutzung des gesamten AVC/H-264-Standards unmöglich gemacht werde, stehe dies einem Schlechthinverbot grundsätzlich nicht entgegen.[2015] Die hiermit verbundenen nachteiligen Folgen für den Patentverletzer würden durch die kartellrechtlichen Beschränkungen des Unterlassungsanspruchs aus dem standardessentiellen Patent kompensiert.[2016] Sofern der FRAND-Einwand – wie vorliegend – nicht durchgreife, könne sich ein Patentverletzer nicht darauf berufen, eine patentfreie Abänderung der angegriffenen Ausführungsform sei deswegen nicht möglich oder unangemessen, weil hierdurch zugleich die Nutzung des Standards vereitelt werde.[2017]

Das LG Düsseldorf führte in seinen Entscheiden vom 12.12.2018 diesbezüglich gleichermaßen aus, die Verhängung eines Schlechthinverbots sei gerechtfertigt, soweit der Unterlassungsanspruch auf Benutzungshandlungen im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG gestützt sei.[2018] Ein Schlechthinverbot komme im Rahmen einer nur mittelbaren Patentverletzung regelmäßig dann nicht in Betracht, wenn die angegriffene Ausführungsform auch patentfrei benutzt werden könne.[2019] Etwas anderes gelte aber nur dann, wenn weder ein Warnhinweis, noch eine Vertragsstrafenvereinbarung Gewähr dafür bieten könnten, dass es unter Verwendung des Mittels nicht zu einer Patentverletzung komme, eine etwaige Patentverletzung für den Schutzrechtsinhaber praktisch nicht feststellbar sei und dem Lieferant ohne weiteres zumutbar sei, das Mittel so umzugestalten, dass es nicht mehr patentgemäß verwendet werden könne.[2020]

Dies sei im Streitfall zu bejahen.[2021] Denn die Nutzung der patentverletzenden AVC-Anwendung erfolge erst beim Endabnehmer der angegriffenen Smartphones, in der Regel einem privaten Endverbraucher.[2022] Diesem gegenüber würden sich Vertragsstrafenvereinbarungen verbieten.[2023] Aber auch ein Warnhinweis komme nicht in Betracht, weil dieser regelmäßig ins Leere laufen würde: Ein Hinweis, die AVC-Kompatibilität nicht nutzen zu dürfen, sei gegenüber einem Endverbraucher nicht nur unzutreffend, sondern dürfe auch ein ernsthaftes Kaufhindernis darstellen.[2024] Gleiches gelte für den Hinweis, dass die angegriffene Ausführungsform nicht AVC-fähig sei.[2025] Darüber hinaus lasse sich seitens der Klägerin nicht feststellen, ob die Abnehmer der angegriffenen Ausführungsform entgegen

[2014] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 324; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 306; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 544; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 467.

[2015] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 325; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 306; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 545; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 467.

[2016] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 325; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 306; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 545; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 467.

[2017] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4 O 15/17, Rn. 325; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 306; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 545; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 467.

[2018] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 437; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 314; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2019] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 437; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 314; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2020] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 437; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 314; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2021] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 438; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2022] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 438; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2023] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 438; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2024] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 438; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2025] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 438; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

einem Warnhinweis doch das patentgemäße Dekodierungsverfahren anwenden würden.[2026] Der Beklagten sei es hingegen ohne weiteres zumutbar, die angegriffene Ausführungsform dergestalt abzuwandeln, dass den Nutzern das geschützte Dekodierungsverfahren nicht mehr zur Verfügung stehe, indem die entsprechenden Codec-Programmbestandteile entfernt würden (auch wenn die hardware-technischen Voraussetzungen noch gegeben seien).[2027]

[2026] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 438; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

[2027] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 438; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 315; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 376; 12.12.2018 – 4b O 17/17, Rn. 300.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

XII. Gegenangebot des Standard-Implementierers

A. Verhaltensanforderungen („conduct requirement“)

1. Verhandlungen nach Treu und Glauben und Lizenzwilligkeit

Der SEP-Inhaber hat das Recht, ein FRAND Gegenangebot auf das FRAND-Angebot des Patentinhabers zu erwidern.[2028] Das Recht zum Gegenangebot (das LG Düsseldorf spricht dabei von einer „Möglichkeit“[2029]) steht dabei im Lichte der grundsätzlichen Lizenzwilligkeit. Ziel ist es, die Verhandlungen zwischen den Parteien zu forcieren. Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand greift nur durch, wenn sich der Implementierer (zumindest im Klagezeitpunkt) lizenzwillig zeigt (dazu oben IX.A). Dadurch soll die Verhandlungsbereitschaft des Benutzers gesichert werden. Auf das FRAND-Angebot des Patentinhabers hat ein Gegenangebot des Benutzers zu folgen, will er den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand geltend machen. Lizenzwilligkeit und Gegenangebot sind insofern miteinander verbunden, als sich die Frage stellt, ob ein Benutzer, der das Angebot des SEP-Inhabers ablehnt und kein Gegenangebot unterbreitet, den Zwangslizenzeinwand nicht geltend machen kann, oder ob eine eigentliche Lizenzunwilligkeit im Sinne einer grundsätzlichen Verweigerung (siehe oben IX.A.2) notwendig ist, damit der SEP-Inhaber sein Ausschließlichkeitsrecht geltend machen kann.

Die Unterbreitung eines Gegenangebots kann, nach Auffassung des LG Mannheim, zumindest mit der Hinterlegung eines Betrages, die Lizenzwilligkeit des Benutzers indizieren, da dies nicht den Schluss zulasse, es handele sich um einen von vornherein lizenzunwilligen Verhandlungspartner, dem gegenüber keine Verpflichtung bestehe darzulegen, aus welchen tatsächlichen Gründen die Angebot des SEP-Inhabers FRAND-Grundsätzen entsprächen (dazu bereits oben IX.A.2).[2030] Das FRAND-Gegenangebot kann daher gewissermaßen als Konkretisierung der Lizenzwilligkeit gesehen werden.

Um den Zwangslizenzeinwand gegenüber dem SEP-Inhaber nach einem FRAND-Angebot seinerseits geltend machen zu können, muss das Angebot des Benutzers auch FRAND sein. Das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 konkretisierte dabei die Voraussetzungen an die FRAND-Gemäßheit des Gegenangebots in generell-abstrakter Weise. Sinn und Zweck des skizzierten Verhandlungsablaufs nach der EuGH-Rechtsprechung sei, eine Verhandlungssituation anzustreben, die derjenigen im freien Wettbewerb am ehesten entspreche (dazu oben III).[2031] Dort ständen sich redliche Parteien gegenüber, die ernsthaft und ausgeglichen Verhandlungen führten und beiderseitig an einer Lizenz interessiert seien.[2032] Dabei postuliere der EuGH im Hinblick auf das Gegenangebot, es obliege dem angeblichen Verletzer, auf das Angebot des SEP-Inhabers mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben zu reagieren, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen sei und unter anderem impliziere, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt werde.[2033]

Betreffend das konkrete Gegenangebot des Benutzers sei die Kammer jedoch der Auffassung, dass es sich nach den gegebenen Umständen des Einzelfalls nicht mehr um ein sorgfältiges Angebot handele, das nach Treu und Glauben abgegeben worden sei.[2034] Dafür sei das gesamte Verhalten der Beklagten

[2028] EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 65, 66 – *Huawei/ZTE*.

[2029] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 413; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 352.

[2030] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 131 – *Funkstation*.

[2031] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 429; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 368.

[2032] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 429; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 368.

[2033] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 429; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 368, beide mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 65, 66 – *Huawei/ZTE*.

[2034] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

und ihres Konzerns in den Blick zu nehmen.[2035] Die maßgeblichen Konzerngesellschaften der Beklagten hätten seit dem Anfang der Verhandlungen eine Lizenznahme mit der Begründung abgelehnt, sie würden für die VRC beziehungsweise für bestimmte Konzernunternehmen keine Lizenzen zahlen wollen.[2036] Im Rahmen der Verhandlungen mit der Lizenzverwalterin hätten sie auch nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, mit der SEP-Inhabern (der Klägerin) in Einzelverhandlungen über ihr AVC-Portfolio zu treten.[2037] Die für die Konzerngesellschaften der Beklagten anwesenden Personen hätten sich vielmehr noch vergewissert, dass jedenfalls die Lizenzverwalterin nicht klageberechtigt sei, sondern nur die einzelnen Patentinhaber.[2038] Daraufhin habe der Konzern fünf Jahre lang die Klage gegen die Beklagte abgewartet, um erst im Rahmen des Prozesses zwei Angebote der maßgeblichen Konzerngesellschaften abzugeben, die sich nunmehr nur auf die AVC-standardessentiellen Patente der Klägerin richteten.[2039] Das gleiche Verhalten würden die Konzerngesellschaften der Beklagten im Parallelverfahren gegen eine andere Klägerin an den Tag legen.[2040]

So verhalte sich keine Partei, die ernsthaft eine FRAND-Lizenz erhalten wolle.[2041] Eine Partei, die überhaupt erst unter dem Druck des Prozesses mit einem Gegenangebot fünf Jahre nach dem Angebot der Klägerin reagiere, handele wie eine Partei, die im Grundsatz nicht an einer Lizenz interessiert sei beziehungsweise diese so lange wie möglich herauszögen wolle.[2042] Damit habe sich die Beklagte aber den Grundvoraussetzungen der seitens des EuGH intendierten Verhandlungssituation enthoben.[2043] Es handele sich nicht um das vielzitierte Verhandlungs-Ping-Pong, sondern die Beklagte habe bis zur Klageerhebung jede Gegenseitigkeit vermissen lassen.[2044] Vor diesem Hintergrund bewege sich die Beklagte mit ihren Angeboten nicht mehr im Rahmen des Verhandlungskorridors, der desjenigen im freien Wettbewerb entspreche.[2045]

2. Angebotshandlung und Qualifikation als Gegenangebot

Das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 hatte sich damit auseinanderzusetzen, inwiefern das Zusenden eines unterzeichneten Standardlizenzvertrags, der im Internet abrufbar ist, als Annahmehandlung, beziehungsweise als Gegenangebot zu qualifizieren ist. Die Lizenzverwalterin hatte den auf ihrer Internetseite abrufbaren Standardlizenzvertrag der Muttergesellschaft der Beklagten als FRAND-gemäßes Angebot zur Lizenzierung des gesamten Konzerns zugeschickt. Die Beklagte, als Tochterunternehmen, sandte der Lizenzverwalterin dann den im eigenen Namen unterzeichneten Standardlizenzvertrag zurück, und machte im Gerichtsverfahrend geltend, sie habe das im Internet publizierte Angebot zur Lizenzierung nur der Tochtergesellschaft angenommen.[2046]

Nach dem LG Düsseldorf sei die Zusendung der unterzeichneten Standardlizenzverträge als (nicht FRAND-konformes) Gegenangebot zu werden, hingegen könne darin nicht die Annahme eines von der Lizenzverwalterin unterbreiteten Angebots erblickt werden.[2047] Die bloße Abrufbarkeit des Standardlizenzvertrags über die Internetseite der Lizenzverwalterin stelle noch keine

[2035] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2036] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2037] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2038] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2039] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2040] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2041] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 431; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 370.
[2042] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 431; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 370.
[2043] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 432; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 371.
[2044] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 432; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 371.
[2045] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 432; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 371.
[2046] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 311; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 293.
[2047] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 312; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 294.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Angebotshandlung dar, sondern diese vielmehr der Information über die Lizenzbedingungen (dazu oben XI.A.1).[2048] Eine Zusendung des Standardlizenzvertrags, die als Angebotshandlung verstanden werden könne, sei allein an die Muttergesellschaft der Beklagten (zur konzernweiten Lizenzierung) erfolgt.[2049] Die Zusendung seitens der Beklagten sei daher als Gegenangebot zu qualifizieren, dass mangels Angebot konzernweiter Lizenzierung nicht FRAND sei.

Den diesbezüglich gleichen Sachverhalt beurteilte auch die Kammer 4b des LG Düsseldorf gleich. Die übermittelten unterzeichneten Standardlizenzverträge stellten ein Gegenangebot und nicht die Annahme des klägerischen Angebots dar.[2050] Die bloße Bereitstellung im Internet sei kein Angebot, sondern allenfalls eine *invitatio ad offerendum*, und das klägerische Angebot sei wiederum allein an die Muttergesellschaft der Beklagten erfolgt.[2051]

Schließlich äußerte sich das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 auch dahingehend, die FRAND-Gemäßheit des ersten (von zwei) Gegenangeboten der Beklagten könne im Grundsatz dahinstehen, da es vom zweiten Gegenangebot abgelöst worden sei.[2052] Nur bei letzterem handele es sich um die aktuellen Lizenzbedingungen, die die Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung zur Disposition gestellt habe und an die sich gebunden fühlen würde.[2053]

3. Rechtzeitigkeit des Gegenangebots

Die zeitlichen Anforderungen an das Gegenangebot wurden offengelassen vom LG Düsseldorf in den Entscheiden vom 9.11.2018.[2054] Ein fünfjähriges Abwarten der Beklagten bis zum Prozess ließ das LG Düsseldorf vom 12.12.2018 dabei nicht mehr als FRAND gelten, da es dies als Teil einer Verzögerungstaktik wertete und das Gegenangebot (unter anderem) daher nicht mehr FRAND sei, da das Zuwarten nicht mehr dem Leitbild redlich handelnder Verhandlungsparteien vereinbar sei.[2055] Zu den allgemeinen Anforderungen an Rechtzeitigkeit und Nachholbarkeit, siehe oben II, III.

B. Sachlich-inhaltliche Anforderungen („content requirement“)

1. Allgemeine Bemerkungen zu den sachlich-inhaltlichen Anforderungen

2. Gegenangebot zur Lizenzierung nur der Tochtergesellschaft

In den Entscheiden vom 9.11.2018 hatte sich das LG Düsseldorf zur Frage zu äußern ob bei einer branchenüblichen konzernweiten Lizenz das Gegenangebot einer beklagten Tochtergesellschaft zur Lizenzierung nur dieser FRAND ist. Ein solches Gegenangebot erweise sich jedoch als nicht FRAND-gemäß.[2056] Einer FRAND-Gemäßheit des Angebots stehe entgegen, dass der Standardlizenzvertrag allein zwischen der Lizenzverwalterin und der beklagten Tochtergesellschaft, nicht hingegen auch mit deren Muttergesellschaft bzw. den übrigen konzernverbundenen Unternehmen, zustande komme.[2057] Grundsätzlich sei es – vor dem Hintergrund, dass eine konzernbezogene Lizenz branchenüblich sei – hinzunehmen, dass die Poolpatentinhaber nur bereit seien, eine Lizenz zu vergeben, die sich auf den

[2048] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 312; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 294.

[2049] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 312; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 294.

[2050] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 303; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 291.

[2051] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 303; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 291.

[2052] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 414; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 353.

[2053] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 414; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 353.

[2054] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 311; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 293; 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 520; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 443.

[2055] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.

[2056] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 313; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 295.

[2057] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 314; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 296.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gesamten Konzern erstrecke (dazu bereits oben XI.B.2.c)1)).[2058] Das gelte gerade auch bei Beachtung des Diskriminierungsverbots, denn der Abschluss einer Poollizenz entsprechen dem mit den bisherigen Lizenznehmern praktizierten Lizenzmodell.[2059]

Auch unter Angemessenheitsgesichtspunkten gelte nicht deshalb etwas anderes, weil die Beklagte – im Unterschied zu ihrer Muttergesellschaft – zur Lizenznahme bereit sei, und sie auf die Muttergesellschaft keinen Einfluss dahingehend nehmen könne, dass diese den Standardlizenzvertrag abschließe.[2060] Zwar sei der Einwand der Beklagten, dass sie nämlich nicht mehr tun könne, um sich ihrerseits FRAND-gemäß zu verhalten und sich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zu erhalten, grundsätzlich erheblich.[2061] Denn auch bei konzernverbundenen Unternehmen handele es sich um juristisch eigenständige Personen, so dass eine Zurechnung des Verhaltens der einen zu der anderen Person nicht ohne das Vorliegen besonderer Umstände möglich sei.[2062] Die vorliegend zur Entscheidung stehende Konstellation sei jedoch dadurch gekennzeichnet, dass die Beklagte eine 100-prozentige Tochter des Muttergesellschaft sei, letztere mithin das Verhalten der Beklagten bestimme.[2063] Dadurch könne diese für einen Gleichlauf der Lizenzen im Sinne der Branchenübung sorgen, indem sie sich ihrerseits zur Lizenznahme bereiterkläre.[2064] Dass die Beklagte – vor dem Hintergrund der Verweigerung der Muttergesellschaft, das FRAND-gemäße Angebot der Lizenzverwalterin anzunehmen – unangemessen behandelt werde, lasse sich somit nicht feststellen.[2065] Vielmehr stehe im Raum, dass die Muttergesellschaft ihrerseits eine auf einzelne Unternehmen bezogene Lizenzierung durchsetze, indem sie – vermittelt über die beklagte Tochtergesellschaft – lediglich der Lizenznahme einzelner Tochterunternehmen zustimme.[2066] Der vorliegende Sachverhalt sei weite dadurch gekennzeichnet, dass die Muttergesellschaft hals vorübergehendes Poolmitglied in besonderer Weise zur Lizenznahme Anlass gehabt habe, um sich nicht selbst treuwidrig gegenüber dem Pool zu verhalten.[2067]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 setzte sich das LG Düsseldorf mit dem diesbezüglich selben Sachverhalt auseinander. Wie bereits die Kammer 4a zum Schluss kam, entspreche ein Standardlizenzvertrag zwischen der Lizenzverwalterin und der Beklagten allein nicht FRAND-Grundsätzen.[2068] Aus den bereits erörterten Gründen (vgl. dazu oben XI.B.2.c)1)) sei eine Konzernlizenz grundsätzlich branchenüblich.[2069] Hier stehe die Beachtung des Diskriminierungsverbots im Vordergrund, denn der Abschluss des Standardlizenzvertrages entspreche dem mit den anderen Lizenznehmern praktizierten Lizenzmodell.[2070] Da die Muttergesellschaft bzw. der Konzern der Beklagten auch unstreitig weltweit tätig sei, erschließe sich nicht, inwieweit die Beklagte einen sachlichen Rechtfertigungsgrund für eine Ungleichbehandlung geltend machen könne (zum Diskriminierungsverbot oben XI.B.3.b)2)).[2071]

[2058] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 315; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 297.
[2059] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 315; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 297.
[2060] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 316; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 298.
[2061] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 317; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 299.
[2062] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 317; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 299.
[2063] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 317; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 299.
[2064] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 317; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 299.
[2065] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 317; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 299.
[2066] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 317; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 299.
[2067] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17, Rn. 317; 9.11.2018 – 4a O 16/17, Rn. 299.
[2068] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 304; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 292.
[2069] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 305; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 293.
[2070] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 305; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 293.
[2071] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 305; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 293.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Ferner könne die Beklagte, wie auch schon die Abteilung 4a feststellte, nicht wirksam ins Feld führen, sie könne nur eine Annahme für sich erklären.[2072] Zwar sei dieser Einwand im Grundsatz erheblich, weil die Beklagte eine eigenständige juristische Person darstelle, jedoch bestehe vorliegend die Besonderheit, dass die Beklagte eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft sei.[2073] Die Muttergesellschaft bestimme das Verhalten der Beklagten und könne somit durch eine selbstständige Lizenznahme für einen Gleichlauf der Lizenzen sorgen.[2074] Dies werde auch dadurch bestätigt, dass das „Intellectual Property"-Strategiekomitee, dessen Vorsitz der CEO innehabe, die IP-Strategie des Unternehmens kontrolliere und alle wichtigen Entscheidungen überprüfe.[2075] Eine unangemessene Behandlung der Beklagten sei daher nicht nachvollziehbar.[2076] Insoweit könne sich die Beklagte auch nicht auf die durch die nationale Reichweite der Patente bedingte Relativität des gesetzlichen Schuldverhältnisses zurückziehen und anführen, sie sei in diesem Verfahren allein Schuldnerin des Unterlassungsanspruchs.[2077] Diese nationale Beschränkung werde den globalen Marktbegebenheiten nicht gerecht und werde durch den Konzern der Beklagten vielmehr ausgenutzt, um unter dem Druck der Klage nur in dem Umfang eine Lizenz zu nehmen, wie sie durch die Reichweite des Titels erzwungen sei.[2078] Faktisch setze damit aber die Muttergesellschaft ihrerseits eine auf einzelne Unternehmen bezogene Lizenzierung durch, indem sie vermittelt durch die Beklagte lediglich der Lizenznahme einzelner Tochterunternehmen zustimme.[2079]

Der Eindruck, dass die Muttergesellschaft die Beklagte letztlich nur „vorschiebe", werde auch durch das bereits geschilderte vorprozessuale Verhalten der Muttergesellschaft erhärtet (dazu bereits oben XII.A.1).[2080] Dieses Verhalten sei gerade nicht mit dem Postulat des EuGH vereinbar, dass der Verletzer auf das klägerische Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten nach Treu und Glauben, zu reagieren habe, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmten sei und unter anderem impliziere, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt werde.[2081] Hier habe die Muttergesellschaft durch ihr ambivalentes Verhalten über Jahre ernsthafte Verhandlungen blockiert und sich überhaupt nicht konkret zu den einzelnen Modalitäten der Lizenz verhalten.[2082] Vor diesem Hintergrund stelle es keine redlichen und ernsthaften Verhandlungen über eine Lizenz im Mobilfunkbereich dar, wenn die Muttergesellschaft sich der Lizenz entziehe und ihre Tochtergesellschaft isoliert unter dem Druck eines drohenden Unterlassungstitels lizenzieren möchte.[2083]

3. Einräumung einer Portfoliolizenz statt einer Poollizenz

Das LG Düsseldorf vom 9.11.2018 hatte sich mit dem Begehren der Beklagten in ihrem Gegenangebot auseinanderzusetzen, bloß eine Lizenz am standardwesentlichen Portfolio der Klägerin, und nicht am

[2072] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294.

[2073] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294.

[2074] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17.

[2075] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294.

[2076] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294.

[2077] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294.

[2078] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294.

[2079] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 306; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 294, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 15/17.

[2080] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 307; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 295.

[2081] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 307; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 295, beide mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 65, 66 – *Huawei/ZTE*.

[2082] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 307; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 295.

[2083] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 307; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 295.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gesamten Patentpool, zu nehmen.[2084] Dies entspreche nicht FRAND-Grundsätzen, da das Begehren der Klägerin zum Abschluss einer Poollizenz sich als fair und angemessen erweise (dazu bereits oben VI.B.1) und die Klägerin zudem vorgetragen habe, dass seit Aufnahme des Pools auch kein Lizenznehmer um eine auf ihre Poolpatente beschränkte Lizenz nachgesucht habe.[2085] Eine Pflicht der Poolmitglieder, abweichend von dieser Lizenzierungspraxis auf ihr Portfolio beschränkte Lizenzen einzuräumen ergebe sich auch nicht aus den Klauseln des Standardlizenzvertrages.[2086]

Auch unter Angemessenheitsgesichtspunkten sei nicht erkennbar, weshalb die Beklagte allein eine auf das Portfolio der Klägerin beschränkte Lizenz benötige – etwa, weil nur diese bei den angegriffenen Ausführungsformen zur Anwendung gelange.[2087] Dagegen stehe schon, dass die Beklagte auch in den Parallelverfahren gegenüber anderen Poolmitgliedern jeweils die Erteilung einer Portfoliolizenz anstrebe.[2088]

Vor dem Hintergrund der etablierten Lizenzierungspraxis in Form einer Poolpatentlizenz sei es schließlich auch aus Gründen der Diskriminierungsfreiheit bedenklich, wenn die Klägerin vereinzelt – ohne erkennbaren sachlichen Grund – Lizenzen allein an ihrem Portfolio vergebe.[2089] Das LG Düsseldorf verwies dabei auf die gleiche Argumentation im Verhältnis Forderung einer Einzellizenz bei Branchenüblichkeit einer Portfoliolizenz in einem früheren Entscheid.[2090]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 setze sich das LG Düsseldorf mit dem Gegenangebot der Beklagten auseinander, das die Lizenzierung nur des klägerischen Portfolios anstelle des gesamten Pools verlangte. So sei festzuhalten, dass allein der Umstand, dass ein Angebot auf eine weltweite Lizenz ausschließlich am klägerischen standardessentiellen Portfolio einschließlich der Poolpatente und der außerhalb des Pools gehaltene SEPs nicht per se als missbräuchlich zu qualifizieren sei.[2091] Beide Parteien hätten ein Wahlrecht, sowohl eine Individuallizenz als auch eine Poollizenz anzubieten.[2092] Diese Möglichkeit werde zu Recht im Standardlizenzvertrag vorgesehen, da ansonsten die Poolverwaltungspraxis der Lizenzverwalterin ihrerseits kartellrechtswidrig wäre (siehe oben VI.B.1.a)).[2093]

Etwas anderes folge insoweit auch nicht aus der Entscheidung *Videosignal-Codierung III*, in der die Kammer hinsichtlich des Vorgängerstandards und dem Vorgänger-Standardlizenzvertrag, der ebenfalls die Option einer Poollizenz oder Einzellizenz an dem Klagepatent vorgesehen habe, geurteilt, dass die Beklagte keine dritte Option in Form einer Poollizenz nur für Deutschland zustehe.[2094] Im Unterschied dazu habe die hiesige Beklagte aber einfach nur Gebrauch von einer der zwei möglichen Optionen gemacht.[2095]

[2084] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 521; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 444.

[2085] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 522; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 445.

[2086] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 523–29; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 446–52.

[2087] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 530; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 453.

[2088] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 530; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 453.

[2089] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 531; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 454.

[2090] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 531; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 454, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 73/14, Rn. 227.

[2091] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 423; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 362.

[2092] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 424; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 363.

[2093] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 424; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 363.

[2094] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 424; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 363, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 11.9.2008 – 4b O 78/07 – *Videosignal-Codierung III*.

[2095] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 424; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 363.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Die reine Wahrnehmung der Wahlmöglichkeit, sich nur das klägerische Portfolio lizenzieren zu lassen, sei für sich genommen kartellrechtlich neutral.[2096] Aus dem Passus der Präambel des Standardlizenzvertrags resultiere allerdings kein Anspruch der Beklagten auf den Abschluss einer solchen Individuallizenz, da die Klägerin ihr Wahlrecht zugunsten einer Poollizenz ausgeübt habe.[2097] Ihre Vertragsfreiheit wäre nur eingeschränkt, wenn Umstände vorlägen, die es sachlich rechtfertigten, die Beklagte anders als die anderen Lizenznehmer zu behandeln und die Klägerin insoweit zum Abschluss einer Individuallizenz gezwungen werden würde.[2098] Dies sei hier jedoch nicht der Fall, so dass sich die Beklagte auf eine Poollizenz hätte einlassen müssen.[2099] Es wäre mit der Vertragsfreiheit unvereinbar, könne die Beklagte ohne sachlichen Grund auf ihrer Forderung bestehen und die Klägerin abweichend von dem von ihr praktizierten Lizenzierungsmodell einer Poollizenz in einen Individuallizenzvertrag zwingen.[2100] Die Beklagte, die sich bereits mit einem FRAND-gemäßen Angebot seitens der Klägerin konfrontiert sehe, habe nicht dargelegt warum für sie ausschließlich ein individueller Lizenzvertrag mit der Klägerin gerechtfertigt sei.[2101] Zu berücksichtigen sei hier, dass auch die SEPs, die die Klägerin außerhalb des Pools halte, mit dem Standardlizenzvertrag aufgrund einer internen Absprache der Pool-Mitglieder mitlizenziert würden.[2102] Insofern werde sie mit der Wahl des Standardlizenzvertrages nicht schlechter gestellt.[2103] Das geäußerte Interesse der Beklagten, ihr gewohntes Lizenzierungsmodell in Gestalt von Kreuzlizenzen beizubehalten sei für sich genommen nichts, was einen zwingenden Grund darstelle, warum die Annahme einer Poollizenz für die Beklagte Ausscheide.[2104] Dies vor allem auch nicht, weil sie selbst keine AVC-SEPs halte und insofern nur mit Schutzrechten aus anderen Technologien kreuzlizenzieren könne.[2105] Objektiv betrachtet bevorzuge die Beklagte eine vertragliche Vereinbarung, die sie nach objektiven Kriterien schlechter stelle: Sie müsse einzelne Lizenzvertragsverhandlungen mit allen Pool-Mitgliedern durchführen, auf sie kämen insgesamt höhere Lizenzzahlungen zu sowie mehr Transaktionskosten, und sie bekommen im Ergebnis nicht mehr Rechte lizenziert, als sie über den Standardlizenzvertrag faktisch auch erhalten würde.[2106]

Selbst wenn man dies anders sehe wollen würde, stehe dem FRAND-Charakter des Gegenangebots noch ein weiterer grundlegender und für die Kammer ausschlaggebender Punkt entgegen.[2107] Wie bereits erwähnt, sei Sinn und Zweck des skizzierten Verhandlungsablaufs nach der EuGH-Rechtsprechung, eine Verhandlungssituation anzustreben, die derjenigen im freien Wettbewerb am ehesten entspreche.[2108] Dort ständen sich redliche Parteien gegenüber, die ernsthaft und ausgeglichen Verhandlungen führten und beiderseitig an einer Lizenz interessiert seien.[2109] Die Kammer sei der Auffassung, dass es sich nach den gegebenen Umständen dieses Einzelfalls nicht mehr um ein sorgfältiges Angebot, dass nach Treu und Glauben abgegeben worden sei, handele.[2110] Hierfür sei das gesamte Verhalten der Beklagten und ihres Konzerns in den Blick zu nehmen.[2111] Im Rahmen der

[2096] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 425; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 364.
[2097] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 426; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 365.
[2098] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 426; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 365.
[2099] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2100] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2101] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2102] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2103] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2104] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2105] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2106] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 427; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 366.
[2107] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 428; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 367.
[2108] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 429; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 368.
[2109] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 429; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 368.
[2110] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2111] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verhandlungen mit der Lizenzverwalterin hätten sie nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, mit der Klägerin in Einzelverhandlungen über ihr AVC-Portfolio zu treten, sondern der Konzern habe fünf Jahre lang die Klage gegen die Beklagte abgewartet, um erst im Rahmen des Prozesses zwei Angebote der maßgeblichen Konzerngesellschaften abzugeben, die sich nunmehr nur auf die AVC-standardessentiellen Patente der Klägerin richteten.[2112] Das gleiche Verhalten hätten die Konzerngesellschaften der Beklagten im Parallelverfahren vor der Kammer gegen eine andere Klägerin an den Tag gelegt.[2113] So verhalte sich keine Partei, die ernsthaft eine FRAND-Lizenz erhalten wolle.[2114]

4. Differenzierung der Lizenzhöhe nach unterschiedlichen Regionen

Das LG Düsseldorf hielt in den Entscheiden vom 9.11.2018 weiter fest, das Gegenangebot der Beklagten erweise sich auch vor dem Hintergrund als FRAND-widrig, als darin eine Differenzierung der Lizenzhöhe nach unterschiedlichen Regionen vorgenommen werde, ohne dass dies in einem hinreichenden Bezug zu den tatsächlichen Marktverhältnissen stehe.[2115] Die vorgeschlagene Gebührenregelung hätten Stücklizenzen für die EU rund das 1,8-fache der für „China und andere Länder“ veranschlagten Gebühren und für die USA rund das 7-fache der für „China und andere Länder“ angesetzten Stücklizenzen betragen.[2116] Die Beklagte habe angeführt, sie habe bei der Bemessung dieser Lizenzgebühren die Tatsache berücksichtigt, dass es sich bei dem chinesischen Markt um einen Markt handele, auf dem der mit Smartphones erzielbare Kaufpreis geringer als in der USA und der EU sei, und weiter habe sie berücksichtigt, dass die Patentdurchsetzung in China erschwert sei.[2117] Dies erweise sich nach dem LG aufgrund zweier Gesichtspunkte als unangemessen.[2118]

Zum einen sei nicht schlüssig dargetan, dass es sich bei dem chinesischen Markt um einen niedrigpreisigen Mobilfunkmarkt handele, und dies noch dazu in einem Größenverhältnis, welches eine Korrektur um 50% rechtfertige.[2119] Zum andere führe die Beklagte keinerlei Gründe dafür an, weshalb neben China auch in allen weiteren Ländern außerhalb der USA und der EU der Ansatz eines niedrigeren Lizenzsatzes gerechtfertigt sei.[2120] Das erweise sich als umso zweifelhafter als die Beklagte selbst Japan als hochpreisigen Markt neben den USA qualifiziert habe.[2121] Mit einer bei Poolpatenten hinnehmbaren Pauschalisierung von Marktbedingungen (dazu oben VI.B.1) könne dieses Vorgehen jedenfalls nicht mehr begründet werden, denn die Beklagte selbst mache ja gerade die unterschiedlichen Marktbedingungen als Kriterium für eine Differenzierung in den Lizenzhöhen aus, kombiniere dann aber – im Widerspruch dazu – doch einen nach ihrem Vortrag niedrigpreisigen mit einem hochpreisigen Markt.[2122]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 hielt das LG Düsseldorf fest, das Gegenangebot der Beklagten enthalte eine unfaire Unterscheidung von Lizenzraten in Bezug auf die regionale Nutzung, indem es die regionalen Märkte USA, EU und „VRC und andere“ unterscheide.[2123] Die regionale Unterscheidung als solche erscheine bereits vor dem Umstand fragwürdig, dass die Preisgestaltung der Beklagten

[2112] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2113] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 430; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 369.
[2114] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 431; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 370.
[2115] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 532; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 455.
[2116] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 533; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 456.
[2117] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 534; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 457.
[2118] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 535; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 458.
[2119] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 536; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 459.
[2120] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 536; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 459.
[2121] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 536; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 459.
[2122] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 536; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 459.
[2123] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 415–19; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 354–58.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

bezüglich ihrer Mobiltelefone zwischen den Kontinenten so gut wie keine Unterschiede zeige.[2124] Auch sei nicht schlüssig dargetan, warum neben der VRC auch der Rest der Welt zum niedrigpreisigen Mobilfunkmarkt zählen solle.[2125] Das sei insofern zweifelhaft, als die Beklagte selbst Japan als einen hochpreisigen Markt bezeichne.[2126] Da die Beklagte gerade die angeblich unterschiedlichen Marktbedingungen als Kriterium für eine Differenzierung heranziehe, könne sie dieses nicht willkürlich vernachlässigen, indem sie einen hochpreisigen mit einem niedrigpreisigen Markt kombiniere.[2127] Es sei sachlich nicht begründet, wieso Nutzungen in Japan, das ansonsten auch von der Beklagten in ihren Absatzübersichten sogar separat von Asien geführt werde, nunmehr ebenso wie solche in der VRC vergütet werden sollten.[2128]

5. Rückwirkung des Lizenzvertrags

In den Entscheiden vom 9.11.2018 hatte sich das LG Düsseldorf auch damit auseinanderzusetzen, dass das Gegenangebot der Beklagten ohne weitere Ausführung eine Rückwirkung des Lizenzvertrags vorgesehen hatte.[2129] Mangels diesbezüglicher Ausführungen sei die FRAND-Gemäßheit des Gegenangebots auch insoweit schon nicht hinreichend dargetan.[2130]

[2124] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 420; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 359.

[2125] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 421; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 360.

[2126] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 421; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 360.

[2127] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 421; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 360, beide mit Verweis auf LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4b O 17/17.

[2128] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 421; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 360.

[2129] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 537; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 460.

[2130] LG Düsseldorf, 9.11.2018 – 4a O 17/17, Rn. 537; 9.11.2018 – 4a O 63/17, Rn. 460.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

XIII. Schadenersatzansprüche, Anspruch auf Auskunft- und Rechnungslegung

A. Bestand

1. Generell

Das OLG Düsseldorf führte mit Beschluss vom 30.3.2017 aus, die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadenersatz blieben dem Grunde nach von einer Nicht-FRAND-Gemäßheit des klägerischen Angebots unberührt (im Gegensatz zu den klägerischen Ansprüchen auf Unterlassung und Rückruf, dazu oben XI.C.2), weil diese – im Gegensatz zu den übrigen klägerischen Anspruchskategorien – keine unmittelbaren Auswirkungen darauf hätten, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprächen, auf den Markt gelangen würden oder blieben.[2131] Die Vorinstanz habe folglich dem Grunde nach zutreffend festgestellt, dass die Beklagten der Klägerin gesamtschuldnerisch zu Schadenersatz verpflichtet seien (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG).[2132]

Ohne Erfolg bleibe auch die Rüge der Beklagten, sie seien jedenfalls mangels eines Verschuldens nicht schadenersatzpflichtig.[2133] Für die Begründung der Schadenersatzhaftung nach § 139 Abs. 2 PatG genüge bereits die fahrlässige rechtswidrige Benutzung einer patentierten Erfindung.[2134] Fahrlässig sei ausweislich der Legaldefinition in § 276 BGB die Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.[2135] Im gewerblichen Rechtsschutz würden strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gestellt; wer seine Interessen trotz zweifelhafter Rechtslage auf Kosten fremder Rechte wahrnehme, trage grundsätzlich das Risiko einer unzutreffenden rechtlichen Beurteilung.[2136] Das erforderliche Verschulden werde durch die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlung indiziert, weshalb der Verletzer die seiner Entlastung dienenden Umstände vortragen müsse.[2137]

Auch reine Händler seien vor Aufnahme ihrer Tätigkeit grundsätzlich verpflichtet, sich nach entgegenstehenden Schutzrechten zu erkundigen.[2138] Die Kenntnis der für sein Fachgebiet einschlägigen Patente und Patentanmeldungen werde daher von Unternehmen erwartet.[2139] Der inländische Importeur habe eine besondere Prüfungspflicht und dürfe sich etwa auf Angaben des ausländischen Herstellers nicht verlassen, insbesondere nicht auf die nur pauschale Erklärung, eine Patentverletzung liege nicht vor.[2140] Die Prüfungspflicht bestehe bei Aufnahme von Vertrieb bzw. Produktion.[2141] Erfahre der Verletzer die den Verletzungstatbestand begründenden Umstände ohne Verletzung seiner Prüfungspflichten erst nach Aufnahme von Produktion bzw. Vertrieb, so sei ihm eine angemessene Frist zur Prüfung der Rechtslage zuzubilligen, soweit der Verletzungstatbestand nicht ohne weiteres erkennbar sei.[2142] Eine Überlegungsfrist könne indessen entbehrlich sein, wenn der

[2131] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 269 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2132] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 272 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2133] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 273 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2134] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 274 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2135] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 274 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2136] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 274 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 16.12.1986 – KZR 36/85 – *Taxi-Ruf-Zentrale*.

[2137] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 274 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 26.1.1993 – X ZR 79/90 – *Wandabstreifer*.

[2138] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2139] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2140] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 13.4.1978 – 2 U 73/77.

[2141] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2142] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verletzer bereits vorher in ausreichend konkreter Form auf das zu erwartende Schutzrecht hingewiesen worden sei.[2143] Die Einholung sachkundigen Rats von erfahrenen Patentanwälten oder patentrechtlich erfahrenen Rechtsanwälten sei zumeist erforderlich, um dem Vorwurf des Verschuldens entgehen zu können, wobei selbst in diesem Falle der Verschuldensvorwurf nicht notwendig entfalle.[2144] Selbst eine günstige Stellungnahme eines Gutachters schließe nicht notwendig ein Verschulden des Verletzers aus; jedenfalls erspare sie ihm keinesfalls eine sorgfältige eigene Prüfung der Sachlage, etwa wenn die Begründung eines günstigen Gutachtens nicht aus sich heraus überzeuge.[2145] Auch insoweit gelte, dass auf eigenes Risiko handele, wer bei zweifelhafter Rechtslage seine Interessen auf Kosten anderer wahrnehme.[2146] Diese Sorgfaltspflichten würden auch für komplexe technische Gegenstände gelten (wie etwa DVD-Player u.Ä.), bei denen etwaige Patentverletzungen nur mit einem für den Händler beträchtlichen Aufwand festzustellen seien.[2147]

Gemäß diesen Grundsätzen stehe das Verschulden der Beklagten für den gesamten Zeitraum seit der Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents zuzüglich der üblichen Karenzzeit von einem Monat außer Frage.[2148] Dies gelte in Anwendung der oben erfolgten Erläuterungen zweifelsohne für solche Benutzungshandlungen der Beklagten, die nach dem ausdrücklichen Verletzungshinweis der Klägerin erfolgt seien.[2149] Insoweit könne nichts Anders gelten als ein einem Falle, in dem der Verletzer eine Abmahnung in Bezug auf die Verletzung erhalten habe.[2150]

Aber auch für die davor liegenden Benutzungshandlungen liege ein (zumindest einfach) fahrlässiges Handeln der Beklagten vor.[2151] Ihr Einwand, es gebe keinen Mobilfunkgerätehersteller, der in der Lage wäre, Mobilfunkgeräte auf den Markt zu bringen, die nicht von irgendwelchen standardessentiellen Patenten, an denen er keine Lizenzen habe, Gebrauch machen würden, knüpfe zwar ersichtlich an die Erwägungen des EuGH an, dass dem Verletzer ein SEP möglicherweise unbekannt sein könne.[2152] Mit diesen Überlegungen sei es zwar gerechtfertigt, dem SEP-Inhaber zwecks Einleitung des Lizenzierungsprocedere vorsorglich einen Hinweis auf die Verletzung abzuverlangen, um dem anderen Teil Gelegenheit zu geben, sich über dessen Lizenzwilligkeit klar zu werden.[2153] Ob zuvor erfolgte Benutzungshandlungen allerdings schuldhaft vorgenommen worden seien, sei eine davon sorgsam zu trennende Rechtsfrage.[2154] Letzteres gelte schon deshalb, weil (wie ausgeführt) für die Begründung der Schadenersatzhaftung schon – keine Kenntnis voraussetzende – Fahrlässigkeit genüge, während Anlass für die Etablierung der Pflicht zum Verletzungshinweis durch den EuGH gewesen sei, einer potentiellen Unkenntnis des jeweiligen SEP vorzubeugen, damit der Erfolg der gebotenen Lizenzverhandlungen nicht von vorn herein daran scheitere.[2155] Vor diesem Hintergrund möge den Beklagten daher zuzugestehen sein, dass die Benutzung von Patenten im Mobilfunkbereich aufgrund

[2143] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2144] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 30.11.1976 – X ZR 81/72 – *Kunststoffhohlprofil.*

[2145] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2146] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG München, 31.5.2012 – 6 U 3770/11.

[2147] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 275 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Mannheim, 6.6.2006 – 2 O 242/05 – *Halbleiterbaugruppe*.

[2148] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 276 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2149] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 277 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2150] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 277 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 16.2.2006 – I-2 U 32/04 und LG Düsseldorf, 20.1.2012 – 4a O 7/09 – *Transglutaminase*.

[2151] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2152] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2153] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2154] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2155] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

der bekanntermaßen bestehenden „Patentdickichte“ bisweilen schwierig zu erkennen sei.[2156] Aber gerade wegen dieser unübersichtlichen Gegebenheiten sei es in besonderem Maße erforderlich, dass selbst ein Händler strenge Sorgfalt walten lassen müsse, um Patentverletzungen vorzubeugen.[2157] Die Beklagten hätten dieser Situation nicht hinreichend Rechnung getragen.[2158]

Soweit sie im Zusammenhang mit der Benutzungsdiskussion ein Privatgutachten eingereicht hätten, vermöge dieses den Vorwurf der Fahrlässigkeit nicht zu entkräften.[2159] Das Privatgutachten gehe ersichtlich von einer unzutreffenden Auslegung des Klagepatentanspruchs aus und verneine zudem mit nicht überzeugenden Erwägungen eine zwingende Umsetzung der Anspruchsmerkmale im Release 4 des GPRS-Standards.[2160] Überdies lasse es außer Acht, dass es allein auf die objektive Eignung zur Benutzung der klagepatentgemäßen Lehre und nicht darauf ankomme, ob die angegriffenen Ausführungsformen diese jeweils auch tatsächlich verwenden würden.[2161] Es fehle mithin an der notwendigen Gesamterheblichkeit des Privatgutachtens.[2162] Die ausgeführten Mängel im Privatgutachten hätten die Beklagten bei der gebotenen sorgfältigen Prüfung der Sachlage selbst feststellen können.[2163] Daher sei für sie erkennbar gewesen, dass es sie vom Vorwurf der fahrlässigen Patentverletzung nicht zu entlasten vermöge.[2164]

Im Übrigen hätten sich die Beklagten (sinngemäß) schlicht mit dem Hinweis auf die oben geschilderte allgemeine Problematik im Telekommunikationsbereich begnügt.[2165] Daher sei es ihnen keineswegs gelungen, ihr aufgrund der Rechtswidrigkeit der Benutzung des Klagepatents indiziertes Verschulden zu widerlegen.[2166]

Das Verschulden der Beklagten übersteige aus den genannten Gründen den Grad einer leichten Fahrlässigkeit, für den § 139 Abs. 2 S. 2 aF. PatG vorgesehen habe, dass das Gericht statt des Schadenersatzes eine Entschädigung festsetzen könne, die in den Grenzen des zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil bleibe, der dem Verletzer erwachsen sei.[2167] Trotz des – von den Parteien nicht erörterten – Umstandes, dass die Erteilung des Klagepatents noch vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 mit Wirkung zum 1. September 2008 erfolgt sei, mit dem die Regelung des § 139 Abs. 2 S. 2 aF. PatG aufgehoben und durch den neuen Satz 2 von § 139 PatG ersetzt worden sei, ergebe sich daher im Ergebnis nichts Abweichendes für die Schadenersatzhaftung: Zwar sei maßgeblich für die Beurteilung der Schadenersatzpflicht diejenige Rechtslage, die zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung bestanden habe.[2168] Mangels bloßer Leichtfertigkeit der Beklagten auch im Zeitraum vor dem 1.9.2008 wirke sich die seinerzeit noch anders gelagerte Rechtslage allerdings nicht entscheidungserheblich aus.[2169]

Das LG Düsseldorf führte in den Entscheiden vom 13.7.2017 aus, die Durchsetzbarkeit des Schadensersatzanspruchs sowie des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs sei durch den

[2156] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2157] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2158] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 278 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2159] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2160] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2161] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2162] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2163] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2164] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 279 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2165] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 280 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2166] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 280 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2167] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 281 – *Mobiles Kommunikationssystem.*
[2168] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 281 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf BGH, 26.3.2009 – I ZR 44/06 – *Resellervertrag*.
[2169] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 281 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

FRAND-Einwand dem Grunde nach nicht ausgeschlossen.[2170] Der Klägerin stehe gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG zu.[2171] Als Fachunternehmen würde es der Beklagten oblegen haben, zu prüfen, ob die angebotenen und gelieferten Produkte klagepatentverletzend seien.[2172] Indem sie eine entsprechende Überprüfung unterlassen habe, habe die Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachten (§ 276 Abs. 2 BGB).[2173]

Das Verschulden werde auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass es sich vorliegend um ein standardessenzielles Patent handele.[2174] Soweit der EuGH in Rn. 62 ausgeführt habe, dass „in Anbetracht der großen Zahl von SEP, aus denen ein Standard wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende bestehe, nicht sicher [sei], dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig wisse, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents benutze“, berühre dies den Haftungsmaßstab des Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG nicht.[2175] Ob ein Patentverletzer ein bestimmtes Patent nicht (zwangsläufig) kenne, sei davon zu trennen, ob er das entsprechende Schutzrecht habe kennen müssen.[2176] Hierfür würden die gleichen Haftungsmaßstäbe gelten.[2177] Das Verschulden übersteige vorliegend auch die leichte Fahrlässigkeit nach § 139 Abs. 2 S. 2 PatG in der bis zum 31.8.2008 gültigen Fassung des Gesetzes, welche für Handlungen bis zu diesem Zeitpunkt weiter ausschlaggebend sei.[2178] Da aber keine leichte Fahrlässigkeit vorliege, hafte die Beklagte für diese gesamte Zeit auf Schadensersatz.[2179]

In seinen Entscheiden vom 12.12.2018 führte das LG Düsseldorf ebenfalls aus, die Klägerin habe gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 und 2 PatG.[2180] Die Beklagte sei zum Schadenersatz verpflichtet, weil sie die Patentverletzung schuldhaft begangen habe.[2181] Als Fachunternehmen habe sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können (§ 276

[2170] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 422 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 372 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 421; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 373.

[2171] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 430 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 429.

[2172] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 431 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 382 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 430; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 383.

[2173] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 431 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 382 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 430; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 383.

[2174] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 432 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 383 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 431; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 384.

[2175] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 432 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 383 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 431; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 384.

[2176] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 432 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 383 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 431; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 384.

[2177] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 432 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 383 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 431; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 384.

[2178] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 432 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 383 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 431; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 384.

[2179] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 432 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 383 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 431; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 384.

[2180] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 439; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 316; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 377; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 301.

[2181] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 440; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 317; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 379; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 303.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

BGB).[2182] Es sei auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin durch die Schutzrechtsverletzung ein Schaden entstanden sei.[2183]

Im Beschluss vom 22.3.2019 äußerte sich das OLG Düsseldorf abermals dahingehend, dass die Klägerin nicht deshalb in der gerichtlichen Durchsetzung ihrer Rechte beschränkt sei, weil es sich bei dem Klagepatent um ein standardessentielles Schutzrecht handele, für das eine FRAND-Erklärung abgegeben sei.[2184] Nach der Rechtsprechung des EuGH unterliege die klageweise Durchsetzung eines standardessentiellen Patents mit FRAND-Erklärung nur insoweit Restriktionen, als es um Unterlassungs- oder Rückrufansprüche gehe, nicht hingegen, wenn und soweit aus der Patentverletzung – wie vorliegend – Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz hergeleitet würden.[2185]

Auch das LG Mannheim in *Funkstation* und im Urteil vom 28.9.2018 urteilte, der Anspruch auf Schadensersatz ergebe sich aus § 139 Abs. 2 PatG.[2186] Die Beklagte habe schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt.[2187] Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB) hätte im Geschäftsbetrieb der Beklagten spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents grundsätzlich erkannt werden können und müssen, dass das Klagepatent durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen verletzt werde.[2188]

Der Urteilsausspruch zu den insoweit beschiedenen Anträgen unterlägen keiner Beschränkung im Hinblick auf den von der Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand und die ETSI-FRAND-Erklärung der Klägerin.[2189] Die Beklagte habe zu Recht in Bezug auf diese Anträge auch keine inhaltlichen Einwände vorgebracht.[2190] Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft/Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach bleibe auch bei einem erfolgreichen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unberührt.[2191]

2. Stufenklage und Rechtsschutzinteresse

Weiter setzte sich das OLG Düsseldorf in *Mobiles Kommunikationssystem* auch mit der Auffassung der Beklagten auseinander, es fehle der Klägerin mit Blick auf die erfolgte Sicherheitsleistung der Beklagten am „Rechtsschutzbedürfnis" für die Feststellung ihrer Verpflichtungen zum Schadenersatz.[2192] Dies treffe aber schon deshalb nicht zu, weil ihre Abrechnungen und ihre Sicherheitsleistungen allenfalls Benutzungshandlungen bis einschließlich des 4. Quartals einschließen würden.[2193] Da es auch in der Folgezeit zu Benutzungshandlungen gekommen sei und – wie von der Vorinstanz zutreffend begründet

---

[2182] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 440; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 317; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 379; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 303.

[2183] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 441; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 318; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 303.

[2184] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 137 – *Improving Handovers*.

[2185] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 137 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE*.

[2186] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 106 – *Funkstation*; LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 92.

[2187] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 106 – *Funkstation;* 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 92.

[2188] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 106 – *Funkstation*; 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 92.

[2189] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 108 – *Funkstation*.

[2190] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 108 – *Funkstation*.

[2191] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 109 – *Funkstation*; 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 101, beide mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 72 ff. – *Huawei/ZTE* und OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 226 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2192] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 284 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2193] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 284 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

– zukünftige Benutzungshandlungen hinreichend wahrscheinlich seien, stehe das „Rechtsschutzbedürfnis“ ebenso wenig wie das Feststellungsinteresse im Sinne von § 256 ZPO in Frage.[2194]

In den Entscheiden vom 13.7.2017 führte das LG Düsseldorf aus, die Klägerin habe an der begehrten Feststellung das erforderliche rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO.[2195] Die Entstehung eines Schadens auf Seiten der Klägerin sei hinreichend wahrscheinlich.[2196] Eine Bezifferung dieses Schadens sei ihr nicht möglich, weil sie ohne Verschulden über die Informationen, die sie mit ihren Klageanträgen begehre, in Unkenntnis sei.[2197]

Auch in den Entscheiden vom 12.12.2018 erwog das LG Düsseldorf, das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergebe sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage sei, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadenersatzpflicht die Verjährung von Schadenersatzansprüchen drohe.[2198]

Im Entscheid vom 8.1.2019 urteilte das LG Düsseldorf, im Schadensersatzfeststellungsprozess bedürfe es noch keiner Festlegung dahingehend, ob der geschuldete Schadensausgleich auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt sei; dem sei erst im Höheprozess nachzugehen.[2199] Anders verhalte es sich hinsichtlich des begleitenden Rechnungslegungsanspruchs (dazu unten XIII.C).[2200]

Das OLG Düsseldorf urteilte in *Improving Handovers* dahingehend, es habe für die Schadensersatzhaftung der Beklagten, die gerichtlich (d.h. dem Grunde nach) festgestellt werden solle, keine Bedeutung, ob die Klägerin ihrer FRAND-Zusage und den daraus resultierenden Pflichten nachgekommen sei.[2201] Denn die Beklagten hätten sich einer widerrechtlichen und schuldhaften Patentverletzung allein deswegen schuldig gemacht, weil sie die Benutzung des Klagepatents aufgenommen hätten, ohne dass zuvor zwischen ihnen und der Klägerin (bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen) ein die Patentbenutzung legitimierender Lizenzvertrag zustande gekommen sei.[2202] Selbst wenn der zu leistende Schadenersatz (für gewisse Zeiträume) der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt sein sollen würde, weil die Beklagten das von ihrer Seite Notwendige getan hätten, um den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zu ermöglichen, würde es sich bei dem geschuldeten finanziellen Ausgleich für die Benutzung des Klagepatents dennoch der Sache nach um die Leistung von Schadenersatz handeln.[2203] Die Verpflichtung der Beklagten hierzu sei deshalb ohne Rücksicht darauf festzustellen, ob der Klägerin als Kompensation für den Schaden nur eine (FRAND-)Lizenzgebühr zustehe oder der Schaden darüber hinaus nach anderen Berechnungsmethoden liquidiert werden könne.[2204] All dies stehe angesichts des Feststellungsantrages, der bloß die Wahrscheinlichkeit irgendeines Schadenseintritts erfordere,

---

[2194] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 284 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2195] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 435 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 386 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 434; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 387.

[2196] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 435 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 386 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 434; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 387.

[2197] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 435 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 386 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 434; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 387.

[2198] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 441; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 318; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 378; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 302.

[2199] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 175.

[2200] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 175.

[2201] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2202] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2203] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2204] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

derzeit nicht zur Entscheidung, sondern sei erst im nachfolgenden Höheprozess zu klären.[2205] Soweit die Beklagten auf Rechtskraftprobleme Bezug nehmen würden, die daraus resultieren sollten, dass ihnen der Einwand, allein eine FRAND-Lizenzgebühr zu schulden, im Höheverfahren abgeschnitten sei, wenn ihre Schadenersatzpflicht erst einmal festgestellt sei, treffe dies nicht zu.[2206] Schwierigkeiten der besagten Art könnten sich nur einstellen, wenn die Frage einer kartellrechtlichen Pflichtverletzung zum Grund der Schadenersatzhaftung wegen Patentverletzung gehören würde, was – wie dargelegt – nicht der Fall sei.[2207] Dafür spreche auch eine weitere Überlegung.[2208] Die pflichtwidrige Weigerung des marktbeherrschenden Patentinhabers, dem um eine Lizenz nachsuchenden Patentbenutzer ein FRAND-gemäßes Lizenzangebot zu unterbreiten, stelle einen mindestens fahrlässig begangenen Verstoß gegen dessen Pflichten aus Art. 102 AEUV dar, welcher den Patentinhaber seinerseits gegenüber dem Lizenzsucher zum Schadenersatz verpflichte (§§ 33 Abs. 1, 33a Abs. 1 GWB). Der in diesem Rechtsverhältnis zu liquidierende Schaden bestehe darin, für die Benutzung des Klagepatents zu mehr als einer bei rechtmäßigem Verhalten des Patentinhabers zu zahlenden FRAND-Lizenzgebühr herangezogen zu werden (nämlich zu vollem Schadenersatz), weswegen der Anspruch des Lizenzsuchers auf Naturalrestitution dahin gehe, ihn von solchen Schadenersatzforderungen freizustellen, die über eine FRAND-Lizenzgebühr hinausgingen.[2209] Über diesen selbstständigen Gegenanspruch des Verletzungsbeklagten sei im Rahmen der Schadenersatzfeststellung keinesfalls mit Rechtskraft entschieden.[2210]

Das LG Mannheim führte in *Funkstation* betreffend Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO aus, diese lägen im Streitfall vor.[2211] Die Klägerin kenne den genauen Umfang der Verletzungshandlungen nicht und könne ohne diese Kenntnis einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht beziffern.[2212] Da aber die Beklagten die Benutzung des Klagepatents und damit die Patentverletzung in Abrede stellten, habe die Klägerin – auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist – ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Ersatzanspruchs alsbald festgestellt werde.[2213]

Auch im Urteil vom 28.9.2018 erwog das LG Mannheim, die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO lägen vor.[2214] Die Klägerin kenne den genauen Umfang der Verletzungshandlungen nicht und könne ohne diese Kenntnis einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht beziffern.[2215] Die Klägerin habe – auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist – ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Ersatzanspruchs alsbald festgestellt werde.[2216] Im gewerblichen Rechtsschutz stehe der grundsätzliche Vorrang der Leistungsklage auch bei Möglichkeit einer Stufenklage im Sinne des § 254 ZPO einer Feststellungsklage unter prozessökonomischen Gesichtspunkten nicht entgegen.[2217]

[2205] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2206] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2207] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2208] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2209] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2210] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 303 – *Improving Handovers*.

[2211] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 105 – *Funkstation*.

[2212] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 105 – *Funkstation*.

[2213] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 105 – *Funkstation*.

[2214] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 92.

[2215] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 92.

[2216] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 92.

[2217] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 92, mit Verweis auf BGH, 15.5.2003 – I ZR 277/00 – *Feststellungsinteresse III*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

B. Höhe

Betreffend die Höhe der Schadenersatzforderung führte das OLG Düsseldorf im Entscheid *Mobiles Kommunikationssystem* aus, dass auch wenn der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand die Durchsetzbarkeit des Schadenersatzanspruches dem Grunde nach unberührt lasse, sei der zu leistende Schadenersatz der Höhe nach auf dasjenige beschränkt, was sich in Anwendung der Schadenausgleichsmethodik „Lizenzanalogie" ergebe: Solange der Lizenzsucher sich seinerseits FRAND verhalte, d.h. seinen Obliegenheiten jeweils nachkomme, schulde er deshalb der Höhe nach nur Schadenersatz auf der Basis einer FRAND-Lizenzgebühr:[2218] Unabhängig von der Frage, ob einer FRAND-Erklärung bloß deklaratorische oder eine konstitutive Wirkung zukomme, begründe die in ihr erhaltene Verpflichtungszusage in jedem Falle einen Vertrauenstatbestand, so dass es dem SEP-Inhaber, der die Voraussetzungen für einen der Höhe nach unbeschränkten Schadenersatzanspruch schaffen möchte, obliege, sich entsprechend seiner FRAND-Zusage, auf die der andere Teil sich entsprechend einrichten dürfe, zu verhalten und das Lizenzierungsprocedere mittels des Vollzugs der ihm vom EuGH auferlegten Pflichten voranzubringen.[2219]

Da die Klägerin ihrer Verpflichtung zur einem FRAND-Lizenzierungsprocedere trotz bestehender Lizenzbereitschaft der Beklagten bisher nicht nachgekommen sei, obwohl die Beklagten bereits vorprozessual ihre Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht hätten, gelte Vorstehendes auch für den vorliegend geltend gemachten Schadenersatzanspruch der Klägerin.[2220] Die Klärung der maßgeblichen Einzelheiten, was im Einzelfalle eine FRAND-Lizenz sei, sei im vorliegenden Verfahren, in dem nur über den Feststellungsantrag zu befinden sei, also gleichsam nur eine Entscheidung über den Schadenersatzanspruch dem Grunde nach zu treffen sei, nicht vonnöten, sondern dies sei einem etwaigen Höheverfahren vorbehalten.[2221]

Auch das LG Düsseldorf hielt in den Entscheiden vom 13.7.2017 fest, auch wenn sich der SEP-Inhaber nicht FRAND-konform verhalte – wie im Streitfall – so stehe ihm zwar ein Anspruch auf Schadenersatzfeststellung dem Grunde nach zu.[2222] Jedenfalls in diesem Falle sei der Schadensersatzanspruch aber nach wohl herrschender Meinung auf eine FRAND-gemäße Lizenzgebühr beschränkt, die sich nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechne.[2223] Habe der SEP-Inhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben, so verpflichte ihn dies, jedermann die Nutzung der geschützten Lehre gegen eine ausbeutungsfreie Lizenz zu gestatten, so dass es jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegendem, in welchem die FRAND-Konformität ohnehin Prüfungsgegenstand sei, gerechtfertigt sei, ihn an seiner FRAND-Erklärung festzuhalten.[2224]

[2218] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 282 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf OLG Karlsruhe, 29.8.2016 – 6 U 57/16 und die a.A. des LG Mannheim, 26.2.2016 – 7 O 38/14.

[2219] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 282 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf die a.A. des LG Düsseldorf, 19.1.2016 – 4b O 122/14.

[2220] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 283 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2221] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 283 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf die a.A. des LG Düsseldorf, 19.1.2016 – 4b O 122/14.

[2222] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 433 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 384 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 432; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 385.

[2223] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 433 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 384 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 432; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 385, alle mit dem Verweis auf die Ansicht, dass kartellrechtliche Einwendungen insofern keine Rolle spielten des LG Mannheim, 4.3.2016 – 7 O 23/14 und dass die Frage letztlich offengelassen worden sei in OLG Karlsruhe, 29.8.2016 – 6 U 57/16, Rn. 32.

[2224] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 433 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 384 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 432; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 385.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Wie hoch ein solcher auf FRAND-Lizenzgebühren beschränkter Schadensersatzanspruch sei, bleibe dem Höheverfahren vorbehalten.[2225] Insofern könne die Schadensersatzfeststellung vorliegend wie üblich tenoriert werden, da die Schadenersatzpflicht nur dem Grunde nach festzustellen sei.[2226]

Im Entscheid vom 8.1.2019 urteilte das LG Düsseldorf abermals, die vom Schutzrechtsinhaber übernommene Pflicht, die Benutzung seines marktbeherrschenden Patents gegenüber jedermann gegen eine ausbeutungsfreie Lizenz zu gestatten, reduziere den Schadensersatzanspruch auf eben diese FRAND-Lizenz und die begleitende Rechnungslegung auf solche Angaben, die für eine Lizenzberechnung erforderlich seien.[2227]

Das LG Mannheim ließ im Rahmen der allein zu bescheidenden Feststellung der Schadenersatzpflicht (dem Grunde nach) dahinstehen, ob in der konkreten Fallkonstellation der Schadensersatz der Höhe nach – insbesondere für sämtliche in Betracht zu ziehenden Zeiträume – tatsächlich auf dasjenige beschränkt sei, was sich in Anwendung der Schadensausgleichsmethodik „Lizenzanalogie“ auf Basis einer FRAND-Lizenzgebühr ergebe.[2228] Denn für den Erfolg des Klagebegehrens genüge es festzustellen, dass aufgrund der patentverletzenden Handlungen überhaupt ein Schaden wahrscheinlich entstanden sei, ohne dass Feststellungen zu dessen Höhe geboten seien.[2229] Das gelte solange, wie der Patentinhaber seinen Verpflichtungen zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages nicht nachkomme.[2230]

C. Auskunft- und Rechnungslegung

Das OLG Düsseldorf vom 30.3.2017 führte weiter aus, die Vorinstanz habe der Klägerin zu Recht auch Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung zugesprochen.[2231] Entgegen der Rüge der Beklagten reiche ihre Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung nicht etwa über den Inhalt der betreffenden gesetzlichen Ansprüche hinaus.[2232] Namentlich habe die Vorinstanz in Bezug auf die nach § 140b Abs. 3 Nr. 1 PatG geschuldeten Angaben die gebotene Beschränkung auf „gewerbliche Abnehmer und Verkaufsstellen“ vorgenommen.[2233] Soweit die Beklagten offenbar meinten, eine entsprechende Einschränkung habe global in Bezug auf alle Angaben vorgenommen werden müssen, treffe dies nicht zu.[2234] Die Vorinstanz habe vielmehr zu Recht einen Wirtschaftsprüfervorbehalt vorgesehen, soweit nichtgewerbliche Abnehmer und Angebotsempfänger betroffen seien.[2235]

Auch sei der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung nicht durch die von den Beklagten vorgelegte Abrechnung/Rechnungslegung wegen Erfüllung (§ 362 BGB) erloschen.[2236] Einer Erfüllung stehe bereits entgegen, dass die Abrechnungen nicht die Angaben gemäß des Tenors des

---

[2225] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 434 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 385 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 433; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 386.

[2226] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 434 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 385 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 433; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 386.

[2227] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 175.

[2228] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 110 – *Funkstation*; 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 102, beide mit Verweis auf die wohl a.A. in OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 236 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2229] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 110 – *Funkstation*; 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 102.

[2230] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 175, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem* und LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 254.

[2231] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 285 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2232] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 286 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2233] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 286 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2234] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 286 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2235] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 286 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2236] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 287 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

angefochtenen vorinstanzlichen Urteils enthielten.[2237] Die bislang vorgelegten Abrechnungen könnten folglich allenfalls als Teilleistung angesehen werden, auf die sich der Gläubiger jedoch anerkanntermaßen nicht einlassen müsse.[2238]

Abzuändern sei das angefochtene Urteil allerdings, soweit es die Ansprüche der Klägerin auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung auch auf Angaben zu Kosten und Gewinn der Beklagten im Zusammenhang mit den rechtswidrigen Benutzungshandlungen erstreckt habe.[2239] Weil der zu leistende Schadenersatz nämlich der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenz beschränkt sei, müsse dementsprechend auch die Rechnungslegung bloß solche Daten umfassen, die für die Schadensermittlung gemäß dieser Methodik notwendig seien.[2240] Soweit das LG Düsseldorf im Entscheid vom 19.1.2016 indessen schieden habe, die betreffende Beschränkung trete erst ab der Weigerung des Patentinhabers ein, eine FRAND-Lizenz zu erteilen, träge dies der vom EuGH in den Fokus gestellten Erwartungshaltung Dritter, die sich gerade auf die FRAND-Zusage des SEP-Inhabers als solche gründe, nach Auffassung des Senats nicht hinreichend Rechnung.[2241] Das auf die FRAND-Zusage gestützte Vertrauen, dass der SEP-Inhaber einen lizenzbereiten Dritten von sich aus ein FRAND-Angebot unterbreiten werde, rechtfertige bereits die entsprechende inhaltliche Beschränkung des Schadensersatzanspruchs.[2242] Solange der Lizenzsucher seinerseits die ihm auferlegten Obliegenheiten erfülle und das Nichtzustandekommen eines FRAND-Lizenzvertrags seine Ursache in der Sphäre des SEP-Inhabers finde, müsse er (der Lizenzsucher) zwar mangels eines gültigen Lizenzvertrages davon ausgehen, für Benutzungshandlungen schadensersatzpflichtig zu sein.[2243] In seinem berechtigten Vertrauen auf ein FRAND-gemäßes Verhalten des SEP-Inhabers habe er aber keinen Anlass zur Annahme, der zu leistende Schadensersatz werde auch denjenigen Betrag umfassen, der sich bei der Schadensermittlung nach den Methoden des „Verletzergewinns“ oder des „entgangenen Gewinns“ ergebe und unter Umständen höher ausfallen könne als in Anwendung der Grundsätze der Lizenzanalogie.[2244] Denn bei pflichtgemäßem Verhalten des gleichsam vorleistungspflichtigen SEP-Inhabers würde dieser einen umfassenderen Schadensersatz erst dann beanspruchen, wenn der andere Teil entweder schon nicht lizenzwillig sei oder ein vom SEP-Inhaber unterbreitetes FRAND-Angebot nicht annehmen würde, ohne seinerseits ein FRAND-Gegenangebot zu präsentieren und entsprechend Sicherheit zu leisten.[2245]

Dementsprechend benötige ein SEP-Inhaber die der Klägerin vom Senat aberkannten Angaben zu Kosten und Gewinn nicht für die Berechnung einer FRAND-Lizenz.[2246] Gründe, die die Kenntnis der entsprechenden Informationen für die Anwendung der Schadensausgleichungsmethode „Lizenzanalogie“ erforderliche machen würden, seien nicht ersichtlich.[2247] Insoweit gelte nichts anderes als für die Anwendung der Grundsätze der Lizenzanalogie in Fällen, in denen der Schadensersatz für die Benutzung eines nicht standardessentiellen Patents zu bestimmen sei.[2248]

[2237] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 288 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2238] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 288 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2239] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 289 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2240] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 19.1.2016 – 4b O 122/14.

[2241] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2242] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2243] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2244] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2245] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 290 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2246] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 291 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2247] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 291 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf insofern bestehende Zweifel des OLG Karlsruhe, 29.8.2016 – 6 U 57/16, Rn. 34.

[2248] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 291 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Die EuGH-Entscheidung „*Huawei Technologies / ZTE*“ stehe den vorstehenden Erwägungen des Senats nicht entgegen.[2249] Der EuGH habe sich allein damit befasst, auf welche Ansprüche wegen Patentverletzung sich die FRAND-Zusage des SEP-Inhabers dem Grunde nach auswirkt, d.h. ein Durchsetzungshindernis für die entsprechende Klageerhebung nach sich ziehe.[2250] Ob darüber hinausgehend die trotz berechtigten FRAND-Einwandes gerichtlich durchsetzbaren Ansprüche auf Auskunft/Rechnungslegung und Schadensersatz inhaltlich bzw. der Höhe nach begrenzt seien, habe der EuGH weder ausdrücklich noch mittelbar entschieden, so dass diesbezüglich kein die nationalen Gerichte bindendes Präjudiz bestehe.[2251] Soweit die Klägerin Auskunft/Rechnungslegung zu Angaben betreffend Kosten und Gewinn begehrt habe, sei die Klage nach alledem ebenfalls als derzeit unbegründet abzuweisen gewesen.[2252]

In den Entscheiden des LG Düsseldorf vom 13.7.2017 urteilte die Kammer, der Klägerin stehe der mit Antrag geltend gemachte Auskunftsanspruch gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1, 3 PatG in vollem Umfang zu.[2253] Umstände, aufgrund derer eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung sich als unverhältnismäßig gemäß § 140b Abs. 4 PatG darstelle, seien weder vorgetragen noch erkennbar.[2254]

Soweit die Klägerin des Weiteren mit ihrem Antrag Rechnungslegung begehre, stehe ihr dieser Anspruch in dem aus dem Tenor erkennbaren Umfang gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 242, 259 BGB zu, damit sie in die Lage versetzt werde, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern.[2255] Die Klägerin sei auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfüge.[2256] Die Beklagten würden durch die von ihr verlangte Auskunft auch nicht erkennbar unzumutbar belastet.[2257]

Der Auskunftsanspruch aus §§ 242, 259 BGB umfasse aber vorliegend aufgrund des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nicht Angaben zu Kosten und Gewinn der Beklagten im Zusammenhang mit der Patentverletzung.[2258] Wenn der SEP-Inhaber für die Nutzung der patentgemäßen Lehre lediglich eine angemessene, FRAND-Bedingungen entsprechende Lizenzgebühr verlangen könne, gebiete es der Grundsatz von Treu und Glauben, auch die Verpflichtung zur Auskunft- und Rechnungslegung auf die zur Berechnung dieser FRAND-Lizenzgebühr erforderlichen Angaben zu beschränken.[2259] Insbesondere sei in diesem Fall kein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers an Angaben zum Verletzergewinn

[2249] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 292 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2250] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 292 – *Mobiles Kommunikationssystem*, mit Verweis auf insbesondere EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 73–74 – *Huawei/ZTE*.

[2251] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 292 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2252] OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15, Rn. 293 – *Mobiles Kommunikationssystem.*

[2253] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 436 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 387 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 435; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 388.

[2254] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 436 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 387 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 435; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 388.

[2255] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 437 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 388 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 436; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 389.

[2256] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 437 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 388 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 436; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 389.

[2257] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 437 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 388 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 436; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 389.

[2258] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 438 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 389 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 437; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 390.

[2259] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 438 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 389 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 437; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 390.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

(Kosten- und Gewinnangaben) ersichtlich, das die berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Patentinhabers überwiegen können würde.[2260]

Das LG Mannheim vom 10.11.2017 führte aus, die Beklagte sei der Klägerin ferner zu Auskunft und Rechnungslegung – grundsätzlich im beantragten Umfang – verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB, wobei die Klägerin Belegvorlage im beantragten und zuerkannten Umfang entsprechend § 259 BGB fordern könne.[2261]

Anders als das OLG Düsseldorf in seiner Entscheidung *Mobiles Kommunikationssystem* in Randnummer 243 ff. vertrete, sei eine inhaltliche Beschränkung des Auskunfts- / Rechnungslegungstenors nach Auffassung der Kammer im Grundsatz ebenso wenig veranlasst wie Feststellungen zur Höhe des Schadenersatzes.[2262] Dabei könne wiederum dahinstehen, ob der Verletzte beim Schadensersatz der Höhe nach auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt sei, namentlich also nicht nach der Methode „Verletzergewinn“ seinen Schaden liquidieren könne.[2263] Denn selbst bei einer Beschränkung des Schadensersatzanspruchs könne der Verletzte in der hiesigen Konstellation die vorliegend geforderten Daten im Rahmen der Rechnungslegung fordern.[2264]

Die Namens-, Anschriften-, Mengen- und Preisangaben sowie die Einkaufspreise im Rahmen der Gestehungskosten schulde der Verletzer schon im Wege der Auskunft über Herkunft und Vertriebswege nach § 140 Abs. 3 PatG, um dem Verletzten die Wahrnehmung seiner Rechte gegenüber weiteren Verletzern in der Lieferkette zu ermöglichen.[2265] Die Auflistung der Einzellieferungen unter Angabe der Lieferzeiten sowie die Angaben zu Angeboten und Werbung könne der Verletzer zudem bereits unter dem Gesichtspunkt der Plausibilisierung und Nachprüfung der sonstigen Rechnungslegungsangaben im Rahmen von § 242 BGB verlangen; insoweit nehme auch das OLG Düsseldorf keine Beschränkung des Rechnungslegungstenors vor.[2266]

Nach Auffassung der Kammer hindere eine mögliche Beschränkung des Schadensersatzes auf Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr nicht, dem Verletzer im Rahmen der Rechnungslegung weitergehend auch Gewinnangaben, letztlich also Angaben zu den zurechenbaren Gestehungskosten, namentlich solche, die ohnehin nach § 140b Abs. 3 Nr. 2 PatG gebotenen Einkaufsangaben hinausgingen, zuzuerkennen.[2267] Zwar seien diese Angaben nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der die Kammer folge, zur Bemessung des Ersatzanspruchs im Wege der Lizenzanalogie „im Regelfall nicht erforderlich“, weshalb diese Angaben bei der Rechnungslegung zur Vorbereitung und Durchsetzung eines solchen Ersatzanspruchs nach § 242 BGB grundsätzlich nicht geschuldet seien.[2268] Indes sei nach diesen Grundsätzen gerade nicht ausgeschlossen, dass solche Angaben im Sonderfall erforderlich sein könnten, zumal der Bundesgerichtshof grundsätzlich die mögliche Relevanz des beim Verletzer erwirtschafteten Gewinns für die Bestimmung der Lizenzgebühr anerkenne, insbesondere als die

[2260] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 438 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 389 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 437; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 390, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 19.1.2016 – 4b O 123/14, Rn. 348.

[2261] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 107 – *Funkstation*, mit Verweis zur Belegvorlage auf OLG Karlsruhe, 14.1.2009 – 6 U 54/06.

[2262] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 111 – *Funkstation*; 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 103.

[2263] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 111 – *Funkstation*; 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 103.

[2264] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 111 – *Funkstation*; 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 103.

[2265] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 112 – *Funkstation.*

[2266] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 112 – *Funkstation.*

[2267] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 113 – *Funkstation.*

[2268] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 114 – *Funkstation*, mit Verweis auf BGH, 11.4.1989 – X ZR 26/87 – *Offenendspinnmaschine*, sowie 20.5.2008 – X ZR 180/05 – *Tintenpatrone* und 17.11.2009 – X ZR 137/07 – *Türinnenverstärkung*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

übliche Umsatzrendite bei der Lizenzanalogie berücksichtigungsfähig sein könne.[2269] In Fallkonstellationen wie der vorliegenden, in denen eine Beschränkung des Schadensersatzes auf eine FRAND-Lizenzgebühr in Betracht zu ziehen sei, allerdings ein am Markt etabliertes Lizenzsystem, welches FRAND-Anforderungen unstreitig oder nachweislich genüge, nicht feststellbar, insbesondere nicht vorgetragen sei und die Parteien vielmehr über die Bemessung der FRAND-Lizenzgebühr und die dabei einzustellenden Umstände streiten würden, habe der Verletzte auch zur Vorbereitung eines Schadenersatzhöheprozesses nach der Methode der Lizenzanalogie ein berichtigtes Interesse, die geforderte Gewinnangaben zur Kenntnis zu bekommen.[2270] Denn in dieser Situation, in der die relevanten Umstände der Lizenzierung unstreitig seien und die Gefahr der Festlegung einer unangemessen niedrigen oder hohen Lizenzgebühr bestehe, könne die Erforderlichkeit von Gewinnangaben zur Beurteilung der FRAND-Grenzen und damit zur Vorbereitung eines Höheprozesses nicht ohne weiteres von vornherein verneint werden.[2271] Die über den Umfang nach § 140b Abs. 3 PatG hinausgehenden Angaben seien dem Verletzer in dieser Situation auch grundsätzlich zumutbar.[2272] Da die Beklagte im vorliegenden Rechtstreit nichts gegen die Antragsweite zur Auskunft/Rechnungslegung erinnere, könne die Kammer nach den vorstehenden Erwägungen Auskunft und Rechnungslegung im beantragten Umfang ohne weiteres zuerkennen.[2273]

Das LG Düsseldorf entschied im Urteil vom 28.6.2018, der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergebe sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG.[2274] Die Angaben seien allerdings für Handlungen vor dem 1.1.2014 (dem Datum, ab dem die Klägerin Schadensersatz beantragt hatte) nicht zu machen und die Klage insoweit abzuweisen.[2275] Der Anspruch nach § 140b PatG verjähre selbstständig; er diene auch nicht der Bezifferung eines (ggf. noch nicht verjährten) (Rest-)Schadensersatzanspruchs.[2276] Die Verjährung bestimme sich nach § 141 PatG i.V.m. §§ 195, 199 Abs. 1 BGB.[2277] Für Handlungen ab dem 1.1.2014 sei aufgrund der Klageerhebung (am 1.3.2017) keine Verjährung eingetreten.[2278]

Für Handlungen vor dem 1.1.2014 sei der Anspruch aus § 140b PatG dagegen verjährt.[2279] Dies betreffe die genannten Ansprüche zu der Herkunft und den Vertriebswegen der angegriffenen Ausführungsformen, die nicht vom Anspruch nach §§ 242, 259 BGB umfasst seien.[2280] Auskunftsansprüche nach § 140b PatG für Handlungen am 31.12.2013 und der Zeit davor seien dagegen bei Klageerhebung bereits verjährt gewesen.[2281] Die drei-jährige Verjährungsfrist des § 195 BGB habe nach § 199 Abs. 1 BGB mit dem 31.12.2013 zu laufen begonnen, so dass Verjährung mit dem Ablauf des 31.12.2016 eingetreten sei.[2282] Am 31.12.2013 sei im Sinne von § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB für die jeweilige patentverletzende Handlung der Anspruch nach § 140b PatG entstanden; weiterhin habe

[2269] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 114 – *Funkstation*, mit Verweis zu letzterem auf BGH, 29.7.2009 – I ZR 169/07 – *BTK*.

[2270] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 114 – *Funkstation.*

[2271] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 114 – *Funkstation.*

[2272] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 114 – *Funkstation.*

[2273] LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16, Rn. 115 – *Funkstation.*

[2274] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 281.

[2275] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 282.

[2276] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 282.

[2277] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 282.

[2278] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 282.

[2279] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 283.

[2280] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 283.

[2281] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 284.

[2282] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 284.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

die Klägerin zu diesem Zeitpunkt nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB jedenfalls grob fahrlässig Unkenntnis über die den Anspruch begründenden Umstände und die Person der Beklagten als Anspruchsschuldner gehabt.[2283] Die Klägerin habe jedenfalls seit 2012 Kenntnis über die patentverletzenden Handlungen im Konzern der Beklagten gehabt, wie ein Schreiben vom 19.11.2012 belege.[2284] Es sei davon auszugehen, dass die Klägerin auch von der Existenz der Beklagten als deutscher Tochterfirma des N-Konzerns gewusst habe oder allenfalls in Folge grober Fahrlässigkeit hiervon in Unkenntnis gewesen sei.[2285] Dass die Verjährung vorliegend aufgrund von Verhandlungen zwischen den hiesigen Parteien gehemmt gewesen sei (§ 203, BGB), habe die Klägerin nicht dargetan und sei auch sonst nicht ausreichend vorgetragen – insbesondere was Verhandlungen mit der Beklagten selber angehe.[2286] Die Klägerin habe zu dem Komplex der Verjährung weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung Stellung genommen.[2287]

Im Entscheid vom 28.9.2018 führte das LG Mannheim aus, ausgehend von der dem Grunde nach bestehenden Schadensersatzpflicht der Beklagten (vgl. oben XIII.A) sei sie der Klägerin hinsichtlich der tenorierten schutzrechtsverletzenden Benutzungshandlungen im Inland ferner zur Auskunft – wegen der Unabhängigkeit von einem Verschuldensmoment frühestens ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung des Klagepatents – und zur Rechnungslegung – frühestens ab einen Monat nach diesem Zeitpunkt – verpflichtet gemäß 140b Abs. 1, Abs. 3 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB.[2288] Die Klägerin kenne die zur Bezifferung ihrer Ansprüche notwenigen Einzelheiten ohne eigenes Verschulden nicht; demgegenüber werde die Beklagte durch die Erteilung der ihr abverlangten Auskünfte nicht unverhältnismäßig belastet und könne sie auch ohne Schwierigkeiten geben.[2289] Der Anspruch bestehe hinsichtlich aller tenorierten, möglichen Benutzungshandlungen, auch soweit diesbezüglich kein konkreter Vortrag der Klägerin geleistet worden sei.[2290]

Mit Entscheid vom 12.12.2018 führte das LG Düsseldorf aus, der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG zu.[2291] Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergebe sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG.[2292] Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgten aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt werde, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern.[2293] Die

[2283] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 284.

[2284] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 284.

[2285] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 284.

[2286] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 284.

[2287] LG Düsseldorf, 28.6.2018 – 4a O 23/17, Rn. 284.

[2288] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 93, mit Verweis auf BGH, 7.12.1979 – I ZR 157/77 – *Monumenta Germaniae Historica* und 24.3.1994 – I ZR 42/93 – *Cartier-Armreif*.

[2289] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 93.

[2290] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 93, mit Verweis auf BGH, 29.3.1960 – I ZR 109/58 – *Kreuzbodenventilsäcke I*.

[2291] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 442; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 319; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 304.

[2292] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 442; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 319; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 304.

[2293] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 442; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 319; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 304.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Klägerin sei auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfüge, und die Beklagte werde durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.[2294]

Im Urteil vom 8.1.2019 urteilte das LG Düsseldorf abermals, ungeachtet dessen, dass der seitens der Beklagten geltend gemachte kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand der Erhebung einer Klage auf Rechnungslegung und Schadensersatz – wie vorliegend nur noch streitgegenständlich – nicht entgegengehalten werden könne, sei er dennoch beachtlich, da eine gegebene Lizenzierungszusage zugunsten des Verletzers einen materiellen Anspruch schaffe, der im Rahmen dessen zu berücksichtigen sei, wie vorgefallene Benutzungshandlungen zu liquidieren seien und über welche Daten infolgedessen vorbereitend Rechnung zu legen sei.[2295] Auch wenn es im Schadensersatzfeststellungsprozess noch keiner Festlegung dahingehend bedürfe, ob der geschuldete Schadensausgleich auf eine FRAND-Lizenzgebühr beschränkt sei, sondern dem erst im Höheprozess nachzugehen sei, verhalte es sich hinsichtlich des begleitenden Rechnungslegungsanspruchs anders, der in Fällen des berechtigten Einwandes keine Angaben zu den Kosten und Gewinnen umfasse.[2296]

Das OLG Düsseldorf in *Improving Handovers* urteilte, dass aus denselben Erwägungen, aus denen es für die gerichtliche Feststellung der Schadenersatzhaftung der Beklagten dem Grunde nach keine Bedeutung habe, ob die Klägerin ihrer FRAND-Zusage und den daraus resultierenden Pflichten nachgekommen sei, der Anspruch der Beklagten auf die Einräumung einer FRAND-Lizenz nichts daran ändere, dass sie für die Vergangenheit wegen ihrer ohne diese Lizenz widerrechtlich unternommenen Benutzungshandlungen nach Maßgabe von § 140b PatG Auskunft zu erteilen hätten.[2297]

Anders verhalte es sich beim Rechnungslegungsanspruch.[2298] Denn die Klägerin könne von den Beklagten Angaben zu ihren Kosten und Gewinnen nur für solche Benutzungszeiträume verlangen, für die die Klägerin deshalb nicht auf das Fordern einer FRAND-Lizenzgebühr (für welche die besagten Kosten- und Gewinnangaben nicht erforderlich seien) beschränkt sei, weil sie selbst und ihre Rechtsvorgängerinnen ihrer Pflicht zur Mitwirkung an einer Lizenzierung des Klagepatents zu FRAND-Bedingungen nachgekommen seien, die Beklagten jedoch nicht.[2299] Da die beschränkte Pflicht zur Rechnungslegung Folge des Verstoßes der Patentinhaberin gegen ihre kartellrechtlichen Pflichten sei, treffe es ersichtlich nicht zu, dass ihr ein nach den Reglungen der Enforcement-RL zustehender Rechtsschutz vorenthalten und der Patentverletzer geradezu dazu eingeladen würde, bei der Lizenzierung hinhaltend zu agieren.[2300] Vielmehr verhalte es sich genau umgekehrt, weil es der Patentinhaber im Anschluss an eine Lizenzierungsbitte des Verletzers in der Hand habe, sich seinen vollen Schadenersatz und Rechnungslegungsanspruch durch in zügig unterbreitetes und formal wie inhaltlich ordnungsgemäßes Lizenzangebot zu sichern.[2301] Die Initiativpflicht zur einem FRAND-gemäßen Lizenzangebot bleibe hierbei – nicht anders als beim Unterlassungsanspruch – auf Seiten des Patentinhabers, der durch seine FRAND-Zusage nicht nur ein berechtigtes Vertrauen des Geschäftsverkehrs in die freiwillige Lizenzbereitschaft des SEP-Inhabers begründet habe, sondern der darüber hinaus auch allein im Wissen um die bereits abgeschlossenen Lizenzverträge sei, denen gegenüber eine Diskriminierung zu vermeiden sei.[2302] Mit Rücksicht auf beide Umstände mache es keinen eine divergierende rechtliche Behandlung rechtfertigenden Unterschied, ob aus der nämlichen

[2294] LG Düsseldorf, 12.12.2018 – 4b O 4/17, Rn. 442; 12.12.2018 – 4b O 5/17, Rn. 319; 12.12.2018 – 4b O 15/17, Rn. 380; 12.12.2018 – 4b O 16/17, Rn. 304.

[2295] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 175.

[2296] LG Düsseldorf, 8.1.2019 – 4a O 12/17, Rn. 175.

[2297] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 304 – *Improving Handovers*.

[2298] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 305 – *Improving Handovers*.

[2299] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2300] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers.*

[2301] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers.*

[2302] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

FRAND-Zusage (wie beim Unterlassungsanspruch) ein den Anspruch blockierendes prozessrechtliches Durchsetzungshindernis oder (wie beim Rechnungslegungs- und Schadenersatzanspruch) eine Beschränkung des sachlichen Anspruchsinhalts hergeleitet werden solle.[2303]

Ebenso sei belanglos, dass die Verletzungsanzeige von der Klägerin erhoben worden sei, bevor die Entscheidung des EuGH veröffentlicht worden sei.[2304] Die Auslegung des Unionsrechts durch den Gerichtshof sei rein feststellend und deswegen von den mitgliedstaatlichen Gerichten auch auf Rechtsverhältnisse anzuwenden, die vor Erlass der Vorabentscheidung begründet worden seien.[2305] Weil das Hindernis eines gänzlich fehlenden oder inhaltlich unzureichenden FRAND-Angebots beseitigungsfähig sei, habe die Klageabweisung – wie geschehen – „als derzeit unbegründet" zu erfolgen.[2306] Im Zusammenhang mit den Rechnungslegungsangaben bedeute dies, dass der Anspruch der Klägerin auf Auskünfte zu den Kosten und Gewinnen (endgültig) für alle diejenigen Benutzungshandlungen abgewiesen werden, die zu einer Zeit vorgenommen worden seien, zu der ein FRAND-Angebot pflichtwidrig nicht unterbreitet gewesen sei.[2307] Sei – wie vorliegend – der gesamte Rechtsstreit ohne ein solches Angebot geblieben, geschehe die Abweisung dementsprechend für die Zeit bis zur letzten mündlichen Verhandlung bzw. bis zu der der Klägerin eingeräumten Schriftansatzfrist.[2308]

Soweit das LG Mannheim in Funkstation „wegen der besonderen FRAND-Situation" Kosten und Gewinnangaben auch dann zusprechen wolle, wenn letztlich bloß eine FRAND-Lizenzgebühr zu entrichten sei, folge der Senat dem nicht.[2309] Abgesehen davon, dass die anspruchsrelevanten „Besonderheiten" nicht näher konkretisiert würden und sich für den Senat auch nicht erschlössen, entspreche es einem allgemeinen Grundsatz, dass nur diejenigen Einzeldaten auskunftspflichtig seien, auf die der Verletzte für seine Schadensberechnung angewiesen sei.[2310] Für Patentverletzungen im Zusammenhang mit einem SEP gelte insoweit nichts Besonderes.[2311] Auch bei ihnen rechtfertige sich die Pflicht zur Rechnungslegung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) aus drei miteinander verknüpften Gesichtspunkten, nämlich aus der unverschuldeten Unkenntnis des Berechtigten über die auskunftspflichtigen Daten, aus seinem Angewiesensein auf die fraglichen Informationen für die Verfolgung seiner Ansprüche und aus der Möglichkeit des Verpflichteten, dem Verletzer das für ihn notwendige Wissen unschwer zu vermitteln.[2312] Wo bestimmte Geschäftsdaten (über Kosten und Gewinne) objektiv nicht benötigt würden, weil sie für die allein in Betracht kommende Schadensberechnung nach FRAND-Regeln nicht erforderlich seien, könne es keinen Anspruch auf deren Bekanntgabe geben.[2313] Daran ändere der Umstand nichts, dass die schadensersatzpflichtigen Patentbenutzung im Zusammenhang mit einem technischen Standard stattgefunden habe.[2314]

[2303] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers.*

[2304] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE.*

[2305] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf BVerfG, 6.7.2010 – 2 BvR 2661/06 – *Honeywell*.

[2306] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers.*

[2307] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers.*

[2308] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 306 – *Improving Handovers.*

[2309] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 307 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf LG Mannheim, 10.11.2017 – 7 O 28/16 – *Funkstation.*

[2310] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 307 – *Improving Handovers.*

[2311] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 307 – *Improving Handovers.*

[2312] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 307 – *Improving Handovers.*

[2313] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 307 – *Improving Handovers.*

[2314] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 307 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Alle übrigen Daten, die zur Berechnung einer (Schadenersatz- oder Entschädigungs-)Lizenzgebühr üblicherweise zuerkannt würden, seien jedoch mitzuteilen.[2315] Insoweit unterscheide sich die FRAND-Lizenz nicht grundlegend von einer gewöhnlichen als Schadenersatz oder Entschädigung geschuldeten Lizenz; wie bei letzterer habe der Lizenzsucher auch in einer FRAND-Situation Rechenschaft auch über alle diejenigen Geschäftsdaten abzulegen, die es dem Patentinhaber erlaubten, die ihm mitgeteilten – streng genommen allein lizenzrelevanten – Umsatzzahlen nachzuvollziehen und auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen, wozu es zwingend detaillierter Angaben zu den einzelnen Liefervorgängen und ihrer Akteure, den Angeboten und der unternommenen Werbung bedürfe.[2316] Soweit die Beklagte erstmals mit Schriftsatz vom 6.3.2019 behaupte, entsprechende Angaben seien in (frei ausgehandelten) Lizenzverträgen völlig unüblich, handele es sich nicht nur um neues, nicht entschuldigtes Vorbringen, das schon aus prozessualen Gründen nicht mehr zuzulassen sei, sondern darüber hinaus um bloß pauschalen Sachvortrag, der schon deshalb nicht überzeugen könne, weil Lizenzgeber selbstverständlich ein vitales Interesse daran hätten, die ihm vom Lizenznehmer benannten Umsatzzahlen verifizieren zu können, und nicht ersichtlich sei, auf welche andere Weise als durch die gebührenpflichtigen Umsatzgeschäfte konkretisierende Daten sonst die Möglichkeit zu einer Nachprüfung eröffnet sein könne.[2317]

Die Klägerin sei ihren Verpflichtungen aus der für das Klagepatent abgegebenen FRAND-Erklärung nicht nachgekommen, weswegen die Beklagten zu Recht auf dem Standpunkt ständen, dass sie – aus eben diesem Grunde – derzeit nur zur Rechnungslegung im Hinblick auf die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr und zu keinem weitergehenden Schadenersatz nebst vorbereitender Rechnungslegung verpflichtet seien.[2318] Nachdem die Klägerin ihren die Gewinne und Kosten der Beklagten betreffenden Rechnungslegungsanspruch im Berufungsverfahren selbst auf die Zeit seit dem 29.6.2017 beschränkt habe, komme es nicht darauf an, ob die Klägerin bereits vorgerichtlich ihrer Pflicht zur Verletzungsanzeige nachgekommen sei und die Beklagten um eine FRAND-Lizenz nachgesucht hätten.[2319] Beide Obliegenheiten seien jedenfalls mit Blick auf die Klageschrift und deren Beantwortung erfüllt und der kartellrechtliche Pflichtenverstoß der Klägerin folge für die relevante Zeit ab dem 29.6.2017 in jedem Fall daraus, dass von ihr im Anschluss an die Lizenzierungsbitte der Beklagten kein FRAND-Anforderungen genügendes Lizenzangebot unterbreitet worden sei.[2320]

[2315] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 308 – *Improving Handovers.*

[2316] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 308 – *Improving Handovers.*

[2317] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 308 – *Improving Handovers.*

[2318] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 309 – *Improving Handovers.*

[2319] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 309 – *Improving Handovers.*

[2320] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 309 – *Improving Handovers.*

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

XIV. Patent Ambush

Das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 hielt fest, es könne dahingestellt bleiben, ob eine patentanmeldende Rechtsvorgängerin tatsächlich das Vorhandensein des Klagepatents verschwiegen habe und ob sich die Klägerin dieses Verhalten ferner zurechnen lassen müsse.[2321] Selbst wenn man diese beiden Punkte bejahe, würde letztlich weder ein Anspruch auf Erteilung einer Freilizenz bestehen noch der Einwand aus § 242 BGB durchgreifen.[2322] Ein Patenthinterhalt führe grundsätzlich nicht dazu, dass der Patentinhaber den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch aus dem verschwiegenen Patent überhaupt nicht mehr durchsetzen könne.[2323] Rechtsfolge sei vielmehr nur eine Lizenzierungspflicht zu FRAND-Bedingungen an diesem Patent.[2324] Durch die Lizenzierungspflicht würden Dritte nämlich zutreffend so gestellt, als ob sich der SEP-Inhaber bei der Standardisierung ordnungsgemäß verhalten haben würde.[2325] Weitergehende Einschränkungen des Patentinhabers würden über den Ausgleich des Fehlverhaltens hinausgehend eine nicht gerechtfertigte Bestrafung bedeuten.[2326]

Eine Verpflichtung der Klägerin zur Lizenzierung zu FRAND Bedingungen bestehe aber ohnehin.[2327] Dabei könne dahingestellt bleiben, ob dies ohne eine entsprechende FRAND-Erklärung bereits ohne weiteres aus Art. 102 AEUV folge, so dass letztlich ein Patenthinterhalt stets folgenlos bleibe.[2328] Denn die Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu vergeben, folge hier zumindest aus der FRAND-Erklärung der Klägerin, die sie gegenüber ETSI abgegeben habe und die auch das Klagepatent umfasse.[2329] Mit der späteren Abgabe einer FRAND-Erklärung sei ein eventueller Verstoß (Patenthinterhalt) grundsätzlich geheilt.[2330]

Eine Freilizenz könne allenfalls dann als Folge eines Patenthinterhalts in Betracht kommen, wenn zumindest eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür festgestellt werden könne, dass bei rechtzeitiger Offenlegung des Schutzrechts eine alternative Technik standardisiert worden wäre.[2331]

[2321] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 424 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 375 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 423; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 376.

[2322] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 424 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 375 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 423; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 376.

[2323] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 425 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 376 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 424; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 377.

[2324] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 425 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 376 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 424; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 377, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 314, 3.11.2015 – 4a O 144/14, Rn. 171 und 24.4.2012 – 4b O 274/10, Rn. 252 und die zustimmende Auffassung des LG Mannheim, 27.11.2015 – 2 O 106/14, Rn. 198.

[2325] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 425 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 376 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 424; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 377.

[2326] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 425 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 376 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 424; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 377.

[2327] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 426 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 377 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 425; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 378.

[2328] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 426 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 377 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 425; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 378.

[2329] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 426 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 377 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 425; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 378, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf. 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 315.

[2330] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 426 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 377 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 425; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 378.

[2331] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 427 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 378 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 426; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 379.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Hierfür trage die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast.[2332] Dieser Darlegungslast sei die Beklagte nicht im Ansatz nachgekommen.[2333] Sie mache keine Angaben dazu, wie die Standardisierung tatsächlich abgelaufen sei und warum eine andere Technik standardisiert worden wäre, wenn die frühere Patentinhaberin das Klagepatent rechtzeitig offenbart haben würde.[2334] Vielmehr trage die Beklagte nur pauschal vor, dass jedenfalls „nicht ausgeschlossen werden" könne, dass die „Standardisierungsgremien bei Kenntnis der Lehre des Klagepatents das Standardisierungsverfahren anders betrieben" haben würden.[2335] Dies reiche erkennbar nicht aus, um ein anderes Standardisierungsergebnis feststellen zu können.[2336]

Auch das LG Mannheim führte im Entscheid vom 28.9.2018 aus, den geltend gemachten Ansprüchen könne die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des sogenannten Patenthinterhalts („Patent Ambush") einen Arglisteinwand nicht mit Erfolg entgegenhalten.[2337] Die Voraussetzungen etwaiger die Rechtsdurchsetzung der Klägerin hindernder Ansprüche aus § 33 GWB, Art. 102 AEUV oder aus § 826 BGB seien bereits ungeachtet der Frage, ob und unter welchen Umständen ein arglistiges Verhalten der Patentanmelderin auch Erwerbern des Patents entgegengehalten werden könne, nicht dargetan.[2338] So könne es dahingestellt bleiben, ob – wie die Beklagte meine – Rechtsfolge eines „Patenthinterhaltes" die Verpflichtung der Klägerin sein würde, Dritten Freilizenzen zu gewähren und dies nicht nur die – die geltend gemachten Ansprüche nicht hindernde – Folge haben könne, dass eine Verpflichtung zur Lizenzierung zu FRAND-Konditionen bestehe.[2339]

Soweit sich die Beklagte auf den Vorwurf stütze, die Rechtsvorgängerin der Klägerin habe die Anmeldung des Klagepatents entgegen den Vorgaben der ETSI-Policy im Standardisierungsverfahren bewusst nicht offengelegt, genüge dies für sich noch nicht.[2340] Zwar könne nach Auffassung der Kammer unter bestimmten Voraussetzungen das Vorgehen des – auch zu FRAND-Bedingungen lizenzierungsbereiten – Patentinhabers aus einem standardessentiellen Patent gegen das aus Art. 102 AEUV folgende Missbrauchsverbot verstoßen.[2341] Indessen werde unter Berücksichtigung des auch im Unionsrecht anerkannten und zu schützenden Grundrechts des geistigen Eigentums ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Inhabers standardessentieller Patente trotz dessen Bereitschaft, Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, nur in Ausnahmefällen festgestellt werden können, in denen durch FRAND-Lizenzen den Wettbewerbszielen der Europäischen Union und der sie gründenden Verträge nicht mehr Geltung zu verschaffen wäre.[2342] Ein solche Fall könne nach der genannten Entscheidung der Europäischen Kommission dann angenommen werden, wenn der an der Standardisierung beteiligte Patentinhaber das Standardisierungsverfahren bewusst im Sinne

[2332] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 427 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 378 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 426; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 379, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 31.3.2016 – 4a O 126/14, Rn. 316.

[2333] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 428 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 379 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 427; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 380.

[2334] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 428 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 379 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 427; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 380.

[2335] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 428 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 379 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 427; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 380.

[2336] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 428 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 379 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 427; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 380.

[2337] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 94.

[2338] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 95.

[2339] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 96, mit Verweis auf die dies ablehnende Ansicht unter Hinweis auf § 249 BGB LG Düsseldorf, 7.6.2011 – 4b O 31/10, Rn. 84–85.

[2340] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 97.

[2341] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 98, mit Verweis auf COM, 9.12.2009 – COMP/38.636 – *Rambus*.

[2342] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 98.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

„vorsätzlich betrügerischen Handelns“ – hintertreibe und eine andere, von der patentgemäßen Erfindung abweichende, technische Spezifikation bewusst vereitele.[2343] Erst dann könne das Bestehen des Patentinhabers auf FRAND-Lizenzen als Missbrauch der ihm durch die Patenterteilung und Standardisierung zugewachsenen marktbeherrschenden Stellung bewertet werden.[2344]

Voraussetzung für den Missbrauch wäre hiernach zunächst, dass eine Offenlegung im Standardisierungsverfahren zu einer abweichenden, nicht die klagepatentgemäße technische Lehre nutzenden Ausgestaltung des Standards geführt haben können würde, wofür die Beklagte darlegungsbelastet sei.[2345] Diese trage nicht vor, welche technische Lösung an Stelle der in den Standard übernommenen technischen Lehre in Betracht gekommen wäre.[2346] Entgegen der Auffassung der Beklagten sei ihr ein solcher Vortrag auch zumutbar.[2347] Denn der insoweit relevante Stand der Technik lasse sich ohne weiteres ermitteln.[2348] Nur in dem Fall, in dem es überhaupt eine alternative Lösung gegeben habe, stelle sich die Frage, ob dem Patentinhaber, welcher in Person oder in Person seines Rechtsvorgängers an dem Standardisierungsverfahren beteiligt gewesen sei, eine sekundäre Darlegungslast zur Frage obliege, ob die alternative Lösung in Betracht gezogen worden wäre.[2349] Die bloße theoretische Möglichkeit einer anderweitigen Lösung genüge – auch ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Teilnehmer der den Standard beratenden Arbeitsgruppe trotz der damit verbundenen FRAND-Lizenz auch für eine von ihnen als vorteilhafter erachtete patentgeschützte technische Lehre entscheiden könnten – nicht.[2350] Daher bestehe für die Kammer auch kein Anlass, die Frage der Rechtsfolge eines Patenthinterhaltes dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV zur Vorabentscheidung vorzulegen.[2351]

[2343] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 98.

[2344] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 98.

[2345] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 99, mit Verweis auf COM, 9.12.2009 – COMP/38.636 – *Rambus*.

[2346] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 99.

[2347] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 99.

[2348] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 99.

[2349] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 99.

[2350] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 99.

[2351] LG Mannheim, 28.9.2018 – 7 O 165/16, Rn. 99.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

XV. Rolle des Art. 101 AEUV

Betreffend die Rolle des Art. 101 AEUV für die FRAND-Lizenzierung führte das LG Düsseldorf mit Versäumnisurteil vom 9.11.2017 allgemein aus, der Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz unter bestimmten Voraussetzungen als Rechtsfolge eines Verstoßes gegen Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB, der dem Schutzrechtsinhaber im Verletzungsprozess als die Durchsetzung seines Rechts hindernder Einwand entgegengehalten werden könne, komme unter anderem für Patente in Betracht, die einem Industrie- oder Branchenstandard zugrunde liegen würden.[2352] Dies treffe für das vorliegende Erfindungspatent zu, das bei dem Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) als Standard für mehrere technische Standards deklariert worden sei.[2353] Eine solche Festlegung sei geeignet, wenn – wie im Entscheidungsfall – für Marktteilnehmer keine Ausweichmöglichkeit auf andere technische Lösungen bestehe, eine Marktabschottung zu bewirken und eine horizontale Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB zu begründen.[2354] Andererseits gewährleiste sie eine branchenweite Interoperabilität.[2355] Für die kartellrechtliche Beurteilung sei deshalb entscheidend, dass alle Marktteilnehmer bzw. alle Marktzutrittswilligen Zugang zu der als Standard festgelegten Technik erhielten, denn er sei Teilnahmevoraussetzung für eine Betätigung auf dem entsprechenden Markt.[2356] Patente, die einem solchen Standard zugrunde lägen, würden als standard-essentielle Patente (SEP) bezeichnet.[2357] Standardisierungsvereinbarungen, die keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm enthielten und Dritten den Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien (FRAND) Bedingungen gewährten, würden nicht zu einer Beschränkung des Wettbewerbs führen.[2358]

In *Improving Handovers* führte das OLG Düsseldorf spezifischer zu Art. 101 AEUV aus, die Verpflichtung zur Offenlegung der abgeschlossenen Lizenzverträge (vgl. zu Geheimhaltung bereits oben XI.B.1.c)3)) verstoße nicht gegen Art. 101 AEUV.[2359] Die gegenteilige Auffassung der Streithelferin beruhe maßgeblich auf der Prämisse, dass die das unterbreitete Lizenzangebot erläuternden Bemerkungen zur bisherigen Lizenzierungspraxis den SEP-Inhaber und seinen Rechtsvorgänger zwingen würden, potenziellen Wettbewerbern Geschäftsgeheimnisse zu offenbaren, was kartellrechtlichen Grundsätzen zuwiderlaufe.[2360] Bereits die Ausgangsthese sei falsch.[2361] Denn es sei in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass innerhalb eines Verletzungsprozesses im Zusammenhang mit der FRAND-Diskussion sehr wohl Maßnahmen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen möglich seien (dazu ausführlich oben XI.B.1.c)3)).[2362]

Auch mit den Patentübertragungen sei ein Verstoß gegen Art 101 AEUV nicht verbunden.[2363] Die Vorschrift verbiete Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten

[2352] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2353] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2354] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24, mit Verweis auf COM, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 14.1.2011 (2011/C 11/01), Tz. 257, 265, 266.

[2355] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2356] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2357] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2358] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24, mit Verweis auf COM, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 14.1.2011 (2011/C 11/01), Tz. 277, 280 ff.

[2359] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[2360] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[2361] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[2362] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 176 – *Improving Handovers*.

[2363] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 185 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

zu beeinträchtigen geeignet seien und eine spürbare Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes entweder subjektiv bezweckten oder objektiv bewirkten.[2364] Austauschverträge (wie sie vorliegend mit Blick auf die entgeltlichen Übertragungen des Patentportfolios der Streithelferin gegeben seien) unterfielen als solche nicht dem Anwendungsbereich von Art. 101 AEUV.[2365] Sie seien auf einen Leistungsaustausch zwischen den vertragsbeteiligten Unternehmen gerichtet und mit diesem Inhalt per se nicht geeignet, wettbewerbsbeeinträchtigende Wirkungen zu entfalten.[2366] Um den Anwendungsbereich des Kartellverbots zu eröffnen, bedürfe es deshalb einer – mindestens objektiv – wettbewerbsbeschränkenden Nebenabrede innerhalb des für sich kartellrechtsneutralen Austauschvertrages, wobei die Nebenabrede über dasjenige hinausgehen müsse, was erforderlich sei, um den Hauptzweck des Austauschvertrages zu verwirklichen.[2367] Entscheidend sei hierbei, ob die vereinbarte Wettbewerbsbeschränkung sachlich erforderlich und zeitlich, räumlich sowie gegenständlich darauf beschränkt sei, den mit dem Austauschvertrag verfolgten Zweck zu erreichen.[2368] Sei dies der Fall, komme ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV auch mit Blick auf die Nebenabrede nicht in Betracht; gehe die Wettbewerbsklausel über das Maß des Erforderlichen hinaus, sei eine zur Vertragsnichtigkeit führende kartellrechtswidrige Wettbewerbsbeeinträchtigung denkbar, wobei allerdings in Fällen eines bloß zeitlichen Übermaßes eine geltungserhaltende Reduktion zulässig sei.[2369]

Weder das Master Sale Agreement noch die Patentübertragungsvereinbarungen enthielten irgendeine wettbewerbsbeschränkende oder -verfälschende Nebenabrede, die den Anwendungsbereich des Art. 101 AEUV eröffnen könne würde.[2370]

Soweit sich die Beklagte auf die Einlassung der Streithelferin beziehe, die Übertragung ihres Patentportfolios sei zu dem Zweck und in der Erwartung geschehen, höhere Lizenzeinnahmen durchzusetzen, als sie ihr (der Streithelferin) selbst in Verhandlungen mit Patentbenutzern möglich gewesen seien, handele es sich um eine bloße Motivationslage für die Patentübertragungen, aber nicht um eine die vertraglichen Rechte- und Pflichtenlage regelnde Klausel (= Nebenabrede), derer es als Anknüpfungspunkt für das Kartellverbot bedürfen würde.[2371]

Abgesehen davon seien die Patenterwerber sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach in gleicher Weise an die FRAND-Zusage gebunden wie es die Streithelferin gewesen sei und sein werden würde (siehe oben VII), womit der Vorwurf der Beklagten, die Patentübertragungen seien dazu geeignet, Lizenzgebühren zu erzielen, die wegen ihrer unangemessenen Höhe non-FRAND seien, auch sachlich einer Grundlage entbehre.[2372] Gleichermaßen bedeutungslos sei unter Wettbewerbsgesichtspunkten das Argument, die Klägerin sei auf dem nachgelagerten Produktmarkt für standardgebundene Erzeugnisse selbst nicht operativ tätig, weshalb sie im Rahmen ihrer Lizenzverhandlungen mit einem Patentbenutzer auch keine Rücksicht darauf nehmen müsse, von diesem aus seinem eigenen SEP-Portfoliobestand angegriffen zu werden.[2373] Ob das Lizenzangebot des klagenden Schutzrechtsinhabers FRAND-Kriterien genüge und insbesondere das mit dem Lizenzangebot verlange

[2364] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*.

[2365] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf BGH, 26.1.2016 – KVR 11/15.

[2366] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*.

[2367] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*.

[2368] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf BGH, 26.1.2016 – KVR 11/15.

[2369] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 186 – *Improving Handovers*.

[2370] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 187 – *Improving Handovers*.

[2371] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 188 – *Improving Handovers*.

[2372] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers*.

[2373] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Benutzungsentgelt der Höhe nach angemessen und diskriminierungsfrei sei, unterliege im Patentverletzungsprozess der uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle, wobei es bereits im Vorfeld dieser Prüfung Sache des Patentinhabers sei, für den Adressaten nachvollziehbar zu begründen, weshalb das mit der Lizenzofferte unterbreitete Regelwerk als Ganzes und namentlich die darin vorgesehene Lizenzgebühr fair, zumutbar und diskriminierungsfrei (=FRAND) sein solle.[2374] Erst wenn diese inhaltliche Rechtfertigung geleistet und die FRAND-Gemäßheit des Lizenzangebotes zugunsten des Schutzrechtsinhabers geklärt sei, komme eine Verurteilung in Betracht, die weitergehend in die Rechtsposition des Verletzers eingreifen würde als es die jedem SEP-Benutzer ohnehin obliegende Pflicht beinhalte, den Gebrach des fremden geistigen Eigentums durch eine FRAND-Lizenzgebühr und eine dem vorausgehende Rechnungslegung zu entgelten.[2375] Eine Verschärfung der Haftung sei unter den besagten Umständen aber auch vollkommen gerechtfertigt, weil die Verurteilung wegen Patentverletzung ihre Ursache allein darin habe, dass der Verletzer das – auch unter Berücksichtigung der vom Rechtsvorgänger vergebenen Lizenzen – FRNAD-Bedingungen genügende Lizenzangebot des SEP-Inhabers unberechtigt ausgeschlagen habe, auf das er hätte eingehen müssen.[2376] Aus dem gerichtlichen Prüfungsvorbehalt folge des Weiteren, dass eine Wettbewerbsbeschränkung noch nicht damit verbunden sein könne, dass der SEP-Inhaber (unberechtigte) Lizenzforderungen erhebe, die mit den dargelegten FRAND-Grundsätzen im Falle eines Patenterwerbs nicht in Einklang ständen.[2377]

Aus denselben Erwägungen heraus sei es kartellrechtlich belanglos, dass die Streithelferin einen Teil des standardessentiellen Patentportfolios in ihrem Besitz gehalten habe.[2378] Ungeachtet dessen, dass auch insoweit keine wettbewerbsbeschränkende Vertragsklausel erkennbar sei, stehe es der Streithelferin selbstverständlich frei, für die Benutzung des bei ihr verbliebenen SEP-Bestandes Lizenzgebühren einzufordern.[2379] Da sie herbei den formellen (sic.: Pflicht zum Lizenzangebot) und sachlichen (sic.: FRAND-Gemäßheit der Lizenzofferte) Beschränkungen aus ihrer Lizenzierungszusage unterliege, liefen Benutzer des Gesamt-Portfoliobestandes nicht Gefahr, zu einer gesetzlich nicht geschuldeten, weil unangemessen hohen Lizenzgebühr verpflichtet zu werden.[2380] Denn wegen der FRAND-Bindung sowohl der Klägerin als auch der Streithelfern setzten die FRAND-Kriterien auch für die Benutzung des kompletten SEP-Bestandes die Obergrenze für jede finanzielle oder sonstige Lizenzbelastung eines SEP-Benutzers.[2381] Dass es der Streithelferin wegen der gegebenen Rahmenbedingungen selbst aus tatsächlichen Gründen nicht möglich gewesen sei, den rechtliche zulässigen Spielraum einer FRAND-Lizenzgebühr in Vertragsverhandlungen mit Verletzern auszuschöpfen, möge sein, habe kartellrechtlich jedoch keine Bedeutung.[2382] Denn das Kartellrecht diene nicht dazu, einen Patentverletzer davon in Schutz zu nehmen, für die Benutzung fremden geistigen Eigentums in demjenigen Umfang zur Zahlung von Lizenzgebühren herangezogen zu werden, der von Gesetzes wegen zulässig sei.[2383] Soweit die Streithelferin bereits – zu ihrem eigenen Nachteil wirtschaftlich unzulängliche – Lizenzen vergeben habe, sei auch die Klägerin als Rechtsnachfolgerin über das Diskriminierungsverbot an diejenige Lizenzierungspraxis der Streithelferin gebunden, die sie bisher praktiziert habe und von der sie selbst – und folgerichtig auch ihre Rechtsnachfolger – nur dann

[2374] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers*, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 – *Mobiles Kommunikationssystem*.

[2375] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers*.

[2376] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers*.

[2377] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 189 – *Improving Handovers*.

[2378] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers*.

[2379] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers*.

[2380] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers*.

[2381] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers*.

[2382] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers*.

[2383] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

und nur insoweit abweichen könne, wie sachliche Unterschiede in den Lizenzierungssachverhalt dies rechtfertigten.[2384]

Soweit sich die Beklagte über die Verfahrenskosten ihrer Inanspruchnahme wegen Patentverletzung in mehreren Ländern beklage, knüpfe die Beklagte an ein rein tatsächliches Verhalten an, welches kartellrechtlich gänzlich belanglos sei.[2385] In einem Rechtsstaat stelle es das gute Recht jedes Patentinhabers dar, seine vermeintlichen Ansprüche vor Gericht durchzusetzen.[2386] Selbst wenn die Streithelferin – wofür schon im Tatsächlichen keinerlei Anhaltspunkte erkennbar seien – im Zuge der Patentübertragung darauf gedrängt haben sollte, dass die Klägerin die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch nehme, folge hieraus kartellrechtlich nichts.[2387] Gerade weil die Streithelferin über eine prozentuale Beteiligung an den vom Patenterwerber erzielten Lizenzgebühren partizipiere, stelle es – im Gegenteil – ein völlig legitimes geschäftliches Interesse dar, dass der Erwerber notfalls auch mit den Mitteln einer Verletzungsklage Vorsorge dafür treffe, dass sich die Beklagte ihrer Verpflichtung zur Zahlung von FRAND-Lizenzgebühren nicht entziehe.[2388] Wegen des in Deutschland geltenden Kostenerstattungsprinzips laufe die Beklagte in diesem Zusammenhang auch nicht Gefahr, im Falle ihres Obsiegens mit finanziellen Nachteilen belastet zu bleiben.[2389] Soweit anderenorts abweichende Kostenregelungen existieren sollten, gelte nichts anderes.[2390] Denn bei einer derartigen Rechtslage entspreche es dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers und könne deshalb nicht als kartellrechtsrelevanter Umstand gewertet werden, dass eine Prozesspartei trotz ihres Obsiegens im Rechtsstreit die Kosten ihrer Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst zu tragen habe.[2391]

Ob die Rechtslage anders zu beurteilen sein könne, wenn ein umfangreiches SEP-Portfolio regelrecht „atomisiert“ werde, indem das Gesamtpaket auf eine unüberschaubare Vielzahl von Einzelinhabern aufgespalten werde, mit denen allein sich der Lizenzsucher bei seinen Lizenzverhandlungen auseinandersetzen müsse, bedürfe im Streitfall keiner Entscheidung, denn ein derartiger Sachverhalt sein im Streitfall nicht einmal ansatzweise gegeben.[2392]

Aus dem Gesagten ergebe sich sogleich, dass die Entgeltregelung im Master Sale Agreement den Vorwurf einer Kartellrechtswidrigkeit ebenfalls nicht tragen könne.[2393] Was zunächst die Regelung anbetreffe, dass die Streithelferin unter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf einen Prozentsatz der von dem Erwerber des Patentportfolios erzielten Lizenzeinnahmen habe, komme dem von vornherein keine Bedeutung zu.[2394] Selbst wenn der Lizenzanteil als unangemessen hoch zu beurteilen sein würde, liege allenfalls ein Ausbeutungsmissbrauch zulasten des Patenterwerbers vor, der keinerlei Betroffenheit im Sinne des Kartellverbots nach Art. 101 AEUV auf Seiten der Beklagten begründen könne.[2395]

Gleichermaßen unbedenklich sein die Vereinbarung, dass in bestimmten Sachverhaltskonstellationen Bemessungsgrundlage für den an die Streithelferin abzuführenden Lizenzgebührenanteil nicht die vom Erwerber des Portfolios tatsächlich erzielten Lizenzeinnahmen seien, sondern stattdessen eine so

[2384] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 190 – *Improving Handovers*.
[2385] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers*.
[2386] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers*.
[2387] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers*.
[2388] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers*.
[2389] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers*.
[2390] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers*.
[2391] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 191 – *Improving Handovers*.
[2392] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 192 – *Improving Handovers*.
[2393] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 193 – *Improving Handovers*.
[2394] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 194 – *Improving Handovers*.
[2395] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 194 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

genannte „Applicable Royalty Rate“.[2396] Sie repräsentiere einen vereinbarten Mindestlizenzbetrag, der als Rechengröße sicherstelle, dass die Streithelferin für den Fall, dass es dem Erwerber nicht gelinge, ausreichende Lizenzeinnahmen zu generieren eine angemessene Vergütung für ihr übertragenes geistiges Eigentum erhalte.[2397] Gegen diese Art der Entgeltvereinbarung sei unter Geltung der Privatautonomie nichts zu erinnern.[2398] Das gelte auch im Hinblick darauf, dass die „Applicable Royalty Rate“ mittelbar einen Anreiz für den Erwerber bieten möge, tunlichst keine niedrigen Lizenzentgelte zu vereinbaren, weil er den der Streithelferin geschuldeten Lizenzanteil ansonsten zum Teil aus eigenen finanziellen Mitteln zusteuern müssen würde.[2399] Der Sache nach handele es sich jedoch um keine andere Situation als sie bestehen würde, wenn für den Portfolioerwerb – was unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten völlig unbedenklich sein würde, ein fester Kaufpreis vereinbart worden würde, der den Erwerber, je höher der vereinbarte Kaufpreis gewesen sei, ebenfalls in die wirtschaftliche Notwendigkeit gebracht haben würde, tunlichst lukrative Lizenzvertragsabschlüsse zu tätigen.[2400] Hinzu komme, dass der Anreiz für eine bestimmte Mindestlizenzvergütung innerhalb des FRAND-Rahmens alle Lizenzinteressenten gleichermaßen betreffen würde, so dass nicht ersichtlich sei, inwiefern die Vergütungsregelung im Master Sale Agreement zu einer Wettbewerbsbehinderung der Nachfrage auf dem Lizenzvergabemarkt führen können würde.[2401]

[2396] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers*.
[2397] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers*.
[2398] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers*.
[2399] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers*.
[2400] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers*.
[2401] OLG Düsseldorf, 22.3.2019 – I-2 U 31/16, Rn. 195 – *Improving Handovers*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

XVI. Weitere prozessuale Themen

A. Trennungsprinzip und Aussetzung

Betreffend Aussetzung der Verhandlung vor dem Hintergrund des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gemäß § 148 Abs. 1 ZPO äußerte sich das LG Düsseldorf vom 13.7.2017 dahingehend, dass nach ständiger Rechtsprechung der Kammer, die auch vom OLG Düsseldorf und vom Bundesgerichtshof gebilligt werde, ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund darstellten, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd sei.[2402] Die Aussetzung des Rechtsstreits sei daher grundsätzlich nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei, dass das Klagepatent vernichtet werde.[2403] Daran fehle es vorliegend auch dann, wenn man aufgrund des Ablaufs der Schutzdauer des Klagepatents von einem herabgesenkten Aussetzungsmaßstab ausgehe.[2404]

B. FRAND-Einwand und Grenzbeschlagnahmeverfahren

Im Versäumnisurteil vom 9.11.2017 vor dem LG Düsseldorf ging es um einen sich aus § 33 Abs. 1 GWB i.V.m. Art. 102 AEUV ergebenden, im Wege einstweiliger Verfügung sicherbaren Anspruch gegen die Antragsgegnerin, wonach diese es zu unterlassen habe, gestützt auf ihr europäisches Patent einen Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 zu stellen, ohne die Antragstellerinnen von einem solchen Antrag ausdrücklich auszunehmen.[2405] Ihre marktbeherrschende Stellung habe die Antragsgegnerin dadurch missbraucht, dass sie den auch gegen die Antragsstellerinnen gerichteten Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörde gestellt habe.[2406]

Zwar sei die Inanspruchnahme des Grenzbeschlagnahmeverfahrens als eines staatlich eingerichteten und geregelten Verfahrens in der Regel nicht rechtswidrig.[2407] Solange sich der Schutzrechtsinhaber des Verfahrens in redlicher Weise bediene, sei es weder möglich noch sachlich gerechtfertigt, den gesetzgeberischen Willen zur Bekämpfung von Produktpiraterie dadurch zu unterlaufen, dass in das Procedere der VO (EU) 608/2013 gestützte auf allgemein-deliktsrechtliche Normen des Zivilrechts eingegriffen werde.[2408] Ein objektiv missbräuchliches Ausnutzen des Beschlagnahmeverfahrens liege aber dann vor, wenn die Schutzrechtsinhaber bei objektiver Betrachtung zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über den Verfügungsantrag ohne Zweifel daran gehindert sei, sein Schutzrecht durchzusetzen, weil der Rechtsdurchsetzung ein rechtshindernder Einwand entgegenstehe.[2409] Dies sei vorliegend der Fall, weil die Antragsstellerinnen dem Versuch der Antragsgegnerin, ihr europäisches Patent z.B. ein einem Verletzungsprozess durchzusetzen, derzeit mit Erfolg den sogenannten kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (FRAND-Einwand)

[2402] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 439–40 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 390–91 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 438–39; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 391–92, alle mit Verweis auf LG Düsseldorf, 20.12.1994 – 4 O 357/93 und OLG Düsseldorf, 16.11.1978 – 2 U 15/78 und 7.12.1995 – 2 U 214/984 und BGH, 11.11.1986 – X ZR 56/85 – *Transportfahrzeug*.

[2403] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 440 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 391 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 439; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 392, alle mit Verweis auf BGH, 16.9.2014 – X ZR 61/13 – *Kurznachrichten*.

[2404] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 441 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 392 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 440; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 393.

[2405] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 20.

[2406] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 22.

[2407] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 23.

[2408] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 23.

[2409] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 23.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

entgegenhalten können würden.[2410] In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass die Bejahung der auf Unterlassung oder Beseitigung gerichteten Ansprüche aus § 33 Abs. 1 GWB ein Verschulden nicht voraussetze.[2411]

Die Erteilung einer Zwangslizenz könne unter bestimmten Voraussetzungen als Rechtsfolge eines Verstoßes gegen Art. 102 AEUV bzw. §§ 19, 20 GWB verlangt werden.[2412] Ein solcher Anspruch, der dem Schutzrechtsinhaber im Verletzungsprozess als die Durchsetzung seines Rechts hindernder Einwand entgegengehalten werden könne, komme unter anderem für Patente in Betracht, die einem Industrie- oder Branchenstandard zugrunde liegen würden.[2413] Dies treffe für das vorliegende Patent zu, das bei ETSI als Standard für mehrere Standards deklariert worden sei.[2414] Eine solche Festlegung sei geeignet, wenn – wie im Entscheidungsfall – für Marktteilnehmer keine Ausweichmöglichkeit auf andere technische Lösungen bestehe, eine Marktabschottung zu bewirken und eine horizontale Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB zu begründen.[2415] Andererseits gewährleiste sie eine branchenweite Interoperabilität.[2416] Für die kartellrechtliche Beurteilung sei deshalb entscheidend, dass alle Marktteilnehmer bzw. alle Marktzutrittswilligen Zugang zu der als Standard festgelegten Technik erhielten, denn er sei Teilnahmevoraussetzung für eine Betätigung auf dem entsprechenden Markt.[2417] Patente, die einem solchen Standard zugrunde lägen, würden als standard-essentielle Patente (SEP) bezeichnet.[2418] Standardisierungsvereinbarungen, die keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm enthielten und Dritten den Zugang zu der Norm zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien (FRAND) Bedingungen gewährten, würden nicht zu einer Beschränkung des Wettbewerbs führen.[2419]

Der EuGH habe in der Sache Huawei Technologies/ZTE Vorgaben dazu gemacht, wann die Durchsetzung des Unterlassungs- und des Rückrufanspruchs aus einem von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessentiellen Patent, dessen Inhaber sich gegenüber dieser Organisation zur Erteilung von FRAND-Lizenzen an jeden Dritten verpflichtet habe, keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AUEV darstelle.[2420] Danach müsse der Inhaber eines SEPs, bevor er seinen Unterlassungs- oder Rückrufanspruch geltend machen könne, den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung hinweisen.[2421] Wenn der Verletzer zur Lizenznahme bereit sei, müsse der SEP-Inhaber ihm ein konkretes schriftliches Angebot auf Lizenzierung des SEPs zu FRAND-Bedingungen unterbreiten und dabei auch die Art und Weise der

[2410] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 23.

[2411] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 23.

[2412] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2413] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2414] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2415] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24, mit Verweis auf COM, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 14.1.2011 (2011/C 11/01), Tz. 257, 265, 266.

[2416] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2417] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2418] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24.

[2419] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 24, mit Verweis auf COM, Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit, 14.1.2011 (2011/C 11/01), Tz. 277, 280 ff.

[2420] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 25, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477 – *Huawei/ZTE*.

[2421] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 25, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 61 – *Huawei/ZTE*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Berechnung der Lizenzgebühren darlegen.[2422] Zu den Voraussetzungen der den Schutzrechtsinhaber in diesem Zusammenhang treffenden sekundären Darlegungslast werde auf den Beschluss des OLG Düsseldorf vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 verwiesen, dessen Inhalt sich die Kammer zu eigen mache.[2423]

Mache der Patentinhaber kein diesen Vorgaben genügendes Lizenzierungsangebot, stehe der Durchsetzung seines Patents gegen den vermeintlichen Verletzer ein „dilatorisches Durchsetzungshindernis", der sogenannte „FRAND-Einwand" (kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand) entgegen.[2424] Für die Entscheidung in diesem Verfahren sei davon auszugehen, dass die Antragstellerinnen sich mit diesem Einwand derzeit erfolgreich gegen den Versuch der Antragsgegnerin verteidigen können würden, sie zivilrechtlich wegen der Verletzung des Patents in Anspruch zu nehmen.[2425] Unter diesen Voraussetzungen stelle sich die Inanspruchnahme des Verfahrens der VO (EU) 608/2013 als eindeutig rechtsmissbräuchlich dar.[2426]

Auch die weitere Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs aus § 33 Abs. 1 GWB, die Wiederholungsgefahr, bestehe, weil der Rechtsmissbrauch der Antragsgegnerin noch andauere und im Übrigen die tatsächliche Vermutung der Wiederholung begründe, die sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung speise, dass ein schon einmal begangener Missbrauch dessen Wiederholung befürchten lasse.[2427]

C. Rolle des Gerichts im FRAND-Prozedere

In den Entscheiden vom 13.7.2017 traf das LG Düsseldorf Ausführungen zur Rolle des Gerichts im FRAND-Prozedere. So sei das Gericht nicht verpflichtet, durch Umterminierung oder Ähnlichem dem SEP-Inhaber die Nachholung des FRAND-Angebots oder die Durchführung des Prozederes zu ermöglichen.[2428] Zweck der Hinweispflicht aus § 139 ZPO sei es, den Parteien aufzuzeigen, zu welchen Punkten sie sich noch erklären müssten – sie diene aber nicht dazu, die Parteien zu einem bestimmten geschäftlichen Verhalten anzuhalten (hier: ein bestimmtes Vertragsangebot abzugeben bzw. anzunehmen oder ihnen vor vorprozessuale Obliegenheiten im Prozess mehr Zeit zu verschaffen).[2429] Auch der EuGH sehe eine Moderation durch das Gericht zur Schaffung eines FRAND-gemäßen Angebots nicht vor.[2430] Vielmehr sollten sich die Parteien vorprozessual einigen und nur wenn dies scheitere, dürfe der Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend gemacht werden.[2431] Erst wenn beide Parteien die Vorgaben des EuGH erfüllten und dennoch kein Lizenzvertrag zustande komme, solle ein

[2422] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 25, mit Verweis auf EuGH, 16.7.2015 – C-170/13, EU:C:2015:477, Rn. 63 – *Huawei/ZTE*.

[2423] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 25.

[2424] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 26, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 30.3.2017 – I-15 U 66/15 und 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 33.

[2425] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 26.

[2426] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 27.

[2427] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 28, mit Verweis zum Lauterkeitsrecht auf BGH, 9.11.1995 – I ZR 212/93 – *Wegfall der Wiederholungsgefahr* und 26.10.2000 – I ZR 180/98 – *TCM-Zentrum* und 25.10.2001 – I ZR 29/99 – *Vertretung der Anwalts-GmbH*.

[2428] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[2429] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[2430] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[2431] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Dritter zur FRAND-Bestimmung eingeschaltet werden dürfen.[2432] Die Mitwirkung eines Dritten bei der Formulierung von Angebot und Gegenangebot sei dagegen nicht vorgesehen.[2433]

Es liege auch im wohlverstandenen Interesse beider Parteien, dass das Gericht ein abgegebenes Angebot nur bewerte, nicht aber vor einem Urteil auf die Abgabe weiterer Angebote hinwirke: Verhalte sich der SEP-Inhaber FRAND-konform und verweigere der Verletzer dennoch den Lizenzvertragsabschluss oder ein ausreichendes Gegenangebot, so habe der SEP-Inhaber ein anerkennungswürdiges Interesse an einem schnellen Unterlassungstitel.[2434] Gebe der SEP-Inhaber dagegen kein (rechtzeitiges) FRAND-konformes Angebot ab, seien die Folgen ebenfalls akzeptabel.[2435] Denn er könne weiterhin FRAND-gemäße Lizenzgebühren für sein Schutzrecht verlangen.[2436] Er erhalte zudem einen Titel auf Auskunft und Schadenersatzfeststellung (allerdings kartellrechtlich begrenzt, dazu oben XIII.B, XIII.C), den er ansonsten nur mit Verzögerung erhalten haben würde.[2437] Hierüber erhalte er auch eine gerichtliche Bestätigung der Standardessenzialität des jeweiligen Klagepatents und eine positive Prognose des Rechtsbestands (wenn dieser angegriffen sei) – oder je nach Rechtsprechung sogar eine Entscheidung darüber.[2438] Weiterhin trete auch hinsichtlich der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung kein endgültiger Rechtsverlust ein: Die Klage werde insoweit nur als derzeit unbegründet abgewiesen (siehe oben XI.C.2), so dass der SEP-Inhaber nach Erfüllung seiner kartellrechtlichen Verpflichtung erneut klagen könne, falls sich die Parteien nicht zwischenzeitlich einigten.[2439]

Die Möglichkeiten des Gerichts, über Hinweisbeschlüsse erfolgreich eine Einigung herbeizuführen, seien schließlich gering und jedenfalls schlechter als die Chancen bei unmittelbaren, außergerichtlichen Verhandlungen der Parteien.[2440] Bestehe aber kaum Möglichkeit auf eine Einigung durch Vorgaben des Gerichts, erscheine es unangemessen, der Verfahren durch zusätzliche Schriftsatzfristen und/oder die Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung zu verzögern.[2441]

D. Einstweiliger Rechtsschutz und SEP

1. Einstweiliger Rechtsschutz des Patentinhabers

Mit Beschluss vom 29.6.2017 wies das OLG Düsseldorf einen ihm vorliegenden Antrag auf Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung ab, da es jedenfalls an der unter anderem für den notwendigen

[2432] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[2433] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 343 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 294 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 342; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 295.

[2434] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 344–45 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 295–96 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 343–44; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 296–97.

[2435] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 346 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 297 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 345; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 298.

[2436] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 346 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 297 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 345; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 298.

[2437] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 346 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 297 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 345; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 298.

[2438] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 346 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 297 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 345; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 298.

[2439] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 346 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 297 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 345; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 298.

[2440] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 347 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 298 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 346; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 299.

[2441] LG Düsseldorf, 13.7.2017 – 4a O 16/16, Rn. 347 – *Kommunikationsvorrichtung*; 13.7.2017 – 4a O 27/16, Rn. 298 – *Mobiles Kommunikationssystem*; 13.7.2017 – 4a O 35/16, Rn. 346; 13.7.2017 – 4a O 154/15, Rn. 299.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Verfügungsgrund erforderlichen zeitlichen Dringlichkeit mangele.[2442] Der Erlass einer einstweiligen Verfügung setze gemäß §§ 935, 940 ZPO voraus, dass sie notwendig sei, um die Vereitelung oder wesentliche Erschwerung der Rechtsverwirklichung zu verhindern oder wesentliche Nachteile für den Antragsteller abzuwenden.[2443] Anders als in Wettbewerbssachen werde der Verfügungsgrund in Patentsachen nicht widerleglich vermutet; die gesetzliche Vermutung des § 12 Abs. 2 UWG sei hier nicht – auch nicht analog – anwendbar.[2444] Daher seien die besonderen Umstände, die eine Eilmaßnahme rechtfertigen sollten, positiv festzustellen, wobei der Antragsteller dafür nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast trage.[2445]

Entscheidend für das Vorliegen eines Verfügungsgrundes sei, ob es dem Antragsteller nicht zugemutet werden könne, ein Hauptsacheverfahren durchzuführen und in diesem auf den Erlass eines Vollstreckungstitels zu warten.[2446] Dies sei zu bejahen, wenn sein Begehren dringlich sei, der Rechtsbestand des Patents hinreichend gesichert sei und die Abwägung der (übrigen) schutzwürdigen Interessen der Parteien unter Berücksichtigung aller Umstände zugunsten des Antragsstellers ausfalle.[2447] Dringlichkeit erfordere, dass der Antragsteller mit der Einleitung des einstweiligen Verfügungsverfahrens nicht ungebührlich lange zugewartet und hierdurch zu erkennen gegeben habe, dass er seine Rechte nur zögerlich verfolge und eines umgehenden Verbots tatsächlich nicht bedürfe.[2448] Wann Dringlichkeit zu verneinen sei, lasse sich nicht anhand fester Fristen, sondern nur unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls bestimmen, was nach konkreter Sachlage zu einem kürzeren oder längeren Zeitraum führen könne.[2449] Sobald der Antragsteller positive Kenntnis von den Umständen der Schutzrechtsverletzung erlangt habe, sei er regelmäßig gehalten, seine Ansprüche zügig und ohne Nachlässigkeit zu verfolgen.[2450] Diese Kenntnis sei vorhanden, wenn ihm sämtliche Tatsachen, die eine Schutzrechtsverletzung begründeten, und die Person des Verantwortlichen zuverlässig bekannt seien.[2451] Vom Zeitpunkt der Kenntniserlangung an habe sich der Antragsteller unverzüglich darüber klar zu werden, ob er gegen der Verletzungstatbestand klagen wolle, und im Anschluss daran ohne zeitliche Verzögerung alles Notwendige zu tun, um den Sacherhalt in einer solchen Weise aufzuklären und aufzubereiten, dass er mit Aussicht auf Erfolg ein gerichtliches Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz anstrengen könne.[2452] Dabei stehe der Zeitraum, den der Antragsteller zur Vorbereitung eines erfolgversprechenden Verfügungsantrags für die sorgfältige Ermittlung des Sachverhalts und die Beschaffung geeigneter Glaubhaftmachungsmittel benötige, der

[2442] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 14.

[2443] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 15.

[2444] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 15, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 29.5.2008 – I-2 W 47/07 und OLG Karlsruhe, 8.7.2009 – 6 U 61/09.

[2445] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 15.

[2446] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 16.

[2447] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 16, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 13.11.2008 – I-2 U 35/08, OLG Karlsruhe, 8.7.2009 – 6 U 61/09 und 23.9.2015 – 6 U 52/15 – *Ausrüstungssatz* und OLG Düsseldorf, 21.1.2016 – I-2 U 48/15.

[2448] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 17, mit Verweis auf BGH, 1.7.1999 – I ZB 7/99, OLG München, 22.4.2008 – 29 W 1211/08 – *Jackpot-Werbung*, OLG Düsseldorf, 29.5.2008 – 2 W 47/07, OLG Hamburg, 29.1.2009 – 3 U 107/08, OLG Düsseldorf, 17.1.2013 – I-2 U 87/12 – *Flupirtin-Maleat*, OLG Köln, 13.12.2013 – I-6 U 100/13 – *Haarverstärker* und 10.7.2015 – 6 U 195/14.

[2449] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 17, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 5.7.2012 – I-2 U 12/12.

[2450] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 17.

[2451] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 17, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 5.7.2012 – I-2 U 12/12 und OLG Karlsruhe, 23.9.2015 – 6 U 52/15 – *Ausrüstungssatz*.

[2452] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 18, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 5.7.2012 – I-2 U 12/12 und OLG Karlsruhe, 23.9.2015 – 6 U 52/15 – *Ausrüstungssatz*.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Dringlichkeit nicht entgegen, solange er die erforderlichen Schritte jeweils zielstrebig in die Wege leite und zu Ende führe.[2453]

Gehe es – wie vorliegend – um die Durchsetzung eines Verfügungspatents, in Bezug auf welches der Antragsteller gegenüber einer Standardisierungsorganisation eine sogenannte FRAND-Erklärung abgegeben und sich folglich mit selbiger verpflichtet habe, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, sie die Erfüllung des Dringlichkeitserfordernisses im Vergleich zur oben geschilderten allgemeinen Rechtslage noch an zusätzliche Bedingungen geknüpft:[2454]

Wie der Senat bereits im Berufungsurteil vom 30.3.2017 (I-15 U 65/15) entschieden und im Einzelnen ausgeführt habe, habe der Patentinhaber aufgrund seiner FRAND-Zusage nämlich voranzugehen, d.h. insbesondere einem hinreichend lizenzwilligen Benutzer ein FRAND-Angebot zu unterbreiten, während der Benutzer erst im Anschluss gehalten sei, seinerseits mit einem FRAND-Gegenangebot zu reagieren und Sicherheit zu leisten.[2455] Wegen der betreffenden Details werde auf die entsprechenden Ausführungen im Berufungsurteil vom 30.3.2017 zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen Bezug genommen.[2456] Im vorliegend interessierenden Zusammenhang sei lediglich zu betonen: Der vom Senat im Berufungsverfahren als durchgreifend bewertete FRAND-Einwand führe nicht zu einem dauerhaften Rechtsverlust, weshalb der Senat (unter entsprechender teilweiser Abänderung des erstinstanzlichen Urteils) die auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen gerichtete Klage auch explizit (lediglich) als „derzeit unbegründet“ abgewiesen habe.[2457] Denn der erfolgreiche FRAND-Einwand begründe ein bloß dilatorisches Durchsetzungshindernis (vergleichbar mit einer fehlenden Fälligkeit) und keinen rechtshindernden oder rechtsaufhebenden Umstand.[2458]

Demnach sei es dem Patentinhaber nicht verwehrt (im Gegenteil: dies bleibe sogar Gegenstand seiner fortbestehenden kartellrechtlichen Verpflichtungen), noch nach einem den Unterlassungsanspruch als derzeit unbegründet abweisenden Urteil die maßgeblichen Anforderungen zu erfüllen und so die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs zu schaffen.[2459] Dies gelte erst recht, wenn das betreffende Urteil noch nicht rechtskräftig sei.[2460]

Ein ganz anderes Thema sei es allerdings, ob es ihm dann (noch) möglich sei, diesen Anspruch im Wege des Eilrechtsschutzes durchzusetzen.[2461] Insoweit gebe der vorliegende Fall keinen Anlass zur grundlegenden Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen in einer FRAND-Konstellation überhaupt Raum für eine Klärung derartiger Streitigkeiten in einem einstweiligen Verfügungsverfahren sei.[2462] In der vorliegend gegebenen Situation, die dadurch gekennzeichnet sei, dass der Unterlassungsanspruch zuvor im Hauptsacheverfahren mangels aktueller Durchsetzbarkeit abgewiesen wurde, scheitere ein entsprechendes Begehren regelmäßig am Dringlichkeitserfordernis.[2463] Dieses sei hier nämlich gegenüber „üblichen“ Fällen (d.h. solchen, die keine FRAND-Konstellation beträfen) dahingehend modifiziert, dass der Patentinhaber auch die spezifischen materiell-rechtlichen Verpflichtungen so zu erfüllen habe, dass sich der Schluss verbiete,

[2453] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 18, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.1.2013 – I-2 U 87/12 – *Flupirtin-Maleat*, OLG Karlsruhe, 23.9.2015 – 6 U 52/15 – *Ausrüstungssatz* und OLG Düsseldorf, 21.1.2016 – I-2 U 48/15.

[2454] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 19.

[2455] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 20.

[2456] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 20.

[2457] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 20.

[2458] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 20.

[2459] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 21.

[2460] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 21.

[2461] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 22.

[2462] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 22.

[2463] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 22.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

ihm sei die Durchsetzung seines Anspruchs nicht dringlich gewesen: Das Erfordernis der Dringlichkeit schließe es hier (kumulativ zu den jenseits der FRAND-Konstellation ohnehin stets einzuhaltenden Kriterien) also ein, dass der Patentinhaber im Anschluss an die Kenntnisnahme von Verletzungshandlungen regelmäßig das Lizenzierungsprocedere soweit vorantreiben müsse, wie ihm das aus eigener Macht möglich sei.[2464] Der Patentinhaber müsse daher nicht nur zeitnah nach Entdecken einer Verletzungshandlung dem anderen Teil den vom EuGH etablierten Verletzungshinweis erteilen, sondern alsdann ebenso zügig auf eine daraufhin (fristgerechte) Lizenzbereitschaftserklärung des Benutzers hin mit der Abgabe eines in jeder Hinsicht ordnungsgemäßen FRAND-Angebots reagieren.[2465] Ein in dilatorischer Art und Weise unterbreitetes FRAND-Lizenzangebot stehe der erforderlichen Dringlichkeit ebenso entgegen wie das Unterlassen eines (ordnungsgemäßen) Angebots überhaupt.[2466]

Nach Maßgabe dieser Grundsätze verbiete es sich, dem Begehren der Antragstellerin die notwenige zeitliche Dringlichkeit zu attestieren.[2467] Unstreitig seien der Antragstellerin im Hauptsacheverfahren wie auch im einstweiligen Verfügungsverfahren Verletzungshandlungen der Antragsgegnerin bereits seit Jahren bekannt.[2468] Die Antragstellerin wisse unstreitig spätestens seit dem Jahre 2014 von den auch vorliegend verfahrensgegenständlichen Handlungen: Seinerzeit habe die Antragstellerin unstreitig zunächst den Erlass einer einstweiligen Verfügung des Landgerichts Berlin – die indes später zu Recht vom Kammergericht unter Zurückweisung des betreffenden Antrags wieder aufgehoben worden sei.[2469]

Sämtliche Gründe, die die Antragstellerin zwecks Untermauerung ihrer Rechtsauffassung, wonach trotz des soeben geschilderten Zeitablaufs seit der erstmaligen Kenntnis von Verletzungshandlungen die erforderliche Dringlichkeit bejaht werden müsse, vorbringe, verfingen nicht.[2470] Kern der Argumentation der Antragstellerin sei ihr unstreitig unter dem Datum des 14.4.2017 (also nach Verkündung des Senaturteils vom 30.3.2017 in der Hauptsache) der Antragsgegnerin unterbreitetes neues Lizenzangebot nebst Begleitschreiben, von dem sie – im Gegensatz zur Antragsgegnerin – annehme, jedenfalls dieses sei nunmehr in jeder Hinsicht FRAND.[2471] Ob die betreffende materiell-rechtliche Bewertung ihres neuen Lizenzangebots Gefolgschaft verdiene, bedürfe (vorliegend) keiner Beurteilung durch den Senat.[2472] Denn die Antragstellerin gehe zumindest in der rechtlichen Einschätzung der Auswirkungen dieses neuen Angebots auf die Bewertung der Dringlichkeit fehl:

Selbst wenn das neue Angebot nämlich tatsächlich FRAND sein sollen würde, wäre die zeitliche Dringlichkeit keineswegs aufgrund einer (wie die Antragstellerin meine) nicht „EuGH-konformen“ Reaktion des Beklagten-Konzerns „neu entstanden“ bzw. „wieder aufgelebt“.[2473] Insbesondere führe die Antragstellerin vergeblich an, das betreffende Senatsurteil – als erstes obergerichtliches Urteil zum betreffenden Komplex – sei angesichts der rechtlich hoch umstrittenen und weitgehend ungeklärten Fragen zum „Thema FRAND“ entscheidend für die Abgabe ihres neuen Angebots im Anschluss an die Verkündung des Berufungsurteils gewesen.[2474]

[2464] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 22.
[2465] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 22.
[2466] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 22.
[2467] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 23.
[2468] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 24.
[2469] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 24.
[2470] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 25.
[2471] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 26.
[2472] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 26.
[2473] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 27.
[2474] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 27.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Soweit die Antragstellerin geltend mache, die Dringlichkeit könne trotz seit vielen Jahren bestehender Kenntnis vom Verletzungstatbestand nicht zweifelhaft sein, weil ein Anspruch aus Gründen des materiellen Rechts (unter Zugrundelegung der Auffassung des Senats im Hauptsacheverfahren) bislang gar nicht bestanden habe, unterliege sie einem grundlegenden Missverständnis: Zwar könnten materiell-rechtliche Gründe, die der Entstehung des Verfügungsanspruchs entgegen ständen, grundsätzlich dazu führen, dass solange auch noch keine Dringlichkeitsfrist in Lauf gesetzt sei.[2475] Dabei müsse es sich aber um solche Hindernisse (z.B. bisherige Benutzungshandlungen hätten nur im Ausland stattgefunden oder eine bislang fehlende Schutzrechtseintragung) handeln, die ihre (zurechenbare) Ursache nicht in der Sphäre des Antragstellers selbst hätten.[2476] Gehe es aber – wie vorliegend – darum, dass der (vermeintliche) Verfügungsanspruch nur deshalb nicht durchsetzbar sei, weil der Antragsteller selbst gegen ihn treffende materiell-rechtliche Pflichten verstoßen habe, sei der Zeitpunkt des Beginns der Dringlichkeitsfrist grundsätzlich entsprechend früher anzusetzen, nämlich auf denjenigen Zeitpunkt, zu dem es ihm bei in jeder Hinsicht pflichtgemäßem Handeln möglich gewesen sei, die Durchsetzbarkeit herbeizuführen.[2477] Wer sich aber entsprechend pflichtwidrig verhalte (insbesondere entgegen seiner FRAND-Zusage potentielle Lizenznehmer diskriminiere), dürfe nicht auch noch eine „Belohnung“ in dem Sinne erwarten, dass sein nachträglich nunmehr (vermeintlich) pflichtgemäßes Handeln zu einer „Renaissance“ der Dringlichkeit führe.[2478]

Der Antragstellerin möge durchaus darin beizupflichten sein, dass sie in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht zögerlich gehandelt habe, sondern stets darauf bedacht gewesen sei, zur Verfügung stehende Rechtsbehelfe auszuschöpfen (beginnend mit dem einstweiligen Verfügungsverfahren vor den Berliner Gerichten, gefolgt vom Hauptsacheverfahren vor den Düsseldorfer Gerichten bis hin zur nunmehr anhängigen Revision vor dem Bundesgerichtshof).[2479] Bei der Beurteilung der zeitlichen Dringlichkeit dürfe indes bei einer derartigen rein verfahrensrechtlichen Bewertung in Anbetracht der oben geschilderten Besonderheiten der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs aus einem mit einer FRAND-Zusage verknüpften Patent nicht halt gemacht werden, sondern es müsse zwingend auch die materiell-rechtliche Ebene in den Blick genommen und folglich berücksichtigt werden, ob der jeweilige SEP-Inhaber auch seinen entsprechenden kartellrechtlichen Pflichten unter Berücksichtigung der von ihm abgegebenen FRAND-Zusage rechtzeitig genügt habe.[2480]

In diesem Kontext sei mit Nachdruck der Darstellung der Antragstellerin zu widersprechen, dass sie berechtigterweise, insbesondere mangels etablierter oder gar höchstrichterlicher Rechtsprechung davon ausgegangen sei, „ihre akzeptierten Standardbedingungen“ würden auch vom Senat als FRAND-konform eingestuft werden.[2481] Zwar trete eine Zäsur, die zu einem entsprechenden Umdenken der Antragstellerin hätte führen müssen, nicht bereits Anfang des Jahres 2016 aufgrund der (teilweisen) Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem erstinstanzlichen Urteil in der Hauptsache ein.[2482] Denn entscheidender Gesichtspunkt für diese – einschneidende – Maßnahme sei für den Senat der Umstand gewesen, dass das Landgericht den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand der Beklagten mit der Begründung zurückgewiesen gehabt habe, dass sich jedenfalls die Beklagten ihrerseits nicht FRAND verhalten hätten und es deshalb das seinerseits in Rede stehende Lizenzangebot der Klägerin (=hiesige Antragstellerin) a priori keiner Überprüfung auf dessen FRAND-Qualität hin unterzogen habe.[2483] Dass unter anderem der Unterlassungsanspruch konkret gefährdet gewesen sei, unter Abänderung des

[2475] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 28.
[2476] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 28.
[2477] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 28.
[2478] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 28.
[2479] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 29.
[2480] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 29.
[2481] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 30.
[2482] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 30.
[2483] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 30.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

erstinstanzlichen Urteils vom Senat (als derzeit unbegründet) abgewiesen zu werden, habe der Antragstellerin allerdings mit Zugang des umfänglichen Hinweisbeschlusses des Senats vom 17.11.2016 klar werden müssen, da die bis dahin der Gegenseite unterbreiteten Angebote allesamt vom Senat als nicht FRAND eingestuft worden seien.[2484]

Soweit die Antragstellerin scheinbar argumentieren möge, erstmals durch das Senatsurteil vom 30.3.2017 die „Mitteilung" erhalten zu haben, dass ihr in Reaktion auf den besagten Hinweisbeschluss der Gegenseite unterbreitetes Lizenzangebot vom 20.12.2016 vom Senat ebenfalls als nicht FRAND angesehen worden sei, verwahre sich der Senat gegen den damit – zumindest implizit – verbundenen Vorwurf einer „Überraschungsentscheidung".[2485] Der Senat habe das Hauptsacheverfahren vielmehr gerade vor dem Hintergrund, dass er sich als erstes (deutsches) Obergericht vor die Aufgabe gestellt sah, in einem Hauptsacheverfahren die „ZTE/Huawei Technologies"-Grundsätze des EuGH in nationales Recht zu implementieren, zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht transparent geführt.[2486] Verfahrensleitend seien zu allen (insbesondere zu den letztlich entscheidungserheblichen Aspekten) Hinweis- und Auflagenbeschlüsse ergangen.[2487]

Im Rahmen ihrer den tatsächlichen Prozessverlauf verzerrt widergebenden Ausführungen in der Antragsschrift mache die Antragstellerin unter anderem geltend, der Senat habe mit seinem Berufungsurteil „eine völlig neue Sach- bzw. Rechtslage geschaffen", indem er nämlich angeblich entgegen der Rechtsprechung des Landgerichts Köln und des Landgerichts Mannheim angenommen habe, „einzelne Ausreißer seien stets [bei der Prüfung der Diskriminierung] zu berücksichtigen".[2488] Diese Ausführungen gäben dem Senat in Anknüpfung an seine im Hauptsacheverfahren bereits getroffenen Erläuterungen Anlass, in Bezug auf das von der Antragstellerin erneut bemühte „Ausreißer-Argument" nochmals Folgendes klarzustellen: Was die inhaltlichen Anforderungen des in Art. 102 AEUV verankerten Diskriminierungsverbots, die sich mit dem „AND"-Bestandteil einer FRAND-Zusage inhaltlich deckten, anbelange hätten weder das EuGH-Urteil noch das Berufungsurteil des Senats irgendwelche Erkenntnisse zutage gefördert, die zu einer „völlig neuen Sach- oder Rechtslage" geführt hätten.[2489] Soweit die Antragstellerin scheinbar davon ausgehe, als marktbeherrschendes Unternehmen sei sie trotz Art. 102 AEUV und trotz ihrer FRAND-Zusage gegenüber der Standardisierungsorganisation nicht gehindert, einem oder gar einigen wenigen ihrer Lizenznehmer im Vergleich zu allen anderen Vorzugskonditionen in exorbitantem Ausmaß zu gewähren, ohne dass ihr dafür (in einem hinreichendem Ausmaß) entsprechende sachliche Rechtfertigungsgründe zur Seite stehen müssen würden, könne dies nur erstaunen.[2490] Für die Annahme eines derartigen eine Diskriminierung gestattenden „Freischusses" fänden sich (was nicht überraschen könne) in der gesamten Rechtsprechung und Literatur zu Art. 102 AEUV keinerlei Anhaltspunkte.[2491] Dies gelte namentlich für die von der Antragstellerin angeführte Rechtsprechung der Landgerichte Köln und Mannheim, in deren Entscheidungen die Antragstellerin einen derartigen allgemeinen Rechtsgrundsatz hineinzulesen versuche.[2492] Wie der Senat im Berufungsurteil vom 30.3.2017 im Einzelnen ausgeführt habe, enthalte das Diskriminierungsverbot zwar keine Meistbegünstigungsklausel, die den Marktbeherrscher verpflichte, allen Abnehmern die gleichen – günstigen – Preise/Bedingungen einzuräumen.[2493] Jedoch seien willkürliche Ungleichbehandlungen,

[2484] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 30.
[2485] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 31.
[2486] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 31.
[2487] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 31.
[2488] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2489] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2490] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2491] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2492] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2493] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

die das Marktgeschehen wettbewerbsverzerrend störten, untersagt.[2494] Die Interpretation der von der Antragstellerin angeführten Rechtsprechung leide darunter, dass sie die gebotene sorgsame Differenzierung zwischen einer Ungleichbehandlung einerseits und deren Rechtfertigung andererseits ausblende.[2495] Zwar könne ein „Ausreißer" mit Blick auf die reine Ungleichbehandlung als solche durchaus unbedenklich sein, jedoch nur dann, wenn selbige (im Wesentlichen) durch beachtliche Rechtfertigungsgründe kompensiert werde.[2496] Nichts andere besagten im Ergebnis die von der Antragstellerin zitierten Entscheidungen, die der Senat schon in seinem Berufungsurteil berücksichtigt habe und von denen er in Bezug auf die vorliegend maßgebliche Rechtsfrage mitnichten abgewichen sei.[2497] Vielmehr habe der Senat im Detail begründet, weshalb die von der Antragstellerin im Hauptsacheverfahren angeführten Rechtfertigungsgründe beileibe nicht ausreichen würden, um die exorbitante Ungleichbehandlung zu legitimieren.[2498] Soweit sich die Antragstellerin als „überrascht" geriert und geltend mache, der Hinweisbeschluss des Senats vom 17.11.2016 hätte keine (näheren) Ausführungen zum Aspekt der Diskriminierung enthalten, sie Folgendes in Erinnerung zu rufen: Die Antragstellerin habe bis zum betreffenden Hinweisbeschluss des Senats keine Obliegenheit und erst Recht keine Verpflichtung ihrerseits gesehen, der Gegenseite und dem Senat auch nur ansatzweise ein Bild von ihrer konkret gelebten Lizenzierungspraxis zu vermitteln.[2499] Sie habe in Reaktion auf besagten Hinweisbeschluss des Senats alsdann (im Rahmen einer vom Senat zumindest befürworteten sekundären Darlegungslast) einen eher kursorischen Einblick in ihre Lizenzierungspraxis gewährt.[2500] Vor allem aber – und dies habe allein die Abweisung unter anderem des Unterlassungsanspruchs getragen – habe die Antragstellerin den zur Annahme einer Diskriminierung berechtigenden Vertrag mit C erst auf eine entsprechende Auflage des Senats nach § 142 ZPO hin erstmals im Februar 2017 vorgelegt.[2501] Es würde im November 2016 mithin geradezu hellseherischer Fähigkeiten des Senats bedurft haben, wenn er die erstmals daraus resultierenden (wenn auch ex post evidenten) Bedenken bereits zum Gegenstand des besagten Hinweisbeschlusses hätte machen wollen.[2502] Der Vorwurf eines überraschenden und intransparenten Vorgehens falle daher letztlich auf die Antragstellerin selbst zurück, da sie das Gericht und die Gegenseite über diesen wesentlichen Bestandteil ihrer Lizenzierungspraxis im Unklaren gelassen habe und diesen entscheidungsrelevanten Vertrag erst unter entsprechender Anordnung zur Akte gereicht habe.[2503] Der Senat habe die Vorlageanordnung unverzüglich getroffen, nachdem die Beklagten entsprechende Anknüpfungspunkte aufgezeigt hätten, die eine Diskriminierung als hinreichend wahrscheinlich erscheinen lassen hätten.[2504] Jedenfalls mit der Vorlageanordnung sei die Antragstellerin also hinreichend gewarnt gewesen und habe sie objektiv damit rechnen müssen, dass der FRAND-Einwand jedenfalls unter dem Aspekt der Diskriminierung Erfolg haben können würde.[2505] Die Antragstellerin habe es allerdings in der (durch den Hinweisbeschluss vom 17.11.2016 vermittelten) Kenntnis, dass sie jedenfalls nach der Rechtsauffassung des Senats gehalten gewesen sei, der (nach der ihr ebenso bekannten Auffassung des Senats) lizenzbereiten Gegenseite ein FRAND-Angebot unter Berücksichtigung ihrer Lizenzvereinbarung mit C zu machen, vorgezogen, von einem neuen, konkreten schriftlichen (Pauschallizenz-)Angebot an die Beklagten abzusehen – trotz der ihr ebenfalls bekannten Neigung des

[2494] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2495] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2496] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2497] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2498] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2499] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2500] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2501] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2502] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2503] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2504] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2505] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Senat, neue Lizenzangebot grundsätzlich noch bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung zu berücksichtigen.[2506]

Wie unhaltbar die (implizite) Rüge einer „Überraschungsentscheidung" durch den Senat sei, erschließe sich einem unbefangenen „Prozessbeobachter" nicht zuletzt anhand eines Blicks in das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 16.2.2017, in deren Rahmen die Öffentlichkeit auf Antrag der Klägerin/Antragstellerin mehrfach ausgeschlossen gewesen sei.[2507] Es heiße dort nämlich unter anderem, die Klägervertreter würden insbesondere anhand der in der an diesem Tag überreichten Anlage rot markierten Passagen im Einzelnen darlegen, weshalb ihrer Ansicht nach aufgrund besonderer Umstände die den Beklagten unterbreiteten Lizenzangebote keine Diskriminierung im Vergleich zu den C gewährten Vertragskonditionen beinhalteten.[2508] Weshalb die Antragstellerin gleichwohl einen Anlass für ihre „gesicherte Auffassung" gesehen habe, in jedem Falle zu obsiegen und deshalb die Abgabe eines erneut verbesserten Lizenzangebotes bis zum Abschluss der Berufungsinstanz in der Hauptsache nicht in Erwägung ziehen zu müssen, sei nicht nachvollziehbar.[2509]

Es verhelfe der Antragstellerin nach alledem nicht zur Begründung der Dringlichkeit, dass sie „schon" knapp zwei Wochen nach Zustellung des Senatsurteils das neue Angebot vom 14.4.2017 (fruchtlos) unterbreitet habe.[2510] Dass man als Marktbeherrscher nicht ohne Rechtfertigungsgründe (exorbitant) ungleich behandeln, d.h. diskriminieren dürfe, gelte ganz unabhängig von der Entscheidung des EuGH als auch des Senatsurteils.[2511] Der Senat habe in diesem im Berufungsverfahren entscheidungserheblichen Gesichtspunkt unter keinem (kartell-)rechtlichen Aspekt „Neuland" betreten, erst recht nicht in einem Ausmaß, das Veranlassung geben könne, hier einen Neubeginn der Dringlichkeitsfrist mit Verkündung/Zustellung des Senatsurteils anzunehmen.[2512]

Die Antragstellerin konzediere – immerhin – zu Recht, dass die Bejahung einer zeitlichen Dringlichkeit bloß aufgrund einer „erstmaligen Entscheidung zur FRAND-Konformität eines Angebots im Hauptsacheverfahren" eine durch die Verletzungsgerichte kaum zu bewältigende Flut von Verfügungsverfahren in „FRAND-Fällen" nach sich ziehen können würde.[2513] Ohne Erfolg versuche sie sich von diesem Szenario dadurch abzugrenzen, dass sie einen vorliegend zur Entscheidung stehenden „seltenen Sonderfall" reklamiere: Sie mache geltend, schon eine Reihe von Gerichten würden über den Sachverhalten entscheiden haben, ohne sich zur FRAND-Qualität ihrer Lizenzpolitik zu äußern.[2514] Dies treffe schon deshalb nicht zu, weil der Senat ihrem Angebot vom 20.12.2016 zweifelsohne die „AND"-Qualität abgesprochen habe.[2515] Es sei in dieser Konstellation nicht Aufgabe eines Verletzungsgerichts, einem Marktbeherrscher, der jedenfalls den jeweiligen Beklagten evident diskriminiere und eine Behebung dieses Mangels (hier: in Form einer im Wesentlichen Gleichbehandlung mit C) im Hauptsacheverfahren schlicht verweigere, in einem die konkrete Gerichtsentscheidung überhaupt nicht tragenden Rechtsgutachten minutiös zu erläutern, was im konkreten Fall „FR" („fair and reasonable") sei.[2516]

Entgegen der Annahme der Antragstellerin sei es ihr (auch unter Zugrundelegung der von ihr angeführten üblichen Dauer von Revisionsverfahren) deshalb in jeder Hinsicht zumutbar, das Ergebnis

[2506] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 32.
[2507] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 33.
[2508] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 33–34.
[2509] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 35.
[2510] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 36.
[2511] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 37.
[2512] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 37.
[2513] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 38.
[2514] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 38.
[2515] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 38.
[2516] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 38.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

ihres gegen das Berufungsgericht eingelegten Rechtsmittels abzuwarten – und zwar unabhängig davon, ob der Kartellsenat des Bundesgerichtshof ihren neuen Vortrag (insbesondere ihr neues Lizenzangebot) im Revisionsverfahren überhaupt berücksichtigen könne und werde.[2517] Dass der Antragstellerin – wie sie anführe – im Falle eines entsprechenden Zuwartens ein erheblicher Schaden entstehen werden würde, der im Wesentlichen darauf beruhe, dass sie in der Zwischenzeit keine Lizenzverträge mehr werde abschließen können, wenn die Unsicherheit bei potentiellen Lizenznehmern zur FRAND-Konformität der Lizenzbedingungen bestehen bleiben würde, habe sie sich aus oben genannten Gründen selbst zuzuschreiben.[2518] Auch der Hinweis, dass die Laufzeit ihres Lizenzportfolios zeitlich begrenzt sei und Schadenersatzansprüche rückwirkend schwer bis gar nicht durchsetzbar sein würden, verfange nicht: Es sie die Antragstellerin, die für sich die grundlegende Entscheidung getroffen gehabt habe, jedenfalls bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens der Rechtsauffassung des Senats zu entscheidungserheblichen Rechtsfragen nicht durch Abgabe eines erneut angepassten Angebots Rechnung tragen zu wollen.[2519] Sie möge daher (was ihr gutes Recht sei) den Versuch unternehmen, den Bundesgerichtshof von ihrer Rechtsauffassung unter anderem zur Einordnung/Bedeutung des Lizenzvertrages mit C zu überzeugen.[2520] Kehrseite des Ganzen sei allerdings (zumindest) eine entsprechende zeitliche Verzögerung.[2521]

Abschließend weise der Senat vorsorglich darauf hin, dass die Antragstellerin auch in der Annahme irre, mit einer etwaigen positiven Entscheidung des Bundespatentgerichts Anfang September 2017 über den Rechtsbestand des Verfügungspatents (was in Anbetracht des Hinweisbeschlusses des Bundespatentgerichts nach § 83 PatG indes äußerst fernliege) entstehe „ohnehin eine neue zeitliche Dringlichkeit".[2522] Dem sei keineswegs so, weil die Bejahung einer Dringlichkeit vorliegend – ganz unabhängig von der Frage des gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatents – ein- und für allemal aus den oben genannten Gründen ausscheide.[2523] Die Antragstellerin habe nämlich in vorwerfbarer Weise davon abgesehen, beizeiten für die materiell-rechtliche Durchsetzbarkeit ihres Unterlassungsanspruchs zu sorgen.[2524] Es bestehe zwar eine (materiell-rechtliche) Nachholbarkeit; jedoch könne dies nicht mehr dazu führen, dass die Durchsetzbarkeit auch in zeitlicher Hinsicht so geschaffen werde, dass deren Funktion als einer der kumulativen Voraussetzungen für die Dringlichkeit noch gewahrt werden können würde.[2525]

Mit Beschluss vom 18.7.2017 hielt das OLG Düsseldorf fest, Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes aus SEP, für die eine FRAND-Erklärung abgegeben sei, kämen keinesfalls unter leichteren Voraussetzungen in Betracht als sonstige Unterlassungsanordnungen in Patentsachen.[2526] Wie sonst auch müsse sich deshalb der Benutzungstatbestand mit den beschränkten Mitteln des vorläufigen Rechtsschutzes (§ 294 ZPO) hinreichend eindeutig feststellen lassen; darüber hinaus habe der Rechtsbestand des SEP ausreichend gesichert zu sein und müsse die Dringlichkeit des Rechtsschutzbegehrens in zeitlicher Hinsicht gegeben sein.[2527] Mit letzterem sei gemeint, dass sich der Antragsteller selbst in einer solchen Weise zügig um seine Angelegenheiten bemüht habe, dass er mit

[2517] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 39, mit Verweis allgemein zur Frage der möglichen Berücksichtigung neuer unstreitiger Tatsachen in der Revisionsinstanz auf BGH, 2.3.2017 – I ZR 273/14 – *Videospiel-Konsolen III.*

[2518] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 39.

[2519] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 39.

[2520] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 39.

[2521] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 39.

[2522] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 40.

[2523] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 40.

[2524] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 40.

[2525] OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 41/17, Rn. 40.

[2526] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 3.

[2527] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 3.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

gutem Recht für sich reklamieren könne. Sein Anliegen in einem gerichtlichen Eilverfahren behandelt zu wissen.[2528]

SEP mit FRAND-Erklärung wiesen hierbei die rechtliche Besonderheit auf, dass der Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung nicht durchsetzbar sei, wenn der Patentinhaber die ihm nach der EuGH-Entscheidung *Huawei/ZTE* obliegende Vorarbeit für das Zustandekommen eines FRAND-Lizenzvertrages über das Verfügungsschutzrecht geleistet habe.[2529] Sobald der Verletzte um die widerrechtliche Benutzung seines SEP wisse, gehöre es deshalb nicht nur zu den Obliegenheiten einer zügigen Rechtsverfolgung, dass er den anspruchsbegründenden Sachverhalt im Tatsächlichen aufkläre und mit geeigneten Glaubhaftmachungsmitteln beweismäßig sichere, um alsdann zeitnah gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen; mit derselben Zielstrebigkeit seien darüber hinaus auch diejenigen Anstrengungen zu unternehmen, die mit Rücksicht auf die für das SEP abgegebene FRAND-Zusage erforderlich seien, um den aus der Rechtsverletzung folgenden Unterlassungsanspruch klagbar zu machen.[2530]

Konkret bedeute dies, dass im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der festgestellten Patentbenutzung eine Verletzungsanzeige zu erfolgen habe und dem Verletzer bei dessen erklärter Lizenzbereitschaft ein ausformuliertes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten sei.[2531] Verspätete Aktivitäten blieben allenfalls für denjenigen Zeitraum unschädlich, für den (z.B. wegen eines zunächst noch unzureichend gesicherten Rechtsbestandes) ohnehin kein Verfügungsverfahren mit Aussicht auf Erfolg betrieben werden könne.[2532] Letzteres heiße freilich nicht, dass bis zu einer streitigen Rechtsbestandentscheidung die Bemühungen um einen FRAND-Lizenzvertrag zurückgestellt werden dürften; vielmehr seien sie – gegebenenfalls auch im Vorfeld der noch ausstehenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung – so zeitig in Angriff zu nehmen, dass die kartellrechtliche Sachlage in dem Moment, zu dem die dem Verletzer günstige Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung vorliege, im Seine einer Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs zum Abschluss gebracht und geklärt sei.[2533] Anderweitige Verzögerungen, die darüber hinausgingen, wirkten dringlichkeitsschädlich, und zwar nicht nur, wenn ein Lizenzangebot gänzlich fehle, sondern in gleicher Weise, wenn das vorhandene Angebot rechtlich deshalb unbeachtlich sei, weil es – entgegen den FRNAD-Anforderungen – sachlich unangemessen und/oder diskriminierend sei.[2534] In einem solchen Fall entlaste den Verletzten eine subjektive Fehleinschätzung in Bezug auf die (äußere und/oder inhaltliche) Zulänglichkeit seiner Offerte grundsätzlich nicht.[2535]

Typischerweise greife ein Unterlassungsgebot wegen Patentverletzung – auch und gerade ein solches, das auf ein SEP gestützt sei – massiv in den Geschäftsbetrieb des Antragsgegners ein.[2536] Im Streitfall gelte das in besonderem Maße, weil von der angestrebten Unterlassungsanordnung ein wesentlicher Teil der von der Beklagten angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich des Vertriebs geeigneter Hardwarekomponenten betroffen sei.[2537] Das relevante Schadenspotential finde seinen sichtbaren Ausdruck nicht zuletzt in der unangefochtenen Streitwertfestsetzung des Landgerichts auf 10000000 EUR.[2538] Um das Risiko einer – wie angezeigt – folgenschweren

[2528] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 3.
[2529] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 4.
[2530] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 4.
[2531] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 5.
[2532] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 5.
[2533] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 5.
[2534] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 5.
[2535] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 5.
[2536] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6.
[2537] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6.
[2538] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Fehlentscheidung zu vermindern, komme der Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung nach der Rechtsprechung grundsätzlich nur in Betracht, wenn sowohl der Bestand des Verfügungspatents als auch die Frage der Patentverletzung im Ergebnis so eindeutig zugunsten des Antragstellers zu beantworten sei, dass eine fehlerhafte, in einem etwaigen nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten sei.[2539] Je klarer beides zugunsten des Patentinhabers zu beurteilen sei, umso weniger sei es gerechtfertigt, mit Rücksicht auf irgendwelche Wettbewerbsinteressen des Antragsgegners gleichwohl von einem einstweiligen Rechtsschutz abzusehen.[2540] Bei eindeutiger Rechtsbestands- und Verletzungslage erübrigten sich deswegen in aller Regel weitere Erwägungen zur Interessenabwägung.[2541] Die Notwendigkeit einstweiligen Rechtsschutzes könne sich deshalb im Einzelfall auch aus der eindeutigen Rechtslage als solcher ergeben.[2542] Je weniger eindeutig die Sach- und Rechtslage sei, umso weniger angebracht sei es – umgekehrt –, im einstweiligen Rechtsschutz Maßnahmen anzuordnen, die den Antragsgegner in seiner geschäftlichen Tätigkeit schwerwiegend oder gar existenziell träfen, und umso mehr komme derartiges nur dann in Betracht, wenn ganz besondere Interessen die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes ausnahmsweise gebieten würden.[2543]

Sobald das Verfügungspatent in seinem Rechtsbestand angegriffen sei, stehe es dabei zur Darlegungslast des Antragstellers, der für sich den vorläufigen Rechtsschutz in Anspruch nehme, das Verletzungsgericht davon zu überzeugen, dass die vorgebrachten Einwendungen unberechtigt seien und das Verfügungspatent mit Sicherheit das laufende Rechtsbestandsverfahren überstehen werde.[2544] Anders als im regulären Hauptsacheverfahren unter Geltung von § 148 ZPO gehe es deswegen zu Lasten des Antragstellers, wenn sich die Erfolgsaussichten deshalb nicht abschließend klären ließen, weil die Technik der Verfügungspatents komplex und einer verlässlichen Beurteilung durch das Verletzungsgericht nicht zugänglich seien.[2545] Grundsätzlich könne nur dann von einem hinreichenden Rechtsbestand ausgegangen werden, wenn das Verfügungspatent bereits in kontradiktorisches erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden habe.[2546] Das Erfordernis eines streitig durchgeführten Verfahrens sei kein Selbstzweck.[2547] Mit Rücksicht darauf, dass Rechtsbestandsangriffe typischerweise von Wettbewerbern des Schutzrechtsinhabers auf dem betreffenden Markt unternommen würden, die den einschlägigen Stand der Technik aufgrund ihrer eigenen Geschäfts- und Anmeldetätigkeit überblickten und darüber hinaus hinreichende Recherchemöglichkeiten besitzen und nutzen würden, stelle das Erfordernis einer kontradiktorischen Entscheidung sicher, dass das dem Patentinhaber günstige Einspruchs- oder Nichtigkeitserkenntnis allen in Betracht kommenden Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgründen Rechnung trage und vor dem Hintergrund des gesamten einschlägigen Standes der Technik (einschließlich für das Patentamt nicht ohne weiteres auffindbarer Firmenschriften und Fachveröffentlichungen) ergangen sei.[2548] Es solle also das bei einem bloß einseitigen (z.B. Prüfungs-)Verfahren bestehende Recherchedefizit ausgeglichen werden, welches sich einerseits darin äußern könne, dass bestimmte Entgegenhaltungen im Verfahren

[2539] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 29.4.2010 – I-2 U 126/09 – *Harnkatheterset* und OLG Karlsruhe, 8.7.2009 – 6 U 61/09.

[2540] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6.

[2541] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 27.10.2011 – I-2 U 3/11 und 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

[2542] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 10.11.2011 – I-2 U 41/11.

[2543] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 6.

[2544] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7.

[2545] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 29.4.2010 – I-2 U 126/09 – *Harnkatheterset*.

[2546] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 29.5.2008 – I-2 W 47/07, 29.4.2010 – I-2 U 126/09 – *Harnkatheterset* und OLG Karlsruhe, 23.9.2015 – 6 U 52/15 – *Ausrüstungssatz*.

[2547] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7.

[2548] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

versehentlich keine Berücksichtigung fänden oder bestimmte Einwendungen (z.B. mangelnde Offenbarung oder unzulässige Erweiterung) nicht unter sämtlichen in Betracht kommenden Blickwinkeln beurteilt würden.[2549] Die Beteiligung Dritter an der Aufbereitung und Würdigung des Entscheidungssachverhaltes erhöhe insofern die Verlässlichkeit der getroffenen Entscheidung.[2550] Unerheblich sei, ob der kontradiktorische Rechtsbestandsstreit zwischen den am Verfügungsverfahren beteiligten Personen geführt worden sei oder zwischen Dritten (z.B. dem vormaligen Inhaber des Verfügungspatents und/oder einem anderen Wettbewerber).[2551]

Von dem Erfordernis einer dem Antragsteller günstigen streitigen Rechtsbestandsentscheidung – nicht von der Notwendigkeit, das mit dem Verfügungsbegehren befasste Verletzungsgericht von dem Rechtsbestand des Verfügungsschutzrechts zu überzeugen[2552] – könne nur in Sonderfällen abgesehen werden, z.B. dann, wenn (i) sich der Antragsgegner oder ein sonstiger kompetenter Wettbewerber bereits mit eigenen Einwendungen am Erteilungsverfahren beteiligt habe, so dass die Patenterteilung sachlich der Entscheidung in einem zweiseitigen Einspruchsverfahren gleichstehe; (ii) ein Rechtsbestandsverfahren deshalb nicht durchgeführt worden sei, weil das Verfügungspatent allgemein als schutzfähig anerkannt werde (was sich in dem Vorhandensein namhafter Lizenznehmer oder darin ausdrücken könne, dass gegen wehrhafte Wettbewerber Verletzungsurteile erstritten worden seien, ohne dass die verurteilten Beklagten einen Rechtsbestandsangriff gegen das Verfügungspatent unternommen hätten); (iii) sich die gegen den Rechtsbestand vorgebrachten Einwendungen schon bei der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gebotenen summarischen Prüfung als haltlos erwiesen; (iv) „außergewöhnliche Umstände“ gegeben seien, die es für den Antragsteller wegen der ihm aus einer Fortsetzung der Verletzungshandlungen drohenden Nachteile unzumutbar machen würden, den Ausgang eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.[2553] Ein solcher Sachverhalt liege regelmäßig bei Verletzungshandlungen von Generikaunternehmen vor.[2554] Während der von ihnen angerichtete Schaden im Falle einer späteren Aufrechterhaltung des Patents vielfach enorm und (mit Rücksicht auf den durch eine entsprechende Festsetzung von Festbeträgen verursachten Preisverfall) nicht wiedergutzumachen sei, habe eine (wegen späterer Vernichtung des Patents) unberechtigte Verfügung lediglich zur Folge, dass das Generikaunternehmen vorrübergehend zu Unrecht vom Markt ferngehalten werde, was durch entsprechende Schadenersatzansprüche gegen den Patentinhaber vollständig ausgeglichen werden könne.[2555] Zu berücksichtigen sei außerdem, dass das Generikaunternehmen für seine Marktpräsenz im Allgemeinen keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingehe (weil das Präparat dank des Patentinhabers medizinisch hinreichend erprobt und am Markt etabliert sei).[2556] „Außergewöhnliche Umstände“ könnten sich weiterhin daraus ergeben, dass der Ablauf des Verfügungspatents bevorstehe, so dass eine Hauptsacheklage aus Zeitgründen nicht mehr zum Erfolg führen könne.[2557] Wenn der Verweis des Antragstellers auf eine erstinstanzliche Entscheidung im laufenden Rechtsbestandsverfahren dazu führen würde, dass vor Ende der Schutzdauer überhaupt kein Rechtsschutz gegen die behaupteten Verletzungshandlungen mehr gewährt würde, habe sich das Verletzungsgericht selbst mit dem Rechtsbestandsangriff zu befassen

[2549] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7.

[2550] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 19.2.2016 – I-2 U 54/15.

[2551] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 7.

[2552] Mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 10.12.2015 – I-2 U 35/15

[2553] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 8–12, mit Verweis zu iv auf OLG Düsseldorf, 29.4.2010 – I-2 U 126/09 – *Harnkatheterset*.

[2554] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 13, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 17.1.2013 – I-2 U 87/12 – *Flupirtin-Maletat*.

[2555] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 13.

[2556] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 13.

[2557] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 13.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

und die beantragte Verfügung zu erlassen, wenn es die Schutzfähigkeit des Patents (weil ein Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund nicht feststellbar sei) bejahe.[2558]

Bei Anwendung der vorstehend dargestellten, in der Senatsrechtsprechung gesicherten Regeln stehe der Verfügungsklägerin das Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes im Streitfall nicht zur Verfügung.[2559] Eine erstinstanzliche, das Verfügungspatent bestätigende Rechtsbestandsentscheidung liege derzeit nicht vor.[2560] Die Voraussetzungen eines Ausnahmetatbestandes, in dem das Erfordernis eines kontradiktorischen Erkenntnis entbehrlich sei, seien gleichfalls nicht gegeben.[2561] Weder stehe das Verfügungspatent kurz vor seinem Ablauf noch lasse die Tatsache zweier vereinzelter Portfoliolizenznahmen am Verfügungspatent, wie sie von der Verfügungsklägerin behauptet werde, dessen Bestand als über einen vernünftigen Zweifel erhaben erscheinen.[2562] Die Tatsache der Lizenznahme belege nur, dass die Lizenznehmer das Portfolio insgesamt als lizenzierungswürdig beurteilt hätten, aber nicht, dass für diese Einschätzung maßgeblich das Verfügungspatent verantwortlich gewesen sei.[2563] Angesichts der Komplexität der technischen Materie, die es im Nichtigkeitsverfahren zu bewältigen gelte, könne auch keine Rede davon sein, dass sich die Rechtsbestandsangriffe für das mit technischen Laien besetzte Verletzungsgericht schon bei einer bloß summarischen Prüfung als haltlos erwiesen.[2564] Der Diskussionsstand der Parteien erfordere vielmehr eine ins Einzelne gehende Aufarbeitung des technischen Umfeldes, die nicht Sache der Verletzungsgerichte in einem einstweiligen Verfügungsverfahren sei.[2565]

Erleichterungen zugunsten der Verfügungsklägerin ergäben sich – anders als die Vorinstanz meine – nicht aus der Rechtsprechung, dass dann kein Anlass für einen durch eine streitige Entscheidung besonders gesicherten Rechtsbestand des Patents bestehe, wenn das einstweilige Verfügungsverfahren vom unterlegenen Antragsgegner praktisch wie ein Hauptsacheverfahren geführt werde, indem er erst Monate nach Zustellung der vollstreckbaren Beschlussverfügung Widerspruch einlege, so dass bis zum Verhandlungstermin über den Widerspruch geraume Zeit vergangen sei, innerhalb derer ausreichend Gelegenheit für Recherchen nach Entgegenhaltungen bestanden habe.[2566] In einem solchen Fall sei die Beschlussverfügung zwar schon dann zu bestätigen, wenn der präsentierte Stand der Technik keinen Anlass zur Aussetzung eines erstinstanzlichen Hauptsacheprozesses gegeben haben würde.[2567] Der maßgebliche Grund hierfür bestehe allerdings darin, dass der von der Eilmaßnahme betroffene Antragsgegner durch sein eigenes dilatorisches Prozessverhalten zur Rechtsverteidigung unmissverständlich deutlich gemacht habe, dass er in seiner geschäftlichen Betätigung offenbar nicht sonderlich beeinträchtigt sei, weswegen sein zunächst vermutetes Schutzbedürfnis, das Anlass für die erläuterte Zurückhaltung beim Erlass vorläufiger Unterlassungsanordnungen sei, abweichend von der Regel als tatsächlich gering zu veranschlagen sei.[2568] Mit der diskutierten Konstellation eines signifikant verzögerten Widerspruchs gegen eine in Kraft befindliche Unterlassungsbeschlussverfügung sei die – im Streitfall gegebene – Situation nicht vergleichbar, dass in einem parallel geführten, ausschließlich auf Rechnungslegung und

[2558] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 13, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 7.11.2013 – I-2 U 94/12 – *Desogestrel*.

[2559] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 14.

[2560] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 15.

[2561] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 15.

[2562] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 15.

[2563] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 15.

[2564] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 15.

[2565] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 15.

[2566] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 16.

[2567] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 16, mit Verweis auf LG Düsseldorf, 19.8.2004 – 4b O 199/04, bestätigt vom OLG Düsseldorf, 23.3.2006 – 2 U 55/05 und auf LG Düsseldorf, 18.3.2008 – 4a O 4/08.

[2568] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 16.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Schadenersatzfeststellung gerichteten und seit geraumer Zeit laufenden Hauptsacheverfahren Rechtsbestandsargumente ausgetauscht würden und danach eine einstweilige Unterlassungsverfügung beantragt werde.[2569] Die Sachlage sei schon deshalb nicht ähnlich, weil der Beklagte des Hauptsacheverfahrens – anders als der Adressat einer vollstreckbaren Beschlussverfügung – gerade keinem ihn unmittelbar belastenden Unterlassungsangebot ausgesetzt sei, so dass es an jeglichem Verhalten des Antragsgegners fehle, das Rückschlüsse auf ein mangelndes Schutzbedürfnis gegenüber einer Unterlassungsanordnung zulassen können würde.[2570]

Unter den gegebenen Umständen bestehe – mangels dilatorischen Verhaltens der Verfügungsbeklagten bei ihrer Rechtsverteidigung – aber nicht nur kein Anlass, die Verfügungsklägerin von einer positiven Rechtsbestandsentscheidung zum Verfügungspatent zu entbinden, was allein schon einem Erfolg des Rechtsmittels der Verfügungsklägerin entgegenstehe.[2571] Im Gegenteil müsse sich – umgekehrt – sogar die Verfügungsklägerin eine nachlässig zögerliche Rechtsverfolgung entgegenhalten lassen, die es ebenfalls ausschließe, ihr die Vorteile eines gerichtlichen Eilverfahrens zukommen zu lassen.[2572]

Nachdem die Vorinstanz unangegriffen festgestellt habe, dass sich die Verfügungsklägerin seit November 2012 um eine Lizenznahme durch die Verfügungsbeklagte und deren Konzern bemühe, sei die Verfügungsklägerin seit vielen Jahren im Bilde über die streitgegenständlichen Verletzungshandlungen, was auch mit Rücksicht darauf plausibel sei, dass sich die Benutzung des Verfügungspatents ihrem eigenen Vorbringen zufolge aus der Einhaltung der gegenständlichen technischen Standards ergebe. Seit der EuGH-Entscheidung *Huawei/ZTE* vom 16.7.2015 bestehe in der Fachwelt und folglich auch für die Verfügungsklägerin zudem grundsätzliche Klarheit darüber, welche Vorarbeit der Inhaber eines SEP mit FRAND-Erklärung zu leisten habe, um seinen patentrechtlichen Unterlassungsanspruch gerichtlich durchsetzbar zu machen.[2573] Wenn die Benutzungshandlungen der Verfügungsbeklagten für die Verfügungsklägerin so belastend gewesen seien, dass ihr deren weitere Begehung nicht mehr zumutbar sei, wie es der jetzige auf eine kurzfristige Unterbindung der betreffenden Geschäftstätigkeit der Verfügungsbeklagten gerichtete Verfügungsantrag suggeriere, so würde es der Verfügungsklägerin oblegen haben, alsbald nach dem Bekanntwerden der EuGH-Entscheidung zügig diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die ihr eine diesbezügliche Rechtsverfolgung ermöglicht haben würden.[2574] Schon vor Erhebung der Hauptsacheklage auf Rechnungslegung und Schadenersatz am 27.1.2016, mithin vollständig im vorgerichtlichen Raum, würde ausreichend Gelegenheit bestanden habe, kurzfristig eine Verletzungszeige anzubringen (sofern dies überhaupt noch nötig gewesen sein sollen würde) und alsdann ein FRAND-Angebot auszuarbeiten und der Verfügungsbeklagten zu unterbreiten.[2575] Dass die Verfügungsbeklagte an einer Lizenzerteilung interessiert gewesen sei, habe seinerzeit nicht ernstlich zweifelhaft gewesen sein können.[2576] Abgesehen davon, dass die Verfügungsklägerin selbst seit Ende 2012 Lizenzierungsbemühungen unternommen habe, was ein prinzipielles Lizenzinteresse der Verfügungsbeklagten voraussetze, seien die in der Folgezeit von der Verfügungsklägerin initiierten Angebote vom 25.3.2016 und 13.3.2017 ganz offensichtlich vor dem Hintergrund einer auch von der Verfügungsklägerin so eingeschätzten grundsätzlichen Lizenznahmebereitschaft der Verfügungsbeklagten erfolgt.[2577] Es sei nichts dafür ersichtlich, weshalb der Verfügungsklägerin ein FRAND-Angebot, wie sie es beispielsweise im März

[2569] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 16.
[2570] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 16.
[2571] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 17.
[2572] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 17.
[2573] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2574] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2575] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2576] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2577] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

2016 offeriert habe, nicht schon nach dem 16.7.2015, jedenfalls vor Erhebung der Hauptsacheklage, möglich gewesen sein solle.[2578] Die in Bezug genommenen Vergleichs-Lizenzverträge datierten vom 3.12.2015 und 14.5.2016.[2579] Das Lizenzangebot der Verfügungsklägerin vom 25.3.2016 belege insoweit, dass ihr zur Bestimmung der FRAND-Lizenzgebühr offenbar schon der frühere der beiden Vergleichsverträge ausgereich habe.[2580] Er würde es der Verfügungsklägerin daher auch ermöglicht haben, schon vorgerichtlich entsprechend tätig zu werden.[2581] Die Erkenntnislage der Verfügungsklägerin im Hinblick auf die Ermittlung einer FRAND-Lizenzgebühr habe sich daher zwischenzeitlich nicht nennenswert verändert.[2582]

Unter der Voraussetzung, dass die angebotenen Konditionen – wie es die rechtliche Pflicht der Verfügungsklägerin gewesen sei – FRAND gewesen seien und die Verfügungsbeklagte sich auf sie zu Unrecht nicht eingelassen haben würde, wie die Verfügungsklägerin vorliegend geltend mache, hätte der Unterlassungsanspruch schon im Hauptsacheverfahren mit geltend gemacht werden können.[2583] Eine sinnvolle Beschränkung des Klagebegehrens würde es der Verfügungsklägerin hierbei erspart haben, den materiellrechtlichen Erwerb des Verfügungspatents zur Überzeugung des Gerichts im Detail nachweisen zu müssen, so dass die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nicht wegen der Geltung des Teilurteilverbots hinausgezögert worden sein würde.[2584] Dass die Verfügungsklägerin in diesem Fall Rechnungslegung und Schadenersatz gegebenenfalls nicht in vollem Umfang in dem nämlichen Klageverfahren verfolgen haben können würde, stehe der Zumutbarkeit eines limitierten Klagebegehrens nicht entgegen.[2585] Denn derjenige, der für sich eine schadensträchtige Unterlassungsverfügung im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes reklamiere, wie sie im Streitfall im Raum stehe, dem müsse auch umgekehrt abverlangt werden, bei einer möglichen Rechtsverfolgung im Hauptsacheverfahren hinnehmbare Abstriche (im Hinblick auf die Durchsetzung von Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung für bestimmte Zeiträume) zu machen, wenn dadurch eine beschleunigte Durchsetzung des vordringlichen Unterlassungsanspruchs im Prozesswege möglich werde.[2586]

Soweit sich die Verfügungsklägerin darauf berufe, die Verfügungsbeklagte verweigere unberechtigt den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung, den sie – die Verfügungsklägerin – zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse im Zusammenhang mit der Rechtfertigung ihrer Lizenzangebot verlangen können würde, folge darauf ebenso wenig eine Dringlichkeit wie aus dem Umstand, dass die Verfügungsbeklagte die ihr unterbreiteten Lizenzkonditionen zu Unrecht nicht als FRAND anzweifele und deswegen sogar ein Feststellungsverfahren in Irland eingeleitet habe.[2587] So sei es das gute Recht der Verfügungsbeklagten, Rechtsschutz für ihre Interessen in Anspruch zu nehmen, genauso wie es das – in Anspruch genommene – Recht der Verfügungsklägerin sei, derartiges zur Durchsetzung ihrer Belange zu tun.[2588]

Zugunsten der Verfügungsklägerin möge unterstellt werden, dass ihre Lizenzangebote FRAND-Kriterien genügten und dass die Verfügungsklägerin sich bei der Herleitung der in Ansatz gebrachten

[2578] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2579] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2580] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2581] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2582] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 18.
[2583] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 19.
[2584] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 19.
[2585] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 19.
[2586] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 19.
[2587] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 20.
[2588] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 21.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

Lizenzregelungen auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen berufen könne.[2589] Selbst wenn die Verfügungsbeklagte angesichts dessen unberechtigt den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung verweigert haben sollen würde, würde Folge davon keinesfalls sein, dass die Verfügungsklägerin ihrer (somit auch gerichtlich nicht weiter verifizierbaren) Pflicht enthoben sein würde, der Verfügungsbeklagten ein FRAND-Lizenzangebot zu unterbreiten und dessen sachliche Berechtigung („Art und Weise der Lizenzberechnung") zu erläutern.[2590] Eine zu Unrecht verweigerte Vertraulichkeitszusage des Lizenzsuchers würde allenfalls zur Konsequenz haben, dass der Verfügungsklägerin nähere, ihre Lizenzkonditionen rechtfertigende Erläuterungen gegenüber der Verfügungsbeklagten in dem Umfang (aber nicht darüber hinaus!) erlassen sein würden, wie dies zur Wahrung ihrer berechtigten Geheimhaltungsinteressen erforderlich sei (siehe dazu ausführlich oben XI.B.1.c)3)iv)(e)).[2591] Angenommen, die Lizenzkonditionen der Verfügungsklägerin seien inhaltlich tatsächlich FRAND, so würde deshalb die Beklagte (sofern im Übrigen von einer Patentverletzung auszugehen sein sollen würde, was genau so im Verfügungsverfahren wie in einem frühzeitig eingeleiteten Klageverfahren gerichtlich zu prüfen gewesen sein würde) zur Unterlassung zu verurteilen sein, denn sie würde weder das FRAND-Angebot der Verfügungsklägerin angenommen noch dieser unverzüglich ein FRAND-Gegenangebot unterbreitet haben.[2592] Die notwenige Prüfung auf FRAND-Gemäßheit würde in gleicher Weise, wie sie sich nunmehr im einstweiligen Verfügungsverfahren stelle, in einem von vornherein auf Unterlassung gerichteten Hauptsacheverfahren durchzuführen gewesen sein werden.[2593] Würde die Verfügungsklägerin daher im Anschluss an das EuGH-Urteil, wie es ihre zur Bejahung einer Dringlichkeit erforderlichen Obliegenheit gewesen sein würde, zügig ihre Rechte verfolgt haben, würde sie gleichermaß zu ihrem Recht gekommen sein, und zwar auf sogar noch leichtere Weise, weil sich die Frage des Rechtsbestandes lediglich im Rahmen der Aussetzungsentscheidung nach § 148 ZPO gestellt haben würde.[2594]

Angesichts dessen würde die Verfügungsklägerin nur dann zu einer Rechtsverfolgung im einstweiligen Rechtsschutz berechtigt sein können, wenn sich seit Juli 2015 die Verhältnisse, unter denen die Rechtsverfolgung stattzufinden habe, für die dahingehend verändert haben würde, dass erstmals durch sie eine aussichtsreiche Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs möglich geworden sein würde.[2595] Derartiges sei nicht zu erkennen.[2596] Im Rechtsbestandsverfahren sei noch keine Entscheidung ergangen; die Verfügungsklägerin könne sich deswegen nicht auf den Grundsatz berufen, dass der Schutzrechtsinhaber vorsichtig agieren dürfe und kein unnötiges Prozessrisiko eingehen müsse, weshalb ihm im Rahmen der Dringlichkeit nicht entgegen gehalten werden könne, er würde den nach Klärung des Rechtsbestandes im vorläufigen Rechtschutzverfahren verfolgten Unterlassungsanspruch schon vorher im Hauptsacheprozess geltend gemacht haben können.[2597] Denn die Verfügungsklägerin habe trotz Fehlens einer wenigstens erstinstanzlichen Nichtigkeitsentscheidung den Unterlassungsanspruch gerichtlich anhängig gemacht und damit zu erkennen gegeben, dass ihr das mit dem Rechtsbestandsangriff verbundene Prozessrisiko gleichgültig sei.[2598] In ihm könne deswegen kein Umstand gesehen werden, der eine späte Inanspruchnahme

[2589] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.

[2590] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.

[2591] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.

[2592] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.

[2593] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.

[2594] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 22.

[2595] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 23.

[2596] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 23.

[2597] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 23, mit Verweis auf OLG Düsseldorf, 29.6.2017 – I-15 U 4/17 – *Vakuumgestütztes Behandlungssystem*.

[2598] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 23.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308

einstweiligen Rechtsschutzes rechtfertigen könne.[2599] Auch sonst seien keine nachträglichen Umstände erkennbar, die die Rechtsposition der Verfügungsklägerin nachhaltig in dem Sinne verbessert haben würden, dass bislang zweifelhafte Erfolgsaussichten für eine Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Hauptsacheprozess durchgreifend günstiger zu beurteilen sein würden.[2600]

Zudem treffe der Einwand, den Unterlassungsanspruch nicht frühzeitig bereits im Hauptsacheprozess geltend gemacht zu haben, die Verfügungsklägerin erst recht, wenn sie – wie sie behaupte – mangels marktbeherrschender Stellung überhaupt keinen kartellrechtlichen Lizenzierungspflichten unterliegen würde.[2601]

2. Einstweiliger Rechtsschutz des Lizenzsuchers

Zum einstweiligen Rechtsschutz gegen eine Anti-Suit Injunction siehe oben I.B.

Das LG Düsseldorf vom 9.11.2017 untersagte mittels einstweiliger Verfügung in Versäumnisurteil der Antragsgegnerin gestützt auf ihr europäisches Patent einen Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 zu einem Grenzbeschlagnahmeverfahren zu stellen, ohne die Antragstellerinnen von einem solchen Antrag ausdrücklich auszunehmen (zum Zwangslizenzeinwand in einem solchen Verfahren siehe bereits oben XVI.B).[2602] So sei der für den Erlass der einstweiligen Verfügung nach §§ 935, 940 ZPO erforderliche Verfügungsgrund zu bejahen.[2603] Für den auf Unterlassung gerichteten Verfügungsantrag gelte das schon deshalb, weil die Antragstellerinnen durch die missbräuchliche Inanspruchnahme des Verfahrens nach Verordnung (EU) Nr. 608/2013 durch die Antragsgegnerin in ihrer wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit erheblich beschränkt würden, weil sie befürchten müssen würden, dass von ihnen importierte Geräte durch den Zoll angehalten würden.[2604]

Soweit der Erlass der einstweiligen Verfügung zur Vorwegnahme der Hauptsache führe, sei dies im vorliegenden Fall ausnahmsweise gerechtfertigt.[2605] Zwar komme der Erlass einer einstweiligen Verfügung, durch deren Befolgung vollendete Tatsachen geschaffen würden, grundsätzlich nur im Ausnahmefall in Betracht, wenn eine besondere Notlage auf Seiten der antragstellenden Partei dies gebiete.[2606] Im Rahmen der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Abwägung der widerstreitenden Interessen der Parteien sei aber – bezogen auf den Entscheidungsfall – zu berücksichtigen, dass sich die Inanspruchnahme des Verfahrens nach der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 durch die Antragsgegnerin ohne Zweifel als missbräuchlich darstelle, was die Entscheidung auch insoweit rechtfertige.[2607]

[2599] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 23.

[2600] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 23.

[2601] OLG Düsseldorf. 18.7.2017 – I-2 U 23/17, Rn. 24.

[2602] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Tenor Ziff. II.

[2603] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 31.

[2604] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 31.

[2605] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 32, mit Verweis auf BGH, 19.11.2015 – I ZR 109/14 – *Hot Sox*.

[2606] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 33.

[2607] LG Düsseldorf, 9.11.2017 – 14d O 13/17, Rn. 33.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4081308